

ÖNSÖZ

2000 yılında müzik eserleri alanında başladığım çalışmalar, o zamana kadar fikirsel ve sanatsal eserler alanında çok çeşitli eser türlerinde yaptığım çalışmalara yeni bir boyut ekledi. Yıllardır haz için ilgilendiğim müzik, o tarihten sonra profesyonel çalışmalarımda önemli bir yer edindi. Bu çalışmalar, benden önce İstanbul’da bu alanda var olan sevgili dostlarım Av. İhsan Tellioğlu ve Av. Özdemir Arkan’ın destekleri ile genişledi. Besteci ve söz yazarlarının içinde olduğu eser sahiplerinden başlayarak komşu hak sahibi olan şarkıcı ve müzik yapımcılarına kadar geniş bir yelpazeye yayıldı çalışmalarım.

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, yaklaşık 50 yıl önce yazılan 5846 sayılı Kanun ile Ülkemizde gelişmek için sağlam bir zemin bulmuştur. Özellikle 1990’lı yıllarda meslek birliklerinin bu alana yapmış oldukları katkılar yasal zeminin gelişmiş ülkelerdeki gibi olmasını sağladı. Bugün itibarıyla Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Türk Hukuku’nun en gelişmiş uygulamalarını kapsayan bir alandır.

2006 yılında **İnternet Hukuku** adlı kitabımda bu alana bir hayli değindim. 2007 yılında yayınlanan **Mimari Eserler** çalışmasında ise fikirsel ve sanatsal eserlerin tüm hukuksal altyapısını bir sistematığe oturttum. Bu geçmiş çalışmalar elinizdeki kitaba kaynak oldu.

Müzik sektöründe yapmış olduğum hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri vesilesiyle şahit olduğum üzücü olay, milyonlarca dolarlık yatırım yapılarak kurulan radyo ve televizyonlar ile otellerden bazılarının telif haklarının ödenmesinden ısrarla kaçınmasıydı. Ki radyo ve televizyon kuruluşları başka birçok faydalı konularda çeşitli kampanyalarla toplumu yönlendirmektedirler. Oteller ise çoğunlukla birçok alanda yatırımlarını çeşitlendirmiş büyük sermaye gruplarına ait olup, bunların sahipleri birçok sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme gelirken, telif hakkı ödemedi müzik emekçilerinin eserlerini bedava kullanmaları düşündürücüdür. Sanki çevre konusunda birçok vakfa destek veren öncü bir şirketler grubunun fabrikalarının çevreyi fütursuzca kirletmesi ve yöre halkının kanser olmasına neden olması gibidir durum. Bu kuruluşların yanında küçük girişimler olan restoranlar ve diğer eğlence yerlerinin de aynı alışkanlığa sahip olarak telif hakkı ödemedi iş

yapmayı sürdürmeleri de bir başka üzüntü sebebidir. Son zamanlarda müzik sektörü tarafından oluşturulan meslek birliklerinin etkin çalışmaları ve yasal girişimler doğrultusunda her geçen gün bu bedavacılığın azaldığını da söylemeliyim.

Müzik Eserleri kitabımız, özellikle 5846 sayılı Kanun'un tümünden değiştirilmesi hakkındaki tartışmaların olduğu bir döneme denk geldi. 2008 yılında Kanun'daki ceza hükümleri Avrupa Birliği uyum çalışmaları açılımıyla değiştirildi. Kitabımız bu değişiklikleri kapsamaktadır. Bazılarının ileri sürdükleri gibi Kanun'un tümünden değiştirilmesi gerekli değildir. Ancak son on yılda yapılan değişikliklerle bir sistematik bozukluğu söz konusu olduğundan, sorunlu olan birkaç düzenleme dışında Kanun'un hükümlerinde bir değişiklik yapılmaksızın sadece sistematikliğini yeniden kurgulamak ve bağlantılı haklar ile eser sahibi haklarını aynı yapıda sıralamak ve yerleştirmek yararlı olacaktır.

Bu çalışmada, sadece müzik eserleri konusunda var olan hukuki düzenlemeleri ve bunlara ilişkin temel açıklamaları; uygulamayı yansıtan yargı kararları ışığında vurgulama ve derleme amacı esas alınmıştır. Ek olarak önem taşıyan bazı tartışmalı alanlarda ise diğer bilimsel çalışmalar referans verilerek yorumlar getirilmiştir. Özellikle belirtmeliyim ki bu kitabın her bir bölüm başlığı yeni bir kitap veya bilimsel tez konusu olabilecek derinliğe sahiptir. Bu nedenle genç hukukçuların ve akademisyenlerin her bir başlığa ilişkin yeni eserler üretmeleri sevincimiz olacaktır.

Bu kitabın ortaya çıkmasındaki yardımları için asistanım Mine Tekşen'e, bu alanda yazdığı eserleri zengin yargı kararları ile bezeyip, yargı pratiğini uygulamacılara sunan Hâkim Ali Orhan ile Av. Dr. Cahit Suluk'a, çalışmalarına desteklerini esirgemeyen müzik sektörünün önemli hukuk adamları, meslekdaşlarım Av. İhsan Tellioğlu'na ve merhum Av. Özdemir Arkan'a, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku'nun Ülkemizdeki gelişmesine yazdıkları önemli eserlerle büyük katkıda bulunan Prof. Dr. Nuşin Ayiter ile Prof. Dr. Şafak Erel ile verdikleri yönlendirici kararlarla eser ve bağlantılı hak sahiplerinin korunmasını sağlayan Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin ve Yargıtay 7. Ceza Dairesinin tüm hakimlerine kalben teşekkürlerimi sunarım.

Sevgiyle kalın...

Gürsel Öngören
Tünel 2010

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	I
I. GİRİŞ.....	1
II. MÜZİK VE MÜZİK ALANI ÇALIŞANLARI	3
A. DÜNYADA MÜZİK	5
a) Ortaçağ Dönemi:	5
b) Rönesans Dönemi:	5
c) Barok Dönem:	6
d) Klasik Dönem:	6
e) Romantik Dönem:	6
f) Popüler Müzik Dönemi/Müziğin Ticarileşmesi:	7
B. TÜRKİYE’DE MÜZİK.....	7
1. Geleneksel Müzik	7
a) Halk Müziği:	8
b) Osmanlı Müziği:	8
c) Mehter:	8
d) Dini Müzik:.....	8
2. Çağdaş Türk Sanat Müziği.....	8
3. Popüler Müzik.....	9
C. MÜZİK ALANI ÇALIŞANLARI.....	10
III. ESER KAVRAMI VE MÜZİK ESERLERİNİN	
FSEK’TEKİ YERİ	13
A. ESER.....	13
1. Sahibinin Hususiyetini Taşımaya: Subjektif Şart	15
2. FSEK’te Öngörülen Eser Türlerinden Birine Dahil Olması:	
Objektif Şart	23
B. MÜZİK ESERLERİ KAVRAMI.....	24
IV. ESER VE BAĞLANTILI HAK SAHİPLİĞİ	
KAVRAMLARI.....	37
A. ESER SAHİPLİĞİ	37
1. Genel Olarak	37
2. Eser Sahibi ile Çalıştıran veya İşveren İlişkisi	41
3. Ortak ve Birlikte Eser Sahipliği	46

B. MÜZİK ESERİ SAHİPLİĞİ	53
C. BAĞLANTILI HAK ve KOMŞU HAK SAHİPLİĞİ.....	57
V. MÜZİK ESERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI	65
A. MÜZİK ESERİ SAHİPLERİNİN MANEVİ HAKLARI.....	72
1. Eseri Umuma Arz Yetkisi	72
2. Adın Belirtilmesi Yetkisi	75
3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Yetkisi	78
4. Eserin Aslına Varma Yetkisi	84
B. MÜZİK ESERİ SAHİPLERİNİN MALİ HAKLARI	86
1. İşleme Hakkı	89
2. Çoğaltma Hakkı	95
3. Yayma Hakkı	101
4. Temsil Hakkı.....	114
5. Umuma İletim Hakkı	125
6. Pay Alma (İzleme) Hakkı	140
VI. KOMŞU VE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİNİN HAKLARI	143
A. İCRACI SANATÇILARIN HAKLARI.....	146
1. İcracı Sanatçıların Manevi Hakları	157
2. İcracı Sanatçıların Mali Hakları	161
a. Tespit Hakkı	161
b. Çoğaltma Hakkı	163
c. Yayma Hakkı	171
d. Temsil Hakkı.....	178
e. Umuma İletim Hakkı.....	188
3. İcracı Sanatçıların Haklarına İlişkin Ortak Hükümler	203
B. FONOGRAM YAPIMCILARININ HAKLARI.....	211
1. Çoğaltma Hakkı	220
2. Yayma Hakkı	227
3. Temsil Hakkı.....	230
4. Umuma İletim Hakkı	238
a. Yayın ve Yeniden Yayın.....	239
b. Kamunun Erişimine Sunma	252
5. Fonogram Yapımcılarının Haklarına İlişkin Ortak Hükümler....	257

C. RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARININ HAKLARI	269
1. Radyo ve Televizyonların Eser ve Diğer Hak Sahiplerinden İzin Alması	270
2. Radyo ve Televizyonların Yayınları Üzerindeki Hakları	277
a. Tespit Hakkı	286
b. Çoğaltma Hakkı	287
c. Yayma Hakkı	288
d. Temsil Hakkı.....	289
e. Umuma İletim Hakkı.....	293
D. FİLM YAPIMCISININ HAKLARI.....	298
VII. MANEVİ VE MALİ HAKLARIN KULLANILMASI VE DEVRİ	313
A. GENEL OLARAK.....	313
B. MANEVİ HAKLARIN KULLANILMASI VE MİRASÇILAR	314
C. MALİ HAKLARIN KULLANILMASI VE MİRASÇILAR.....	318
D. MALİ HAKLARIN DEVRİ	321
E. MALİ HAKLARIN LİSANSI.....	331
F. CAYMA HAKKI.....	340
G. HAK YÖNETİM SİSTEMLERİ	346
H. MESLEK BİRLİKLERİ	350
VIII. ESER VE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİNİN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI	357
A. KAMU DÜZENİ DÜŞÜNCESİYLE SINIRLANDIRMA	359
B. GENEL MENFAAT DÜŞÜNCESİYLE SINIRLANDIRMA	360
C. KİŞİSEL KULLANIM İÇİN GETİRİLEN SINIRLANDIRMALAR.....	367
D. DEVLETE TANINAN YETKİLERLE SINIRLANDIRMA	373
E. RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARININ GEÇİCİ TESPİTLERİ İÇİN SINIRLANDIRMA.....	376
IX. HAKLARIN KORUNMA SÜRELERİ	377
X. MÜZİK ESERLERİNE İLİŞKİN TECAVÜZLER VE HAKLARIN DAVA YOLUYLA KORUNMASI	381
A. HUKUK DAVALARI	390

1. Eser Sahibinin Tespiti Davası.....	390
2. Tecavüzün Ref'i Davası.....	392
3. Tecavüzün Men'i Davası	400
4. Tecavüzün Tespiti Davası.....	402
5. Tazminat Davaları.....	404
a. Manevi Hakların İhlali Halinde Tazminat Davası	404
b. Mali Hakların İhlali Halinde Tazminat Davası.....	409
c. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Tazminat Davası.....	423
6. Hukuk Davalarına İlişkin Genel Bilgiler	425
a. Görevli Mahkeme.....	425
b. Davacı	428
c. Davalıya İlişkin Ek Bilgiler	428
d. Zamanaşımı.....	431
B. CEZA DAVALARI.....	432
1. Manevi, Mali ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Halinde Oluşan Suçlar.....	433
2. Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Suçlar	440
3. Bandrole İlişkin Suçlar	440
4. Ceza Davalarına İlişkin Genel Bilgiler	442
a. Şikayetçi ve Savcılık Soruşturması	442
b. Suçun Faili	445
c. Suç Konusu Eşyalara El Koyma, Zapt, Müsadere ve İmha	447
d. Zamanaşımı.....	450
e. Yetkili ve Görevli Mahkeme.....	452
XI. TÜRK HUKUKUNDA HUKUK VE CEZA	
DAVALARINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER.....	453
A. İHTİYATİ TEDBİRLER	453
B. HÜKMÜN İLANI	459
C. İZİNSİZ DIGİTAL İLETİM İHLALLERİNDE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ	461
KAYNAKÇA	463
Prof. Dr. Gürsel Öngören'in Diğer Kitapları	469

I. GİRİŞ

Son yıllarda bilim ve teknolojiadaki gelişmeler sayesinde, sanayi toplumu yerini bilgi toplumuna bırakmıştır. Bilgi toplumunda üretimdeki unsurlar sanayideki hammadde ve makine ilişkisinden çok bilgi ve teknolojiye dayalı olup, yaratıcı düşünceden kaynaklanan fikirsel ve sanatsal yaratımlar ön plana çıkmaktadır. Fikirsel ve sanatsal yaratımlardan etkilenen teknolojik üretim ise bu yaratımlara dayalı yeni tip ürünler oluşturmaktadır. Bilgi üretiminin artması; yeni ürünlerin ortaya çıkmasının yanı sıra, fikirsel ve sanatsal ürünlerden yeni yararlanma şekillerini gündeme getirmektedir.

Klasik mülkiyet ilişkisi ve mülkiyeti koruyan sistemlere ilişkin kurallar; yeni ürünleri ve eski ürünlere ilişkin yeni yararlanma şekillerini yaratanları ve üretenleri koruyamamıştır. Bu sebeple mülkiyete ilişkin kurallardan da yararlanarak yeni koruyucu kurallar üretmek gerekmiştir. Ticari markalar, patentler ve endüstriyel tasarımlar alanındaki ürünler uluslararası sözleşmelerin de desteği ile iç hukuklarda “Endüstriyel Mülkiyet Mevzuatı” ile geniş kapsamlı olarak korunmaya başlamıştır. Düşünce dünyasının diğer yanında ise fikirsel ve sanatsal çalışmaları yaratanları ve yaratıcılardan bazı hakları alıp ürün üretenleri korumak amacıyla, yine uluslararası sözleşme hükümlerinin desteği ile her bir ülke iç hukukunda “*Fikir ve Sanat Eserleri Mevzuatı*” oluşturulmuştur. Bu mevzuatın içindeki koruyucu hükümlerin veya kuralların hepsine birden “*Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku*” adı verilmektedir.

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku sürekli devinim içindedir. Eserlerin üretiminde kullanılan malzemelerin ve eser üretme yöntemlerinin ilerleyen teknoloji doğrultusunda gelişmesi uygulanacak hukuk kurallarını da etkilemektedir. Bilgi işlem teknolojisindeki hızlı atılımlar ile dünyadaki ucuz iş gücünün global ekonomi’ye başta Uzakdoğu halkları olmak üzere katılması yepyeni iş yapma ve üretim yöntemleri ortaya çıkarmıştır. Her türlü müzik eseri ileri teknoloji ile kopyalanmaktadır. Gerek dijital kullanımlar ile kopyacılık ve gerekse eserlerin bir kısmının kimliği belirsiz ucuz işgücü ile oluşturulması fikirsel ve sanatsal haklarda yeni sorunları çözümleyen yeni kurallar belirlenmesini gerekli kılmaktadır.

Hukukçular da bu yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kurallar oluşturarak Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku’nu dinamikleştirmektedir.

Bu alanda gerek ilk getirilen kurallar ve gerekse teknolojik gelişmeler sonucu yeni eklenen kurallar ile fikirsel ve sanatsal hak sahiplerine, yasaklama da dahil tekel niteliğinde birçok yetkiler sağlanmıştır. Bu şekilde fikirsel ve sanatsal hak sahibi; izni olmadan başkalarının kendi fikirsel ve sanatsal mülkiyet hakkını kullanmasını kolayca engelleyebilmekte, ürettiği eserin kullanım şekli doğrultusunda piyasa değerinin üç katı tazminat alabilmekte ve izinsiz kullananların hapisle cezalandırılacağı yasal yolları harekete geçirebilmektedir¹. Fikirsel ve sanatsal mülkiyet hakları, haksız rekabeti yasaklayabilme yeteneğinin yanında manevi haklara yönelik saldırıları da önlemeyi sağlamaktadır.

Kısacası Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku; eserlere, sahiplerinin haklarına ve korumaya ilişkin kuralların tümünü içerir. Fikir ve sanat eseri üzerindeki haklar; eser ve komşu hak sahibinin maddi menfaatlerini tecavüzlere ve sömürülere karşı korur, hak sahibine ekonomik yararlanma olanakları sağlar, eser sahibinin izni olmadan eserin alenileşmesine ve değiştirilmesine engel olur ve eserin eser sahibinin isteğine uygun bir şekilde adıyla veya takma bir adla ya da anonim olarak kamuya sunulmasını gerçekleştirir. Bu şekilde hak sahibine eseri üzerinde maddi ve manevi anlamda tasarruf yetkileri bahşeder².

Ancak, bu haklara sahip olabilmek için her şeyden önce fikirsel ve sanatsal emek sonucu ortaya çıkan ve Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku kapsamında korunmaya değer olan bir “eser” bulunmalıdır. Ortada bir eser varsa, bunun sahibi ve hakları hukuk kuralları doğrultusunda belirlenebilir.

Tüm bu açıklamalar ışığında, konumuz olan “müzik eserleri” açısından bilgi aktarımı için; önce “müzisyenleri” ve “müziksel ürünleri” sonra müzik çalışmalarının “eser” kavramı içindeki yeri, daha sonra eser sahibi ve komşu hak sahiplerine verilen yetki ve haklara olan saldırılara karşı korunma yöntemleri üzerinde duracağız.

¹ Bkz. Ünal TEKİNALP, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, Beta Yayınları, İstanbul, Eylül 2004, s. 7.

² TEKİNALP, *age.*, s. 8.

II. MÜZİK VE MÜZİK ALANI ÇALIŞANLARI

Müziğin ya da müzik eserinin kesin bir tanımını yapmak hemen hemen imkansızdır; çünkü yüzyıllardır “sanat” kavramının ne olduğu ya da ne olması gerektiği üzerinde büyük tartışmalar yapılmaktadır ve her dönemde değişik estetik anlayışları, farklı beğeni kriterleri ve sanat formları geliştiği için müziğin tanımı sık sık değişmektedir.

Müzik, en genel tanımı ile **sesin biçim ve devinim kazanmış halidir**. Öte yandan müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. Biçim ve devinim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir.

Dictionnaire Larouse’da¹ müzik, “*insan ve çalgı seslerinin biçimsel bir güzellik veya duygusal bir ifade yaratacak biçimde düzenlenmesini içeren sanat*” olarak ve Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ünde “*birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki*” olarak tanımlanırken, “güzel”, “çirkin” gibi kavramlar (estetik felsefesinin ana kavramları olmalarına rağmen) göreceli kavramlar oldukları için bu alanda yapılan tanımlamalarda kullanılmamışlardır. Müziğin notayla tespit edilmiş olması, sabit bir şekilde kaydedilmesi, armoni kalıplarına uyması gibi özellikler aranmaz. Uzunluğu, kısalığı, insan gırtlığından çıkması ya da enstrümanla çalınması da bir kriter oluşturmaz.²

Yine müzik; kelimelerle anlatılamayan duygu ve düşüncelerin seslerle anlatılması sanatıdır. Müzik; duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları; başka gerçeklerin de katkısıyla belli durum, olgu ve olayları, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre birleştirip, biçimlendirilmiş seslerle işleyerek anlatan estetik bir bütündür.

¹ Dictionnaire Larousse, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1993.

² Emre GÖKYAYLA, Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi. Ankara, Yetkin Yayınları, 2000, s. 86-87.

Eski Yunan felsefesinde müziğin etkisi yoğun olarak görülür. Nitekim; musiki- musika -muzika -müzik kelimeleri Yunanca kökenlidir. Yunan alfabesinde m-o-u-s-a harfleriyle yazılan ve musa diye okunan peri anlamındaki kelimenin sonuna gelen “ike” veya “ika” takısı, o kelimeye konuşulan dil anlamını kazandırır; Elenika (Yunanca), Turkika (Türkçe), İtalika (İtalyanca) örneklerinde olduğu gibi.

Musa’ya eklenen “ike” takısı, peri kelimesine de “**perilerin konuştuğu dil**” anlamını verir. Musiki kelimesine bizde de İslami terimle meleklerin dili denilmiştir. Bu durum, müziğe eski çağlardan itibaren batıda ve doğuda gizemli özellikler atfedildiğini gösterir.

Müzik, temel olarak dört ana unsurdan oluşur: Diklik, yoğunluk, süre ve tını.

Diklik, bir sesin ne kadar “tiz” ya da “pes” olduğunu ifade eder. Örneğin do, re, mi gibi her nota ismi farklı bir dikliğe sahiptir. Aynı nota isimleri de hangi oktavda bulunduklarına bağlı olarak farklı diklikleri ifade edebilirler. Akustik olarak birimi frekanstır.

Yoğunluk, bir sesin gürülüğünü ifade eder. Müzikte forte, piano, fortissimo gibi nüanslar kullanılır. Akustik olarak birimi desibeldir.

Süre, bir sesin ne kadar sürdüğünü ifade eder. Müzikte ikinin katları biçiminde birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik gibi ifade edilir, ancak nota değerlerinin yanlarına konan noktalar sürenin kendi değerinin yarısı kadar daha uzamasını sağlar.

Tını, bir sesin rengini ifade eder. Örneğin aynı oktavda aynı notayı aynı yoğunlukta ve aynı uzunlukta çalan bir kemanla bir flüt arasındaki fark, tını farkıdır. Dört özellik içinde en karmaşık olan özellik budur. Akustik olarak tını, sesin doğuşkan (harmonik) yapısına bağlı olarak değişir.³

Müzik; hem bir sanat hem de bir bilimdir. Duygusal olarak algılanışının yanı sıra akıl ile de kavranabilir. Bu özelliği ile bireyin ve toplumun duyuş ve biliş açısından durumunu belirlediği gibi, gelişim ve değişimini de sağlayan organik bir yapıdır. Sesin en güzel şekli müzik ile dile gelir. Resim, renklerin birleşmesinden; şiir, kelimelerin kaynaşmasından nasıl oluşuyorsa; müzik de seslerin, duygu, düşünce ve heye-

³ Bkz. www.wikipedia.org/wiki/Müzik ve www.ansiklopedi.turkcebilgi.com/Müziğin_özellikleri

canımızı anlatmak üzere belli bir estetik anlayışına göre seçilip işlenmesinden oluşmaktadır⁴.

Müziğin tanımı tarihsel dönem, bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağımlı olarak büyük farklılık gösterir. Özellikle 20. yüzyıl çağdaş Batı müziğinde ortaya çıkan çok farklı müzik akımları, ortak bir tanımla büyük ölçüde imkansızlaştırmaktadır. Bunun ötesinde, gittikçe daha fazla insanın erişme olanağı bulduğu farklı kültürlerle ait yerel müzikler de bu tanımlama zorluğunu arttırmaktadır.

Tüm bu sebeplerden dolayı, müziğin tek bir tanımla açıklanması yerine sosyolojik, psikolojik, akustik, politik gibi farklı açılardan yapılan birden fazla tanımla açıklanması yaygınlık kazanmıştır. Bir sosyoloğun müziğe olan yaklaşımıyla, bir akustik fizikçinin yaklaşımı arasında gerek tanım, gerek metodolojik olarak büyük farklılık vardır. Tüm bu yaklaşımlar müzikologlar ve müzik teorisyenleri tarafından araştırılır ve değerlendirilir.⁵

A. DÜNYADA MÜZİK

Dünya tarihi içinde müziğe baktığımızda çeşitli ayırımların yapıldığını görürüz. Bir müzik bilimcisi olmamakla birlikte bu ayırımları şu şekilde özetleyebiliriz.

a) Ortaçağ Dönemi:

Ortaçağ'da müzik hıristiyan ibadetinin önemli bir parçasıydı. Gregoryen ilahileri denilen tarzda pek çok dini metin bestelenmişti. Bestecilerin çoğunluğu da kilise mensubuydu. Yani müzik, kilisenin tekelindeydi. Ortaçağ Avrupa'sında dokuzuncu yüzyıla kadar belli başlı bir nota sistemi de kullanılmadı. 12. yüzyıldan sonra kilisenin hakimiyetinden çıkan müzik, bu kez de saray ve asilzadelerin tekeline geçti⁶.

b) Rönesans Dönemi:

İnsana ve bireye verilen önemin artması ve dinin egemenliğinin azalması sonucu sanat; eğitim ve kültürün önemli bir ölçüsü haline geldi.

⁴ www.tr.wikipedia.org

⁵ www.ansiklopedi.turkcebilgi.com

⁶ "Eras: Middle Age." *Essentials of Music*. Online. Internet. <http://www.essentialsofmusic.com/eras/eras.html>

Coğrafi keşifler, mal alışverişinin yanında kültürel ve müzikal etkileşimi de beraberinde getirdi. Ancak “sanat” olarak nitelendirilen müzik yine zengin sınıfa ve aristokrasiye hitap eden bir etkinlik olarak sınırlıydı.⁷

c) Barok Dönem:

Rönesans döneminin sanat anlayışında sadelik, temizlik ve saflık anlayışı hakimken barok dönemde, duygular daha sert, karmaşık, süslü ve abartılı bir şekilde ifade edildi. Müzikte “kontrast” kavramı gelişti, yani aynı tınılardaki çalgılar birbirleriyle karşıtlık oluşturacak şekilde çalındı. Bu dönemde müzik ve dramının sentezi olan opera ve enstrümantal müzik de ön plana çıktı.⁸

d) Klasik Dönem:

Bu dönemde doğallık, saflık ve denge gibi unsurlar ön plana çıktı. Dönemin en önemli bestecileri Haydn, Mozart ve Beethoven’dır. Bu besteciler senfonik orkestrayı yarattılar ve özellikle Haydn ile, yaylılar dördlüsünden senfoniye kadar yeni türlerin parlak örneklerini verdiler. Yine aynı dönemde senfonik müzik (veya orkestra müziği) oda müziğinden ayrıldı ve Germen, hatta Viyana müziği, birbuçuk yüzyılı aşkın bir süre boyunca bütün Avrupa’ya hakim oldu.⁹

e) Romantik Dönem:

Romantik dönemde müzisyenler, klasik döneme göre doğayı daha az idealize eden bir bakış açısına sahiptiler. Romantik besteciler, gerçek dünyadan ziyade, doğaüstü ve gizemli metinleri ve hikayeleri bestelemeye yöneldiler. İlk defa müzik bu dönemde hikaye anlatmak için ve yalnızca müzikal anlamların ötesinde anlamlar yaratmak için kullanılmaya başlandı. Müzik; insanları, nesneleri ve dramatik durumları, duyguları hatta felsefi fikirleri bile temsil edecek şekilde işlendi. Yine bu dönemde bazı besteciler müziği milli kimliği yüceltmek için bir araç olarak da kullandılar. Bedrich Smetana gibi enstrümantal besteciler folk

⁷ “Eras: Renaissance” *Essentials of Music*. Online. Internet. <http://www.essentialsofmusic.com/eras/eras.html>

⁸ “Klasik Müzik Tarihi: Barok Dönem” *Klasik Müzik*. Online. Internet. <http://www.klasikmuzik.org/history.htm>.

⁹ “Klasik Müzik Tarihi: Klasik Dönem” *Klasik Müzik*. Online. Internet. <http://www.klasikmuzik.org/history.htm>.

müzik ve milli imgelere göndermeler yaparken, Verdi gibi opera bestecileri milliyetçi yönleri ağır basan hikayeler bestelediler. Besteciler bu dönemde çeşitli etnik grupların müziklerine de ilgi gösterdiler ve onları kendi müziklerinde kullanmaya başladılar.¹⁰

f) Popüler Müzik Dönemi/Müziğin Ticarileşmesi:

Müziğin ticarileşmesi, 20. yüzyıl başlarında Avrupa’da endüstriyelleşme hareketleriyle beraber doğmuş; teknolojinin gelişmesi, kayıt teknikleri, fonograf ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla müziğin çoğaltılarak kitlelere ulaşması kolaylaşmıştır. Aristokrasinin estetik ve sanat anlayışıyla biçimlenen klasik saray müziklerinden farklı olarak, popüler müzik geniş halk kitlelerini hedef almıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte, kapitalist ekonomi politikalarının ve tüketim kültürünün egemenlik kazanması sonucu kültür ürünleri (müzik de dahil olmak üzere) birer metaya indirgenmiş olsalar da, yığınsal üretim yapabilecek teknolojik imkanlar çoğaldığı için, bir zamanlar üst sınıfın tekelinde olan müzik, kitleler tarafından tüketilebilir hale gelmiştir. Ortalama toplumsal beğeniye hitap ettiği için, popüler müzik kolay tüketilebilecek, fazla konsantrasyon ve algılama çabası gerektirmeyecek şekilde üretilir. 1950’li yıllardan itibaren bir müzik akımı olarak kendini kabul ettiren pop müziğin en çok bilinen türleri arasında rock, caz, soul, disco, reggae ve son yıllarda da elektronik müzik, hip-hop, R&B sayılabilir.¹¹

B. TÜRKİYE’DE MÜZİK

Kültür Bakanlığı’mızca hazırlanan sitede belirtildiği üzere, Türkiye’de var olan müzik türleri ise; Geleneksel Müzik, Çağdaş Türk Sanat Müziği ve Popüler Müzik olmak üzere üç ana gruba ayrılır¹²:

1. Geleneksel Müzik

Bu tür, kendi içinde, halk müziği, Osmanlı müziği, mehter müziği ve dini müzik olarak dörde ayrılır.

¹⁰ “Klasik Müzik Tarihi: Romantik Dönem.” *Klasik Müzik. Online. Internet.* <http://www.klasikmuzik.org/history.htm>.

¹¹ Ahmet SAY, *Müzik Ansiklopedisi. Başkent Yayınevi, Ankara: 1985, s. 1038-1042.*

¹² Bu bölüm için bkz. Oğuz ELBAŞ; Yalçın TURA; Ertuğrul BAYRAKTARKATAL; İsmail Lütfü EROL, “Türk Müzik Kültürü”, T.C Kültür Bakanlığı, *Online Internet*, http://www.kultur.gov.tr/portal/sanat_tr.asp?belgeno=35573.

a) Halk Müziği:

Bu müzik türü, “bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen, severek söylenen ve çalınan, o yöre insanının ortak yapıtı haline gelen ve kulaktan kulağa aktarılarak yaşatılıp günümüze kadar ulaşan ve çoğunlukla anonim olan müziklerdir” şeklinde tanımlanmıştır.

b) Osmanlı Müziği:

Bugün “Klâsik Türk Müziği” ya da “Türk Sanat Müziği” olarak adlandırdığımız bu türün kökeni adından da anlaşıldığı üzere Osmanlı Kültürüne dayanmaktadır. Oldukça farklı kültürleri bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu’nun müziği de kendisi gibi çok kültürlüdür. Türklerle birlikte yaşayan Bizans, Rum, Acem, Arap, Yahudi, Ermeni gibi azınlık kültürlerinin de bu müziğe katkısı olmuştur. Ancak bu müzik halktan kopuk bir şekilde genellikle Osmanlı saray kültürünün bir parçası olarak gelişmiştir. Temelde “makam birliği” esasına dayanan “fasıl” düzeni içinde oluşturulmuş ve seslendirilmiştir.

c) Mehter:

Bu gelenek, İslamiyetten önceki Türk devletlerinde başlamış, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde bazı değişiklikler göstererek devam etmiştir. Devletin gücünü ve ihtişamını sembolize eden mehter müziği, savaş sırasında halka moral veren, düşmanın gözünü korkutan, barış zamanında da hakan’ın saltanatının ve devlet hayatının devam ettiğini gösteren bir takım sembolik nitelikler kazanmıştır. Bunun dışında davul ve mehter, devletin haber alma, iletme ve ilan etme gibi işlerinde de kullanılmıştır.

d) Dini Müzik:

İslam dininde Allah’a yapılan ibadette sevgi ve şükran duygularının bir ifadesi olarak kullanılan ve dini temalar işleyen bu müzik türü, kullanım yoluna göre “Şer’i Müzik” ve “Tasavvufi Müzik”; seslendirildiği yere göre de “Cami Müziği” ve “Tekke Müziği” diye sınıflandırılmıştır.

2. Çağdaş Türk Sanat Müziği

“Klasik Türk Müziği” ya da “Türk Sanat Müziği” olarak adlandırılan Osmanlı Müziği’nden Çağdaş Türk Sanat Müziği’nin farkı, Türkiye Cumhuriyeti döneminde gelişim göstermesi ve çok sesli batı müziğiyle

bir sentez meydana getirmesidir. Cumhuriyet yönetimi tarafından, müzik eğitimi almak üzere Avrupa'nın çeşitli kentlerine gönderilen bazı yetenekli müzisyenler “*Çağdaş Çoksesli Türk Müziği*”nin temellerini atan isimler olmuşlardır. Ön plana çıkan en önemli beş isim Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses'tir. Bu müzisyenler daha sonra Türk Beşleri olarak adlandırılmıştır.

3. Popüler Müzik

Türkiye’de serbest piyasa ve liberal ekonomi hareketlerinin hız kazandığı 80’li yıllardan önce müzik endüstrisinin oturmamış olmasının temel nedenlerinden biri 1980 öncesinde devletçi politikaların izlenmesi ve kitle iletişim araçlarının devletin tekelinde olmasıdır. Örneğin İngiliz BBC’nin elitist kültür tutumunu örnek alan TRT’de, popüler kültür öğelerine fazla yer verilmemiştir. Denetimler oldukça sıkı, sansür uygulamaları yaygındır. 80’li yıllarda dünyayı kuşatan; büyük sanayileşme ve kentleşme hareketlerini içeren süreçle beraber ortaya çıkan kitle toplumunun bir örneği de Türkiye’de oluşmaya başlamıştır. “Devletçi” olarak nitelenen ekonomik politikaların geri plana atılması ve liberal ekonomi politikalarına ağırlık verilmesi, serbest piyasa ekonomisinde özelleştirme mantığının egemen olması, müzik alanını da etkilemiş ve 80’li yıllardan itibaren müzik bir ticari sektör halini almıştır.

Müziğin pazar ortamında değişim değeri taşıyan bir tüketim nesnesine dönüştürüldüğü yolundaki eleştirilere rağmen, popüler müzik piyasası hızla gelişmiştir. 1990’lardan itibaren özel radyo ve televizyonların açılmasıyla beraber her türlü müziğin, radyo ve televizyonlardan halka ulaşmaya başlaması da Türkiye’de popüler müziğin yaygınlaşmasında büyük etken olmuştur.

Popüler müzik, bazı kesimlerce genellikle batının popüler müzik anlayışını taklit eden tarzıyla kültürel alışverişin, gelişmenin ve modernleşmenin göstergelerinden biri olarak algılanmıştır. Diğer taraftan, bazı kesimler tarafından Türk Pop Müziği, yerel özellikleri dışladığı ve tamamen batı özentisi şeklinde üretildiği için kültürel emperyalizmin; sermayenin ve ekonomik sömürünün bir uzantısı olarak görülmüştür. “Demokratikleşme, çoğulculuk, çok seslilik, farklı kültürlerle saygı” söylemlerinin 80’lerle beraber iyice gelişmesi sonucunda, Türk Pop Müziğinde pek çok tür bir araya getirilmeye ve kutuplaşmış türler bir biri içerisinde erimeye başlamıştır. Arabesk-pop; halk müziği-sanat müziği, Türk mü-

ziği -Batı müziği arasındaki çatışmalar giderek yok olmuştur; çünkü artık önemli olan büyük kitlelere hitap edebilecek, bol satış ve kazanç sağlayacak, basit ve kolay tüketilebilecek müzikler yapmaktır. Müziğin kalitesinden çok tanıtımının, pazarlanmasının ve dağıtımının nasıl yapılacağı önem kazanmıştır.¹³

C. MÜZİK ALANI ÇALIŞANLARI

Müzik hakkındaki genel açıklamaların ardından müzik yapıtlarını üreten ve onlara katkıda bulunan kişileri de saymakta ve tanımlamakta yarar görüyoruz.

Söz yazarı; müzik parçalarının güftelerini yazan kimsedir. Bu kişi sözleri bir müzik varken ona yönelik olarak da yazabilir ya da bir şairin yazdığı sözler veya söz yazarının yazdığı dizeler sonradan üzerine müzik eklenerek birleşik bir müzik yapıtı haline getirilir.

Besteci (bestekar); bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü yapan kişidir. Kimi zaman var olan sözler ya da bir hikayeyi veya duyguyu esas alarak buna uygun ezgiler üretir. Bazen de doğrudan müziği oluşturur.

Aranjör; türlere göre veya enstrümanlara göre çeşitli kriterler kullanarak müziği düzenleyen kişidir.

Şarkıcı (icracı, yorumcu); şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, okuyucu, hanende, muganni, muganniye olarak tanımlanmaktadır. Wikipediada şarkıcı; sesini şarkı söylemek veya diğer enstrümanların da yer aldığı bir müzik eserine eşlik etmek için kullanan müzisyendir. Şarkıcı terimi daha çok belli bir melodiyi söyleyen müzisyenler için kullanılırken vokalist terimi, insana özgü ancak melodik olmayan diğer sesleri de kompozisyon içinde kullanan müzisyenler için dile getirilir. Ana vokal terimi (veya sadece vokal) müzik eserinin önde yer alan, birincil vokalini seslendirenler için; arka vokal terimi ise ana vokale veya parçaya eşlik eden diğer müzisyenler için kullanılır.

Çalgıcı; müzik eserlerini seslendirmek için müzik aletlerini çalan kişidir.

Müzik yapımcısı; bir müzik çalışmasını maddi ortamda ortaya çıkarmak için kaset, cd, bilgisayar gibi maddi ortamlar üzerine sözlü ya da

¹³ SAY, *age*, s. 1043-1044.

sözsüz tüm seslerin ilk tespitini veya kayıt işlemini yapan, bunun için besteci, söz yazarı, şarkıcı, çalgıcı gibi kimseleri bir araya getirerek organizasyonu sağlayan kişidir.

Yönetmen; bir müzik yapıtının müzik klipi gibi görsel ve işitsel bütünlük içinde izlenebilmesi için, kendi sanatsal anlayışı içinde bir senaryo doğrultusunda veya doğaçlama olarak kimi zaman ışık, dekor unsurları ve oyuncular da kullanarak bant, video veya bilgisayar kayıt ortamlarına çekimini yapan, yaptıran veya üstlenen kişidir.

Dağıtımçı; müzik yapıtlarının yapımcı tarafından kaset, cd veya bilgisayar ortamına kaydının yapılması ile ortaya çıkan müzik içeren ürünü kişilere veya kuruluşlara pazarlayan ve satan kişidir.

Her kültürel ürünün ekonomik boyutu olduğu gibi müzik eserlerinin de endüstrisi vardır. Bu sektörde yukarıda tanımladığımız pek çok katılımcı faaliyet göstermektedir. Müzik yapımcıları tarafından organize edilen müzik yapımı iş kolunun evreleri şu şekilde sıralanabilir:

Söz yazarı, besteci, aranjör ile anlaşma,

Şarkıcı, müzisyenler, yönetmenlerle müzik icrası ve kaydı aşaması,

(Ses ve/veya görüntü bandına alınması)

Ses kaseti, CD'nin çoğaltılması, görüntü kasetinin (klip) yayına hazır hale getirilmesi, bilgisayara yüklenmesi

Ses kaseti ve CD'nin pazarlanması, kliplerin TV'de yayınlanması, internette kullandırılması.¹⁴

Pek çok katılımcının faaliyetini içeren bu aşamaların belirli bir yasa ve düzen içerisinde yürütülebilmesi ve eser sahipleri ile komşu hak sahiplerinin haklarına zarar gelmesini önlemek için, uluslararası sözleşmeler ve fikir ve sanat eserleri kanunları aracılığıyla müziği oluşturan ve satan tarafların hakları belirtilmiş ve koruma altına alınmıştır.¹⁵

¹⁴ Oktay GÜVEMLİ, *Müzik Yapım İşkolunda Telif Haklarının Giderleştirilmesi, Vergi Dünyası*, 2000/224, s. 36.

¹⁵ Bu bölümde tarafımdan hazırlatılan, Aydilge SARP, *Müzik Eserleri ve FSEK, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Ödevi*'nden yararlanılmıştır.

III. ESER KAVRAMI VE MÜZİK ESERLERİNİN FSEK'TEKİ YERİ

A. ESER

Uluslararası sözleşmelerde “eser” kavramı hakkında bir tanım yapılmamıştır. Bern Sözleşmesi’nde “eser” kavramının tanımı yapılmamakla birlikte, eser türlerinin sayıldığı 2. maddede eserle ilgili iki önemli özellikten bahsedilmektedir. Bu özelliklerinden biri eserin özgün (orijinal) olması¹; diğeri eserin yaratıcı düşünce ürünü olmasıdır². **Evrensel Fikir Hakları Sözleşmesi**’nde (Universal Copy Convention/ kısaca Evrensel Sözleşme) ise; eserlerin insan aklının emeğinden, insanların düşünce ürünlerinden doğduğu belirtilmektedir.

Bern Sözleşmesi’nde ayrıca yaratıcı düşünce ürünü özgün eserlerin türleri sayılmıştır. Sözleşmenin ikinci maddesinde; edebiyat ve sanat eserleri içinde genel ve ayrıntılı bir sıralama yapılmaktadır. Buna göre; “*edebiyat ve sanat eserleri deyimi, ifade şekli ne olursa olsun, edebiyat, bilim ve sanat alanındaki kitaplar, dergiler ve diğer yazılar, konferanslar, kitaplar, vaazlar, eserler ve gösteri eğlenceleri, sözlü veya sözsüz müzik kompozisyonları, sinema tekniğine benzer bir yöntemle ifade edilen sinema eserleri, çizim, sulu ve yağlı boya resim, mimarlık, heykeltıraşlık, oymacılık ve taş basma eserleri, fotoğraf tekniğine benzer bir yolla elde edilen fotoğraf eserleri, uygulamalı sanat eserleri, resimlendirmeler, haritalar, planlar, krokiler ve coğrafya, topografya, mimari ve bilimsel boyutlu eserler gibi bütün ürünleri içerir*” şeklinde ifade edilmiştir.

Bern Sözleşmesi, 9 Eylül 1886 tarihli “**Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme**” adıyla bu alandaki ilk uluslararası düzenlemedir. Türkiye de bu Sözleşmeyi kabul etmiştir.

Unesco’nun öncülüğünde, 1952 yılında gerçekleştirilen “Evrensel Fikir Hakları Sözleşmesi”nde ise; eser türleri bakımından ayrıntıya girilmemiş; sadece ilk maddesinde “*yazılar, müzik, dramatik ve sinematografik eserler ile resim, heykeltıraşlık ve oymacılığı içeren edebiyat ve*

¹ Brüksel Anlaşması madde 2/2, Paris Anlaşması madde 2/3.

² Brüksel Anlaşması madde 2/3, Paris Anlaşması madde 2/5.

bilim eserleri sahipleri” ifadesi ile yetinilmiştir³. Türkiye bu sözleşmeyi halen⁴ kabul etmemiştir.

Yine Türkiye’nin taraf olduğu 1961 tarihli Roma Sözleşmesi’nde ise; eser kavramı ele alınmamış; “ıcracı sanatçı, fonogram, plak yapım-cısı, yayım, çoğaltma, radyo ve televizyon yayınları, tekrar yayım” gibi müzik eserleriyle ilgili terimlerin tanımı yapılmıştır.

Bern ile Roma sözleşmeleri ve Avrupa Birliği uyum sürecinde çeşitli Birlik direktiflerinden etkilenerek şekillendirilen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) ilk maddesi ise **eseri**; “... **sahibinin hususiyetini taşıyan**⁵ ve ... **ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulü** ...” şeklinde tanımlamıştır. Maddede belirtilen özellikleri bünyesinde bulunduran bir yaratım, eser statüsünde kabul edilir ve FSEK kapsamında korumadan yararlanır.

Bu yasal dayanaklardan yola çıkarak bir fikirsal ya da sanatsal ürünün “**eser**” olarak tanımlanabilmesi için gereken özellikleri veya şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Sahibinin hususiyetini (özellikliğini) taşıması (**subjektif şart**)
2. FSEK’te öngörülen eser türlerinden birine dahil olması (**objektif şart**)

Sayılan bu özelliklerin yanı sıra bir çalışmanın eser sayılabilmesi için, fikir düzeyinde kalmayıp dış dünyaya yansıtılmış olması da gerekmektedir.⁶

³ Bilge KILIÇ, *Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda “Eser” Kavramı, Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, C.1, S.1, Legal Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2005, s. 108-109.*

⁴ 2008 yılı için.

⁵ “Sahibinin hususiyetinden maksat eserin, sahibinin kişiliğinden aldığı özelliktir.” Mustafa ATEŞ, *Fikir ve Sanat Eserleri Üzerinde Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s. 57-59.*

⁶ Halil ARSLANLI, *Fikri Hukuk Dersleri, II: Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul, 1954, s. 2-3; Mustafa Reşit BELGESAY, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 1955, İstanbul, s. 14; Şeref ERTAŞ/ K. Emre GÖKYAYLA, “Mimari Projeler Üzerindeki Telif Hakkı” Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, DEÜ Yay., İzmir, 2000, s. 408. Naklen Cahit SULUK; Ali ORHAN, *Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, Cilt II, Genel Esaslar Fikir ve Sanat Eserleri, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2005, s. 141-142.**

Söz konusu unsurların bir çalışmada bulunup bulunmadığının tespiti mahkemeler tarafından görevleri gereği araştırılmaktadır.⁷

1. Sahibinin Hususiyetini Taşımaya: Subjektif Şart

Bir eserin sahibinin özelliğini taşıyor olması, o eserin daha önceki eserlerden bağımsız olması ve yaratanın fikirsel veya sanatsal emeği sonucunda var olması demektir. Elbette bu ifadeden “*daha önce hiç yapılmamış olanın yapılması*” anlamı çıkmamalıdır. Başka bir eserden esinlenmek, ilham almak mümkündür ancak bu ilham veya esinlenme başkasının eserini gaspa veya intihale⁸ yahut taklide⁹ varacak ölçüde

⁷“Davacı, kendisinin maddi yükünü de yüklenerek yaptığı kazılarda çıkan eserler hakkında yayın yapma hakkının kendisine ait olduğu halde davalı tarafından, haksız olarak bir kısım eserlerin resim ve krokilerini yayınlamak suretiyle kendisinin hakkına tecavüz edildiğini ileri sürmüştür. Mahkeme ise kazılarda çıkarılan eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümlerine göre değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir. **Zira Yasanın isminden de anlaşılacağı üzere bu Yasanın uygulanması için ortada kişinin yarattığı bir eserin mevcut olması gerektiğini vurgulamıştır.**” 4.HD., 1.7.1978, E. 1976/5913, K. 1977/7617; Senai OLGAÇ, Fikir Hakları ve Yayın Sözleşmeleri, Ankara, 1979, s. 99; Gürsel ÜSTÜN, Fikri Hukukta İşleme Eserler, Besim, İstanbul, 2001, s. 4 vd. Naklen SULUK/ORHAN, age., s. 134 vd.; “Derule” türküsünün tarihi gelişiminin incelenmesi; folklor ürünü mü yoksa sırf davacı muhayyalesinde ve sanat gücü ile yaratılan bir eser mi yahut da kendinden katkıda bulunarak esasen mevcut olan bir folklor ürününü yeni bir eser haline mi getirdiği veya mücerret folklor ürününü nota ile tespit mi ettiğinin araştırılması gerekir. Bu araştırmanın yapılabilmesi için, eğer mevcut ise folklor ürününün tespit edilmiş olması iktiza eder. Bu suretle iki eserin ses, nota ve güfte bakımlarından karşılaştırılması lazımdır. Bu karşılaştırılmanın yapılabilmesi amacı ile izlenecek yolun tayini için ilgili resmi mercilerden gerekirse yetenekli bilirkişilerden yörelere göre Türk folklor musikisinin, özellikle, folklor ürünü olarak “Derule” türküsünün tespit edilmediğinin tahkiki ve ondan sonra karşılaştırmanın Türk folklor musikisine ve tarihin gelişime bihakın vakıf yetenekli bilirkişiler aracılığı ile yapılması ve bunun kazai denetimine de olanak sağlayacak şekilde raporla belirtilmesi iktiza eder. Böyle bir tespit mevcut değilse, yani notaya alınmamış, bir bant doldurulmamış yahut bir plağı bulunmuyor ise, karşılaştırma ses, ahenk ve güfte gibi musiki kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır. Yukarıdaki esaslar uyarınca gerekli inceleme yapılmadan eksik tahkikata müsteniden ve son bilirkişilerin mesnedini göstermedikleri mücerret kanatlarını ifade eden raporlarına dayanılarak yazılı olduğu şekilde hüküm tesisinde isabet görülmemiştir. Yargıtay 11. H.D., 23.5.1974, E. 1974/1100, K. 1974/1805 – YKD, C. III, 1977, s. 675-677; SULUK/ORHAN, age, s. 791-792

⁸ **İntihâl, başkasına ait bir eseri kendine mâl etmedir.**

olmamalıdır. Başkasına ait bir esere, küçük veya büyük bazı fikirselsel ve sanatsal katkılar ekleyerek sahiplenilmesi etik açıdan ve hukuken yasaktır. İşte tam bu anlamda eser; bağımsız olmalı, yaratıcısından izler taşımalıdır. HİRSCH¹⁰ ve AYİTER¹¹, hususiyet kavramını “*herkes tarafından vücuda getirilmeyen, yani ancak yaratıcı bir fikri çaba mahsulü*”; YARSUVAT¹², “*orijinal, yani özgünlük ölçütünün olması*”; EREL¹³ ise, “*yaratıcı gücün yansıması*” şeklinde değerlendirmişlerdir.

Kanaatimizce, bir yaratının sübjektif şarta sahip olmasını; eser sahibinin kendi emeği sonucunda, varolanlardan önemli ölçüde değişik (yoksa “taklit” olur, “eser” olmaz) bir ürün yapılması ve bu yapılan ürünün *eser sahibinden izler taşıması* olarak değerlendirebiliriz.

Yargıtay bu konuya ilişkin vermiş olduğu bir kararında¹⁴; yaratının “eser” sayılıp sayılmaması açısından, “somut şekilde bağımsız bir çalışma ve emek unsurunun varlığını barındırıp barındırmadığı ve özgünlük taşıyıp taşımadığı” hususlarının belirleyici olacağını söylemektedir.

Yine Yargıtay, anonimlik iddiası olan müzik eserlerinde konunun uzmanlarınca eserin birçok açılardan incelenmesi gerektiğini şöyle belirtmektedir.

“Davacı, söz ve müziği kendisine ait “Derule” adlı türkünün söz ve yazısını aynen almak suretiyle davalılardan B.’nin diğer firma adına plağa okuyup, plakların satışa çıkarılmış olduğunu beyanla,

⁹ Yargıtay bir kararında; “bir kitabın **maksadını haklı gösterecek orandan fazla şekilde; alıntılar, benzetmeler yaparak, dil, üslup, dizayn, örnekleme konularında davacıya ait kitaptan alıntılar yapılmak suretiyle** kitabın bu şekilde içerik ve sayfa düzeninde birebir benzerlikler göstermesini taklit olarak kabul etmiştir.” 11.HD., 26.1.1995, E. 1994/7727, K. 1995/461. “...Davalı tarafından yayımlanan “Genel Kurmay Belgelerinde Kürt İsyanları” adlı 2 ciltlik eserin **davacı tarafından yayınlanan eserin kopyası olduğu gerekçesiyle**, tecavüzün men ve ref’ine, 72, 000, 000 TL kazanç mahrumiyetinin dava tarihi 28.12.1992 tarihinden itibaren %30 yasal faiziyle tahsiline ve fazla istemin reddine karar verilmiştir.” Yargıtay 11. H.D., 3.6.1996, E. 1996/6793, K. 1996/6925, SULUK/ ORHAN, age, s. 766

¹⁰ HİRSCH, Hukuki Bakımdan Fikri Say. C. II, Fikri Haklar (Telif Hukuku), İstanbul, 1943, s. 12.

¹¹ Nuşin AYİTER, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, 2. Bası, Ankara, 1981, s. 6 Naklen SULUK/ORHAN, age., s. 142.

¹² Duygun YARSUVAT, Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, 2. Bası, İÜSBF Yay., İstanbul, 1984, s. 41 Naklen SULUK/ORHAN, age., s. 142.

¹³ Şafak EREL, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1998, s. 27.

¹⁴ Yargıtay 11. H.D., 21.12.2004, E. 2004/2772, K. 2004/12672.

45,000 lira maddi ve 55,000 lira manevi ki cem'an 100,000 liranın faizi ile davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar savunmalarında, dava konusu türkünün, halka malolmuş bir Karadeniz folklor türküsü olup, davacı ile alakası bulunmadığını, talebin fahiş olduğunu ileri sürmüştür.

Mahkemece, özetle ..., türkünün davacıya ait bir eser olduğu anlaşılmakla ve alınan diğer raporlarda kadri maruf olduğu belirtilen 40,000 lira maddi tazminat ile takdiren 5,000 lira manevi tazminatın ... tahsiline... karar verilmiştir.

Hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılabilir gibi, davacı, davalılardan B. tarafından (okunan) diğer davalı S. plak firması sahibi F.'nin plak haline getirerek satışa arz ettiği "Derule" türküsünün beste ve güftesinin kendisine ait olduğunu iddia ettiğine ve adı geçen davalılar da bu türkünün Trabzon yöresinin folklor ürünü bulunduğunu savunduğuna göre her şeyden önce bu iddia ve savunmanın kanıtlanması gerekir. Gerçekten davacı tanıkları, davacının bu türkünün notasını İstanbul Radyo Müdürlüğü'ne 1964 yılında verdiğini ve bu suretle davacının repertuarına alındığını söylemişler ve fakat davalıların savunması ve türkünün menşei hakkında bir beyanda bulunmamışlardır.

Davalıların tanıkları ise savunmayı teyit etmişlerdir.

Mahkemece seçilen ilk bilirkişi raporu savunmayı doğrulamış, iddia ve savunmanın incelenmesi için İstanbul Konservatuarından tayin edilen üç kişilik bilirkişi kurulu ise, iddiayı teyit etmekle beraber, kanaatini destekleyen delilleri ve incelemenin musiki kurallarına ne suretle uygun bulunduğunu raporunda belirtmemiştir. Kaldı ki, davacı dahi mahkemeye ibraz edilen bir beyanında türkünün dedesi zamanından kaldığını ifade etmiştir.

Bu durumda "Derule" türküsünün tarihi gelişiminin incelenmesi; folklor ürünü mü yoksa sırf davacı muhayyalesinde ve sanat gücü ile yaratılan bir eser mi yahut da kendinden katkıda bulunarak esasen mevcut olan bir folklor ürününü yeni bir eser haline mi getirdiği veya mücerret folklor ürününü nota ile tespit mi ettiğinin araştırılması gerekir. Bu araştırmanın yapılabilmesi için, eğer mevcut ise folklor ürününün tespit edilmiş olması iktiza eder. Bu suretle iki eserin ses, nota ve güfte bakımlarından karşılaştırılması lazımdır. Bu karşılaştırılmanın yapılabilmesi amacı ile izlenecek yolun tayini için ilgili resmi mercilerden gerekirse yetenekli bilirkişilerden yörelere göre Türk folklor musikisinin, özellikle, folklor ürünü olarak "Derule" türküsünün tespit edilmediğinin tahkiki ve ondan sonra karşılaştırmanın Türk folklor musikisine ve tarihi gelişimine bihakkın vakıf yetenekli bilirkişiler aracılığı ile yapılması ve bunun kazai denetime de olanak sağlayacak şekilde raporla belirtilmesi iktiza eder. Böyle bir tespit mevcut değilse, yani notaya alınmamış, bir bant doldurulmamış yahut bir plağı bulunmuyor ise, karşılaştırma ses, ahenk ve güfte gibi musiki kurallarına

uygun şekilde yapılmalıdır. Yukarıdaki esaslar uyarınca gerekli inceleme yapılmadan eksik tahkikata müsteniden ve son bilirkişilerin mesnedini göstermedikleri mücerret kanaatlerini ifade eden raporlarına dayanılarak yazılı olduğu şekilde hüküm tesisinde isabet görülmemiştir. ...¹⁵

Görüldüğü gibi sübjektif şarta ilişkin olarak, kesin çizgilerle bağımsızlık ve daha önce yapılanlara hiçbir şekilde benzemezlik şartı aranmamaktadır. Fikri Hukuk; mevcut malzemenin başka türlü şekillendirilmesini, düzenlenmesini yahut mevcut bir fikir veya anlayışın farklı tarzda incelenmesini, açıklanmasını veya yorumunu da kabul etmektedir.¹⁶ Nitekim bazı bilimsel eserlerde, sözlüklerde, haritalarda¹⁷, içtihat dergileri ve benzerlerinde eser sahibinin özelliği; kullanılan bilimsel ve teknik malzeme arasında belirgin şekilde fark edilmeyebilir. Buna rağmen bu tarz çalışmalarda belirlenen fikri emeğin korunması gerektiği şüphesizdir ve yukarıda açıklandığı anlamda “sahibinin özelliğini taşıma” şartı var olduğu ölçüde, bunlar da eser sayılırlar.¹⁸ Ancak taklitçilikte bu sübjektif şart bulunmaz ve Yargıtay taklitçiliği veya başkasının eseriyle çok benzer eserler oluşturmayı FSEK’e aykırı bulmuş ve bu nedenle bu işi yapanları tazminat ödemeye hükmetmiştir.¹⁹

FSEK madde 13/II uyarınca, **eser sahibine tanınan hak ve yetkiler, eserin bütününe ve parçalarına şamildir.** Buna göre eser tamamlanmasa da eğer o zamana kadar oluşturulan bölüm, eser sahibinin hususiyetini taşıyorsa veya hususiyetinden izler taşıyorsa, eser sahibinin parça üzerinde de hakları bulunmaktadır²⁰. Örneğin çoğaltma hakkının

¹⁵ Yargıtay 11. H.D., 23.5.1974, E. 1974/1100, K. 1974/1805 – YKD, C. III, 1977, s. 675-677.

¹⁶ Halil ARSLANLI, age., s. 7 Naklen EREL, age., s. 27-28.

¹⁷ “Davacının çizmiş olduğu haritanın, davalılarca izinsiz çoğaltılarak ücretli ve ücretsiz dağıtılması nedeniyle açılan (davada)... ve çizilen haritanın bağımsız bir emek sonucunda, **özgün şekilde yapıp yapılmadığının** tespitinden sonra yapılan tecavüzün FSEK kapsamında değerlendirilmesine...” 11.HD., 21.12.2004, E. 2004/2772, K. 2004/12672.

¹⁸ EREL, age., s. 34.

¹⁹ “Davacının eseri olan “En Zayıf Halka” isimli yarışma programının davalı şirketçe izin alınmadan ve anlaşma olmaksızın; aynı format, içerik ve kurallarla “Kim Gitsin” ismiyle yayınlanması nedeniyle tecavüz edildiğine ilişkin açılan davada; davalının eylemleri FSEK’e aykırı bulunmuş ve tazminata hükmedilmiştir.” 11.HD., 21.9.2004, E. 2003/12452, K. 2004/8678.

²⁰ FSEK md. 13/II’deki “parça” kavramını Kanun tanımlamadığı için yazarların bazıları koruma için hususiyeti yeterli görürken (TEKİNALP, age., s. 96, N. 12;

devrini taahhüt ederek borçlandırııcı sözleşme yapabilir (FSEK md. 50). Ayrıca parçaların küçüklüğü, önemi ya da değeri önemli değildir; önemli olan, eserin parçasında da eser sahibinin hususiyetinin bulunmasıdır²¹.

Eserin sahibinin özelliğini taşıması şartının kabul edilmesi ile, meydana getirilen fikirsel veya sanatsal eser ile eser sahibi arasındaki bağ ortaya konmuş olur. Böylece herkes tarafından kolayca veya rasgele meydana getirilebilecek fikir ve sanat ürünlerinin tamamının eser sayılması da önlenmiştir.²² Örneğin bir klasik müzik bestecisinin yeni bir müzik yapmasında, ortaya çıkan fikir ürününün eser sahibinin özelliğini taşıdığını söyleyebiliriz. Buna karşılık, müzik ile uğraşmayan bir kimse-nin, rasgele müziksel bir çalışma yapması, bu çalışmanın eser niteliğini taşıdığını göstermez.

Yargıtay folklorik ve anonim bir eserden yararlanmakla birlikte sahibinin özelliklerini taşıması halinde o çalışmanın eser sayılacağını aşağıdaki kararlar hüküm altına almıştır.

“Davacı, dava dilekçesinde kendisine ait ‘E...’ adlı eserin kısaltılmış ve tahrif edilmiş (bozulmuş) şekilde izin alınmadan ve telif hakkı ücreti ödenmeden davalı yapımcı (tarafından) F.T. isimli sanatçının sesiyle ‘E.... Gözbebeğimsin’ adlı bir kasette yayın ve ticaret konusu yaptığını ileri sürerek 50,000,000 lira maddi, 50,000,000 lira manevi tazminatın, eserin Kültür Bakanlığına tescil tarihi esas alınarak %45 ticari faiziyle birlikte tahsilini, kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili davaya cevabında, davacının şiirin sanatçı F.T. tarafından bestelenmesine izin verdiğini, ... dava konusu şiirin davacıya ait olmayıp ‘Y... Sürmeli’ adlı folklorik bir şiirden büyük oranda alıntılar taşıdığını, talep olunan tazminatın fahiş olduğunu, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporlarına nazaran, **davaya konu ‘E...’ adlı şiirin davacının eseri olduğu, şiirde folklorik bir eserden alıntılar mevcutsa da, eserin sahibinin hususiyetini taşıyan bir edebiyat eseri niteliğinde olduğu** anlaşıldığından, davacının izni alınmaksızın **bu eserin değiştirilerek kullanılması ve piyasaya sürülmesi nedeniyle davacının maddi ve manevi haklarına tecavüzde bulunulduğu gerekçeleriyle 50,000,000 lira maddi, 25,000,000 lira manevi tazminatın**

ÖZTRAK, age., s. 38); bazıları ayrıca parçanın kendi içinde bütünlük taşıması gerektiğini belirtmektedir. (ARSLANLI, age., s. 39; HIRSCH, age., s. 135).

²¹ TEKİNALP, age., s. 96, N. 12; ÖZTRAK, age., s. 38. Ayrıca bkz.; Y. 4. H.D., 29.03.1988 T., 1987/9793 E., 1988/3221 K. sayılı kararı (YKD., C.XIV, S.8, AĞUSTOS 1988).

²² ERTAŞ/ GÖKYAYLA, age., s. 409.

dava tarihinden itibaren %30, 1.1.1999 tarihinden itibaren taleple bağlı kalınarak %45 yasal faizi ile davalıdan **tahsiline**, fazla talebin reddine **karar verilmiştir**.²³

Müzik eserlerinde yaratıcının özelliği, seslerin birbirini izleyişteki, ses dizilerinin birbirine bağlanışındaki ve ritimdeki özelliğe göre belirlenir. Yoksa mevcut bir müzik eserinin birden çok müzik aleti yahut bir orkestra tarafından veya asıl bestelendiği aletten farklı bir aletle çalınmak üzere düzenlenmesi (orkestrasyon ve enstrümantasyon) bağımsız müzik eseri değil, ancak şartları varsa FSEK 6/4 maddesi doğrultusunda “işleme eser” olarak korunur. Yine bir klasik müzik parçasının dans müziği haline getirilmesiyle yeni bir musiki eseri yaratılmış olmaz. Bu ancak bir işleme eseri olarak korunabilir.²⁴ Diğer taraftan müzik eserlerinde muhteva ve şekil birbiriyle sıkı şekilde bağlıdır. Bilimsel ve teknik eserlerde olduğu gibi iki bestekar tarafından aynı muhtevada, fakat farklı şekillerde iki müzik eserinin bestelenmesi düşünülemez.

Bu bakımdan özelliğin tespitinde, muhteva ve şekil ayrımına girmeksizin, doğrudan doğruya seslerin birleştirilme ve düzenlenmesindeki orijinallik esas alınmalıdır.²⁵

Bir çalışmanın eser olabilmesi için temel ilk şartın, o çalışmanın yaratıcısının hususiyetini taşıması gerektiğini belirtmiştik. Hususiyet içerikte mi, şekilde mi aranmalıdır? Bazılarına göre içerik; yani eserde işlenen konu, herkes tarafından kullanılabilir; korunması ve hususiyet taşıması gereken şekildir²⁶. Bazılarına göre ise, şekil ile içerik arasında bu şekilde ayırım yapılmamalıdır; hususiyet bazen şekilde, bazen içerikte, bazen her ikisinde de bulunabilir²⁷. ARIDEMİR’e göre, şekil ve içerik arasında bir ayırım yapmadan, hususiyetin içerikte veya şekilde

²³ Yargıtay 11.HD, 30.11.1998, E. 1998/6658, K. 1998/8391, SULUK/ORHAN, age, s. 187-8.

²⁴ EREL, age., s. 45.

²⁵ EREL, age., s. 45.

²⁶ HIRSCH, age., s. 134; Alman Hukuku’nda hususiyetin şekilde aranması gerektiği görüşü ve buna ilişkin eleştiriler hakkında bakınız; AYİTER, age., s. 42 vd. Naklen ARIDEMİR, age., s. 19

²⁷ ARSLANLI’ya göre “umumun malı sayılan fikir ve ideler” ve bunların dışında “edebi ya da ilmi bir eserde ifade bulan fikirler” vs. serbesttir. Bunların dışında eser sahibinin bizzat yarattığı konular ve daha önceden var olup da eser sahibinin “ilmi, bedii faaliyetinin anladığımız manada istiklaliyeti” varsa içerik de koruma kapsamındadır. Bakınız; ARSLANLI, age., s. 8; TEKİNALP, age., s. 95. N. 10; EREL, age., s. 35.

veya her ikisinde de bulunabileceğini kabul eden görüş daha isabetlidir²⁸. Örneğin, konu eser sahibi tarafından yaratılmış, onun hayal ürünü ise ve bu eser sahibinin hususiyetini yansıtıyorsa, içerik de korumadan yararlanmalıdır. Ayrıca musiki eserleri gibi şekil ve içeriğin bütünleştiği eserlerde içerik ve şeklin birbirinden ayrılması güçtür.

Eserde biçim; yapı ve ritimden, içerik ise melodiden oluşmaktadır. Müzik eserlerinde, bu unsurların bir arada bulunması şart değildir. Hususiyet; sesler arasındaki bağılılık ve seslerin düzeninde; bazen melodide²⁹, bazen her ikisinde de bulunabilir. Müzik eserlerinin belirli bir melodiye, armoni ve kontrpuan kurallarına, bilinen müzik formlarına ya da estetik değer yargılarına uygun olması önemli değildir. Önemli olan, müzik eserinin sahibinin hususiyetini taşıması, eserin fikri çaba sonucunda bir duygu ve düşüncüyü anlatmasıdır.

Musiki eserlerinde bir veya birden çok melodi bulunabilir. Bu durumda eserde yer alan melodilerin eserin bütününden bağımsız olarak korunup korunamayacağı doktrinde tartışılmıştır. ARSLANLI'ya göre, melodi olmaksızın musiki eseri esas özelliğinden yoksun renksiz bir çiçek gibidir. Bu nedenle, bütünlük taşımak kaydıyla melodi tek başına korunabilmelidir³⁰. HIRSCH'e göre ise, bir melodinin ya da birkaç notanın musiki eseri olarak nitelendirilmesi mümkün değildir³¹. ÖZTRAK ise, eserin basitlik veya karmaşıklığına ve sadelik veya zenginliğine göre ayırım yapılması gerektiğini belirtmektedir³². EREL, melodinin etrafındaki ses ve ritimlerin süsleme niteliğinde olduğunu; eser, içindeki belirli melodilerle tanınmışsa veya eserin belirgin özelliğini muayyen bir melodik yapı teşkil ediyorsa, korumanın eserin bütünü kadar melodileri de kapsayacağını ifade etmektedir³³.

²⁸ Arzu Genç ARIDEMİR, *Türk Hukukunda Eser Sahibinin Çoğaltma ve Yayma Hakları*, İstanbul, 2003, s. 20

²⁹ ARIDEMİR, age., s. 28. Melodide eser sahibinin hususiyeti kavramını birkaç sayfa ileride B.MÜZİK ESERLERİ KAVRAMI bölümünde daha ayrıntılı olarak değerlendireceğiz.

³⁰ ARSLANLI, age., s. 22.

³¹ HIRSCH, age., s. 42. Aynı görüşte; AYİTER, age., s. 52.

³² ÖZTRAK, age., s. 22.

³³ EREL, *Fikri Hukukta Musiki ve Sinema Eserleri ve Yargıtay'ın 18.2.1981 Günlü Esas 1980/1, Karar 1981/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Hukuk Bölümü Kararının İncelenmesi ve Tenkidi*, YD., C.15, S.4, Ekim-1987, s. 538. Naklen ARIDEMİR, age., s. 28.

Yargıtay da aşağıdaki kararıyla melodideki benzerliği hukuka aykırı bularak tazminata hükmetmiştir.

“Davacı vekili, davalıların seslendirip yapımcılığını üslendiği kasette yer alan “Anayurdum” adlı eserin müziğinin müvekkillerinin murisine ait olduğunu, buna rağmen kasette davalıya aitmiş gibi gösterildiğini, müvekkillerinin telif haklarının ödenmediğini, derin üzüntü yaşadıklarını ileri sürerek, 500.000.000 TL. maddi ve 1.000.000.000 TL. manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, yörelerdeki melodilerin birbirlerine benzerlik gösterdiğini, davaya konu eserinde davacılar murisinin eseri ile sözlerin giriş bölümünde benzerlik bulunmasına rağmen bunun normal olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporuna göre, davaya konu eserin davacılar murisinin eserine melodi bakımından büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini, davacıların mali ve manevi haklarının ihlal edildiği, FSEK’in 68. maddesine göre maddi tazminat ve 14, 15, 16. maddelerini ihlal ile 70. maddeye göre manevi tazminata hak kazandıkları gerekçeyle, davanın kısmen kabulü ile 300.000.000 TL. maddi ve 600.000.000 TL. manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiştir.³⁴

ERDİL’e göre, müzik eserleri, bir muhtevayı seslerle ifade eden kulak vasıtasıyla istifade edilebilecek sanat eserleridir. Bu eser türü, ze-kâya değil, işiterek duygulara hitap etmesi itibarıyla da diğer güzel sanat eserlerinden ayrılmaktadır. Öte yandan çağımızın müziği olarak ortaya çıkan ve çıkarılan sesin matematiksel bir kesinlikle belirlendiği elektronik müzik de musiki eserler kapsamında korunmalıdır. Elektronik bir müzik ürününün eser vasfını haiz olup olmadığı ise sanatçının teknik imkânları, aletleri seçmesi ve değerlendirmesindeki rolüne göre ölçülür. Eğer bu seçim ve değerlendirme şahsi hususiyet taşıyorsa bir başka deyişle başkalarından farklı ise ortada eser vasfını haiz bir musiki eser var demektir.³⁵

Bu bakımdan tabiatıta zaten mevcut olan yahut başka şahısların çıkardığı seslerin tespitine yönelik bir çalışma, bunun için ne tür ve ne kadar yoğun bir emek harcanmış olursa olsun, musiki eseri olarak korunmaz. Bu tür çalışmalar, şartları varsa FSEK madde 44 ve 84 hükümleri kapsamında korunur. Diğer taraftan seslerin eser niteliğine sahip

³⁴ Yargıtay 11. H.D., 29.03.2004, E. 2003/8671, K. 2004/3213.

³⁵ Engin ERDİL, *Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku’nda İşlenme Eserler*, İstanbul, 2003, s. 26 vd

olması için nota ile yahut manyetik bant veya plakla tespiti de şart değildir. Esasen, nota ile tespit edilmiş bir beste seslendirilmediği sürece, müzik diliyle, yani FSEK madde 2/bent 1 uyarınca dil ile ifade olunmuş bir eser olarak sayılmak gerekir. Bunun gibi müzik öğretimine yarayan her türlü kitap, solfej anahtarı vs. de musiki eseri olarak değil, bilim ve edebiyat eseri olarak korunur.³⁶

Sinema eserlerinde ise hususiyet, sinema tekniğinin özelliği olarak, ışık, tertibat, renkler, sahnenin sıralanması gibi hususların yanısıra sinema eserinin konusu gereği dikkate alınması gereken özelliklerde de aranmaktadır. Örneğin, bir roman bir sinema eserine dönüştürüldüğünde, hususiyet belirlenirken; ilim ve edebiyat eserlerinde aranan hususiyet ölçülerine de dikkat edilecektir.³⁷

Televizyon yayınları değerlendirildiğinde, bunların bir kısmının önceden çekilen dizi ve sinema filmleri olduğu görünebilir. Eser sahiplerinin hususiyetini taşımak kaydıyla, bunlar zaten sinema eseridir. Ancak bu şekilde önceden belli bir vasıtaya tespit edilmeden “canlı” olarak yapılan ve asıl televizyon eseri olan programlar, sinema eseri olarak kabul edilmeli midir? Doktrin, sinema eserlerinde aranan ölçü ve esasların bulunması kaydıyla, “canlı” televizyon eserlerini de sinema eseri olarak kabul etmektedir.³⁸

2. FSEK'te Öngörülen Eser Türlerinden Birine Dahil Olması: Objektif Şart

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yukarıda anılan ilk maddesiyle “eser” niteliğinin tespitinde subjektif şartın yanında, insan duyularıyla doğrudan ya da dolaylı olarak algılanabilir olmasını aramaktadır. Yani henüz düşünce olan gerçek hayata yansımayan fikirler FSEK korumasından yararlanamazlar. Gerçek dünyaya yansıyan fikirlerin eser olabilmesi için ise; FSEK'te yer alan ve sınırlayıcı bir şekilde eser olarak sayılan;

1. İlim ve edebiyat eserleri,
2. Musiki eserler,
3. Güzel sanat eserleri,
4. Sinema eserleri veya

³⁶ EREL, age., s. 44 vd.

³⁷ ARSLANLI, age., s. 28; AYİTER, age., s. 61; ÖZTRAK, age., s. 26-27.

³⁸ GÖKYAYLA, age., s. 104-105.

5. İşleme ve derleme eserler

kategorilerinden birine girmesi gerekmektedir.

Sayılan bu eser kategorilerinin içindeki eser türleri açısından ise; örnekleme yöntemi geçerli olup, zaman içinde farklı alt türler çıkabilir. Sözgelimi ilim ve edebiyat eserleri kategorisi içinde yer alan eser çeşitleri FSEK’de *“herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri, bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait maket ve benzerleri, herçeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri”* şeklinde sayılanlarla sınırlı değildir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 3. maddesinde müzik (musiki) eserleri ise **sözlü besteler** ve **sözsüz besteler** olarak alt türlere ayrılmıştır. İleride bu türlere yeni alt türler de eklenebilir. Değişen koşullar ve teknolojik gelişmeler sonucunda bambaşka tür eserlerin ortaya çıkması mümkündür. Ancak bunların eser olduğunun tespiti ve hangi kategori içinde değerlendirileceği netleştirilmelidir.

Pozitif hukuk bakımından eser niteliğinin tespiti için şekil unsuruna yer verilmesinin en önemli sonucu, fikirsel ürünün bu şekil altında ifadesi halinde eser olduğu karinesinin doğmasıdır³⁹.

B. MÜZİK ESERLERİ KAVRAMI

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 3. maddesinde müzik (musiki) eserleri, **“her nevi sözlü ve sözsüz besteler”** şeklinde tanımlanmıştır.

AYİTER, Hukukta Fikir ve San’at Ürünleri adlı kitabında müzik eserlerini, **“içeriği seslerle ifade edilen ve kulak aracılığıyla algılanabilen sanat eserleri”** olarak tanımlamıştır.⁴⁰

ARKAN’a göre müzik eserleri için; *“bir düşünce ya da duyguyu sesle ifade eden ve duyma yoluyla algılanan eserler”* şeklinde bir tanım daha iyi olacaktır. Hem sözsüz, enstrümantal besteler; hem de sözlü, güftelenmiş besteler; bu kapsamada eser olarak korunacaktır.⁴¹

³⁹ AYİTER, age., s. 39 Naklen EREL, age., s. 38.

⁴⁰ AYİTER, age., s. 51.

⁴¹ Azra ARKAN, Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar, İstanbul, 2005, s. 23

İsviçre Federal Mahkemesi müzik eserini; “*sese dayalı bağımsız düşünce ürünü*” olarak çeşitli kararlarında tanımlamış bulunmaktadır. Bu hüküm Bern Sözleşmesi’nden aynen alınmıştır. 1957 Fransız Kanunu da aynı yolda hareket etmiştir. Bilindiği gibi musiki eserleri bir muhtevayı seslerle ifade eden ve kulak yolu ile insanlara duyuran sanat eserleridir. Şarkılar, marşlar, türküler, operalar, ilahiler örnek olarak sıralanabilir. Musiki eserlerinde temel unsur olan ses, bir müzik aleti vasıtası ile ortaya çıkacağı gibi insan hançeresinden de meydana gelebilir. Güzel olup olmamasının eser vasfına haiz olup olmaması bakımından rolü yoktur. Seslerin nota üzerinde tespit edilmesine de gerek yoktur. Seslerin melodi ve harmoniye sahip olup olmaması da önemli değildir. Nitekim modern atonal müzik eserleri de korunmaktadır.⁴²

Bütün müzik eserleri üç unsurdan oluşmaktadır: Melodi, harmoni ve ritim. **Harmoni**, çeşitli sesler arasında kulağa hoş gelen uyum olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan akordun tek başına bir değer taşıdığı söylenmemektedir; zira akordlar sınırlı olup bütün kompozitörlerin emrine amade bulunmaktadır. Bu nedenledir ki, ancak melodi ile yan yana gelebilen harmoni, kanun koyucular tarafından korunan bir değer teşkil etmektedir. **Ritim** ise, bir müzik cümlesinde kuvvetli zamanlar ile zayıf zamanların düzenli aralıklarla tekrarlanmasıdır. Ritim de, harmonide olduğu gibi, tek başına korunmaya layık hukuki bir değer teşkil etmemektedir; melodi ile yan yana gelen ritim Kanun tarafından korunabilen fikri bir eser oluşturmaktadır. **Melodi** ise, müzik eserinin temelini oluşturan birbirini takip eden seslerden meydana gelen ezgidir. Bu ezgi hem düşünceye hem de duyguya hitap etmektedir.

Bir müzik ürününün eser olarak nitelendirilmesi için, bu üründeki şekillendirmenin yani seslerin birbirini izleyişinin, birbirine bağlanışının ve ritmin “hususiyet” taşıması gerektiğini belirtmiştik. Müzik eserlerinde yaratıcının özelliği; seslerin birbirini izleyişindeki, ses dizilerinin birbirine bağlanışındaki ve ritimdeki özelliğe göre belirlenir. Diğer taraftan musiki eserlerinde muhteva ve şekil birbirleriyle sıkı şekilde bağlıdır. Bilimsel ve teknik eserlerde olduğu gibi bestekâr tarafından aynı muhtevada, fakat farklı şekillerde iki musiki eserinin bestelenmesi düşünülemez. Mesela bir klasik müzik parçasının dans müziği haline getirilmesiyle yeni bir musiki eseri yaratılmış olmaz. Bu ancak bir işleme eser olarak korunabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, özelliğin tespitinde

⁴² YARSUVAT, age, s. 61 vd

muhteva ve şekil ayrımına gitmeksizin, doğrudan doğruya seslerin birleştirilme ve düzenlenmesindeki orijinallik esas alınmalıdır. Öte yandan mevcut bir müzik eserinin birden çok müzik aleti veya bir orkestra tarafından veya asıl bestelendiği aletten farklı bir aletle çalınmak üzere düzenlenmesi olan “aranjmanlar”, daha önceki bir besteden bir tema veya melodinin alınıp bunlara yeni gelişmelerin eklenmesiyle elde edilen “variationlar”, bir icracı sanatçının kendi esinine göre çalması ve bunun tespit edilmesi olarak tanımlanan “emprovizyonlar” bağımsız ve musiki eseri olarak değil; şartları varsa işlenme eser olarak korunur. Aranjmanlar müzik çevirileridir. Nitekim FSEK de aranjmanları işlenme olarak nitelendirmektedir⁴³. EREL’e göre de, bir müzik eseri ne kadar sanat-kârca yahut orijinal tarzda icra edilmiş olursa olsun, bu icra yeni bir müzik eseri sayılmaz ve icracıya eser sahibi statüsü kazandırmaz. İcracının fikri emeği, şartları varsa “Komşu Haklar” kapsamında koruma altındadır.

Bir müzik eserine dahil olan belirli bir melodinin, o eserden ayrı olarak eser niteliğine sahip olup olamayacağı konusu da tartışmalıdır. Bazı yazarlara göre bir melodi negamat olarak telif hakkı mevzuu olamaz. İsviçre Hukukunda melodinin kullanılması, edebi eserlerdeki fikrin kullanılmasına benzetilmekte ve düşüncelerin serbest olması gibi melodinin de herhangi bir kimsenin tekeline girmesinin söz konusu olamayacağı ileri sürülmektedir. Türk Hukukunda ARSLANLI, bir tek melodinin dahi musiki eseri sayılması gerekeceğini ileri sürmüştür. HIRSCH’e göre, tek başına bir melodinin musiki eseri olarak korunması mümkün değildir, melodi ancak bir eserin aksamından olarak korunabilir. ÖZTRAK ise, eserin basitlik veya karmaşıklığına ve sadelik veya zenginliğine göre ayırım yapılması gerektiğini belirtmektedir. EREL, melodinin etrafındaki ses ve ritimlerin süsleme niteliğinde olduğunu, eser içindeki belirli melodilerle tanınmışsa veya eserin belirgin özelliğini muayyen bir melodik yapı teşkil ediyorsa, korumanın eserin bütünü kadar melodileri de kapsayacağını ifade etmektedir. GÖKYAYLA, melodinin eser olarak değerlendirilip değerlendirilmemesinin somut olayın koşullarına göre belirlenmesi gerektiğini, bazı durumlarda bir eserden parçaların alınması halinde bir ihlalin var olabileceğini, bu durumda ihlale uğrayanın eserin parçası değil eserin bütünü olduğunu belirtmektedir.

Kanaatimizce, bir müzik parçasının özelliği birkaç nota ile belirlenemez. Bu nedendir ki, melodinin müzik eserinde iştigal ettiği yere

⁴³ ERDİL, age., s. 26 vd. ve ARIDEMİR, age., s. 27 vd.

bakmak gerekir. Alınmış bulunan melodi, alınan eseri tanıtıcı niteliğe sahip ise Kanun tarafından korunacağı konusunda şüphe bulunmamaktadır. 19. yüzyılda verilen mahkeme kararlarında melodinin başkaları tarafından kullanılmasının yasaklanamayacağı görüşü yer almakta idi. Bugün için bazı mahkeme kararlarında ve doktrinde bu yaklaşıma rastlanılmakla birlikte hâkim olan görüş melodinin tek başına hukuki bir değer olarak korunacağı yolundadır. Bir Fransız Mahkeme kararı, Monte Carlo Radyosunun tanıtma müziğinde Thomas Migon'un opera eserinden 4 ölçünün kullanılmasını taklit olarak nitelendirmiştir.⁴⁴

EREL'e göre, bu konu özellikle bir melodinin üçüncü şahıslarca başka bir eserde kullanılması bakımından önem taşımaktadır. Büyük bir opera veya senfonide geçen bir melodinin bir diğer opera veya senfonide tekrarlanması, eser sırf bu melodiden ibaret olmadığı için, ikinci eserin hususiyetine bir engel oluşturmaz; fakat basit bir şarkıda zaten bütün hususiyet belirli bir melodiden ortaya çıkmışsa, bunun başka bir şarkıda gene temeli oluşturması halinde artık yeni bir eserden bahsetmeye olanak yoktur⁴⁵. EREL'e göre, bir müzik eserin zengin ve karmaşık/kompleks olması, o eserden bir melodinin serbestçe alınıp, kullanılmasına gerekçe teşkil edemez. Zira musiki eserlerinde yaratıcının özelliği zaten bestelenen çeşitli melodilerde ve bu melodilerin birbiriyle örülmesinde görülür. Melodinin etrafındaki sesler ve ritim süsleme niteliğindedir. Hele bir musiki eseri, içindeki belirli melodilerle tanınmışsa yahut eserin belirgin özelliğini muayyen bir melodik yapı teşkil ediyorsa, fikri hukuk bakımından koruma, eserin bütünü kadar o melodileri de kapsamalıdır. Ancak tabiidir ki, anonim melodilerin yahut folklor müziğine ait tema ve motiflerin kullanılması serbesttir; fakat burada da melodi, tema veya motifin başka bir besteci tarafından işlenmiş hali değil, sadece ori-

⁴⁴ ARIDEMİR, age, s. 27 vd. ve ÖZTRAK, age., s. 23 vd.

⁴⁵ Hamide TOPÇUOĞLU, Fikri Haklar Ders Notları, Ankara, 1964, s. 43; ÖZTRAK, age., s. 22. "Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporuna göre, **davaya konu eserin davacılar murisinin eserine melodi bakımından büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini**, davacıların mali ve manevi haklarının ihlal edildiği, F.S.E.K.nun 68. maddesine göre maddi tazminat ve 14, 15, 16. maddelerini ihlal ile 70. maddeye göre manevi tazminata hak kazandıkları gerekçeyle, davanın kısmen kabulü ile 300.000.000 TL. maddi ve 600.000.000 TL. manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiştir." Yargıtay bu kararı onamıştır. Yargıtay 11. H.D, 29.03.2004, E. 2003/8671, K. 2004/3213

jinali kullanılabilir⁴⁶. Herhalde iktibas serbestisinin sınırlarını tespit ederken, müzik eserleri bakımından daha titiz davranılmalıdır (Bkz. FSEK md. 35/2).⁴⁷ Yargıtay, bugüne kadar verdiği kararlarda, müzik eserleri ve diğer eserler açısından etkilenme ile kopyacılık veya çalma (aşırma) olaylarında hassas bir değerlendirme yapmaktadır.⁴⁸

Müzik eserlerinin bir çoğu şiir gibi diğer edebiyat eserlerinden yararlanılarak oluşturulmaktadır. Bu şekildeki eserler müzik eserleri olduğu gibi aynı zamanda işlenme (işleme) eserlerdir. İşlenme eserler, FSEK madde 1b-c maddesinde “tanımlar” bölümünde “**diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsulleri,**” olarak tanımlanmıştır. Öte yandan musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserleri; sinema eseri haline dönüştürülecek olursa, Kanun bu sinema eserinin de işleme eser sayılacağı belirtmektedir. Özellikle müzik klipleri

⁴⁶ “Bir müzik eseri olan türküde, eser sahibinin belirlenmesi, türkünün tarihi gelişiminin ışıltı altında: a) Türkü folklor ürünü mü? b) Bir kişinin muhayyalesinde ve sanat gücü ile yarattığı bir eser mi? c) Bir folklor ürünü yeni bir eser haline mi getirilmiştir? d) soyut folklor ürünü nota ile mi saptanmıştır? sorularına resmi mercilerden sorularak ya da yetenekli bilirkişilere incelettirilerek yanıt bulmakla mümkündür. Anlaşmazlık konusu iki eser ses, ahenk ve güfte açısından karşılaştırılmalıdır. Tazminatın hesabında, ... diğer eserin satışa ne oranda etkili olduğu araştırılmalıdır.” 11. H.D. 23.5.1974, E. 1100, K. 1805, Y:K.D. Mayıs 1977, s. 675-677.

⁴⁷ EREL, age., s. 44 vd.

⁴⁸ “Davalının yaptığı filmin, davacının eserinden sadece esinlenme, öykülenme sonunda meydana getirilmiş genel bir etkileşim ürünü olmayıp, intihal düzeyinde alımlardan oluştuğu sonucuna varılmalıdır. Uygulama ve öğretiye göre, **bir eserden yapılan alıntılar ortaya çıkan yeni esere galip geliyorsa, artık masum alıntıdan söz edilemez.** Davalı, davacıya ait sosyolojik bir inceleme niteliğindeki bilimsel eserden, çeşitli alıntı, uyarlama ve değişikliklerle belgesel bir sinema eseri meydana getirmiştir.” HGK, 02.04.2003, E. 2003/4-260, K. 2003/271 – FMR, C. III, S. 3/2003, s. 157-166; ve “Mahkemece, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, mali hakları davacılar aیت “Gülyüzlüm” adlı **eserin fark edilemeyecek derecede birtakım değişiklikler ile “Annem ve Ben” adı altında film haline getirilerek** televizyonda yayınlandığı, bu hususun davacıların maddi ve manevi haklarına tecavüz oluşturduğu, tespit edilen zarardan davalıların sorumlu olduğu gerekçesi ile, asıl davada davalı tecavüzlerinin men’i ile 100.000.000-TL. maddi ve 100.000.000-TL. manevi, birleşen davada 650.000.000-TL. maddi tazminatın olay tarihi olan 12.02.1997 tarihinden yürütülecek reeskont oranındaki temerrüt faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmiştir.” Yargıtay kararı onamıştır. Yargıtay 11. H.D., 04.04.2002, E. 2002/310, K. 2002/3101

ya da bir müzik eserinden yararlanılarak yapılan bir sinema filmi bu kapsamda tartışılabilir.

Kanun, asıl eserin sinema veya TV eserine dönüştürülmesi için filme alınması yanında, filme almaya veya radyo-TV ile yayıma (yayına) *müsait hale sokulmadan* da söz etmektedir. Ancak bu safhada ortada henüz bir işleme eser yoktur. Eseri filme çekmeye veya yayımlamaya (yayınlamaya) *müsait hale sokmaktan* amaç; asıl eserin senaryosunun hazırlanması ise, o zaman da bu çalışma eseri dil ile ifade edilen başka bir şekle sokmak olur ki, bu “*roman, hikaye, şiir, tiyatro piyes ve benzerlerinin bu türlerden bir başkasına çevrilmesi*”dir⁴⁹.

İleride eser sahibinin mali haklarının olduğu bölümde işleme eserlere, işleme hakları kapsamında genişçe yer verilmektedir.

Bir müzik eserinde temalara sadık kalmak suretiyle yapılan parafraz ve varyasyonlar, başka bir musiki formuna dönüştürme, çok sesli veya tek sesli hale getirme, eserin belli bir enstrüman grubu yahut orkestra tarafından çalınmak üzere düzenlenmesi (enstürmantasyon, orkestrasyon), özellik taşıyan bağımsız bir fikri emek sonucu meydana getirilmişse işleme eser sayılacaktır. Ancak böyle bir emek sarfını gerektirmeksizin yapılabilecek işlemler, mesela eserin başka bir sesli nakli (transpozisyon) yahut birden çok bestenin birbirine eklenmesiyle yaratılan potpuriler, işleme eser niteliğinde değildir⁵⁰.

Bu alanda işlemler, herhangi bir eserin aslına sadık kalmak kaydıyla ve orijinal eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek ve ondan yazılı izin almak şartıyla yapılmış olmalıdır⁵¹. Bir aranjmanın eser olarak sayılması için “hususiyet” kavramı burada da karşımıza çıkmaktadır. Yani işleme eserin, onu işleyen kişinin özelliğini taşıması gerekir.

Müzik eserlerinin pazarlanması için video klip yapılması ya da müzik ve sinemayı veya müzik ile illistürasyonları birleştirerek yeni bir müziksel ürün yaratılması, özellikle cep telefonları ve diğer küçük cihazlarla bunların izlenebilmesi sebebiyle, müzik endüstrisinin teknoloji ile iç içe girdiği karmaşık fikri haklar alanlarıdır. Çeşitli bilimsel platformlarda müzik kliplerinin işleme eser mi veya sinema eseri mi olarak

⁴⁹ ARSLANLI, *age.*, s. 34; AYİTER, *age.*, s. 68-69.

⁵⁰ EREL, *age.*, s. 59

⁵¹ GÖKYAYLA, *age.*, s. 113

korunacağı çok tartışılan bir konudur. Biz de bu tartışmaları özetleyerek müzik kliplerinin korunma yöntemini belirlemekte fayda görüyoruz.

Müzik Klipleri

Kullanıcıda daha iyi bir izlenim bırakması ve televizyon, bilgisayar, mp4 çalar ve cep telefonu gibi görüntülü araçlarda tüketilebilmesi için asıl eser olan müziğe görüntüler eklenerek müzik klipleri elde edilmektedir. Müzik kliplerinde ses ve görüntünün birlikte sunulması, aynı zamanda müzik eserini, televizyon seyircileri için izlenebilir hale getirmektedir. Müzik eserlerine klip çekilmesinin birçok nedeni vardır. Müzik albümünün ve sanatçının tanıtımı, albümün reklamı ve nihayet ürünün satışının artırılması temel nedenlerdir. Bazen de yeni bir işleme eser yaratma amacı bulunmaktadır.

Dünya uygulamasında da müzik kliplerinin gelirlerinin müzik endüstrisi için büyük bir kalem teşkil ettiği görülmektedir⁵². Almanya’da müzik sektörü için GEMA bu tahsilatları takip etmektedir⁵³. Söz konusu takip ve izinlerde ilgili fonogram yapımcılarının da hakları açıkça belirtilmektedir.

Müzik klipi, bir müzik yapımcısının; eser sahibi ve icracı sanatçıdan gerekli izini alarak yaptığı ilk tespiti üzerine (tamamıyla bu ilk tespit (master kayıt) bulunan müzik ve şarkıcının sesi kullanılmak üzere) kamera ile senaryolu ve senaryosuz görüntüler koyularak yapılmakta ve televizyonlarda ya da cep telefonlarında ya da diğer tip görüntülü müzik aletlerinde yayınlanmaktadır. Bu filme alma esnasında kimi zaman herhangi bir ortamda icracı sanatçı şarkıyı okur gibi yapmakta; kimi zaman da bir konserin görüntüsü kullanılmakta veya çizgi filmlerde olduğu gibi illüstrasyonlardan yararlanılmaktadır. Bazen de manken veya oyuncular bulunarak şarkının hikayesine uygun görüntüler kullanılmaktadır. Müzik yapımcısı, ilgililerle çoğu zaman sözleşme yaparak; bazen de sözleşmesiz olarak söz konusu klip çekimlerini yaptırmaktadır.

Müzik kliplerinde müzik kasetleri ya da CD’lerden farklı olarak sadece ses (müzik) değil, aynı zamanda sese eşlik eden görüntüler dizisi

⁵² Steffen PROSSDERF, “Alternative Vermarktungsstrategien in der Tontraegerindustrie unter besonderer Berücksichtigung der Urheber- und Leistungsschutzrechte bei der Musikproduktion, www.4fo.de/download/altverm-strat_stepro_print.pdf, s. 22 Naklen MEMİŞ, agm., s. 3

⁵³ www.gema.de Naklen MEMİŞ, agm., s. 3

de bulunmaktadır. Bu nedenle müzik kliplerinin fikri hukuk bakımından niteliğinin tayininde bu unsurların da göz önünde bulundurulması gerekir.

Tekin Memiş'e göre; müzik kliplerinin sinema eseri olup olmadığı konusunda açıklama yapmadan önce bir filmin sinema eseri sayılabilmesi için gerekli şartların açıklanması gerekmektedir. Bir eserin "sinema eseri" olarak korunabilmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirlenen şu kriterler var olmalıdır: **i.** Klibin mutlaka "sahiplerinin" olması gerekir, **ii.** Mutlaka her klibin senaryosu ve yönetmeni bulunmalıdır, **iii.** Ürün, sahiplerinin hususiyetini taşımalıdır, **iv.** FSEK madde 5'te sayılan kategorilerin içinde yer almalıdır. Bir filmin sinema eseri sayılabilmesi için gerekli olan bu hususlardan konumuzla ilgili olanlar, aşağıda ayrıntıları ile ayrıca ele alınmaktadır:

a. Öncelikle ve özellikle bir senaryoya sahip olmayan müzik kliplerinin "sinema eseri" olarak kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle senaryosuz bir şekilde çekime konu olan kliplerde, FSEK anlamında sadece mevcut olan müzik bir "eser" olarak korunmaya mazhar olur. Görüntüler, bir eser olarak kabul edilmediği için, FSEK anlamında bir sinema eseri bulunmamaktadır⁵⁴.

b. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda eser, "*sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri*" olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle eserin objektif ve subjektif niteliklerinden bahsetmek gerekmektedir. Eserin subjektif niteliği, sahibinin hususiyetini taşıması, objektif niteliği ise eserin sayılan kategorilerden birinin içinde olmasıdır.

Burada hemen belirtmek gerekir ki, müzik klibinin, FSEK içinde sayılan türlerin dışında bir "eser" türü olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira kanun koyucu, eser kategorilerini sınırlayıcı bir şekilde (tahdidi) olarak belirlemiştir.

c. Kanun, sinema eserini, "*her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisi*" olarak tanımlamaktadır.

⁵⁴ Bkz. STRASSER, "Die Abgrenzung der Laufbilder vom Filmwerk", Strasser, "Die Abgrenzung der Laufbilder vom Filmwerk, 1995. Naklen MEMİŞ, agm., s. 6

Sinema eseri, birbiriyle ilişkili olmak üzere hareketli bir görüntü dizisi, bu görüntü dizisinin az veya çok kalıcı bir ortamda tespiti ve tespit edilen görüntü dizisinin mekanik, elektronik veya benzeri bir araçla gösterilebilir olması unsurlarından oluşmaktadır. Sinema eseri, birden fazla kimsenin değer itibarıyla eş olmayan çeşitli çalışmalarından meydana gelir. Bir sinema eserinde, senaryo yazarının, yönetmenin ve özgün müzik bestecisinin çalışmaları bir araya gelmekte bir eser oluşmaktadır. Buna karşın sinema eserinin sesli ya da sessiz olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır⁵⁵.

Ancak hemen belirtmek gerekir ki birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisinin sinema eseri olarak kabul edilebilmesi için FSEK madde 1/B-a ile FSEK madde 5 birlikte düşünülmeli; yani bu görüntü dizilerinin şahsi yaratıcı çabayı içinde bulundurması şartı da aranmalıdır. Şahsi yaratıcı çabanın olmadığı, sıradan görüntülerin aktarıldığı hallerde birbiriyle ilişkili hareketli görüntü dizilerinin sinema eseri olarak kabul edilmesi mümkün değildir⁵⁶.

MEMİŞ; birbiriyle ilişkili görüntülerin varlığını, sinema eserinin varlığı için şart olduğunu açıklanmışken; “*görüntülerin birbiri ile ilişkili olduğu nasıl tespit edilecektir*” sorusuna da değinmek gerektiğini belirtmektedir. Görüntülerin birbiri ile ilişkili olması, belirli bir akışın tasarlanmış olmasını, arka planda belirli bir düşünce unsurunun ve mesajın bulunmasını, görüntüleri en azından mantıksal bir dizgide sıralama iradesini ifade etmektedir.

Müzik kliplerinin sinema eseri olarak kabul edilebilmesi için öncelikle yukarıda anlatılan bu unsurların varlığı şarttır⁵⁷. MEMİŞ, müzik klipleri içinde sinema eserinin varlığının nadir hallerde mümkün olduğunu belirtmekte ve bu hallere, özellikle arka planda bir yaratıcı kurgunun yapıldığı, senaryonun mevcut olduğu ve müzik olmasa dahi birbi-

⁵⁵ SCHRÖCKER/LOWENHEIM, “Urheberrecht-Kommentar”, München 1999, § 2, Rn. 186. Naklen MEMİŞ, agm., s. 7.

⁵⁶ Bkz. Haimo SACHACK, “Urheber- und Urhebervertragsrecht”, 2. Auflage, Tübingen 2001, s. 106 ve 295. Naklen MEMİŞ, agm., s. 8

⁵⁷ Bkz. Manfred REHBINDER, “Urheberrecht” München 1996, Rn. 145 ve SCHRÖCKER/LOWENHEIM, Urheberrecht, § 7 Rdnr. 3; GAHRAU, E.: “Einleitende Überlegungen”, (HOEREN, T./ SIEBER, U.: Handbuch Multimedia-Recht, Rechtsfragen des elektronischen Geschäftsverkehrs”, München 1999)7.1, Rdnr. 28. Naklen MEMİŞ, agm., s. 10

rini izleyen anlamlı, hareketli karelerden oluşan çekimleri örnek olarak göstermektedir.

EREL'in düşüncesine göre de; bir fikir ürününe “eser” niteliği kazandıran, onu yaratan kimselerin bu yolda ortaya koydukları iradedir⁵⁸. Bu irade aynı zamanda eserin hukuki nitelendirilmesinde, yani hangi eser kategorisine dahil edileceğinin tespitinde de önem taşır.

MEMİŞ'e göre, müzik kliplerinin işleme eser olarak kabulü ilk akla gelendir. Müzik parçasında bir işlemeyen bahsedilebilmesi için onun unsurlarında bir değişikliğin olması veya yeni müzikal unsurların ilave edilmesi gerekmektedir⁵⁹. Müzikal bir işleme, müzik parçasının yeni unsurlarla varyasyonlarının elde edilmesi, yeni enstrümanların ilave edilmesi veya vokal yapılmasında olduğu gibi seslerin değiştirilmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Fikri hukuk anlamında bir işlemeyen bahsedilebilmesi için eseri dönüştüren kimsenin de bir katkısının bulunması gerekmektedir. İşleme eserde iki unsurun bulunması gerekir. Birincisi işleme eser, orijinal eserden bağımsız değildir, ikincisi ise onu işleyen kişilerin de esere bir katkısını taşımalarıdır⁶⁰.

Eserin kısaltılması veya genişletilmesi işlenme sayılmaz. Bir roman veya hikayenin kısaltılması, bir tabloda belirli bir kısmın çıkarılması, senaryonun rejisör tarafından kısaltılması birer işlenme değildir. Eserin büyüklüğünde veya boyutlarında değişiklik yapılması işleme değil, çoğaltmadır. EREL de, “eserin başka bir sesle nakli”ni işleme eser olarak kabul etmemektedir. Hatta mekanik vasıtaların kullanımı ile de bunun yapılması sonucu değiştirmez. Eserde meydana getirilen dış değişiklikler, ona bir yaratıcı emeğin katkısı değil de sadece bir sunumun, naklin, yaymanın sonucu ise, yine bir işlenme eserin varlığından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Mesela bir tablonun değişik ışıklandırılmalar altında sergilenmesi gibi. Esere bir başka boyut kazandırılması durumlarında da işlenme eser mevcut değildir. Müzik eserine sinema eseri niteliğinde görüntüler eklenmesinde, işlenme eserden değil, bir eser beraberliğinden bahsedilmektedir. Eser beraberliğinde ortada yeni bir

⁵⁸ EREL, *age*, s. 35; AYİTER, *age*, s. 45

⁵⁹ Bkz. SCHRİCKER/LOEWENHEİM, “Urheberrecht-Kommentar”, München 1999, § 3 UrhG, Rdnr. 24 ve Riedel, UFITA 58 (1970), s. 198. Naklen MEMİŞ, *agm.*, s. 12

⁶⁰ Bkz. Haimo Schack, “Urheber- und Urhebervertragsrecht”, 2. Aufl. Tübingen 2001, Rdnr. 237. Naklen MEMİŞ, *agm.*, s. 12

eser mevcut olmadığından her eser bağımsız bir eser olarak değerlendirilir. Bir müzik eserinin operada kullanılması, bir şiirin tiyatro temsilinde okunmasında da işlenme eserden bahsedilemez⁶¹.

Bir müzik parçasının mp3 formatına çevrilmesi de işlenme eser olarak kabul edilemez. Öncelikle müzik parçasının söz konusu formata çevrilmesinde mevcut esere yaratıcı bir katkı ilave edilmemektedir. Her ne kadar Kanunumuzun 6. maddesinin ifadesinde, işlenme eserlerin varlığı için “yaratıcı düşünce”den bahsedilmemiş olsa da Kanunda verilen örnekler, “**yaratıcı bir düşüncenin**” varlığının aranmasını gerektirmektedir. Kişinin herhangi bir çabasına gerek kalmaksızın, herkesin uygun araç ve bilgisayar programları ile ortaya çıkarabildiği boyut değişikliğinin işlenme eser olarak kabul edilmesi düşünülemez⁶². Mp4’ler içinde aynı açıklamalar geçerlidir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında MEMİŞ’e göre, müzik kliplerinin işleme eser olarak ayrı bir kategoriye sokularak müzik eserlerinin işlenmediğinden bahsetmek mümkün değildir. Burada müzik eserinin niteliğinde ve onu oluşturan unsurlarda herhangi bir değişiklik olmamakta; **bilakis müzik eseri aynen muhafaza edilmektedir**. Bu halde müzik eserine görüntünün ilave edilmesi, müzik eserinin işlendiği anlamına gelmez. Eğer şartları varsa ve görüntüler yukarıda belirtildiği gibi bir sinema eseri olarak kabul edilebiliyorsa bu durumda sadece **bir eser beraberliğinden söz etmek** gerekecektir.

Burada akla gelebilecek bir diğer soru da, FSEK madde 6/3’ün nasıl yorumlanması gerektiğidir. FSEK 6/3’de “*musikî, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulması veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması*” işlenme olarak kabul edilmiştir. Kanun’un bu hükmünün de işlenmenin şartları ile birlikte düşünülmesi gerekir. MEMİŞ’in değerlendirmelerine göre, mevcut bir fonogramdaki ses kaydına, yani müziğin asıl unsurlarına hiçbir etkisi ve katkısı olmayan sadece müziğin pazarlanması veya var olan

⁶¹ Geniş Bilgi için bkz. Fırat ÖZTAN, “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler”, Prof.Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 229 vd; EREL, age, s. 59 ve Haimo SCHACK, H.: Urheber- und Urhebervertragsrecht, 2. Aufl. Tübingen 2001, s. 140-141, p. 291.

⁶² Bu konuda bkz. Tekin MEMİŞ, “Fikri Hukuk Bakımından İnternet Ortamında Müzik Sunumu”, Ankara 2002, s. 107 vd.

müzikten bir başka ürünü elde etmek amacına yönelik filme alma ya da radyo-televizyon yayını haline getirme “işlenme” olarak kabul edilemez.

EREL'e göre; bir bestenin filme alınması yahut filme almaya veya radyo ve televizyonla yayına müsait şekle sokulması, müzik klipi çekilmesiyle aynı değildir. EREL'in kanaatine, Kanunda bu ibareyle kastedilen, izleyici huzurunda veya stüdyoda icra edilmekte olan bir müzik eserinin konser veya stüdyo icralarının ya doğrudan filme alınması veya radyo-televizyon yayın amacıyla ve yayın tekniğinin gerektirdiği işlemlerle tabi tutulmasıdır. Halbuki müzik eserine klip çekilmesi bundan tamamiyle farklıdır. Bu halde icranın olduğu gibi, aynen nakli söz konusu değildir. Klipte icranın yanısıra, hatta bazen icra dahi gösterilmeksizin artistik görüntülerin besteye eşlik etmesi durumu vardır.⁶³

MEMİŞ'e göre; müzik klibinin bir sinema eseri olması hallerinde dahi, müzik eserinin ve bu eser üzerindeki hakkın, çekimlerden önce var olduğu (pre-existing works) 1967 Stockholm Konferansı'ndan bu tarafa ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu tür eserler üzerinde eser sahiplerinin kendiliğinden hak sahibi olduğu kabul edilmiştir⁶⁴. Müzik kliplerinde kullanılan müzik eserleri (fonogram-master kayıt) üzerindeki haklar da klip çekiminden önce mevcut olduğu için bu hakların icracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları açısından kullanılmasında herhangi bir değişiklik olmaz. Bir yargıtay kararında bu husus isabetli bir şekilde şöyle vurgulanmıştır: “*Mahkemece taraflarca sunulan kanıtlar ve yaptırılan bilirkişi incelemesine göre, asıl davada davacıya ait kitapların ilmi eser olduğu, içerisindeki resimlerin ayrı bir eser olup, bunların sahiplerinin resmi yapan ressamlar olduğunun anlaşıldığı; taraflar arasındaki 1995 tarihli sözleşme uyarınca eserle ilgili mali hakların beş yıllığına davalıya devredildiği ve beş yılın bitimi ile eser üzerindeki mali hakların eser sahibine geri döndüğü, bu nedenle kitap basımı ile ilgili film ve ozalitlerin, şarkı kasetlerinin, orijinal nüsha ve yazara ait tüm materyallerin iadesi gerektiği, kitaplarda kullanılan resimlerin yazara ait olduğu tevşik edilemediğinden resimlerin iadesinin istenemeyeceği kanaatine varıldığı, birleştirilen davada ise kitaplardaki resimlerin kitapları bütünlüyen nitelikte olmadığı, FSEK madde 9/1 nci maddesi hükmü çerçevesinde resim ve müzik olarak kısımlara bölünebileceği, her kısmın ayrı*

⁶³ EREL, (Müzik Klipleri) agm., s. 55 vd.

⁶⁴ Akın BEŞİROĞLU, *Düşünce Ürünleri Üzerindeki Haklar, Fikir Hukuku*, Ankara 2002, s. 78.

bir eser olarak fikri haklardan yararlanabileceği, bu itibarla ortak bir eserden söz edilemeyeceği, gerekçesiyle ... davanın reddine karar verilmiştir.⁶⁵”.

Müzik eserine eşlik eden görüntülerin sinema eseri sayılması halinde bu durumda yukarıda da verildiği gibi asıl bahsedilmesi gereken, eser beraberliğidir. Eser beraberliğinde birden fazla eser birlikte sunulmakla birlikte, her eserin hak sahipliği ve hakları, o eseri vücuda getiren kişilere aittir ve her eser bağımsız biçimde takip edilir. Her bir eser sahibi, diğerinden bağımsız olarak kendi vücuda getirdiği eser kısmının mali ve manevi haklarını kullanma yetkisine sahiptir. Kendi eser kısmı ile ilgili kısımları, diğer eser sahibi ya da sahiplerinin onayını almadan yapabilir⁶⁶.

Kanaatimce, müzik eserlerinin klip haline getirilmesinde; hem var olan müzik eseri varlığını sürdürmekte, hem de sinema eseri veya işleme eser olarak da nitelenebilecek yeni bir eser ortaya çıkmaktadır. Bu yeni eseri, sinema veya işleme eser olarak isimlendirmek için; önce yaratanların iradesine sonra da eserlerin ilgili şartları taşıyıp taşımadığına bakmak gerekir.

Eğer gerekli şartları varsa klip; pekala işleme veya sinema eseri olabilir.

Bir müzik klbinde bu yüzden, müzik eseri sahiplerinin ve komşu hak sahiplerinin yanısıra işlemeyi yapanların ya da sinema eseri sahibi olacak yönetmen, senaryo yazarı gibi kişilerin de hak sahibi olabileceğini söyleyebiliriz.

Neticeden bir müzik klbinin kullanmak isteyenler tüm haksahiplerinden izin almak zorunda olup; eğer izinsiz bir kullanım olursa, yukarıda sayılan kişilerin her biri yasal yollara başvurarak yasaklama veya tazminat gibi sonuçlar elde edebilir.

⁶⁵ Bkz. 11.HD.26.02.2004, E. 2003/7291, K. 2004/1772. Naklen MEMİŞ, agm., s. 13

⁶⁶ Bkz. Naci KINACIOĞLU, “Sinema Eserleri ve Bunlarda Eser Sahipliği”, Prof.Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 213 ve AYİTER, age., s. 63; TEKİNALP, age., s. 140. Naklen MEMİŞ, agm., s. 13

IV. ESER VE BAĞLANTILI HAK SAHİPLİĞİ KAVRAMLARI

A. ESER SAHİPLİĞİ

1. Genel Olarak

FSEK madde 8/1 hükmü kısaca, “***bir fikir ve sanat eserinin sahibi, onu vücuda getirendir***” demektir. Eser kavramını incelerken değinildiği üzere, her türlü fikir ürünü değil; sadece eser sahibinin özelliğini taşıyanlar eser sayılacağından, ***eser sahibi, yaratıcı gücünün özelliğini meydana getirdiği fikir ve sanat ürününe yansıtan şahıstır.*** Bu tanımdaki eser sahibinin, eseri yaratan gerçek kişi olacağı ifadesi, “yaratma gerçeği ilkesi” olarak anılmaktadır. Bu ilkenin kaynağı tabii hukuk olup, sahibi olan insanın hususiyetini/özelliğini taşıması şartıyla uyum içinde bulunmaktadır. Zaten tüzel kişilerin, -içinde bulunan gerçek kişilerden ayrı- fikirsel ve sanatsal faaliyetleri bulunmadığı için fikir ve sanat ürünü yapımları da mümkün olmamaktadır.

FSEK madde 8’de bulunan “*bir eserin sahibi onu meydana getirendir*” ana kuralı çerçevesinde; bir müzik eserinin sahibi onu meydana getiren kişidir. Bu kişi çoğunlukla müzisyen olup, kimi zaman o ana kadar müzikle ilgisi olmayan biri de olabilir.

Eser sahipliği için, maddi bir fiil olarak eserin meydana getirilmesi (*ipso jure*) yeterlidir ve eser sahibinin fiil ehliyetinin varlığı gerekmemektedir. Çünkü eserin dış dünyaya yansıyacak şekilde ortaya çıkmasıyla birlikte hak da kendiliğinden doğmaktadır.

FSEK’teki eser sahipliği sıfatı; marka, patent, tasarım ve faydalı modeldeki sahiplikten farklı olarak tescille değil, eserin doğumuyla birlikte ortaya çıkmakta, tescil veya kamuya sunum gibi bir işleme ihtiyaç duymamaktadır.

Ülkemizde fikir ve sanat eserleri eğer kitap, kaset, film gibi bir yapımla haline gelmişse tescil edilmektedir. Ancak bu tescil hak sahipliği yaratmamaktadır. Kültür Bakanlığı’nca 17/05/2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “*Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik*”in ilk maddesinde, “*bu Yönetmeliğin amacı, fikir ve sanat*

eserlerini içeren yapımlar üzerinde hak ihdas etmek amacı taşımaksızın mali ve manevi hak sahiplerinin söz konusu haklarının ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla eserlerin ve yapımların kayıt ve tescilinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir” denilerek “hak sahibini belirleme amacı taşımayan bir tescil ilkesi”nin uygulandığı vurgulanmaktadır.

Eser üzerindeki mali ve manevi hakların ihlal edilmemesi, mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla bu Yönetmelik ile düzenlenen prosedüre uygun olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilen, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlayan kayıt ve tescil işlemi sonucu bir tescil belgesi verilmektedir. Yönetmeliğin 5. maddesine göre; sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespiti gerçekleştirilen film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırmak zorundadırlar. Ayrıca yurt dışından ithal edilen yapımlar da aynı işleme tabidir. Bu zorunlu bir tescildir. Kayıt ve tescil belgesinde; eserin adı, dili, menşei, yapım yılı, yapımcısının adı, yapımcı kodu, eser sahipleri, diğer komşu hak sahipleri, eser grubunun baş harflerini içerir kayıt ve tescil numarası, kayıt ve tescil tarihi, daha önce herhangi bir kayıt ve tescil işlemi yapıldıysa tarih ve numarası ile gerekli görülebilecek diğer bilgiler yer alır.

Yönetmeliğin 6. maddesine göre; filmlerin veya seslerin Türkiye’de ilk tespitini ticari amaçla gerçekleştiren kişiler, ilgili ticaret odası tarafından düzenlenmiş ve faaliyet alanını gösterir faaliyet belgesi ve ilgili alan meslek birlikleri tarafından düzenlenmiş ve yapımcılık yapılabileceğini gösterir nitelik belgesini ibraz etmek suretiyle Bakanlıktan bir yıl süreli geçici yapımcı belgesi ve yapımcı kodu alırlar. Geçici yapımcı belgesi ve yapımcı kodu bir defadan fazla yenilenmez. Yapımcı belgesi, sinema eserlerini içeren yapımlar için bir; müzik eserlerini içeren yapımlar için iki adet yapım gerçekleştirilmesi; bunları içeren materyallere alınan bandroller ile diğer iletim biçimlerini gösteren belgelerin ibrazı üzerine, yapımcı kodu aynı kalmak koşuluyla sürekli hale çevrilir. Bu maddede bahsi geçen yapımcı belgesi ve yapımcı kodu faaliyetin devam ettiğinin belgelenmesi halinde beş yılda bir yenilenir. Yapımcılar, adres

ve faaliyet değişikliklerini otuz gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Eseri veya hak sahibini, hak doğuracak biçimde tescil etme ilkesinin benimsenmemesi, uygulamadaki hak sahipliğinin belirlenmesi açısından ispat güçlükleri oluşmaktadır. Bunu önlemek için gerek uluslararası sözleşmelerde ve gerekse ülkelerin iç hukuklarında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bern Sözleşmesi'nin 15. maddesi 1. bendinde; *“Sözleşme ile korunan edebiyat ve sanat eseri sahiplerinin, aksine bir kanıt bulunmadıkça, Birlik ülkelerinde ihlallere karşı yasal yollara başvurabilmeleri için, eser üzerinde olağan şekilde adının bulunmasının yeterli olduğu”* düzenlenmiştir. *Takma olsa dahi eser sahibince kabul edilen ad, eser sahibinin kimliği üzerinde şüphe uyandırmadıkça bu hüküm uygulanır.*

Sözleşmenin 15/3 hükmü gereğince; 1. bendde değinilenler dışında isimsiz veya takma adlı eserler ile ilgili olarak, eser üzerinde adı bulunan yayımcı/yapımcı, aksine bir kanıt bulunmadıkça, eser sahibinin temsilcisi olarak kabul edilir ve bu sıfatla eser sahibinin haklarını korumak ve takip etmek hakkına sahip sayılır. Bu hükümler, eser sahibinin kimliğini açıklaması ve eserin sahipliğine ilişkin haklarını kullanması halinde son bulur.

Sözleşmenin 15/4 hükmüne göre, yayınlanmamış eserlerle ilgili olarak, eser sahibinin kimliği bilinmemekle birlikte, kendisinin bir Birlik ülkesi uyruğu olduğuna inandıracak nedenlerin mevcudiyeti halinde, eser sahibini temsil edecek ve Birlik ülkelerinde haklarını koruyacak ve takip edecek yetkili makam, bu Birlik ülkesi mevzuatı ile belirlenir.

Ülkemizde de Bern Sözleşmesi hükümleri, İç Hukuk düzenlemelerine konu olarak FSEK'e dahil edilmiştir. FSEK hak sahipliğinin ispatı açısından şu karineleri düzenlemiştir:

a) FSEK madde 11/1 hükmüne göre; yayınlanmış eser nüshalarında veya güzel sanat eserlerinin aslında, o eserin sahibi olarak adını ya da müstear adını kullanan kimse, aksi ispatlanana kadar o eserin sahibi sayılmaktadır.

b) FSEK madde 11/2 gereğince; umumi yerlerde veya radyo-TV aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, mutad şekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılmaktadır; meğer ki eserde eser sahibi olarak başkasının adı yazılmış olsun.

c) Yayınlanmış olan bir eserin sahibi 11 inci maddeye göre belli olmadıkça, yayımlayan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve yetkileri kendi namına kullanabilir.

d) Bu salahiyetler, 11 inci maddenin 2 nci fıkrasındaki karine ile eser sahibinin belli olmadığı hallerde konferansı verene veya temsili icra ettirene aittir.

e) Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl hak sahipleri arasındaki münasebetlere, aksi kararlaştırılmamışsa, adi vekalet hükümleri uygulanır.

Bu karineler kullanılarak eser ve hak sahibi ilk aşamada belirlenebilir. Öte yandan bu karinelerin aksi ispatlanarak, gerçek eser sahibinin kim olduğu her zaman ortaya çıkarılabilir.

Eser sahibine ait hak ve yetkileri kullanabilecek kişiler FSEK madde 12’de şöyle düzenlenmiştir.

“Yayınlanmış olan bir eserin sahibi 11 inci maddeye göre belli olmadıkça, yayımlıyan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve salahiyetleri kendi namına kullanabilir.

Bu salahiyetler, 11 inci maddenin 2 nci fıkrasındaki karine ile eser sahibinin belli olmadığı hallerde konferansı verene veya temsili icra ettirene aittir.

Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl hak sahipleri arasındaki münasebetlere, aksi kararlaştırılmamışsa, adi vekalet hükümleri uygulanır”

Özellikle halk müziğine ait eserlerde derleyen veya yayımlayan şeklindeki kişiler bu hükme dayanarak hakları kullanmaktadırlar¹.

¹ “ Davacı vekili, “İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar” isimli müzik eserinin müvekkili tarafından 1973 yılında okunup piyasaya tanıtıldığını, 1978 yılında TRT tarafından müvekkilinin adı ile derleme eser olarak nitelendiğini, davalıların izinsiz olarak eseri ses kaseti olarak piyasaya sürdüklerini ileri sürerek,TL. maddi veTL. manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir...

Mahkemece, iddia ve savunmaya göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davacının eserin yaratıcısı olmamasına rağmen FSEK’nun 12.maddesine göre yayımlayan sıfatı ile eser sahibine ait hak ve yetkileri kullanabileceğini, davalıların izinsiz olarak davacının hakkını kullandıkları gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 2.500.000.000 TL maddi ve 1.500.000.000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalılar temyiz etmiştir.

... Davacı, davaya konu eserin sözlerinin Aşık H.G.’ a ait olduğunu, kendisinin eserin kaynak kişisi ve bestecisi olduğunu ileri sürmüştür.

Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi ... karar vermeye yeterli değildir.

2. Eser Sahibi ile Çalıştıran veya İşveren İlişkisi

Ana kural “*müzik eserinin sahibi onu yaratandır*” olmakla birlikte; çalışan-işveren ilişkisi olan bazı hallerde Kanun, eseri bizzat üreten veya yaratandan başkasına esere ilişkin “sahiplik” ölçüsünde bazı haklar tanımaktadır. Bu hallerde eser sahibi gibi sayılan (yani eser sahipliği haklarını kullanan) kişinin, eserin yaratılması faaliyetine katkısı; özü oluşturan “özgün fikir ürününü meydana getirmek” değil, bu ürünün ortaya çıkışını sağlayan bir takım hukuksal ve ekonomik ilişkilerde bulunmasıdır.

Bu ekonomik ve hukuksal ilişkiler, eseri ve eserden kaynaklanan hakları; eser sahibiymiş gibi işverenlerin veya sözleşmesel ilişki sahiplerinin kullanmasına yol açabilir. Aslında eser sahibi yine yaratıcıdır, ancak eser sahibinin eserden doğan bazı haklarının kullanımı farklı kişilere geçmiştir. Bu kullanım, çoğunlukla mali hakların kullanılmasıyla ilgilidir; yoksa eserin sahibinde ve manevi hakların eserin yaratıcısı tarafından kullanılması durumunda bir değişiklik yoktur.

Eser sahibinin mali hakları kullanamadığı bu haller; çalışanların işleri gereği yaptıkları eserlerde ortaya çıkmaktadır. FSEK madde 18/2 de; “*aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce kullanılır. Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır*” hükmü düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, bir kişinin yanında çalışan kişilerin ürettiği eserlerin mali haklarını kullanma yetkisi çalıştırana aittir. Öyle aittir ki, artık eser sahibi bu hakları kullanamaz, sadece işveren veya çalıştıran kullanır. Her ne kadar maddede “haklar” ibaresi yazılmakta ise de, bu ibareden anlaşılmaması gereken sadece mali haklardır. Manevi haklar yine eser sahibince kullanılmaya devam eder.

FSEK’nun 12.maddesinde, yayımlanmış olan bir eserin sahibinin belli olmaması hali düzenlenmiş olup, davaya konu eserin bu kategoride sayılıp sayılmayacağı konusunda dosya içerisinde bulunan deliller ve bilhassa davacı vekilinin yargılama sırasında 21.05.2003 tarihli dilekçesinde eser sahibinin Aşık H.G. olduğuna ilişkin beyanı dikkate alınmamıştır. O halde Mahkemece fikir ve sanat eserleri konusunda uzman hukukçu bir bilirkişinin de yer aldığı bilirkişi kurulu vasıtasıyla inceleme yaptırılarak, davacının FSEK’nun 12. maddesi kapsamında kaynak kişi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin belirlenip, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir...”. Yargıtay 11.HD, 7.2.2005, E. 2004/4393, K. 2005/857

FSEK 18. maddeye göre bir müzik eserinin yaratımı; gerçek veya tüzel kişi olan işverenin memuru, işçisi veya hizmetlisi tarafından yapılmış olursa ve eserin üzerindeki (mali) hakların işçi veya hizmetli tarafından kullanılacağı özel olarak bir sözleşme ile düzenlenmemişse veya işin mahiyetinden “*bu eserlerin mali hakları çalışanlarıdır/yaratıcılarıdır veya mali hakları çalışanlarca/yaratıcısıncı kullanılır*” şeklinde bir sonuç çıkarılması mümkün değilse; müzik eserini hazırlayan kişi eserin sahibi olmakla birlikte, eserden kaynaklanan mali hakları ve her türlü yararlanma, kullandırma ile devir haklarını işveren kullanır. **Ancak bu kuralı sürekli iş ilişkisine özgülemek gerekir.** Sigortalı veya sigortasız olarak bir işverenin yanında çalışanların, çalışma dönemi içinde yarattıkları eserlerin hakları işverence kullanılır. Bir televizyon kanalında çalışanların ürettikleri programın mali haklarını kullanma yetkisinin yayıncı şirkete ait olduğu Yargıtay’ca da onaylanmıştır.²

² “...Mahkemece, sunulan kanıtlara dayanılarak, “Televole” programının 7.11.1994 tarihinden beri X A.Ş.ne ait Kanal ... TV.sinde yayınlanmakta olduğu, dava dışı Ş.B. ve arkadaşlarının, X A.Ş. ile yaptığı sözleşme tarihinin ise 15.11.1995 olduğu, sözleşmenin 4/c maddesinden bu programın sözleşmeden önce yayınlandığı teyit edilmekle anılan yapımcı ve sunuculardan oluşan ekibin sözkonusu programın yaratıcıları ve ilk kez yayıncıları olduklarının anlaşıldığı ve bu nedenle “Televole” adı üzerinde eser sahibi hakları bulunmadığı, taraflara ait TV. Kanallarında yayınlanan programın aynı olduğu, sahibi bulunduğu Kanal ... televizyonunda bu program üzerinde korumaya değer kadim ve üstün hakkı bulunduğu gerekçesiyle asıl ve birleştirilen İstanbul 3.Ticaret Mahkemesi’nin 1997/985 sayılı davaların kabulü ile “Televole” program adının Y A.Ş. tarafından kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespiti ve önlenmesine, Y A.Ş.ne ait 171513 nolu Televole markasının siciliden silinmesine, birleştirilen diğer davanın ise reddine karar verilmiştir.

..., Öncelikle dava konusu programı ilk kez meydana getirenin saptanması zorunlu bir husus olmaktadır. Mahkemece, anılan programın 7.11.1994 ten itibaren yayınlanmaya başlandığı, oysa Ş.B. ve ekibi ile yapılan hizmet sözleşme tarihinin 15.11.1995 olduğu, sözleşmede programın bu ekipçe yaratıldığının belirtilmemesi ve spor servisinde önceden hazırlana gelmekte olduğundan söz edilmesinden hareketle programı ilk olarak yayına sokan TV Kanal ... sahibinin öncelikli ve üstün hakkı bulunduğu sonucuna varılırken, bu kanı yeterli inceleme ve araştırmaya dayandırılmamıştır. Bu bakımdan, davalı ve birleştirilen dava davacısı Y A.Ş. vekilinin istemi doğrultusunda, uzman bilirkişiler aracılığı ile 7.11.1994 ile 15.11.1995 programlarının bantları ve o tarihlerdeki gazete haberleri incelenerek programı meydana getirenlerin kim veya kimler olduğu ve bunun sonucunda eser sahipliği sıfatının aidiyetinin saptanması gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporu ile yetinilerek karar verilmesi doğru görülmemiştir. Yargıtay 11. H.D. 2000/6049 E. 2000/8439 K.

Ancak EREL'e göre; sürekli bir ilişki olmaksızın vekalet, hizmet veya istisna biçimindeki çalışmalar da çalıştırının mali hakları kullanma yetkisine sahip olduğu çalışma ilişkileri olarak görülse bile, bizce kapsamı bu kadar genişletmemek gereklidir.³ İstisna sözleşmesi yani eser sözleşmesi zaten tarafların hak ve yükümlülüklerini açıkça düzenlediğinden, eser sözleşmesinin içerdiği şartlara bakarak mali hakların kime ait olduğu konusunda sorun çözülür. Eğer hakların kime ait olduğu sözleşmede açıkça düzenlenmedi ise FSEK 52 ve diğer maddeler doğrultusunda mali hakların kime ait olduğu sorunu çözümlenebilir.

Örneğin bir müzik eseri; dizi film veya müzik yapımcısı tarafından aralarında sürekli bir iş ilişkisi olmayan üçüncü bir kişiye hazırlanmış olabilir. Bu durumda tarafların aralarında yazılı sözleşmeye (istisna/eser sözleşmesi) bakılması gerekir. Sözleşme ile eser üzerindeki haklar müzik veya film yapımcısına devredilmedikçe ya da lisans (ruhsat) verilmedikçe mali ve manevi hakları kullanma yetkisi müzisyen veya çalışan müzik yaratıcılarındır.

Çalışan ve işveren arasındaki özel bir sözleşmede veya **işin mahiyeti açısından** aksinin gösterilmesi hallerinde, mali hakların işverence kullanılması kuralının işlemediğini belirtmiştik. İşin mahiyetinin aksini göstermesi çeşitli biçimlerde olabilir. Mesela bir müzisyen, müzik şirketine idareci veya danışman olarak girmiştir ve hizmet sözleşmesinde veya iş tanımında idarecilik görevi açıkça bellidir. Bu durumda çalışan idareci müzisyen, idarecilik görevi tanımının dışında bir çalışma yaparak bir eser yaratmışsa, bu durumda FSEK madde 18 kuralı bu esere uygulanmaz ve mali haklar eser sahibi yaratıcı tarafından kullanılır ve işverence kullanılamaz.⁴

³ EREL, age., s. 81

⁴ “Mahkemece; iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davacı vakıf nezdinde çalışan kişilerin ürettiği eserlerin mali haklarından yararlanmada davacının 5846 S.K.nun 8. (şimdi 18.) maddesine göre hakkının bulunduğu, davalının hazırladığı kitabı oluşturan materyal ve dökümanların %60'ının, davacının okulunda çalışan öğretmenlerin meydana getirdiği eserlerden oluştuğu, davalının eyleminin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırılık oluşturduğu, istenen manevi tazminatın makul ve ılımlı olduğu, davalı ..Yayınevinin tüzeli kişiliğinin bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile 500.000.000 TL maddi ve 250.000.000 TL manevi tazminatın davalılar M.T. ve ... A.Ş.den tahsiline diğer davalı hakkındaki davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Buradaki “**kullanma**” kavramına da değinmek gerekir. Mali haklar işverence kullanılırken, gelirler ve nemalar açısından eser sahibi adına vekaletli veya vekaletsiz olarak bir iş mi görülmektedir? Yani önce işveren kullanacak sonra gelip parayı çalışana mı verecektir? Bu soruların yanıtı “hayır” olmalıdır. İşveren kullanır ve nemaları kendisinde kalır. Çalışan/yaratıcı gidip, “*sen bu hakları benim adıma kullandın, getir parayı veya yarısını ver*” diyemez. Çünkü çalışan/yaratıcı bu çalışmayı işveren adına yapmaktadır ve mali anlamda maaş veya ücret şeklinde karşılığını almaktadır. Tabii ki çalışan ve işveren arasında başka bir paylaşım sözleşmesi varsa, o zaman sözleşme hükümleri doğrultusunda mali haklar kullanılır ve çalıştıran/işveren sözleşmenin gereğini yerine getirmelidir.

FSEK 18’deki “**tayin**” kelimesi “**çalışanı işe tayin**” olarak anlaşılmalıdır, burada BK 385’de olduğu gibi “**eserin içeriğini tayin edip, etmeme**”den bahsedilmemektedir. Ayrıca içerik tayini bir fikirdir, FSEK tarafından korunan “**fikir**” değil “**eser**”dir; yani eserin sahibinin özelliğini taşıyarak yaratılması ve beste veya düzenleme haline getirilmesidir.

FSEK 18. maddesi; eser sahipliği hakkını değil, “**mali hakları kullanma hakkı**”nı işverene verirken Borçlar Kanunu’nun 385. maddesi; sadece yayınlanan eserler için, işçilerin yarattıkları eserlerde tüm hakları doğrudan yayıncıya vermektedir. 385. maddeye göre yayıncının tayin ettiği plan dairesinde bir eser meydana gelmişse, eseri yaratanlar sözleşmedeki bedele hak kazanır, bu eser üzerindeki haklar (telif hakları) ise işverene ait olur. Burada esere ilişkin planı işveren (eseri içeriği ve niteliğiyle tayin eden) vermektedir. Bu durumda işveren gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. ***Borçlar Kanunu’nun 385. maddesine***

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 8/2. maddesine göre, aralarındaki sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça, memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserlerin mali hak sahipleri bunları çalıştıran veya tayin edenlerdir. Bu hükme dayanılarak davacı şirket lehine mali haklarına tecavüz olduğundan bahisle maddi tazminata karar verilmiş ise de, ***davacı şirket anılan maddede açık bir şekilde belirlendiği üzere, davaya konu eserin mali hak sahibi olup, eserin manevi haklarının sahibi değildir. Anılan Kanunda mali ve manevi haklar ayrı ayrı düzenlenmiş olup, manevi haklar tadadi olarak gösterilmiştir. Sayılan bu haklardan dolayı manevi tazminat isteme hakkı da manevi hak sahibine aittir. O halde davaya konu eserin mali hak sahibi olan davacının bu eserden dolayı manevi tazminat isteyemeyeceğinin kabulü ile (sadece) bu istek kaleminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Karar bozulmuştur. Yargıtay 11. H.D. 2001/2687 E. 2001/5080 K.***

göre, tüzel kişi de eser sahibi olabilecektir.⁵ Borçlar Kanunu (BK) 385. maddesi uyarınca önemli olan işveren tarafından verilen ayrıntılı hazırlık emirleri dolayısıyla yaratıcının sadece işverenin bir yardımcısı olarak görülmesidir. Yayımlayanın planı tam ve ayrıntılı değilse BK madde 385 uygulanması tehlikeye girer. Belirtmeliyiz ki BK 385 hükmü uluslararası sözleşmeler ve FSEK’deki eser sahipliği sistemi ile karşılaştırıldığında “doğal yaratım” ilkesine aykırı düşmektedir. Yaklaşık 80 yıllık BK 385 hükmü fiktisel ve sanatsal haklardaki çağdaş gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Bu sebeple BK 385. madde hükmü en kısa zamanda kaldırılmalıdır. Hatta bize göre, FSEK’in bu gün itibarıyla ulaştığı çağdaş ve kapsayıcı hali göz önüne alırsak ayrıca Borçlar Kanunu’nda yayım sözleşmesini ve ilişkisini düzenlemeye de gerek kalmamıştır.

Kanunda 2001 yılında yapılan değişiklikle eskiden “mali haklar” işverene/çalıştırana ait iken, şimdi sadece “**mali hakları kullanma hakkı**” işverene/çalıştırana geçmiştir.⁶ Kanun’un daha önceki metnine göre; işveren ve çalışanların eser sahibi sıfatına sahip olduğu gibi bir sonuç çıkmaktaydı. Bu durumda müzisyen olmayan herhangi bir vatandaşın bir müzik şirketi açarak ücretli olarak yanında çalıştırdığı müzisyenlerin yarattıkları eserlerin sahibi olması şeklinde garip bir sonuç doğmaktaydı. Fakat 2001 yılında yapılan bu değişiklik sonrasında ülkemizde sıkça rastlanan ve eserin gerçek yaratıcısı olan müzisyenlerin/müzik eseri sahiplerinin haklarına zarar veren ve kavram kargaşası yaratan durum kaldırılmıştır.

Çalıştıran ve görev veren işverenlerin personeli tarafından üretilen eserler üzerindeki mali hakları kullanma hakkının, TEKİNALP’in de savunduğu gibi, çalıştıranların eser sahibi oldukları ve oluşturulan eserler

⁵ ÜSTÜN, özellikle büyük bilgisayar programlarında hak sahibinin tüzel kişiler olmasının uygulamada bir ihtiyaç olduğunu, bu ihtiyacın da Hukukumuzda BK madde 385 ile karşılandığını savunmaktadır.

⁶ “Mahkemece, ...FSEK’nun 3/1 maddesi gereğince eser olan **yapımın davalının siparişi üzerine davacı ile birlikte dava dışı firma tarafından yapıldığı**, FSEK 8/3 maddesi gereğince aralarında özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça bir ve birden fazla kimse yayınlayanın tayin ettiği plan dairesinde bir eser meydana getirmişler ise bu eserin sahibinin yayınlayan olduğu, taraflar arasındaki protokolün imza tarihinde yürürlükte bulunan FSEK 3-4. maddeleri gereğince **istisna akdi ile oluşturulan eserin mali haklarının iş sahibi davalıya ait olduğu** ... gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir.” Karar onanmıştır. Yargıtay 11. H.D. 2003/9931 E. 2004/5299 K.

üzerinde mali haklar yanında manevi yetkilere de sahip bulundukları şeklinde yorumlanması bizce yanlıştır⁷. Zira eserin yaratıcısına ait olan manevi hakların devredilmesi mümkün değildir. Yargıtay verdiği bir kararda; hazırlanan ders ve sınav materyallerinin hazırlayan kişi tarafından yayınlanmasına karşı açılan davada, mali hak sahibinin davacı okul olduğunu kabul etmiş, ancak davacının manevi hakların sahibi olmadığını (yani manevi hakların eseri yaratan kişiye ait olduğunu) belirterek, eseri izinsiz olarak yayınlayan yaratıcı kişiye karşı manevi tazminata hak kazanamadığını vurgulamıştır.⁸ Yine Yargıtay 2003 tarihinde verdiği bir kararda; davacı firmaya ait projeleri, kendi yararına kullanan önceki işçiyi tazminata mahkûm etmiştir.⁹

3. Ortak ve Birlikte Eser Sahipliği

Müzik eserinin çoğu zaman birden fazla kişinin ortak emeği sonucunda oluştuğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar sözlü müzik eserlerinde asıl olan beste (eğer düzenleme varsa beste + düzenleme) ise de müzik sektöründe, sözleri yazan kişi de eser sahibi olarak besteci ile eşit tutulmaktadır. Bu uygulama meslek birliklerinin yapısına da yansımış ve eser sahipleri meslek birlikleri bir ayırım yapmadan söz yazarları ve bestecileri aynı kapsamda üye olarak kabul etmişlerdir. Meslek birlikleri eser sahiplerinin haklarını temsil ederken besteciler, aranjörler ve söz yazarlarını aynı potada değerlendirmektedir. Sadece bir şarkıdan veya eserden gelen telif bedelinin dağıtım yüzdeleri farklılaşmaktadır. Mesela besteci %50, aranjör %20 ve söz yazarı %30 gibi elde edilen geliri paylaşmaktadır.

Birden çok şahsın emeği sonucunda bir eser meydana geldiyse bu durumda; eserin kısımlara ayrılıp ayrılmamasına göre eser sahipliği de-

⁷ TEKİNALP, age., s. 135.

⁸ “Birden fazla kişinin iştiraki ile vücuda getirilen eser, ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eser üzerindeki haklar eser sahiplerini bir araya getiren gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılır” hükmünden hareketle; hazırlanan ders ve sınav materyallerinin mali hak sahibinin Okul olduğu kabul edilmiştir.” 11.HD., 04.06.2001 tarihli, 2687/5080 sayılı yayınlanmamış kararı. Naklen TEKİNALP, age., s. 135.

⁹ “Davacı firma bünyesinde çalışan davalılardan birinin işçi, diğerinin ise genel müdür olarak çalışırken; sadakat yükümlülüklerini ihlal ederek başka bir firma ile anlaşmış ve görevlerinden istifa etmişlerdir. Daha sonra, çalıştıkları (eski) firmada yaratılan şirkete ait proje işlemlerini, kendi yararlarına ve yeni firmaları adına kullanmışlardır. Yargılama sonunda yaptıkları bu eylem nedeniyle tazminata mahkum edilmişlerdir.” 11. H.D., 15.5.2003, E. 2003/2276, K. 2003/4996.

ğışmaktadır. FSEK sistematığıne baktığımızda; kısımlara ayrılabilen eserlere 9. maddenin ve bölünemeyen (ayrılmaz bir bütün teşkil eden) eserlere ise 10. madde hükümlerinin uygulandığını görürüz.

Eğer yaratılan eser, kısımlara ayrılabiliriyorsa ortak (müşterek) eserdir ve FSEK madde 9/1 gereğince yaratıcı kişilerden her biri meydana getirdiği kısmın sahibi olmaktadır. Söz yazarının ve bestecinin ve hatta aranjörün bulunduğu eserlere bu kural uygulanır. Besteci bestesi, söz yazarı ya da şair söz veya şiiri, ek olarak varsa aranjör yapılan düzenleme üzerindeki haklara sahip olur ve haklarını ayrı ayrı koruyabilirler. Sadece sözlere ihtiyacı olan kullanıcı veya sadece besteye ihtiyacı olan kullanıcı yalnız ilgilisi ile devir veya lisans sözleşmesi yaparak gereksinimini karşılar.

Ortak (müşterek) eserlerde önemli olan nokta, bütünü oluşturan kısımların kendi başlarına telif haklarına konu olabilmeleri ve tek başına ekonomik olarak değerlendirilebilme olanağının bulunmasıdır. Bu olanağın fiilen kullanılmış olup olmaması yahut bağımsız kısımların eser bütününe olan katkılarının nitelik ve yoğunluğu veya bazı kısımlar ayrıldıktan sonra eserin bütününe değer kaybedip kaybetmemesi önem taşımaz¹⁰. Müşterek eser sahiplerinden her biri kendi oluşturduğu kısım üzerinde mali ve manevi hak sahibi olmakta ve bunları bizzat kullanabilmektedirler. Örneğin bir müzik eserinin bestecisi sözler olmadan sadece müziğin, bir web sitesi açılış müziği olarak kullanılmasına veya bir gsm şirketi tarafından cep telefonu müziği olarak kullanılabilmesine söz yazarından bağımsız biçimde karar verebilir ve bu yönde anlaşmalar yapabilir. Söz yazarı da eserin bir kitapta basılmasına veya reklamlarda beste olmadan spot olarak kullanılmasına besteciye danışmadan karar verebilir ve bu yönde çeşitli şirketlerle sözleşme yapabilir.

Ancak müşterek eserin tamamı üzerindeki haklar eser sahiplerinin tümüne aittir. Bu hakların kullanılmasına ilişkin kararlar ancak eser sahiplerinin oybirliği ile alınabilmektedir. Aynı cep telefonu şirketi eğer müziği sözleri ile birlikte kullanıcılarına satacaksa bu durumda hem söz yazarı hem de besteciden ya da bunların üye olduğu meslek birliğinden izin alıp, anlaşma yapmak zorundadır. Kullanıcı açısından baktığımızda çoğu zaman, bir şarkının söz ve bestesi ile bir bütün olarak kullanılması gerekir. Kullanıcı sadece sözü veya sadece besteyi ayrı ayrı değil, çoğu zaman söz ve bestenin bütün olduğu bir şarkıyı, bir opera eserini kul-

¹⁰ AYİTER, age., s. 99 Naklen EREL, age., s. 76.

lanmak istemektedir. Bu kullanım şekli açısından kullanıcı, besteci ve söz yazarından ayrı ayrı izin alma prosedürü gerçekleşmelidir.

İki ayrı hak sahibinden izin almak bazen sorunlara da yol açmaktadır. Bu teorik sorun, uygulamada meslek birliklerine eser sahiplerinin birlikte üye olması ile veya bir kişinin hakları kendisinde toplaması ile çözülmektedir. Ama söz yazarının bir meslek birliğine bestecinin ise diğer meslek birliğine üye olması veya birinin meslek birliğine üye olmaması hallerinde bu teorik sorun gerçeğe dönüşmektedir ve kullanıcılar için zorluk çıkmaktadır. Bu sorunun kolayca çözümlenmesi için öncelikle eser sahipleri meslek birliklerine üye olmalıdır ve meslek birlikleri ya anlaşmalarla ortak hareket etmelidir ya da tek bir çatı altında olmalıdır.

Sorun kimi zamanda yargı yoluyla çözülmektedir. Eğer taraflar eseri oluştururken, bir sözleşme ile veya sözle “*ne olursa olsun veya mahkemeye bile başvurulsa bu eseri yaratıcılardan biri tek başına kullanamaz*” şeklinde bir anlaşma yapılmamışsa; ortak eser sahipleri bütünün kullanılması konusunda anlaşamazlarsa, sorun FSEK 9/2. hükmüne göre mahkemede çözülecektir. FSEK 9/2’ye göre; “*aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri bütün eserin değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerlerinin iştirakini isteyebilir. Diğer taraf muhik bir sebep olmaksızın iştirak etmezse, mahkemece müsaade verilebilir. Aynı hüküm mali hakların kullanılmasında da uygulanır.*” Bu düzenleme doğrultusunda taraflardan biri gerek manevi haklar ve gerekse mali hakların kullanılması, devredilmesi, lisans verilmesi açısından diğerine “*şöyle bir durum var, gel birlikte şu şekilde hareket edelim*” diye başvurabilir. Bu başvuruya gerçekten haklı bir sebep olmadıkça olumsuz cevap gelirse veya verdiği süre içinde talep sahibi cevap alamazsa; sözleşme yapmak isteyen hak sahibi mahkemeye başvurarak, üçüncü kişi ile mali hakların kullanımı konusunda sözleşme yapılmasına izin kararı çıkarabilir ve katılmayan eser sahibinin adına da tahakkuk edecek paraların belli bir banka hesabına yatırılması için kararda hüküm koydurabilir. Bu maddede “*eserin yayımlanması*”ndan bahsedilmektedir. Yayımlama mali haklardan biri olduğu için buradaki ayrı yazım gereksizdir. Ancak maddede ayrıca bir manevi hak olan “*eserin değiştirilmesi*”nden bahsedilmektedir. Eserin değiştirilmesi için eser sahibinin mahkemece zorlanması pek kolay bir şey değildir. Türk Hukukunda bu yönde bir uygulamaya rastlamış değilim. Mahkemenin eser sahibine “*illaki eserini şu şekilde değiştir*” demesi, bu maddenin Anayasa Mahkemesine temel haklar açısından gitmesine bile neden olabilir. Ancak

diğer eser sahibinin eserde yapmayı düşündüğü bir değişiklik için mahkemeye başvurabilmesi doğru bir çözümdür ve uygulanabilir. Manevi hakların, üçüncü kişilerden veya diğer ortak eser sahibinden gelen saldırılara karşı korunması için yasal başvurular konusunda taraflar zaten ayrı ayrı olarak da hareket edebileceklerdir.

Gelelim müzik eserinin ayrılmaz bir bütün olmasına.

Meydana getirilen eserin farklı kişilerce oluşturulan kısımları ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa; FSEK madde 10/1'e göre eserin sahibi onu meydana getirenlerin birliğidir. Bu duruma, birlikte eser sahipliği veya iştirak halinde eser sahipliği denir. Örneğin iki kişi ortaklaşa besteyi yapmışsa veya bestenin üzerinde düzenleme/aranje olmasında bu eser ikiye ayrılamayacağından (en azından beste olmadan düzenleme olamayacağından) aranje edilmiş haliyle bu eseri kullanmak isteyen kişiler beste sahiplerinin ikisinden veya besteci ve aranjörden birlikte izin almalıdır. Bir kişiden izin alınması yeterli değildir. Fakat aranje olmadan sadece besteyi kullanmak isteyen kişi, besteciden izin alarak müziği kullanabilir. Zira beste aranjenin bağımsız ayrılabilir eserdir.

Kanundaki “*eserin ayrılmaz bir bütün teşkil etmesi*” ifadesinden amaç, eserin yaratılmasında yapılan katkıların, eserin bütününden ayrı olarak tek başlarına telif haklarına konu olamayacaklarını ve mali açıdan değerlendirilemeyeceklerini belirtmektir. Başka deyişle, eserin ayrılmaz bütün olması halinde; eseri meydana getiren parçalar, eserin bütünlüğünü ve eser niteliğini bozmadan ondan ayrılamayacaklarından -ayrılabilir- kendi başlarına eser sayılamazlar. Ancak bu durum eserdeki yaratıcı kişilerin özelliğinin de tek ve bölünmez olduğu anlamına gelmez. Ortaklaşa yapılan bir müzik eserinde sanatçılardan her birinin özelliği konunun uzmanları tarafından eserin bütünü içinde ayırt edilebilir¹¹. Ne var ki özellik taşıyan bu parça ve bölümlerden hiçbirisi bağımsız eser sayılmaz ve kendi başlarına değerlendirilemezler.¹²

Ayrılmaz bir bütün teşkil eden esere muhtelif yaratıcıların sarf ettikleri fikri emek aynı nitelikte yahut aynı yoğunlukta olmayabilir. Esere çeşitli kişiler çeşitli oranlarda katkı sağlamış olabilirler¹³. Bu durum

¹¹ AYİTER, age., s. 100; Aksi fikir ARSLANLI, age., s. 68 Naklen EREL, age., s. 72.

¹² EREL, age., s. 72.

¹³ Yargıtay'ın 4. H.D., 28.5.1984, E. 1984/2865, K. 1984/5113 nolu kararında; “... davacılar Sadi ve Zarif; davalı Erdoğan ve diğer davalı Erdem'in miras bırakanı Hamit Zübeyir ile birlikte "Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağla-

yaratıcıların iştirak halinde eser sahibi olmalarına engel değildir; yeter ki sarf edilen fikri emek eserde yaratıcının özelliğini yansıtabilsin.

FSEK 10. maddeye göre; eserdeki ve eser sahipleri arasındaki bu birlik içindeki mülkiyet ilişkisi, iştirak halinde (elbirliği halinde) mülkiyettir. Ve bu birliğe adi şirket hakkındaki hükümler uygulanmaktadır. Âdi şirket, ortakların iradelerini gerektiren bir sözleşme türü, bir hukuki işlemdir. Halbuki bir eser yaratma hukuki işlem değil, hukuki eylemdir. Bu yüzden adi şirkete ait hükümler, iştirak halinde eser sahipleri birliğine ancak nitelikleri elverdiği ölçüde uygulanabilir¹⁴. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun adi şirket hükümlerine yaptığı atıf, ortakların adi şirket malları üzerinde kural olarak iştirak halinde malik olmalarından (BK madde 534) ileri gelmektedir ve iştirak halinde mülkiyet rejimi, eser sahipleri birliğinin hukuki yapısına uygun bir çözümdür¹⁵. Eser sahipleri aralarında yaptıkları bir sözleşmeye aksini kararlaştırmadıkları sürece, birliğe katılmaları, kar ve zarardaki payları Borçlar Kanunu'nun 521 ve 523. maddelerine kıyasen birbirine eşittir. Telif ücretlerinin nasıl bölüşüleceği ve eser üzerindeki haklarının kullanılması ve gerekli karar nisabı konularında da, yine aksi kararlaştırılmadıkça Borçlar Kanunu madde 523 ve 524 hükümleri uygulanacaktır. Ancak adi şirkette ortaklardan birinin ölümünün, aksine sözleşme yoksa şirketi sona erdireceği yolundaki hüküm (BK madde 535/2), eser sahipleri birliğine uygulanamaz. Çünkü birliğin sona ermesi, eserin yahut eser üzerindeki hakların eser sahipleri arasında bölüştürülmesini gerektirir ki, bu da mümkün

rında Türk Kazı Tarihi" isimli eseri hazırladıklarını, ancak Zübeyir'in ölümünden sonra davalı Erdem'in eseri yalnız Hamit adına basılmak üzere eser sahibi olarak Kültür Bakanlığı'na verdiğini, bu nedenle ortak esere ait telif ücretinin hangi oranda paylaştırılacağına tespitine karar verilmesini istemişlerdir. Mahkeme, eser sahibinin Hamit olduğunu kabul etmiş, ancak eserin hazırlanmasında davacılar ve davalı Erdoğan'ın katkıları gözetilerek 12 ciltlik eserin hazırlanmış haliyle yayınlanması durumunda telif ücretinin % 65'inin Hamit varisi Erdem, % 15'inin davacı Sadi, % 10'unun Zarf ve %10'unun da davalı Erdoğan'a ait olacağına tespitine karar vermiştir. Mahkemenin, eserin sahibinin Hamit olduğu yolundaki kabulü doğrudur; ancak buna rağmen eserin telif hakkı bedelini taraflar arasında paylaşması ise hatalı olmuştur. Davacıların yardımları nedeniyle sözleşmeye dayanan bir alacak hakları varsa bir eda davasıyla istenmesi olanağı olduğu da unutulmamalıdır." şeklinde karar verilmiştir. Naklen Walter Sauter'e atfen Doç. Dr. İbrahim KAPLAN, Türk İsviçre Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın Sorumluluğu, Ankara, 1983, s. 7

¹⁴ AYİTER, age., s. 101; ARSLANLI, age., s. 69,

¹⁵ HIRSCH, age., s. 87,

değildir. FSEK bu sorunu 64. maddesiyle şöyle çözümlemiştir: Eser henüz bitmeden yahut bittiği halde alenileşmeden önce eser sahiplerinden biri ölürse, ölenin mirasçılarının birliğe dahil olmaları düşünülemez. Çünkü mirasçılarının yaratıcılık nitelikleri itibarıyla ölenin şahsiyetini aynen devam ettirmeleri söz konusu değildir. Bu yüzden ölenin payı diğer eser sahiplerine intikal eder; ancak bunlar ölenin mirasçılarının uygun bir bedeli tazminat olarak ödemekle yükümlüdürler. Miktar üzerinde uzlaşamazlarsa, bunu mahkeme tayin eder¹⁶.

Adi şirket hükümlerinin iştirak halinde eser sahiplerine uygulanmayacağı diğer bir hal, Borçlar Kanunu madde 535/3 de öngörülmüştür. Buna göre, adi şirket ortaklarından birinin şirketteki payı üzerinde cebri icra işlemleri yapılır, bu pay haczedilir yahut ortak iflas ederse şirket son bulur. Bu hükmün iştirak halindeki eser sahipleri birliğine uygulaması mümkün değildir, zira diğer eser sahipleri muvafakat etmedikçe eser bunlardan birinin borcu için icra yoluyla satılamaz. Satışa muvafakat etmeyen eser sahipleri FSEK madde 64'ün kıyasen uygulanmasıyla alacaklıya uygun bir bedel ödeyip, borçlu eser sahibini birlikten çıkarabilirler¹⁷.

FSEK madde 64/2'ye göre; eser alenileştikten sonra eser sahiplerinden biri ölürse, diğer eser sahipleri ölenin mirasçılarıyla birliği devam ettirip ettirmemekte serbesttirler. Kanun eser alenileştikten sonra ölen eser sahiplerinin mirasçılarının birliğe alınmasında bir mahzur görmemiştir; zira artık eser sabit bir hüviyet kazanmış ve geriye sadece mali ve manevi hakların kullanılması kalmıştır. Sağ kalan eser sahipleri ölenin mirasçılarının birliğe almaya karar verirse, kendilerinden birliğe karşı haklarını kullanmak üzere bir temsilci tayin etmelerini isteyebilirler. Şayet mirasçılar birliğe almamaya karar verirlerse, o takdirde kendilerine uygun bir tazminat öderler. Uyuşmazlık halinde tazminat miktarını yine mahkeme belirler.¹⁸

FSEK 10/2 gereğince; eser sahiplerinden biri, birlikte yapılacak bir muameleye muhik bir sebep olmaksızın müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece verilebilir. Eser sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket edebilir.

FSEK 10. madde düzenlemesi 9. maddeden bazı konularda farklıdır. FSEK 9. maddede; birlikte eser sahipleri, diğer eser sahibinin eserin

¹⁶ EREL, age., s. 75

¹⁷ ARSLANLI, age., s. 71, AYİTER, age., s. 103.

¹⁸ EREL, age., s. 75

kullanılması için mahkemeye gitmesini bile *aksini kararlaştırarak (sözle veya yazılı anlaşma ile) engelleyebiliyorlardı*. Yine 9. maddede mali haklar ile eserin yayımı ve değiştirilmesi hakları ayrı düzenlenmişti.

Netice olarak birlikte eser sahipliğinde, FSEK 10/2 hükmü doğrultusunda eser sahiplerinden biri; gerek manevi haklar ve gerekse mali hakların kullanılması, devredilmesi, lisans verilmesi açısından diğerine “*şöyle bir durum var, gel birlikte şu şekilde hareket edelim*” diye başvurabilir. Bu başvuruya gerçekten haklı bir sebep olmadan olumsuz cevap gelirse veya verdiği süre içinde cevap alamazsa şu ya da bu şekilde haklarını kullanmak isteyen hak sahibi mahkemeye başvurarak, üçüncü kişi ile mali hakların kullanımı konusunda sözleşme yapılması gibi konularda izin kararı çıkarabilir ve katılmayan eser sahibinin adına tahakkuk edecek paraların da belli bir banka hesabına yatırılması için kararda hüküm koydurabilir. Yine birlikte eser sahibi olanlardan her biri mali veya manevi haklara bir tecavüz olduğunda, hakların korunması için tek başına gerekli girişimlerde bulunabilir ve dava açabilir. Ancak açılan dava sonucunda hükmedilecek tazminat tutarı üzerinde, hiçbir eser sahibi tek başına tasarruf edemez¹⁹.

İştirak halindeki (birlikte) eser sahipliğinde eser tek olduğundan, bazı manevi hakların diğer eser sahiplerinden bağımsız olarak kullanılması mümkün değildir. Özellikle eserin kamuya sunumu, yayımlanma zamanının ve şeklinin belirlenmesi (FSEK madde 14) sadece bütün eser sahiplerinin oybirliği ile kullanabilecekleri bir manevi haktır. Oybirliği ile verilmiş bir karara rağmen, eser sahiplerinin her biri bu manevi hakkın kendi şeref ve itibarını düşürecek şekilde kullanılmasına engel olabilir (FSEK madde 14/III). Keza eser sahiplerinden her birinin esere katkılarında veya eserin bütünü üzerinde yahut eserin veya eser sahiplerinden birinin adında yapılacak değişiklikler için yine oybirliğiyle karar verilmesi gerekir (FSEK madde 16). Zira eser, tamamlanmış haliyle bir bütün teşkil eder ve sahiplerinden her biri, eser meydana gelirken diğerlerinin katkılarını ve haklarını göz önünde tutarak ortak çalışma iradesini açıklamıştır. Eserin nitelik ve özelliğini değiştirmeye yönelik davranışlar bu iradeye aykırıdır ve eser sahiplerinin de bu tür değişikliklere engel olma yetkisi mevcuttur²⁰.

¹⁹ ARSLANLI, age., s. 70, ÖZTRAK, age., s. 46.

²⁰ AYİTER, age., s. 102.

Ortak eser oluşturmak veya birlikte eser oluşturma konusundaki sık rastlanan bir uyumsuzluk türü de esere yaratım aşamasında üçüncü kişiler tarafından yardım edilmesi halleridir. Bu yardımcı kişiler daha sonra davalar açarak eser sahiplerinden biri olduklarını iddia etmektedirler. Belirtmeliyiz ki doktrin ve yargı kararları; eserin meydana getirilmesi sırasında yapılan teknik hizmetler ve yardımların eser sahipliği birliğinin oluşmasına yeterli olmadığı konusunda aynı görüştedirler. Teknik hizmeti yapanlar veya yardımcıları birlik içinde eser sahibi olarak değerlendirilemezler. Örneğin bir bestenin yaratılmasında “Vivaldi’nin Dört Mevsim’inin müziğine benzetelim” gibi fikir vererek yardımcı olmak veya bir bilimsel eserin hazırlanması için belge veya bibliyografya araştırması yapmak, meydana getirilen esere bir katkı sağlamaz ve iştirak halinde veya ortak eser sahipliğine yol açmaz. Müzik eseri meydana getirirken söz yazarı/ bestecinin, diğer bazı kişilerin çalışmalarından yan unsur olarak yararlanmış olması, onların işlerini kullanması veya onlara bazı görevler vermesi; yararlanan kişilere (eğer eserde bu kişilerin özelliği açıkça ortaya çıkmamışsa) eser sahibi oldukları iddiasında bulunma hakkını vermemektedir.

Yargıtay, dipnottaki kararda görüleceği üzere, davacıların davalının yarattığı eserde katkıları bulunduğu gerekçesiyle eser sahibi sayılmalarını talep ettikleri davada; eserin hazırlanmasında davacıların yaratıcı çaba ve katkılarının bulunmadığını, eserin yaratılmasına sadece yardım ettiklerini belirterek davacıların taleplerini reddetmiştir.²¹

B. MÜZİK ESERİ SAHİPLİĞİ

Medeniyetin ortaya çıkmasından bu yana bireysel yaratıcılıkla yürütülen müzik üretimi, özellikle 20. Yüzyıldan sonra teknolojinin gelişmesi ile yeteneğe dayalı bireysel bir uğraş olmaktan çıkıp, uzun süreli yatırımların yapıldığı bir iş kolu haline gelmiştir.

²¹ “Mahkemece, ... uyumsuzluk konusu ilaç rehberlerinin genelde birbirinin aynısı olduğu ve FSEK 6/7 maddesi anlamında derleme ve işleme eser niteliği taşıdığı, rehberin veri değerlendirme ve sınıflanmasının eczacı olan davalılardan N., E. ve K. tarafından gerçekleştirildiği, ...giriş redaksiyonu üstlenen davacının katkısının FSEK 10/3 maddesi anlamında, teknik hizmetler veya ayrıntıya ilişkin yardımlardan ibaret bulunduğu, 1996 ve 1997’de yayınlanan rehberlerle eser sahibi sıfatı taşımayan davacının aktif dava ehliyetinin bulunmadığı, ... gerekçesiyle asıl davanın reddine, ... karar verilmiştir. Karar onanmıştır. Yargıtay 11. H.D. 2003/6239 E. 2004/568 K.

Yoğun hislerle ve bir ilhama dayalı olarak sürdürülen söz yazma ve beste yapmak uğraşı; ekonomik sonuçları sebebi ile 20. Yüzyıldan itibaren müzik yapımcıları tarafından daha çok desteklenmeye başlamış ve bu alanda çalışan kişilere yatırım yapılması ile sürmüştür. Eserlerin topluma sunulma aşamasının bir ürün satışı olması ve pazarlama ilkeleri ile yürütülmesinin gerekmesi karşısında yapımcılar, güçlü pazarlama için gösteri kısmında yer alan icracı sanatçıları kendi saflarında tutmuş ve birlikte hareket etmişlerdir. Pazarlama tekniğine dayalı bu birliktelik bir süre sonra hakların bölüşülmesinin yasal altyapısını da oluşturmuştur. 1800'lü yılların sonunda, telif haklarına sadece eser sahipleri olarak besteciler ve söz yazarları sahip iken, ilerleyen yıllarda bu haklar; eserlerin toplumda yayılmasını temin eden icracı sanatçılara ve bu eserlerin üretimi için uygun ekonomik olanaklar sağlayan müzik yapımcılarına da verilmiştir.

Yaklaşık elli yıldır tartışılıp, yasal altyapısı sağlanan bağlantılı haklar; müzik yapımcıları ve icracı sanatçılar için çağdaşlık iddiasında olan tüm ülkelerde uygulanmaktadır.

Uluslararası sözleşmelerde de telif hakkı sahipliği açısından ikili bir ayırım artık oturmuştur. Eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri olarak benimsenen bu ayırım ile bir müzik eserinin içindeki tüm unsurlar kapsanmakta ve her grup hak sahibi kendi hakları açısından kullanıcılarla toplu veya bireysel olarak görüşmeler yapıp anlaşılmakta ve elde edilen çıkarlar belli oranlarda bölüşülmektedir.

Müzik eseri sahipleri olarak nitelenen ilk grup hak sahipleri daha önce de belirttiğimiz gibi üç küme insan topluluğundan oluşmaktadır.

Meslekleri müzisyenlik olup, ağırlıklı bir nota bilgisi ve müzik kültürü sahibi olan ilk grup hak sahibi bestecilerdir. Besteciler ya yetenekleri sonucu ya da aldıkları müzik eğitiminin sonucu olarak müziksel faaliyetlerini gerçekleştirirken içten gelen bir esinlenme veya bazı kişi ve kuruluşların talebi sonucu eser üretmektedirler. Önceleri sadece müzik aletleri ile icra edilebilmesi için sözsüz üretilen eserler, sonraları işin drama kısımlarının da talep görmesi ya da var olan dramının müziksel olarak sunulmasının gerekmesi neticesinde çeşitli sözlerle hikayeleri ve konuları içerir hale gelmiştir.

Efsaneleri, önemli olayları ve en çok da aşkları anlatan sözlerin müzik eserlerinde kullanılması sonucu, müzikte tek eser sahibi olan müzisyenlere, söz ve hikaye yazarları da eser sahibi olarak katılmıştır. Söz-

süz eserler açısından tek eser sahibi besteci müzisyen iken, sözlü eserlerde eğer sözleri besteci yazmamışsa; yeni bir kişi olan söz yazarı, besteciye ait bu haklardan pay almaya başlamıştır. Söz ve beste özünde birbirinden ayrılabilir eserlerdir. Söz veya müzikte kullanılan hikaye zaten çoğu zaman tek başına bir edebiyat eseridir. Sözlerin yer aldığı beste açısından besteci ve söz yazarı ortak mülkiyet sahibidirler.

Tek işleri müzik olmayan söz yazarları kimi zaman aktif bir biçimde besteci ile birlikte o müzik eserini oluşturmak için birlikte çalışırken, kimi zaman besteci var olan şiir, roman için edebiyat eseri sahibinden izin alarak, bunlardan yararlanmaktadır. Bu üretim biçiminde söz yazan kişiler daha pasif bir konumda bulunmaktadırlar. Bu pasif konum sebebiyle; müzik eseri topluma sunulduktan sonra ekonomik getirilerin ortaya çıkması ile bu kez besteci ve söz yazarı olan kişi arasında paylaşmaktan veya paylaşamamaktan kaynaklanan sorunlar çıkmaktadır.

Eser sahiplerinin son grubu aranjörlerdir. Bu kişiler; var olan beste için, ya bestecisi ile birlikte ya da ilgili kişilerin besteciden izin alması sonucu tek başına, bestenin kullanılacağı ürüne veya yere göre bir takım unsurları ön plana çıkartarak (ancak ana esere sadık kalarak) farklı bir sunuş gerçekleştirmektedirler. Müziksel olarak besteye katkıda bulunan bu çalışmayı yapan aranjörler/düzenlemeciler zaman içinde eser sahipliği statüsüne kavuşmuştur. Aranjör veya düzenlemeciler söz yazarlarının çalışmalarında olduğu gibi tek başına değer oluşturan çalışmalar yapamamakta sadece alttaki bestenin yanında ve beste ile bütünleşen bir çalışmaya sahip olabilmektedirler. Bu kişiler daha çok bestenin o versiyonu için eserin birlikte sahibidirler ve aranjörün çalışması ana besteden ayrılmaz. Bu ilişki bestenin aranje edilen versiyonu için aranjör açısından iştirak halinde eser sahipliğidir.

Müzik eserlerinin üretim sürecine ilişkin bu açıklamalarımızdan sonra Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda eser sahipliği hukuki durumunu açıklayalım.

Bir eser oluşturan kişi, yaratma olgusu ile “eser sahipliği” hukuki durumuna girer. Bu hukuki durum, meydana getirilen eser üzerindeki her türlü fikri hakkın kaynağıdır. Bir fikir ve sanat eserinin yaratılmış olması, yaratan şahsın eser sahibi statüsünde (durumunda) yer alması ve buna bağlı olarak eser üzerindeki hakların doğumu için gerekli ve yeterli

şarttır²². Başka deyişle, eser üzerindeki hakların doğumu ve eser sahibi sayılmak için hiçbir hukuki işleme, hatta bu yolda bir iradenin varlığına dahi gerek yoktur. Bu yüzden küçükler ve mümeyyiz olmayanlar bile sırf özellik taşıyan bir eserin yaratılmış olması sebebiyle *ipso jure* eser sahibi sayılırlar²³. Diğer taraftan eser sahipliği statüsünün kazanılması için, marka ve patent haklarında olduğu gibi fikir veya sanat ürününün herhangi bir makama sunulmasına, resmi bir mercide kayıt ve tesciline yahut bir berat veya lisans alınmasına da gerek yoktur²⁴.

Bir fikir ve sanat eserinin meydana gelmesi karşısında, fikri hakların sadece yaratma olgusuyla yaratan şahsa aslen kazandırılması²⁵, Alman hukuk doktrininde "*yaratma gerçeği ilkesi*" terimiyle anılmaktadır. Aynı ilke Fransız ve İsviçre hukukunda da benimsenmiştir²⁶.

Yaratma gerçeği ilkesi uyarınca eser sahibi olma, sadece gerçek şahıslar bakımından söz konusudur. Tüzel kişiler, organlarını oluşturan gerçek kişilerin irade ve fiilleri dışında eser yaratmaz ve dolayısıyla onun sahibi de olamazlar. Tüzel kişiler ancak bir hukuki işlem yapmak için organları vasıtasıyla iradelerini açıklayabilirler. Halbuki eser sahibi statüsünün ve eser üzerindeki hakların kazanılması için ne iradeye, ne de hukuki işlem yapmaya gerek vardır. İsviçre Federal Mahkemesi de İsviçre Telif Hakları Kanunu'nda hüküm bulunmamasına rağmen sadece gerçek kişilerin eser sahibi sayılabileceğini, tüzel kişilerin İsviçre Fikri Hukukuna göre eser sahibi olamayacaklarını hükme bağlamıştır²⁷.

Türk Hukukunda FSEK madde 8 ile; "*bir eserin sahibi onu meydana getirendir*" denilerek yaratma gerçeği ilkesi benimsenmiştir. Hukukumuzda eser sahipliği statüsünün aslen kazanılması, sadece yaratıcı eser sahiplerine özgü bir durumdur.

²² ÖZTRAK, age., s. 35.

²³ AYİTER, age., s. 90; TOPÇUOĞLU, age., s. 54; ARSLANLI, age., s. 62-63.

²⁴ EREL, age., s. 69 vd.

²⁵ Hakkın aslen kazanılması, başka bir şahıs yahut makamın izin veya aracılığına gerek kalmadan şahsın kendi irade ve fiili ile hak sahibi olmasıdır. Ancak eser üzerindeki hakların kazanılması bir hukuki işlemle değil, hukuki eylemle olduğundan, irade unsuru söz konusu olmayacaktır.

²⁶ Bkz. TROLLER, age., s. 693; AYİTER, age., s. 90.

²⁷ BGE 74, II, s. 112. vd.

C. BAĞLANTILI HAK ve KOMŞU HAK SAHIPLİĞİ

Müzik eserinin topluma sunulması için; besteci, aranjör ve söz yazarı olarak sayılan eser sahiplerinin yanı sıra çeşitli enstrümanları çalanlar veya şarkıcı/sanatçılar tarafından müziğin seslendirilmesi gerekmektedir. Bir müzik eserini yaygın olarak topluma sunmak için onu ürün haline getirmek ve bazı araçlarla dinlenmesini veya izlenmesini sağlamak da gerekir. Müzik yapımcıları ile radyo ve televizyon kuruluşları ve film yapımcıları; müzik eserlerini belli plak, cd, kaset, manyetik band veya bilgisayar ortamına kaydederek teyp, radyo, televizyon, cep telefonu, müzik çalar, sinema gibi iletim araçları ile topluma sunan kişi veya kuruluşlardır. Bu kişiler eser sahibi olmamakla birlikte, müzik eserini ortaya çıkarmak için eser sahibi olan besteci, aranjör ve söz yazarlarına olanak sağladıkları için ve müzik eserini ilk kez kayıt altına aldıkları için, esere komşu bazı haklara sahip olmaya değer bulunmuşlardır.

Bu kişilere kısaca bağlantılı hak sahipleri veya komşu hak sahipleri adını veririz.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ilke olarak fikirsel ve sanatsal yaratıcılığın ürünü olan eseri korur. Bununla birlikte, esere önemli şekilde katkı sayılabilecek fikirsel veya sanatsal emeğin korunmasının gerektiği haller mevcuttur.²⁸ Özellikle, bir eseri yorumlayıp icra ederek, onun değerini ortaya koyan, eseri belki de gerçek anlamda aleniyete kavuşturarak topluma mal olmasını sağlayan şarkıcı veya icracı sanatçıların, eserin toplumda yaygın şekilde dinlenip seyredilmesini sağlayacak ses ve görüntü tespitlerini veya kayıtlarını yapan yapımcıların ve nihayet yaptıkları yayınlarla eseri ülke çapında, hatta sınır ötesinde tanıtan radyo ve televizyon kuruluşlarının haklarının da fikri hukuk tarafından korunması gerektiği uygar dünyada kabul edilmektedir.²⁹ Eseri yaygınlaştırma araçlarına bilgisayarları, cep telefonlarını, mp3 ve mp4 çalarları, film oynatıcılarını, ipodları da dahil edebiliriz. Uluslararası Sözleşmeler ve Avrupa Birliği direktifleri işte benzer gerekçelerle bağlantılı hakların tanınması gereğini çeşitli biçimlerde dile getirmişlerdir.

Avrupa Birliği'nde bağlantılı haklara değinen 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı "*Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi*"nin

²⁸ AYİTER, age., s. 72-89; ARSLANLI, age., s. 49-60

²⁹ EREL, age., s. 163

girişinde; yeni yaratıcı sanat eserlerinin oluşturulma temeli olarak, eser sahiplerine ve icracılara ait yaratıcı sanat çalışmalarına yeterli gelir miktarı gerektiğinden, özellikle fonogram ve film yapımı için gereken yatırımlar, oldukça yüksek ve riskli olduğundan; bu gelirin korunma olasılığı ve söz konusu yatırımın karşılanmasının ilgili hak sahiplerinin yeterli yasal korunmaları ile etkin bir şekilde garanti edilebileceğinden; adı geçen yaratıcı, sanatsal ve girişimcilik gerektiren faaliyetler, büyük ölçüde serbest meslek sahiplerine ait olduğundan; bu nevi faaliyetlerin takibinin Topluluk içerisinde uyumlaştırılmış yasal koruma sağlayarak kolaylaştırılması gerektiğinden; özellikle bağlantılı hak sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik bir direktifin çıkarıldığı vurgulanmıştır.

22 Mayıs 2001 tarih ve 2001/29/AT sayılı “*Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi*”nde ise; bağlantılı hakların tanınması gerekçeleri şu şekilde sayılmıştır:

-Şu andaki telif hakları ve bağlantılı haklar ile ilgili varolan Hukuk’un, yeni işletme biçimleri gibi ekonomik gerçeklere yeterli karşılık olabilmesi için uyarlanması ve tamamlanması gerektiğinden,

- ...Avrupa bilgi toplumunun düzgün gelişmesini engelleyen, yasal belirsizliklere neden olan telif hakları ve bağlantılı haklara ilişkin ulusal hükümlerin düzeltilmesi ve teknolojik gelişmelere uyumsuz ulusal (iç hukuk) düzenlemelerinden kaçınılması gerektiğinden;

- Bilgi toplumunun çeşitli sosyal, toplumsal ve kültürel etkileri; ürünlerin ve hizmetlerin içeriklerinin özel niteliklerinin dikkate alınmasını gerektirdiğinden; bunlar fikri yaratım anlamında çok önemli olduklarından, telif hakları ve bağlantılı haklarda her uyumlaştırmanın yüksek seviyede bir korumayı temel alması gerektiğinden; bunların korunmasının eser sahiplerinin, icracı sanatçıların, yapımcıların, tüketicilerin, kültür, endüstri ve en geniş anlamda kamunun menfaatine olarak yaratıcılığın korunması ve geliştirilmesine yardım ettiğinden; bu yüzden fikri mülkiyet “mülkiyet hakkı”nın ayrılmaz bir parçası olarak tanındığından,

-Yazarlar ve icracı sanatçıların, yaratıcı ve artistik eserlerini sürdürmeleri gerektiğinden, eserlerinin kullanımı açısından yapımcıların da bu eserleri finanse edebilmek için uygun karşılık almaları zorunlu olduğundan; fonogram, film ya da multimedya ürünleri gibi ürünlerin ve erişim hizmetlerinin üretilmesi için gereken yatırım dikkate değer olduğundan; bu yatırımların tatmin edici bir şekilde geri dönüşleri için fırsat

temin etmek ve belirtilen karşılıklarını garanti etmek için fikri mülkiyet haklarının yasal olarak yeterli derecede korunması gerekli olduğundan;

- Titiz ve etkili bir “*telif hakları ve bağlantılı haklar koruma sistemi*”; Avrupa kültürel yaratıcılığının ve üreticiliğinin beslenmesini sağladığından ve sanatsal yaratıcıların ve icracı-sanatçıların bağımsızlığını ve onurunu koruyan ana yollardan biri olduğundan;

- Özellikle dijital ortamdan kaynaklanan gereklilikler ışığında, meslek birliklerinin rekabet kurallarına uymaları konusunda yüksek seviyede bir açıklık ve gerçekliği temin etmeleri gerekli olduğundan;

WIPO *İcralar ve Fonogramlar Andlaşması*’nın³⁰ girişinde de bu anlaşmaya taraf devletlerin;

-icracı sanatçılar ve fonogram yapımcılarının haklarının mümkün olduğunca etkili ve düzenli olarak korunmasını sürdürmeyi ve geliştirmeyi isteyerek,

-icra ve fonogramların yaratılması ve kullanımına ilişkin iletişim teknolojileri ve haberleşmenin gelişimindeki güçlü etkiyi bilerek,

-icracı sanatçılar ve fonogram yapımcılarının hakları ile, eğitim, araştırma ve bilgiye erişim hakkındaki geniş kamu yararı arasındaki dengeyi koruma gereksinimini bilerek

işbu Anlaşmayı imzaladıkları düzenlenmiştir.

Bağlantılı hakların niçin gerektiği hakkındaki bu açıklamalarımızdan sonra FSEK’in ilk maddesinden yararlanarak “*bağlantılı haklar*” ve içerdği bir başka kavram olan “*komşu haklar*” tanımlarına geçelim.

Bağlantılı haklar; *eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları haklar* demektir.

Komşu haklar ise; *eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radio-televizyon kuruluşlarının sahip oldukları hakları* ifade eder.

³⁰ Bu anlaşma TBMM tarafından 02.05.2007 tarihinde 5646 sayılı Kanun ile kabul edilmiştir.

16.11.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği”nin 4. maddesinde de komşu hak, “*eser sahibinin haklarına zarar vermeden ve onun rızası ile bir eseri özgün biçimde icra eden veya icrasına katılan, bir icrayı ya da sesleri ilk defa tespit eden, yayınlayan gerçek ve tüzel kişilerin münhasıran sahip oldukları; icrayı tespit etme, çoğaltma, kiralama, telli-telsiz her türlü araçla yayınlama ve kamuya açık yerlerde temsil suretiyle bundan faydalanma hakları*” olarak tanımlanmıştır.

Fikri hukukta “*komşu hak*” deyimi fikir haklarına yakınlık gösteren, benzer yahut komşu kabul edilen bazı hak konuları düşünülerek yakın bir geçmişte benimsemiş ve *icracı sanatçıların, plâk yapımcılarının ve radyo-televizyon kuruluşlarının kendi ürünleri üzerindeki haklarını* ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Bu ürünlerle eser arasında, eser üzerindeki haklar saklı kalmak üzere bir bağlantı kurulmuş ve komşu hak sahiplerine kendi ürünlerinden başkalarının yararlanması konusunda izin verme veya bu kullanımı yasaklama yahut önleme hakkı tanınmıştır.³¹

İcracı sanatçıların, plâk (kaset, cd vs) yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşlarının kendi ürünleri üzerindeki haklarının fikri hukuk açısından birlikte düşünülerek korunmalarının sebebi, bunlar arasında uygulamada yakın bir ilişkinin bulunmasıdır. Plâğa (kasete, cd’ye veya bilgi işlem ortamına) alınmış bir icranın radyo ve televizyonlarda (yada internette) yayınlaması gibi günlük hayatta sık rastlanan bir durum, bu hak kategorileri arasındaki yakın ilgi ve ilişkiye örnektir.³²

Bağlantılı hakların korunmasına ilişkin ilk yasal düzenlemeler, geçen yüzyılın başlarında ortaya çıkmaya başlamıştır. 1901 tarihli Alman Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 1910 yılında yapılan değişiklikle, bir sanatçının musiki veya edebiyat eserinin yorum ve icracısının tespitinde kullandığı vasıtalar, söz konusu eserin işlenmesi olarak mütalaa edilmiş ve icracı sanatçı da bu eserin işleyeni olarak nitelendirilmiştir. Almanyadaki bu uygulamayı zamanla diğer ülkeler de takip ederek, bağlantılı haklara fikri hukuk koruması tanımaya başlamışlardır.³³

³¹ Bu alanda uluslararası mevzuattaki gelişim süreci hakkında geniş bilgi için bkz. C. Bülent TURHAN, *Fikri Hakların Uluslararası Boyutu ve Türkiye’de Yapılan Mevzuat Uyum Çalışmaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1996, s. 16 vd.*

³² EREL, age., s. 164

³³ ATEŞ, age., s. 201

Komşu haklar ilk kez 1926 yılında Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından ele alınmıştır. Bern Birliği, ILO ve UNESCO'nun yoğun çalışmaları sonucunda, 1959 yılında hükümetler arası diplomatik toplantıda komşu hakların korunması alanında somut sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Nihayet, 1960 yılında Lahey'de çalışmalara başlayan uzmanların gayretleriyle, bütün komşu hak kategorilerini korumayı amaçlayan bir sözleşme tasarı metni ortaya çıkmıştır. *Roma Sözleşmesi* olacak bu tasarı, aynı yıl Roma'da toplanan 39 devletin temsilcileri tarafından müzakere edilmiş ve katılımcı ülkelerden 18'i tarafından 1961 yılında imzalanarak, 18 Mayıs 1964 tarihinde yürürlüğe konulabilmiştir. Sözleşmeye katılım, Bern Sözleşmesi ve Evrensel Fikri Haklar Sözleşmesi'ne taraf olan tüm ülkelere açıktır. 15 Temmuz 2001 tarihine dek 68 ülkenin katıldığı *Roma Sözleşmesi*'ni ülkemiz 1995 yılında onaylamıştır.³⁴

Daha sonra fonogram yapımcılarının haklarının uluslararası alanda korunması amacıyla, 32 devletin iştirakiyle 1971 yılında Cenevre'de bir sözleşme imzalanmıştır. 15 Temmuz 2001 tarihine kadar 67 ülkenin katılmış olduğu *Fonogram Yapımcıları Hakkında Cenevre Sözleşmesi*'ne, Türkiye henüz katılmamıştır.³⁵

UNESCO ve WIPO'nun gözetiminde, çeşitli ülkeler 21 Mayıs 1974 tarihinde Brüksel'de yapılan diplomatik konferansta biraraya geleerek "*Uyduyla Nakledilen Program Taşıyıcı Sinyallerin Dağıtımına Dair Sözleşme*"yi imzalamışlardır. Türkiye'nin henüz iştirak etmediği bu sözleşmeye, 15 Temmuz 2001 tarihine kadar katılan üye ülke sayısı 24'e ulaşmış bulunmaktadır.³⁶

Ülkemizin de taraf olduğu *TRIPS Anlaşması*, bağlantılı hakların himayesine dair hükümler içeren uluslararası bir başka metindir.

Bu alanda en son anlaşılan ve önemli ilkeler içeren bir düzenleme ise, 1996 tarihli *WIPO Fikri Haklar Anlaşması*'dır. Bu anlaşma, komşu haklara karşı elektronik araç ve yöntemlerle yapılacak ihlallerin önlenmesine ilişkin hükümler koymasıyla önemlidir. WIPO, 1996 yılında *Fikri Haklar Anlaşması*'ndan başka, haberleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişimin icra ve fonogramlar üzerindeki güçlü etkisini

³⁴ ATEŞ, *age.*, s. 203

³⁵ ATEŞ, *age.*, s. 203

³⁶ ATEŞ, *age.*, s. 206

dikkate alarak, icracı sanatçılar ile fonogram yapımcılarının haklarına ilişkin ikinci bir anlaşmayı da karara bağlamıştır. 20.12.1996 tarihinde Cenevre’de sonuçlanan ve WIPO merkez bürolarında katılımcıların imzasına açılan *WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması*, 30 Temmuz 2001 tarihine kadar 50 ülke tarafından imzalanmış ve Temmuz 2002’ye kadar da 34 ülke tarafından onaylanmış bulunmaktadır. 20 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan anlaşmaya katılım, *WIPO Fikri Haklar Anlaşması* gibi, kural olarak, sadece WIPO’ya üye ülkeler ve Avrupa Birliği ülkelerine açıktır.³⁷

Bu düzenlemeler dışında, Avrupa Konseyi de özellikle televizyon yayıncılığı alanında aşağıdaki bazı düzenlemeleri yapmıştır.³⁸ Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949 tarihinde on kadar Avrupa ülkesinin katılımıyla kurulan bir uluslararası organizasyondur. Türkiye’nin 8 Ağustos 1949’da katıldığı örgüte Batı Avrupa ülkelerinin tümü değişik tarihlerde dahil olmuştur.³⁹

1. Televizyon Filmleri Vasıtasıyla Program Değişimine Dair Avrupa Anlaşması

Bu anlaşma, 1958 yılında Paris’te imzalanmıştır. Anlaşmaya Ülke-miz 27 Şubat 1964 tarihinde katılmıştır. Anlaşmanın amacı, uluslararası değişime konu olan sinema eserleri ve televizyon programlarının eser sahipliği ile ilgili olarak, ulusal hukuk sistemleri arasındaki düzenleme farklılıklarından kaynaklanan sorunları gidermektir.⁴⁰

2. Televizyon Yayınlarının Korunması Hakkında Avrupa Anlaşması

1960’ta imzalanmış olan bu anlaşma da yukarıda sözü edilen anlaşma ile aynı amacı taşımaktadır; ancak kapsam olarak ondan daha geniştir. İmzalandığı sırada konuyu daha ayrıntılı olarak düzenlemeyi amaçlayan Roma Sözleşmesi henüz müzakere aşamasında olduğu için, anlaşmanın 13’üncü maddesinde, televizyon yayınlarının korunmasını da içeren müstakbel (Roma) Sözleşme yürürlüğe girdiğinde, bu anlaşmanın yürürlükten kalkması öngörülmüştür.

³⁷ ATEŞ, *age.*, s. 204

³⁸ ATEŞ, *age.*, s. 201 –202

³⁹ ATEŞ, *age.*, s. 207

⁴⁰ ATEŞ, *age.*, s. 208

3. Korsan Yayınların Engellenmesine Dair Avrupa Anlaşması

22 Ocak 1965 tarihinde Strasburg'da imzalanan bu anlaşma, yayıncılıkla ilgili diğer Avrupa anlaşmaları gibi, Avrupa Konseyi'nin gözetiminde gerçekleştirilmiştir. 1993 yılına kadar 17 ülkenin katıldığı anlaşmaya Ülkemiz 1975 yılında taraf olmuştur. Anlaşmanın kapsamı 1'inci maddesinde; *“ulusal sınırlar dışındaki gemiler veya uçakların bordolarına, ulusal hava sahası dışındaki hava sahalarında dolaşan sair cisimler üzerine monte edilen radyo istasyonları üzerinden sürdürülen yayınların menedilmesinin düzenlenmesi”* şeklinde belirlenmiştir.

4. Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi

Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, 5 Mayıs 1989 tarihinde Strazburg'da Avrupa Konseyi üyesi ülkeler ile Avrupa Kültür Sözleşmesi'ne taraf ülkeler arasında imzalanmış, 1993'te Türkiye tarafından onaylanmış bulunmaktadır. Sözleşmenin amacı, televizyon program hizmetleri alanında topluma daha geniş bir tercih alanı sunmak, Avrupa kültür mirasını ve bu mirasın görsel, işitsel eserlerini geliştirmek, kültürel amaçların gerçekleştirilebilmesi için kaliteli programların üretimi ve dağıtımını yapmak, radyo ve televizyon alanında uydu kapasitesinin kullanımını artırmak gibi hedeflerin gerçekleştirilmesidir.⁴¹

Komşu hak kavramı ve bunun düzenlenmesi pozitif hukukumuzda ilk defa FSEK madde 80, 81 ve 82 hükümlerinde 7.6.1995 tarihli ve 4110 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu girmiştir. Yine FSEK madde 80/I hükmüne göre; *“Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarının aşağıda belirtilen komşu hakları vardır.”* Ayrıca madde 82 hükmüne göre, *“Bu Kanunun bağlantılı haklarla ilgili hükümleri, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu bir uluslararası andlaşma hükümlerine göre korunan icracı sanatçılara, yapımcılara ve radyo-televizyon kuruluşlarına da uygulanır.”*

1997 tarihinde çıkarılan *“Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği”*⁴²ne göre de komşu hak; *“eser sahibinin haklarına zarar*

⁴¹ ATEŞ, age., s. 208 - 210

⁴² Resmi Gazete 16 Kasım 1997, sayı 23172

vermeden ve onun rızası ile bir eseri özgün biçimde icra eden veya icrasına katılan, bir icrayı ya da sesleri ilk defa tespit eden, yayınlayan gerçek ve tüzel kişilerin münhasıran sahip oldukları; icrayı tespit etme, çoğaltma, kiralama, telli-telsiz her türlü araçla yayınlama ve kamuya açık yerlerde temsil suretiyle bundan faydalanma haklarını” ifade eder.⁴³

Komşu haklar bazı sınırlamalara tabi tutulmuştur. Eser üzerindeki fikri hakların çeşitli sebeplerle sınırlandırıldığı hallerde, bu fikri haklarla ilgili olan komşu haklar da doğal olarak sınırlandırılmış olur ve artık bu hakların kullanılması için komşu hak sahibinin izni gerekmez. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda ve 1997 tarihli “*Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği*” madde 24 hükmünde, fikri haklar ve komşu haklara getirilen bu sınırlamalar sıralanmaktadır: Buna göre, *aile çevresinde gerçekleştirilen özel ve ücretsiz icralar; özel kullanım için hazırlanmış ve herhangi bir ortak kullanım amacı taşımayan çoğaltmalar ve evde yapılan kayıtlar; eserin tanıtımı ya da bilimsel araştırma amacıyla yapılan analizler; güncel bilgilendirme amaçlı olarak toplanılarda yapılan sunuşlar ve konuşmalar; yayın kuruluşlarının haber verme bilgilendirme amaçlı kullanımı; eser sahibinin ve komşu hak sahibinin şeref, ve kişilik haklarını zedelemeyecek, türünün kurallarına uyan parodi ve karikatürleri; fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ya da röportaj amacıyla icra edilmesi hallerinde, komşu hak sahibinin izni gerekmeyecektir.⁴⁴*

⁴³ EREL, age., s. 164

⁴⁴ EREL, age., s. 165

V. MÜZİK ESERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Fikir ve sanat eserleri konusunda her ülke kendi kültür ve hukuk anlayışı çerçevesinde eser sahiplerine bazı haklar tanımış ve bunları iç hukuk kuralları olarak belirlemiştir. Ancak fikir ve sanat eserlerinin ülke sınırlarını aşarak diğer ülkelerde yaşayan insanlar tarafından da sevilmesi, yararlı bulunması ve kullanılması sebebiyle ülkesel düzenlemeler yeterli olmamış; eser sahiplerinin haklarının ülke dışında, diğer ülkelerde de korunması gerekmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar 1883 yılında Paris Sözleşmesi'ni ve 1886 yılında bu Sözleşmenin geliştirildiği *Bern Sözleşmesi*'ni ortaya çıkarmıştır. Bern Sözleşmesi'ni imzalayan ülkeler, Sözleşmedeki kuralları kendi ülkeleri için **“asgari hukuki koruma kuralları”** olarak belirlemiş ve iç hukuklarına bu asgari kuralları mutlaka almıştır. Kültür ve hukuk düzenlerindeki farklar sebebiyle bazı ülkeler Bern Sözleşmesi'ndeki bu asgari kurallarla yetinmeyip, ülkelelerinde eser sahiplerine Bern Sözleşmesi'nde belirtilenlerden daha geniş haklar tanımışlardır. Zaten Bern Sözleşmesi de bunu amaçlamıştır. Bern Sözleşmesi'nin 19. maddesi, fiktisel ve sanatsal haklar açısından **“bu Sözleşme hükümleri, Birlik ülkeleri mevzuatı ile tanınan daha geniş bir korumadan yararlanma isteğine engel oluşturmaz”** ve 20. maddesi **“Birlik ülkelerinin hükümetleri, aralarında eser sahiplerine bu Sözleşme ile tanınan haklardan daha geniş haklar veren veya bu Sözleşmeye aykırı hükümler içermeyen özel anlaşmalar yapma hakkını saklı tutarlar”** diyerek bu amacı açıkça ortaya koymuştur.

Sözleşmelerle sadece olmazsa olmaz asgari kuralları koyma amacı; Bern Sözleşmesi'nden sonra hazırlanan Roma Sözleşmesi, WIPO Sözleşmeleri ve AB direktiflerinin hepsinde sürdürülmektedir.

İşte Bern Sözleşmesi'ne uygun hazırlanan bizim Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'muz; daha sonra ortaya çıkan uluslararası hukuk sözleşme ve kurallarındaki gelişmeler paralelinde asgari koruma yanında, ayrıca ülkemizdeki fikir ve sanat eserleri üretimini teşvik etmek ve yaygın olan ihlalleri önlemek için daha geniş hukuki koruma kurallarını ve hakları eser ve diğer hak sahiplerine tanımıştır.

Aslında, FSEK doğrudan ne eser sahibini ne de eseri korumaktadır. Korunan sadece belli bir eser bağlamında eser sahibinin mali ve manevi menfaatleridir.¹ Bu ilke FSEK madde 13’de yer almaktadır. Bahsi geçen bu hüküm *“fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri Kanun dairesinde himaye görür”* şeklinde düzenlenmektedir. Buradan çıkan anlam şudur: FSEK, eser üzerindeki hakları manevi ve mali haklar olarak ayırmış ve devamı maddelerinde bunları sınırlayıcı bir biçimde sayarak düzenlemiştir. AYİTER ve EREL, yapılan bu ayrımı yapay bulmaktadırlar ve aslında mali ve manevi hakların birbirlerine sıkı şekilde bağlı olduğunu savunmaktadırlar. Bu görüş; *“mali haklardan olan eseri yayma hakkının kullanılabilmesi, bir manevi hak olan eseri kamuya sunma (umuma arz) yetkisi bulunmadan mümkün değildir. Keza eserin kamuya sunulmasında eser sahibinin adının açıklanma(ma)sı veya eserin bozulup değiştirilmesi, eser sahibinin manevi olduğu kadar mali çıkarlarını da zedeler”*² şeklinde ifade edilmektedir. Nitekim bir müzik eserinin, Kanundaki “haber verme” gibi istisnalar dışında, müzik eseri sahibinin izni olmadan bir yayın organında yayınlanması, bir radyo veya televizyon programında sunulması, internette yayınlanması hem müzik eseri sahibinin kamuya sunma yetkisine (manevi hakkına) hem de eseri yayma ve umuma iletim haklarına (mali haklarına) saldırı oluşturmaktadır.

Manevi ve mali hakların gruplar halinde ve sınırlayıcı olarak sayılması bazı faydalar ve sakıncalar taşımaktadır. Sayılan hakların nitelik ve kapsamının etraflıca düzenlenebilmesinin faydası, bunlara yapılacak tecavüzlerin açık olarak tespiti olanağıdır. Sakıncası ise, teknik gelişmeler sonucu eserden yeni yararlanma olanakları doğması halinde, eser sahibinin bunlar üzerinde bir hak iddia edememesi ve başkalarının bu yoldan eserinden yararlanmalarına engel olamamasıdır³.

Modern bazı kanunlar, Fransız ve Alman kanunları; eser üzerindeki yetkileri sınırlayıcı bir biçimde saymak yerine, eser sahibinin tek ve kapsamlı bir hakkı olduğunu kabul etmişlerdir. Bern Sözleşmesi de, mali ve manevi haklar arasında bir ayrım yapmamakta ve mükerrer 6. maddesi ile mali ve manevi haklar kategorileri arasında ilişkiyi *“eser sahibinin haiz olduğu mali haklardan müstakil olarak ve bu hakların devrin-*

¹ TEKİNALP, age., s. 145.

² AYİTER, age., s. 99 Naklen EREL, age., s. 76.

³ ARSLANLI, age., s. 79 Naklen EREL, age., s. 111.

den sonra dahi eserin kendi eseri olduğunu beyan etmek ve bu eserin kendi şeref ve şöhretine zarar verecek her türlü bozuluşuna, parçalanışına ve herhangi bir şekilde değişikliğe uğratılmasına muhalefet etmek hakkını bütün hayatı boyunca muhafaza eder”⁴ şeklinde ifade etmektedir.

Hukuk düzeni, eserin meydana gelmesiyle birlikte eser sahibine manevi ve mali haklar vererek, bunları korumaktadır. Eser üzerindeki her türlü manevi ve mali hakkın doğumu için sadece bir eserin yaratılmış olması yeterli olmaktadır.

Ancak bu şekilde doğan hakların eser sahibi tarafından bizzat kullanılabilmesi bakımından, manevi ve mali haklar arasında bir ayırım yapılmalıdır⁵. Manevi hakların kişilik haklarıyla olan ilgisini göz önüne alan kanun koyucu, bu hakların kullanılmasında eser sahibinin temyiz kudreti (ayırt edebilme gücü)⁶ olmasını yeterli görmekte ve FSEK madde 18/ son cümleye göre, temyiz kudreti olan küçüklerle, mahcurların manevi hakları kullanmakta kanuni temsilcilerinin rızasına dahi muhtaç olmadıklarını belirtmektedir. Bu hüküm, kişilik haklarının kullanılmasına ilişkin Medeni Kanun madde 16/II hükmüne paraleldir. Buna karşılık mali haklar, malvarlığına ilişkin haklar oldukları için, bunların eser sahibi tarafından kullanılması olağan ehliyet şartlarına tabidir.⁷

Manevi haklar, doğrudan eser sahibinin kişiliğine bağlıdır. FSEK madde 18’e göre, eser sahibi gerçek kişiye yaşadığı sürece, tüzel kişi ise tüzel kişilik devam ettiği müddetçe madde 14, 15 ve 16 uyarınca sahip olduğu manevi hakları kullanır. Eser sahibi mali hakları devretmiş bile olsa manevi hakları kullanmaya devam eder ve bu haklara bir saldırı varsa dava açabilir. Bu konuda bir kararı dikkatinize sunuyoruz:

“Davalı şirketçe ibraz edilen ve içeriği aynen belirtilen devir belgesine göre, davacı taraf, dava konusu olan “E....” adlı şiiri tüm mali hakları ile süresiz olarak devir ve temlik etmiştir. Bu durumda, davalı Şirket en geniş biçimde bu hakları kullanabilir. Ve başkalarına da devir edebilir hakka sahip olmuştur. Hal böyle

⁴ Bu hüküm Sözleşmenin Paris değişikliği madde 6 bis (1)’de de aynen tekrarlanmaktadır.

⁵ EREL, age., s. 112.

⁶ Ayırt Etme Gücü Olanlar (MK madde 13): Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, Türk Medeni Kanununa göre ayırt etme gücüne sahiptir.

⁷ EREL, age., s. 112.

olunca, davacının E... adlı şiir için hiçbir mali hakkı kalmadığı sonucuna varılmıştır. ...

Ancak, **davacının manevi hakları devir etmediği anlaşılmıştır.** Bu nedenle davacının manevi hakları yönünden ileri sürdüğü tüm iddiaların ve özellikle **eser sahibinin adının gösterilmemesi ve eserin şeref ve itibarının düşürüldüğü hususları üzerinde durulması gerekir.** Davacının manevi haklar yönünden ileri sürdüğü iddialarının esastan incelenmesi gerektiğinden ve bu konu bir uzmanlığı da gerektirdiğinden, tarafların başkaca delilleri var ise ibraz olanağının sağlanması ve uzman bilirkişi kurulundan rapor alınması ve hasil olacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, bu hususun gerekçesiz biçimde değerlendirilmesi doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir⁸...”

Eser sahibinin manevi hakları sınırlı sayılma prensibine göre şu şekilde sıralanabilmektedir:

- a. Eseri umuma arz (kamuya sunma) yetkisi
- b. Adın belirtilmesi yetkisi
- c. Eserde değişiklik yapılmasını önleme yetkisi
- d. Eserin aslına ulaşabilme yetkisi

Bu sayılan haklar kişiliğe bağlı oldukları için mirasa konu olmamaktadırlar. Ancak FSEK madde 19’da belirtildiği gibi eser sahibinin yakınları⁹, mali hakları devralanlar ya da lisans alanlar veya gereğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kullanılabilirler. Buna göre; ilk olarak, eser sahibinin yakınları bu hakları kullanabilirler. Bunlar

⁸ Yargıtay 11. H.D., 12.12.1995, E. 1995/6393, K. 1995/9199.

⁹ 11. H.D., 22.12.2005, E. 2004/14950, K. 2005/12769; “Davacılar murisi oldukları eserin, izinleri olmadan, davalı yayıncı şirket tarafından yayınladığını belirterek, maddi ve manevi tazminat ve verilecek kararın gazetede ilanını talep etmişlerdir. Bunun neticesinde Yargıtay’a intikal eden olayda şu sonuca varılmıştır; 5846 sayılı FSEK’in 63. maddesi gereğince, bu Kanun ile tanınan mali haklar miras yolu ile intikal etmektedir. Eser sahibinin aynı Kanun’dan doğan manevi hakları ise ölümü halinde mirasçılara intikal etmemekle birlikte, eser sahibinin ölümünden sonra manevi hakları kullanabilecek olanlar; tayin edilmişse vasiyeti tenfiz memuru, tayin edilmemişse sağ kalan eşi, çocukları, mansup mirasçıları, ana babası ve kardeşidir. Görülen davada, işleme eser sahibinin mirasçısı olan davalıların isteminin, eserin davalı şirket tarafından izinsiz olarak umuma arzı nedeniyle FSEK’in 14. maddesi yoluyla aynı Yasa’nın 70/1. maddesine dayalı manevi hak tazminatı olduğuna göre, FSEK’in 19/1. maddesi uyarınca davacıların tazminat talep etme hakları olamayacağı için istem reddedilmiştir.” (YKD., Cilt: 32, Sayı: 4, Nisan 2006). Görüldüğü gibi sayılan kişilerin eserin manevi hakları açısından kötü kullanımları engelleme yetkileri olmakla beraber tazminat hakkı yoktur.

kullanmazlarsa ikinci olarak, eser sahibinden veya halefinden mali hakları iktisap edenler kullanabilirler. Üçüncü olarak ise; bazı şartların varlığı halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı da manevi hakları kullanabilir.

Aşağıdaki kararda mali hakları devralanların manevi hakları kullanma açısından dava açabileceklerini görüyoruz.

“Metni yukarıya aynen derç’edilen temliknamenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, **merhum bestekar S.A., temliknamede isimleri yazılı sekiz eseri üzerindeki telif hakkını, hiçbir ayırma, tabi tutmadan, diğer bir deyişle, hem maddi (mali) ve hem de manevi telif hakkını birlikte, davacıya temlik etmiş bulunmaktadır. Bu husus temliknamede yer alan, (...telif haklarımı) cemi edatı kullanılmış olması ile, yine aynı temliknamedeki, (...artık bu eserlerde benim hiçbir hakkım ve alakam kalmayıp bütün bunlar bayan S.A.T.’nin mülkiyetine geçmiştir), cümlesinden kesinlikle anlaşılmaktadır. Her ne kadar, kaideten manevi tazminat talep ve dava hakkı, mağdurun veresesine (MK. madde 85/f. 2’de olduğu gibi) veya manevi tazminatın isteğine dayanak yapılan bir hakkı temellük edene intikal etmesi mümkün değil ise de, bütün Türk hukukçuları ile yabancı hukukçuların da ittifakla belirttikleri üzere, şayet; mağdur manevi tazminat talep hakkını ilerde de arama arzu ve iradesini temliknamede izhar etmiş veya o hakkın aranmasına bir kanun hükmü imkan tanımış (BK. madde 162/f. I) veya işin mahiyeti buna mani değil ise, o zaman, manevi tazminat isteğinin de, temellük eden kimseye intikal ettiğinin kabulü icap eder (Dr. Nisim Franko, Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararın Tazmini, Ank, 1973, Sh. 210 221), (Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay, Borçlar Hukuku, İst. 1979/4. Bası. Sh. 216 219), (Prof. Dr. Kenan Tunçomağ, Borçlar Hukuku, C. 1. Genel Hükümler, İst. 1972, 5. Bası, Sh. 650 ve müteakip), (Andreas von Tuhr, Borçlar Hukuku, Cevat Edege Tercümesi, Yargıtay Yayını- No:15, Ankara - 1983, Sh. 117 ve müteakip), (Dr. H. Oser Dr. W. Schönerberger Borçlar Hukuku, Dr. Recai Seçkin Tercümesi, Ank. 1947, Sh. 968 ve müteakip). İsviçre Federal Mahkemesi de manevi tazminat taleplerinin devir ve temlikini mümkün görmüştür. BGE 95. II 481 jdt 1971 1 226 Prof. Dr. S. Sulhi Tekinay, age., s. 218. Dip Not. 7. bkz.).**

5846 sayılı (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) nun 14-19. maddeleri hükümleri, hem (manevi hakları) kimlerin isteyebileceğini ve hem de hangi hallerde (manevi tazminat) istenebileceğini ayrı ayrı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Kanun koyucu, adı geçen Kanunun 16/f. 2. hükmü ile bir eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değişikliği, o eser yönünden, manevi tazminat talebi için yeterli bir davranış saydığı gibi, diğer taraftan, **eser sahibinin ölümünden sonra kimlerin “manevi tazminat” isteyebileceklerini de aynı Kanunun 19. maddesi hükmünde belirtmiş bulunmaktadır.** Davacı-

nın, temellük eden kimse olarak, gerek BK'nun 162 ve 168. maddeleri hükümlerine göre, kendisine yapılan temlik sonucu ve (işin mahiyeti) icabı olarak manevi tazminat talebine hakkı bulunduğu gibi, ayrıca da **Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 19. maddesi hükmünden kaynaklanan (halefiyet) nedeniyle de, keza, "manevi tazminat" talebine hakkı bulunmaktadır.** Doktrin de aynı görüştedir. **Manevi hakların çoğunun kullanılması, mali hakların kullanılmasıyla yakın bir bağlantı gösterir, bu itibarla, manevi haklar, ölümle sona eren "şahsiyet" haklarından farklı olarak, en az mali haklar devam ettiği sürece devam eder. Binaenaleyh, mali bir hakkı devir alan kimserin de eser sahibinin ölümünden sonra manevi hakları kullanabilme yetkisine sahip olduğunun kabulü icap eder. Esasen, mali haklarla manevi haklar arasındaki ayrım sun'i bir ayrımdır, mali hakların da kullanılmasını kapsar¹⁰.**

Eser sahipleri veya onun adına hareket eden diğer yetkililer; eserin izni dışında umuma sunulmasına, eserin bozulmasına ve değiştirilmesine, eser sahibinin adının koyulmamasına, eserin aslına ulaşılamamasına karşı; tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i, tazminat ve ceza davalarıyla korunmuştur.

Mali haklar ise; eserden ekonomik olarak yararlanma ve bunun şeklini belirleme olanağını tek başına ve sadece eser sahibine veren, eser sahibi eserden üçüncü kişilerin izinsiz yararlanmalarına engel olma yetkilerini tanıyan mutlak haklardır. Eserden ekonomik yarar sağlanabilmesi için onun ekonomik yönden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu özelliklere sahip ve Kanun'da sınırlı sayı prensibi çerçevesinde sayılmış mali haklar şu şekilde sıralanmaktadır:

- a. İşleme Hakkı
- b. Çoğaltma Hakkı
- c. Yayma Hakkı
- d. Temsil Hakkı
- e. Umuma İletim Hakkı
- f. Pay Alma (İzleme) Hakkı

Her ne kadar FSEK madde 20 mali hakları türleri itibariyle sınırlandırmışsa da, bu hüküm mali hakların yararlanma şekli/biçimi bakımından bölünmesine engel değildir¹¹. Bir mali hakkın konusunu teşkil eden yararlanma şekilleri teknik gelişmelere göre değişebilir veya

¹⁰ HGK., 11.2.1983, E. 4-70, K.123.

¹¹ ARSLANLI, age., s. 172, EREL, age., s. 114

genişleyebilir.¹² Örneğin umuma iletim mali hakkı açısından baktığımızda, bir müzik eserinin bir radyoda yayınlanarak umuma iletilmesi yararlanma biçiminin yanı sıra gelişen teknoloji neticesinde internette web sitelerinde yayınlanma yararlanma biçimi ortaya çıkmıştır. Çoğaltma mali hakkı açısından baktığımızda, cd veya kasede kopyalanan müzik eserleri artık bilgisayarlar veya bilgi işleme ve gönderme işlevine sahip cep telefonlarıyla çoğaltılmaktadır ve bu yeni bir yararlanma biçimidir.

Manevi hakların aksine mali haklar, eser sahibinin malvarlığından tamamen çıkacak şekilde tasarruf ve devir edilebilir. Ayrıca manevi haklarda olduğu gibi, mali haklar hakkında sadece kullanılması açısından yetki verilmesi de mümkündür; bu yetki verme işi FSEK madde 48/I ve II'de açıklanan lisans sözleşmesi niteliğindeki ruhsat verme yoluyla olur¹³. Mali hakların devri ve lisans verilmesi ileride ayrıntılı olarak incelenecektir.

Mali bir hakkın anlaşılan sürede veya uygun bir süre içinde kullanılmaması halinde, çıkarları zarar gören eser sahibi, FSEK madde 58 gereğince sözleşmeden cayabilir. Mali haklara ilişkin bu "*cayma hakkı*" da eser sahibinin manevi haklarından ve manevi hakları kullanma yetkisinin geri alınması hususundaki FSEK madde 14/III hükmüne paraleldir. Gerçi Kanun sırf mali hakkın kullanılmamasından bahsetmekte ise de mali haklarla manevi haklar birbirine bağlı olduğundan, mali hakkın kullanılmaması aynı zamanda manevi hakka da tecavüz teşkil eder¹⁴. Cayma hakkından önceden vazgeçilemez, ancak cayma hakkından hakkın doğumundan sonra vazgeçmek mümkündür. Keza FSEK madde 58/son fıkraya göre, cayma hakkının kullanılması sözleşmeyle iki yıla kadar ertelenebilir.

Tüm bu açıklamalar ışığında doktrinde varılan nokta olarak, eser sahibine tanınan mali ve manevi hakların olumlu (izin verme) ve olumsuz (yasaklama yetkisi) olmak üzere iki ayrı yönü bulunduğunu söyleyebiliriz. Olumlu yönü; kanunen eser sahibine verilen hakların ancak eser sahibi veya onun izin verdiği kimselerce kullanabilmesidir. Örneğin bir müzik eserinin çoğaltılabilmesi için eser sahibinin izni gerekmektedir. Olumsuz yönü ise; eser sahibinin, elindeki hak ve yetkilerle eserlerin izinsiz olarak kullanılmasını engelleyebilmesidir. Örneğin bir besteciye

¹² EREL, age., s. 114

¹³ ARSLANLI, age., s. 172 vd.; AYİTER, age., s. 206 vd. Naklen EREL, age., s. 114

¹⁴ ARSLANLI, age., s. 82-83; AYİTER, age., s. 219-220 Naklen EREL, age., s. 114

ait müzik eserinin, izinsiz olarak şarkıcı/ sanatçı tarafından icra edilmesi halinde eser sahibi besteci, izni olmadığı için mahkemeden tedbir koydurarak şarkıcının bu şarkıları söylemesini engelleyebilmektedir.

Şimdi müzik eserleriyle ilgili mali ve manevi hakları Yargıtay kararları ışığında tek tek inceleyelim.

A. MÜZİK ESERİ SAHİPLERİNİN MANEVİ HAKLARI

1. Eseri Umuma Arz Yetkisi

Bern Sözleşmesi'nin 11. maddesi, *“Dramatik, dramatik-müzik ve müzik eserlerinin sahipleri:*

Eserlerinin her türlü yöntem ve araçla toplum önünde icrasına;

Eserlerinin toplum önündeki icrasının her türlü iletimine izin verme hususunda inhisari hak sahibidirler.

Dramatik veya dramatik müzik eserlerinin sahipleri, özgün eserleri üzerindeki haklarının devamı süresince, bu eserlerin çevirileri üzerinde de aynı haklardan yararlanırlar” şeklinde düzenlenmiştir.

FSEK madde 14 uyarınca; *“bir eserin umuma arz edilip edilmemesi, yayımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tayin etmektedir. Bütünü veya esaslı bir kısmı âlenileşmemiş olan, yahut ana hatları herhangi bir suretle henüz umuma tanıtılmayan bir eserin muhtevası hakkında ancak o eserin sahibi malûmat verebilir. Eserin umuma arz edilmesi veya yayımlanma tarzı, sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette ise eser sahibi, başkasına yazılı izin vermiş olsa bile eserin gerek aslının, gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılması veya yayımlanmasını menedebilir. Menetme yetkisinden sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür. Diğer tarafın tazminat hakkı saklıdır.”*

Bu hükmü dikkate aldığımızda, umuma arzın (kamuya sunmanın); eserin sahibinin kontrolünden yani fiili hakimiyetinden çıkacak şekilde ilk defa üçüncü kişilere açıklanması ve eserin ilgililere sunulması olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak bu üçüncü kişiler eser sahibinin aile ve yakınları dışındaki kişiler olarak algılanmalıdır.

Müzik eseri sahibi müzik eserini ne zaman isterse o zaman ilk defa kamuya açıklayabilir. Müzik eseri sahibi özel bir yetki veya izin vermedikçe hiç kimse, bütünü veya bir kısmı sunulmamış eser hakkında üçüncü kişilere bilgi veremez, açıklama yapamaz. Bu kurala aykırılık, çoğunlukla bir yapımcı, bir menejer veya o eseri icra etmeye hazırlanan

bir şarkı yorumcusu tarafından, katılınan bir televizyon röportajında veya bir basın toplantısında gerçekleştirilmektedir.

Eğer eserin bütünü veya önemli bir kısmı daha önce kamuya sunulmuşsa, yahut ana hatları herhangi bir şekilde kamuya sunulmuşsa veya eser sahibi eserin kamuya sunulması konusunda izin vermişse, eserin ne olduğu hakkında yapımcı veya yorum yapacak icracı sanatçı üçüncü kişilere bilgi verebilir. Mesela bir milli marş veya Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmak için bir sanatçıya eser siparişi verilebilir. Bu eser hakkında eser sahibi dışındaki kimseler, eser henüz kamuya sunulmadan önce “eser hüznü bir eserdir, batı sazları ile çalınıyor” veya “şarkı İngilizce, oryantal formunda” gibi eserin içeriği hakkında bilgiler veremezler.

Müzik eseri sahibinin, eseri topluma sunup sunmamaya karar vermenin yanı sıra müzik eserinin ilk defa yayınlanma zamanını ve nasıl yayınlanacağını belirleme hakkı da bulunmaktadır. FSEK 14. maddede belirtildiği gibi, müzik eserinin kamuya sunuş şekli ve tarzı, besteci ve/veya söz yazarının şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette ise, eser sahipleri; yayınlayana umuma sunuş için yazılı izin vermiş olsalar bile, eserinin kötü bir tarzda kamuya tanıtılması veya yayımlanmasını yasaklayabilmektedirler. Müzik eseri sahibinin, şeref ve itibarını zedelese bile her şartta yayınlanmasına önceden izin vermesi veya bu konudaki yasaklama yetkisinden yapılan sözleşme ile önceden vazgeçmesi hükümsüzdür. Ancak müzik eseri sahibinin yasaklama yetkisini kullandığı durumlarda, daha önce bu konuda yetki almış ve kusursuz olan yayıncı tarafın da eser sahibinin bu müdahalesi sebebiyle uğramış olduğu zararlara ilişkin tazminat hakkı saklıdır.

Bir eserin ilk kez “umuma arz edilmesi” o eserin “*alenileşme*”si anlamına gelmektedir.

Aleniyet; bir fikir ve sanat eserinin yaratıcısının kişisel gizlilik çevresinden çıkmasını ifade eder ve fiili bir durumdur. Bu yüzden sahibinin iznine dayansın veya dayanmasın, bir kez kamuya sunulmuş eserler alenileştirmiş sayılacaktır. Ancak FSEK ceza hükümleri sahibinin rızası olmadan bir eserin umuma arzını cezalandırmakta; madde 67/I hükmü de eserin açıklanmasına ilişkin manevi hakkın ihlali halinde tecavüzün refi (kaldırılması) davasının açılacağını öngörmektedir.

Gerçekte aleniyetin fikri hukuk alanındaki etkileri, eserin sahibinin rızasıyla kamuya sunulmuş olmasından başlar. Nitekim FSEK madde 7/I

"hak sahibinin **rızasıyla** umuma arz edilen bir eser alenileşmiş sayılır" demektedir.¹⁵

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda eserin alenileşmesine bağlanan sonuçlar şunlardır:

a) Koruma süreleri eserin alenileştiği yılı takip eden yılın ilk gününden itibaren işlemeye başlar (FSEK madde 26/III, V).

b) Üçüncü şahıslar henüz alenileşmemiş bir eser hakkında bilgi veremezler (FSEK madde 14/II). Alenileşmiş fakat yayımlanmamış eser hakkında bu mümkündür.

c) Eserden meşru sınırlar içinde iktibasta (alıntıda) bulunabilmek için eserin alenileşmiş olması gerekir (FSEK madde 35/I).

f) Ancak alenileşmiş bilim ve edebiyat eserlerinin bazı bölümleri, röportaj amacıyla sınırlı kalmak üzere radyo-tv ile yayımlanabilir (FSEK madde 37/II).

g) Bir eserin müsveddesi veya aslı eser alenileştikten sonra kanuni veya akdi bir rehin hakkına, cebri icraya yahut hapis hakkına konu olabilir (FSEK madde 62/I).¹⁶

Aleniyetin fikri hukuk bakımından önem taşıyan bu sonuçları doğurabilmesi için iki unsurun varlığı gerekir: *Fiili unsur*, **eserin fiilen umuma arz edilmiş olması** ve *iradi unsur*, **sahibinin eseri alenileştirme hususundaki niyeti**¹⁷.

Aleniyetin *fiili unsuru* çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Mesela müzik eserinin konserde çalınması veya internette yayınlanması gibi. Eserin alenileşmiş sayılması için umuma arzın bir defa olması yeterlidir, tekrar şart değildir. Yine eserin sunulduğu çevrenin genişliği veya darlığı; resmi yahut özel niteliği; buraya girişin ücretli veya ücretsiz oluşu da önem taşımaz¹⁸.

Aleniyetin *iradi unsuru*, eser sahibinin eseri kamuya sunma hususundaki niyetidir. Gerek bizzat eser sahibi, gerek onun bu manevi hakkını kullanmaya yetki verdiği şahıslar, herhangi bir özel sıfat taşımayan herkesin eseri tanınmasını arzu ediyorsa iradi unsur gerçekleşmiş olur. Açıklama iradesinin bulunmadığı hallerde, mesela bir bestenin gizli tu-

¹⁵ EREL, age., s. 88

¹⁶ EREL, age., s. 88

¹⁷ ARSLANLI, age., s. 43-44; TOPÇUOĞLU, age., s. 55.

¹⁸ EREL, age., s. 88

tulmak kaydıyla bestecinin birkaç arkadaşına çalınmasında eser alenileşmiş sayılmaz. Buna karşılık açıklama ve kamuya duyurma niyeti ile eserin tek bir şahsa, mesela bir basın mensubuna gösterilmesi bile aleniyet için yeterlidir¹⁹. Bazı hallerde açıklama şekli de iradi unsurun varlığına işaret edebilir; mesela bir operanın halka açık bir yerde sergilenmesi açıklama niyetinin bulunduğunu gösterir. Aleniyet iradesinin varlığı araştırılırken, FSEK madde 14/II doğrultusunda *eser sahibinin kendinden başkalarının da eser hakkında kamuya bilgi vermelerine müsaade edip etmediği* incelenmeli ve bu müsaade verilmişse, açıklama niyetinin bulunduğu sonucuna varılmalıdır²⁰.

2. Adın Belirtilmesi Yetkisi

Adın belirtilmesi yetkisiyle, eser ile eser sahibi arasında bir bağ kurulmaktadır. Bern Anlaşması'nın 6. (mükerrer) maddesinde asgari hakların arasında yer alan bu yetki, eserin kullanıldığı her durumda geçerlidir.

Türk Hukuku açısından adın belirtilmesi yetkisi/hakkı FSEK madde 15'de; *“eseri, sahibinin adı veya müstear ad ile yahut adsız olarak, umuma arz etme veya yayımlama hususunda karar vermek salâhiyeti münhasıran eser sahibine aittir. Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde edilen kopyalarla bir işlenmenin aslı veya çoğaltılmış nüshaları üzerinde asıl eser sahibinin ad veya alâmetinin, kararlaştırılan veya âdet olan şekilde belirtilmesi ve vücuda getirilen eserin bir kopya veya işlenme olduğunun açıkça gösterilmesi şarttır. Bir eserin kimin tarafından vücuda getirildiği ihtilâflı ise, yahut herhangi bir kimse eserin sahibi olduğunu iddia etmekte ise, hakikî sahibi, hakkının tespitini mahkemedен isteyebilir”* şeklinde düzenlenmiştir.²¹

Bu madde ışığında adın belirtilmesi yetkisini şu şekilde açıklayabiliriz: FSEK madde 15/1'de yer alan eser sahibine ait *“adın belirtilmesi hakkı”* esas itibariyle; eser sahibi olarak tanıtılmayı amaçlanmaktadır. Ancak, adın tam olarak açıklanması zorunlu değildir. Kamuoyunca tanınacak şekilde bir kısaltma, rumuz veya müstear (takma) ad da kullanılabilir. Doğal olarak eser sahibinin bu hakkı kullanmaktan vazgeçmesi ve

¹⁹ AYİTER, *age. s. 108*; TOPÇUOĞLU, *age. s. 55*.

²⁰ ARSLANLI, *age. s. 44*. Naklen EREL, *age. s. 89*

²¹ Bern Sözleşmesinin 10. maddesi, *eserin her türlü kullanımında eser sahibinin adı ve kaynağın belirtilmesi gerektiğini düzenlemektedir.*

eserini kamuoyunca tanınmayan bir kısaltma, rumuz veya takma adla, hatta adsız olarak kamuya sunması mümkündür. Eserde adın belirtilmesi, eser sahipliğine ilişkin karineler ve eser üzerindeki tasarruf yetkisinin ispatı bakımından önem taşır²².

Eserde ad belirtme hakkı eser sahibi tarafından bizzat kullanılacağı gibi, bu hakkı kullanma yetkisi başka bir şahsa, özellikle mali hakları devir almış olanlara da bırakılabilir. Eser sahibinin ölümünden sonra bu yetki FSEK madde 19/I’de belirtilen şahıslar tarafından kullanılabilir. Yeter ki eser sahibi kimliğini gizli tutmak hususunda açık veya gizli bir irade açıklamasında bulunmuş olmasın. Şayet eser sahibi adının açıklanmasını istememişse ilgililer onun bu arzusuna uymak zorundadırlar.²³

Eserde sahibinin adının belirtilmesi, her eser kategorisi için o kategoriye has özelliklere göre olur. Müzik eserlerinde uygun araçlarla (radyoda dj’in ağzından; televizyonda sunucu tarafından veya alt yazı ile; internette eserin adının yer aldığı bölümde yazılı olarak) dinleyicilere ve izleyicilere duyurulması ve plak, kaset, cd vb. üzerine konulması²⁴; sinema eserlerinde filmin jeneriğinde yer alması gerekir²⁵.

Yargıtay’ın 1989 tarihli bir kararında; eser kullanılırken, eser sahibinin adının belirtilmemesinin maddi ve manevi tazminata dayanak oluşturacağı belirtilmiştir.

“... Davacı söz ve müziği kendisine ait olan “Sevdim Seni” adlı şarkının, davalıya ait filmde izinsiz olarak kullanıldığını ileri sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir.

Mahkeme, nedenlerini göstermeden manevi tazminat isteğini reddederken, 50,000 lira maddi tazminatın davalılardan tahsiline karar vermiştir.

... FSEK’in üçüncü bölüm A/II kısmında ... “adın belirtilmesi salahiyeti” başlığı altında düzenlenen 15. maddenin 2. bendinde “eser üzerinde adın belirtilmesi” manevi hak olarak kabul edilmiştir. Bu haktan vazgeçilmedikçe, eserin sahibinin adı altında açıklanması ve yayınlanması gerekir. Diğer taraftan sahibinin adı belirtilmeden yayınlanmalarda kusurun ve saldırının ağır olduğu da (FSEK m. 70) ka-

²² EREL, age., s. 119 vd.

²³ EREL, age., s. 119

²⁴ Yasal korumadan yararlanan eserden yapılan plakların üstüne eser sahibinin adının yazılmaması hali kusuru oluşturur ve manevi tazminatı gerektirir. 11. H.D. 23/3/1978, E 78/687, K. 78/1437, (Y.K.D. Temmuz 1979, s. 1012-1013.)

²⁵ EREL, age., s. 119

bul edilmektedir. (Ayiter, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, sh. 262 ve dipnot 14'te anılan kararlar). O halde Mahkemenin izinsiz kullanma iddiası içinde "eser sahibinin isminin açıklanması" olgusunu araştırmadan ve hiçbir gerekçe göstermeden, manevi tazminat isteğinin reddine karar vermiş olması hatalı olmuştur...²⁶

Bu konuda daha yeni tarihli bir karar da şudur:

"Asıl davada, davacı vekili, müvekkilinin 1980'li yıllarda bizzat okuyarak, doldurduğu "Çeyiz" adlı kasetin B yüzünde "Söz-Müzik M.K." olarak kaydettiği ve 1985 yılında da Fransa'da plak halinde yayınladığı "Metris" adındaki müzik eserinin, davalı G.I.'ın okuduğu "Oraktan ..." adlı kasetin A yüzünde, "Söz-Müzik A.A." adına kayıtlı olarak yayın ve ticaret konusu yapıldığını, ileri sürerek 100 milyon lira manevi tazminat ile şimdilik 500 milyon lira maddi tazminatın, birleşen davada da, saklı tuttuğu 400 milyon lira maddi tazminatın faizleriyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlar, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda davacının 1980 ve 1985 yıllarında ilk kez besteleyip yayınladığı eserin sahibi olduğu, davalının izinsiz olarak bu eseri yayınladığı, üzerine eser sahibinin adını yazmadığı, bu şekilde davacının FSEK'nun 15/2 maddesi kapsamındaki manevi hakkını, FSEK'nun 70/3 maddesine göre de mali hakkını ihlal ettiği, maddi tazminatın 900 milyon lira olarak hesaplandığı gerekçeleriyle asıl ve birleşen davanın kabulü ile toplam 900 milyon lira maddi tazminatın tahsiline asıl davanın manevi tazminat yönüyle kısmen kabulüne, 75 milyon lira manevi tazminatın davalı G.I.'tan tahsiline, ... karar verilmiştir. Karar onanmıştır²⁷."

FSEK madde 15/2, bazı eserlerin niteliğinden hareketle özel hükümler öngörmektedir. Bir güzel sanat eserinin işleme suretiyle meydana getirilmesi veya kopyalanması halinde (doğaldır ki işleme veya kopyalama için eser sahibinden izin almak gerekir); mevcut eserin bir kopya ve işleme olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Buradaki amaç, kopyayı yapan kişinin, toplumu yanıltmasını önlemektir. Ayrıca kopyanın kötü olması halinde gerçek eser sahibinin adının belirtilmesi nedeniyle eser sahibinin itibarının zedelenmesinin de önüne geçilmiş olmaktadır.

FSEK madde 15/3; bir eserin kimin tarafından yapıldığının çekişmeli olduğu durumlarda, eser sahibinin tespiti davasının açılabileceğini düzenlemektedir. Bu hükme göre tespit davası iki durumda açılabilir: İlki, bir başkasının bir esere sahip çıkması, ikincisi bir kişiye yaratma-

²⁶ Yargıtay 4. H.D. 9.2.1989, E. 8503, K. 1052 . Naklen ERDİL, s. 44, 161

²⁷ Yargıtay 11. H.D. 2000/2483 E. 2000/3590 K.

dığı bir eserin - şöhretinden yararlanmak veya onu kötülemek amacıyla - mal edilmesi²⁸.

Dava açma yetkisi, eser sahibinin ölümünden sonra FSEK madde 19/I'de belirtilen şahıslar; meşru menfaatini ispat eden mali hak sahipleri ve memleket kültürü bakımından önemli görülen eserlerde Kültür Bakanlığı tarafından *kendi namlarına* kullanılabilir. Kanunda belirtilmiş olmamakla beraber, bu dava hakkından önceden feragat etmek geçerli değildir²⁹.

FSEK madde 11/I uyarınca, eser kimin adına kamuya sunulmuşsa, o şahsın eser sahibi olduğu yolunda bir karine doğar. Bu yüzden eseri gasp edilen şahıs kendi eser sahipliğini kanıtlamak zorundadır. Buna karşılık bir kimse kendi adıyla kamuya sunulmuş bir eserin sahibi olmadığını iddia ediyorsa, onun bu iddiasını doğru kabul ederek, ispat yükünü aksini iddia eden tarafına vermek menfaatler durumuna daha uygun olacaktır³⁰.

3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Yetkisi

Bern Sözleşmesi'nin mükerrer 6. maddesinde; *“mali haklarından bağımsız olarak ve bu hakların devrinden sonra dahi eser sahibi; eseri üzerindeki sahipliğini ileri sürerek eserinde yapılacak her türlü tahrifata, bozulma, diğer değişikliklere, onur ve şöhretine zarar verebilecek her türlü küçük düşürücü fiillere itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu paragrafta eser sahibine tanınan haklar, kendisinin ölümünden sonra en az mali hakların ortadan kalkmasına kadar”* devam edeceği belirtilmektedir.

Bern Sözleşmesi'nin 12. maddesinde ise; *“edebiyat ve sanat eseri sahiplerinin, eserlerinin uyarlanması, düzenlenmesi ve diğer değişikliklerine izin verme konusunda inhisari hak sahibi oldukları düzenlenmiştir.*

Bern Sözleşmesi'nin iç hukuka yansımış hali olan FSEK madde 16; *“Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz. Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri işleyen, umuma arz eden, çoğaltan, yayımlayan, temsil eden veya başka bir suretle yayan kimse; işleme, ço-*

²⁸ AYİTER, age., s. 119-120. Naklen EREL, age., s. 121

²⁹ ARSLANLI, age., s. 84. Naklen EREL, age., s. 122

³⁰ AYİTER, age., s. 120. Naklen EREL, age., s. 122

ğaltma, temsil veya yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sahibinin hususî bir izni olmaksızın da yapabilir. Eser sahibi, kayıtsız ve şartsız olarak yazılı izin vermiş olsa bile şeref ve itibarını zedeleyen veya eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değiştirilmeleri menedebilir. Menetme yetkisinden bu hususta sözleşme yapılmış olsa bile vazgeçmek hükümsüzdür.” şeklinde düzenlenmiştir.

Anayasa madde 90’a göre; imzalanmış uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde olduğundan Bern veya diğer uluslararası sözleşmeler ile FSEK arasında çelişki halinde uluslararası sözleşme hükümleri esas alınmaktadır.

Bir yaratının eser olarak adlandırılabilmesi ve hukuki korumalardan yararlanabilmesi için sahibinin hususiyetini (özelliklerini) taşıması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu nedenle bir eserde değişiklik yapmak kimi zaman o eserin özelliğine zarar vermek anlamına gelmektedir. Eser sahibinin özelliği eserin bütününde veya eserin kimliğini belirleyici bir parçasında görülebileceği için, eserin özelliğini etkileyecek bu tür bir parçasının değiştirilmesi, çoğu zaman eserde değişikliği engelleme hakkını ihlal etmek anlamına gelir ve tazmin edilmesi gerekir.

Bu açıklama dahilinde FSEK 16. maddesini şu şekilde detaylandırabiliriz:

Eserin adı ve muhtevası ile şekil olarak eserin kendisi bir bütünlük arz ettiği için; bu bütünlüğün korunmasında eser sahibinin manevi bir çıkarının olduğu oldukça açıktır. Bu nedenle ondan izinsiz, eserde özelliği (veya sahibinin kişiliğini kötü yönde) etkileyecek her değişiklik hak ihlali sayılmaktadır³¹. Aşağıdaki kararlarda eserin değiştirilmesi sonucu tazminat alındığını görebilirsiniz.

“Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi S.T.’ın “İkinci Kurtuluş” isimli eserinin 35. Sayfasındaki “Ağaç Dedi Ki” isimli şiirinin; davalılardan N. Şirketinin yapımcı, davalı N.D. nin sanatçı olarak, kasete “Aç Gözünü Adamım” ismiyle okuyarak haksız rekabet meydana getirdikleri, davacılara telif hakkı vermediklerinden 5,000,000 TL maddi 50,000,000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalı N. Şti. vekili, husumet itirazı ile, kaset yapımcısı bir firma olan müvekkilinin, N.D. tarafından okunan parçaların kime ait oldu-

³¹ Bir güzel sanat eserinin hususiyet ve tamamîyetini her türlü değiştirici davranış manevi tazminat talebi için yeterlidir. HGK. 11/2/1983, E. 1981/4-70 K. 1983/123, Naklen Orhan Nuri ÇEVİK, İçtihatlı- Notlu Fikri Hukuk Mevzuatı, Ankara, 1988, s. 22

ğunu bilemeyeceklerini, müvekkilin sorumlu olmadığından davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

“Mahkemece, iddia, savunma, kaset, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından davalıların murisi S.T.’ın **“Ağaç Dedi Ki” isimli şiirinin izinsiz olarak** ve telif haklarına aykırı olarak **“Aç Gözünü Adamım” adı ile değiştirip** kasete okuyarak bu isim altında kaset çıkarması sonucu davalıların telif hakkı ödemesini gerektirdiği bunun 4,000,000 TL olup takdiren 30,000,000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiştir.³²”

Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporlarına nazaran, mali hakları davacıya ait “*Seni Andıkça*” adlı eserin edebi ve müzik eseri niteliğinde olduğu, davalıların ise **sözleri üzerinde önemsiz değişiklikler yaparak**, aynı eseri “Mektup” adı altında çoğaltıp **yayınladıkları, bu hususun davacıların mali ve manevi haklarını ihlal ettiği**, istenebilecek maddi tazminatın 18,185,999,999 lira olup, tecavüzün niteliğine ve ağırlığına, tarafların durumlarına nazaran manevi tazminat isteginin de yerinde olduğu gerekçesi ile asıl ve birleşen davaların kabulüne karar verilmiştir³³.

FSEK madde 16/1 de belirtildiği gibi; eser üzerinde sahibinin izni olmadan değişiklik yapılmayacağına ilişkin kural sadece eser için değil, aynı zamanda eserin ismine ilişkin değişiklikleri de kapsamaktadır.

Kanun eserin adının korunması konusunda FSEK 83. maddesinde de bir özel hüküm koymuştur.

“Bir eserin ad ve alametleri ile çoğaltılmış nüshaların şekilleri, iltibasa meydan verebilecek surette diğer bir eserde veya çoğaltılmış nüshalarında kullanılamaz.

1 inci fıkra hükmü umumen kullanılan ve ayırt edici bir vasfı bulunmayan ad, alamet ve dış şekiller hakkında uygulanmaz...

Tecavüz eden tacir olmasa bile, birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında haksız rekabete mütaallik hükümler uygulanır.”

Bu düzenlemeye göre bir müzik eserinin adı; genel olarak kullanılan ve ayırt edici niteliği bulunmayan bir isim değilse, başka bir eserde kullanılamaz. Ancak genel şarkı isimleri veya ayırt edici bir niteliği bulunmayan şarkı isimleri herkes tarafından kullanılabilir. Özel bir şarkı ismi başkası tarafından karışıklığa meydan verecek şekilde kullanılmışsa eser sahibi haksız rekabet hükümlerinden faydalanarak, bu şarkının isminin kullanılmasını yasaklayabilir ve tazminat talep edebilir.

³² Yargıtay 11. H.D, 6.5.1996, E. 1996/2725, K. 1996/3018, SULUK/ORHAN, age, s. 153.

³³ Yargıtay 11. H.D, 07.12.2000, E. 2000/7797, K. 2000/9773. Naklen ERDİL, s. 105-107,

Her ne kadar EREL; “*eserin adı yahut muhteva veya biçimi yönünden eserin kendisinde yapılacak bir değişikliğe karşı koyma hakkı; ya eser sahibinin şeref ve itibarının zedelenmesi veya eserin nitelik ve özelliğinin bozulması halinde söz konusudur*” demekteyse de biz bu görüşe katılmıyoruz. Eserdeki değişikliğe karşı koymak için bu şartları koymak veya aramak hem Bern Sözleşmesi’ne ve hem de FSEK madde 16’ya aykırıdır. Yargıtay’ın kararları da bu yöndedir.

“... FSEK’nun 14. maddesi uyarınca eser sahibinin kayıtsız şartsız izin vermesi halinde bile, manevi haklardan sözleşme ile vazgeçmek hükümsüz olduğundan, manevi hakları çiğnemenin eser sahibinin bu eylemlere karşı koyma ve manevi tazminat isteme hakkı vardır. Uygulamada manevi hakların kullanılmasına izin vermek mümkün olduğundan Mahkemece taraflar arasında bağitlanan sözleşmenin 3. maddesinin manevi haklardan sözleşme ile vazgeçme mi yoksa kullanmaya izin anlamında mı olduğu, gerekli şekilde araştırılmamış ve Karar’da bu husus tartışılmamıştır. Diğer taraftan, eserin parça parça ve bütünlüğünün bozularak yayınlandığı hususu da gerekli şekilde irdelenmemiştir. Mevcut kanıtlara göre, **davalı televizyonunda eserin iddia edilen biçimde yani parça parça ve eserin bütünlüğünün bozularak yayınlanmasının gerçek olması halinde, bunun eser sahibinin manevi haklarını ihlal edip etmediğini yeterli açıklıkta tartışılmamış**, Karar’ın gerekçe kısmında bilirkişi raporuna atıf yapılmış ve incelenen bilirkişi raporunda bu konular gerekli açıklıkta yer almamıştır. Bu durumda Mahkemece, iddia edilen hususların gerekli şekilde araştırılması, gerektiğinde bilirkişi dinlenmesi ve hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucunda yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.”³⁴

Türk Hukuku Bern sözleşmesinde olmayan bir kuralı FSEK’e dahil etmiştir. Bu düzenleme şudur; *Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri işleyen, umuma arz eden, çoğaltan, yayımlayan, temsil eden veya başka bir suretle yayan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sahibinin hususî bir izni olmaksızın da yapabilir.*

Piyasa kuralları gereği müzik yapımcısı veya radyo ile televizyon şirketi; eserin sunuşunda veya gösterisinde değiştirilmek gereğinin ortaya çıkması veya zamanla yeni müzik aletleri ile çalınması gereksinimi karşısında FSEK madde 16’da yer alan bu istisnadan yararlanabilmektedir. Eserde değişiklik yapılmasına karşı koymak eser sahibinin manevi hakkı olduğundan, “*bu değişiklikler ilke olarak sadece kendisi tarafın-*

³⁴ Yargıtay 11. H.D., 1.10.1999, E. 1999/1726, K. 1999/7358.

dan yapılır” kuralının ilk istisnası bu düzenlemedir. İkinci istisna ise; eserin mali haklarını devralan veya lisans alanların “eserde değişiklik yapma” hakkında eser sahibinden izin veya yetki almasıdır.

Sonuç olarak; FSEK madde 16/2, esere ilişkin mali hakların devri sırasında eser sahibinin, eserde değişiklik yapma yetkisini de yeni hak sahibine yazılı bir belgeyle veya bir sözleşme maddesiyle tanımlı olabileceğinden ya da işlenme, özellikle çoğaltma, temsil veya yayma haklarını devir almış olanların, bu haklarını kullanabilmeleri için eserde zaruri olan değiştirmeleri yapabileceklerinden bahsetmektedir.

Maddeye göre; yapılan değişiklik *objektif olarak* eser sahibinin şeref ve itibarını düşürüyor yahut eserin nitelik ve özelliğini bozuyor ise eser sahibi (önceden izin vermiş olsa bile) bu değişikliklere karşı koyabilir ve eserin kamuya sunulmasını engelleyebilir. Eser sahibinin bu konudaki yetkisinden sözleşmeyle tamamen feragati de FSEK madde 16/3 gereğince hükümsüzdür.

Bu konuya örnek bir yargı kararı aşağıdadır.

“Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi olan Aşık A.İ.Ö.’a ait “Mühür Gözlüm” adlı şiirin davalılar tarafından **şiiir ve müzik formu değiştirilerek** izinsiz kaset yapılarak piyasaya sürüldüğünü, davalıların eyleminin FSEK’na aykırı olduğunu, müvekkillerinin mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini, anılan Kanunun 21, 22, 23 ve 24. maddelerdeki hakların ihlali nedeniyle 70/2. maddeye göre şimdilik 14.000.000 TL. haksız fiil tazminatı, 70/3 maddesi gereği şimdilik 14.000.000 TL. kar payı tazminatı olmak üzere mali haklar tazminatı, 14, 15, 16. maddelerin ihlali nedeniyle 70/1 maddeye göre şimdilik **14.000.000 TL. manevi haklar tazminatı** ile BK 49 ve MK 24/a maddelerine göre ihlale uğrayan kişilik hakları nedeniyle tüm davacılar için 60.000.000 TL. manevi tazminatın olay tarihinden itibaren reeskont oranında faizi ile tahsilini talep ve dava etmiş, açılıp birleştirilen davada da, 70/3 maddeye göre 86.000.000 TL. kar payı bedeli, 70/2 maddeye göre 86.000.000 TL. mali haklar tazminatı ve 70/1 maddeye göre 286.000.000 TL manevi haklar tazminatının eser işletme alınış tarihinden itibaren reeskont oranında faizi ile davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davaya konu kasetin 1993 yılında çıkarıldığını, kasette 14 parça daha bulunduğunu, eserin N.E.’a ait ve onun tarafından tanıtılan bir eser olduğunu, Mesam Meslek Birliği kayıtlarında da eser sahibinin N.E. gözüktüğünü, davacıların taraf sıfatlarının bulunmadığını, aradan geçen süre nedeniyle talep hakları da olmadığını, istenen tazminatın fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davalıların davacılar mürşesine ait “Mühür Gözlüm” adlı şiiri değiştirerek hafif müzik tarzında icra ettikleri, eserin nitelik ve özelliğini bozarak davacı yazarın manevi tazminat istemine olanak sağladıkları, tazminat miktarlarının bilirkişiler tarafından tespit edilmiş olduğu gerekçesiyle FSEK’nun 70/1 maddesi uyarınca 250.000.000 TL, 70/2 uyarınca 83.333.333 TL., 70/3 uyarınca 33.333.333 TL.’nin 04.05.1993 tarihinden itibaren reeskont oranında faizi ile davalılardan tahsiline, ... karar verilmiştir. Karar onanmıştır.³⁵”

Yine; klasik müzik olarak yazılan bir eserin pop veya r&b gibi başka bir şekle sokulmasına eserin gerçek sahibi tarafından izin verilmişse ve bu değişmeyi bir başkası yapıyorsa ve yapılan değiştirme değişikliği yapanın hususiyetini taşıyorsa yeni yapılan pop eser bir işlemedir ve ortaya çıkan yeni bir eser sayılmaktadır.

Müzik eserlerinde değişiklik yapılmasını önlemeye yönelik davalar eser sahibi tarafından hayatı boyunca açılabilceği gibi, ölümünden sonra 70 yıl içinde yapılmış tecavüzlere karşı FSEK madde 19/1’de belirtilen kişiler tarafından kendi namlarına da açılabilir. Ayrıca eser sahibi veya haleflerinden mali bir hakkı devir almış olup, meşru bir menfaati bulunduğunu ispat eden kişiler de bu mali hakkın koruma süresi içinde dava açabilirler. Ek olarak, Ülke kültürü bakımından önemli görülen eserlerde koruma süreleri dolmuş olsa bile, Kültür Bakanlığı dava açma yetkisine sahiptir.³⁶

Eserlerde değişiklik yapılması hakkındaki önemli bir düzenleme de FSEK 67. maddede bulunmaktadır. Buna göre; “*eser sahibi, eserin değiştirilmiş şekilde çoğaltılmasının, yayım ve temsilinin, radyo ile yayımının menedilmesini ve tecavüz edenin, tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki değişiklikleri düzeltmesini veya bunların eski haline getirilmesini talep edebilir. Değişiklik, eserin, gazete, dergi veya radyo ile yayımı sırasında yapılmışsa eser sahibi, masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş şekilde yayımlamış olan bütün gazete, dergi ve radyo idarelerinden değişikliğin ilan yolu ile düzeltilmesini talep edebilir*”.

Bu düzenleme doğrultusunda, başlamış ve devam etmekte olan bir tecavüz sebebiyle açılacak “*tecavüzün ref’i*” davasıyla; eserin değiştirilmiş şekliyle çoğaltılmasının yasaklanması ve tecavüz edenin piyasada

³⁵ Yargıtay 11. H.D. 2000/7675 E. 2000/9048 K.

³⁶ EREL, age, s. 123.

dolaşımında bulunan çoğaltılmış kopyalardaki değişiklikleri düzeltmesi veya eseri eski haline getirmesi talep edilir. Değişiklik, müzik eserinin radyo ile yayımı sırasında yapılmışsa eser sahibi; FSEK madde 67/bent 1 gereğince masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş şekilde yayımlamış olan radyo idaresinden değişikliğin ilan yolu ile düzeltilmesini de talep edebilir.

Sonuç olarak, müzik eserinde değişiklik yapılması konusunda karar verme ve gerekirse yapılan değişikliği menetme yetkisi; eser sahibi olan besteci, aranjör ve söz yazarına, hak sahibi olduğu eserdeki kendilerine ait kısımlar için tanınmaktadır

4. Eserin Aslına Varma Yetkisi

FSEK madde 17 bu konuda; *“eser sahibi, gerekli durumlarda, aslın maliki ve zilyedinden, koruma şartlarını yerine getirmek kaydıyla, ... eserlerinin asıllarından geçici bir süre için yararlanmayı talep etme hakkına sahiptir. Eser sahibinin bu hakkı, bu eserlerin ticaretini yapanlar tarafından, eseri satın alan veya elde eden kişilere müzayede ve satış kataloğu veya ilgili belgeler ile açıklanır. Aslın maliki, eser sahibi ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir. Ancak eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin haklarına zarar veremez. Eserin tek ve özgün olması durumunda eser sahibi, kendisine ait tüm dönemleri kapsayan çalışma ve sergilerde kullanmak amacıyla, koruma şartlarını yerine getirerek iade edilmek üzere eseri isteyebilir.”* hükmüne yer vermiştir.

Bu madde hükmünü açıklayabilmek için öncelikle şu konuya değinmek gerekmektedir. Fikir ve sanat eserleri, üzerinde cisimlendikleri maddi maldan ayrı bir hukuki varlığa sahiptirler. Maddi mal her türlü hukuki işleme serbestçe konu olabilir, üzerinde başka şahıslar lehine şahsi veya ayni haklar tesis edilebilir. Bu durum maddi mal halinde cisimlenmiş bir eser üzerindeki fikri hakları kural olarak³⁷ etkilemez. Mesela bir ressamın sattığı resmi veya bir bestecinin sattığı el yazısı notalara konu olan bestesi üzerinde bütün manevi hakları ve mali haklarından da bir kısmı ressam ve besteci yararına kullanıma hazır var olmaya devam eder³⁸.

³⁷ Maddi mal üzerindeki tasarrufların bazı hallerde fikri hakları da etkileyeceği karine olarak kabul edilmiştir. Bu hususta bkz. FSEK madde 57/II ve III

³⁸ EREL, age., s. 130

Bu düzenleme müzik eseri sahipleri açısından farklı durumlarda kullanılabilir. Müzik eseri çoğu zaman yapımcılar veya radyo ve televizyon kuruluşları tarafından icra ettirilerek çeşitli kayıt malzemelerine kayıt edilmektedir. Çoğu zaman bu kayıtlardan eser sahibi olan besteci, aranjör ve söz yazarları kopya elde edememektedirler. Hatta kopyalarının yanında ilk kayıt/master kayıt, yapımcı ve yayıncı bu kişi ve kuruluşlarda aynen orijinal tablolar ve heykeller gibi saklanmakta; piyasaya ise kopyaları sunulmaktadır. İşte bu düzenlemeye dayanarak eser sahipleri, kendilerine ait tüm dönemleri kapsayan çalışma³⁹ ve sergilerde kullanmak amacıyla ve diğer gerekli durumlarda, koruma şartlarını yerine getirerek, iade edilmek üzere, kendilerinde bulunmayan eserin icrasını içeren master kaydını isteyebilirler.

Yine bir müzik eseri yarışması veya gösterisi sonunda elde edilen bestelerin yazılı olduğu notalar veya piyano ile bestecinin yaptığı icranın tespitleri yarışmayı veya gösteriyi düzenleyen kuruluş tarafından alınmaktadır. Daha sonra ise bu çalışmaların akıbeti yani düzenleyen tarafından saklanıp saklanmadığı belli olmamaktadır. Oysa müzik eseri sahibinin bunlar üzerindeki yararlanma hakkı hâlâ devam etmektedir. Gerek söz yazarının güftenin yazılı olduğu kağıt, gerek bestecinin notaları yazdığı pörşemen üzerinde ve de o esnada yapılan icraların kayıtları üzerindeki yararlanma hakkı devam etmektedir. İşte Kanunun bu maddesiyle müzik eseri sahipleri başka yarışmalara katılmak, yayın yapmak veya maddede sayılan diğer amaçlarla bu orijinal kayıt ve çalışmaları iade etmek üzere geri isteyebilme hakkına sahip olmaktadırlar.

FSEK madde 17/II hükmünde “*aslın maliki, eser sahibi ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir. Ancak eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin haklarına zarar veremez*” şeklinde belirtildiği üzere; eser sahibinin eserde değişiklik yapmasını men etmek hususunda FSEK madde 16’da belirtilen manevi hakkının özel bir uygulaması gösterilmektedir. Eser sahibi mali hakları devrettiği kimselerin eserde kendi şeref ve itibarını yahut eserin nitelik ve özelliğini bozan değişiklikler yapmalarını nasıl yasaklayabiliyorsa; aynı yetkiyi notalar veya güftenin yazılı olduğu veya icraların saklandığı bant kayıtları şeklindeki maddi malın malikine, hatta esere tecavüz eden üçüncü şahıslara karşı da haizdir.⁴⁰

³⁹ Bu kavram çok geniş olduğundan her türlü iş açısından ve her amaçla kullanılabilir.

⁴⁰ EREL, age., s. 132

Malik, zilyed veya üçüncü şahıslar tarafından eserin maddi veya manevi bütünlüğüne, eserin bozulması veya yok edilmesi şeklinde yapılacak tecavüzlere karşı eser sahibi; tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i, tazminat ve ceza davalarıyla korunmuştur.

B. MÜZİK ESERİ SAHİPLERİNİN MALİ HAKLARI

Daha öncede ifade ettiğimiz gibi; mali haklar, eser sahibine eserden ekonomik olarak yararlanma yetkisi verir. Bazı diğer ülke kanunlarının aksine FSEK; mali hakları, eserden ekonomik olarak her türlü yararlanmayı kapsayan bütün bir hak değil, fakat sınırlı şekilde sayılmış beş hak kategorisi halinde düzenlenmiştir. EREL, bu sınırlı sayıda belirtilen mali haklara “*pay ve takip hakkı*”nın da eklenmesi görüşündedir.⁴¹ Biz de, Kanun'un başka bir faslında düzenlenmiş olsa dahi Ülkemizde uygulaması yaygınlaşmamış olan pay ve takip hakkının mali haklara eklenmesi düşüncesindeyiz.

Mali hakların kullanılması konusunda, eserin alenileşmiş olup olmamasına göre bir ayırım yapılmaktadır. Henüz alenileşmemiş bir eser fikri hak düzeni içinde sınırlı biçimde korumaya konu olmaktadır.

Ayrıca FSEK madde 20'ye göre mali haklar; manevi haklardan farklı olarak, birbirinden bağımsızdırlar ve bunlardan biri üzerindeki tasarruf ve kullanımlar diğerlerini etkilememektedir.

Eser sahipleri tarafından, yapımcıya, icracı sanatçıya, radyo ve televizyon kuruluşuna ya da internet sitesi işletene yapılacak tüm mali hakların devri veya lisans verme işlemleri FSEK madde 52'de belirtildiği gibi muhakkak; yazılı şekilde yapılmalı ve hangi mali hakların devredileceği ayrı ayrı yazılarak özellikle belirtilmelidir. Bu yolla, mali hak devir işleminde, bahse konu mali hak devralana geçmekte ve eser sahibi gibi devralan tarafından kullanılabilir. Mali hak konusunda lisans vermede ise yapılan lisans sözleşmesi doğrultusunda ya sadece lisans alan tarafından ya da hem lisans alan ve hem lisans veren tarafından lisans süresi boyunca kullanılmaktadır.

Üçüncü kişilerin ve kuruluşların kullandıkları eserler için besteci ve söz yazarlarından veya onların meslek birliklerinden izin almamaları halinde, eser sahipleri FSEK'de yer alan tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i, maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davaları açabilirler.

⁴¹ EREL, age, s. 133

Bu kısımda mali haklarla ilgili FSEK'deki genel kurallardan da bahsetmekte yarar görüyoruz.

FSEK madde 60'a göre; eser sahibi yahut mirasçıları, kendilerine kanunen tanınan mali haklardan, önceden yapılmış tasarruflarını ihlal etmemek şartıyla, bir resmi senet düzenlenmesi ve bu konunun Resmi Gazete'de ilanı yoluyla vazgeçebilirler. Vazgeçme, ilan tarihinden başlayarak koruma süresinin bitmesi halindeki hukuki neticeleri doğurur. Bu durumda mali haklar eser sahibinden izin alınmadan herkes tarafından kullanılır. Eser izinsiz olarak çoğaltılabilir, satılabilir, her türlü yolla iletilir.

FSEK madde 61'e göre de; İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 24 ve 30 uncu maddelerinin hükümleri mahfuz kalmak şartıyla:

1. Eser sahibinin veya mirasçılardan birinin mülkiyeti altında bulunan henüz alenileşmemiş bir eserin müsvedde veya asılları;

2. Sinema eserleri hariç olmak üzere birinci bentte zikredilen (alenileşmemiş) eserler üzerindeki mali haklar;

3. Eser sahibinin, mali haklara dair hukuki muamelelerden doğan paradan gayri alacakları;

kanuni veya akdi bir rehin hakkının, cebri icranın veya hapis hakkının konusu olamaz.

İİK madde 24 hükmü menkul malların teslimine, madde 30 hükmü ise bir şeyin yapılması konusundaki mahkeme kararlarının yerine getirilmesine ilişkindir. Eser sahibi alenileşmemiş bir eserin teslimini taahhüt etmiş fakat bu taahhüdünü yerine getirmemişse, alacaklı mahkemeden alacağı ilamı icraya koyarak eserin veya müsveddelerinin haczini ve kendisine teslimini sağlayabilir. Keza, eser sahibinin belirli bir eseri hazırlama taahhüdüne aykırı davranması halinde, bunun tespit edilecek tarihe kadar bitirilmesi icra kanalıyla emredilir. Ancak şahsi bir borcun zorla icrası mümkün olmadığından, eser sahibinin işi yapmaması halinde, kendisine bunun değeri tazmin ettirilir. Eser sahibi mahkemenin yasakladığı bir işi yapmış, mesela sattığı müzik eserinin benzerini hazırlamışsa, İİK madde 30/son fıkra ve madde 343'e göre şikayet üzerine beş günden bir aya kadar hafif hapis cezasına çarptırılır⁴².

⁴² ARSLANLI, age., s. 202-203; HIRSCH, *Urheberrechtsgesetz der Türkei*, s. 60. Naklen EREL, age., s. 287

Eserin cisimlendiği maddi malın haczi için, eser tamamlanmış olmalıdır. Kanunda müsveddelerin haczinden söz edilmesi, eserin tamamlanmamış vaziyette haciz olunabileceğini göstermez. Eser bitmeden kamuya sunulmuş olsa bile, tamamlanmasına engel olacak şekilde müsveddelerin veya eser parçalarının⁴³ haczi, eser sahibinin şahsiyet haklarını ihlal eder. O yüzden eser kopyalarının haczi, bunlar ancak tamamlanmış bir esere ait ise uygun görülebilir.

Maddi malın haczi, alacaklıya bu malda cisimlenen eser üzerinde tasarruf yetkisi sağlamaz. Mesela, eserin müsveddelerini (bant kayıtlarını, kopyalarını) haciz ettiren alacaklı, bu müsveddelerden istifade suretiyle eserin çoğaltıp yayımlamak hakkına sahip değildir. Keza, bir güzel sanat eserinin haczi, bundan teşhir yoluyla yararlanmak yetkisi vermez. Alacaklı bu malların sadece maddi değerinden istifade hakkına sahiptir. Diğer yandan mimari eserler hariç, eserin cisimlendiği mal çoğu kez bir menkul mal olduğundan gerek haciz gerek paraya çevirme safhalarında İcra İflas Kanunu'nun bu husustaki hükümleri uygulanacaktır (İİK madde 85-89,106-112).⁴⁴

FSEK madde 62 gereğince ise;

1. Alenileşmiş bir eserin müsveddesi veya aslı,
 2. Yayımlanmış bir eserin çoğaltılmış nüshaları,
 3. Eser sahibinin korunmaya layık olan manevi menfaatlerini ihlal etmemek şartıyla alenileşmiş bir eser üzerindeki mali hakları,
 4. Eser sahibinin mali haklara dair hukuki muamelelerden doğan para alacakları,
- kanuni veya akdi bir rehin hakkının, cebri icranın yahut hapis hakkının konusunu teşkil edebilir.

Rehin sözleşmesinin muteber olması için yazılı şekilde yapılması lazımdır. Sözleşmede rehin olarak verilenler ayrı ayrı gösterilmelidir.

Mimarlık eserleri hariç olmak üzere güzel sanat eserlerinin asılları ve eser sahibine yahut mirasçılara ait musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin müsveddeleri, birinci fıkranın üçüncü bendinde yazılı mali haklar üzerinde cebri icra tatbiki için lüzumlu görüldüğü nispette zilyed olan kimselerden geçici olarak alınabilir.

⁴³ EREL, age., s. 287

⁴⁴ EREL, age., s. 287

FSEK madde 63'e göre; bu Kanunun tanıdığı mali haklar miras yolu ile intikal eder.

Mali haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruflar yapılması caizdir.

Yapılan bu kısa açıklamanın ardından mali hakları müzik eserleri açısından tek tek inceleyelim.

1. İşleme Hakkı

FSEK 1. maddesinde işleme eserler; *“diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakıl olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsulleri”* şeklinde tanımlanmıştır.

FSEK'de sayılan işleme türleri çok çeşitli olmakla birlikte, müzik eserlerini ilgilendiren işleme biçimlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- *Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin filim haline sokulması veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması,*

- *Musiki aranjman ve tertipleri,*

- *Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külli-yat haline konulması,*

- *Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi,*

- *Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır),*

- *Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması,*

İşleme eser türleri FSEK madde 6'da örnekleme kabilinde sayılmıştır. Sayılan örneklerin dışında, bir eserin başka şekillere dönüştürül-mek üzere işleme hakkı ve bu hakkın devri yine sadece eser sahibine ait bir haktır.

FSEK 6. maddesinin ek fıkrası; *“istifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek şartıyla oluşturulan ve işleyenin hususiyeti-ni taşıyan işlenmeler, bu Kanuna göre eser sayılır”* demektedir.

Bir eserden yararlanılarak başka bir eser oluşturulması şeklinde kısaca tanımlayabileceğimiz işleme için FSEK'in 6. maddesi iki şart öngörmektedir:

* İstifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirilmemelidir.

* İşleme işleyenin özelliğini taşımalıdır.

Bu iki şart yoksa ortaya çıkan yaratıcı çalışma “eser” sayılmaz.

Bern Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 3 no’lu bendinde; işlemlerin, müzik düzenlemelerinin ve edebiyat eserlerindeki diğer değişimlerin (müzikte kullanılan sözler açısından) özgün eser üzerindeki haklara zarar vermeksizin, özgün eser olarak korunacağı düzenlenmiştir.

Bern Sözleşmesi’nin 12. maddesi; “*edebiyat ve sanat eseri sahipleri eserlerinin uyarlanması, düzenlenmesi ve diğer değişikliklerine izin verme konusunda inhisari hak sahibidir*” dediğinden dolayı orijinal eserin bir biçimde değişmesinden oluşan işleme eser için işleyenin mutlaka eser sahibinden izin alması gerekmektedir.

Yine Bern Sözleşmesi’nin 14. maddesi, edebiyat ve sanat eseri sahiplerinin;

- eserlerinin sinematografik uyarlanması ve çoğaltılmasına,
 - uyarlanan ve çoğaltılan eserlerin dağıtımına,
 - uyarlanan ve çoğaltılan eserlerin umuma arzına ve temsiline,
- izin verme hususunda inhisari hak sahibi oldukları belirtilmiştir.

Bern Sözleşmesi doğrultusunda eser sahibinin işleme konusundaki yetkisi FSEK madde 21’de; “*bir eserden, onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir*” şeklinde ifade edilmiştir.

FSEK’nun bu maddesi, eserin işleme hakkını başkalarına kullanıma yetkisini sadece eser sahibine verdiğini açıkça ifade etmektedir. FSEK madde 20/4’e göre; bir işlemenin sahibi, işleme eserden doğan mali haklarını asıl eser sahibinin verdiği izin ölçüsünde kullanabilecektir.

İşleme hakkını diğer mali haklardan ayıran husus, işleme hakkının kullanılmasındaki “yaratıcılık”dır. Bir eserin çoğaltma, yayma, temsil ve yayın haklarını kullanmada veya bu hakların ihlalinde yaratıcılık söz konusu değilken, işlemede yaratıcılık unsuru ön plana çıkmaktadır.⁴⁵ Yaratıcılığa benzer diğer kavram TEKİNALP’in üzerinde durduğu “*düşünce yaratıcılığı*”dır.

TEKİNALP’e göre, “*düşünce yaratıcılığı*” terimine AT’nun 96/6 Yönergesinde kullanılan “yaratma” ve “fikri yaratım” (madde 3 (1), madde 7) terimleri esin vermiş olabilir. Alman ESK § 2 (2) hükmünde de “fikri yaratım” ve “fikri yaratma” terimi yer almakta ve öğretilerdeki “individualität” kavramı bundan çıkarılmaktadır. Ancak, Türkçe’ye aktarılmış şekli ile kavram başarılı değildir. Kavramdaki “düşünce” sözcü-

⁴⁵ ERDİL, age., s. 93

günün “fikri/intellectual/ geistig” şeklinde anlaşılması şarttır. Kavram; derleme eserler için kullanıldığından, bu eserlerin niteliklerine uygun bir şekilde anlamlandırılması gerekir. Bu bağlantı da fikri yaratımın ne ile ilgili olduğu sorusunu ortaya çıkartır. Bir edebiyat, musiki veya güzel sanat eserindeki fikri yaratıcılığı derleme eserde aramak mümkün değildir. “Düşünce yaratıcılığı” derleme eserin tümü için öngörülmüştür. Başka bir deyişle derleme eser, yani “bütün”, düşünce yaratıcılığının ürünü olmalıdır. Düşünce yaratıcılığını derlemeyi oluşturan “seçme” ve “düzenleme” çalışmasına özgüleyemeyiz. Çünkü, tanım böyle bir özgülemeye olanak bırakmamakla, seçmenin ve düzenlemenin değil, eserin düşünce yaratıcılığının sonucu olmasını istemektedir. Yaratma, bir makinanın, bir mekanizmanın ya da doğanın değil, insanın fikri nitelikteki şekillendirme ve öz verme faaliyeti olmalı, beşeri fikri çalışma, yani düşünce kaynaklanan faaliyet derleme eserde yansımaları bulmalıdır. Bu yaratıcılık, derleme düşüncesinin (idesinin) bulunmasında, şekillenmesinde ve öz kazanmasında etkili olmalıdır. Derleme konusunun “bulunması” ise basit bir konu belirlemeden farklı olarak değerlendirilmelidir.⁴⁶

“Düşünce yaratıcılığı”nın derlemeler için öngörülmüş olması hem uygunluk ve elverişlilik sorgulamasını ortaya çıkarmakta, hem de bu yeni kavramın “hususiyet”i etkileyip etkilemeyeceği, etkileyecekse bunun boyutunun belirlenmesini sorun haline getirmektedir. Başka bir deyişle, bir edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eseri için sahibinin hususiyetinin varlığı yeterli görülürken bir derleme için “*düşünce yaratıcılığı*” aramak hem derlemeye uygun ve elverişli olmayan bir ölçü koymak çelişkisini doğurur hem de derlemeyi eserin üstünde yer alan bir düzeye çıkarabilir. Kanun’un bu yapısal çelişkisinden, hatta bozukluğunun bertaraf edilmesi, “hususiyet” kavramının şimdiye kadar olduğundan farklı şekilde anlamlandırılmasını gerektirebilir. “Hususiyet”in bu yeni yorumunda “düşünce yaratıcılığı”nın da yer alması bir zorunluluk niteliğini kazanır. Çünkü, eserler hiyerarşisinde daha düşük bir konumda bulunan bir esere yüksek, daha yüksek nitelikleri haiz eserlere ondan düşük tanım ölçütleri koymak olanağı yoktur. Kanun böyle bir dengesizliğe ve uygunsuzluğa yer vermişse, bunun düzeltilmesi öğretinin ve ilkesel nitelikteki mahkeme kararlarının görmezden gelinemeyecek görevi durumuna gelir.⁴⁷

⁴⁶ Ünal TEKİNALP, “Derleme Eser, Düşünce Yaratıcılığı ve Bunun “Hususiyet” Üzerindeki Etkisi”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, Yıl 5 Cilt 5, Sayı 1 s. 69 vd.

⁴⁷ TEKİNALP, *agm.*, s. 69 vd.

İşleme faaliyeti, asıl esere bağımlı olan fakat ekonomik olarak ondan bağımsız şekilde değerlendirilmeye elverişli yeni bir eser oluşturmaktır. Örneğin, bir müzisyenin sanat müziği formundaki eserinin başka bir kişi tarafından pop müzik veya film haline sokulması işleme eser oluşturmastır.

Eser sahibine, eserinden işleme yoluyla elde edilecek yeni eserin kamuya sunulması ve ekonomik olarak değerlendirilmesi hususunda bağımsız bir yetki verilmiştir. Bu nedenle işleme hakkı eser sahibi tarafından bizzat kullanılabilmesi, yani eser sahibi kendi eserini yine kendisi işleyebileceği gibi, bu hakkı başkalarına da devredebilir. Üçüncü şahıslara işleme hususunda izin verme yetkisi, ancak işleme eserin kamuya sunulacak veya ekonomik olarak değerlendirilecek olması halinde söz konusudur.

İşleme hakkını (eser sahibinden) yasalara uygun olarak devralan şahıs, o işleme türüne münhasır kalmak şartıyla, kendi işlemesi üzerinde eser sahipliğinden doğan bütün hak ve yetkileri haizdir⁴⁸. Burada devir almak yerine, süre veya yerle kısıtlı bir lisans da alınabilir. İşleme eserin sahibi; işleme eseri kamuya sunmak, asıl eser sahibininkiyle birlikte kendi adını belirtmek, kendi yaptığı işlemde değişiklik yapılmasını men etmek gibi manevi haklar yanında; işlemeyi ekonomik olarak değerlendirmek için gerekli mali haklara da sahiptir. Bu hakların kullanılabilmesi için, işleme izni veya lisansının FSEK 52. maddeye uygun yazılı olması yeterlidir.

İşleme hakkıyla birlikte devredilmiş kabul edilen bu mali haklar sadece iki açıdan sınırlanmıştır. İlk olarak işleme hakkı özel olarak hangi işleme türü için tanınmışsa, onunla sınırlıdır. Mesela, bir müzik eserinin sadece film haline sokulması için izin verilmesi halinde bunun ayrıca radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması mümkün değildir. İkinci olarak da, işleme eser üzerinde yeniden bir işleme yapılması, işleyenden başka asıl eser sahibinin de iznine tabidir. İşleyen kendi meydana getirdiği işleme eseri, tekrar işlemek veya başkasına işletmek istiyorsa, yine asıl eser sahibinin iznine ihtiyaç duymaktadır.

Yani diğer mali hakların devrinden farklı olarak, FSEK madde 49/II ve 55 gereğince, eserin her yeni işlemesinde veya işleme hakkını devir alanın bunu bir başkasına devretmesinde, asıl eser sahibi veya mirasçılarının izni gerekmektedir.

⁴⁸ ÖZTRAK, age., s. 32, Naklen EREL, age., s. 136; Bern Sözleşmesi madde 2/II ve 2/III hükümlerinde; edebiyat ve sanat eserlerinden yapılan işlemlerin, özgün eser üzerindeki haklara zarar vermeksizin, özgün eser olarak korunacağı kabul edilmiştir.

İzin alınarak yapılmış bir işleme, gerek asıl eser sahibine, gerek üçüncü şahıslara karşı korunmaktadır. Örneğin, bir müzik eserinin aranjmanını yapmak için asıl eser sahibi olan besteci ve söz yazarından izin alınması halinde, ortaya çıkan yeni eser işleyen tarafından hem asıl eser sahibine hem de diğer üçüncü şahıslara karşı korunmaktadır.

Ancak izin alınmadan yapılan işleme eser, özellikle yapılan alıntılar intihal düzeyinde ise işleyene karşı FSEK’de sayılan davaların açılmasına neden olmaktadır. Yargıtay bir eserden yararlanılarak bir sinema eserinin yapılması sırasında izinsiz işlenmenin ve intihalin sonuçlarını şu kararlar hüküm altına almıştır.

“...Dosyadaki kanıtlara ve bilirkişi raporuna göre, “Yeşilçam’da Bir Sultan” adlı eserin FSEK 2/1 kapsamında “bilimsel eser” ve aynı Yasanın 8/1. maddesine göre de eser sahibinin davacı yazarlar bulunduğu anlaşılmaktadır. Bilirkişi raporları, özel dairenin ilk bozma kararı kapsamına ve bu bozmadan sonra mahkemenin kabulüne göre, ***davalının yaptığı filmin, davacının eserinden sadece esinlenme, öykülenme sonunda meydana getirilmiş genel bir etkileşim ürünü olmayıp, intihal düzeyinde alımlardan oluştuğu sonucuna varılmalıdır.*** Uygulama ve öğretiye göre, bir eserden yapılan alıntılar ortaya çıkan yeni esere galip geliyorsa, artık masum alıntıdan söz edilemez. Davalı, davacıya ait sosyolojik bir inceleme niteliğindeki bilimsel eserinden, çeşitli alıntı, uyarlama ve değişikliklerle belgesel bir sinema eseri meydana getirmiştir.

Davalının eylemi, davacının bilimsel eserinden, onun izni olmadan işlenme eser meydana getirmedir. ... taraflar arasında eserin işlenme hakkının davalılara devir edildiğine dair yazılı bir sözleşme yoktur. ... davalılar, davacıya ait “bilimsel eseri” işleyerek bir “sinema eserine” dönüştürmüşler ve işleme eseri çoğaltmak, televizyonda oynatmak suretiyle, eser sahibinin eserini çoğaltma ve yayma hakkını ihlal etmişlerdir. Davalıların bu eyleminin, FSEK’te yazılı davacının mali haklarına bir saldırı teşkil ettiği yerel mahkeme ve özel dairenin kabulünde bulunmaktadır.⁴⁹”

İşleme için eser sahibinden izin alma kuralının istisnaları da bulunmaktadır.

FSEK madde 34’e göre, eğitim ve öğretim gayesine tahsis edilmek şartıyla, yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden maksadın haklı göstereceği ölçüde iktibaslar yapılarak seçme ve toplama eserler meydana getirilmesi (yani bunla-

⁴⁹ HGK, 02.04.2003, E. 2003/4-260, K. 2003/271, FMR, C. III, S. 3/2003, s. 157-166; KAZANCI, Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri, S. 7 / Mart 2005, s. 148 – 152.

rın FSEK madde 6, bent 7 hükmünde belirtilen şekilde işlenmesi) serbesttir⁵⁰. Örneğin konservatuarda bir derste bir öğretim üyesinin öğrencilerine belli tip müzik eserlerinin işlenmesi ile ilgili bilgi vermesi için mix aletleri veya benzeri araçlarla müzik eserinin rumba, caz, disko gibi değişik versiyonlarının yapılması.

Müzik eserlerinin işlenmesi konusunda FSEK madde 6'nın içinde özel iki örnek bulunmaktadır. İlki, FSEK madde 6 bent 3'te musiki eserlerin film haline sokulması veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir hale sokulması. İkincisi de musiki aranjman ve tertipleridir. Bir türkünün hikayesinin filme konu edilmesi ve senaryonun temel taşı oluşturmaları veya radyodaki bir caz programı için bir klasik müzik eserinin orijinalinden farklı caz müzik türünde aranjmanının yapılması bu alanda verilebilecek örneklerdir.

Bu bölümde müzik eserleri için çok rastlanan bir başka işleme biçimine de değinmemiz gerekiyor: **Yabancı şarkıların Türkçe'ye uyarlanması.**

Eğer yabancı bir bestecinin eseri, sözleri hiç kullanılmadan bambaşka Türkçe sözler ile sunulmak istenirse, bu durumda eserin bestecisi ve varsa aranjöründen izin almak yeterli olacaktır. Bu konuda müzik meslek birlikleri birçok ülke ile anlaşmalı olduklarından bu kuruluşlar vasıtasıyla hareket edilmesi yararlı olacaktır.

Yabancı şarkıların Türkçe versiyonlarında sıkça kullanılan yöntem, sözlerin Türkçeye çevrilmesi (tercüme edilmesi) şeklindedir. Bu durumda besteci ve varsa aranjörün yanısıra söz yazarlarından tercüme için izin almak gereklidir.

BERN sözleşmesinin 8. maddesi; edebiyat ve sanat eserlerinin sahiplerinin, özgün eserleri üzerindeki haklarının koruma süresi içinde eserlerinin çevirilerini yapmak ve yapılmasına izin vermek hususunda inhisari hak sahibi olduğunu düzenlemektedir. Yine BERN sözleşmesinin 11. maddesi, edebiyat eserleri sahiplerinin özgün eserleri üzerindeki hakların koruma süresinin tamamı boyunca, bu eserlerinin çevirileri ile ilgili olarak benzer haklara sahip olduklarını söylemektedir.

Bu yüzden müzik eserinin sözleri (şartları olduğundan dolayı) eser ise, bu sözlerin ait olduğu kişiden de müzik eserinin sözlerini türkçeye çevirmek için izin almak gerekmektedir. Günümüzde iletişim olanakları

⁵⁰ EREL, age., s. 137.

yaygınlaştığından bu konuda internet üzerinden yapılacak bir araştırma ile ilgili kişiler bulunarak kolayca temasa geçilebilir. Yine bu kişiler çoğunlukla edisyon şirketleri tarafından temsil edildiğinden, bu şirketlere kolayca ulaşılarak işleme hakları için izin alınabilir.

2. Çoğaltma Hakkı

Bern Sözleşmesi'nin 9. maddesi; *“bu Sözleşme ile korunan edebiyat ve sanat eseri sahipleri, hangi biçim ve yöntemle olursa olsun eserlerinin çoğaltılmasına izin vermek hususunda inhisari hak sahibidirler”* demektedir.

Yine Bern Sözleşmesi'nin 14. maddesi, edebiyat ve sanat eseri sahiplerinin;

- eserlerinin sinematografik uyarlanması ve çoğaltılmasına,
 - uyarlanan ve çoğaltılan eserlerin dağıtımına,
 - uyarlanan ve çoğaltılan eserlerin umuma arzına ve temsiline,
- izin verme hususunda inhisari hak sahibi olduklarını belirtmiştir.

Bu uluslararası bağlayıcı hükümlerin Türk İç Hukuku'na aktarılmış şekli olan FSEK madde 22 hükmüne göre ise; *“bir eserin aslını veya işlenmelerini kısmen ya da tamamen çoğaltma hakkı, münhasıran sahibine aittir.”*

Çoğaltma, eserin aynen tekrarlanmasını ve maddi bir varlık olarak tekrarlanacak şekilde nesnelleştirilmesini sağlayan teknik bir işlemdir⁵¹. Bu işlem müzik eserleri açısından FSEK madde 22/2 de;

- a. Eserin aslından ikinci bir kopyanın çıkarılması,
- b. Eserin işaret, ses ve görüntü nakil ve tekrarına yarayan bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kayıt edilmesi,
- c. her türlü ses ve müzik kayıtları şeklinde ifade edilmiştir.

Kanun koyucu çoğaltma tekniklerini bu şekilde sayarak bu teknikler bakımından sayma yöntemini tercih etmiş bulunmaktadır. Ancak her geçen gün yeni çoğaltma araçları veya teknikleri ile karşılaşmak söz konusu olacağı için çoğaltma teknikleri veya araçlarının sayma yöntemiyle belirlenmesi pek doğru değildir. Öte yandan FSEK madde 22'de yer alan *“...bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kayıt... çoğaltma sayılır”* ifadesi ise çoğaltma teknik ve araçları açısından yeni gelişmelerin bu Kanun kapsamında ele alınmasına olanak tanımaktadır.

⁵¹ TEKİNALP, age., s. 170.

Bir bestenin çoğaltılması için öncelikle notaya geçirilmesi, bir kasete kaydı şart mıdır, kasete kayıt ile eserin aslı mı yoksa nüshası mı elde edilmiştir? Eser türleri açısından bakıldığında, ilim ve edebiyat eserlerinden bazıları ile müzik eserlerinin maddi bir varlık olarak somutlaşmaları, eser olarak korunabilmeleri için şart değildir. Örneğin; müzik eserlerinde, eserin notaya, plağa, diskete kaydı önemli değildir; önemli olan eserin sahibinin hususiyetini taşımasıdır⁵². Nitekim Kanunda da müzik eserlerinin zorunlu olarak maddi bir varlık şeklinde somutlaşması aranmamıştır (FSEK md. 3).

FSEK madde 22 gereğince, eserin herhangi bir şekilde veya yöntemle çoğaltılması mümkün olup; eserin taş, kağıt, cam, plak, kaset gibi ses taşıyıcılarına, film, video gibi görüntü kaydeden cihazlara, disk, CD, USB gibi dijital kayıt cihazlarına, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kaydedilmesinin önemi yoktur⁵³.

Bu açıklamalarımız ışığında sonuç olarak, eser sahibi olan söz yazarından izin alınmadan eserin çoğaltılarak kasete koyulmasında aşağıdaki kararlarda görüleceği üzere mahkeme fonogram yapımcısı şirketleri tazminat ödemeye mahkum etmiştir.

“Davacı vekili, davalı grubun müvekkilinin ‘Saklı Kalan’ adlı şiir kitabında yer alan ‘Konuğum 01’ adlı şiiri izinsiz olarak şarkı sözü haline getirip bestelediğini ve bilahare de söz konusu besteye diğer davalı ile birlikte ‘Dünyanın Kapıları’ adlı kasette yer verip, kasetin Türkiye çapında satışa sunulduğunu ve şarkının konserlerde okunmaya devam ettiğini, şiirin işlenerek başka şekle sokulmuş olduğunu belirterek, FSEK 70/1’e göre ... 40,000,000.- TL tazminatının (20,000,000.- TL’sinin maddi tazminat ve) 20,000,000.- TL’sinin manevi tazminat (istemiştir) ...

Mahkemece, kasetin Ankara’da da satışa sunulması nedeniyle yetki itirazının reddiyle, bilirkişi raporuna göre, davalının isteyebile-

⁵² ARSLANLI, age., s. 21; AYİTER, age., s. 51-52; EREL, age., s. 44; YARSUVAT, age., s. 61.

⁵³ Kayıt teknikleri şunlardır: Mekanik kayıt, en eski kayıt türü olup, bir madde üzerine iz yaparak (kazıyarak) kaydetme esasına dayanır. Optik kayıt, ışık esasına dayanan kayıt türüdür; film üzerinde uygulanır. Magnetik kayıt, bir malzeme üzerine yapılarak, sesin elektrik enerjisine dönüşmesinden sonra titreşimler, magnetik zemin üzerine aktarılır. Laserli kayıt, laser ışınlarından faydalanarak, özel zeminler üzerine tespit edilen kayıt türüdür. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sedat CERECİ, “Radyoda Canlı Yayından Bant Yayınına Geçiş”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1988, s. 24-25. Fotokopi makineleri ve benzeri daha gelişmiş fotoğrafik tekniklerden yararlanarak çoğaltma işlemi, “reprografik” kavramı ile ifade edilmektedir. Bkz.; Y. Selim SARIİBRAHİMOĞLU, “Korsan Kopya Yayıncılık ve Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının İhlali”, ABD, C.45, 1988, s. 1-25. Naklen ARIDEMİR, age., s. 60

ceği maddi tazminat tutarının 11,272,729.- TL olduğu, ayrıca davacının “Konuğum 01” adlı şiirinin izinsiz şarkı sözü haline getirilip kasete doldurulup, tüm Türkiye çapında satışa arz edilmesinin **kötü niyetli hareket olarak kabul edilmekle** ve FSEK’in 14, 15 ve 81. maddesinde eser sahibine verilen hakların da ihlali olarak kabul edilerek 7,500,000.- TL **manevi tazminatın davalıdan tahsili gerektiği** gerekçesiyle 11,272,728.- TL maddi tazminat ile 7,500,000.- TL manevi tazminatın eserin işletme kayıt tescil tarihi olan 18.8.1987 tarihinden itibaren %45 nispetindeki reeskont faiziyle birlikte **davalı şirketten tahsiline**, fazla isteğin reddine, diğer davalı aleyhine davanın açılmış sayılmasına **karar verilmiştir.**⁵⁴

“Davacı vekili, müvekkillerinin murisinin yazdığı “Aramayın Beni Başka Yerlerde” isimli şiirinin davalı tarafından “Yummayın Kırpiklerini” ve “Aramayın Beni Başka Yerlerde” isimli müzik kasetlerinde izinsiz olarak türkü halinde seslendirildiği, **eserin bozularak değiştirildiği ve kalitesiz bir müzikle icra edildiğinden** 50,000,000 TL maddi, 50,000,000 TL manevi **tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiştir.**

Davalı vekili, müvekkilinin dava edilen iki şiiri ilk defa 1987 tarihinde okuduğunu teklif edilen telif hakkını murisin o tarihte almadığını, **küçük parçaların kullanılmasında sakınca olmadığını**, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından **davacıların murisine ait eseri davalının izinsiz olarak plağa okunmasının maddi ve manevi haklara tecavüz teşkil ettiği** bilirkişi raporuna göre davacının talep edebileceği tazminatın 60,000,000 TL olmasına rağmen talepten fazlaya hükmedilemeyeceğinden 50,000,000 TL **maddi**, 30,000,000 TL **manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.**⁵⁵

Eser kasete çoğaltılabildiği gibi eser sahibinden izin alınmadan bir film için film bandına da çoğaltılabilir. Eser sahibinden izin alınmadan eserin filmde kullanılması için şu mahkeme kararını örnek verebiliriz:

“**Mahkemece**, iddia, savunma ve dosya arasındaki yazılara göre; davalı şirketin “*İstanbul Kanatlarımın Altında*” adlı filmin yapımcısı olduğu, filmin müziklerinin hazırlanması sırasında davalı ile ihbar olunan arasında bir sözleşme yapıldığı ve davalı tarafından ödeme yapıldığı, filmin önemli bir sahnesinde sözleri N.Y.G.’nun, bestesi ise davacıya ait olan “*Malazgirt Marşı*” adlı müzik eserinin kullanıldığı, aynı müziğin ihbar olunan tarafından daha önce yayınlanan “*Les Janissaries (Yeniçeriler)*” adlı CD’de 7 numara altında bestecisi bilinmeyen eski bir eserin arasında hak sahiplerinin adları verilmeden

⁵⁴ Yargıtay 11. H.D, 4.11.1992, E. 5632, K. 7038, ERDİL, age., s. 25-26, 41-42, 44-45 ve 235-236

⁵⁵ Yargıtay 11. H.D, 21.10.1996, E. 1996/6614, K. 1996/7038, SULUK/ORHAN, age, s. 152-3

kullanıldığı, filmin sinema severler arasında büyük ilgi gördüğü ve çok izleyici topladığının anlaşıldığı, yaptırılan bilirkışı incelemesine göre “Malazgirt Marşı”nın bestecisinin davacı olduğunun saptandığı, FSEK’in 68. ve 70. maddelerine göre maddi ve manevi dava açma hakkı bulunduğu, davalının da filmin yapımcısı olduğundan davalıya husumet yöneltilmesinde bir usulsüzlük bulunmadığı, aynı Yasanın 70/2 maddesine göre, davalının kusurlu bir şekilde davacının mali ve manevi haklarını ihlal ettiği, sinema eserinin gişe hasılatı ve davacının devlet memuru olması göz önünde tutularak talep edilen miktarın rayice uygun olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile, 150,000,000 TL maddi, 100,000,000 TL manevi tazminatın reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir. ...⁵⁶

İleride mali hakların devrini anlatacağımız bölümde geniş olarak inceleyeceğiz, ancak burada belirtmeliyiz ki, eser sahibinden alınan iznin veya ruhsatın ya da hakları devir sözleşmesinin kapsamı ve içeriği de önemlidir. Eğer eser sahibi eserine ilişkin sınırlı bir lisans veriyorsa, lisans alanın bu sınırlara uyması gerekmektedir. Aksi halde aşağıdaki mahkeme kararında olduğu gibi eser sahibi vermediği haklarına ilişkin yasal yolları başarıyla kullanabilir.

“Davacı vekili, müvekkilinin “Zikir” isimli eserinin **plak yapılmak ve satışa arz edilmek üzere davalıya mali hakları devrettiğini, davalının (bu eserin) izin almadan ses kaseti ve compact disk haline getirdiğini** iddia ederek 2.000.000 lira maddi, 1.000.000 lira manevi tazminatın reeskont faiziyle birlikte tahsilini, **plak dışında üretim yapılmasının önlenmesini** talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya içerisindeki yazılara göre, davanın kabulü ile 2.000.000 lira maddi tazminatın %30 faiziyle birlikte tahsiline, manevi tazminat isteminin reddine, **davalıca (eserin) bundan böyle ses kaseti ve compact disk olarak üretim yapılmasının önlenmesine**, bunların kalıplarının önlenmesine, hüküm özetinin gazete ile ilanına karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekilleri temyiz etmişlerdir.

Karar, Dairemiz’in 21.10.1993 gün ve 92/7541-92/6666 sayılı kararı ile bozulmuştur.

Mahkemece, bozma ilamına uyulup, bu doğrultuda yapılan yargılama sonunda, davacının fazlaya ait talep hakkı saklı kalmak kaydı ile ses kaseti için 1.000.000 lira compact disk için 1.000.000 lira olmak üzere 2.000.000 lira maddi tazminatın dava tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte tahsiline, manevi tazminatın koşulları oluş-

⁵⁶ Yargıtay 11. H.D; 10.3.1997, E. 1997/1153, K. 1997/1514, SULUK/ORHAN, age, s. 194-5

madiğundan bu konudaki talebin reddine, davalının kaset, compact disk şeklindeki üretimden men'ine, hüküm özetinin en yüksek tirajlı iki gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir⁵⁷.

İcracı sanatçı ile yapılan çoğaltma konusundaki lisans sözleşmesine yapımcı uymazsa ve sözleşme gereği ödemelerini sanatçıya yapmazsa aşağıdaki yargı kararında da görüleceği üzere icracı sanatçı sözleşmeden dönebilir.

"Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında albüm yapım sözleşmesi imzalandığını, sözleşme uyarınca taraflar arasında her üç ayda bir hesap mutabakatı yapılması ve buna göre 1 ay içinde ödeme yapılması gerektiğini ancak davalının bu edimini yerine getirmediğini, bu konuda davalıya gönderilen ihtarnamenin de sonuçsuz kaldığını ileri sürerek sözleşmenin feshedilmesine karar verilmesine talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, sözleşmeye göre mutabakatın, sanatçının bir alacağının doğması ve bir ödeme yapılması halleri için gerektiğinin açıkça belirtildiği, oysa albümün 15.000 satış rakamını bulmadığını ve bu sanatçının bir alacağı doğmadığını, müvekkilinin alacaklı durumda olduğunu, cevabi ihtarname ile kasetlerin son satış raporlarının davalıya bildirildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalının sözleşmeye uymadığı, sözleşmede öngörülen süreler içerisinde sanatçıya yazılı bildirimde bulunmadığı bu nedenle davacının sözleşmeden tek tarafı olarak feshedilmesinde hukuka aykırı bir durum bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar onanmıştır⁵⁸.

Çoğaltma ne zaman gerçekleşmiş sayılır? Özellikle koruma süresi dolmuş bulunan bir eserin çoğaltılmak üzere bir vasıtaya alınmış olmasında mı yoksa bu vasıttan yararlanılarak ikinci bir nüshanın elde edilmesinde mi çoğaltma gerçekleşmiştir? Çoğaltma, vasıtaya alınmada değil, örneğin kitabın matbaada dizilmesinde değil, baskıya geçilmesinde, yani vasıttan nüsha elde edilmesi anında gerçekleşmiştir ve hukuki sonuçlar bu ana göre doğacaktır⁵⁹.

⁵⁷ Yargıtay 11. H.D, 16.3.1995, E. 1995/288, K. 1995/2049

⁵⁸ Yargıtay 11. H.D. 2001/11220 E. 2002/3587 K.

⁵⁹ Matbaada dizi halinde bulunan bir edebiyat eserinde "nakil" vasfı yoktur. Bu itibarla eserin bilvasıta nakle yarayan bir vasıta üzerine alınması çoğaltma hadisesini tekemmül ettirmiş olmaz. İlim ve edebiyat eserlerinde çoğaltmanın mebdai, kitabın matbaada dizilmeye başladığı an olmayıp basıldığı tarihtir." ARSLANLI, age., s. 98. Aynı fikirde bakınız EREL, age., s. 140. Naklen ARIDEMİR, age., s. 64.

Mekanik veya digital araçlar yardımıyla bir müzik eserinin kopyasının çıkarılması, bir çoğaltmadır. Mekanik araçların yardımı olmaksızın eserin bir benzerinin yapılması, mesela konservatuarda bir müzik bölümü öğrencisinin ünlü bir bestecinin bestesini örnek alarak beste yapması ne bir taklittir, ne de çoğaltmadır⁶⁰. Duruma göre; sınırlı biçimde esinlenme varsa yeni bir eser veya orijinal eser ama esinlenme kapsamını aşmışsa ve asıl eser sahibinden izin alınmışsa işleme eser sayılabilir.

Çoğaltma hakkı konusunda eser sahibinden izin alma zorunluluğu, Bern Sözleşmesi'nin 10. maddesinde bulunan basında haber verme, eğitim amacı gibi bazı sebeplerle sınırlandırılmış veya ortadan kaldırılmıştır. Benzer sınırlamalar ve eser sahibinden izin alma gerektirmeyen yararlanma biçimleri FSEK'de de bulunmaktadır.

Bunları şöyle sıralayabiliriz: FSEK madde 26 ve 27'deki eserin koruma süresinin bitmesi; FSEK madde 30 uyarınca eserin ispatı maksadıyla mahkeme ve diğer resmi makamlar huzurunda bir işleme konu teşkil etmek üzere kullanılması; FSEK madde 33'de belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarında, yüzyüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili.

Yine FSEK 37. maddesine göre; haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla, günlük olaylara bağlı olarak fikir ve sanat eserlerinden bazı parçaların işaret, ses ve resim nakline yarayan vasıtalarla alınması, bu şekilde alınmış parçaların çoğaltılması serbesttir.

FSEK madde 38/I'e göre; bütün fikir ve sanat eserlerinin, yayımlanma veya kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya özgü olarak çoğaltılması mümkündür. Çoğaltma hakkı iktibas hakkıyla da sınırlandırılmıştır. İktibas, bir eserin bazı parçalarının başka bir eser içinde kullanılması olduğundan, iktibas serbestisi bulunan hallerde (Bkz. FSEK madde 35 ve 36) eser parçalarının, iktibasın haklı göstereceği ölçüler içinde serbestçe çoğaltılması mümkündür⁶¹. Örneğin müzik bölümü öğrencileri için bir müzik türünü açıklamak ve dersi aydınlatmak amacıyla, başkasına ait bir müzik eserinin bir bölümünün ders kitabına koyulması veya cd halinde dağıtılması hukuka uygun yararlanmalardır.

⁶⁰ ÖZTRAK, age., s. 24-25; bu taktirde model olarak kullanılan eserin sahibinden izin alma zorunluluğu yoktur.

⁶¹ AYİTER, age., s. 132 Naklen EREL, age., s. 141.

Yukarıda sayılan bu özel durumlarda (koruma süreleri henüz dolmamış olsa dahi) eser sahibinin izni alınmadan eserin çoğaltılması mümkündür.

Günümüzde birçok müzisyen, müzik eserlerini ve çalışmalarını internet ortamında sergilemektedir. Ancak internet ortamı birçok haksız çoğaltma için olanak sağlamaktadır. Bu açıdan; internet ile ulaşılan ve dinlenebilen ancak çoğaltılması ve üçüncü kişilere nakledilmesi yasaklanmış olan bir müzik eserinin ileride üçüncü kişilere ulaştırılmak amacıyla, kullanıcının bilgisayarının hard-diskine kaydedilmesi çoğaltma hakkının ihlali sayılır.

Çoğaltma konusunda önemli bir düzenleme de FSEK 16. maddede belirtilen “*Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri ... çoğaltan ... kimse; ... çoğaltma ...veya yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sahibinin hususi bir izni olmaksızın da yapabilir*” düzenlemesidir. Burada, eserde değişiklik yapıldığının eser sahibi tarafından iddia edilmesine karşı, çoğaltma tekniği açısından çoğaltanlara bir korunma sağlanmıştır. Örneğin, bir cd üzerindeki müzik eseri, internette umuma iletilmesi için digital ortama aktarılırken zorunlu olarak birçok açıdan değişmektedir. Cd’den digital ortama aktarma da bir tür çoğaltmadır. Ancak bu değişiklikler yayın tekniği icabı zaruri olduğundan, eser sahipleri eserin değiştiği iddiasını ileri süremez, sürerlerse o zaman çoğaltanın fiilinin hukuka uygun olduğu ortaya çıkar. Bu düzenleme Bern Sözleşmesi’ne de uygundur. Zira Bern Sözleşmesi’nin 13. maddesine göre; her Birlik ülkesi, söz yazarının izni ile yapılan kayıtlı ilgili olarak müzik eseri sahibine tanınan inhisari hak üzerine, müzik eserinin söz ile birlikte ses kaydının yapılması hususunda şart ve çekince öngörebilir; ancak bütün bu şartlar ve çekinceler, yalnızca öngörülen ülkelerde uygulanır.

FSEK madde 57 asıl veya çoğaltılmış kopyalar üzerindeki mülkiyet ve buna ilişkin araçların devri konusunda şu düzenlemeyi yapmıştır. “*Asıl veya çoğaltılmış nüshalar üzerindeki mülkiyet hakkının devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, fikri hakların devrini ihtiva etmez.*”

3. Yayma Hakkı

Bern Sözleşmesi’nin 14. maddesi, edebiyat ve sanat eseri sahiplerinin;

- uyarlanan ve çoğaltılan eserlerin dağıtımına,

- uyarlanan ve çoğaltılan eserlerin umuma arzına

izin verme hususunda inhisari hak sahibi olduklarını belirtmiştir.

WIPO Telif Hakları Andlaşma'sının 6. maddesi, “Yayma Hakkı” başlığı altında; “*edebiyat ve sanat eserlerinin sahipleri(nin), eserlerinin özgün nüshaları ya da kopyalarının satılması ya da sahipliğinin el değiştirmesi yoluyla topluma sunulmasına izin verme hususunda münhasıran hak sahibi*” olduğunu düzenlemiştir. Maddenin 2. paragrafına göre; bu Andlaşmadaki hiçbir hüküm, akit tarafların birinci paragrafta öngörülen eser sahibinin izni ile eserin özgün nüshası ya da kopyası üzerindeki sahipliğin, ilk satış ya da el değiştirmesinden sonra son bulması koşullarını düzenleme yetkisini etkilemeyecektir.

WIPO Telif Hakları Andlaşma'sının 7. maddesi de “Kiralama Hakkı” başlığı altında; “*akit tarafların ulusal yasalarında tanımlandığı şekliyle fonogramlara tespit edilmiş eserlerin sahipleri; eserlerinin özgün nüshaları ya da kopyalarının toplumda ticari nitelikte kamuya kiralanmasına izin verme hususunda münhasıran hak sahibi*” olduklarına hükmetmektedir. Birinci paragraf hükümlerine rağmen, 15 Nisan 1994 tarihinde, fonogramların içerdiği eserlerin kopyalarının kiralanması karşılığında eser sahiplerine hakkaniyetli bir ücret sistemi uygulayan ve uygulamakta olan *Âkit* bir taraf, fonogramların içerdiği eserlerin ticari olarak kiralanması, eser sahiplerinin münhasır çoğaltma hakkına maddi şekilde zarar vermedikçe, bu sistemi muhafaza edebilir.

Avrupa Birliği Konseyi ise, 92/100/AET sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi'nin birinci maddesinde; “*Üye devletler (eser sahiplerine), telif hakkı eserlerinin ve nüshalarının ve diğer konuların kiralanması ve ödünç verilmesi konusunda yetkilendirme ve yasaklama hakkını sağlarlar*” demektedir.

92/100/AET sayılı Direktifi'n 2/1. maddesine göre; “*kiralama ve ödünç vermeyi yetkilendirme ve yasaklama münhasır hakkı,*

- *eserin orijinali ve diğer nüshaları hakkında, eser sahibine,*
- *icra tespiti hakkında, icracı sanatçıya,*
- *fonogramlar hakkında, fonogram yapımcısına ve*
- *film ya da yayınları hakkında, filmin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıya aittir”.*

Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin 22 Mayıs 2001 tarih ve 2001/29/AT sayılı Direktifi'nin 4. maddesine göre;

1. Üye devletler, eser sahiplerinin eserlerinin orijinallerini veya kopyalarını satış veya başka şekilde kamuya dağıtımının her türü ile ilgili müsaade etme veya yasaklama münhasır haklarını korur.

2. Çalışmaların orijinal ve kopyaları ile ilgili dağıtım hakkı, hak sahibi veya onun onayıyla Topluluk içinde ilk satışın yapılması veya mülkiyet devrinin gerçekleştirilmesi durumu dışında tüketilemez.

FSEK madde 23 ise; **“bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını; kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir”** şeklinde yayma hakkını düzenlemiştir.

Bu düzenlemeler sonucu yayma hakkı; bir eserin aslından yahut işlenmesinden çoğaltma ile elde edilen nüshaların dağıtılması, kiralaması, ödünç verilmesi, satışa çıkarılması yahut diğer bir şekilde ticaret konusu yapılması şeklinde tanımlanabilir.

Satışa çıkarılma hakkı ile, *eserin satılmasını sağlamak için yapılan tüm hareketler* kastedilmektedir. Bu açıdan hükmün, eserin aslının veya nüshalarının bir bedel karşılığında devrinin yanında, bir şeyin temlik borcunu doğuran trampa⁶² ve bağışlama sözleşmelerini de kapsadığı doktrince kabul edilmektedir⁶³.

Kiralama hakkı, *“eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik ve ticari bir menfaat sağlanması için belirli bir süre bir diğer şahsın kullanımına hazır tutulması”*; **ödünç verme hakkı**, *“eserin belirli bir süre için doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir ekonomik veya ticari menfaat gütmeyen (avantaj sağlanmadan) kamuya açık kurumlar tarafından kamunun yararlanmasına amade tutulması”* olarak tanımlamıştır⁶⁴.

⁶² Sevil EROĞLU, *Rekabet Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması*, İstanbul, 2000, s. 104; GÖKYAYLA, age., s. 197.

⁶³ Sahir ERMAN/Çetin ÖZEK, *Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat*, İstanbul, 2000, s. 33; ATEŞ, age., s. 171. Kiralama Hakkı ile Ödünç Vermeye İlişkin Avrupa Konseyi Yönergesi'nde de kiralama ve ödünç verme haklarının, “dağıtım”dan farklı olduğu, dağıtımın, koruma kapsamındaki ürünlerin mülkiyetinin devrine ilişkin bir hak olarak tanımlandığı görülmektedir. (Yönerge md. 1.1, md. 9). Bakınız TEKİNALP/ TEKİNALP/ ATAMER/ ODER/ ODER/ OKUTAN, *Avrupa Birliği Hukuku*, Geliştirilmiş 2. Bası, İstanbul 2000, s. 714, N.52

⁶⁴ İlhan YILMAZ, “Avrupa Topluluğunda Fikri ve Sınai Haklar”, MÜATE, *Avrupa Araştırmaları Dergisi*, C.4, S.1-2, 1995-1996, s. 17 vd.

Eser sahibinin kiralama hakkından söz edebilmek için, eser ya da eser nüshasının kullanımının belli bir süre ile diğer bir şahsın kullanımına bırakılması ve doğrudan ya da dolaylı olarak ticari veya ekonomik bir menfaat sağlanması gerekmektedir⁶⁵.

Eserin ya da eserin nüshasının kullanımının belirli bir süre ile başkalarına bırakılması halinde, “*belirli süre*”den ne anlaşılması gerektiği açık değildir. Kullanımın belli bir süre ile sınırlı olmasının nedeni, kira ve ödünç vermeyi, satım veya bağıştan ayırmaktır⁶⁶. Eserin kullanımı, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik veya ticari bir menfaat sağlanması karşılığında üçüncü kişiye bırakılmaktadır. Örneğin, müzik video kasetinin (veya dvd’sinin) belirli bir bedel karşılığında bir gece için kiraya verilmesi⁶⁷.

Kamuya ödünç verme hakkı’nda ise, eserin ya da eser nüshasının doğrudan ya da dolaylı ekonomik veya ticari bir menfaat güdülmesizin, kamuya açık kurumlar kanalı ile belirli bir süre kullanıma açık tutulması esastır. Ödünç verme hakkında, eser ya da eser nüshası, kamuya açık kurumlar tarafından, örneğin kütüphaneler tarafından, kişilere herhangi bir ticari veya ekonomik bir karşılık aranmaksızın ödünç verilmekte, kamunun yararlanılmasına bırakılmaktadır. Buradaki kamu kavramından anlaşılması gereken, halk ya da cemaattir; kamu, özelin karşılığı olarak değerlendirilmelidir⁶⁸. Burada üzerinde durulması gereken, hak sahibi ile kamuya ödünçte aracılık eden kurum arasındaki ilişkide, hak sahibinin söz konusu aracı kurumdan ek bir para talep etme hakkının bulunup bulunmadığı sorundur. Her ne kadar ticari bir menfaat sağlanmamak bakımından kiradan ayrılrsa da, ticari bir menfaat sağlanmaması ödünç vermenin ivazsız olacağı anlamına da gelmemektedir⁶⁹. Çünkü “basa-mak sistemi” olarak adlandırılan ilkeye göre, eserin her yeni tüketici

⁶⁵ ARIDEMİR age., s. 108

⁶⁶ Mehmet ÖZCAN, *Avrupa Birliğinde Fikri ve Sınai Haklar*, Ankara, 1999, s. 169

⁶⁷ ARIDEMİR age., s. 109

⁶⁸ TEKİNALP, age., s. 178, N. 103

⁶⁹ ÖZCAN, age., s. 169. Ödünç vermenin Türk hukuku bakımından karşılığı, “ariyet sözleşmesi”dir. Ariyet sözleşmesi, bir şeyi kullanma hakkının devrine yönelik sözleşmedir. Taşınır ve taşınmaz eşya dışında, hakların da ariyete konu olabileceği belirtilmiştir. Ancak ariyet sözleşmesinde hakkın veya eşyanın kullanımını bedelsiz olarak karşı tarafa bırakılmaktadır. (BK madde 299). Bu nedenle ariyet, “ödünç verme” hakkını tam olarak karşılamamaktadır. (TEKİNALP, age., s. 178, N.103; EROĞLU, age., s. 103, dipnot:205).

kitlesine ulaştırılması halinde hak sahibine yeni bir bedel ödenmesi gerekmektedir⁷⁰. Örneğin kütüphanenin, eseri kişilerin yararlanmasına sunması veya eve götürme amacıyla ödünç vermesi hallerinde, eser kütüphane dışında yeni bir tüketici çevresine ulaştırılmakta, eser sahibinin eserinden ekonomik olarak yararlanması sınırlandırılmaktadır. FSEK, hak sahiplerine bu yönden bir bedel ödeneceğine yönelik açıklık taşımaktadır. Ancak tükenme ilkesini düzenleyen FSEK madde 23/II c.3'te kamuya ödünç verme hakkının saklı tutulması Kanun'un tutumunun bu yönde olabileceğini göstermektedir. Açıkça bedelden söz edilmese de ödünç verme hakkının tükenmemesi sayesinde, her yeni kitleye ulaşma halinde, eser sahibinin bedel alma hakkı olabilecektir⁷¹.

Avrupa Birliği Konseyi yayma hakkının türleri olan kiralama ve ödünç verme mali haklarının önemini 92/100/AET sayılı *Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi*'nde şöyle vurgulamıştır.

“Avrupa Birliği Konseyi;

Üye devletlerin yasaları ve uygulamaları tarafından, telif hakkı eserleri ve ilgili hakların korunması konusunda, kiralama ve ödünç vermeye yönelik sağlanan yasal korumada farklılıklar mevcut olduğundan; bu nevi farklılıklar, iç pazarda başarı kazanılmasını ve uygun işleyişi geciktiren ticaret engellerinin ve rekabet bozulmasının kaynağı olduğundan;

Telif hakkı eserlerinin kiralanması ve ödünç verilmesi ve ilgili hakların korunması konusu; özellikle eser sahipleri, icracılar, fonogram ve film yapımcıları açısından giderek artan önemli bir rol oynadığından, korsanlık artan bir tehdit haline geldiğinden;

Tespit, çoğaltım, dağıtım, yayın ve kamuya iletim hakkı ile ilgili hakların korunması konusunun yanında, kiralama ve ödünç verme haklarıyla telif hakkı eserlerinin yeterli korunmasının ve ilgili hakların korunması konusunun, benzer şekilde Topluluğun ekonomik ve kültürel gelişimi açısından büyük önem taşıdığı düşünüldüğünden;

Telif hakkı ve ilgili hakların korunmasının, farklı yararlanma biçimleri gibi yeni ekonomik gelişmelere uyum sağlaması gerektiğinden;

Yeni yaratıcı sanat eserlerinin oluşturulma temeli olarak, eser sahiplerine ve icracılara ait yaratıcı sanat çalışmaları yeterli gelir mikta-

⁷⁰ TEKİNALP, age., s. 178, N.104

⁷¹ TEKİNALP, age., s. 178, N.104. Naklen ARIDEMİR, age., s. 110

rını gerektirdiğinden; özellikle fonogram ve film yapımı için gereken yatırımlar, oldukça yüksek ve riskli olduğundan; bu gelirin korunma olasılığı ve söz konusu yatırımın tazmin edilmesi, sadece ilgili hak sahiplerinin yeterli yasal korunmaları yoluyla etkin bir şekilde garanti edilebileceğinden;

Adı geçen yaratıcı, sanatsal ve girişimcilik gerektiren faaliyetler, büyük ölçüde serbest meslek sahiplerine ait olduğundan; bu nevi faaliyetlerin takip edilmesinin, Topluluk içerisinde uyumlaştırılmış yasal koruma sağlayarak kolaylaştırılması gerektiğinden;

Üye devletlerin mevzuatlarına, söz konusu devletlerin birçoğunun telif hakkı ve ilgili haklarını içeren yasaların temelini oluşturan uluslararası konvansiyonlara tezat oluşturmayacak şekilde yaklaşılması gerektiğinden;

Kiralama ve ödünç verme hakkı, telif hakkı ile bağlantılı bazı haklar hakkındaki Topluluk yasal çerçevesi; Üye devletlerin belirli hak sahiplerine kiralama ve ödünç verme alanında sağladıkları hakların ve belirli hak sahiplerinin, ilgili hakların korunması alanında tespit, çoğaltım, dağıtım, yayın ve kamuya iletim haklarının belirlenmesinden oluşabilir;

İşbu Direktif amacı kapsamında, kiralama ve ödünç verme haklarının tanımlanması gerektiğinden;

Açıklık sağlamak amacıyla; kamu icrası ya da yayını, gösteri amaçlı sunum ya da reklâm amaçlı kullanım için, bazı sunum biçimlerinin işbu Direktif çerçevesindeki “kiralama ve ödünç verme”den, örneğin fonogram ve film gösterimi (sesli ya da sessiz, sinema eserleri, görsel-işitsel çalışmalar ya da hareketli görüntüler) hariç tutulması gerekli görüldüğünden; işbu Direktif çerçevesindeki ödünç verme, kamuya açık tesisler arasındaki iletimi içermediğinden;

Kamuya açık tesis tarafından gerçekleştirilen ödünç vermenin, meblağı işletme masraflarının karşılanmasını aşmayacak ödemeye neden olduğu durumda, işbu Direktif çerçevesinde doğrudan ya da dolaylı ekonomik ya da ticari yarar sağlanmadığından;

Söz konusu hakkın yönetimini, temsilci meslek birliklerine havale etme olasılığını elinde bulunduran eser sahipleri ve icracılar tarafından vazgeçilmez adil bedel elde edilmesini sağlayan düzenlemeler gerekli olduğundan;

Adil bedel, sözleşme sırasında ya da sözleşmeden sonra herhangi bir zamanda yapılan ödeme ya da ödemeler temel alınarak ödenebileceğinden;

Adil bedel için, fonogram ya da filmle ilgili eser sahiplerinin katkılarının öneminin hesaba katılması gerekli olduğundan;

Kamuya ödünç verme hakkında, belirli düzenlemeler yaparak, en azından eser sahiplerinin haklarının korunması da gerekli olduğundan; ancak, işbu Direktifin madde 5'ine dayanan önlemlerin, topluluk yasasına, özellikle anlaşmanın madde 7'sine uygun olması gerekli olduğundan;

Üye devletler, telif hakkına ilişkin hak sahipleri için, işbu Direktifin madde 8'inde gerekli görülenden daha geniş kapsamlı koruma sağlayabileceklerinden;

Kiralama ve ödünç verme hakları ile telif hakkına ilişkin haklar alanında uyumlaştırılmış korumanın, Üye devletler arasındaki ticarete gizli kısıtlama teşkil etmeyecek şekilde ya da Societe Cinetheque v. FNCF (4) ile bildirilen hükümden tanımlandığı şekilde, medya kullanım kronolojisi kuralına aykırı olarak uygulanmaması gerektiğinden;

İşbu Direktifi kabul etmiştir”.

Yayma hakkı, çoğu kez ticaret mevkiine koyma anlamına gelmektedir. Aslında yayma hakkı, “yayım” (FSEK madde 7/II) denilen fiili durumun fikri hukuk bakımından muteber şekilde gerçekleşmesi için, eser sahibinin göstereceği iradeyi, kullanacağı yetkiyi ifade eder⁷².

Avrupa Birliği Konseyi ise 92/100/AET sayılı *Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi*'nde madde 2 (1)'de belirtildiği şekilde, telif hakkı eserlerin, nüshalarının ve diğer konuların satışı ya da herhangi bir şekilde dağıtımı yoluyla son bulmaz.

Çoğu zaman karıştırılan yayma hakkı ile kamuya sunma (umuma arz) anlamına gelen yayımlama hakkı birbirinden farklı kavramlardır. Yayma hakkı; FSEK madde 23'e göre eser sahibinin mali haklarından birisidir ve eser sahibi, bu maddede belirtilen yetkilere sahiptir. FSEK madde 7'de düzenlenen yayımlama ise; eser sahibinin yayma hakkını kullanması ile eserin kamuya sunulması olayıdır.⁷³ Yayımlama veya yayımlama eserin alenileşmesini de sağlar.

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki; yayma hakkı çoğaltma hakkının bir uzantısıdır. Çoğaltılmış eserler amacını gerçekleştirmek için ticarete konu olmaktadır. Bu nedenle çoğaltma hakkının devredildiği

⁷² AYİTER, age., s. 133 Naklen EREL, age., s. 145

⁷³ ARIDEMİR, age., s. 94

çoğu zaman yayma hakkı da devredilmiş olmaktadır. Ancak netice olarak bu iki hakkın konuları birbirinden farklıdır ve bazı durumlarda bu haklar birbirinden ayrı ayrı devredilmek ya da lisans verilmek durumunda kalabilirler. Bu nedenle FSEK madde 52 gereğince çoğaltma ve yayma haklarının devredildiği ya da lisansının verildiği yazılı sözleşmede ayrı ayrı belirtilmelidir. Ayrıca yayma hakkı FSEK madde 33⁷⁴ uyarınca çoğaltma hakkına nazaran daha büyük sınırlamalara tabidir. Bu sınırlama sadece yayımlanmış eserler için söz konusudur. Doktrinde EREL, yayma hakkının söz konusu olabilmesi için mutlaka bir çoğaltmanın da yapılması gerektiğini, çoğaltma yapılmadan yayımın mümkün olamayacağını ve bir eserin çoğaltılmış maddi nüshalarının değil, fakat doğrudan doğruya aslının kamuya sunulduğu, mesela eserin okunduğu, çalındığı veya oynandığı hallerde yayma hakkının kullanıldığının söylemeyeceğini savunmuştur. MEMİŞ ise, çoğaltmanın yaymanın zorunlu bir aşaması olmadığını, eserin hiç çoğaltılmadan da yayma hakkına konu olabileceğini ifade etmiştir.⁷⁵

Yayma hakkı eser sahibi tarafından bizzat kullanılabilmesi gibi, süreli veya süresiz, ivazlı veya ivazsız, belirli bir ülke için veya böyle bir sınırlama olmaksızın tüm ülkeleri kapsar biçimde devir veya lisans sözleşmesi sonucu üçüncü kişilerce kullanılabilir. Yayma hakkı, ilim ve edebiyat eserleri için uygulamada “*neşir mukavelesi*” (BK madde 372 vd.) ile devredilmekte ve yayımlayan (naşir) eseri hem çoğaltma, hem de yayma taahhüdü altına girmektedir. Ancak yayım sözleşmesi hakkın devrinden farklı olarak, yalnız yayımlayan bakımından bir hak doğurmakla kalmaz, aynı zamanda onu eser sahibine karşı eseri çoğaltma ve yayma borcu altına da sokar⁷⁶.

Kanun yayma hakkını; eser nüshalarının dağıtılması, ödünç verilmesi, kiralınması, satışa çıkarılması veya herhangi bir biçimde ticaret konusu yapılması şeklinde belirttiği için, yayma hakkının mutlaka “*kâr amacı*yla” kullanılmasının gerekip gerekmediği akla gelebilir. Bizim de katıldığımız fikre göre, yayma hakkının kullanılmasındaki ticari gaye kiralama tanımında da belirttiğimiz gibi dolaylı kâr etmeyi de kapsar

⁷⁴ FSEK madde 33: “Yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutlak şekilde açıklanması şartıyla serbesttir.”

⁷⁵ EREL, age., s. 145.

⁷⁶ AYİTER, age., s. 242 Naklen EREL, age., s. 145.

şekilde geniş şekilde yorumlanmalı ve eserin kâr amacı olmaksızın dağıtılması da -ödünç verme örneğinde görüleceği üzere- bu kapsamda sayılmalıdır⁷⁷. Zira yayma hakkının amacı çoğaltılmış eser nüshalarının herhangi bir yoldan kamuya sunulmasıdır ve diğer mali haklar nasıl kâr amacı olmaksızın veya karşılıksız olarak başkalarına devir edilebiliyorsa, yayma hakkı da bu yolla devredilebilir. Yayma hakkının kâr sağlamak amacıyla kullanıldığı hallerde de bu kârın dolaylı veya doğrudan olması ya da fiilen gerçekleşmiş olup olmaması önemli değildir.

Yayma hakkının kullanılarak müzik eserinin ticari hayata sunulması halinde, üçüncü şahıslar satın alma yoluyla eline geçen fiziken çoğaltılmış plak, kaset, bant, cd gibi nüshalar (kopyalar) üzerinde mülkiyet hakkı elde etmektedirler ve bu üçüncü şahıslar eline geçen eser örneklerini başkalarına kiralayabilir veya ödünç verebilirler. Mesela, birçok müzik eserinin içerdiği kaset veya cd satın alındıktan sonra, eser sahibinin manevi haklarını ihlal etmemek şartıyla bunun istenilen yer, zaman ve fiyat üzerinden tekrar satılması, kiralınması, ariyet verilmesi mümkündür. Ancak çoğaltılmış nüshayı (kopyayı) satın alan, doğal olarak bunu çoğaltma hakkına sahip değildir. Yayma hakkının bu şekilde tahditsiz olarak devri, hakkın eser sahibi bakımından tükenmiş olmasını ifade eder.⁷⁸ Alman Hukukunda “tükenme ilkesi” (Erschöpfungsgrundsatz)⁷⁹ olarak adlandırılan bu esas, FSEK madde 23/II tarafından da hükme bağlanmıştır: *“Belirli nüshaların hak sahibinin yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek ülke sınırları içinde ilk satışı ya da dağıtım yapıldıktan sonra bunların yeniden satışı ya da kiralınması biçiminde yayımı, -kiralama ve kamuya ödünç verme hakkı saklı kalmak şartıyla-, eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez.”*

Bu kapsamda belirtmemiz gerekir ki, yurt dışında çoğaltılan eserler, Türkiye’ye ithal edilirse, ilk satış Türkiye’de gerçekleşmediği için hakkın tükenmesinden söz edilemez. Eser Türkiye’de hak sahibi tarafından veya onun yetkilendirdiği kişi tarafından piyasaya sürüldükten sonra ihraç edilir ve aynı eser ithal edilirse, hakkın tükenmiş olduğu kabul edilmelidir. Ancak söz konusu eserin bir kısım nüshaları Türkiye’de çoğaltılıp piyasaya sürülmekte, bir kısım nüshalar ise, yurt dışında çoğaltılıp Türkiye’ye ithal edilirse, yurt dışında çoğaltılan nüshalar bakı-

⁷⁷ ARSLANLI, age., s. 102 Naklen EREL, age., s. 147.

⁷⁸ EREL, age., s. 147.

⁷⁹ AYİTER, age., s. 135 Naklen EREL, age., s. 147.

mından tükenme ilkesi gerçekleşmez. Çünkü, ilke, sadece Türkiye’de hak sahibinin rızasıyla piyasaya sürülen eser nüshaları bakımından geçerlidir⁸⁰.

FSEK 23/III’e göre, bir eserin veya çoğaltılmış kopyalarının kiralanması veya ödünç verilmesi yoluyla yayma hakkı kullanımı, eser sahibinin çoğaltma hakkına zarar verecek şekilde eserin yaygın kopyalanmasına yol açamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kültür Bakanlığı’nca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Biraz da müzik eserlerinin bilgisayar veya cep telefonları üzerinde kullandırılmasına⁸¹ ve bunun yayma hakkı ile ilişkilerine değinelim.

ARKAN’a göre yayma hakkı konusunda çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri, yaymanın konusunun hangi nesnelerin oluşturabileceği hakkında çıkmaktadır. Daha açık bir ifade ile yaymanın, maddi bir cisme bürünmüş nüshalar açısından söz konusu olduğu konusunda bir tereddüt yoktur⁸². Ancak madden şekillenmemiş eser ve icraların yayma hakkına konu olup olmayacağı önemli tereddütlere yol açabilecek niteliktedir. Elektronik ticaretin⁸³ yaygınlaşması ile bu konu günümüzde pratik açıdan son derece önemli hale gelmiştir. Sorunu şöyle somutlaştırabiliriz: Bir eserin icrasını içeren kaset, video kaset veya DVD gibi elle

⁸⁰ Ülkesel tükenmede hak sahibinin rızası ile ülke içinde piyasaya sürülmüş eserler ile ülke dışında piyasaya sürülmüş eserlerin hukuki kaderlerinin birbirinden farklı olduğu hakkında bakınız; Fahrettin KAYHAN, “Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthal ve Marka Hakkının Tükenmesi”, AB FM ve RHD, C. 1, S. 1, s. 51-71. Naklen ARIDEMİR, age., s. 119.

⁸¹ İnternet üzerinden veya cep telefonları ile müzik dinletme ve izletme yöntemleri; Tek dinleme, Çok dinleme, Dinleme ve aktarma, Dinleme ve bilgisayar harddiskine kopyalama, Dinleme, aktarma ve süre ve sayı ile sınırlı cd’ye kopyalama, Full track, Ring back tone/rbt/pgs, Rbt (aylık), Streaming, Kısa klip izletme, Sekreter servisi, IVR üzerinden 'dinletme' uygulamaları olarak kısaca sayılabilir.

⁸² REHBINDER, (Schweizerisches Urheberrecht), § 14 N. 121; EREL, s. 146; GÖK-YAYLA, s. 169. Naklen ARKAN, age., s. 86

⁸³ Bilgisayar ve iletişim ağıları aracılığıyla elektronik ticaretin konusunu oluşturmaktadır. (GÜNGÖR, G., “İnternet Yoluyla Girişilen Elektronik Tüketici Akitleri ve Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması”, AÜHFD, 1997, C.46, S. 1-4, s. 101). Bu tarzdaki ticaret iki türlü olabilmektedir. İlk türde, sipariş sanal mağazalarda gezilerek elektronik olarak verilmekte fakat sipariş üzerine mal normal şekilde müşteriye teslim edilmektedir. İkinci türde ise, internete özgü mal ve hizmetler internet üzerinden talep edenin erişimine sunulmaktadır. ÖZDİLEK, s. 21 vd.; Naklen ARKAN, age., s. 86

tutulur bir nesneyi herhangi bir dükkana giderek satın almak veya kiralamanın hatta internet vasıtasıyla ısmarlayarak teslim almanın yayma kavramı altında değerlendirileceğine şüphe yoktur. Ancak söz konusu icrayı elektronik olarak kiralamak da yayma kapsamına girecek midir?

Günümüzde dijital eser ve icralar giderek maddi kopyaların yerini almaktadır. Kişiler artık, bir telefon ya da bilgisayar vasıtasıyla istedikleri eser ya da icraları, diledikleri saatte televizyon, cep telefonu veya bilgisayar ekranlarına getirebilmektedirler. Ülkemizde de giderek çoğalan bu tarz servisler, yurt dışında çok daha yaygındır. Bu servislere, “talebe bağlı hizmet” olarak tercüme edebileceğimiz “on demand service” adı verilmektedir. İlk bakışta, bir video kaset satan veya kiralayan bir mağazaya giderek, kaset kiralamakla, telefon veya internet vasıtasıyla kiralarak bir icranın elektronik olarak, televizyon veya bilgisayar ortamına getirilmesini sağlamak arasında bir fark yok gibi görünmektedir. Ayrıca burada adı üstünde bir kiralamanın söz konusu olduğu; yani seçilen bir icradan belirli bir süre yararlanmak için karşılığında bir bedel ödeneceği, verilen hizmetin bedelsiz olması halinde ödücün söz konusu olacağı ki, tüm bu kavramların aslında yayma hakkına ilişkin olduklarını ileri sürmek de mümkündür⁸⁴. Yalnız bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta, gerek ulusal gerek uluslararası düzenlemelerde ve gerekse Avrupa Birliği Hukuku’nda yaymanın ancak maddi bir cisme bürünmüş nüshalar açısından söz konusu olabileceği; yani vücutsuz icraların dağıtılmasının, teknik olarak yayma hakkına konu olamayacağı genellikle kabul edilmektedir. Örneğin, Alman Eser Sahibi Hakları ve Akraba Hakları Kanunu’nun genel olarak eser sahibi haklarını düzenleyen 15. paragrafında madden cisimlenmiş eserlerin yayma hakkına konu olabileceği düzenlenmektedir⁸⁵. WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın yayma hakkı ile ilgili gerekçesinde de bu hakkın madden cisimlenmiş objelere ilişkin olduğu açıkça ifade edilmiştir⁸⁶. Keza bağlantılı hak sahiplerinin haklarını düzenleyen 92/100 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Eser Sahiplerinin Haklarına Bağlantılı Haklara İlişkin Konsey Direktifi”nin hazırlık çalışmaları sıra-

⁸⁴ AKİPEK/DARDAĞAN, age., (Sanal Ortamda Telif Hakları), s. 59. Naklen ARKAN, age., s. 86

⁸⁵ Eser sahibinin yayma hakkına ilişkin olarak bu yönde BARRELET/EGLOFF, Art. 10 N. 16 Naklen ARKAN, age., s. 86

⁸⁶ Gerekçe için bkz. STERLING, (World Copyright Law) § 40 N 17 veya http://www.wipo.org/eng/diplconf/distrib/97dc.htm#a2_e Naklen ARKAN, age., s. 86

sında da Konsey’de yaymanın elle tutulur nüshalar için söz konusu olduğu açıklanmıştır. Direktif tasarısının hazırlanması çalışmalarına aktif olarak katılan REINBOTHE ve LEWINSKI ise, bu tutuma karşı çıkmış ve elektronik kiralama ve ödünç verme eylemlerinin de yayma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir⁸⁷. Ancak bugün fikri hukuk mevzuatlarına, internet ve benzeri ortamlarda elektronik ticarete ya da iletişime konu olan eser ve bağlantılı hak sahiplerini korumak için, yaymanın bir türü olan “kiralama” yerine Türkçe’ye **“kamunun erişimine sunma”** şeklinde tercüme edebileceğimiz umuma iletim hakkının bir türü olan yeni bir hak türü girmiştir⁸⁸.

Bu hak çeşitli mevzuatlarda bazen tamamen bağımsız; bazılarında ise yayın hakkıyla birlikte düzenlenmiştir. Aşağıda bu hak incelenirken konuyla ilgili detaylı bilgi verilecektir. Ancak şimdiden şu kadarı söylenmelidir ki; ülkemizde de açıkça düzenlenen bu hak karşısında, ARKAN’ın belirttiği gibi, maddi olmayan objeler için yayma hakkından bahsedilemeyeceği meydandadır ve zaten buna ihtiyaç da kalmamıştır. Sonuç olarak internet kullanıcılarının kendi bilgisayarlarına indirmelerine olanak sağlayacak tarzda bir icranın bilgisayara yüklenmesi; bunun gibi, bir telefon ya da bilgisayar ağı yardımıyla erişebilen ve giderek maddi kopyaların yerini alan dijital eser ve icraların, elektronik olarak kiralanması ya da ödünç verilmesi yayma kapsamına girmez⁸⁹. Biz de bu görüşe katılıyoruz. Bilgisayar veya cep telefonları üzerinden müzik eserlerinin çoğaltılarak kullanıcılar tarafından izlenmesi veya dinlenmesi yayma hakkının bir türü olan “kiralama” değil bir “umuma iletim” şeklidir. Özellikle hak takip sistemlerinin kullanılmaya başlanması ile; herhangi bir müzik eseri, ya bir süreliğine veya sınırlı sayıda veya sınırsız olarak dinlenmek veya izlenmek üzere ilgililerin kullanımına açılmaktadır. Bu kullandırma biçimi kimi zaman satış olarak da adlandırılmaktadır, ancak satış hukuki işleminin temel şartı olan mülkiyeti devretme bu işlemlerde olmadığından, bu işlem satıştan daha çok “kamunun erişimine sunma” veya “gerçek kişilerin erişimine açma” olarak adlandırılan bir umuma iletim şeklidir.

⁸⁷ REINBOTHE/von LEWINSKI, s. 41 vd. ve 101 vd.; FICSOR, s. 132. Naklen ARKAN, age., s. 86

⁸⁸ ARKAN, age., s. 87

⁸⁹ ARKAN, age., s. 88

92/100/AET sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi'nin 4. maddesi ise yayma haklarının türü olan kiralamaya ilişkin eser sahiplerinin mutlaka adil (makul) bir bedel alma gereğini şu şekilde düzenlemiştir.

“1. Eser sahibinin ya da icracının fonogram, film ya da kopyasına ilişkin kiralama hakkını fonogram ya da film yapımcısına aktardığı ya da devrettiği durumda, söz konusu eser sahibi ya da icracı, kiralama konusunda adil bedel elde etmek için, bu hakkı elinde tutar.

2. Kiralama konusunda adil bedel elde etme hakkı, eser sahipleri ya da icracıları temsil eden meslek birliklerine havale edilebilir.

3. Adil bedel elde etme hakkının yönetimi, eser sahiplerini ya da icracıları temsil eden meslek birliklerine havale edilebilir.

4. Üye devletler, söz konusu bedelin kimden talep edilip alınacağı konusu yanında, adil bedel elde etme hakkının meslek birlikleri tarafından yönetiminin uygulama sınırlarını düzenleyebilirler”.

Aynı Direktif 5. maddesinde de ödünç verme hakkındaki bedel alma düzenlemelerini şu şekilde kural altına almıştır.

“1. Üye devletler, en azından eser sahiplerinin bu nevi ödünç verme için bedel elde etmeleri şartıyla, kamuya ödünç verme hakkında madde 1’de sağlanan münhasır hakkı elden alır. Üye devletler, kültürel tanıtım amaçlarını göz önünde bulundurarak, söz konusu bedeli belirleme hakkına sahiplerdir.

2. Üye devletler, fonogramlara, filmlere ve bilgisayar programlarına ilişkin madde 1’de sağlanan münhasır ödünç verme hakkını uygulamadıklarında, en azından eser sahipleri için bir bedel sunarlar.

3. Üye devletler, bazı kuruluşları, 1. ve 2. fıkralarda göndermede bulunulan bedel ödemesinden muaf tutabilirler”.

Yayma hakkı konusunda eser sahibinden izin alma zorunluluğu; Bern Sözleşmesi’nin 10. maddesinde bulunan basında haber verme, eğitim amacı gibi bazı sebeplerle sınırlanmış veya ortadan kaldırılmıştır. Benzer sınırlamalar ve eser sahibinden izin alma gerektirmeyen yararlanma biçimleri FSEK’de de bulunmaktadır. Eser sahibinin izin verme ve yasaklama hakkına ilişkin sınırlamalar hakkında önceden anlatılan diğer mali haklar içinde genel olarak açıklamalar yapıldığından ve ileride genel fikirselsel ve sanatsal haklar sınırlama sebepleri bir bölüm halinde anlatılacağından, daha geniş bilgi için bu kısımlara ve bölümlere bakılabilir.

92/100/AET sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi'nin 10. maddesi ise, yayma haklarının türü olan kiralama ve ödünç verme hakkındaki, eser sahiplerinin münhasır izin verme ve yasaklama haklarına ilişkin çeşitli sınırlama sebeplerini şu şekilde düzenlemiştir.

“1. Üye devletler,

a) özel kullanım;

b) güncel olaylar hakkında haber verilmesine ilişkin olarak, kısa alıntılarının kullanımı;

c) bir yayın kuruluşu tarafından kendi tesislerinin olanaklarıyla ve kendi yayınları için gerçekleştirilen geçici tespit;

d) sadece eğitim ya da bilimsel araştırma amaçlı kullanım, hakkında, ... haklara sınırlama getirebilirler”.

4. Temsil Hakkı

Bern Sözleşmesi'nin 11. maddesi gereğince; dramatik-müzik ve müzik eserlerinin sahipleri:

- eserlerinin her türlü yöntem ve araçla toplum önünde icrasına;
- eserlerinin toplum önündeki icrasının her türlü iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidirler.

Dramatik müzik eserlerinin sahipleri, özgün eserleri üzerindeki haklarının devamı süresince, bu eserlerin çevirileri üzerinde de aynı haklardan yararlanırlar.

Bern Sözleşmesi'nin 11. (tekrar) maddesine göre de; edebiyat ve sanat eserleri sahipleri: ... radyo ve televizyon ile yayınlanan eserin hoparlör ile veya diğer benzer bir araçla ya da işaret, ses ve görüntü nakleden bir araçla topluma iletimine izin verme hususunda inhisari hak sahibidir.

Aynı maddenin 2. paragrafına göre; yukarıdaki paragrafta öngörülen hakların uygulanma şartları Birlik ülkelerinin mevzuatı ile düzenlenir; ancak bu şartlar yalnızca öngörülen ülkelerde uygulanır. Bu şartlar, hiçbir şekilde eser sahibinin manevi haklarını veya eser sahibinin, bir anlaşmanın yokluğu halinde, yetkili makam tarafından tespit edilen uygun ücreti elde etme hakkını haleldar edemez.

FSEK madde 24 ise temsil hakkını; “bir eseri doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi yerlerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek” şeklinde tanımlamaktadır.

Burada iki tip temsil hakkı söz konusudur. İlki “**doğrudan temsil**”dir ve müzik eserleri için uygulaması çok fazladır. Örneğin, bir şarkının konserde sanatçı tarafından söylenmesi. İkinci tür temsil ise “**dolaylı temsil**” olup, radyo, televizyon ya da internet gibi yayın araçları ile bir müzik eserinin dinlettirilmesi veya seyrettirilmesidir. Ancak zamanla dolaylı temsilin içinde olan “kitle iletişim araçlarıyla (radyo, televizyon ve günümüzde internet) yayın” o kadar genişlemiş ve karmaşıklaşmıştır ki zorunlu olarak uluslararası sözleşmelerde olduğu gibi FSEK’de de ayrı bir başlık altında “**umuma iletim**” adıyla düzenlenmiştir.

Kitle iletişim araçlarıyla umuma iletimde yayın, umumi yerde veya bireysel bir yerde olabilir. Temsil hakkında ise yapılan yayının (okuma, çalma, oynama, gösterme) umumi yerde olması gereklidir. Kitle iletişim araçlarıyla yapılan umuma iletim belirli bir kişi veya yere yönelik olmayan genel yayın araçları kullanılarak yapılır. Temsilde ise belirli bir yere (mekana, alana) özgü olarak işaret, ses veya resim nakline yarayan “aletler” kullanılır. Umuma iletimde hedef umum yani bir hak topluluğudur, temsilde ise hedef “*umumi yer*”dir. Özellikle FSEK 25. maddesi ile kitle iletişim araçlarıyla umuma iletim ayrı bir hak olarak düzenlendiğinden, “umumi yer” kavramı ve “belirli bir topluluğa yönelik yayın aleti kullanımı” temsil hakkını umuma iletim hakkından ayırır. Bu açıklamaları şu şekilde örnekleyebiliriz. Belediyenin kurduğu bir çadırdaki bir konser verilmesi doğrudan temsildir. Bu konserin çeşitli araçlarla kaydedilerek aynı anda çadırın dışında biriken halka ekranlarda yayını ise dolaylı temsildir. Bu konserin yayın araçlarıyla canlı olarak televizyon veya internette yayını ise umuma iletimdir.

Kanun’un açıklaması dahilinde; **temsil**’i; “eserin yayım (yayın-lama) dışında kalan yollardan halka hitap edecek şekilde kamuya sunulması⁹⁰” şeklinde tanımlayabiliriz. Kanun eserin okunması, çalınması, oynanması ve gösterilmesinden söz etmekle beraber; bu sayma temsil hakkını tarif bakımındandır ve sınırlayıcı değildir. Eseri bunlar dışındaki yollardan da duyularla algılanmaya uygun hale getiren her fiil temsil sayılır⁹¹.

FSEK 24/2 gereğince, “temsilin umuma arzedilmek üzere vukubulduğu mahalden başka bir yere herhangi bir teknik vasıta ile nakli de eser sahibine aittir”.

⁹⁰ AYİTER, age., s. 136 Naklen EREL, age., s. 150

⁹¹ ARSLANLI, age., s. 108; AYİTER, age., s. 136-137 Naklen EREL, age., s. 150.

Temsil hakkı eser sahibi tarafından bizzat kullanabileceği gibi, üçüncü şahıslara devir edebilir veya lisans verilebilir. FSEK madde 24/1 hükmü eser sahibinin temsil hakkını, eserin gerek aslını ve gerekse işlemlerini kapsar şekilde düzenlemiştir. Mesela, işleme suretiyle meydana getirilen bir müzik eserinin umuma sunumu, yani doğrudan doğruya temsili olanaklıdır. Yine işleme eserin başka türlü, örneğin yayım yoluyla değerlendirilmesi mümkünken, izinsiz gösterilmesi hukuka aykırıdır⁹².

Temsilde iki temel unsur bulunmaktadır:

- Eserden yararlanma, geçici olmalı ve yararlanma anıyla sınırlı kalmalıdır.
- Temsil, kamunun istifadesine elverişli umumi bir yerde gerçekleşmelidir.

Öğretide, umumi sayılmayacak bir yerde yapılan temsile rağmen, eserin burada kamuya sunulmak niyetiyle temsil edildiği anlaşıyorsa; umumi yer unsuru gerçekleşmiş kabul edilmektedir⁹³. Ama eserin tek bir şahsa veya dar bir şahıs topluluğuna icra edilmesi temsil sayılmamaktadır.

FSEK 24 son fıkra düzenlemesi temsil hakkının kullanımında sınırlamalar getirmektedir. Buna göre; “*temsil hakkı; eser sahibinin veya meslek birliğine üye olması halinde, yetki belgesinde belirttiği yetkiler çerçevesinde meslek birliğinin yazılı izni olmadan, diğer gerçek ve tüzel kişilerce kullanılamaz. Ancak, 33 üncü ve 43 üncü maddelerdeki hükümler saklıdır*”.

Burada belirtilen 33. maddeye baktığımızda “*yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüzyüze eğitim ve öğretim amacıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutlak şekilde açıklanması şartıyla serbesttir*” şeklinde bir istisnayı görmekteyiz. Buna göre; bazı hallerde, gerek özel yararlar gerekse kamu yararı bakımından eser sahibinden temsil için izin almaya ve telif ücreti ödemeye gerek yoktur. Yüz yüze eğitim öğretim amacıyla öğrencilere yahut doğrudan veya dolaylı olarak kâr amacı güdülmeksizin bir konferans veya oyun esnasında bir müzik eserinin ilgililere dinlettirilmesi bu düzenlemeye örnek kullanım biçimleridir. Burada ihmal edilmemesi gereken eser sahibinin ve eserin adının verilmesidir, yoksa eylem hukuka aykırı olur.

⁹² Bkz. EREL, age., s. 150.

⁹³ SULUK/ORHAN, age., s. 399; EREL, age., s. 151.

FSEK 24. maddesinin son fıkrasında istisna ile gösterilen 43. maddenin ise, sonradan 43. madde metninde yapılan değişiklik sonrasında 24. madde ile bir ilgisi kalmamıştır. Fakat bizde hukuk mühendisliği olmadığından FSEK 24. maddeden 43. maddenin silinmesi unutulmuştur. İnşallah “Hukuk Devleti” yerine “Kanun Devleti” uygulamasını yeğleyen bir yargı mensubu tarafından kimsenin canı yakılmadan 24. madde düzeltilir.

Ayrıca FSEK madde 35/4’te, iktibas serbestisi kavramıyla temsil hakkı için eser sahibinden izin alınması gereğine bir başka istisna tanınmıştır. Bu düzenlemeye göre, “alenileşmiş” güzel sanat eserlerini ve bu eserin içinde yer alıyorsa müzik eserini de ilmi konferans veya derslerde konuyu aydınlatmak için projeksiyon gibi cihazlarla göstermek serbesttir. Burada önemli olan, göstermenin “umumi yer”de yapılmasıdır; zira eserin umumi olmayan bir yerde gösterilmesi zaten temsil kapsamına girmez. Öte yandan; alenileşmemiş bir eserin nerede olursa olsun izinsiz gösterilmesi ise “eseri kamuya sunma / umuma arz” hakkının ihlali niteliğindedir.

Temsil hakkı, eserin içeriği hakkında bilgi verme yetkisiyle de sınırlandırılmıştır. FSEK madde 14/II gereğince; bütünü veya esaslı bir kısmı henüz alenileşmemiş bir eserin içeriği hakkında sadece eser sahibi bilgi verebilir. Eser alenileştikten sonra bu yetkiye üçüncü şahıslar da sahiptir. Şayet alenileşmiş bir eserin muhtevası hakkında bilgi verme eserin temsilini gerektiriyorsa, mesela umumi yerde verilen bir konferansta bilgi vermek amacıyla eserin gösterimi söz konusu olursa, eser sahibinin izni olmadan gerçekleşen bu temsil, madde 35/4 gereğince temsil hakkının sınırlaması sayılabilir⁹⁴.

Umuma Açık Yerlerde Müzik Eserlerinin Kullanılması

Temsil hakkı konusundaki önemli bir konu da müzik eserlerinin; mağazalar, işyerleri, spor salonları, pastahaneler, kafeler, restoranlar, gece klüpleri, diskotekler ve oteller gibi umumi mahallerde (yerlerde/umuma açık yerlerde) çeşitli araçlarla dinletilmesi ve gösterilmesidir.

TEKİNALP’e göre; fikir ve sanat eserleri hukukundaki gelişmeler ile teknik buluşların ulaştığı düzey, eser sahibinin korunmasına yeni bir boyut kazandırmıştır. Bir bestenin CD’sinin veya ses kasetlerinin otellerin lobilerinde, belli bölümlerinde, müzikli çaylarda, düğünlerde, resto-

⁹⁴ Bkz. ARSLANLI, age., s. 109 Naklen EREL, age., s. 155.

ranlarda, kahvelerde, pastanelerde, defilelerde çalınmaları; görüntülü video kasetlerinin çeşitli yerlerde gösterilmeleri olağan ve yaygındır. Bu hallerde eser sahibinin mali haklarının zedelendiği eskiden beri kabul edilmekte ve eser sahibini korumak için kanunlara hükümler konulmaktadır. Çünkü, örnekleri verilen genel yerler; çalınan müzik parçaları ve gösterime konulan video kasetleri sebebiyle ya ek bir kazanç sağlamakta ya da bunlar –düğün salonlarında olduğu gibi- işletmenin vazgeçilmez araçları niteliğini taşımaktadır. **Müzik eşliğinde defile veya defile içine yerleştirilmiş bir bale epizodu izleyicileri cezbedebilmekte, video kasetinden film gösteren kahveler daha çok müşteri bulabilmekte, düğünlerde CD’ler çalınarak dans edilmektedir. Bu kuruluşa ek bir kazanç sağlamasa bile bir otelin lobisinde otururken, danışma önünde beklerken veya berberinde traş olurken gelen hafif bir müzik müşterilerin hoşuna gitmekte, otele ilgiyi ve güveni artırmaktadır**⁹⁵.

Zaten FSEK madde 41/2’de de “fıkrî mülkiyete konu eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası olması ve ürün veya hizmete katkısı” ibareleriyle, umumi yerlerde çalınan müziğin işletmeye katkısı olacağı ama bu katkının oranına, niteliği ya da derecelerine göre işletmelerin sınıflandırılacağı (gruplara ayrılacağı) ve meslek birliklerinin umumi yerler için müzikle yapılan katkı oranında sınıflara uygun tarife yapacağı ve umumi yerlerin bu bedelleri ödeyeceği düzenlenmiştir.

Bu açıklamalarımız doğrultusunda FSEK madde 24 ve 41; umuma açık yerlerde müzik eserlerinin kullanılması için eser sahiplerinden izin alınmasını ve bir bedel ödenmesini düzenlemiştir.

FSEK 41. maddesi şöyledir:

“Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı malî hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar.

Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanan ve/veya ileten umuma açık mahaller; mahallin bulunduğu bölgenin özelliği, mahallin nitelik ve niceliği, fıkrî mülkiyete konu eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası ve

⁹⁵ TEKİNALP, age., s. 245

ürün veya hizmete katkısı olup olmadığı ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle sınıflandırılır veya sınıflandırma dışı bırakılır.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımından ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile umuma açık mahaller arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

Tarifelere ilişkin sözleşmelerde takvim yılı esas alınır ve bu tarifeler takvim yılı başından itibaren geçerli olur.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasını teminen:

1. Meslek birlikleri temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bilgileri, Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimler her üç ayda bir güncellenir ve Bakanlıkça oluşturulan ortak bir veri tabanı üzerinden ilgili taraflara açılır.

2. Eser sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya bağlantılı hak sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya aynı sektörlerde faaliyet gösteren meslek birlikleri, biraraya gelerek protokole bağlamak suretiyle ortak tarifeler belirleyebilirler. Ortak tarifeler protokole taraf meslek birlikleri açısından bağlayıcıdır.

Meslek birlikleri, tarifeler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildirirler ve kamuoyuna duyururlar. Umuma açık mahaller, müzakere ve sözleşme yapılmasına ilişkin verecekleri bağlayıcı nitelikteki yetki belgeleri ile üye oldukları meslek kuruluşları aracılığıyla da tarifeleri veya ortak tarifeleri müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler. Ancak, tarifelerin götürü usulde tespit edilmesi halinde umuma açık mahaller sadece meslek kuruluşları aracılığı ile müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler.

Onuncu ayda umuma açık mahaller veya meslek kuruluşları ile meslek birlikleri arasında tarifeler veya ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde, en geç bu ayın sonuna kadar, meslek birlikleri ve/veya meslek kuruluşları tarafından bu tarifelerin Bakanlıkça oluşturulacak uzlaştırma komisyonunda müzakere edilmesi talep edilebilir.

Uzlaştırma komisyonu, taraflardan birinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, tarifeleri müzakere etmek üzere, Bakanlık tarafından talep tarihinden itibaren onbeş gün içinde oluşturulur. Komisyon Bakanlıktan bir, Rekabet Kurumundan iki temsilci ve ilgili meslek birlikleri ile kullanıcıları temsil eden meslek kuruluşlarının birer temsilcisinden oluşur. Bakanlık temsilcisi aynı zamanda komisyon başkanıdır. Aynı usulle, komisyon üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık ilgili birimi tarafından yürütülür. Komisyon, oluşturulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde, raporunu hazırlayarak, Bakanlığa ve taraflara bildirir. Umuma açık mahaller ve meslek birlikleri, Komisyon raporunun açıklandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde, meslek birliklerinin açıklamış oldukları tarifeleri veya müzakereler neticesinde mutabakata vardıkları tarifeleri sözleşmeye bağlayabilirler. Meslek birliklerince belirlenen tarife veya ortak tarifeler üzerinden sözleşmenin yapılmaması halinde, taraflar yargı yoluna başvurabilirler. Yargılama sürecinde, bir önceki yıl sözleşme yapmış olan mahaller, ilgili meslek birlikleri aksini bildirmedikçe, dava konusu tarifenin 1/4'ünü dava sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir meslek birlikleri adına açılmış banka hesabına yatırmak suretiyle eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilir ve/veya iletebilirler. Bir önceki yıl sözleşme yapmamış umuma açık mahaller ile ilk defa sözleşme yapacak umuma açık mahallerin bu fıkra da öngörüldüğü şekilde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilmeleri ve/veya iletebilmeleri ise ilgili meslek birliklerinin iznine bağlıdır. Dava sonuçlanıncaya kadar bu şekilde ödenen miktar, mahkeme kararıyla tespit edilen tarife bedelinden mahsup edilir.

Tarifelerin tespit edilmesinde ve uzlaşmazlıkların hallinde, bu Kanunun 42/A maddesinin üçüncü fıkrasında⁹⁶ yer alan, tarife tespitine ilişkin esaslar dikkate alınır.

⁹⁶ FSEK 42/A 3. fıkrası: Tarifelerin tespit edilmesinde; tarifelerin uluslararası uygulamaların ülkenin ekonomik ve toplumsal koşullarına uyarlanabilirliği göz önünde bulundurularak makul seviyede belirlenmesi ile teknolojik alandaki değişimlerin yanı sıra eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların yaratıldığı ve kullanıldığı sektörlerin yapısını tahrip edici, üretimi ve kullanımı engelleyici ve genel kabul görmüş uygulamalara zarar verici bir etki yaratılmaması, rekabeti bozucu şartlar oluşturulmaması, yapılan sınıflandırma, ilgili sektörlerdeki ürün fiyatları ve bu sektörlerin gayrisafi millî hâsıladaki payı, eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya ile-

Mahallerde kullanılan ve/veya iletimi yapılan eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar üzerinde hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, bunların kullanımına ve/veya iletimine ilişkin ödemelerin yapılmasını ancak yetki verdikleri meslek birlikleri aracılığı ile talep edebilirler. Sinema eserleri bakımından bu fıkranın uygulanması zorunlu değildir.

Sınıflandırma, uzlaştırma komisyonuna başvuru halinde Bakanlıkça alınacak ücretler ve uzlaştırma komisyonunun çalışması ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.”

Bu düzenleme ile; elektrik, benzin ve doğalgazda olduğu gibi müzik ürünleri fiyatının tespitine ve satış şartlarına Devlet açıkça müdahale etmiştir. Düzenlemede “Uzlaştırma Komisyonu” adı ile ne idüğü belirsiz bir komisyon kurularak tarifeler konusunda bir rapor yazacağından bahsedilmektedir. Doğaldır ki, dava açma sürecini ve davanın yürütülmesini geciktirebilecek böyle bir komisyonun oluşturacağı raporun da taraflar üzerinde hiçbir baskısı ve bağlayıcılığı olmayacaktır.

Daha da önemlisi madde metni incelendiğinde görüleceği üzere, satış şartlarında anlaşılamamaları halinde müzik eserlerini kullanmak isteyenler mahkemeye bir para depo ederek eser ve bağlantılı hak sahipleri karşı çıksa bile onların ürünlerini kullanmaya başlayabilmektedirler. Bu tür müdahaleler üstün bir kamusal yararı sağlamak ve dar gelirliyi korumak amacıyla ancak elektrik, benzin ve doğalgaz gibi kamusal tüketim maddeleri için yapılabilir. Müzik eserini kullanmada ise üstün bir kamu yararı yoktur.

Bu yasal düzenlemeyi ayrıntılandırmak için ayrıca bir de Yönetmelik yapılmıştır.

08.06.2004 tarihinde çıkarılan “*Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik*” gereğince umuma açık yerler kendi aralarında sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırma doğrultusunda Meslek Birlikleri umumi mahaller/yerler için tarifeler belirlemektedirler. Yönetmelik, umuma açık mahalleri; konaklama tesisleri (oteller, tatil köyleri, moteller, apart oteller, hosteller, pansiyonlar, kampingler, belediye belgeli tesisler -oda sayısı

ve m²'yi tarife belirlemede kriter almış-), yeme içme, eğlence tesisleri (lokanta, restoran, kafe, eğlence yeri, gece klübü, diskotek, pavyon, gazino, bar, taverna, kabare), sağlık ve spor merkezleri (spor merkezleri, termal turizm tesisleri, sağlık rehabilitasyon ve bakım tesisleri, temalı plaj tesisleri), kongre, sergi ve gösteri alanları ve merkezleri, rekreasyon tesisleri, (tatil merkezleri, eğlence merkezleri, temalı parklar, günübirlik tesisler, kırsal turizm tesisleri, yüzer tesisler, kış sporları ve kayak merkezleri, mekanik tesisler), özel tesisler (turizm kompleksleri, mola noktaları, özel belgeli diğer tesisler), ticaret merkezleri (alışveriş merkezleri, marketler, mağazalar), terminaller, eğitim ve öğretim kurumlarının ticari amaçla kullanılan dinlenme, sinema ve gösteri yerleri ve 50 m²'den büyük umuma açık diğer mahaller (burada da m² ve çalışma süreleri kriter alınmış) şeklinde sayarak örnekleme yolu ile belirlenmiştir. Bu belirleme sınırlı sayıda olmayıp, başka bir işletme de (kuaför, internet cafe, ulaşım aracı gibi) umuma açık mahal niteliğini taşıyorsa tarife dahil edilecektir.

Bu Yönetmeliğin 8. maddesine göre; meslek birlikleri sözleşme yapılabilmesi için idaresini sağladıkları haklara ilişkin ücret tarifelerini süresinde belirlemek ve belirlenen tarifeleri ve bu tarifelerdeki her türlü değişikliği süresinde duyurmakla yükümlüdür. Meslek birlikleri bu tarifelerde, kendi maddi ve/veya manevi menfaatleri bakımından gerekli gördükleri her türlü indirim veya ödeme kolaylığını sağlayabilir. Tarifelerin tespit edilmesinde; tarifelerin uluslararası uygulamaların ülkenin ekonomik ve toplumsal koşullarına uyarlanabilirliği göz önünde bulundurularak makul seviyede belirlenmesi ile teknolojik alandaki değişimlerin yanı sıra eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların yaratıldığı ve kullanıldığı sektörlerin yapısını tahrip edici, üretimi ve kullanımı engelleyici ve genel kabul görmüş uygulamalara zarar verici bir etki yaratılmaması, rekabeti bozucu şartlar oluşturulmaması, yapılan sınıflandırma (ile), ilgili sektörlerdeki ürün fiyatları ve bu sektörlerin gayrisafi milli hasıladaki payı, eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletim sıklığı, birim fiyat veya götürü usulü ödeme, ödeme planı ve benzeri hususlar esas alınır. Bu Yönetmeliğe göre meslek birlikleri birleşerek ortak tarifeler oluşturabilir.

FSEK madde 24 ve 41'deki düzenlemelere baktığımızda, sonradan oluşturulan FSEK madde 41'deki eser ve hak sahiplerinin işini zorlaştıran birçok düzenlemeye rağmen, umumi mahal/yerlerde müzik eserlerinin kullanımı için umumi mahal/yer işletmecileri açısından; eser sahiple-

rinden izin almak, onlarla sözleşme yapmak ve ilgili bedelleri ödemek zorunludur. Yargıtay da aşağıda görüleceği gibi aynı görüştedir.

“Davacı vekili, müvekkilinin koruması altındaki yerli ve yabancı müzik eserlerinin davalı tarafından müvekkillerinden yazılı izin alınmaksızın ve telif ücreti ödenmeksizin **otelinde ticari amaçlı kullanıldığını** ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1000 ABD Doları alacağın **FSEK’nun 68. maddesi uyarınca üç kat artırılarak 3000 ABD Doları olarak davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.**

Davalı vekili, müvekkilince işletilmekte olan otelde yapılan müzik yayınında yasal koruma süresi devam eden eserlerin kullanımından kaçınıldığını, otelde davacının iddia ettiği kadar alan bulunmadığını, diskonun başka bir kiracı tarafından işletildiğini, **radio istasyonundan yapılan yayın listesinin ve toplantı salonunda yayınlanan müzik eserlerinin tespitine olanak bulunmadığını belirterek**, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemenin davanın kabulüne dair verdiği kararının Dairemizce onanması üzerine, davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerekçelere göre, davalı vekilinin HMUK.nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteginin reddi gerekir.⁹⁷

Eğer eser sahipleri temsil haklarını fonogramların yapımı esnasında icracı sanatçıya veya yapımcıya ya da radyo ve televizyon tespitleri için yine yazılı sözleşmelerle yayıncı kuruluşa devretmişlerse ve umumi yerlerde fonogram kayıtları (kaset, cd veya bunların bilgisayara kaydedilmiş hali) veya radyo ve televizyon kayıtları kullanılıyorsa, o durumda eser sahiplerinden değil, bu yeni hak sahiplerinden izin almak gereklidir.

Umumi yerlerden sayılan oteller açısından önemli bir sorun da otel odalarının umumi mahal/yer kapsamına girip girmemesidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (European Court of Justice) 3. Dairesinin 7 Aralık 2006 tarihli kararında otel odalarının umuma mahsus yer olup olmadıkları ele alınmıştır. Mahkemenin kararında, otel odalarında yapılan yayınlar ele alınarak otel sahiplerinin bu yayınlardan dolayı hak sahiplerine telif hakkı ödemesi tartışılmış ve sonuçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; otel odalarında yapılan yayınları da (temsil sayması gerekirken) umuma sunum ve iletim saymış, otelcilerin hak sahiplerinden

⁹⁷ Yargıtay 11. H.D., 18.3.2005, E. 2005/2153, K. 2005/2480.

izin alıp bedel ödeme yükümlülüğü olduğunu belirtmiş, fikri hakların korunması konusunda otel odalarını diğer umuma açık yerlerle aynı mütalaa etmiştir. Kararın önemli bölümleri şöyledir:

41. WIPO tarafından hazırlanan ve bağlayıcılığı olmadığı halde Konvansiyonun yorumuna yardım eden bir yorumlama belgesi olan **Bern Konvansiyonu Rehberi'nde açıklandığı üzere, eser sahibi eserinin yayınına izin verdiğinde, sadece doğrudan kullanıcılara, yani ister şahıslarına ait olan, ister ev ya da aile çevrelerinde bulunan alıcı cihazlarıyla programı alanlara yayın yapılması için izin vermiştir.** Rehberde göre, eğer sunum daha geniş bir çevre için, belki de kâr amacıyla yapılıyorsa, yeni bir alıcı kitlesi eseri görür ya da duyar ve bir programın hoparlör ya da analog cihazlarla umuma iletimi artık programın basit bir sunumu olarak kalmaz, yayınlanan eser yeni bir kitleye iletiildiği için bağımsız bir eylem haline gelir. Rehberin de açıklığa kavuşturduğu gibi, böyle bir umuma sunum eser sahibinin mutlak izin hakkının kapsamındadır.

42. Bir otelin müşteri çevresi, böyle bir yeni kitleyi oluşturur. Televizyon setlerini kullanarak yayınlanan eserlerin müşteri çevresine iletilmesi, sadece orijinal yayının seyredilebileceği alandaki sunumunu sağlamak ya da geliştirmek için teknik bir araç değildir. Tam aksine, burada otel, hareketinin bütün sonuçlarını bilerek, korunan eserlere müşterilerinin erişimini sağlamak için duruma müdahale etmektedir. Böyle bir müdahalenin yokluğunda, fiziksel olarak o alanda bulunsalar bile, prensip olarak söz konusu yayınları izleyemeyeceklerdi.

43. Direktif 2001/29'un 3(1). maddesinden ve WIPO Telif Hakları Andlaşmasının 8. maddesinden çıkarılabileceği üzere, umuma sunumun gerçekleşebilmesi için, esere umumi oluşturan insanların erişebilmesi yeterlidir. **Buna göre, Rafael ve İrlanda'nın dilekçelerinde belirttiklerinin aksine, televizyonlarını açmayan müşterilerinin esere erişemeyeceği iddiası yerinde değildir.**

44. Dahası, Mahkemeye sunulan belgelerde açıkça görüldüğü üzere, otelin yayınlara müşterilerinin ulaşmasını sağlama eylemi, menfaat elde etme amacıyla gerçekleştirilen ek bir hizmettir. Bu hizmetin sunulmasının otelin var oluşuna ve bu nedenle de oda fiyatlarına ciddi bir şekilde etkisi olacağı tartışılmaz. Buna göre, Avrupa Toplulukları Komisyonunun yaptığı gibi, kâr amacının umuma iletimin varlığı için gerekli bir şart olmadığı görüşü savunulsa bile, her halükarda, ana yargılamanın konusunu teşkil eden koşullarda yapılan umuma iletimin kazanç sağlayıcı mahiyette olduğu kesindir.

45. Tek başına otel odalarına televizyon setleri kurulması eyleminin Direktif 2001/29'un 3 (1). maddesi bağlamında bir umuma iletim oluşturup oluşturmadığı sorusuna istinaden, söz konusu Direktifin giriş kısmındaki 27. başlangıç maddesinin, WIPO Telif Hakları

Andlaşmasının 8. maddesiyle uyumlu bir şekilde, “bir iletişimi kurmak ya da sağlamak için salt fiziksel olanakların tedariki, tek başına bu Direktif anlamında bir iletim sayılmayacaktır” hükmünü getirdiği vurgulanmalıdır.

46. Sadece fiziksel olanakların tedariki, genellikle otelin yanı sıra televizyon setlerinin satışı ve kiralınmasında uzmanlaşan şirketleri de kapsadığı için, Direktif 2001/29 anlamında bir umuma iletimi teşkil etmemektedir; ancak böyle olanakların kurulması, yayınlanan eserlere umumun erişimini teknik açıdan mümkün hale getirmektedir. Buna göre, bu şekilde kurulmuş **televizyon setleri aracılığıyla otel, sinyalleri odalarında kalan müşterilere dağıttığında, sinyali iletmek için kullanılan teknikten bağımsız olarak, umuma iletim gerçekleşmektedir.**

47. **Sonuçta,** ... sadece fiziksel olanakların tedariki Direktif 2001/29 anlamında umuma iletim teşkil etmezken, **bir otel tarafından odalarında kalan müşterilere televizyon setleri aracılığıyla sinyallerin dağıtılması, Direktifin 3(1). maddesi anlamında umuma iletimi teşkil etmektedir.**

54. Bütün yukarıdaki düşüncelerin ışığında, otel odalarının özel mahiyetine ilişkin ikinci sorunun cevabı, televizyon setleri aracılığıyla iletim yapılmasının, bu eylemin Direktif 2001/29 madde 3 (1) bağlamında umuma iletim sayılmasını engellemeyeceğidir.

Bu zeminden hareketle, Mahkeme (Üçüncü Daire) şu karara varmıştır:

1. Tek başına fiziksel olanakların tedariki, “22 Mayıs 2001 tarihli ve 2001/29/AT no’lu Bilgi Toplumundaki Telif Haklarının ve Bağlantılı Hakların Uyumlaştırılmasına Dair Direktif” anlamında bir iletim teşkil etmezken, **bir otel tarafından odalarında kalan müşterilere televizyon setleri vasıtasıyla sinyallerin dağıtılması, sinyallerin iletilmesinde kullanılan teknikten bağımsız olarak, söz konusu Direktifin 3 (1). maddesi bağlamında bir umuma iletim teşkil eder.**

2. Otel odalarının özel mahiyeti, televizyon setleri aracılığıyla bu odalarda kalanlara bir eserin iletilmesinin Direktif 2001/29 madde 3 (1) anlamında umuma iletim sayılmasını engellememektedir.”

5. Umuma İletim Hakkı

BERN Sözleşmesi (Tekrar) madde 11 yayın hakkını şöyle düzenlemiştir.

“(1) Edebiyat ve sanat eserleri sahipleri:

(i) *Eserlerinin radyo ve televizyon ile yayınlanmasına veya telsiz olarak işaret, ses veya görüntü nakline yarayan her türlü araçla topluma iletilmesine;*

(ii) Eserin kablo ile topluma iletimine veya radyo ve televizyon yayınlarının kaynak kuruluştan başka bir kuruluş tarafından yapılması halinde tekrarlanmasına;

(iii) Radyo ve televizyon ile yayınlanan eserin hoparlör ile veya diğer benzer bir araçla ya da işaret, ses ve görüntü nakleden bir araçla topluma iletimine,

izin verme hususunda inhisari hak sahibidir.

(2) Yukarıdaki paragrafta öngörülen hakların uygulanma şartları Birlik ülkelerinin mevzuatı ile düzenlenir; ancak bu şartlar yalnızca öngörülen ülkelerde uygulanır. Bu şartlar, hiçbir şekilde eser sahibinin manevi haklarını veya eser sahibinin, bir anlaşmanın yokluğu halinde, yetkili makam tarafından tespit edilen uygun ücreti elde etme hakkını haleldar edemez.

(3) Aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu maddenin 1. paragrafına uygun şekilde verilen izin, radyo ve televizyon ile yayınlanan eserlerin ses veya görüntü kaydına yarayan araçlarla kayıt iznini ihtiva etmez. Ancak, radyo ve televizyon kuruluşlarının kendi yayınlarında kullanılmak üzere kendi imkanları aracılığı ile yaptıkları geçici kayıtlara uygulanacak kurallar Birlik ülkelerinin mevzuatı ile düzenlenir. Bu tespitlerin, istisnai dokümantasyon niteliği taşıması nedeniyle resmi arşivlerde saklanmasına mevzuat ile izin verilebilir.”

WIPO Telif Hakları Andlaşma'sının 8. maddesi “Kamuya İletim Hakkı” başlığı ile şu düzenlemeyi yapmıştır.

“Bern Sözleşmesi'nin 11 (1) (ii), 11 Tekrar (1) (i) ve (ii), 11 ikinci Tekrar (1) (ii) ve 14 (1) (ii) ve 14 Tekrar (1) maddeleri, hükümleri haleldar edilmeksizin, edebiyat ve sanat eserleri sahipleri, eserlerinin telli ya da telsiz ortamda, toplum üyelerinin kendileri tarafından seçilen bir yer ve zamanda bu eserlerden kişisel olarak yararlanacak biçimde topluma iletilmesine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir”.

Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin 22 Mayıs 2001 tarih ve 2001/29/AT sayılı Direktifi'nin 2 maddesine göre; “üye devletler, kısmen veya tamamen, her türlü yöntem ve şekilde, kalıcı veya geçici röprodüksiyonları hakkında: eser sahipleri ve onların eserlerinin kablolu veya karasal iletilip ileilmeyeceğinin düzenlenmesini; doğrudan veya dolaylı yasaklama veya müsaade etmeye münhasır haklarını korur”.

2001/29/AT sayılı Direktifi'n 3 maddesine göre ise; “üye devletler, eser sahiplerinin, tel üzerinden veya telsiz vasıtalarla eserlerini yayımlama, böyle bir yolla kamunun tercih ettikleri bir zamanda ve bir yerden

erişebilmeyi mümkün kılmayı içeren, her türlü haberleşmeyi yasaklama veya müsaade etmeye münhasır haklarını temin eder”.

Bu uluslararası kuralların Türk İç Hukuku’na yansımaları şu şekildedir:

FSEK madde 25; *“bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir.*

Eser sahibi, eserin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine⁹⁸ izin vermek veya yasaklamak hakkına da sahiptir.

Bu madde ile düzenlenen umuma iletim yoluyla eserlerin dağıtım ve sunumu eser sahibinin yayma hakkını ihlal etmez”.

Bu yasal düzenlemelerin ışığında, “umuma iletim hakkı”; “yayın”, “yeniden yayın” ve “kamunun erişimine sunma” şeklinde üç alt hakkı içerir.

Maddenin 1. fıkrası **“yayın”** haklarını (bu hak daha öncede bahsettiğimiz gibi yayma ve dolaylı temsil hakkından farklıdır) ve 2. fıkrası ise; **“kamunun erişimine sunma”** hakkını irdelemektedir. Yayınlanma; eserin radyo- TV veya dijital vasıtalarla “yayın” veya “yeniden yayın” şeklinde umuma iletilmesiyle; FSEK madde 7 de yer alan yayma hakkı, bir eserin fiziki olarak aslının veya çoğaltılmış nüshalarının ticarete sunulması anlamına gelmektedir. Bir müzik eserine bir web sitesinde yayınlanmak üzere yer verilmesi ve bu eserin belirli bir dönem veya sayıda kullanılmak üzere internet veya gsm şebekesi üzerinden kullanıcıların müzik cihazlarına indirilmesi yoluyla kiralanması veya satılması ise FSEK 25/2. maddesinin son kısmında belirtilen “kamunun erişimine sunma”dır.

⁹⁸ Burada kullanılan umuma iletim kavramı kafa karıştırmaktadır. Sanki yayın ve umuma iletim kavramları ayrı ayrı haklara yönelik kavramlarmış gibi kullanılmaktadır. “Umuma iletim” kavramının içine yeniden yayın/iletimi de kapsar biçimde “yayın” girmekte ve bir de “gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi” girmektedir.

Tüm bu açıklama dahilinde FSEK madde 25'deki eserin kullanım biçimlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Fikir ve sanat eserlerinin,

- Aslı veya kopyalarının radyo-tv, uydu, kablo gibi telli ve telsiz araçlarla ve dijital iletim araçları ile yayını,
- Yukarıdaki kuruluşlarının yayınının yeniden yayını/yeniden iletimi,
- Aslı veya kopyalarının, telli ve telsiz araçlarla satışı ve diğer biçimde umuma dağıtılması veya sunulması⁹⁹,
- Gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi veya ulaşımı.

Bu maddedeki eserleri yayınlama veya umuma iletme şeklindeki kullanım biçimleri, eskiden temsil hakkı içinde değerlendirilirken radyo yayını ile başlayan teknolojik gelişmeler, temsil hakkındaki “yayın”ın “umumi yer” ile sınırlı olması karşısında temsil hakkından ayrı yeni bir düzenleme gereksinimini ortaya çıkarmış ve Kanun değiştirilerek önce radyo, sonra televizyon ve daha sonra da internet erişimiyle bilgisayarları da kapsar biçimde “yayın” ve “umuma iletim” adları verilen bir başlık altında yeni bir mali hak meydana getirilmiştir. FSEK 25. madde, ikinci fıkrasında; internetin ve bilgisayarda dosya saklamanın gelişmesi paralelinde, internet ortamında; web siteleri veya kişisel bilgisayarların hard diskinde diğer kişilerin paylaşımına açık olarak tutulan dosya şeklinde ortaya çıkan yeni bir yayıncılık türünü de düzenlemektedir. Burada sanal ortamda bir eser interaktif kullanıma yani gerçek kişilerin dilediği yer ve zamanda erişimine veya ulaşımına açık olarak tutulmaktadır. İnternet web sitesinde veya herhangi bir kişinin bilgisayarında bulunan bir esere, kişiler kolayca erişebilmekte ve özel olarak çeşitli dijital tekniklerle önlenmemişse kolayca çoğaltabilmektedirler.

Bu bölümde öncelikle “yayın” veya “yayınlama” mali hakkını inceleyelim.

Roma Anlaşması'nın 3. maddesinde “**yayın**”, seslerin yahut resim ve seslerin toplumun yararlanacağı şekilde radyo dalgaları ile yayını; ve

⁹⁹ FSEK çeşitli zamanlarda değişikliğe uğradığından 60 yıllık Kanun'un bütünlüğü de bozulmuş yanlış yerlere yanlış haklar yerleştirilmiştir. Bu hak; yayma hakkının düzenlendiği kiralama ve satış hakkındaki AB Direktiflerinde yer almaktadır. Bizim görüşümüze göre de kiralama ve satış, yayma hakkının kapsamına girmektedir. Bu yüzden yayma hakkı ile ilgili maddenin AB Direktifleri doğrultusunda yeniden düzenlenip, kiralama ve satışın, telli ve telsiz araçlarla satışın ve dağıtımın yayma ile ilgili maddede düzenlenmesi gereklidir.

“**Tekrar yayını**”, bir yayının kuruluşunun yapmış olduğu yayının, diğer bir yayının kuruluşu tarafından aynı anda yayını olarak tanımlanmıştır.

WIPO İcralar Sözleşmesi ise 2. maddesinin (f) bendinde “**radio-televizyon yayını**”, topluma ulaştırılması amacıyla seslerin veya görüntü ve seslerin telsiz iletimi olarak tanımlanmıştır. WIPO Sözleşmesi’ne göre, bu ifade aynı zamanda uydu ile gerçekleştirilen aynı türde bir iletimi de tanımlar; radyo televizyon kuruluşu tarafından veya onun rızası ile şifre çözücü araçlarla topluma sağlanan şifreli sinyallerin iletimi de “radyo ve televizyonla yayını” sayılır.

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun ise 3. maddesinde yayını türleri ve yeniden iletim konusunda şu tanımları vermiştir:

Radyo yayını: Elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan ses yayınıları,

Televizyon yayını: Elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan, hareketli veya sabit resimlerin (görüntü) sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınıları,

Kablolu yayını: Radyo, televizyon ve veri yayınlarının kablo, cam iletken ve benzeri bir fiziki ortam üzerinden abonelere ulaştırılmasını sağlayan yayını türü,

Uydu yayını: Radyo ve televizyon programlarının, yetkili yayıncı veya hizmeti temin edecek kişi veya kuruluş tarafından şifreli veya şifresiz olarak uzayda sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtasıyla yapılan ilk yayını,

Yeniden iletim: Yetkili yayını kuruluşu tarafından kullanılan teknik araç ne olursa olsun, halkın izlemesi amacıyla yayınlanan radyo ve televizyon program hizmetlerinin değişiklik yapılmaksızın bütününe veya bir bölümünün alınması ve aynı anda veya daha sonra iletilmesi.

FSEK madde 25’de görüleceği üzere, **yayını veya yeniden yayını eser sahibinin mali hakları içindedir. Bu yüzden karasal, uydu, kablo veya internet yolu ile radyo ve televizyon yayını sonucu bir müzik eserinin umuma iletilmesi hak sahiplerinden izin almayı gerektirmektedir.**

Yayının canlı veya banttan olması, radyo ve televizyonda olduğu gibi sırayla yayınlanan eserleri belirleme imkanı olmadan izleniyor olması ya da -internette olduğu gibi- dekodeerler kullanan Digitürk, Smart

gibi yayın biçimlerinde izleyicilerin çoktan seçmeli ve interaktif olarak istedikleri programı izlemelerinin sağlanması önemli değildir. Hepsi yayın olarak mütalaa edilir ve eser sahiplerinin izni gerekir.

Bu açıklamalarımıza örnek olarak, eser sahibinden izin alınmadan bir eserin televizyon yayınında kullanılması sonucu eser sahibinin açtığı davayı ve mahkemenin kararını verebiliriz.

“Davacı, kendisine ait “E...” adlı eserin kısaltılmış ve tahrif edilmiş şekilde izni alınmadan ve telif hakkı ücreti ödenmeden davalı şirket televizyonunun “İşte Müzik İşte Eğlence” adlı programında M.K. tarafından okunduğunu ileri sürerek 20,000,000 lira manevi, 15,000,000 lira maddi tazminatın %45 reeskont faizi ile davalıdan tahsiline, hüküm özetinin ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yargılama aşamasında ölen davacı mirasçıları vekili aracılığı ile davayı takip etmiştir.

Davalı vekili savunmasında, müvekkil şirket televizyonunda böyle bir program yayınlanmadığını, dava konusu şiirin bestelenmesi talimatının müvekkilince verilmediğini, dolayısıyla kısaltma ve tahrifattan sorumlu olmadıklarını, müvekkilin Mesam ile yaptığı anlaşma ile yayınlanan eserin telif ücretlerinin Mesam’a ödendiğini, maddi tazminat için hangi kritere dayanıldığının belli olmadığını, istenen faizin fahiş olduğunu, manevi tazminatın da fahiş olduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; toplanan kanıtlar, tanıklar ve bilirkişi raporuna göre, **davalının, FSEK’çe korunan mali ve manevi haklarına (aykırı olarak) ... eser sahibinin yazılı iznini almadan eseri yayınladığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne**, 15,000,000 lira maddi ve 15,000,000 lira manevi tazminatın 18.3.1994 tarihinden itibaren %30 yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline **karar verilmiştir.**¹⁰⁰

FSEK’da yayın konusundaki önemli düzenleme, “Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Yayınlanmasına ve/veya İletilmesine İlişkin Esaslar” başlığı ile 43. maddede şu şekildedir:

”Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin almak zorundadırlar. Bu kuruluşlar sahneye konmuş eserler dışında kalan (bu guruba müzik eserleri de girmektedir) eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52nci maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın

¹⁰⁰ Yargıtay 11. H.D, 30.9.1996, E. 1996/5873, K. 1996/6286, SULUK/ORHAN, age., s. 196.

ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadırlar. 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren radyo-televizyon kuruluşları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, anılan Kanun dışında kalan ve yayın ve/veya iletim yapan diğer kuruluşlar ise Bakanlık tarafından sınıflandırılır¹⁰¹.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram ve yapımların yayın ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile kuruluşlar arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılan müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

Meslek birliklerinin temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bildirim zorunluluğu, tarifelerin belirlenmesi, duyurulması, müzakere edilmesi, sözleşme yapılması, uzlaşmazlıkların halli ve diğer hususlarda bu Kanunun 41 inci maddesinin dört ilâ onüçüncü fıkraları uygulanır.¹⁰² Ancak yayın ve/veya iletim yapan kuruluşlar bakımından 41 inci maddenin altıncı fıkrasının son cümlesinin¹⁰³ uygulanması zorunlu değildir.

¹⁰¹ FSEK madde 43, ana amaç olarak radyo ve televizyon yayınlarını kapsamaktadır. Ama yazım olarak “ileride bulunacak teknik imkanlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar” dendiği için madde, internet üzerinden yayıncılık yapan kuruluşları da kapsar bir şekil almıştır. Bu durum ise, FSEK madde 25’de düzenlenen “kamunun erişimine sunma” hakkı ve araçları ile karışma yaratmaktadır. Bakanlık FSEK madde 43’deki sınıflandırma yapma yetkisinde; internetteki “kamunun erişimine sunuş” yapan araçları da kapsama alırsa ciddi bir karışıklık çıkar.

¹⁰² FSEK 41. maddesinin 4. fıkrası: Tarifelere ilişkin sözleşmelerde takvim yılı esas alınır ve bu tarifeler takvim yılı başından itibaren geçerli olur.

FSEK 41. maddesinin 13. fıkrası: Mahallerde kullanılan ve/veya iletimi yapılan eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar üzerinde hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, bunların kullanımına ve/veya iletimine ilişkin ödemelerin yapılmasını yetki verdikleri meslek birlikleri aracılığı ile talep edebilirler. Sinema eserleri bakımından bu fıkranın uygulanması zorunlu değildir.

¹⁰³ FSEK 41. maddesinin 6. fıkrasının son cümlesi: Ancak, tarifelerin götürü usulde tespit edilmesi halinde umuma açık mahaller sadece meslek kuruluşları aracılığı ile müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler.

Ayrıca, 41 inci maddenin 10 uncu fıkrasının¹⁰⁴ uygulanması bakımından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yayınlarında yer verdiği eser, icra, fonogram ve yapımları her üç ayda bir meslek birliklerince belirlenen yıllık tarifenin 1/4'ünü yatırmak suretiyle kullanabilir.”

Yasal düzenlemenin fıkrası gereğince; radyo ve televizyoncularla müzik meslek birliklerinin, tarife şartlarında anlaşamamaları halinde; müzik eserlerini kullanmak isteyen radyo ve televizyoncular ve kamu yayıncısı TRT, mahkemeye bir para depo ederek eser ve bağlantılı hak sahipleri karşı çıksa bile onların ürünlerini kullanmaya başlayabilir. Böyle bir uygulama, halkın zorunlu ihtiyaç maddesi olan ekmek ve diğer gıda ürünlerinde bile yapılmamaktadır. Bu düzenleme ile amaçlanan; üstün bir kamu yararı olmayıp, sadece radyo ve televizyon yayıncılarına hak sahiplerinden izin alma gereğini duymadan – tabii ki yasal hakları da ödemedens- müzik eserlerinden yararlanması olanağını sağlamaktır. Halbuki hiçbir sektörde ürün fiyatını beğenmeyen tüketiciler; bu ürünün ücretinin 1/4'ünü yatırarak¹⁰⁵ ve mahkemeye bir dava açarak ürünü kullanamazlar.

¹⁰⁴ FSEK 41. maddesinin 10. fıkrası: Meslek birliklerince belirlenen tarife veya ortak tarifeler üzerinden sözleşmenin yapılmaması halinde, taraflar yargı yoluna başvuru-bilirler. Yargılama sürecinde, bir önceki yıl sözleşme yapmış olan mahaller, ilgili meslek birlikleri aksini bildirmedikçe, dava konusu tarifenin 1/4'ünü dava sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir meslek birlikleri adına açılmış banka hesabına yatırmak suretiyle eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilir ve/veya iletebilirler. Bir önceki yıl sözleşme yapmamış umuma açık mahaller ile ilk defa sözleşme yapacak umuma açık mahallerin bu fıkra da öngörüldüğü şekilde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilmeleri ve/veya iletebilmeleri ise ilgili meslek birliklerinin iznine bağlıdır. Dava sonuçlanıncaya kadar bu şekilde ödenen miktar, mahkeme kararıyla tespit edilen tarife bedelinden mahsup edilir.

¹⁰⁵ Bu 1/4 oranının, bir yıllık tarifenin dörtte biri olarak yorumlanması gerekirken, bazı mahkemelerin bir yıllık tarifenin dörtte birinin 1/4'ü gibi saçma bir yorum yapıp durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirdiklerini de duyuyoruz. Düzenlemedeki “dava konusu tarifenin 1/4'ünü dava sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir meslek birlikleri adına açılmış banka hesabına yatırmak” ibaresindeki anlam –adaleti esas aldığınızda- her üç ayda bir, yani dört taksitte bir yıllık tarife rakamını çeyrek taksitler halinde kullanıcıya tamamlatarak, davanın sonunda eser ve diğer hak sahiplerinin mağdur olmasını önlemektir. Yoksa her üç ayda bir yani dört defa, sadece bir yıllık tarifenin 1/16'sını ödeyerek ve toplamda yılda, yıllık tarifenin sadece 1/4'ünü (1/16x4) ödeyerek bu eserlerden faydalanmak hangi adalet anlayışına sığar ?

Sonuç olarak eser sahiplerinden izin almadan müzik eserinin televizyonda yayınlanması haklara tecavüz olup, yayıncı kuruluş izin almadan yaptığı yayın sebebiyle aşağıda görüldüğü gibi tazminata mahkum olur.

“Davacı, “Bir Yangının Külünü” adlı şiirini davalı şirkete ait televizyon kanalında bir programda adı belirtilmeden ve kendinden izin alınmadan yayınladığını, bu nedenle FSEK’e aykırı davranıldığını iddia ederek telif hakkı karşılığı 7,500,000 TL ile manevi zarar karşılığı 20,000,000 TL’nin %45 faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, şiirin yaklaşık 30 yıl önce davalıdan alınıp bestelendiğini ve müzik eseri olarak ortaya çıktığını, ... günün şartlarına göre izin alınmasına gerek olmadığını, şiirin bir program sırasında programa katılan sanatçı tarafından okunduğunu kendileri tarafından hazırlanmadığını, ayrıca Mesam (meslek birliği) adlı kuruluşla davalı şirket arasında yapılan sözleşme uyarınca sanatçıların eserlerinin izin alınmaksızın yayınlanabildiğini, muhatabın Mesam olduğunu, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma ve dosya arasındaki yazılara göre, bilirkişi değerlendirmesi sonucunda, davacının eserinin izinsiz yayınlanması nedeniyle talep ettiği maddi ve manevi tazminat yönünden haklı bulunduğu, ... maddi tazminatın aynen, manevi tazminatın takdiren 7,500,000 TL maddi, 7,500,000 TL manevi tazminat olmak üzere 15,000,000 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek %30 faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, taraflar temyiz etmişlerdir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebepler ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde görülmeyen davalı vekilinin tüm, davacının aşağıdaki bentler dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Ancak, davacı dava dilekçesinde, haksız fiil tarihinden itibaren temerrüt faizine hükmedilmesini istemiştir. Mahkemece, davacının maddi hakları FSEK m. 68 ile manevi haklarının FSEK m. 67 ve 70 gereği tecavüze uğradığı kabul edildiğine göre, hükmedilen tazminata haksız fiil tarihi olan yayın tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir. Bu nedenle hükmün faiz başlangıcına ilişkin kısmı doğru görülmemiştir.

3-Öte yandan, davalının tacir olmasına ve davacının %45 oranında temerrüt faizi istemesine göre, hükmedilen faiz oranının bu miktarın altında olması ... 3095 sayılı Yasa ve TTK’nun 3. maddesine aykırı görülmüştür.

4-Ayrıca, davacı hüküm özetinin TV’de yayınlanmasını talep ettiği halde, hüküm fıkrasında FSEK m. 78 uyarınca, bu hususta olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi de kararın bozulmasını gerektirmiştir.¹⁰⁶

Radyo ve televizyonların yayınlarında kullandıkları eserler için besteci ve söz yazarlarından veya onların meslek birliklerinden izin almamaları halinde, eser sahipleri FSEK’de yer alan tecavüzün ref’i, teca-vüzün men’i, maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davaları açabi-lirler. Bu davaların yanı sıra eser sahipleri özel radyo ve televizyon ku-ruluşlarının idari olarak uyarılması ve cezalandırılması için Radyo Te-levizyon Üst Kuruluna da 3984 sayılı Kanun gereğince başvurabilirler. 3984 sayılı *Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun* yayın ilkeleri ile ilgili 4. maddesinin “o” bendinde; “yayınlarda eser ve bağlantılı hak sahiplerine 5846 sayılı FSEK ile tanınan hakların ihlal edilmemesi”ni radyo ve televizyonlar için bir yükümlülük olarak koymuştur. Kanun 37. maddesinde de; “Radyo-Televizyon kuruluşla-rınca yayınlanan ve/veya iletilen eser, fonogram ve yapımları kullana-bilmek için, eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri veya bu kişilerin üyesi oldukları meslek birlikleri ile izin almak üzere sözleşme yaparlar ve bu sözleşme ile belirlenen mali hak bedellerini öderler . Bu sözleşme ve ödemeler, 5846 sayılı *Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun* ilgili hüküm-leri çerçevesinde yapılır. Bu madde hükümlerini ihlal eden yayın kuru-luşları hakkında ayrıca bu Kanunu’n 33 üncü madde hükümleri uy-gulanır” diyerek, Kanuna uyulmaması halinde RTÜK’ün, yayın kuru-luşlarına uyarı, program durdurma, para cezaları ve sonunda yayın izni-nin iptaline kadar cezalar verebileceğini belirtmektedir¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Yargıtay 11. H.D, 11.4.1996, E. 1996/1908, K. 1996/2631, SULUK/ORHAN, age, s. 159-60.

¹⁰⁷ 3984 sayılı *Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun*’un 33. maddesi şöyledir:

“Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve bu Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâlê konu olan programın yayını, bir ilâ oniki kez arasında durdurulur. Cezaya yol açan fiilde sorumlulukları belirlendiği takdirde programın yapımcısı ve varsa sunucusu da bu süre içerisinde hiçbir ad altında başka bir program yapamaz ve sunamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, ka-dın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alış-

FSEK 43. maddesinde yayınlanma için kullanılacak araçlar sınırlandırılmamıştır. Değişen şartlar dahilinde oluşacak yeni teknolojik gelişmelerle umuma iletime sınır koyulması olanaksızdır. Zaten bir Kanun'un uzun soluklu olması ve maddenin teknolojik gelişmeler sonucu işlevini kaybetmemesi için bu şekilde düzenlenmesi bir zorunluluktur.

Maddenin “*bu madde ile düzenlenen umuma iletim yoluyla eserlerin dağıtım ve sunumu eser sahibinin yayma hakkını ihlal etmez*” şeklin-

kanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Aykırlığın tekrarı hâlinde;

a) Ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara, ihlâlin ağırlığına göre, ikiyüzellibin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla beşyüzbin Türk Lirasına kadar,

b) Yerel, bölgesel ve kablo ortamından yayın yapan kuruluşlara;

1. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, bir milyondan fazla nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, yüzyirmibin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla ikiyüzbin Türk Lirasına kadar,

2. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, beşyüzbin ilâ bir milyon arasında nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara ihlâlin ağırlığına göre, otuzbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla altmışbin Türk Lirasına kadar,

3. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibin ilâ beşyüzbin arasında nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, yirmibin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla kırkbin Türk Lirasına kadar,

4. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibinden az nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, beşbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla onbin Türk Lirasına kadar,

c) Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar,

idarî para cezası verilir.

İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı hâlinde bu idarî para cezaları yarı oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde ikinci kez tekrarında ihlâlin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur.

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılması hâlinde uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur. İhlâlin tekrarı hâlinde yayın süresiz olarak durdurulur ve yayın lisans izni iptal edilir.

Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile ile elde eden kuruluşların yayın lisans izni iptal edilir.

Uyarı cezasını gerektiren hâller dışındaki ihlâllerde ilgili tarafın savunması alınır.

Cezaların uygulanış usulleri ile gerekçeli olarak kamuoyuna duyuruş şekli yönetmelikle belirlenir.”

deki son fıkrasında belirtildiği gibi, eğer bir kişi bir eserin umuma iletim hakkına sahipse, bu hakkın kullanımı eser sahibinin yayma hakkının ihlali anlamına gelmeyecektir.

Gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimi ise internet iletimi düşünülerek Kanun'a dahil edilmiş bir kavramdır. Müzik eserlerinin web sitelerinde yer alarak dinlenilmesi “yayın” kavramından ayrı olarak düzenlenmiştir. Ancak bu alan “yayma” hakkı içindeki “satış” ve “kiralama” ile farklı olup, “yayma”da fiziksel kopyalar, internetle umuma iletimde (kamunun erişimine sunmada) digital (fiziki olmayan, elle tutulmayan) kopyalar satılmakta ve kiralanmaktadır. İnternet ortamında müzik eserlerinin umuma iletilmesi veya yararlanılması çok çeşitli biçimlerde olmaktadır.

Tek dinleme: Tüketici tarafından seçilen müzik yapıtı'nın tüketici bilgisayarına kopyalanmaksızın bir kez dinlenmesi.

Çok dinleme: Tüketici tarafından seçilen müzik yapıtı'nın tüketici bilgisayarına kopyalanma suretiyle, belirlenecek sayı veya süre ile sınırlı olarak birçok kez dinlenmesi.

Dinleme ve aktarma: Tüketici tarafından seçilen müzik yapıtı'nın tüketici bilgisayarına kopyalanma ve/veya bu kaydın başka bilgisayarlara ve/veya taşınabilir müzik dinleme cihazlarına aktarılması suretiyle, belirlenecek sayı veya süre ile sınırlı olarak birçok kez dinlenmesi.

Dinleme ve bilgisayar harddiskine kopyalama: Tüketici tarafından seçilen müzik yapıtı'nın tüketici bilgisayarına kopyalanma ve/veya bu kaydın belirlenecek sayı ve süre ile şahsen kullanım için bilgisayar hard diskine kopyalanması suretiyle, belirlenecek sayı veya süre ile sınırlı olarak birçok kez dinlenmesi.

Dinleme, aktarma ve süre ve sayı ile sınırlı cd'ye kopyalama: Tüketici tarafından seçilen müzik yapıtı'nın tüketici bilgisayarına kopyalanma ve/veya bu kaydın başka bilgisayarlara ve/veya taşınabilir müzik dinleme cihazlarına aktarılması suretiyle sayı veya süre ile sınırsız olarak birçok kez dinlenmesi ve/veya bu kaydın sayı ve süre ile sınırlı olarak şahsen kullanım için kompakt diske kaydedilmesi.

İnternet gibi cep telefonları da günümüzde yaygın olarak müzik eserlerinin/ yapıtlarının dinlendiği ve izlendiği iletişim araçlarıdır. Müzik eserleri cep telefonlarına yüklenerek satılabilir veya gsm operatörleri tarafından veya diğer biçimlerde cep telefonlarına indirilebilir. Cep telefonlarındaki müzik uygulamaları da şu şekilde tanımlanabilir.

True tone : Önceden kaydedilmiş müzik yapıtları arasından gsm operatörlerinin abone'lerinin yapacakları seçim sonucunda, seçilen müzik yapıtının 20-25 saniye arasındaki kısmının, cep telefonlarının zil sesi yerine, gerçek şarkı sesi olarak atanması ve herhangi bir limit olmadan dilediği kadar dinlenmesi/çalınmasına yarayan yapıt formatıdır.

Full track : Önceden kaydedilmiş müzik yapıtları arasından gsm operatörlerinin abone'lerinin yapacakları seçim sonucunda, seçilen müzik yapıtının cep telefonlarına indirilmesi ve herhangi bir limit olmadan diledikleri kadar dinlenmesini sağlayan formattır.

Ring back tone/rbt/pgs: Önceden kaydedilmiş müzik yapıtları arasından gsm operatörlerinin abone'lerinin yapacakları seçim sonucunda, seçilen müzik yapıtının en fazla 6 aylık bir süre için başka bir abone'nin ve/veya abone'lerin (mobil ve/veya sabit telefon hattı abone'leri) aramasına atanması ve müzik yapıtı'nın atandığı abone'ye ve/veya abone'lere, arama sırasında gsm hat cevaplanıncaya kadar geçen süre içinde dinletilmesidir.

Rbt (aylık) : Önceden kaydedilmiş müzik yapıtları arasından gsm operatörlerinin abone'lerinin yapacakları seçim sonucunda, seçilen müzik yapıtının abone'ler tarafından kendilerini arayan kişilere zil sesi yerine, dinletmek için yaptığı belirli bir süre geçerliliğini koruyan atama işlemidir.

Streaming : Önceden kaydedilmiş müzik yapıtları arasından gsm operatörlerinin abone'lerinin yapacakları seçim sonucunda, seçilen müzik yapıtının mobil operatör şebekeleri üzerinden veri aktarımı yolu ile, kullanıcı isteğine bağlı olarak ya da belirli bir yayın programı çerçevesinde, gerçek yapıt yayını yapılması ve abone'nin cep telefonu üzerinden dinlemesinin sağlanmasıdır.

Kısa klip izletme : Önceden kaydedilmiş müzik yapıtları arasından gsm operatörlerinin abone'lerinin yapacakları seçim sonucunda, seçilen müzik yapıtının kesintisiz ve en fazla 40 sn. uzunluktaki bir video görüntüsünün cep telefonlarına indirilerek limitsiz olarak izleyebilmesine imkan veren uygulamadır.

Video tone : Önceden kaydedilmiş müzik yapıtları arasından gsm operatörlerin abone'lerinin yapacakları seçim sonucunda, seçilen müzik yapıtının kesintisiz ve en fazla 40 sn. uzunluktaki bir video görüntüsünün, abone'nin kendi cep telefonuna görüntülü zil sesi olarak indirmesini sağlayan uygulamadır.

Sekreter servisi: Müzik yapıtları arasından gsm operatörlerinin abone'lerinin bir servis numarası kullanılarak seçtikleri müzik yapıtı'nın abone'nin hattına ulaşamaması halinde abone'ye gelen çağrının telesekretere yönlendirilmesi ve bunun sonucunda anons esnasında seçilen müzik yapıtı'nın dinletilmesini sağlayan uygulamadır.

IVR üzerinden 'dinletme' uygulamaları : Herhangi bir mobil operatör üzerindeki bir servis numarasının aranarak, önceden kaydedilmiş müzik yapıtları arasından gsm operatörlerinin abone'lerinin yapacakları seçim sonucunda seçilen müzik yapıtının veya belirli bir yayın programı çerçevesindeki müzik yapıtlarının dinlenmesi imkanı veren uygulamadır.

“Umuma iletim” biçimlerinden biri olan “gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda müzik eserine erişimi” hem internet aracılığı ile web sitelerinde müzik eserinin yayını, hem bu eserin satış ve kiralama yoluyla kullanılması ve hem de web sitesi olmadan dosya paylaşımı yoluyla ve cep telefonları vasıtasıyla indirilmesi ve kullanılması gibi yararlanma biçimlerini kapsamaktadır. Bu yollarla müzik eserlerinden yararlanma için eser sahiplerinden izin alınması ve sözleşme yapılması gerekmektedir.

Bu mali hak doğrultusunda eser sahibinden bir müzik eserinin yukarıda belirttiğimiz tüm kullanım biçimlerini kapsar biçimde ve genel ibare ile “*umuma iletim hakkı*”nı almış olan kişi, o eseri karasal vericili televizyonda veya bir uydu kanalında yayınlayabilir, internette bir web sitesinde erişimine izin verebilir veya herhangi bir bilgisayarda bulunan bir dosyanın içindeki bu eseri insanların bir link ile ulaşıp açıp incelemesine ve beğenirlerse kendi bilgisayarlarına bir kopyasının yapılmasıyla dağıtılmasına olanak tanıyabilir. FSEK 52. maddeye göre yazılı bir sözleşme ile umuma iletim hakkı, eser sahibi tarafından üçüncü kişilere devredilebilir veya sınırlı bir süre ile lisans verilebilir. Ama hakkı devir almadan veya umuma iletim konusunda bir lisans almadan müzik eseri sahibinin internet sitesinde yayınlanan eserini bir üçüncü kişi alıp kendi web sitesinde yayınlamaz veya link veremez.

Eğlence Sektörü adı verilen bir ekonomi alanında yer alan müzik sektörü, son yıllarda özellikle internet ve cep telefonlarının yaygınlaşması ile ürün çeşitliliği sağlamıştır. Geleneksel plak, kaset ve CD ürünlerinden sonra internet üzerinden ya da cep telefonları içinde dağıtılabilen yazılım veya ses kayıtları şeklinde ürün geliştiren bu sektör, geleneksel

ürünlerde kaybettiği pazar paylarını bu yeni ürünler ile yeniden yakalamıştır. Ancak müzik sektörü yararına internet ve yazılımların gelişmesi öte yandan izinsiz ya da korsan çoğaltımları da denetlenemez düzeyde arttırmıştır. 2009 yılı verileriyle internet üzerinde sadece %5 oranında yasalara uygun yararlanma yapılmaktadır. Yani internet kullanıcılarının %95'i müzik eserlerini yasalara aykırı olarak kullanmaktadırlar.

İnternetteki web siteleri veya kişisel sayfalar yoluyla birçok müzik eseri kitlelere izinsiz olarak sunulmaktadır. Hatta 2000'li yılların başında www.sarkiindir.org veya www.muzikindir.com gibi siteler çok moda idi. Müzik eserlerinin kulanıcılara izinsiz olarak ulaşmasını sağlayan bu sitelere karşı FSEK'e 2004 yılında eklenen Ek madde 4 hükmü ile; bu sitelerin erişimini sağlayan Türk Telekom gibi internet servis sağlayıcılar vasıtasıyla önlem alınmıştır. Bu düzenleme şöyledir:

“Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâlê konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlê durdurulmasını ister. İhlâlê devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâlê devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlê durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

Gelişen teknoloji sayesinde müzik eserlerinin izinsiz olarak kullanılması internet kullanımı yoluyla daha kolay hale gelmiştir. Bu noktada, teknolojinin sağladığı peer to peer (p2p) sisteminin umuma iletim sayılıp sayılmayacağı konusu önem arz etmektedir. Peer to peer sisteminin temeli, kişiden kişiye veri transferine dayanmaktadır. Bu arada e-postalar aracılığı ile bir kişiye eserin gayri maddi muhtevasının gönderilmesi umuma iletim sayılmaz. Çünkü normal olarak veri gönderen kimsenin, e-posta ile veri gönderdiği kişiler, onun şahsi çevresi sayılır ve bu kimselerin birden fazla olması ”umum” kavramını da oluşturmaz. Peer to

peer temeline dayanan müzik değişimlerinde, elektronik posta yolu ile yapılan yazışmalardan farklı olarak herhangi bir ilgiden ve şahsi bağlantıdan söz edilememektedir. Kişiler arasında gerçekleşen veri değiş tokuşu, programdaki arama fonksiyonu sayesinde kurulmaktadır. Arama sonuçlarına göre, veri transferlerinin en kolay yapılabileceği kişilerden kopyalama yapılmaktadır. Ancak müzik değişim programlarında, müzik parçalarının diğer internet kullanıcılarının kopyalanması için hazır bulundurulması, umuma iletim sayılmalıdır.¹⁰⁸ Bu yüzden şahsi kullanım kapsamını aşan p2p uygulamaları için eser sahiplerinden izin alınmalıdır.

Özellikle internet ortamında çoğaltılan ve dağıtılan ürünler açısından yeni bir sorun olarak hak sahipliği tartışmaları ortaya çıkmıştır. Geleneksel ürünler olan plak, kaset ve cd açısından daha kolay izlenebilen telif hakları internet ve sayısız download sebebi ile hak sahipliği iddiaları açısından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerini karşı karşıya getirmiştir. Uluslararası sözleşmeler ve İç Hukuk düzenlemeleri; yeni teknolojilerle gündeme gelen yeni yararlanma biçimleri sebebiyle, özellikle çoğaltma ve yayma hakları açısından besteci, aranjör ve söz yazarlarından oluşan eser sahipleri ile bağlantılı hak sahibi olan müzik yapımcılarını ve eserleri seslendiren yorumcu/icracıları oluşan yeni hakların paylaşımında bir mücadele içine sokmuştur. Meslek birlikleri vasıtasıyla yapılan bu mücadeleler, neticede Avrupa'daki uygulamaları da esas alarak uzlaşma ile sonuçlanmış ve hak sahipleri bir bütün halinde çoğaltma ve yayma haklarını ihlal edenlere karşı mücadelede üstünlük kazanmışlardır.

Umuma iletim hakkı konusunda eser sahibinden izin alınmadan yayın yapılabilmesi konusundaki istisnalar; FSEK madde 26 ve 27'de yer alan zaman bakımından istisnalar; FSEK madde 30 uyarınca kamu düzenini koruma gerekçesiyle istisnalar; FSEK madde 31 ve 37 arasında belirtilen genel menfaat gerekçesiyle istisnalar (mevzuat ve içtihatlar, nutuklar, iktibas, gazete münderecatı ve haberler); FSEK madde 38'de yer alan şahsen kullanma şeklinde düzenlenmiştir. Bu istisna durumlarında koruma süreleri henüz dolmamış olsa dahi eserin serbestçe yayını ve umuma iletilmesi mümkündür.

6. Pay Alma (İzleme) Hakkı

Bir eserin eser sahibi tarafından satıldıktan sonra değerinin artması ve çok yüksek para ile tekrar satılması rastlanan durumlardandır. Bu tak-

¹⁰⁸ MEMİŞ, age. s. 118

tirde eser sahibine veya ölmüşse mirasçılarına, eserde meydana gelen değer artışından bir pay verilmesi hakkaniyet ile fıkırsel ve sanatsal haklar mantığı gereğidir.

Bu kapsamda müzik eserleri açısından söz ya da müziğin yer aldığı besteci veya sözyazarının ilk orijinal nota, şarkı sözü ve yazı metinleri pay alma hakkının konusu olabilecektir.

Bu konudaki yasal düzenlemeler şöyledir:

Bern Sözleşmesi madde 14'e (İkinci Tekrar) göre; eser sahibi veya onun ölümünden sonra ulusal mevzuatça yetkili kılınan kişi veya kurumlar, orijinal sanat eserleri ve yazar ve bestecilerin orijinal el yazmaları konusunda, eserin sahibi tarafından yapılan ilk devrin ardından eserin herhangi bir satışındaki kârda devir ve ferağı mümkün olmayan haklardan yararlanacaktır.

27 Eylül 2001 tarihli 2001/84/AT sayılı “*Özgün Bir Sanat Eserinin Yazarının Faydalanabilmesi İçin Yeniden Satış Hakkı Hususundaki Avrupa Parlamentosu Direktifi*”nin ilk maddesine göre; üye devletler özgün bir sanat eserini oluşturan eser sahibinin lehine, önceden ortadan kaldırılamayan ve ayrı bir hak olarak tanımlanan, eser sahibinin eserin ilk devrini müteakip eserin yeniden satışı ile ilgili olarak alınmış olan satış fiyatı bazında bir telif hakkı ödenmesi için yeniden satış hakkı sağlayacaklardır. Bu Direktife göre, birinci fıkrada sözü edilen hak; satış merkezleri, sanat galerileri ve genel anlamda sanat eserleri ile ilgilenen herhangi bir tüccar kuruluş gibi, satıcılar, alıcılar veya sanat eserleri piyasası uzmanları olarak çalışan kişileri de içeren yeniden satışın bütün işlem ve faaliyetlerine uygulanacaktır. Üye devletler, bu hakkın, söz konusu satıştan önceki üç yıllık süreden daha kısa bir süre içinde, doğrudan bir şekilde alıcının eseri yaratıcısından satın almış olduğu yerde ve yeniden satış fiyatının 10.000 Euro düzeyini aşmadığı durumda, yeniden satış işlemlerine uygulanmayacağını göz önüne alabilir.

Direktifin 2. maddesine göre, “özgün eser”, sanatçı tarafından şahsen yapılmış olması veya özgün eser olduğu kabul edilen kopyalar olmaları kaydıyla, resimler, kolajlar, yağlı boya resimleri, çizimler, oyma çalışmalarları, baskılı eserler, litograflar, heykeller, büstler, dokuma eserleri, seramikler, cam eserler ve fotoğraflar gibi, grafik veya plastik sanat eserleri anlamında kullanılacaktır. Sanatçının şahsen sınırlı sayıda oluşturmuş olduğu veya kendi kontrolünde ve yetki vermesi ile oluşturulmuş

olan ve bu Direktif kapsamında yer alan eserlerin kopyaları bu Direktifin amaçları doğrultusunda, özgün sanat eseri olarak kabul edileceklerdir.

Direktifin 3. maddesine göre; birinci maddede sözü edilen satışların yeniden satış hakkına konu edilmesini getiren asgari bir satış fiyatının belirlenmesi, Üye devletin yetki ve görev alanı içinde olacaktır. Söz konusu asgari satış fiyatı, hiçbir durumda 3.000 Euro düzeyini aşamaz.

Türk Hukuku'nda ise FSEK madde 45, pay alma hakkını bazı şartlara bağlamış ve her eser türü için değil; sadece güzel sanat eserlerinin asılları ile eser sahibinin kendisinin sınırlı sayıda meydana getirdiği veya eser sahibinin kontrolünde ve izniyle meydana getirilmiş ve eser sahibi tarafından imzalanmış veya başka bir şekilde işaretlenmiş olmaları nedeniyle özgün eser olduğu kabul edilen kopyaları, yazarlarla bes-tecilerin el yazısıyla yazılmış eserlerinin asıllarından biri için bu hakkın uygulama alanı bulacağını belirtmiştir. Pay almaya konu olacak eser türleri sınırlı olarak sayıldığından müzik eserleri açısından geniş bir uygulama olanağı yoktur.

VI. KOMŞU VE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİNİN HAKLARI

Bağlantılı haklar dört grup hak sahibi için düzenlenmiştir. İlk üç grup hak sahibi komşu hak sahipleri olarak anılmaktadır. Komşu hak sahipleri; icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon yayıncılarıdır. Diğer bağlantılı hak sahibi ise film yapımcılarıdır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ilk maddesinin **j** bendinde **bağlantılı haklar**; *“eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları haklar”* ve **k** bendinde **komşu haklar**; *“eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarının sahip oldukları haklar”* şeklinde tanımlanmıştır.

FSEK 80. maddenin ilk kısmında da; eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarının bu maddede düzenlenen komşu hakları olduğu belirtilmiştir. Aynı maddede daha sonra diğer bağlantılı hak sahibi olan film yapımcılarına değinilmiştir.

1995 yılında Türk Hukuku'na giren bağlantılı haklar ülkemizde 35 yıllık bir yarayı tedavi etme misyonunu üstlenmiştir. İlk olarak 1961 yılında Roma Sözleşmesi ile korunmaya başlayan bağlantılı hak sahipleri 35 yıl Türkiye'de yok sayılmış ve bu sebeple bağlantılı hak sahiplerinin ürettikleri yapıtlar adeta talan edilmişlerdir. Bu kadar yıl boyunca otel, lokanta, cafeler, gece klüpleri, mağazalar gibi umumi yerlerde gerek plak ve kasetlerden ve gerekse cd'lerden ve Devlet'e ait radyo ve televizyonlarda dinletilen müzik yapıtları için hak sahiplerine hiçbir ödeme yapılmamıştır. Yine 1990'larda başlayan özel radyo ve televizyon ya-

yınları birçok müzik yapıtını yaklaşık on yıl boyunca (son beş yılı yasal düzenlemeye aykırı olarak) çoğunlukla herhangi bir bağlantılı hak sahibinden izin almadan ve onlara telif bedeli ödemededen kullanmışlardır.

2000’li yıllarda müzik yapımcıları, icracı sanatçılar ve radyo ve televizyon kuruluşları tarafından kurulan meslek birlikleri sayesinde, müzik eserlerini bağlantılı hak sahiplerinden izin almadan ve onlara para ödemededen fütursuzca kullanan kişilere karşı mücadeleye başlanabilmiştir. Yaklaşık beş yıl boyunca daha çok yargı kararları ile yapılan bu mücadele nihayet müzik eserlerini izin almadan kullanan kişileri artık meslek birlikleri ile anlaşma yapıp izin almak zorunluluğu aşamasına getirebilmiştir. Radyo ve televizyonlardan başlayan izin alma ve sözleşme yaparak lisans alma sürecine otellerin işletmecisi ve sahiplerinin çektiği bir grup umumi yer birkaç yıl daha direnmiştir. Sonunda 2008 yılında bu direniş de sona ermiştir.

Bu süreç içinde özellikle Alman Hukuku’ndaki “bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın sadece uygun bir bedel ödenme esası”na dayanan telif hakkı ihlalcileri, özellikle Alman Hukukunu eserlerinde inceleyen bazı akademisyenlerin eserlerinden yararlanmış bazende arkalarına aldıkları ticaret odalarının hazırlattığı ve bastırdığı yine telif haklarının farklı biçimde korunduğu ülke hukuk kurallarına dayandırılan ama Türk Hukuku’nu özellikle incelemekten kaçınan bazı hukukçuların çalışmalarından fayda ummuşlardır.

O dönemlerde de her platformda ve toplantılarda belirttiğimiz gibi Alman ve Amerikan Hukuklarının bizimki gibi bir koruma sistemini seçmemeleri doğaldır. Çünkü bu ülkelerde bağlantılı hak sahiplerinin hakları zaten ihlal edilmemektedir. Bu ülkeler vatandaşlarının kültür düzeyi -telif ihlallerini hırsızlık olarak gördüğünden- ülkemizden farklıdır. Bu ülkelerde müzik yapıtını kullanmak isteyen bir kuruluş veya kişi daha işini kurarken gidip, ilgili kuruluşlardan iznini almakta ve sözleşmesini yapmaktadır. Almanya ve Amerika’da vergi vermek gibi telif bedeli ödemek de oturmuş bir uygulamadır. Ancak bizim ülkemizde telif bedeli ödemek kültürü olmadığı gibi aksine telif bedeli ödemek enayilikti. Bu yüzden bizim yasa koyucumuz diğer birçok hukuk kuralında olduğu gibi ülkemiz koşullarına uygun biçimde, müzik yapıtlarını işyerlerinde veya yayınlarında kullanan kişilere sadece bedel ödeme zorunluluğunu değil, aynı zamanda bağlantılı hak sahiplerinden izin alma zorunluluğunu da getirmiştir. Yine Kanunumuz aksine davranışlar karşısında bağlantılı hak sahiplerine yargı yoluyla müzik yapıtlarının izinsiz kullanımlarını ya-

saklama hakkı da getirmiştir. Türk Hukuku'nun tercih ettiği bu koruma biçimi aynı zamanda uluslararası sözleşmelere de uygundur. Uluslararası sözleşmeleri imzalayan ülkeler, Sözleşmedeki kuralları kendi ülkeleri için **“asgari hukuki koruma kuralları”** olarak belirlemiş ve iç hukuklarına bu asgari kuralları mutlaka almıştır. Bazı ülkeler ise ya ihlallerin yaygınlığı sebebiyle ek korumalar sağlama amacıyla ya da başka ülkesel amaçlarla Bern Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerdeki bu asgari kurallarla yetinmeyip, ülkelerinde eser ve bağlantılı hak sahiplerine (uluslararası sözleşmelerde belirtilenlerden) daha geniş haklar tanımışlardır. Bern Sözleşmesi'nin 19. maddesi, fiktisel ve sanatsal haklar açısından **“bu Sözleşme hükümleri, Birlik ülkeleri mevzuatı ile tanınan daha geniş bir korumadan yararlanma isteğine engel oluşturmaz”** ve 20. maddesi **“Birlik ülkelerinin hükümetleri, aralarında eser sahiplerine bu Sözleşme ile tanınan haklardan daha geniş haklar veren veya bu Sözleşmeye aykırı hükümler içermeyen özel anlaşmalar yapma hakkını saklı tutarlar”** diyerek ve Roma Sözleşmesi'nin 1. maddesi **“Bu Sözleşme ile öngörülen koruma edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki telif haklarının korunmasını hiçbir suretle ihlal etmez ve etkilemez. Bu sebeple bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, işbu korumayı ihlal edebilecek şekilde yorumlanamaz”** ve 21. maddesi **“Bu Sözleşme tarafından öngörülen koruma, icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının ve yayın kuruluşlarının başka şekilde yararlanabilecekleri korumaya halel getirmez”**; 22. maddesi de **“Akit devletler, icracı sanatçılara, fonogram yapımcılarına veya yayın kuruluşlarına, bu Sözleşmedeki haklardan daha kapsamlı haklar tanıyan veya bu Sözleşmeye aykırı bulunmayan diğer hükümleri içeren özel anlaşmalar yapma hakkını saklı tutarlar”** diyerek, anlaşmacı ülkelere kendi ülke iç hukuk kurallarıyla müzik eseri ve bağlantılı hak sahiplerine daha geniş haklar tanınması olanağını vermektedir.

Sözleşmelerle sadece olmazsa olmaz asgari kuralları koyma amacı; Bern Sözleşmesi'nden sonra hazırlanan Roma Sözleşmesi, WIPO Sözleşmeleri ve AB direktiflerinin hepsinde sürdürülmektedir. İşte Bern Sözleşmesi'ne uygun hazırlanan bizim Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'muz, daha sonra ortaya çıkan uluslararası hukuk sözleşme ve kurallarındaki gelişmeler paralelinde bağlantılı hak sahiplerine, uygun bedel alma asgari koruması yanında, ülkemizdeki fikir ve sanat eserlerine yönelik yaygın saldırıları önlemek için izin ve yasaklama yetkilerini de kapsayan daha geniş hukuki koruma kurallarını ve hakları tanımıştır.

Avrupa Adalet Divanı'nın otel odalarında çalınan müzik yapıtları için telif bedeli ödeme zorunluluğu ve ülkemizdeki otellere karşı alınan izinsiz müzik yayınlarının durdurulması ve tazminat ödenmesi yönündeki yargı kararlarının da etkisiyle son kale olan otelciler direnişi de sona ermiştir. Artık müzik eserlerini kullanan radyo televizyon yayıncıları gibi otelciler ve mağaza sahipleri de kendi sivil toplum kuruluşları aracılığı ile müzik meslek birlikleri ile yaptıkları görüşmeler sonucu toplu biçimde lisanslama düzenine girmişlerdir. Meslek birlikleri ile müzik yapıtlarını kullanan meslek temsilcilerinin toplu sözleşme görüşmeleri yaparak anlaşmaları özellikle diğer kullanıcılarda bir bilinçlenmeye yol açmakta ve telif hakkı ihlallerini önemli oranda azaltmaktadır.

Bağlantılı haklar alanında şu dönemlerdeki en önemli sorun internet üzerinde müzik yapıtlarını kullanan kişi ve grupların yaptıkları ihlallerdir. Bu sorun eser sahipleri için de geçerlidir. Günümüzde internet ortamlarında %95 oranındaki ihlaller için de yakın bir zamanda etkili önlemler oluşturulacağına dair inancımızla bağlantılı haklara ilişkin bu giriş açıklamamızı sonlandırıyoruz.

A. İCRACI SANATÇILARIN HAKLARI

1961 Roma Sözleşmesi ile hukuk alanında ortaya çıkan ve hakları korumaya alınan icracı sanatçılar, Türk Hukuku açısından korunmaya 1995 yılında FSEK'de yapılan değişiklikle başlanmış ve kısa zamanda uygulamacılar açısından bu koruma kabul görmüştür.

İcracı sanatçı genellikle kendisine ait olmayan bir eseri seslendirerek ve yorumlayarak, o esere ruh ve anlam kazandıran kişidir. Bu bakımdan icracı sanatçı gerçekte eser sahibi ile eserden yararlanacak olanlar arasında bir tür aracılık görevi yapmakta ve sarf ettiği sanatsal emekle eserin yaratılmasına değil, fakat yayılmasına hizmet etmektedir. EREL'e göre; icra ve temsil sanat açısından ne kadar büyük bir değer taşırsa taşırsın, sanatçının faaliyeti gerçekte eser sahibinin duygularını ifadede bir vasıta olmaktan ibarettir; meydana gelen fikri ürün başkasına ait eserin nakliyle sınırlıdır ve ortaya “*eser*” niteliğinde yeni bir ürün çıkmış olmaz.

Bazı hallerde eser icracı sanatçının kimliğiyle özdeşleşebilir ve eser, sahibinden çok icracının adıyla anılabilir. Buna rağmen ne icrayı eser saymak, ne de icracıyı eser sahibi kabul etmek mümkündür. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, işlemler dahil olmak üzere bir fikir ürününe eser niteliği tanınabilmesi için; az çok bağımsız bir fikri emek sarfıyla

var olandan başkasının meydana getirilmiş olması aranır. Halbuki icracı sanatçının faaliyetinde bu unsur eksiktir; meğer ki sanatçı eseri icra ve temsil ederken improvizasyonda bulunsun, yani doğaçlama yoluyla kendiliğinden bazı ilaveler yaparak esere farklı bir şekil vermiş olsun¹. Bununla birlikte aynı eserin değişik sanatçılar tarafından icrasının dinleyici veya seyirci üzerinde başka etkiler yaratması, icra ve temsilin eserin kendisinden farklı bir fikri (sanatsal) emek ürünü olduğunun kanıtıdır. İşte icra ve temsilde sanatçının korunacak olan fikri emeği budur!²

EREL'e göre; icracı sanatçının korunması, ancak icranın orijinal bir fikri emek ürünü olması halinde mümkündür. Bir eserin herkesin yapabileceği tarzda icra ve temsil olunması halinde, kanaatimizce ortada korunmaya değer bir fikri emek ürünü yoktur. Fikir ürünlerinin eser sayılmasında az çok bağımsız bir fikri emeğin mevcudiyeti ve var olandan başkasının meydana getirilmiş olması yeterli iken, zaten mevcut bir eserin alelade her yorumuna da başlıbaşına bir koruma sağlamak doğru değildir. Bu yüzden icracı sanatçının fikri emeğinde orijinallik ve özellik ölçüsü, asıl eserde aranandan daha ileri bir düzeyde olmalıdır. Nitekim Roma Sözleşmesi'nde "*fikir ve sanat eserlerini **kendi kişisel özellikleri ile tanıtan, anlatan, söyleyen, oynayan veya icra eden***" kişilerden FSEK madde 80/I'de de "*....fikir ve sanat eserlerini **özgün bir biçimde icra eden**, yorumlayan icracı sanatçılar*"dan söz edilmektedir.³ ARKAN'a göre; özgünlük; icracının, icrada kendi kişisel ve sanatsal özelliklerinin yer alması ve bu şekilde yapılan icranın diğer icralardan ayrılması şeklinde tanımlanabilir⁴.

Ancak EREL'in bu görüşünün ve FSEK'in "özgünlük" şartının önemi; WIPO Sözleşmesi'nin "*edebiyat ya da sanat eserlerini veya folklorik ifadeleri **herhangi bir şekilde** yorumlayan*" şeklindeki icracı tanımı karşısında artık kalmamıştır. Çünkü kim olursa olsun yorumcunun seslendirmesi veya eseri sunuşu mutlaka o icraya bireysel bir özellik katacaktır.

İcracının korunmasıyla asıl eserin korunması arasında da bir denge kurmak zorunluluğu vardır. Doktrinde eskiden, sanatçının icra ve temsilde belirtilen emeğinin korunması, hiçbir zaman asıl eserin korunma-

¹ ARSLANLI, age., s. 49-50; AYİTER, age., s. 74-75

² EREL, age., s. 165

³ EREL, age., s. 166

⁴ ARKAN, age., s. 51

ısıyla aynı düzeyde olamayacağı⁵ kabul edilmekteydi. Bu görüşün taraftarları, icracı sanatçıyla eser sahibini fikri hukukun aynı vasıta ve imkanlarından istifade ederek korumanın, sonuçta eser sahibinin eseri üzerindeki serbest tasarruf imkanını kısıtlamaya ve eserin başka sanatçılar tarafından icra edilmesini engellemeye kadar gidebileceğini belirtmekteydiler. Bize göre, Roma Sözleşmesi'nden sonra ve özellikle WIPO Sözleşmesi'nin vurguları ve koruma sistemi ile; eser sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri arasındaki öncelikli koruma yöntemi ortadan kalkmış ve her iki gurubun da hakları eşit ve önceliksiz olarak korunmaya başlamıştır. AB direktiflerinin giriş kısımlarında, eser sahibine paralel bir konumlama özellikle icracı sanatçılara ve fonogram yapımcılarına tanınmıştır.

FSEK madde 82'ye göre, icracı sanatçılara, bu Kanunun icracı sanatçılara ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için şu şartlardan birinin yerine gelmesi gereklidir:

- İcracı sanatçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise bu Kanun hükümlerine tabi olacaktır.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamakla birlikte, icraları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirilen, bu Kanun hükümlerinin uygulandığı ses taşıyıcılarına dahil edilen ve bir ses taşıyıcısına tespit edilmiş ancak bu Kanun hükümlerinin uygulandığı fonogramlara veya ilk film tespitlerine dahil edilen ve bir fonograma veya bir filme tespit edilmemiş ancak bu Kanun hükümlerinin uygulandığı radyo-televizyon yayınlarıyla yayınlanan, icracı sanatçılar da bu Kanun hükümlerine tabi olacaktır.

Aynı maddeye göre, bu Kanun'un bağlantılı haklarla ilgili hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu bir uluslararası anlaşma hükümlerine göre korunan icracı sanatçılara, yapımcılara ve radyo televizyon kuruluşlarına da uygulanacaktır⁶.

1961 Roma Antlaşmasına göre de her akit devlet aşağıdaki şartlardan birinin mevcudiyeti halinde yorumlayan ve icra eden sanatçılara ulusal uygulama tanıyacaktır:⁷

- a) İcranın başka bir akit devlet sınırları içinde yapılmış olması,
- b) İcranın 5 inci madde gereğince korunan bir plâğa kaydedilmiş olması,

⁵ Doktrinde ileri sürülen görüşler ve kaynaklar için bkz. AYİTER, age., s. 74 not 1

⁶ Gül OKUTAN, "Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Fikir ve Sanat Eserleri", Prof. Dr. Nihal Uluocak Armağanı, İstanbul, 1999, s. 241-242; § 5 N. 39.

⁷ EREL, age., s. 168

c) Bir plâğa kaydedilmemiş olan icranın 6 ıncı madde gereğince korunan bir yayınla yayınlanmış olması.

Türkiye, Roma (madde 4) ve TRIPS Anlaşmaları'na (madde 3) taraf olmakla, diğer Anlaşmacı Devletlerin vatandaşlarına, belli şartların gerçekleşmesi ile Türk Hukuku'nun eser ve bağlantılı hak sahiplerini koruma konusundaki hükümlerini uygulamak yükümü altına girmiştir.

İcracı Sanatçı Kavramı

1961 tarihli Roma Sözleşmesi'nin madde 3/a hükmüne göre de, *“yorumlayan veya icra eden sanatçı (performing artists, artistes interpretes ou executants); fikir ve sanat eserlerini kendi kişisel özellikleri ile tanıtan, anlatan, söyleyen, oynayan veya icra eden aktörleri, şarkıcıları, müzisyenleri, dansçıları ve diğer kişileri (...) ifade eder.”*⁸

1996 tarihli WIPO İcralar Ve Fonogramlar Andlaşması'nın 2. maddesine göre de; **“icracı sanatçılar”**, *edebiyat ya da sanat eserlerini veya folklorik ifadeleri herhangi bir şekilde yorumlayan, tanıtan, söyleyen, oynayan ya da icra eden aktörler, şarkıcılar, müzisyenler, dansçılar ve diğer kişileri ifade eder.*

FSEK madde 80/I hükmüne göre; *“eser sahibinin maddi-manevi haklarına hanel getirmemek şartıyla, fikir ve sanat eserlerini özgün bir biçimde icra eden, yorumlayan, icracı sanatçılar(ın)....eser sahibinin haklarına komşu hakları vardır.”* Burada belirtilen **icracı sanatçı** kavramı, 1997 tarihli *“Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği”*nde, *“sanat eserleri ile folklor eserlerini özgün biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden; oyuncular, ses sanatçıları, müzisyenler ve dansçılar vb. diğer kişiler”* şeklinde tanımlamıştır.

Görüldüğü gibi gerek Roma ve WIPO Antlaşmalarında gerek onun kadar ayrıntılı olmayan FSEK hükmünde icracı sanatçı tanımı, neredeyse fikir ve sanat eserlerini temsil yoluyla kamuya sunabilen bütün şahısları kapsayacak ölçüde geniş tutulmuştur. EREL'e göre; burada A.B.D. Hukukunda yapılan “public performance” ve “public display”

⁸ 26.10.1961 tarihli Roma Sözleşmesinin Türkçeye tercümesi için bkz. Akın BEŞİROĞLU, “Fikir Haklarına Komşu Haklar”, Ankara Barosu Dergisi, 1967, Sayı 6, s. 934-942.

ayırımı dikkate alınmalı⁹ ve icracı sanatçı; eseri teşhir (display) eden değil, icra (perform) eden şahıs olarak düşünülmelidir. Ayrıca bu geniş tanım içine sinema eserlerinde rol alan oyuncular da dahil etmek mümkün olduğu halde, uygulamada bu şahısların haklarını baştan sözleşmeyle yapımcıya devrettikleri görülmektedir. Buna karşılık sahne eserlerinde, koro ve orkestralarda bulunan aktör, dansçı, müzisyen, solist ve diğer sanatçılar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu açısından “icracı sanatçı”dırlar.¹⁰

İcracı sanatçı kapsamına, eseri doğrudan doğruya icra eden yani çalan, söyleyen, oynayan kimseler kadar, artistik katkılarıyla bu icraya yön ve şekil veren şef ve yönetmen de dahildir. Bir orkestra, koro veya tiyatro grubu tarafından icra edilen eserlerde FSEK madde 80/III hükmü; icranın tespit, çoğaltma, kiralama ve yayını hususunda şefin izninin yeterli olduğunu belirterek orkestra şefine icracı sanatçı statüsü tanınmıştır.¹¹

EREL’e göre; sinema ve sahne eserlerinde değişik nitelik ve yoğunlukta katkıda bulunan kimseler, mesela kameraman, ışıkçı, kostümcü vb. de bir bakıma icracı sanatçılardır. Ancak bunların katkısı icranın bütününden ayrı olarak ve başlıbaşına değerlendirilmeye elverişli olmadığından, mali menfaatleri kendilerini istihdam edenle yaptıkları sözleşme çerçevesinde korunacak ve icranın tespit, çoğaltma ve yayını üzerinde hak talep edemeyecektir.¹² ARKAN; EREL’in aksine bu kimseleri

⁹ A.B.D. 1976 tarihli Telif Hakları Kanunu § 101 hükmünde “display (teşhir)”, bir eserin aslının veya kopyasının doğrudan doğruya veya film, slayt, televizyon görüntüsü yahut diğer herhangi bir vasıta veya süreçle (process) gösterilmesi, sinema eserleriyle diğer görsel/işitsel (audiovisual) eserlerde ise münferit görüntülerin peş peşe olmadan gösterilmesi olarak; “performance (icra)” ise, bir eserin doğrudan doğruya veya bir araç yahut süreç yardımıyla okunması, nakledilmesi, oynanması dans veya aktörlük icrasıyla canlandırılması, sinema eserlerinde ve diğer görsel/işitsel eserlerde ise görüntünün herhangi bir sırayla gösterilmesi veya eşlik eden seslerin duyurulması şeklinde tarif edilmektedir. Donald F. JOHNSTON: Copyright Handbook, Second Edition, New York & London, 1982, s. 42-43; William F. PATRY: Latman’s The Copyright Law, BNA Books, Washington D.C. 1986, s. 218-220, 238. Naklen EREL, age., s. 167

¹⁰ EREL, age., s. 167

¹¹ Tiyatro gruplarında şef o grubu istihdam eden şahsı, böyle bir şahıs yoksa yönetmeni ifade eder.

¹² EREL, age., s. 168

icracı sanatçı olarak nitelendirmemektedir.¹³ Biz de ARKAN gibi düşünüyoruz.

Yine şiir icra edenleri icracı sanatçı olarak korumak mümkün olabilmektedir.¹⁴

Doktrinde tartışma alanı bulan diğer bir konu ise icracı sanatçının, icra ettiği eserin aynı anda eser sahibi olması durumunda icracı sanatçıya ait hükümlerden mi yoksa eser sahibine ilişkin hükümlerden mi yararlanacağıdır? AYİTER ve EREL; söz konusu durumda kendi eserini icra eden kişinin zaten eser sahibi sıfatıyla korunduğunu ek bir korumaya ihtiyacı olmadığını ileri sürmektedirler. ARKAN'a göre böyle bir durumun varlığı halinde kişi, hem eser sahibine ilişkin hükümler çerçevesinde hem de icracı sanatçıya ilişkin hükümler çerçevesinde korunurlar. Bize göre de; bu kişi icraları açısından icracı sanatçı olarak ve yarattığı beste ve/veya söz açısından ise eser sahibi olarak ayrı ayrı korunmalıdır. Çünkü bir ihlal olduğunda, ihlal sadece bir alana özgü olabilir ve eser veya icrası korumasız kalabilir.

İcra sanatçı sayılmak ve buna bağlı haklardan yararlanmak için temyiz kudretine sahip olmak dahi gerekli değildir. Zira icra bir hukuki işlem değil, maddi bir fiildir. Bir çocuk ya da zihinsel özürlü de icracı sanatçı sayılır ve bu statüye bağlanan haklardan yararlanır. Öyleyse günümüzde gösterilerine sıklıkla rastladığımız çocukların ya da zihinsel özürlü kimselerin yaptıkları icralar, onlara icracı sanatçıya tanınan hakları sağlar¹⁵. Bu kimselerin haklarının korunması yasal temsilcileri tarafından sağlanacaktır. Bu arada belirtilmelidir ki, icranın birden çok icracı tarafından gerçekleştirilmesi de mümkündür¹⁶.

Bu açıklamalarımız doğrultusunda ARKAN'ın kimlerin icracı sanatçı olabileceklerine dair kullandığı unsurları vermekte fayda görüyoruz¹⁷.

1) Ancak gerçek kişiler icracı sanatçı olabilir.

2) Yalnızca sanatsal faaliyet gösteren kişiler icracı sanatçı olarak korunabilir.

¹³ ARKAN, *age.*, s. 45

¹⁴ ARKAN, *age.*, s. 49

¹⁵ TEKİNALP, *age.*, § 12 N. 13.

¹⁶ ARKAN, *age.*, s. 44

¹⁷ ARKAN, *age.*, s. 44 vd.

3) Bir kimsenin icracı sanatçı olarak korunabilmesi için bir eser icra etmesi gerekir .

4) İcranın özgün olması gerekir.

5) İcranın üçüncü kişiler için yapılması gerekir.

Bu genel açıklamalardan sonra gelelim icracı sanatçıların haklarına.

Roma Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre; *“icrası sanatçılar için sağlanan koruma:*

a) *Yayın veya umuma arz suretiyle kullanılan icranın bizzat daha evvel radyo ile yayınlanmış bir icra olması veya daha önce yapılan bir tespitten yayınlanması hariç, kendi icralarının izinleri olmaksızın yayınlanmasını ve umuma arzını;*

b) *İzinleri olmaksızın tespit edilmemiş olan icraların tespitini;*

c) *İzinleri olmaksızın tespit edilmiş olan icralarının;*

i- *Eğer ilk tespit izinleri olmaksızın yapılmışsa;*

ii- *Eğer çoğaltma, izin vermiş oldukları amaçlar dışında başka bir amaçla yapılmışsa;*

iii- *Eğer ilk tespit, 15'inci maddeye göre yapılmış ve bu madde hükümleri ile güdülen amaçlardan başka amaçlar güdülerek çoğaltılmışsa, izinleri olmaksızın çoğaltılmasını önleyecektir.”*

Aynı maddenin 2. fıkrasına göre;

“(1) *İcracı sanatçının, yayına izin vermesi halinde yayın tekrarlarına, yayın amacıyla yapılacak tespitlere ve böylece bir tespitin yayın amacıyla çoğaltılmasına karşı öngörülecek koruma, ülkesi üzerinde koruma istenilen akit devletin ulusal mevzuatı ile düzenlenir.*

(2) *Yayın kuruluşları tarafından, yayın amacıyla yapılmış olan tespitlerin yayın kuruluşları tarafından kullanılma şekilleri, ülkesi üzerinde koruma istenilen akit devletin ulusal mevzuatı ile düzenlenir.*

(3) *Bununla birlikte, bu maddenin 1 ve 2 numaralı alt paragraflarında öngörülen hallerde ulusal mevzuat, icracı sanatçıların yayın kuruluşları ile ilişkilerini anlaşma yolu ile düzenleme hakkında mahrum edemez.”*

Sözleşmenin 8. maddesine göre; *her akit devlet, icracı sanatçılar arasından birden fazlasının aynı icraya katılmaları halinde, bunların haklarını kullanma bakımından temsil edilme şekillerini kendi ulusal mevzuatıyla tayin edebilir.*

Sözleşmenin 9. maddesi ise, her akit devletin, kendi ulusal mevzuatıyla, işbu Sözleşmede öngörülen korumayı, edebiyat veya sanat eserleri icra etmeyen sanatçılara da teşmil edebileceğini düzenlemektedir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 6. maddesi “İcracı Sanatçıların Tespit Edilmemiş İcralarına İlişkin Mali Hakları” başlığı ile icracı sanatçının mali haklarını;

“(1) Tespit edilmemiş icraların, bunların henüz yayınlanmış olduğu durumlar hariç, radyo televizyon ile yayınlanmasına ve topluma iletilmesine ve,

(2) Tespit edilmemiş icranın tespit edilmesine, münhasıran izin verme hakkı” olarak düzenlemiştir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 7. maddesi “çoğaltma hakkını”; *“icracılar, herhangi bir şekil veya yöntemle, tespit edilmiş icraların doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılmasına münhasıran izin verme hakkından faydalanacaktır”* şeklinde düzenlemiştir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 8. maddesi “yayma hakkını”;

“(1) İcracı sanatçılar, fonogramlar üzerine tespit edilmiş olan icralarının aslı veya kopyalarının satış veya başka bir şekilde hak sahipliğini devretmek yoluyla topluma sunulmasına münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

(2) Bu Andlaşmadaki hiçbir hüküm, akit tarafların sanatçının izni ile tespit edilmiş olan icrasının özgün nüshası ya da kopyası üzerindeki sahipliğin ilk satışı ya da başka bir şekilde hak sahipliğinin devrinden sonra, (1) inci paragrafta öngörülen hakkın tükenmesine ilişkin muhtemel şartları belirleme yetkisine halel getirmez” şeklinde düzenlemiştir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 9. maddesi “Kiralama Hakkını”;

“(1) İcracı sanatçılar, fonogramlar üzerine tespit edilen icraların asıl ya da kopyalarının sanatçının verdiği yetki ile ya da bu yetkiye uygun olarak dağıtılmasından sonra dahi, akit tarafların ulusal yasaları ile belirlendiği şekilde topluma ticari olarak kiralınması hususunda münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

(2) (1) inci paragraf hükümlerine rağmen, 15 Nisan 1994 tarihinde, fonogramların içerdiği eserlerin kopyalarının kiralınması karşılığında eser sahiplerine hakkaniyetli bir ücret sistemi uygulayan veya uygulamakta olan akit bir taraf, fonogramların içerdiği eserlerin ticari olarak kiralınması eser sahiplerinin münhasır çoğaltma hakkına maddi şekilde zarar vermedikçe, bu sistemi muhafaza edebilir” biçiminde belirtmiştir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 10. maddesi “kamu-
nun erişimine sunma hakkını”, “*gerçek kişilerin seçtikleri yer ve za-
manda erişim sağlayabilecekleri şekilde, icracılar fonogramlarda tespit
edilmiş icralarının aslı ya da çoğaltılmış nüshalarını telli veya telsiz
araçlarla topluma iletilmesine münhasıran izin verme hakkından fayda-
lanacaklardır*” şeklinde hüküm altına almıştır.

22 Mayıs 2001 tarih ve 2001/29/AT sayılı “Bilgi Toplumunda Telif
Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İliş-
kin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi”nin 2. maddesinde ise “
çoğaltma hakkı” konusunda;

“Üye devletler, kısmen veya tamamen, her türlü yöntem ve şekilde,
kalıcı veya geçici röprodüksiyonları hakkında: ... icracı-sanatçılar ve
onların icralarının düzenlenmesini;

*doğrudan veya dolaylı yasaklama veya müsaade etmeye münhasır
haklarını korur*” şeklinde düzenleme yapmıştır.

Aynı Direktif 3. maddesinde “yayın ve umuma iletim” konusunda;

“Üye devletler, tel üzerinden veya telsiz vasıtalarla eserlerini ya-
yınlama, böyle bir yolla kamuya bireylerin tercih ettikleri bir zamanda
ve bir yerden erişebilme münhasır haklarını

(a) *icracı-sanatçılar, kendi icralarının düzenlenmesi;*

için korur” şeklinde hüküm koymuştur. Direktifte bu hakların, ya-
yınlama veya yayınlama kararının alınması için yapılan haberleşmenin
herhangi bir işlemi tarafından tüketilemeyeceği de düzenlenmiştir.

19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri
Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair
Konsey Direktifi” ise şu düzenlemeleri getirmiştir.

Direktifin “kiralama ve ödünç verme hakkı” konusundaki 2. mad-
desine göre; *kiralama ve ödünç vermeyi yetkilendirme ve yasaklama
münhasır hakkı, icra tespiti hakkında icracı sanatçıya aittir. Bu haklar;
aktarılabılır, devredilebilir ve akdi lisans vermeye tabi olabilir.*

Direktifin “vazgeçilmez adil bedel hakkı” konusundaki 4. madde-
sine göre;

“1. Eser sahibinin ya da icracının fonogram, film ya da kopyasına
ilişkin kiralama hakkını fonogram ya da film yapımcısına aktardığı ya
da devrettiği durumda, söz konusu eser sahibi ya da icracı, kiralama
konusunda adil bedel elde etmek için, bu hakkı elinde tutar.

2. Kiralama konusunda adil bedel elde etme hakkı, eser sahipleri ya da icracıları temsil eden meslek birliklerine havale edilebilir.

3. Adil bedel elde etme hakkının yönetimi, eser sahiplerini ya da icracıları temsil eden meslek birliklerine havale edilebilir.

4. Üye devletler, söz konusu bedelin kimden talep edilip alınacağı konusu yanında, adil bedel elde etme hakkının meslek birlikleri tarafından yönetiminin uygulama sınırlarını düzenleyebilirler.”

Direktifin “kamuya ödünç verme hakkı” konusundaki 5. maddesine göre;

“1. Üye devletler, en azından eser sahiplerinin bu nevi ödünç verme için bedel elde etmeleri şartıyla, kamuya ödünç verme hakkında madde 1’de sağlanan münhasır hakkı elden alır. Üye devletler, kültürel tanıtım amaçlarını göz önünde bulundurarak, söz konusu bedeli belirleme hakkına sahiplerdir.

3. Üye devletler, bazı kuruluşları, 1. ve 2. fıkralarda göndermede bulunulan bedel ödemesinden muaftutabilirler.”

Direktifin tespit hakkı konusundaki 6 maddesine göre; üye devletler, icracılara, icralarının tespiti konusunda yetki verme ya da yasaklama münhasır hakkını sağlarlar.

Direktifin çoğaltım hakkı konusundaki 7. maddesine göre; üye devletler icracılara icralarının tespiti konusunda, doğrudan ya da dolaylı çoğaltıma izin verilmesi ya da bunun yasaklanması münhasır hakkını sağlarlar. Çoğaltım hakkı, aktarılabilir, devredilebilir ya da akdi lisansların verilmesine tabi olabilir.

Direktifin yayın hakkı konusundaki 8. maddesine göre;

“1. Üye devletler, yayın icrası veya tespit sonucu gerçekleştirilen icra haricinde, icracılara kablosuz yayın konusunda yetkilendirme ya da yasaklama ve icralarının kamuya iletimi münhasır hakkını sağlarlar.

2. Üye devletler, ticari amaçlarla yayınlanan fonogram ya da bu nevi fonogramın çoğaltımı, kablosuz yöntemlerle yayın ya da kamuya iletim amacıyla kullanılıyorsa, tek adil bedelin kullanıcı tarafından ödenmesini sağlamak ve söz konusu bedelin ilgili icracılar ve fonogram yapımcıları arasında paylaşılmasını sağlamak için hak sağlarlar. Üye devletler, icracılar ve fonogram yapımcıları arasında anlaşma olmaması durumunda, söz konusu bedelin onlar arasında paylaşılmasını belirleyen şartları düzenlerler.”

Direktifteki dağıtım hakkı konusundaki 9. maddesine göre;

“1. Üye devletler, icralarının tespiti hakkında icracılara, satış ya da başka yollarla, buradan itibaren “dağıtım hakkı” olarak göndermede bulunulan söz konusu maddelerin ve kopyalarının kamuya sunumu münhasır hakkını sağlarlar.

2. Dağıtım hakkı, söz konusu maddenin topluluk içerisindeki ilk satışının hak sahibi tarafından ya da kendi rızasıyla gerçekleştirildiği durum haricinde, 1. fıkrada göndermede bulunulan maddeye ilişkin olarak topluluk içerisinde son bulmaz.

Dağıtım hakkı, aktarılabilir, devredilebilir ya da akdi lisansların verilmesine tabi olabilir.”

FSEK madde 80’nin 1 no’lu fıkrasında A bendinde icracı sanatçıların hakları şu şekilde sayılmıştır:

“(1) İcracı sanatçılar, mali haklardan bağımsız olarak ve bu hakları devretmelerinden sonra dahi, tespit edilmiş icraları ile ilgili olarak uygulama şartlarının gerektirdiği durumlar hariç, icralarının sahibi olarak tanıtılmalarını ve icralarının kendi itibarlarını zedeleyebilecek şekilde tahrif edilmesi ve bozulmasının önlenmesini talep etme hakkına sahiptirler.

(2) Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçı, bu icranın tespit edilmesine, bu tespitin çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve temsiline izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidir.

(3) İcracı sanatçı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespit edilmiş icralarının, aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme veya yasaklama hakkına sahiptir.

(4) İcracı sanatçı, tespit edilmiş icrasının veya çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda icrasına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. Umuma iletim yoluyla, icraların dağıtım ve sunulması icracı sanatçının yayma hakkını ihlal etmez.

(5) İcracı sanatçılar bu haklarını uygun bir bedel karşılığında sözleşme ile yapımcıya devredebilirler.

(6) *İcranın, bir orkestra, koro veya tiyatro grubu tarafından gerçekleştirilmesi halinde, orkestra veya koroda yalnız şefin, tiyatro grubunda ise yalnız yönetmenin izni yeterlidir.*

(7) *Bir müteşebbisin girişimi ile ve bir sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen icralar için müteşebbisin¹⁸ de izninin alınması gereklidir.”*

Bu yasal düzenlemeleri aktardıktan sonra ARKAN’ın yöntemini kullanarak icracı sanatçıların haklarını şu şekilde sıralayabiliriz¹⁹:

Manevi Haklar:

- a) İcrasının Sahibi Olarak Tanıtılmasını Talep Hakkı
- b) İcrasının İtibarını Zedeleyecek Şekilde Değiştirilmesi Yasaklama Hakkı
- c) İcradan Doğan Hakların Sanatçı Kişiliğine Zarar Verecek Şekilde Kullanılmasını Yasaklama Hakkı.

Mali Haklar:

- a) Tespit Hakkı
- b) Çoğaltma Hakkı
- c) Yayma Hakkı
- d) Temsil (Kamuya Sunma) Hakkı
- e) Kamuya (Umuma) İletim Hakkı
 - Yayın ve Yeniden Yayın Yoluyla Kamuya İletim
 - Kamunun Erişimine Sunma (Kamuda Erişebilir Kılma Yoluyla Kamuya İletim)

1. İcracı Sanatçıların Manevi Hakları

İcracı sanatçıların manevi hakları konusunda ilk düzenlemeyi WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 5. maddesinde şu şekilde görüyoruz: *“Sanatçıların mali haklarından bağımsız olarak ve bu hakların devredilmesinden sonra dahi, icracı sanatçılar, canlı sesli icralar ya da fonogramlar üzerine tespit edilmiş icralar ile ilgili olarak, icranın*

¹⁸ Bu hüküm özellikle konser düzenleyen organizatörler tarafından kullanılabilir. Konser kayıtlarını mali haklar açısından çeşitli şekillerde kullanmak isteyenler; eser sahibi ve icracı sanatçının (eğer konserde playback yapılıyorsa fonogram yapımcısının da) ve organizatörün iznini almak durumundadırlar.

¹⁹ ARKAN, age., s. 67 vd.

kullanım şekli bu ifadenin ortadan kaldırılmasını gerektirmedikçe, icracı sanatçı kendi eserlerinin icracısı olarak tanımlanma hakkını muhafaza eder ve icranın kendi itibarını halel getirecek şekilde tahrif edilmesine, bozulmasına ve herhangi bir şekilde değiştirilmesine muhalefet etme hakkını muhafaza eder”.

Türk Hukukunda ise manevi haklar konusundaki ilk düzenleme FSEK madde 80’nin 1 no’lu fıkrasında A bendinde şu şekilde belirtilmiştir. *“İracı sanatçılar, mali haklardan bağımsız olarak ve bu hakları devretmelerinden sonra dahi, tespit edilmiş icraları ile ilgili olarak uygulama şartlarının gerektirdiği durumlar hariç, icralarının sahibi olarak tanıtılmalarını ve icralarının kendi itibarlarını zedeleyebilecek şekilde tahrif edilmesi ve bozulmasının önlenmesini talep etme hakkına sahiptirler.”*

Bu düzenlemeye örnek olarak aşağıdaki mahkeme kararı verilebilir. Bu olayda icracı sanatçının icraları bir filmde kullanılmış ve icracının adına film afişi ve jenerikte yer verilmemiştir. Mahkeme icracı sanatçının adının filmde belirtilmemesini manevi hakların ihlali görmüş ve manevi tazminata hükmetmiştir.

*“Davacı vekili, müvekkilesinin ... ses sanatçısı olduklarını, davalı M.’un yapımcısı olduğu bir filmde başrollerden birini oynayan davalı S.’nin, bu filmde söylediği şarkıların hiçbir izin ve muvafakat alınmaksızın **davacının sesiyle seslendirildiğini, bu hususun filmin afiş ve jeneriklerinde gösterilmediğini**, bu davranışın davacının haklarına tecavüz ve dinleyici kitlesinde iltibasa yol açtığını ileri sürerek, 250,000 lira maddi ve 250,000 lira **manevi tazminatın** faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen **tahsilini talep etmiştir...***

Mahkemece ... davacının izni olmaksızın davalının söylediği şarkılarda davacının sesini kullanmak suretiyle, davacının kişilik haklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle davalı S. hakkındaki davanın reddine, 20,000 lira maddi ve 100,000 lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı M.’tan tahsiline karar verilmiştir.²⁰

Bazen de kişinin adı öyle bir eserde yer alır ki icracı sanatçı böyle bir icrada adının anılmasından üzüntü duyabilir. İşte buna örnek bir dava:

“Davacı vekili müvekkillerinin klasik müzik dalında uluslararası üne sahip keman sanatçısı ve orkestra şefi olduğunu, halen Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi olduğunu, davacının adının, davalının yapımcısı olduğu ve A.. Grubuna ait pop müziği kaset ve CD’sinde klasik keman sanatçısı olarak kullanıldığını,

²⁰ Yargıtay 11. H.D, 14.4.1987, E. 346, K. 2206 . ERDİL, age., s. 42-43 ve 179.

isminin izinsiz olarak kullanılmasının kişilik haklarına ve sanat anlayışına haksız saldırı teşkil ettiğini ileri sürerek bu tecavüzün önlenmesine, 2,000,000,000.- TL manevi, 1,000,000,000.- TL maddi tazminatın reeskont oranında faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı R...Müzik Yapım San. A.Ş. vekili davacının adının kaset ve CD kartonetine sehven yazıldığını, davacının ihtarnamesi üzerine müvekkilince yanlışlık fark edilerek ondan sonra piyasaya sürülen kaset ve CD'lerden davacının adının çıkarıldığını, müvekkilinin kusurunun bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve dosyadaki kanıtlara göre; profesör unvanı ile konservatuvar öğretim üyesi, uluslararası üne sahip ve klasik müzik dalında keman sanatçısı olan davacının adının, pop müziği kasetinde sıradan kemancılar arasında yer almasından davacının büyük üzüntü duyduğu, sanatçıların bu hususta daha duyarlı davranmak gerektiği, talep edilen manevi tazminatın miktar yönünden uygun bulunduğu gerekçesiyle, ... iki milyar TL tazminatın dava tarihinden itibaren %57 (reeskont) oranında faizi ile birlikte davalı ... Müzik Yapım San. Tic. A.Ş.'den tahsiline karar verilmiştir.²¹

FSEK madde 80/1A-1'de icracı sanatçıların, manevi haklarını mali haklardan bağımsız olarak ve mali hakları devretmelerinden sonra dahi kullanabilecekleri açıkça ifade edilmiştir. Aynı hüküm, söz konusu hakkın sınırını da göstermektedir. Buna göre; tespit edilmiş icralar açısından, uygulama şartları bazen icracı sanatçının, icrasının sahibi olarak tanıtılmasını mümkün kılmayabilir. Bir başka deyişle tespit edilmiş icralarda uygulama şartları bazen icracı sanatçının isminin belirtilmesine olanak tanımaz; böyle bir durumda icracı sanatçının söz konusu hakkından da bahsedilmeyecektir. Bu durumda örnek olarak bir web sayfasının açılış müziğinin sunumu verilebilir²².

Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 10. maddesi de "İcracı sanatçılar, koro ve orkestralarda şef ve solistler, tiyatro gruplarında şeflik yapan veya başrol oynayan aktörler işaret, resim ve ses nakline yarayan araçlarda adlarının belirtilmesini isteme hakkına sahiptirler" diyerek bu hakkı vurgulamıştır. Ancak burada bir eksiklik söz konusudur. Eser sahibine FSEK madde 15'de tanınan eseri, müstear adla ya da adsız olarak kamuya arz etme yetkisi örnekseme yoluyla icracı sanatçılara da tanınmalıdır. Zira bugün ülkemizde olduğu gibi, bütün dünyada icracı sanat-

²¹ Yargıtay 11. H.D, 12.3.1998, E. 1997/9368, K. 1998/1667, SULUK/ORHAN, age, s. 794.

²² ARKAN, age., s. 68

çıların gerçek isimleri ile değil de; müstear adlarıyla tanınmaları son derece yaygındır. Bu nedenle bu konuda icracı sanatçının bir takdir yetkisine sahip olduğu ve kendisinin dilerse gerçek adıyla, dilerse müstear adıyla tanıtılmasını isteyebileceği gibi; bilakis kimliğinin gizli kalmasını talep yetkisini de elinde bulundurduğu kabul edilmelidir. Elbette yorum yoluyla ulaştığımız bu hususların (eser sahibinin manevi hakları konusunda olduğu gibi) açıkça düzenlenmiş olması çok daha isabetli olurdu²³.

İracı sanatçıların icralarının bozulmasını önleme hakkı, WIPO Sözleşmesi ve FSEK dışında ayrıca Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 6. maddesinde de, *"icracı sanatçının icra ettiği eser üzerindeki icradan doğan hakları herhangi bir şekilde sanatçının topluma yansıyan kişiliğini zedeleyecek biçimde kullanılamaz"* şeklinde düzenlenmiştir.

Bu hüküm, icracı sanatçıya tanınan tespit, çoğaltma, yayın gibi hakları kullananların, bu hakları, icracının sanatçı kişiliğini zedeleyecek biçimde kullanmalarını yasaklamaktadır. Zira bu tarz ihlaller genellikle icranın tespiti ve çoğaltılması sırasında ortaya çıkar. Örneğin yapılan kaydın kalitesindeki bozukluk ya da hatalı kayıtlar bu tarz ihlallerdir. Ancak elbette her durum kendi özelliği içinde incelenmelidir. Mesela eski şarkılardan oluşan bir kaydın ya da bir konser kaydının iyi kalitede olması beklenmez. Bunun gibi, yayının kalitesindeki bozukluklar da bu kapsama dahil edilebilir. Tabii unutulmamalıdır ki, bu hükmün ihlal edilmiş sayılması için, söz konusu teknik bozuklukların, icracı sanatçının kişiliğini zedeleyecek düzeyde olması gerekir²⁴. Bu hakka dayanarak icracı sanatçı, tespit edilen icrası üzerinde teknik kontrolde bulunabilir ve hatalı çoğaltmaların yapılmasına ve kamuya sunulmasına engel olabilir. Bunun gibi, çoğaltılmış nüshalar üzerinde kaydın bir konser sırasında yapıldığının belirtilmesini isteyebilir²⁵.

Bu konuda ilginç bir yargı kararını bilginize sunuyoruz:

"Davacı vekili; ses sanatçısı olan müvekkilinin, davalı firma için beş adet kaset seslendirdiğini, daha sonra davalının bu kasetlerde yer alan eserlerden oluşan yeni bir kaseti izinsiz yayımladığını, yeni bir repertuar ve konser programı biçiminde derleme şeklinde yayımlanmasının müvekkilinin manevi haklarını zedeler nitelikte olduğunu ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek şimdilik (10.000.000) lira

²³ ARKAN, age., s. 67

²⁴ ARKAN, age., s. 70

²⁵ A. DURAL, *İracı Sanatçıların Hakları ve Korunması*, İstanbul, 1998, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 38.

maddi, (40.000.000) lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, söz konusu kaset ve bunu çoğaltmaya yarayan vasıtaların müsadere ve imhasını bununla ilgili reklamların durdurulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının verdiği taahhütnamelerde dava konusu kasetteki eserlerin çoğaltılması ve yayımlanması hususunda müvekkilinden bir hak talebinde bulunmayacağını taahhüt ettiğini, müvekkilinin sözleşme ve yasaya aykırı bir davranışının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davacının, eserleri üzerindeki kullanma, çoğaltma ve yayma haklarını içeren mali hakların sözleşme ve taahhütnameler uyarınca süre ve yer kısıtlaması olmaksızın davalıya devrettiğinden mali hakkı kalmadığı, bu eserlerin dilediği gibi kullanma hakkıyla birlikte davalıya devretmesi, davalının eserlerde değişiklik yapmadan kullanması, eserin başında anons ve alkış bulunmasının FSEK'nun 16/2. maddesi uyarınca değerlendirilmesi nedeniyle manevi hak isteminin de yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir²⁶.

Mahkemenin kararı haklıdır ama gerekçede FSEK madde 16'yı dayanak yapması yanlıştır. Bu madde sadece eser sahipleri için kullanılabilir. Ama bu kararın verildiği zaman icracı sanatçı hakları henüz FSEK'de olmadığından Mahkeme kıyasen ama yanlış bir uygulama yapmıştır.

Yukarıda açıkladığımız yasal düzenlemeler sonucunda; icracı sanatçılar, isimlerinin hiç belirtilmemesi ya da yanlış veya eksik belirtilmesi halinde yahut icrasının itibarını zedeleyebilecek şekilde tahrif edilmesi veya bozulması halinde; FSEK madde 67'ye dayanarak tecavüzün ref'i, FSEK madde 69'a dayanarak tecavüz tehlikesinin varlığı halinde tecavüzün men'i davaları ile şartları gerçekleşmişse FSEK madde 70'e dayanarak tazminat davası açabilir.

2. İracı Sanatçıların Mali Hakları

a. Tespit Hakkı

Kayıt imkanının olmadığı devirlerde bir eserin icrası, yapıldığı yerle sınırlı kalıyor, adeta uçup gidiyordu. Bu devirde şarkılar ancak canlı icra ediliyor, bunların kaydedilerek tekrar izlenmesi ya da dinlen-

²⁶ Yargıtay 11. H.D, 8.12.1992, E. 1991/4907, K. 1992/11246

mesi mümkün olmuyordu. Bu imkanın olmaması, icranın geniş halk kitlelerine ulaşmasına da engel oluyordu²⁷.

Teknolojik gelişmeler öncelikle seslerin kaydına imkan tanımıştır. Önce plaklar, sonra müzik kasetleri, daha sonra CD (compact disc)'ler kişilerin istediği zaman müzik dinleyebilmeleri için raflardaki yerlerini almışlardır. Daha sonra sesler gibi görüntüler de kaydedilmeye başlanmıştır. Video kasetler, CD ROM'lar, DVD'ler (digital video disc) sayesinde görüntüler de kaydedilebilmiştir. İşte bu araçlar sayesinde bunlara kaydedilmiş olan sesler ya da ses ve görüntüler artık işyerlerinde ve evlerde dinlenebilir ve seyredilebilir olmuştur²⁸. Ayrıca günümüzde bilgisayar ortamında ve cep telefonlarında kayıt yapabilme olanağı müzik eserlerinden her yerde yararlanmayı kolaylaştırmıştır.

Bir icranın (müzik dinletisinin) bir araca kaydedilmesi gerçekten çok önemli bir olaydır. Çünkü böylelikle icranın uçup gitmesi engellenmektedir. Ancak öncelikle icracı sanatçı, icrasının tespit edilip edilemeyeceği ve edilecekse kimin tarafından edileceği hususlarında karar vermelidir. Örneğin, konser veren bir icracı sanatçı bu icranın yapıldığı yerde kalmasını ve kayıt edilmemesini isteyebilir. İşte bu sebeple bağlantılı hakları tanıyan gerek ulusal gerekse uluslararası düzenlemelerde, icrasını tespit hakkı münhasıran icracı sanatçıya tanınmıştır²⁹.

Seslerin ve/veya görüntülerin, tekrarlanabilecekleri şekilde **ilk defa** bir araca kaydedilerek somutlaştırılmasına **“tespit”** adı verilmiştir. FSEK madde 1/B-e'de tespit; “seslerin veya temsillerinin veya ses ve görüntülerinin anlaşılabilir, çoğaltılabilir veya iletilerilecek şekilde bir araca kaydedilmesi işlemi” olarak tanımlanmıştır. Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 4/e maddesinde ise tespit; “seslerin maddi bir araç üzerine kaydedilmesi” olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi bu iki tanım birbirinden farklıdır. Komşu Haklar Yönetmeliği tespiti sadece seslerle sınırlandırırken, Kanunda görüntü tespitleri de korunmuştur. Yönetmeliğin de Kanuna uygun şekilde değiştirilmesi gerekmektedir³⁰.

Tespit hakkı uluslararası mevzuatta Roma Anlaşması'nın 7/1b, TRIPS Anlaşması'nın 14/1., WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaş-

²⁷ ARKAN, age., s. 75

²⁸ Ses taşıyıcıları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. ARKAN, age., II. Bölüm, § 2, II.

²⁹ ARKAN, age., s. 75

³⁰ ARKAN, age., s. 75

ması'nın 6. maddelerinde bulunmaktadır. 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı “*Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi*”nin 6. maddesi de “*üye devletler, icracılara, icralarının tespiti konusunda yetki verme ya da yasaklama münhasır hakkını sağlarlar*” diyerek tespit hakkını tanımıştır.

Türk Hukukunda ise tespit hakkı FSEK 80. maddede A bendinde 2 no'lu kısımda ve Komşu Haklar Yönetmeliğinin 7. maddesinde bulunmaktadır. Bu düzenlemelere göre, tespit için icracı sanatçıdan yazılı izin alınması gereklidir.

Bir eser icrasının hukuka uygun olarak tespiti için sadece icracı sanatçının izni yeterli değildir. Ayrıca icra edilen eserin bestecisi ve söz yazarından da izin alınması gereklidir. Ancak eser sahipleri icracıya icra izni verirken, bu izinde tespite ilişkin eser sahibi haklarını icracı sanatçıya devretmiş olabilirler. Bu durumda sadece icracı sanatçının izni tespit için yeterli olur.

FSEK madde 80 ve Komşu Haklar Yönetmeliğinin 9. maddesine göre ise; koro, orkestra ve sahne eserlerinin icrasını tespit etme, bu tespiti çoğaltma, kiralama, icranın telli-telsiz her türlü araçla yayınlanması ya da temsili suretiyle faydalanma hakkının devrinde yalnız şefin izni yeterlidir.

b. Çoğaltma Hakkı

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 22. maddesinden yararlanarak icracı sanatçı açısından “**çoğaltma**”yı, “**bir icra tespitinin ses ve/veya görüntü nakil ve tekrarına yarayan her türlü araca kaydedilerek; bir veya daha fazla kopya haline getirilmesi**” şeklinde tanımlayabiliriz. Çoğaltmanın hangi usulle yapıldığı önemli değildir³¹. Günümüzde çoğaltma için çok çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Kasetler, CD'ler, DVD'ler, VCD'ler, CD-ROM'lar, bilgisayar hard diskleri, USB'ler, internet ortamı, mp3 çalarlar ve cep telefonları çeşitli çoğaltma araçlarıdır.

İracı sanatçıların çoğaltma hakkı ilk olarak *Roma Sözleşmesi*'nde 7. maddede düzenlenmiştir. *WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması*'nın 7. maddesi ise, “*icracılar, herhangi bir şekil veya yöntemle, tespit edilmiş icraların doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılmasına*

³¹ TEKİNALP, age., § 17 N 27; AYİTER, age., s. 128; GÖKYAYLA, age., s. 163.

münhasıran izin verme hakkından faydalanacaktır” şeklinde düzenlenmiştir. TRIPS Anlaşması olarak bilinen “Fikir Mülkiyeti Haklarının Ticari Niteliklerine İlişkin Anlaşma”nın 14. maddesi ise; “sanatçılar icralarının bir plak üzerine tespit edilmesi ile ilgili olarak, izinleri olmaksızın girişilen aşağıdaki fiilleri önleme olanağına sahip olacaklardır: Tespit edilmemiş uygulamalarının tespitini ve bu gibi tespitlerin çoğaltılmasını” düzenlemesini getirmiştir.

Ancak Roma Anlaşması’nın konuyla ilgili 7/1c hükmü, diğer iki anlaşmadan biraz farklıdır. Bu hükme göre, çoğaltma için izin alınması yalnızca ilk tespitinin izinsiz olarak yapıldığı hallerde gereklidir. Bir başka deyişle, ilk tespit için icracı sanatçıdan izin alınmışsa, artık tespitin çoğaltılması için izin alınmasına gerek kalmayacaktır. Böyle bir düzenlemenin çok da yerinde olduğu söylenemez. Zira mali hakların kullanılması birbirinden bağımsızdır. Yani bir icranın tespitine izin verilmesi, o tespitin çoğaltılmasına izin verildiği anlamına gelmemelidir. Bu haklar birbirinin yanında ama birbirinden bağımsızdır. Bu haklar pratikte sıklıkla toplu olarak verilmekle birlikte, bu kanuni bir zorunluluk olmamalıdır. Yani tespit hakkının verilmesi, çoğaltma hakkının da verildiği anlamını taşımamalıdır³². Zaten, daha yeni tarihli olan TRIPS (madde 14) ve WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nda (madde 7) ve Almanya, İsviçre, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin ulusal mevzuatlarında da böyle bir düzenleme mevcut değildir. Keza konuyla ilgili FSEK madde 80/1A-2’de de böyle bir hüküm yoktur. Buna karşılık bu hüküm, Komşu Haklar Yönetmeliği’nin 7/c maddesine aynen alınmıştır³³. Yasada yer almayan ve önemli bir hakkın kaybına sebep olabilecek böylesine bir düzenlemenin Yönetmeliğe konması hiç de doğru olmamıştır. Kanaatimizce Yasaya aykırı şekilde bir hakkın sınırlandırılmasına yol açan bu Yönetmelik hükmünün kaldırılması gereklidir³⁴.

³² ARKAN; age., s. 76

³³ Komşu Haklar Yönetmeliği 7. madde: Aşağıdaki durumlarda icracı sanatçının;

- a) Daha önce tespit edilmemiş icralarının tespiti,
- b) Ticari amaçla çoğaltılmış icralarının kopyalarının kiraya verilebilmesi,
- c) İlk tespiti izinsiz yapılan icraların çoğaltılması,
- d) Çoğaltma izni verdiği tespitin amaç dışında çoğaltılması,
- e) Ticari amaçla kamuya sunulan bir tespitten yapılmayan veya bir radyo ve televizyon yayını icraların, radyo ve televizyon kuruluşları tarafından yayınlanması için yazılı izni gereklidir.

³⁴ ARKAN, age., s. 81

22 Mayıs 2001 tarih ve 2001/29/AT sayılı “Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi”nin 2. maddesinde ise; “üye devletler, kısmen veya tamamen, her türlü yöntem ve şekilde, kalıcı veya geçici röprodüksiyonları hakkında: ... icracı-sanatçılar ve onların icralarının düzenlenmesini; doğrudan veya dolaylı yasaklama veya müsaade etmeye münhasır haklarını korur” şeklinde düzenleme yapmıştır.

19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi” ise çoğaltma hakkı konusunda madde 7’de; “üye devletler, icracılara icralarının tespiti konusunda, doğrudan ya da dolaylı çoğaltıma izin verilmesi ya da bunun yasaklanması münhasır hakkını sağlarlar. Çoğaltım hakkı, aktarılabilir, devredilebilir ya da akdi lisansların verilmesine tabi olabilir” düzenlemesini getirmiştir.

İracı sanatçıların hakları FSEK’e 1995 yılında yapılan değişikliklerle girmiştir. Bu tarihe kadar açılan davalarda mahkemelerce genel hükümlere göre karar veriliyordu. Bu yöndeki tarihi bir kararı sunuyoruz:

“Davacı vekili, müvekkilinin davalı firmalara (2) adet uzunçalar **plak yaptığıını**, plakların piyasaya çıktığını, plakların piyasaya çıktığı tarihte kaset olmadığını, **kaset üretimine başlanınca**, davalılardan K... Elk. A.Ş. nin çoğalttığı türkü kasetlerini diğer davalı limited şirketinin piyasaya sürdüğünü, telif ücretinin davacıya uyarıya rağmen ödenmediğini ileri sürerek, 5.000.000 TL’sinin davalılardan faizi ile müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalılar vekili cevabında; 5846 sayılı FSEK’nun 8/2 maddesi uyarınca eserin sahibinin davalılar olduğunu, icracı olarak davacıya ücret ödenmesinin söz konusu olmadığını beyanla, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; bilirkişi raporu, ek rapor ve toplanan delillere göre; **FSEK’da sanatçıya telif ücreti adı altında ödeme yapılması öngörülmemiş ise de, aynı Yasanın 81/1 maddesinde, kaset çoğaltma işleminde davacının yazılı izni şart edildiği**, hem anılan Yasa, hem de BK 42/2 maddesi gereğince **davacının (icracı sanatçının) tazminat hakkının doğmuş olduğu**, bu hakkın uluslararası uygulamada (komşuluk hakkı) olarak isimlendirildiği **gerekçeyle, davanın kabulü** ile bilirkişi raporu ile belirlenen 5.000.000 TL sinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmiştir.³⁵

³⁵ Yargıtay 11. H.D, 30.09.1996, E. 1996/5931, K. 1996/6174

1995 yılında yapılan değişiklikle Hukukumuzda giren icracı sanatçı hakları 2001 ve 2004 yılındaki düzenlemeler ile son halini almıştır. Bugünkü düzenlemede **FSEK 80. maddesi; icracı sanatçının, tespit edilen icrasının çoğaltılmasına izin verebileceğini ya da yasaklayabileceğini düzenlemiştir.**

Eğer icracı sanatçı, icralarının çoğaltma hakkına ilişkin bir izin veya lisans vermişse veya bu haklarını müzik yapımcısına devretmişse artık bu çoğaltma eylemine karşı çıkamaz. Yargıtay'ın da benzer düşündüğü bir mahkeme kararını örnek verebiliriz:

“Davacı vekili; ses sanatçısı olan müvekkilinin, davalı firma için beş adet kaset seslendirdiğini, daha sonra davalının bu kasetlerde yer alan eserlerden oluşan yeni bir kaseti izinsiz yayımladığını, yeni bir repertuar ve konser programı biçiminde derleme şeklinde yayımlanmasının müvekkilinin manevi haklarını zedeler nitelikte olduğunu ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek şimdilik (10.000.000) lira maddi, (40.000.000) lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, söz konusu kaset ve bunu çoğaltmaya yarayan vasıtaların müsadere ve imhasını bununla ilgili reklamların durdurulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının verdiği taahhütnamelerde dava konusu kasetteki eserlerin çoğaltılması ve yayımlanması hususunda müvekkilinden bir hak talebinde bulunmayacağını taahhüt ettiğini, müvekkilinin sözleşme ve yasaya aykırı bir davranışının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; **davacının; eserleri üzerindeki kullanma, çoğaltma ve yayma haklarını içeren mali hakların sözleşme ve taahhütnameler uyarınca süre ve yer kısıtlaması olmaksızın davalıya devrettiğinden mali hakkı kalmadığı,** bu eserleri dilediği gibi kullanma hakkıyla birlikte davalıya devretmesi, davalının eserlerde değişiklik yapmadan kullanması, ... **gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir**³⁶.

Komşu Haklar Yönetmeliğinin 8. maddesine göre, icracı sanatçı ile yapımcı arasında yapılan sözleşmeyle çoğaltma hakkı uygun bir bedel karşılığında yapımcıya devredilmişse, çoğaltma için icracı ve yorumcu sanatçıların yazılı izni aranmayacaktır. Ancak, bu haklardan belli bir kısmının yapımcıya devredilmesi halinde, devredilmeyen hakların kullanımı söz konusu olduğunda bunlar için icracı sanatçılarla eser sahibinin yazılı izninin alınması gereklidir.

³⁶ Yargıtay 11. H.D, 8.12.1992, E. 1991/4907, K. 1992/11246

Eğer bu düzenlemeler doğrultusunda icracı sanatçının icrası izin alınmadan herhangi bir şekilde ve araca çoğaltılıyorsa bu davranış hukuka aykırıdır. Aşağıda icracı sanatçıdan izin alınmadan icrasının bir kasette, cd’de ve bir filmde çoğaltılmasına iki örnek karar görülmektedir:

“Davacı vekili, müvekkilinin davalı yapımcı firma ile akdedilmiş hiçbir sözleşmesi yok iken, davalının müvekkilinin geçmişte meydana getirdiği eserleri toplayarak “F.E.K.” isimli bir kaset ve CD çalışması yapıp, piyasaya sürdüğünü, bunlarda müvekkiline ait yeni konser resimlerinin kullanıldığını, müvekkilinin aynı dönem içerisinde ...Müzik Ltd. Şti. ile yeni bir kaset çalışması için anlaşma yaptığı halde davalının eylemi nedeniyle piyasaya çıkarılmasının ertelendiğini, davalının bu kez de “F.D.E.3 E.K.” ismi altında aynı eserleri yeniden piyasaya sürdüğünü belirterek şimdilik 1 Milyar TL maddi, 1 Milyar TL manevi tazminatın 3 katı fazlasıyla ve ilk ihtarname tarihinden itibaren reeskont faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davalının müvekkili ile imzaladığı 03.10.1985 günlü sözleşme, 22.04.1996 günlü muvafakatname (yayın izni) ve tahhütname ve 22.04.1989 tarihli muvafakat beyanı ile müvekkili firma adına okuduğu yapımlar nedeniyle kendisine ve MESAM’a ödenen bedeller olduğunu, dava konusu “F.E.K” adlı yapının Ş... Plak Firması adına “eser işletme belgesi” ve “müzik eseri kayıt ve tescil belgesi”ne bağlandığını ve devirlerle bu hakların müvekkiline geçtiğini, 3.10.1995’te davacı ile 1 yıllık ve 1 kasetlik sözleşme gereği telif ücretlerinin davacıya ve daha sonra mali haklarını devir ettiği MESAM’a ödendiğini, eserin yayma ve çoğaltma haklarının müvekkilinde olduğunu, kasette resim kullanılmadığını, kaldı ki resmin kasete yeni imajını veremeyeceğini, eserde ilk halin korunduğunu, herhangi bir değişiklik yapılmadığını, davacının çıkaracağı yeni kasetine bu durumun engel olmayacağını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından davanın kısmen kabulü ile 789,000,000 TL maddi, 789,000,000 TL manevi tazminatın 12.02.1999 gününden itibaren reeskont faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve **davacının FSEK’in 68/2. maddesinde yer alan seçeneklerden üçüncüsünü tercih ederek; bir sözleşme yapılsaydı davalıdan ne tutarda bir bedel isteyecek idiye, bunun üç katını talep ettiğine ve Mahkemece de bu miktara hükmedildiğine göre, davalının işbu davada belirlenen miktarda çoğaltmış olduğu eserin elinde olan kopyalarını kanuni şartlar dairesinde ticaret mevkiine koyabileceğinin tabii bulunmasına** göre kararın onanması gerekmiştir.³⁷ⁿ

³⁷ Yargıtay 11. H.D, 22.11.2002, E. 2002/5432, K. 2002/10736. Ayrıca bkz. BEŞİROĞLU, age., s. 1345-1346

“Davacı vekili, müvekkilesinin ve davalı S.’nın ünlü birer ses sanatçısı olduklarını, dava M.’un yapımcısı olduğu bir filmde başrol-lerden birini oynayan davalı S.’nın, bu filmde söylediği şarkıların hiçbir izin ve muvafakat alınmaksızın **davacının sesiyle seslendirildiğini**, bu hususun filmin afiş ve jeneriklerinde gösterilmediğini, bu davranışın davacının haklarına tecavüz ve dinleyici kitlesinde iltibasa yol açtığını ileri sürerek, 250,000 lira maddi ve 250,000 lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir...

Mahkemece davalı S.’nın filmde söylediği şarkıların davacının sesiyle seslendirilmesinde eylemi ve kusuru bulunmadığı, diğer davalı M.’un yapımcısı olduğu filmde, davacının izni olmaksızın davalının söylediği şarkılarda davacının sesini kullanmak suretiyle, davacının kişilik haklarına tecavüz ettiği gerekçeyle davalı S. hakkındaki davanın reddine, 20,000 lira maddi ve 100,000 lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı M.’tan tahsiline karar verilmiştir.

Hüküm davalı M. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14/1. maddesi uyarınca bir eserin umuma arz edilip arz edilmemesi ve yayınlanma zamanı ve tarzının tayininin, münhasıran eser sahibine ait olacağı kabul edilmiş olmasına ve **davalı M.’un, davacının rızasını almadan davacının sesini yaptığı filmde kullanarak davacının yukarıda anılan haklarını bile-rek zedelemiş bulunmasına**, bu durumda aynı yasanın 70/1. maddesindeki koşullar da gerçekleşmiş bulunmasına göre, **davacı yararına manevi tazminata dahi hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığından**, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.³⁸

Komşu Haklar Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; icracı sanatçıların icralarını iş ve hizmetten doğan sorumluluklarından dolayı yapmaları ve yapılan bu icra sonunda elde edilen tespit, iş ve hizmet dışında kullanılmak istenildiği takdirde bu kullanımın şartları işveren ya da iş sahibiyle icracı sanatçılar arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Yönetmeliğin 9. maddesine göre ise; koro, orkestra ve sahne eserlerinin icrasını tespit etme, bu tespiti çoğaltma, kiralama, icranın telli-telsiz her türlü araçla yayınlanması ya da temsili suretiyle faydalanma hakkının devrinde yalnız şefin izni yeterlidir.

³⁸ Yargıtay 11. H.D, 14.4.1987, E. 346, K. 2206. ERDİL, age., s. 42-43 ve 179.

Yönetmeliğin 11. maddesine göre; bir sanat eseri birden fazla icracı sanatçı tarafından icra ediliyorsa ve ortaya çıkan eser de kısımlara ayrılabilirse, bu sanatçılardan her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır. Şayet icra edilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, bu yapımın sahibi onu vücuda getirenlerin birliğidir. Ortaya çıkan ortak yapım ile ilgili tüm hakların kullanımında icracılar, birbirlerinin haklarına öncelikle riayet etmek zorundadırlar. İcracı sanatçılar hakların korunmasında ortak hareket edebilirler ya da içlerinden birisine yetki verebilirler. İcracı sanatçılardan biri, birlikte yapılacak bir muameleye haklı bir sebep olmaksızın izin vermezse, bu izin mahkemece verilebilir. İcracı sanatçılardan her biri birlik menfaatlerine saldırıldığı takdirde tek başına hareket edebilir.

Bilgisayarın, telefonla bağlantısının kurulması neticesinde dünya çapında bir bilgisayar ağı olan internetin ortaya çıkması gerçekten hayal edilmesi güç sonuçların doğmasına sebep olmuştur. Elektronik posta (e-mail); verilerin, çeşitli bilgilerin, fikri ürünlerin depolanması; bunların merkezi bir bilgisayardan, yan bir bilgisayara aktarılması (download) veya yan bir bilgisayardan merkezi bilgisayara nakli (upload); ticaret yapma (e-ticaret) internetin insanlığa kazandırdığı kolaylıklardır. Ancak bu yenilikler yasa koyucuların daha evvel düşünmediği, yeni hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir³⁹. İnternetle ilgili olarak doğan sorunların bir çoğunun fikri hak ihlalleri olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Zira internet ortamında fikri ürünler ışık hızıyla yolculuk etmektedir. Ayrıca ülke sınırlarını hiçbir engele takılmadan aşarak yapılan bu yolculuk sırasında ortaya çıkan hukuka aykırılıklar ülkeler arasında birçok kanunlar ihtilafı problemine neden olmaktadır⁴⁰. Biz bu

³⁹ TEKİNALP, age., § 10 N 59; ÖZDİLEK, age., s. 13-14; MACKAAY, E., *The Economics of Emergent Property Rights on the Internet, The Future of Copyright in a Digital Environment, Proceedings of the Royal Academy Colloquium* (Amsterdam, 6-7 July 1995), Editor: HUGENHOLTZ, P.B, The Hague, London, Boston , 1996, s. 13 vd. Naklen ARKAN, age., s. 82. Ayrıca internete ilişkin teknik bilgi için bkz. ÖZDİLEK, age., s. 14 vd.

⁴⁰ GELLER, P. E., *Conflicts of Law in Cyberspace: International Copyright in a Digitally Networked World, The Future of Copyright in a Digital Environment, Proceedings of the Royal Academy Colloquium*, (Amsterdam, 6-7 July 1995) Editor: HUGENHOLTZ, P. B., The Hague, London, Boston, 1996, s. 27. Ayrıca bu konuda karşılaşılabilecek kanunlar ihtilafına ilişkin sorunlar için bkz. AKİPEK, Ş./DARDAĞAN, E., “Sanal Ortamda Gerçekleşen Telif Hakkı İhlallerine Uygulanacak Hukuk”, AÜHFD. 2001, C. 50, S. 3, s. 115 vd.; AKİPEK, Ş./DARDAĞAN, E.,

hukuki sorunlara elbette çalışmamızın kapsamına girdiği ölçüde ve yeri geldikçe değineceğiz.

Çoğaltma hakkıyla ilgili olarak mevcut olan web sayfalarına, tespit edilmiş bir icranın yüklenmesi (upload) veya bu sitelerden icraların indirilmesi (download) eylemlerinin niteliği incelenmeye değer. Eser sahibinin çoğaltma hakkına ilişkin FSEK madde 22'nin 2. fıkrasına göre; “*eser aslından ikinci bir kopyasının çıkarılması ya da işaret, ses ve görüntü nakil ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride gelişecek olan her türlü araca kayıt edilmesi, her türlü ses ve müzik kayıtları .. da çoğaltma sayılır...*”⁴¹ düzenlemesi mevcuttur.

Söz konusu eylemler (upload ve download), bir icra tespitinin, ses ve/veya görüntü nakil ve tekrarına yarayan bir araca kaydedilmesi niteliğinde olduklarına göre, çoğaltma olarak değerlendirilmesi gerekir⁴². Ayrıca yükleme (upload) eylemi ile icra tespitleri internete giren diğer kim-selerin erişimine sunuldukları için, bu eylemin ayrıca aşağıda incelenecek olan kamunun erişimine sunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir⁴³.

Son yıllarda dijital hale getirilmiş müzik parçalarının hacimleri geliştirilen bir usulle sıkıştırılarak azaltılmaktadır. Bu formata mp3 denmektedir. Bu sıkıştırma sayesinde bir müzik parçasının işgal ettiği hacim çok azalmaktadır. Mp3 formatına dönüştürülen müzik parçaları gerek ses taşıyıcıda gerekse bilgisayar ortamında fazla yer tutmamakta ve parçalar hızlı kopyalanmakta ve hızlı nakledilebilmektedir. Bu formattaki müzik parçaları, CD kaydedicileri tarafından kolayca çoğaltılabilmekte ve in-

“Sanal Ortamda Telif Hakları”, BATIDER, 2001, C. 21, S. 1, s. 47 vd. Naklen ARKAN, age., s. 83

⁴¹ ARKAN, age., s. 83

⁴² FICSOR, M., *Towards a Global Solution, The Future of Copyright in a Digital Environment*, The Hague, London, Boston, 1996, s. 124; SPOOR, J. H., *The Copyright Approach to Copying on the Internet: (Over) Stretching the Reproduction Right, The Future of Copyright in a Digital Environment*, The Hague, London, Boston, 1996, s. 78; HUGENHOLTZ, P. B., *Adapting Copyright to the Information Superhighway, The Future of Copyright in a Digital Environment*, The Hague, London, Boston, 1996, s. 87. BARRELET/EGLOFF Art. 10 N. 12; BUHLER, L., *Schweizerisches und Internationales Urheberrecht im Internet*, Freiburg, 1999, s. 157-159; ATEŞ, age., s. 168-169; TEKİNALP, age., § 14 N 91. Naklen ARKAN, age., s. 83

⁴³ ARKAN, age., s. 83

ternet ortamında erişime de sunulabilmektedir⁴⁴. Bu sebeple söz konusu teknoloji, eser sahipleri ve icracı sanatçılar için büyük risk oluşturmaktadır. Bir sanatçının belki de bütün ömrü boyunca ürettiği eserler ya da icraların içinde yer aldığı mp3 formatında tek bir CD'nin hukuka aykırı şekilde çoğaltılması sonucu sanatçıların mali hakkı ciddi şekilde ihlal edilmiş olmaktadır. Bir müzik parçasının mp3 formatına dönüştürülmesi sırasında her ne kadar eserin boyutlarında bir değişiklik yapılıyor olsa da, içeriğinde bir değişiklik yapılmamaktadır. Bu nedenle burada söz konusu olan bir işlenme değil, bir çoğaltma işlemidir. Zaten amaca uygun yorum da budur. Zira bağlantılı hak sahiplerine işleme hakkı tanınmamıştır⁴⁵.

FSEK madde 80 gereğince, yukarıda sayılan eylemlerin yapılabilmesi için de icracı sanatçılardan izin alınması gereklidir.

c. Yayma Hakkı

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 8. maddesi “yayma hakkını”,

“(1) İcracı sanatçılar, fonogramlar üzerine tespit edilmiş olan icralarının aslı veya kopyalarının satış veya başka bir şekilde hak sahipliğini devretmek yoluyla topluma sunulmasına münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

(2) Bu Andlaşmadaki hiçbir hüküm, akit tarafların sanatçının izni ile tespit edilmiş olan icrasının özgün nüshası ya da kopyası üzerindeki sahipliğin ilk satışı ya da başka bir şekilde hak sahipliğinin devrinden sonra, (1) inci paragrafta öngörülen hakkın tükenmesine ilişkin muhtemel şartları belirleme yetkisine halel getirmez” şeklinde düzenlemiştir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 9. maddesi yayma hakkının bir parçası olan “kiralama hakkını”,

“(1) İcracı sanatçılar, fonogramlar üzerine tespit edilen icraların asıl ya da kopyalarının sanatçının verdiği yetki ile ya da bu yetkiye uygun olarak dağıtılmasından sonra dahi, akit tarafların ulusal yasaları ile

⁴⁴ MEMİŞ, age., s. 38-39. Ayrıca mp3 formatı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. ARKAN, age., s. 83

⁴⁵ MEMİŞ, age., s. 73-74; A. Osman ÖZDİLEK, *İnternet ve Hukuk*, İstanbul, 2002, s. 85; KNIES, B., *Die Rechte der Tonträgerhersteller internationaler Agenda der neuen WIPO-Verträge*, Bern, 2000, s. 142-143. Naklen ARKAN, age., s. 83

belirlendiği şekilde topluma ticari olarak kiralanması hususunda münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

(2) (1) inci paragraf hükümlerine rağmen, 15 Nisan 1994 tarihinde, fonogramların içerdiği eserlerin kopyalarının kiralanması karşılığında eser sahiplerine hakkaniyetle bir ücret sistemi uygulayan veya uygulamakta olan akit bir taraf, fonogramların içerdiği eserlerin ticari olarak kiralanması, eser sahiplerinin münhasır çoğaltma hakkına maddi şekilde zarar vermedikçe, bu sistemi muhafaza edebilir” biçiminde belirtmiştir.

19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi” ise şu düzenlemeleri getirmiştir:

Kiralama ve ödünç verme hakkı konusunda madde 2; “kiralama ve ödünç vermeyi yetkilendirme ve yasaklama münhasır hakkı, icra tespiti hakkında icracı sanatçıya aittir. Bu haklar; aktarılabilir, devredilebilir ve akdi lisans vermeye tabi olabilir.”

Vazgeçilmez adil bedel hakkı konusunda madde 4;

“1. Eser sahibinin ya da icracının fonogram, film ya da kopyasına ilişkin kiralama hakkını fonogram ya da film yapımcısına aktardığı ya da devrettiği durumda, söz konusu eser sahibi ya da icracı, kiralama konusunda adil bedel elde etmek için, bu hakkı elinde tutar.

2. Kiralama konusunda adil bedel elde etme hakkı, eser sahipleri ya da icracıları temsil eden meslek birliklerine havale edilebilir.

3. Adil bedel elde etme hakkının yönetimi, eser sahiplerini ya da icracıları temsil eden meslek birliklerine havale edilebilir.

4. Üye devletler, söz konusu bedelin kimden talep edilip alınacağı konusu yanında, adil bedel elde etme hakkının meslek birlikleri tarafından yönetiminin uygulama sınırlarını düzenleyebilirler.”

Kamuya ödünç verme hakkı konusunda madde 5;

“1. Üye devletler, en azından eser sahiplerinin bu nevi ödünç verme için bedel elde etmeleri şartıyla, kamuya ödünç verme hakkında madde 1’de sağlanan münhasır hakkı elden alır. Üye devletler, kültürel tanıtım amaçlarını göz önünde bulundurarak, söz konusu bedeli belirleme hakkına sahiplerdir.

3. Üye devletler, bazı kuruluşları, 1. ve 2. fıkralarda göndermede bulunulan bedel ödemesinden muaf tutabilirler.”

Dağıtım Hakkı konusunda madde 9;

“1. Üye devletler, icralarının tespiti hakkında icracılara, satış ya da başka yollarla, buradan itibaren “dağıtım hakkı” olarak göndermede bulunulan söz konusu maddelerin ve kopyalarının kamuya sunumu münhasır hakkını sağlarlar.

2. Dağıtım hakkı, söz konusu maddenin Topluluk içerisindeki ilk satışının hak sahibi tarafından ya da kendi rızasıyla gerçekleştirildiği durum haricinde, 1. fıkrada göndermede bulunulan maddeye ilişkin olarak Topluluk içerisinde son bulmaz.

Dağıtım hakkı, aktarılabilir, devredilebilir ya da akdi lisansların verilmesine tabi olabilir.”

Bu uluslararası kuralların ardından gelelim Türk Hukukuna. FSEK madde 80/1 no’lu fıkrasında A bendinde icracı sanatçıların yayma hakları şu şekilde sayılmıştır:

“(2) Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçı, bu icranın ... satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine ... izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidir.

(3) İcra sanatçı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespit edilmiş icralarının, aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme veya yasaklama hakkına sahiptir.

(4) İcra sanatçı, tespit edilmiş icrasının veya çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımına veya sunulmasına ... izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir.

(5) İcra sanatçı bu haklarını uygun bir bedel karşılığında sözleşme ile yapımcıya devredebilirler.

(6) İcranın, bir orkestra, koro veya tiyatro grubu tarafından gerçekleştirilmesi halinde, orkestra veya koroda yalnız şefin, tiyatro grubunda ise yalnız yönetmenin izni yeterlidir.

(7) Bir müteşebbisin girişimi ile ve bir sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen icralar için müteşebbisin de izninin alınması gereklidir.”

Kanun’un ifadesinden sanki icra tespitinin (yani ilk tespit yapıldığı master kaydın); satılmasının, kiralanmasının ya da ödünç verilmesinin mümkün olduğu gibi bir anlam çıkmaktadır. Oysa burada satma, kiralamaya, ödünce konu olan icra tespitinin yer aldığı seslerin ya da

görüntülerin ya da her ikisinin kaydedildiği maddi (kayıt kopyaları, nüshalar) araçlardır⁴⁶.

Komşu Haklar Yönetmeliğinin 7. maddesi, yayma haklarını eksik biçimde düzenlemiştir. Buna göre; ticari amaçla çoğaltılmış icralarının kopyalarının kiraya verilebilmesi için icracı sanatçının yazılı izni gereklidir.

Burada hemen ifade edilmelidir ki; hukuka uygun olarak yayma için sadece icracı sanatçının izni yeterli olmaz. Diğer hak sahiplerinden yani icraya konu olan eserin sahibinden, ilk tespiti gerçekleştiren fonogram yapımcısından veya film yapımcısından ve icra bir yayından tespit edilmiş veya çoğaltılmışsa, yayını yapan kuruluştan da izin alınması gereklidir⁴⁷.

Bağlantılı hak sahiplerinin yayma hakkına ilişkin bir tanım ne FSEK’de ne de Komşu Haklar Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Eser sahibinin yayma hakkını düzenleyen FSEK madde 23’den yararlanarak, **“icracı sanatçıların yayma hakkı”; tespit edilmiş bir icranın, asıl veya çoğaltılmış maddi nüshalarını kiralamak, satmak, ödünç vermek veya diğer yollarla dağıtmak** şeklinde tanımlanabilir⁴⁸. Yaymanın bir yolu olan **“kiralama”**; Komşu Haklar Yönetmeliği’nin 4. maddesinde: *“üzerine seslerin ya da görüntülerin ya da her ikisinin kaydedildiği maddi araçların bir kopyasının ticari amaçla belli bir süre için ücret karşılığında zilyetliğinin el değiştirmesidir”* şeklinde tanımlanmıştır. Bunun dışında ne FSEK’de ne de Komşu Haklar Yönetmeliği’nde konuya ilişkin bir tanım mevcut değildir. Kalan tanımlar konusunda öğretiden yararlanabiliriz. TEKİNALP’e göre; **“tespitin satılması”**; *“üzerine seslerin ya da görüntülerin ya da her ikisinin kaydedildiği maddi araçların herhangi bir tarzda satılması”*; **“tespitin ödünç verilmesi”**; *“üzerine seslerin ya da görüntülerin ya da ikisinin kaydedildiği maddi araçların bedelsiz olarak başkalarının yararlanması için bırakılması”* şeklinde tanımlanabilir⁴⁹.

Burada kısaca internet veya gsm şebekeleri üzerinden veya digital paketli televizyonlardaki yayın seçme şekliyle icraların kullanıcılara su-

⁴⁶ TEKİNALP, age., § 14 N. 103.

⁴⁷ ARKAN, age., s. 85

⁴⁸ TEKİNALP, age., § 17 N. 27-28.

⁴⁹ ARKAN, age., s. 85 naklen TEKİNALP, age., § 17 N 27 ve § 14 N 103, 104.

nulmasına da değinelim. Gerek ulusal gerek uluslararası düzenlemelerde gerekse Avrupa Birliği Hukuku'nda yaymanın ancak maddi bir cisme bürünmüş nüshalar açısından söz konusu olabileceği; yani vücutsuz icraların (internetten veya gsm şebekesinden indirilen icraların) dağıtılmasının, teknik olarak yayma hakkına konu olamayacağı genellikle kabul edilmektedir. WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın yayma hakkı ile ilgili gerekçesinde bu hakkın madden (fiziken) cisimlenmiş objelere ilişkin olduğu açıkça ifade edilmiştir⁵⁰. İnternet ve digital kullanımlar çeşitli mevzuatlarda bazen tamamen bağımsız; bazılarında ise yayın hakkıyla birlikte düzenlenmiştir. Umuma iletim hakkı incelenirken konuyla ilgili detaylı bilgi verilecektir. ARKAN'a göre de, maddi olmayan objeler için yayma hakkından bahsedilemeyeceği meydandadır ve zaten buna ihtiyaç da kalmamıştır⁵¹. Biz de bu görüşe katılıyoruz. Sonuç olarak; internet kullanıcılarının kendi bilgisayarlarına indirmelerine olanak sağlayacak tarzda bir icranın bilgisayara yüklenmesi; bunun gibi, bir telefon ya da bilgisayar ağı yardımıyla erişebilen ve giderek maddi kopyaların yerini alan dijital eser ve icraların, elektronik olarak kiralınması ya da ödünç verilmesi de yayma kapsamına girmez.

Çoğaltmadan sonra çoğu kez yayma aşaması gelir. Ancak bir çoğaltmanın mutlaka yayma ile sonuçlanması şart değildir. Bazen de çoğaltma ile yayma arasında belirli bir süre olabilir. Örneğin icracı sanatçı, icrasının kasetlere kopyalama yoluyla çoğaltılmasına izin vermekle beraber bu kasetlerin okullar kapandıktan sonra piyasaya sürülmesini isteyebilir. TEKİNALP'e göre, çoğaltma hakkı devredilmişse, bunun çoğu kez yayma hakkının da devri anlamını taşıyacağı kabul edilmelidir. Zira çoğaltmanın asıl amacı zaten nüshaların yayılmasıdır. Bu nedenle çoğaltma hakkı verilmekle beraber yayma hakkının verilmediğinin ileri sürülmesi ancak tarafların bunu kararlaştırması ya da hal ve şartların böyle bir yorumu desteklemesi halinde mümkün olmalıdır⁵². Oysa bizce Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 23. maddesi uyarınca bağlantılı hakların devrine ilişkin olarak kıyasen uygulanacak FSEK madde 52'nin açık hükmü, böyle bir yorum yapılmasına olanak vermemektedir. Daha evvel ayrıntılı

⁵⁰ Gereke için bkz. *STERLING, (World Copyright Law) § 40 N 17 veya* http://www.wipo.org/eng/diplconf/distrib/97dc.htm#a2_e Naklen ARKAN, age., s. 86

⁵¹ ARKAN, age., s. 88

⁵² *TEKİNALP, age., § 14 N 100. Naklen ARKAN, age., s. 87*

olarak incelenen bu hükme göre⁵³, mali haklara dair sözleşme konusu olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. Zaten Yazar da, eserin konuyla ilgili başka bölümlerinde bu hususu belirtmiştir⁵⁴. Bizim gibi, ARKAN da TEKİNALP'in yorumuna katılmamaktadır⁵⁵.

Burada son olarak **“tükenme ilkesi”** veya **“ilk satış ilkesi”** denilen prensibe değinmek yerinde olacaktır. Bu prensip FSEK madde 23/2’de eser sahipleri ve madde 80’de radyo-televizyon kuruluşları dışındaki bağlantılı hak sahiplerinin yayma hakkı bakımından kabul edilmiştir. Bu ilkeyi kısaca şöyle tanımlamak mümkündür: Fikri hak sahibi, eser veya icra tespitinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satışı veya diğer yollarla dağıtılması hususunda bir kez izin vermekle, bu izni izleyen satışlar için de izin vermiş sayılır. Bir başka deyişle ilk satışa izin vermekle, satış hakkı tükenir. Bu ilke icracı sanatçılar açısından, FSEK madde 80/1A-3’de düzenlenmiştir. Bu hükme göre, icracı sanatçılar, yurt içinde satış veya başka yollarla dağıtılmamış, tespit edilmiş icralarının aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satış veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama yetkisine sahiptir. Burada kastedilen ilk satıştır. Örneğin, icrasını içeren ses taşıyıcıların yayma hakkını bir fonogram yapımcısına veren icracı sanatçı artık söz konusu taşıyıcıların baş bayilere, onlar tarafından bayilere ve bayiler tarafından da tüketiciye satımına engel olamaz. Bu hallerde tükenen sadece satış hakkıdır; kiralama ve ödünç verme hakları hak sahibinde kalmaya devam eder. Tükenme ilkesi kural olarak ülkeseldir. Yani ilk satım hangi ülkede yapılmışsa, hak sadece o ülke açısından tükenir. Bir başka deyişle **“paralel ithalat”** yasaktır⁵⁶. Örneğin, satış hakkı Türkiye’de yapılmışsa, dağıtımına sunulan kopyalar bakımından satış ve dağıtım hakkı Türkiye’de tükenmiştir. Türkiye için verilen izin uluslararası tükenmeyi beraberinde getirmez. Bu yetki yurt dışında devam eder ve her ülkenin kendi hukukuna göre tükenme gerçekleşir. Ancak Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerde, ülkesel tükenme ilkesi yerini bölgesel tükenme ilkesine bırakmıştır.

⁵³ Bkz. ARKAN, age., II. Bölüm, § 1, IV, 1. Naklen ARKAN, age., s. 87

⁵⁴ TEKİNALP, age., § 15 N 23 ve § 17 N 22. Naklen ARKAN, age., s. 87

⁵⁵ ARKAN, age., s. 87

⁵⁶ Fikri mülkiyet koruması altında bulunan bir ürünü barındıran ve bir ülkede yasal olarak piyasaya sürülen orijinal malların buradan satın alınarak, başka bir ülkede satışa sunulmasına paralel ithalat adı verilmektedir. Kavramla ilgili detaylı bilgi için bkz. ASLAN, A., Türk ve AB Hukukundan Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi, İstanbul, 2004, s. 48 vd. Naklen ARKAN, age., s. 90

Buna göre, Birliğe dahil ülkelerden birinde hak sahibinin rızası ile satışa sunulan ürünler için artık tüm birlik ülkelerinde tükenme gerçekleşmiş sayılmaktadır⁵⁷. Avrupa Topluluğu Mahkemesi'nin "Deutsche Grammophon" davasında verdiği kararda bölgesel tükenme ilkesi açıkça kabul edilmiştir. Karara konu olay şöyle gelişmiştir: Almanya'da üretilen müzik kasetleri Fransa'ya ithal edilerek yetkili satıcı tarafından Fransa'da satışa sunulmuş; ancak sonra kasetler, daha pahalı satıldıkları Almanya'ya yeniden ithal edilmiştir. Almanya'daki hak sahibi bu duruma karşı çıkmıştır. Karara göre, hak sahibinin izniyle topluluğa dahil bir ülkede piyasaya sunulan malların bir başka ülkede piyasaya sürülmesine hak sahibi engel olamaz⁵⁸.

Bu konuda Avrupa Topluluğu Mahkemesi kararına konu olan şu olay da ilginçtir: İngiliz uyruklu şarkıcı Phil Collins'in Amerika'da verdiği bir konser, söz konusu sanatçının izni alınmaksızın kaydedilerek çoğaltılmış ve söz konusu ses taşıyıcıları (kaset ve cd'ler) Almanya'da piyasaya sürülmüştür. Olayın geçtiği sırada yürürlükte bulunan Alman mevzuatı, yabancı uyruklu icracı sanatçıların Almanya dışında sundukları icralarına herhangi bir koruma tanımamakta idi. Bununla birlikte Mahkeme, Avrupa Topluluğu Anlaşması'nın⁵⁹ 7. maddesindeki ayrımcılık yasağına ve Roma Anlaşması'na dayanarak Alman vatandaşı olmayan diğer üye ülke vatandaşlarının da Alman ulusal mevzuatına göre koruma talep edebileceğini ifade etmiştir⁶⁰.

⁵⁷ TEKİNALP, age., § 14 N. 107; ARIKAN, A.S., "Fikri ve Sınai Hakların Tükenmesi ve Rekabet Hukuku, Fikri Haklara İlişkin Sözleşmeler", Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, C. 1, Ankara 2002, s. 755-756; VANDOREN, P., Copyright and Related Rights in the Information Society, The Future of Copyright in a Digital Environment, The Hague, London, Boston, 1996, s. 160. Tükenme ilkesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. ASLAN, s. 145-155 ve 161 vd. OKUTAN, G., Exhaustion of Intellectual Property Rights: A Non-Tariff Barrier to International Trade?, Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul, 1996, C. 30, S. 46, s. 110 vd; KALİ, S., "Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkının Tüketilmesi ve Sınai Mülkiyet Hukukuyla İlişkisi", FMR., 2001, C.1, S. 4.s. 55 vd. Naklen ARKAN, age., s. 90

⁵⁸ C-78/70 (ATKD, 1971, 487). Ayrıca kararla ilgili bir değerlendirme için bkz. FERİD, H., Zur Anwendung von Art. 36 EWG-Vertrag auf nationale Urheberrechte und Verwandte Schutzrechte, Festgabe-zum 65. Geburtstag von Eugen ULMER, 1973, s. 76 vd. Naklen ARKAN, age., s. 90

⁵⁹ Anlaşma metni için bkz. <<http://www.documentarchiv.de/in/ewg.html>> Naklen ARKAN, age., s. 90

⁶⁰ C-92/92 ve 326/92 (ATKD, 1993, 1-5145). Olayın Alman Hukuku'ndaki yansımaları için bkz. LOEWENHEIM, U., Der Schutz ausübenden Künstler aus anderen

d. Temsil Hakkı

Roma Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre; *icrası sanatçılar için sağlanan koruma: ...yayın veya umuma arz suretiyle kullanılan icranın bizzat daha evvel radyo ile yayınlanmış bir icra olması veya daha önce yapılan bir tespitten yayınlanması hariç, kendi icralarının izinleri olmaksızın ... umuma arzını... önleyecektir.*

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 6. maddesi; icracı sanatçının, *tespit edilmemiş icraların, bunların henüz yayınlanmış olduğu durumlar hariç... topluma iletilmesine ...münhasıran izin verme hakkı olduğunu düzenlemiştir.*

Görüldüğü gibi Roma ve WIPO Sözleşmeleri temsil hakkını sadece belirli durumlar için düzenlemişlerdir. Sözleşmelere göre icracı sanatçının temsil hakkı; icraların,

- daha önce radyo ile yayınlanmamış olması,
 - daha önce yapılan bir tespitten yayınlanmamış olması ve
 - daha önce yayınlanmamış olması
- hallerinde sözkonusudur.

FSEK madde 80/1 no'lu fıkrasında A bendinde; “bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçı, bu icranın ... temsiline izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidir” ifadesi ile temsil hakkı düzenlenmiştir. Uluslararası sözleşmelerle getirilen bu asgari korumayı daha da genişleten Türk Hukuku, temsil hakkını ister daha önceden yayınlanmış veya tespit edilmiş olsun isterse olmasın icranın kullanıldığı tüm durumlar için getirmiştir.

FSEK 41. maddesi ise; umumi yerlerde müzik yayını için icracı sanatçılardan izin alma gereğini diğer hak sahipleri ile icracı sanatçıları organize ederek aşağıdaki biçimde farklı bir sisteme bağlamıştır.

“Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı mali hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar.

Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanan ve/veya ileten umuma açık mahaller; mahallin bulunduğu bölgenin özelliği, mahallin nitelik ve niceliği, fikrî mülkiyete konu eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası ve ürün veya hizmete katkısı olup olmadığı ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle sınıflandırılır veya sınıflandırma dışı bırakılır.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımından ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile umuma açık mahaller arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

Tarifelere ilişkin sözleşmelerde takvim yılı esas alınır ve bu tarifeler takvim yılı başından itibaren geçerli olur.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasını teminen:

1. *Meslek birlikleri temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bilgileri, Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimler her üç ayda bir güncellenir ve Bakanlıkça oluşturulan ortak bir veri tabanı üzerinden ilgili taraflara açılır.*

2. *Eser sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya bağlantılı hak sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya aynı sektörlerde faaliyet gösteren meslek birlikleri, biraraya gelerek protokole bağlamak suretiyle ortak tarifeler belirleyebilirler. Ortak tarifeler protokole taraf meslek birlikleri açısından bağlayıcıdır.*

Meslek birlikleri, tarifeler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildirirler ve kamuoyuna duyururlar. Umuma açık mahaller, müzakere ve sözleşme yapılmasına ilişkin verecekleri bağlayıcı nitelikteki yetki belgeleri ile üye oldukları meslek kuruluşları aracılığıyla da tarifeleri veya ortak tarifeleri müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler. Ancak, tarifelerin götürü usulde tespit edilmesi halinde umuma açık mahaller sadece meslek kuruluşları aracılığı ile müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler.

Onuncu ayda umuma açık mahaller veya meslek kuruluşları ile meslek birlikleri arasında tarifeler veya ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde, en geç bu ayın so-

nuna kadar, meslek birlikleri ve/veya meslek kuruluşları tarafından bu tarifelerin Bakanlıkça oluşturulacak uzlaştırma komisyonunda müzakere edilmesi talep edilebilir.

Uzlaştırma komisyonu, taraflardan birinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, tarifeleri müzakere etmek üzere, Bakanlık tarafından talep tarihinden itibaren onbeş gün içinde oluşturulur. Komisyon Bakanlıktan bir, Rekabet Kurumundan iki temsilci ve ilgili meslek birlikleri ile kullanıcıları temsil eden meslek kuruluşlarının birer temsilcisinden oluşur. Bakanlık temsilcisi aynı zamanda komisyon başkanıdır. Aynı usulle, komisyon üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık ilgili birimi tarafından yürütülür. Komisyon, oluşturulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde, raporunu hazırlayarak, Bakanlığa ve taraflara bildirir. Umuma açık mahaller ve meslek birlikleri, Komisyon raporunun açıklandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde, meslek birliklerinin açıklamış oldukları tarifeleri veya müzakereler neticesinde mutabakata vardıkları tarifeleri sözleşmeye bağlayabilirler. Meslek birliklerince belirlenen tarife veya ortak tarifeler üzerinden sözleşmenin yapılmaması halinde, taraflar yargı yoluna başvurabilirler. Yargılama sürecinde, bir önceki yıl sözleşme yapmış olan mahaller, ilgili meslek birlikleri aksini bildirmedikçe, dava konusu tarifenin 1/4'ünü dava sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir meslek birlikleri adına açılmış banka hesabına yatırmak suretiyle eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilir ve/veya iletebilirler. Bir önceki yıl sözleşme yapmamış umuma açık mahaller ile ilk defa sözleşme yapacak umuma açık mahallerin bu fıkra da öngörüldüğü şekilde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilmeleri ve/veya iletebilmeleri ise ilgili meslek birliklerinin iznine bağlıdır. Dava sonuçlanıncaya kadar bu şekilde ödenen miktar, mahkeme kararıyla tespit edilen tarife bedelinden mahsup edilir.

Tarifelerin tespit edilmesinde ve uzlaşmazlıkların hallinde, bu Kanunun 42/A maddesinin üçüncü fıkrasında⁶¹ yer alan, tarife tespitine ilişkin esaslar dikkate alınır.

⁶¹ FSEK 42/A 3. fıkrası: Tarifelerin tespit edilmesinde; tarifelerin uluslararası uygulamaların ülkenin ekonomik ve toplumsal koşullarına uyarlanabilirliği göz önünde bulundurularak makul seviyede belirlenmesi ile teknolojik alandaki değişimlerin yanı sıra eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların yaratıldığı ve kullanıldığı sektörlerin yapısını tahrip edici, üretimi ve kullanımı engelleyici ve genel kabul görmüş uygulama-

Mahallerde kullanılan ve/veya iletimi yapılan eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar üzerinde hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, bunların kullanımına ve/veya iletimine ilişkin ödemelerin yapılmasını yetki verdikleri meslek birlikleri aracılığı ile talep edebilirler. Sinema eserleri bakımından bu fıkranın uygulanması zorunlu değildir.

Sınıflandırma, uzlaştırma komisyonuna başvuru halinde Bakanlıkça alınacak ücretler ve uzlaştırma komisyonunun çalışması ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.”

Bu düzenleme birçok açıdan icracı sanatçılar için sakıncalar içermekle birlikte tekrardan kaçınmak için, bu sakıncalar ve eleştirilerimiz hakkında “V. Müzik Eseri Sahibinin Hakları, B. Müzik Eseri Sahiplerinin Mali Hakları, 4. Temsil Hakkı, Umuma Açık Yerlerde Müzik Eserlerinin Kullanılması” adlı bölüme bakılmasını öneriyoruz.

Komşu Haklar Yönetmeliği’nde temsil hakkı konusunda bir düzenleme yoktur.

Her zaman söylediğimiz gibi, FSEK’de zamanın zorlaması ile yapılan düzenlemeler bir bütünsellikten uzaktır. Bu yüzden kısa zamanda FSEK, kendi içindeki çelişki ve belirsizliklerden arındırılmak için yeniden yazılmalıdır. Bu yazımda öncelikle bağlantılı hak sahipleri için hakların kapsamı açıklanmalıdır.

İracı sanatçılar için temsil hakkının hangi kapsamda olduğuna dair FSEK bir tanım getirmediğinden eser sahiplerine özgü temsil hakkı tanımından yararlanacağız.

FSEK madde 24 eser sahipleri için **temsil hakkını**; “*bir eseri doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi yerlerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek*” şeklinde tanımlamaktadır.

Burada iki tip temsil hakkı söz konusudur. İlki “**doğrudan temsil**”dir ve müzik eserleri için uygulaması çok fazladır. Örneğin bir şarkının konserde sanatçı tarafından söylenmesi doğrudan temsildir. İkinci tür temsil ise “**dolaylı temsil**” olup, televizyon ya da büyük ekranlar gibi

malara zarar verici bir etki yaratılmaması, rekabeti bozucu şartlar oluşturulmaması, yapılan sınıflandırma, ilgili sektörlerdeki ürün fiyatları ve bu sektörlerin gayrisafi milli hâsıladaki payı, eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletim sıklığı, birim fiyat veya götürü usulü ödeme, ödeme planı ve benzeri hususlar esas alınır.

yayın araçları ile şehir meydanında müzik eserinin dinlettirilmesi veya seyrettirilmesidir.

ARKAN, bizim de katıldığımız görüşünde; icracı sanatçılar açısından doğrudan temsil hakkının olamayacağını ifade etmektedir. Doğrudur; sanatçı zaten fiziken orada olmasa kendisi açısından temsil gerçekleşmez. Sanatçı fiziken oraya gidip konsere çıkıyorsa zaten icracı sanatçının temsil hakkı açısından bir başkasının izni söz konusu değildir. Bu nedenle icracı sanatçılar açısından sadece dolaylı temsil söz konusudur.

Eğer icracı sanatçının icrasında bir fonogram kullanılıyorsa, icracı sanatçının yanı sıra fonogram yapımcısından da veya icra bir televizyon yayıncısı tarafından kaydedilip yayınlanmışsa bu kez ek olarak televizyon yayıncısından da şehir meydanındaki bu temsil için izin alınması gerekmektedir.

Eskiden dolaylı temsilin içinde anılan ve onun bir türü olan kitle iletişim araçlarıyla (radyo, televizyon ve günümüzde internet ile) yayın o kadar genişlemiş ve karmaşıklaşmıştır ki zorunlu olarak tüm dünya mevzuatında olduğu gibi bizde de temsil hakkından ayrılmış; FSEK de ayrı bir başlık altında “*umuma iletim*” adıyla düzenlenmiştir. **Kitle iletişim araçlarıyla umuma iletimde yayın, umumi yerde veya özel bir yerde olabilir. Temsil hakkında ise yapılan yayının (okuma, çalma, oynama, gösterme) mutlaka umumi yerde olması gereklidir.** Kitle iletişim araçlarıyla yapılan umuma iletim belirli bir kişi veya yere yönelik olmayan genel kitle hedeflenerek yapılır. Temsilde ise belirli **bir yere özgü olarak** işaret, ses veya resim nakline yarayan “aletler” kullanılır.

Temsilde iki temel unsur bulunmaktadır:

- Eserden yararlanma, geçici olmalı ve yararlanma anıyla sınırlı kalmalıdır.
- Temsil, kamunun istifadesine elverişli umumi bir yerde gerçekleşmelidir.

Öğretide, umumi sayılmayacak bir yerde yapılan temsile rağmen, eserin burada kamuya sunulmak niyetiyle temsil edildiği anlaşıyorsa; umumi yer unsuru gerçekleşmiş kabul edilmektedir⁶². Eserin tek bir şahsa veya dar bir şahıs topluluğuna icra edilmesi ise temsil sayılmaktadır.

⁶² SULUK/ORHAN, *age.*, s. 399; EREL, *age.*, s. 151.

İcracı sanatçının canlı icrasının, icranın yapıldığı yer dışına ekran, hoparlör gibi araçlarla taşınarak kamuya naklinin izne tabi olduğunu belirtmiştik. Böylece icranın, yapıldığı yer dışında izinsiz olarak taşınması önlenerek, icracı sanatçıya, icrasının tesir sahasını belirleme yetkisi tanınmıştır. Ancak icranın, yapıldığı yerin her tarafından duyulmadığı veya izlenmediği büyük alanlarda ekran ya da hoparlör yardımıyla alanın her tarafından işitilir ve görölür hale getirilmesi için izne ihtiyaç yoktur.

Temsil hakkını ilgilendiren bir başka konu olan; mağaza, otel, lokanta, cafe, diskotek ve oteller gibi umumi yerlere yapılan dolaylı temsil hallerinde veya umuma iletim hallerinde icracı sanatçıların durumuna bakmakta fayda vardır.

Öğretide, otel ve mağaza gibi yukarıda sayılan umumi yerlerde müzik eserlerinin cd'den veya bilgisayar kayıtlarından yahut bir radyo ve televizyondan orada bulunanlara izletilmesi veya dinletilmesi temsil hakkının bir türü olarak kabul edilmektedir. Temsil hakkının kapsamına; canlı icraların icra yapılan yer dışındaki umumi yerlerde aynı anda yayını girdiği gibi, tespit edilen icraların sonradan (canlı değil/ banttan veya fonogramlardan) umumi yerlerde yayını da girmektedir. Üzerinde tartışılan konu, icracı sanatçıların kaydedilmiş icralarının buralarda yayınlanabilmesi için icracılardan ve diğer bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmasının gerekip gerekmediği veya icracı ve bağlantılı hak sahiplerinin yasaklama yetkilerinin bulunup bulunmadığıdır. Bize göre ülke-mizde FSEK 80 ve 41. maddelerindeki yasal düzenleme doğrultusunda, icraların kullanılması için icracı sanatçılardan veya onların meslek birliğinden izin zorunluluğu getirildiğinden böyle bir tartışmanın hiç gereği yoktur.

Ancak ARKAN, özellikle Alman Hukuku'nun düzenlemeleri doğrultusunda umumi mahallerde özellikle radyo ve televizyon yayını yoluyla icraların kullanılması için icracı sanatçının iznine gerek görmektedir. Yazara göre; icracı sanatçı, yayıncı kuruluşa veya bir fonogram yapımcısına bir icrasını tespit ettirdiği anda, canlı yayınlar haricinde bu kaydın sonradan umuma sunumuna da izin vermiş sayılmaktadır. İcracı sanatçılar gibi eser sahiplerinin veya fonogram yapımcılarının da, radyo ve televizyon yayınlarının umumi yerde temsilinde; kendi icraları, eserleri veya fonogramları kullanılmış olsa dahi yayıncı kuruluşa bu kayda alma iznini vermesiyle, bu kaydın radyo ve televizyonlar vasıtasıyla sonradan umumi yerlerde yayını için izinlerinin gerekmediğini, dolayısıyla icracıların, eser sahiplerinin ve fonogram ya-

pımcılarının bu hakkın kullanımını yasaklama yetkisinin olmadığını belirtmektedir. Umumi yerde yapılan radyo ve televizyon yayınları için eser sahipleri, icracı sanatçılar ve fonogram yapımcılarının sadece uygun bir bedel alma haklarının bulunduğunu belirtmektedir. Yazar görüşünü desteklemek için uygun bedel düzenlemesinin tüm uluslararası sözleşmelerde olduğunu belirtmektedir⁶³.

Evet, Alman Hukuku açısından bu tercih Alman yasa koyucu tarafından uygun bulunmuş olabilir ama uluslararası sözleşmeler ve Türk Hukukunda FSEK 80 ve 41. madde düzenlemelerine bakıldığında, Yazarın bu görüşüne katılma olanağı yoktur. Uluslararası sözleşmelerde uygun bedel düzenlemesi bulunmakta ancak; ek olarak icracı sanatçıdan izin alma zorunluluğu ve/veya icracı sanatçının yasaklama hakkı da bulunmaktadır. Roma Sözleşmesi'nin 7. maddesinin 1/a maddesi "*Sözleşmenin icracı sanatçılar lehine umuma arz suretiyle kullanılan icranın muvafakatı olmaksızın umuma arzını önleyecek nitelikte olduğunu*" açıkça ortaya koymaktadır. TRIPS Anlaşması'nın 14. maddesinde canlı icranın temsili için icracı sanatçının izninin alınması şartı düzenlenmiştir. Sonuç itibarıyla, Alman Hukuku bir tercihte bulunmuştur, ama Türk Hukuku kendi ülkesindeki şartların gereğince uluslararası sözleşmelere uygun olarak bir başka tercihte bulunmuştur.

Bir kere, tüm uluslararası sözleşmeler fiktisel ve sanatsal hakların olmazsa olmazlarını düzenleme amacıyla yapılmışlardır. Uluslararası sözleşmeleri imzalayan veya AB direktiflerine tabi ülkeler, ilgili sözleşmedeki kuralları kendi ülkeleri için "**asgari hukuki koruma kuralları**" olarak belirlemiş ve iç hukuklarına bu asgari kuralları mutlaka almıştır. Kültür ve hukuk düzenleri gelişmiş veya gelişmemiş ülkeler kendi içsel konumları⁶⁴ sebebiyle Bern Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerdeki bu asgari kurallarla yetinmeyip, ülkelerinde eser sahiplerine uluslararası sözleşmelerde belirtilenlerden daha geniş haklar tanımışlardır. Bern Sözleşmesi'nin 19. maddesi, fiktisel ve sanatsal haklar açısından "***bu Sözleşme hükümleri, Birlik ülkeleri mevzuatı ile tanınan daha geniş bir korumadan yararlanma isteğine engel oluşturmaz***" ve 20. maddesi

⁶³ ARKAN, age., s. 95 vd.

⁶⁴ Ülkemiz açısından fiktisel ve sanatsal haklarda, uluslararası sözleşmelere nazaran FSEK kurallarıyla daha geniş bir korunma gereksinimi; telif haklarının ödenmesi bilincinin tabanda yaygınlaşmaması ve telif hakkı ihlallerinin yaygın olması sebebiyle tercih edilmiştir.

“Birlik ülkelerinin hükümetleri, aralarında eser sahiplerine bu Sözleşme ile tanınan haklardan daha geniş haklar veren veya bu Sözleşmeye aykırı hükümler içermeyen özel anlaşmalar yapma hakkını saklı tutarlar” düzenlemesiyle ve Roma Sözleşmesi’nin 1. maddesi **“Bu Sözleşme ile öngörülen koruma edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki telif haklarının korunmasını hiçbir suretle ihlal etmez ve etkilemez. Bu sebeple bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, işbu korumayı ihlal edebilecek şekilde yorumlanamaz”** ve 21. maddesi **“Bu Sözleşme tarafından öngörülen koruma, icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının ve yayın kuruluşlarının başka şekilde yararlanabilecekleri korumaya hanel getirmez”**; 22. maddesi de **“Akit devletler, icracı sanatçılara, fonogram yapımcılarına veya yayın kuruluşlarına, bu Sözleşmedeki haklardan daha kapsamlı haklar tanıyan veya bu Sözleşmeye aykırı bulunmayan diğer hükümleri içeren özel anlaşmalar yapma hakkını saklı tutarlar”** düzenlemeleri ile bu amacı açıkça ortaya koymuştur.

Sözleşmelerle, sadece olmazsa olmaz asgari kuralları koyma amacı; Bern Sözleşmesi’nden sonra hazırlanan Roma Sözleşmesi, WIPO sözleşmeleri ve AB direktiflerinin hepsinde sürdürülmektedir. İşte Bern Sözleşmesi’ne uygun hazırlanan bizim Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’muz, daha sonra ortaya çıkan uluslararası hukuk sözleşme ve kurallarındaki gelişmeler paralelinde bağlantılı hak sahiplerine, uygun bedel alma asgari koruması yanında, ülkemizdeki fikir ve sanat eserleri üretimini teşvik etmek ve yaygın telif hakları ihlallerini önlemek için, izin ve yasaklama yetkilerini de kapsayan daha geniş hukuki koruma kurallarını ve hakları tanımıştır. Eser sahipleri haklarında olduğu gibi FSEK 80 1/A maddesi açıkça; **“Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçı, bu icranın tespit edilmesine, bu tespitin çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve temsiline izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidir”** ve FSEK 41. maddesi **““girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı malî hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar”** demektedir. Aynı düzenleme fonogram yapımcıları için aynı maddelerde sözkonusudur.

Öte yandan ARKAN'ın yorumuna katılırsak; gerçekten eser ve bağlantılı hak sahiplerine manevi olarak büyük acı çektirecek bir sistem söz konusu olur. Bir umumi yer veya kullanıcı o eser veya bağlantılı hak sahibi kişiye karşı hakaret etmiş olabilir, ona karşı bir suç işlemiş olabilir. Bu sebeple hak sahibi müzik eserinin hiçbir biçimde orada çalınmasına izin vermez. Ama ARKAN'ın yorumu gerçekleşirse, kullanıcı "nasıl olsa bedelini veriyorum, çalarım kardeşim" diyebilir.

Sonuç olarak, FSEK 80. ve 41. maddesi düzenlemesi doğrultusunda Türk Hukukuna göre, temsil hakkının bir biçimi olan umumi yerlerde müzik eserlerinden yararlanmaya izin verme veya yasaklama hakkına, icracı sanatçılar, eser sahipleri, fonogram yapımcıları ve radyo ve televizyon kuruluşları aynı anda sahiptirler. FSEK 41. madde gereğince bu izin hak sahipleri tarafından veya meslek birlikleri tarafından verilmektedir. Radyo ve televizyon yayını alan ve temsil eden umumi yer sorumlusu açısından meslek birlikleri yerine hak sahiplerinden izin almak için kimlerin hak sahibi olduğunu belirlemek gereklidir. Bu konuda müzik yapının hak sahipleri arasındaki sözleşmelere bakmak gerekmektedir.

Bu açıklamalarımızın örneğini teşkil eden bir mahkeme kararına bakalım. Bu kararda; hak sahibi veya onların meslek birliğinden izin alınmadan bir mağazada eserin veya icranın kullanılması halinde işletmenin, maddi tazminat olarak normal ücretin üç katı bedel ödediği görülmektedir.

"Davacı vekili, davalı şirkete ait mağazada Süper FM radyo istasyonundan, müvekkil birliğe kayıtlı olan S.E. isimli sanatçının "La!" isimli eserinin halka açık şekilde ve izinsiz yayınlandığını ileri sürerek, 5846 sayılı FSEK'nun 76/2 ve 68. maddeleri uyarınca hesaplanan 900 ABD Dolarının haksız fiil tarihinden itibaren TCMB döviz faiziyle birlikte fiili ödeme günündeki TL karşılığının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, Uluslararası Telif Birlikleri Konfederasyonunun hazırladığı ölçülere uyularak belirlenen ve Kültür Bakanlığı onayından sonra uygulanan tarifelere göre ve FSEK'nun 68. maddesi uyarınca davacının 720 ABD Doları talep edebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, anılan meblağın haksız fiil tarihinden itibaren döviz faiziyle birlikte fiili ödeme günündeki TL karşılığının davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Karar onanmıştır⁶⁵.

⁶⁵ Yargıtay 11. H.D. 2003/12916 E. 2004/6868 K.

Eğer icracı sanatçı umumi yerler açısından kendinde olan hakları fonogram yapımcısına yazılı bir sözleşme ile devretmişse, icracı sanatçının artık bu yayınlar hakkında izin verme hakkı kalmadığından, bir mali hak ve bedel de talep edemez. Bu durumda umumi yerlerde sunulan fonogramlar için umumi yer sorumlusunun fonogram yapımcısı ile anlaşması gereklidir. Eğer icracı sanatçı fonogramlardaki veya kliplerdeki icraları için fonogram yapımcısına sadece çoğaltım ve satış lisansı/izni vermişse, -temsil hakkı konusunda bir lisans açıkça yazılı olarak verilmediği için- bu hak icracı sanatçıdadır. Bu halde umumi yerlerde sunulan fonogramlar için umumi yer sorumlusunun, icracı sanatçının veya kolay yolu seçerse onun meslek birliğinin ve fonogram yapımcısının yazılı iznine gereksinimi vardır.

Umumi yerde yapılacak yayın, eğer radyo veya televizyon yayını ise yine taraflar arasındaki sözleşmeye bakmak gerekir. Eğer icracı sanatçı radyoda yaptığı kayıt veya televizyonda çıktığı program için umumi yerler açısından hakları yazılı olarak yayıncı kuruluşa devretmemişse veya süreyle sınırlı olarak bir lisans vermemişse bu haklar hâlâ kendisinde olduğundan, umumi yer sorumlusunun icracı sanatçı ile veya onun meslek birliğiyle ve yayıncı kuruluşla anlaşması gerekmektedir. Yine icracı sanatçı temsil haklarını eğer fonogram yapımcısına devretmişse ve fonogram yapımcısı bu fonogramların veya kliplerin umumi yerlerde çalınması açısından yayıncı kuruluşa bir yetki vermediyse umumi yer sorumlusu sadece yayıncı kuruluş ile yapacağı bir sözleşme ile bu icralardan yararlanamaz, ek olarak fonogram yapımcısından veya yapımcının meslek birliğinden de izin almak zorundadır..

Günümüzde umumi yerler, meslek birlikleri ile görüşerek bu izinleri almaktadırlar. Meslek birlikleri; üyelerinin kim olduğunu umumi yer işletmecisine bildirdiği için, umumi yer sahiplerinin “kimle masaya oturmalıyız?” veya “gerçek hak sahibi kim?” sorununu engellemişlerdir. Zaten bu noktadan sonra umumi yer sorumlularının meslek birliği ile sözleşme yapmak dışında bir alternatifleri kalmamıştır.

İracı sanatçıların çoğunun meslek birliğine üye olmaları ve yetki belgeleri ile bu hakları meslek birliğine devretmiş olmaları sebebiyle FSEK 42/A son fıkraya göre; meslek birlikleri hakların takibini, yetki belgeleriyle aldıkları yetkiler kapsamında yapmaktadırlar. Bilindiği gibi yetki belgelerinin içindeki yetkiler tam ruhsat veya devir hükmüne haiz hukuki işlemlerdir. Verildikleri süre içinde bu mali hakların icracı sanatçılar tarafından bizzat dahi kullanılmaları imkansızdır. Bu konuda Yar-

gıta'yın uygulamaları, hak için tam ruhsat verilmesi veya başkasına devir edilmesi halinde o hakkın sözleşme şartlarında hak sahibinin mal varlığından çıktığını göstermektedir. Bu yüzden artık, üyeleri için izin verme yetkisi meslek birliklerindedir.

e. Umuma İletim Hakkı

2001/29/AT sayılı AB “Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Direktif”in girişinde;

“(9) Fikri yaratım anlamında çok önemli olduklarından, telif hakları ve bağlantılı haklarda her uyumlaştırmanın yüksek seviyede bir korumayı temel alması gerektiğinden; bunların korunmasının eser sahiplerinin, icracı-sanatçıların, yapımcıların, tüketicilerin, kültür, endüstri ve en geniş anlamda kamunun menfaatine olarak yaratıcılığın korunması ve geliştirilmesinin sağlanmasına yardım ettiğinden; bu yüzden fikri mülkiyetin mülkiyet hakkının ayrılmaz bir parçası olarak tanındığı,

(10) Yazarlar ve icracı-sanatçıların, yaratıcı ve artistik eserlerini sürdürmek durumunda olduklarından, eserlerinin kullanımı için, yapımcılar da bu eserleri finanse edebilmek için uygun bir karşılık almaları zorunlu olduğundan; fonogram, film ya da multimedya ürünleri gibi ürünlerin ve talep üzerine hizmetler gibi hizmetlerin üretilmesi için gereken yatırım dikkate değer olduğundan; bu yatırımların tatmin edici bir şekilde geri dönüşleri için fırsat temin etmek ve adı geçen karşılıklar gibi karşılıkları garanti etmek için, fikri mülkiyet haklarının yasal olarak yeterli derecede korunması gerekli olduğu” sebepleriyle işbu Direktifin çıkarıldığı belirtilmektedir.

Direktifin Girişinde 23 no’lu paragrafta, “**umuma iletim**”; “**iletişimin kaynaklandığı yerde bulunmayan halkı da kapsayan geniş bir anlamda iletim olarak anlaşılması gerektiğinden; bu hak, yayını da içeren, kablolu veya kablosuz araçlarla bir eserin halka her türlü aktarımını veya yeniden aktarımını**” şeklinde tanımlanmaktadır.

Direktif 3. maddesi ile, umuma iletim hakkı için; “Üye devletler, tel üzerinden veya telsiz vasıtalarla eserlerini yayınlama, böyle bir yolla kamuya bireylerin tercih ettikleri bir zamanda ve bir yerden erişebilme münhasır haklarını,

(a) icracı-sanatçılar, kendi icralarının düzenlemesi;

(b) fonogram üreticileri, kendi fonogramları;

(c) filmleri düzenleyen ilk üreticiler, kendi orijinal filmleri ve kopyaları;

(d) yayın kuruluşları, kendi yayınlarını kablo veya uydu yayını da dahil olmak üzere, kablo üzerinden veya karasal üzerinde iletip iletmeme düzenlemesi;

için korur” şeklinde düzenleme yapmış ve 8. maddesinde “*üye devletler, bu Direktifte düzenlenen haklar ve sorumlulukların ihlali halinde başvurulacak uygun yaptırım ve hukuki yolları sağlarlar ve bu yaptırım ve hukuki yolların uygulanmasını temin etmek amacıyla gereken her türlü önlemi alırlar, bu şekilde sağlanan yaptırımların etkili, orantılı ve caydırıcı olması sağlanır*” diyerek üye devletlere ihlallere karşı etkili önlemler alma ve uygulama mükellefiyetini yüklemiştir.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun “2001/29 sayılı Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Haklarla İlgili Belli Hususların Uyumlaştırılması Hakkında Parlamento ve Konsey Direktifi”nin 23 sayılı gerekçesinde; “*umuma iletim hakkı, iletimin ilk yapıldığı yerde hazır bulunan kamuya yönelik yapılan her tür iletimi kapsayacak şekilde geniş anlamda ele alınmalıdır. Bu hak, radyo televizyon yayınları da dahil olmak kaydıyla, telli telsiz araçlarla eserin kamuya her tür iletimini ve yeniden iletimini kapsamalıdır*” denilmektedir.

Müzik eserleri açısından **umuma iletim** günümüzde üç biçimde gerçekleşmektedir. Bunlar; “**yayın**”, “**yeniden yayın**” ve “**kamunun erişimine sunma**”dır. Şimdi bu üç umuma iletim hakkını ayrı ayrı inceleyelim.

Yayın

Komşu Haklar Yönetmeliğine göre yayın; seslerin ya da görüntülerin veya her ikisinin toplumun yararlanacağı şekilde radyo ve televizyon araçlarıyla telli ya da telsiz olarak kamuya sunulmasıdır.

Roma Anlaşması’nın 3. maddesinde “*yayın*”, *seslerin yahut resim ve seslerin toplumun yararlanacağı şekilde radyo dalgaları ile yayını; olarak tanımlanmıştır.*

WIPO İcralar Sözleşmesi ise 2. maddesinin (f) bendinde “*radyo-televizyon yayını*”, *topluma ulaştırılması amacıyla seslerin veya görüntü ve seslerin telsiz iletimi olarak tanımlanmıştır.* WIPO Sözleşmesi’ne göre, bu ifade aynı zamanda **kablo** ve **uydu** ile gerçekleştirilen bir iletimi de tanımlar; ek olarak radyo televizyon kuruluşu tarafından veya onun rızası ile şifre çözücü araçlarla topluma sağlanan **şifreli sinyallerin iletimi** de “*radyo/ televizyonla yayın*” sayılır.

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun'a göre yayınla ilgili tanımlar, eser sahiplerinin mali haklarını işlediğimiz bölümde "Umuma İletim Hakkı" adlı bölümde verildiğinden oraya atıfla yetiniyoruz⁶⁶.

Bir icranın talep üzerine, elektronik olarak, televizyon veya bilgisayar ortamına getirilmesini sağlayan "talebe bağlı iletimler"; teknik anlamda umuma/kamuya yayın hakkı kapsamında değerlendirilemez. Zira yayın halinde televizyonun veya radyonun kendi yayın akışı bir düğmeye basılmasıyla izleyici ya da dinleyicinin karşısına çıkmakta; izleyici ya da dinleyici, bu akışa müdahalede bulunamamaktadır. Talebe bağlı iletimlerde ise, izleyici veya dinleyici tamamen kendi istediği bir icrayı, istediği saatte televizyonuna, radyosuna ya da internet ekranına getirebilmektedir⁶⁷. Dolayısıyla bu tür eylemler "yayın" kavramında değil; "kamunun erişimine sunma" hakkı kavramı içinde değerlendirilmelidir⁶⁸.

TRIPS Anlaşması'nın 14. maddesine göre; (icracı) *sanatçılar, aynı zamanda, izinleri olmaksızın girişilen aşağıdaki fiilleri de önleme olanağına sahip olacaklardır:*

-doğrudan yapılan uygulamalarının telsiz araçlarla yayınlanması ve topluma iletimi.

Roma Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre; *icrası sanatçılar için sağlanan koruma:*

yayın veya umuma arz suretiyle kullanılan icranın bizzat daha evvel radyo ile yayınlanmış bir icra olması veya daha önce yapılan bir tespitten yayınlanması hariç, kendi icralarının izinleri olmaksızın yayınlanmasını ve umuma arzını önleyecektir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre;

icracı sanatçının, yayına izin vermesi halinde yayın tekrarlarına, yayın amacıyla yapılacak tespitlere ve böylece bir tespitin yayın ama-

⁶⁶ Yine de 3984 sayılı Kanun'daki tanımları şu şekilde verebiliriz. **Radyo yayını:** Elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan ses yayınları; **Televizyon yayını:** Elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan, hareketli veya sabit resimlerin (görüntü) sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınlar; **Kablolu yayın:** Radyo, televizyon ve veri yayınlarının kablo, cam iletken ve benzeri bir fiziki ortam üzerinden abonelere ulaştırılmasını sağlayan yayın; **Uydu yayını:** Radyo ve televizyon programlarının yetkili yayıncı veya hizmeti temin edecek kişi veya kuruluş tarafından şifreli veya şifresiz olarak uzayda sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtasıyla yapılan ilk yayın.

⁶⁷ BARRELET/EGLOFF, Art. 10 N. 26. Naklen ARKAN, age., s. 104

⁶⁸ ARKAN, age., s. 104

ciyla çoğaltılmasına karşı öngörülecek koruma, ülkesi üzerinde koruma istenilen akit devletin ulusal mevzuatı ile düzenlenir.

Roma Anlaşması'nın icraların tespitlerinin kullanılmasına ilişkin diğer hükümleri de 7. maddenin 2. kısmında;

“(1) İcracı sanatçının, yayına izin vermesi halinde yayın tekrarlarına, yayın amacıyla yapılacak tespitlere ve böylece bir tespitin yayın amacıyla çoğaltılmasına karşı öngörülecek koruma, ülkesi üzerinde koruma istenilen akit devletin ulusal mevzuatı ile düzenlenir.

(2) Yayın kuruluşları tarafından, yayın amacıyla yapılmış olan tespitlerin yayın kuruluşları tarafından kullanılma şekilleri, ülkesi üzerinde koruma istenilen akit devletin ulusal mevzuatı ile düzenlenir.

(3) Bununla birlikte, bu maddenin 1 ve 2 numaralı alt paragraflarında öngörülen hallerde ulusal mevzuat, icracı sanatçıların yayın kuruluşları ile ilişkilerini anlaşma yolu ile düzenleme hakkından mahrum edemez” şeklinde düzenlenmiştir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 6. maddesi “İrcacı Sanatçıların Tespit Edilmemiş İcralarına İlişkin Mali Hakları” başlığı altında icracı sanatçıların;

“(1) Tespit edilmemiş icraların, bunların henüz yayınlamış olduğu durumlar hariç, radyo televizyon ile yayınlanmasına ve topluma iletilmesine ...münhasıran izin verme hakkı” olduğunu düzenlemiştir.

22 Mayıs 2001 tarih ve 2001/29/AT sayılı “Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi” 3. maddesinde “Yayın ve Umuma İletim” başlığı altında;

“Üye devletler, tel üzerinden veya telsiz vasıtalarla eserlerini yayınlama, böyle bir yolla kamuya bireylerin tercih ettikleri bir zamanda ve bir yerden erişebilme münhasır haklarını

(b) icracı-sanatçılar , kendi icralarının düzenlenmesi;

için korur” şeklinde hüküm koymuştur. Direktifte bu hakların yayınlama veya yayınlama kararının alınması için yapılan haberleşmenin herhangi bir işlemi tarafından tüketilemeyeceği de düzenlenmiştir.

19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi” ise yayın hakkı konusunda madde 8 ile;

“1. Üye devletler, yayın icrası veya tespit sonucu gerçekleştirilen icra haricinde, icracılara kablosuz yayın konusunda yetkilendirme ya da yasaklama ve icralarının kamuya iletimi münhasır hakkını sağlarlar.

2. Üye devletler, ticari amaçlarla yayınlanan fonogram ya da bu nevi fonogramın çoğaltımı kablosuz yöntemlerle yayın ya da kamuya iletim amacıyla kullanılıyorsa, tek adil bedelin kullanıcı tarafından ödenmesini sağlamak ve söz konusu bedelin ilgili icracılar ve fonogram yapımcıları arasında paylaşılmasını sağlamak için hak sağlarlar. Üye devletler, icracılar ve fonogram yapımcıları arasında anlaşma olmaması durumunda, söz konusu bedelin onlar arasında paylaşılmasını belirleyen şartları düzenlerler” düzenlemesini getirmiştir.

FSEK madde 80/1 no’lu fıkrasında A bendinde icracı sanatçıların yayın hakları şu şekilde sayılmıştır:

(2) Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçı, bu icranın ... işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ... izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidir.

(4)... Umuma iletim yoluyla, icraların dağıtım ve sunulması icracı sanatçının yayma hakkını ihlal etmez.

(5) İcracı sanatçılar bu haklarını uygun bir bedel karşılığında sözleşme ile yapımcıya devredebilirler.

(6) İcranın, bir orkestra, koro veya tiyatro grubu tarafından gerçekleştirilmesi halinde, orkestra veya koroda yalnız şefin, tiyatro grubunda ise yalnız yönetmenin izni yeterlidir.

(7) Bir müteşebbisin girişimi ile ve bir sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen icralar için müteşebbisin de izninin alınması gereklidir.”

FSEK yine 80. maddede film yapımcılarının haklarını düzenleyen maddeden sonra, “Fonogramlara tespit edilmiş icraların ve filmlerin, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanı sıra, icracı sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlüdürler” düzenlemesi getirilmiştir.

Yayın hakları ayrıca FSEK 43. maddesinde özel biçimde düzenlenmiştir:

“Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin almak zorundadırlar.

Bu kuruluşlar sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadırlar.

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren radyo-televizyon kuruluşları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, anılan Kanun dışında kalan ve yayın ve/veya iletim yapan diğer kuruluşlar ise Bakanlık tarafından sınıflandırılır.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram ve yapımların yayın ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile kuruluşlar arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılan müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

Meslek birliklerinin temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bildirim zorunluluğu, tarifelerin belirlenmesi, duyurulması, müzakere edilmesi, sözleşme yapılması, uzlaşmazlıkların halli ve diğer hususlarda bu Kanunun 41 inci maddesinin dört ilâ onüçüncü fıkraları uygulanır. Ancak yayın ve/veya iletim yapan kuruluşlar bakımından 41 inci maddenin altıncı fıkrasının son cümlesinin uygulanması zorunlu değildir.

Ayrıca, 41 inci maddenin 10 uncu fıkrasının uygulanması bakımından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yayınlarında yer verdiği eser, icra, fonogram ve yapımları her üç ayda bir meslek birliklerince belirlenen yıllık tarifenin 1/4'ünü yatırmak suretiyle kullanabilir”.

Bizde “hukuk mühendisleri” olmadığından ve hukuk kurallarını kaleme alan Bakanlık görevlileri yeterince sistematik düşünmediğinden Komşu Haklar Yönetmeliği; FSEK 80 ve 43 değişiklikleri karşısında bir başka sorun haline gelmiştir.

Komşu Haklar Yönetmeliği’nin 7/e maddesine göre; “ticari amaçla kamuya sunulan bir tespitten yapılmayan veya bir radyo ve televizyon yayını olmayan icraların, radyo ve televizyon kuruluşları tarafından yayınlanması için (icracı sanatçının) yazılı izni gereklidir”.

Bu yönetmelik maddesi artık FSEK’e aykırı hale gelmiştir. Çünkü FSEK tüm icraların yayını için izin alma zorunluluğunu getirirken Yönetmelikle, (Yönetmeliğin 7/e maddesi özellikle aynı Yönetmeliğin 15.

maddesindeki uygun bedel hakkı ile birlikte değerlendirildiğinde) sanki fonogramlardan yapılan yayınlarda veya daha önceki radyo ve televizyon yayıncıları tarafından tespit edilen kayıtlardan yapılan yayınlarda, icracı sanatçının izninin gerekmediği, sadece kendisine sonradan bir bedel ödeneceği anlaşılmaktadır.

Alman Hukuku'ndaki *“icracı ve fonogram yapımcılarından izin alınma gereği olmadan sadece kendilerine bir bedel ödenmesi yoluyla umuma iletim yapılabilmesini”* savunan ARKAN'a göre; bu Yönetmelik hükmü Kanuna istisna getirmektedir. Bu düzenleme doğrultusunda; yayıncı kuruluşlar icracı sanatçılardan izin almadan, fonogram kayıtlarını ve önceki radyo ve televizyon yayın bandlarını kullanarak yayın yaparlar ve bunun karşılığında bir bedel öderler⁶⁹. Maalesef bu yorum hatalı ve hukuka aykırıdır. Çünkü Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku'nun temel ilkelerinden biri “normlar hiyerarşisi” olup, hiçbir zaman “yönetmelik” üstteki norm olan “kanun”a aykırı olamaz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda, yönetmeliğin kanuna aykırılığı sonucu yönetmelik hükmü talep üzerine Danıştay tarafından iptal edilir. Kanunda olmayan bir istisna, bir yönetmelik maddesi ile getirilemez. Temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanacağı Anayasa hükmüdür. Bu nedenle mülkiyet hakkının özel bir türü olan bağlantılı hak sahipliği sadece kanunla sınırlanabilir, yönetmelik düzenlemesi ile sınırlanamaz. Bu yüzden ARKAN'a ait, “yönetmelik ile kanuna istisna getirildiği görüşü” hukuka aykırıdır. Bu Yönetmelik herhangi bir uyuşmazlık halinde FSEK'e aykırı olduğu için mahkemelerce uygulanmayacak ve Danıştay tarafından iptal edilecektir. ARKAN'ın bu konudaki görüşlerine niçin katılmadığımızla ilgili daha geniş açıklama için bir önceki “Tespit Hakkı” başlığı altındaki açıklamalarımıza da bakabilirsiniz. Öte yandan üzücü olan taraf, bu Yönetmeliği çıkaran Bakanlık yetkililerinin durumun farkına varıp, yıllardır bunu iptal etmemiş ya da değiştirmemiş olmalarıdır.

Radyo ve televizyonların yayınlarında kullandıkları icralar için icracı sanatçılardan izin almamaları halinde, icracı sanatçılar FSEK'de yer alan tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i, maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davaları açabilirler.

⁶⁹ Bkz. ARKAN, *age.*, s. 106 vd.

Aşağıda müzik alanına kolayca uyarlanabilecek tiyatro eserleri için yayın hakkına ilişkin bir mahkeme kararı sunuyoruz:

“Dava konusu tiyatro oyunları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında eser niteliğinde olup, aynı Kanunun 52. maddesine göre, **mali haklara ilişkin sözleşmede hangi hakları devredildiğinin açıkça gösterilmesi zorunludur.**

Davalı N. ... ile davacı arasında yapılan sözleşmelerde N. ... ve ekibince oynanan tiyatro eserlerinin video çekimi ve yayın hakkının davacıya devredildiği, satıldığı belirtilmiş, televizyonlarda gösterim hakkının da verildiğinden söz edilmemiştir. Şayet televizyonlarda gösterim (yayın) hakkı da devredilmiş olsaydı, bunun sözleşmeye açıkça yazılması gerekirdi. Anılan Yasa hükmü karşısında sözleşmelerin televizyonda yayın hakkını da kapsadığı yolunda daha geniş bir yoruma tabi tutulması mümkün değildir. Davacının 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu uyarınca ilgili Bakanlıktan eser işletme belgesi almış olması, dava konusu hakların davacıya devredildiğine dair yeterli kanıt olamaz.

Mahkemece bu hususlar üzerinde durulmadan yazılı şekilde davanın kabulü doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir⁷⁰”.

İcracı sanatçılar yukarıdaki davaların yanı sıra özel radyo ve televizyon kuruluşlarının idari olarak uyarılması ve cezalandırılması için Radyo Televizyon Üst Kuruluna da 3984 sayılı Kanun gereğince başvurabilirler. 3984 sayılı *Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun* yayın ilkeleri ile ilgili 4. maddesinin “o” bendinde; “yayınlarda eser ve bağlantılı hak sahiplerine 5846 sayılı FSEK ile tanınan hakların ihlal edilmemesi”ni radyo ve televizyonlar için bir yükümlülük olarak koymuştur. Kanun 37. maddesinde de; “Radyo-Televizyon kuruluşlarınca yayınlanan ve/veya iletilen eser, fonogram ve yapımları kullanabilmek için, eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri, veya bu kişilerin üyesi oldukları meslek birlikleri ile izin almak üzere sözleşme yaparlar ve bu sözleşme ile belirlenen mali hak bedellerini öderler . Bu sözleşme ve ödemeler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır. Bu madde hükümlerini ihlal eden yayın kuruluşları hakkında ayrıca bu Kanunu’nun 33 üncü madde hükümleri uygulanır” diyerek, Kanuna uyulmaması halinde RTÜK’ün; yayın kuruluşlarına uyarı, program durdurma, para cezaları

⁷⁰ Yargıtay 11. H.D., 18.11.1999, E. 1999/2264, K. 1999/9338

ve sonunda yayın izninin iptaline kadar varan cezalar verebileceği düzenlenmektedir⁷¹.

⁷¹ 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun'un 33. maddesi şöyledir:

“Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve bu Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâl konulu olan programın yayını, bir ilâ oniki kez arasında durdurulur. Cezaya yol açan fiilde sorumlulukları belirlendiği takdirde programın yapımcısı ve varsa sunucusu da bu süre içerisinde hiçbir ad altında başka bir program yapamaz ve sunamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlaki gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Aykırılığın tekrarı hâlinde;

a) Ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara, ihlâlin ağırlığına göre, ikiyüzellibin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla beşyüzbin Türk Lirasına kadar,

b) Yerel, bölgesel ve kablo ortamından yayın yapan kuruluşlara;

1. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, bir milyondan fazla nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, yüzyirmibin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla ikiyüzbin Türk Lirasına kadar,

2. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, beşyüzbin ilâ bir milyon arasında nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara ihlâlin ağırlığına göre, otuzbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla altmışbin Türk Lirasına kadar,

3. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibin ilâ beşyüzbin arasında nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, yirmibin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla kırkbin Türk Lirasına kadar,

4. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibinden az nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, beşbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla onbin Türk Lirasına kadar,

c) Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar, idarî para cezası verilir.

İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı hâlinde bu idarî para cezaları yarı oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde ikinci kez tekrarında ihlâlin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur.

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılması hâlinde uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur. İhlâlin tekrarı hâlinde yayın süresiz olarak durdurulur ve yayın lisans izni iptal edilir.

Yeniden Yayın

Roma Anlaşması'nın 3. maddesinde “**tekrar yayın**”, *bir yayın kuruluşunun yapmış olduğu yayının, diğer bir yayın kuruluşu tarafından aynı anda yayını olarak tanımlanmıştır. FSEK’de yeniden iletim tanımı yoktur.*

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun ise 3. maddesinde, “yeniden yayın”ı, “yeniden iletim” adı ile “yetkili yayın kuruluşu tarafından kullanılan teknik araç ne olursa olsun, halkın izlemesi amacıyla yayınlanan radyo ve televizyon program hizmetlerinin değişiklik yapılmaksızın bütününe veya bir bölümünün alınması ve aynı anda veya daha sonra iletilmesi” olarak tanımlamıştır.

Görüldüğü gibi yeniden yayın, alınan yayının aynı anda veya daha sonra yapılmasını da kapsar biçimde tanımlanmaktadır.

27 Eylül 1993 tarihli “Uydu Yayınları ve Kablo ile Yeniden İletime Uygulanan Telif Hakları ve Telif Haklarına İlişkin Belirli Kuralların Koordinasyonu Hakkında Konsey Direktifi”nin giriş kısmında; “Sınır ötesi uydu yayınları ve programların diğer üye devletlerden kablolu yayınlarla tekrar yayınlanması alanlarında bu hedeflere ulaşılması, belli bir ölçüde hukuksal belirsizlik ve telif haklarına ilişkin ulusal kurallar arasındaki bir dizi farklılıktan dolayı engellenmekte olduğundan; bu nedenle hak sahipleri eserlerinin karşılığında ödeme yapılmaksızın yayınlanması tehdidi ile karşı karşıya bulunduğu ve çeşitli üye devletlerdeki münhasır lisans sahipleri bu haklardan yararlanılmasını engellediğinden; özellikle hukuksal belirsizlik programların topluluk içinde serbest dolaşımını doğrudan doğruya engellediğinden” ve “uydu ile kesintisiz ve serbest sınır ötesi yayıncılığın ve diğer üye devletlerden yayınlanan programların eş zamanlı ve değişikliğe uğratılmamış olarak kablo yolu ile yeniden iletiminin ilke olarak sözleşmesel bir çerçeve içinde kurulmasını sağlayacak asgari kuralların konulması gerekli olduğundan” yeniden iletim hakkı açısından, üye devletlerin ulusal mevzuatlarında gereken düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile ile elde eden kuruluşların yayın lisans izni iptal edilir.

Uyarı cezasını gerektiren haller dışındaki ihlallerde ilgili tarafın savunması alınır.

Cezaların uygulanış usulleri ile gerekçeli olarak kamuoyuna duyuruş şekli yönetmelikle belirlenir.”

Bu Direktifte her ne kadar yeniden iletim tek başına ele alınmamışsa da kablo ile yeniden iletim düzenlenmiş olup, normal yeniden iletim için kıyasen kablo ile yeniden iletim hükümlerinden yararlanılabilir. Nitekim Direktifte “kablo ile yeniden iletim”; “...bir başka üye devlette kamuya iletilmek amacıyla kablo ile veya uydu da dahil olmak üzere kablosuz yoldan ilk kez yayınlanan televizyon ya da radyo programlarının, kablo ya da mikro dalga sistemi ile değişiklik ve kesintiye uğratılmaksızın, eşzamanlı olarak yeniden iletilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.

Yine bu Direktifin 8’inci maddesinde üye devletlere kablo ile yeniden iletim hakkı konusunda şu yükümlülükler verilmiştir: “*üye devletler, başka bir üye devletteki yayınların kendi bölgelerinde kablolu yayında yeniden iletilmesi hallerinde, telif hakları ve bağlantılı haklara ilişkin kurallara uyulmasını ve yeniden iletimin telif hakkı ve komşu bağlantılı hak sahipleri ile kablo operatörleri arasında toplu ya da bireysel sözleşmelere dayanmasını sağlayacaklardır.*”

FSEK madde 80/1 no’lu fıkrası A bendine göre; “bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan **icracı sanatçı**, bu icranın ... işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve **yeniden iletimine ... izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidir**”.

FSEK madde 43/2’ye göre: “*Bu kuruluşlar (radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkanlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar⁷²) sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52’nci maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram, ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadırlar...*”.

Uluslararası ve ulusal düzenlemelerde görüldüğü gibi; yeniden yayın için icracı sanatçıdan izin alınması gereklidir. Fakat FSEK madde 43 düzenlemesine göre; yayıncı kuruluşlar 80. maddedeki izni tek tek icracı

⁷² FSEK 43/1 maddesini yazmadığımız için bu açıklama gerekmiştir. FSEK madde 43/1: “Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin almak zorundadırlar”.

sanatçılardan değil, onların meslek birliklerinden alacak ve gerekli ödemeleri buraya yapacaklardır. Meslek birliklerine üye olmayan icracı sanatçıların bu düzenlemede unutulması konusundaki eleştirilerimiz için bir önceki “Yayın” bölümüne bakabilirsiniz.

FSEK yine 80. maddede film yapımcılarının haklarını düzenleyen maddeden sonra *“Fonogramlara tespit edilmiş icraların ve filmlerin, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanı sıra, icracı sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlüdürler”* düzenlemesi getirilmiştir.

İcracı sanatçıların, üzerinde hak sahibi bulunduğu icralarının işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yeniden yayınlanmasına izin vermek hususunda FSEK 80. maddesinde yetkilendirilmiş olması, icracı sanatçıların ihtiyati tedbir, ceza ve tazminat davaları gibi FSEK’ten doğan tüm dava ve şikayet haklarını kullanmaları için yeterlidir. Bu davaların yanı sıra icracı sanatçılar özel radyo ve televizyon kuruluşlarının idari olarak uyarılması ve cezalandırılması için Radyo Televizyon Üst Kuruluna da 3984 sayılı Kanun gereğince başvurabilirler. 3984 sayılı *Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun* yayın ilkeleri ile ilgili 4. maddesinin “o” bendinde; *“yayınlarda eser ve bağlantılı hak sahiplerine 5846 sayılı FSEK ile tanınan hakların ihlal edilmemesi”*ni radyo ve televizyonlar için bir yükümlülük olarak koymuştur. Kanun 37. maddesinde de; *“Radyo-Televizyon kuruluşlarıncı yayınlanan ve/veya iletilen eser, fonogram ve yapımları kullanabilmek için, eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri veya bu kişilerin üyesi oldukları meslek birlikleri ile izin almak üzere sözleşme yaparlar ve bu sözleşme ile belirlenen mali hak bedellerini öderler . Bu sözleşme ve ödemeler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır. Bu madde hükümlerini ihlal eden yayın kuruluşları hakkında ayrıca bu Kanunu’nun 33 üncü madde hükümleri uygulanır”* diyerek, Kanuna uyulmaması halinde RTÜK’ün; yayın kuruluşlarına uyarı, program durdurma, para cezaları ve sonunda yayın izninin iptaline kadar varan cezalar verebileceğini belirtmektedir⁷³.

⁷³ Bkz. Geride dipnot 71.

Kamunun Erişimine Sunma⁷⁴

Günümüzde yeni teknolojik gelişmeler paralelinde yeni eser kullanım türleri ortaya çıkmıştır. 1920’li yıllarda radyo yayını ortaya çıktığı an, nasıl bu yayın açısından eserleri ve sahiplerinin haklarını koruma için özel birtakım kurallar gerekmişse, sonra televizyon yayıncılığı için, daha sonra da elektronik ya da digital yayıncılık için eser ve bağlantılı sahiplerinin haklarının korunması açısından yeni kurallar gerekmiştir. Fikir ve sanat eserlerine yönelik olarak en yeni kurallar; “kamuya erişim hakkı” adı verilen digital yararlanmalar alanında ortaya çıkmıştır. Önce uluslararası sözleşmeler ve AB direktiflerine konulan bu kurallar daha sonra ülkelerin iç hukuk düzenlemelerine konu olmuştur. “Kamunun erişimine sunma hakkı”, özellikle web yayıncılığı, cep telefonları ve bilgisayar ağ ortamlarında (internet); dinleme, aktarma, kopyalama, true tone, fulltrack, ring back tone, streaming, video izleme, video tone şekillerinde müzik eserlerinin kullanılması sebebiyle fikirsal ve sanatsal hak sahiplerini korumak amacıyla getirilmiştir. Kamunun erişimine sunma alanındaki kurallar, p2p adı verilen dosya paylaşım sistemleri yoluyla müzik eserlerinin izinsiz kullanılmasının yaygınlaşması ve çok ciddi hak kayıplarına neden olması yüzünden daha da geliştirilmiştir. Yine klasik televizyon ve radyo yayıncılığının değişmesi; dinleyici ve izleyicilerin ne yayınlanırsa onu izlemek yerine, yayınlardaki programları seçebilmeleri, listeleyebilmeleri ve digital recorder aracılığıyla kopyalayabilmeleri ya da internet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarından yararlanabilmeleri karşısında yeni hak koruma düzenlemelerine gereksinim duyulmaktadır. Müzik eserleri ve diğer eser türlerinden bu yeni yararlanma biçimleri hukuk uygulamasına “kamuya erişim hakkı” kavramının girmesine ve yeni eser kullanım biçimlerinin bu kural aracılığıyla düzenlenmesine neden olmuştur.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 10. maddesi “Umuma İletim Hakkı” başlığı altında “kamunun erişimine sunma hakkı”nı; “**gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim sağlayabilecekleri şekilde, icracılar, fonogramlarda tespit edilmiş icralarının aslı ya da çoğaltılmış nüshalarını telli veya telsiz araçlarla topluma iletilmesine münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır**” şeklinde hüküm altına almıştır.

⁷⁴ Bu hakkın İngilizcedeki karşılığı “right of making available to the public” olduğu için Türkçe karşılığı olan “kamunun erişimine sunma” ifadesini tercih ediyoruz.

“Bilgi Toplumunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara İlişkin Belli Konuların Uyumlaştırılmasına Yönelik Direktif”’in giriş kısmında fikir ve sanat eserlerinin bu yeni kullanım biçimlerinin yer aldığı “kamunun erişimine sunma hakkı”na ilişkin düzenlemelerin gerekçeleri şu şekilde aktarılmıştır.

“-Teknolojik gelişme, yaratım ve üretim, işletmenin bileşenlerini artırıp çeşitlendireceğinden, fikri mülkiyetin korunmasında yeni kavramlara ihtiyaç duyulmamakla birlikte, şu andaki telif hakları ve bağlantılı haklar ile ilgili mer’i hukukun, yeni işletme biçimleri gibi ekonomik gerçeklere yeterli karşılık olabilmesi için uyarlanması ve tamamlanması gerektiğinden,

- Özellikle dijital ortamdan sadır olan gereklilikler ışığında, meslek birliklerinin rekabet kurallarına uymaları konusunda yüksek seviyede bir açıklık ve gerçekliği temin etmeleri gerekli olduğundan;

- Ağlar üzerinden telif haklı eserlerin ve bağlantılı haklar tarafından korunan konuların talep üzerine aktarım işlemlerinin koruma seviyesi ve doğası ile ilgili yasal belirsizliğin Topluluk seviyesinde uyumlaştırılmış bir koruma sağlanarak üstesinden gelinmesi gerektiğinden; bu Direktif tarafından tanınan tüm hak sahiplerinin, telif haklı eserlerini ve diğer her türlü istek üzerine etkileşimli aktarım konuların halka sunulması hakkına münhasıran sahip olmalarının açıkça ortaya konması gerektiğinden; böyle etkileşimli istek üzerine aktarımlar, halk tarafından kişisel olarak seçilen bir zamanda ve kişisel olarak seçilen bir yerden bu aktarımlara ulaşabilme olanağı olarak karakterize edildiğinden;

- Teknolojik gelişme, özellikle ağlarda eserlerin dağıtılmasını kolaylaştıracağından ve bu, hak sahipleri için, eserlerin, diğer konuların, eser sahiplerinin veya diğer hak sahiplerinin belirlemesinde ve hakların yönetimini daha kolaylaştırmak için eserlerin ve diğer konuların kullanımının şartları ve koşulları hakkında bilgi elde etmek ihtiyacına sebep olacağından; hak sahiplerinin, yukarıdaki söz edilen bilgiye ek olarak, eserler ve diğer konular bilgisayar ağlarına konulduğunda, diğerlerinin yanı sıra öncelikle hak sahiplerinin iznini belirtici işaretler kullanmaya teşvik edilmeleri gerektiğinden;”

Aynı Direktifin 3. 2 no’lu maddesinde “kamuya erişim hakkı” şu şekilde hüküm altına alınmıştır.

“Üye devletler, tel üzerinden veya telsiz vasıtalarla eserlerini yayımlama, böyle bir yolla kamuya bireylerin tercih ettikleri bir zamanda ve bir yerden erişebilme münhasır haklarını

(a) icracı sanatçılar , kendi icralarının düzenlemesi;

- (b) fonogram üreticileri , kendi fonogramları;
 (c) filmleri düzenleyen ilk üreticiler, kendi orijinal filmleri ve kopyaları;
 (d) yayın kuruluşları, kendi yayınlarını kablo veya uydu yayını da dahil olmak üzere, kablo üzerinden veya karasal üzerinde iletip iletmeme düzenlemesi;
 için korur”.

Uluslararası bu düzenlemelere uygun olarak FSEK madde 80/1 no’lu fıkrasında A-4 bendi; “İcracı sanatçı, tespit edilmiş icrasının veya çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda icrasına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. Umuma iletim yoluyla, icraların dağıtım ve sunulması icracı sanatçının yayma hakkını ihlal etmez” düzenlemesini yapmıştır.

FSEK yine 80. maddede film yapımcılarının haklarını düzenleyen maddeden sonra “Fonogramlara tespit edilmiş icraların ve filmlerin, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanı sıra, icracı sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlüdürler” düzenlemesi getirilmiştir.

Eğer bu hakka ilişkin yararlanma talebe bağlı hizmet şeklinde radyo ve televizyon yayıncısı şirketler tarafından yapılacaksa o zaman ek olarak 43. maddesinin “Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları ... sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52 nci maddede uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadırlar” kuralı da devreye girecektir.

FSEK madde 80’nin açıkladığımız düzenlemesi karşısında; cep telefonlarında, web sitelerinde, dosya paylaşım sistemlerinde, seçmeli yayınların seçildiği ve kopyalandığı bilgisayar veya yayın ortamlarında müzik eserlerinden faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşların ya da bunları işleten ve kamunun erişimine sunan kişi ve kuruluşların icracı sanatçılardan veya onların meslek birliklerinden izin alarak sözleşme yapması

ve bir bedel ödemesi gerekmektedir. Eğer bu haklar icracı sanatçılar tarafından fonogram yapımcılarına veya başka kişilere devredilmişse o zaman da icracı sanatçılar yerine fonogram yapımcılarından veya başka kişilerden bu yönde izin alınması gereklidir.

FSEK'e 2004 yılında eklenen Ek madde 4 hükmü ile; müzik eserlerini yasalara aykırı ve izinsiz olarak kullanıcılara ulaştıran web sitelerine ve kişisel sayfalara kullanıcıların erişimi engellenebilmektedir. Bu düzenleme şöyledir.

“Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâlê konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlê durdurulmasını ister. İhlâlê devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan (Türk Telekom ve diğer internet servisi sağlayanlardan) ihlâlê devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlê durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

3. İcracı Sanatçıların Haklarına İlişkin Ortak Hükümler

İcracı sanatçıların bir eseri icra edebilmesi için eser sahibinden veya sahiplerinden “**izin**” alması gerekmektedir. FSEK 80. maddede yer alan izin; “*eser sahibinin izni ile*” denilerek vurgulanmıştır. Bizim görüşümüze göre; FSEK madde 80’de yer alan, icracı sanatçının eser sahibinden eseri seslendirme, okuma veya yorumlama için almış olduğu “izin”; mali hakların başkalarınınca kullanılması olanağı veren “devir” veya “ruhsat” kapsamı içinde değildir. Bu hak alımı, alan kişi açısından “devir”e benzeyen hükümler taşıyan mutlak hak niteliğinde özel bir hukuki durumdur. “İzin” ile; icracı sanatçı icrasını ve fonogram yapımcısı fonogramını oluşturmaktadır. Bu oluşumlar sonucunda; icracı sanatçı veya fonogram yapımcısının elinde bulunan yapımlar açısından; bunlara

izin verenlerin dahi dokunamayacağı komşu haklar niteliğinde bağımsız ve müdahale edilemeyecek yeni haklar oluşturulmaktadır.

İcracı sanatçı, eser sahibinden “*eserimin ...(icracı) tarafından icrasına izin veriyorum*” şeklinde bir izin aldığında, kendisi bu eseri her yerde icra edebilecektir. İcracı sanatçı bu şekilde bir izin ile kendi icraları üzerinde mutlak bir hak sahipliğine ulaşmış olur. Eser sahibi çıkıp da, bir yapımcıya “*ben eserimin ... tarafından icra edilmiş versiyonunun çoğaltılma ve yayma hakkını veriyorum*” dese de fonogram yapımcısının ek olarak icracı sanatçıdan da izin alması gerekir. Böyle bir izin verme hakkı; eser açısından eser sahibinde olmakla beraber, o eserin şarkıcı/yorumcu tarafından icra edilmiş hali açısından icracı sanatçıdadır. Görüldüğü gibi icra edilmiş versiyona –devretmediği haklarla ilgili konular hariç- eser sahibi karışamaz. Ama pratik uygulaması açısından mesela radyoda yayını için sadece icracı sanatçıdan izin alınması yukarıdaki izin metni düşünüldüğünde yeterli olmaz (çünkü icranın yayını için icracıya yetki verilmemiştir), ek olarak eser sahibinden de izin almak ve eğer icra bir fonograma kaydedilmişse fonogram yapımcısından da izin almak gerekir.

TEKİNALP, izin üzerine gerçekleştirilen icra ile icracı sanatçının bağlantılı hakları ipso jure edineceğini, eser sahibinin ayrıca izin vermesine gerek olmadığını belirtmiş ve sonra eser sahibinin, mali haklardan bazılarını icracı sanatçının iktisap etmesini istemiyorsa, iznini söz konusu hakları istisna edecek şekilde vermesi gerektiğini ifade etmiştir⁷⁵. EREL ise, “..eser sahibi hangi icracıya temsil yetkisi vermiş olursa olsun, eserin tespitine, umumi yerlerde temsil ve icrasına, ayrıca icracı uygun görüyorsa radyo-televizyonla yayınına da *ipso jure* izin vermiş olacaktır⁷⁶,” demek suretiyle görüşünü ifade etmiştir. Doktrindeki karşı görüş sahibi olan ÜSTÜN, icracı sanatçının, bağlantılı hak kazanabilmesi için sadece icraya ilişkin izin almasının yeterli olmadığını, bunun için eser sahibinin tüm haklarına ilişkin izin vermesi; yani o sanatçının icrasına ilişkin tüm haklarını devretmesi ya da bu haklara ilişkin ruhsat vermesi gerektiği yönündedir⁷⁷. ARKAN ve AYDINCIK da FSEK

⁷⁵ Bkz. TEKİNALP, *age.*, B.17.N.21 s. 278

⁷⁶ EREL, *age.*, s. 170 ve 176

⁷⁷ Gürsel ÜSTÜN, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda 4630 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler ve Eleştirilerimiz”, İBD, 2001, C.75, s. 1

52'deki hakların ayrı ayrı devri zorunluluğu sebebine dayanarak TEKİNALP ve EREL'in görüşlerine katılmamaktadır⁷⁸.

Bizim görüşümüze göre, FSEK 52 hükmü genel bir hükümdür ve buna dayanarak icracı sanatçıların eser sahiplerinden açıkça hangi mali hakkı kullanmak istiyorsa o hakka ilişkin mali hakların tek tek sayıldığı izinler alması gerekmektedir. Örneğin, *“eserimin ... (ircacı) tarafından icrasına ve bu icranın icracı tarafından çoğaltılmasına ve umuma iletilmesine ilişkin haklar için ve bu hakların icracı tarafından 3. kişilere devredilmesi de dahil olmak üzere 2 yıl süre ile sadece Türkiye sınırları içinde lisans verdim”* gibi. Yoksa, icracı sanatçı sadece *“eserimin ... kişi tarafından icra edilmesine izin verdim”* şeklinde bir izin sahibi ise, bu icrasının ne çoğaltma hakkına ve ne de umuma iletim hakkına sahip değildir ve kendi icraları üzerinde bile (eser sahibinden ek izin alınmadan) böyle bir hakkı yapımcıya veya yayıncıya tanıyamaz. Eğer icracı, bu haklara sahip olmak istiyorsa yine gidip eser sahibinden ek bir sözleşme yaparak bu haklar hakkında lisans alacak yahut yapımcı veya radyo televizyon yayıncısı ile yanına eser sahibini de alıp birlikte bir sözleşme imzalayacaktır. Eğer eser sahibi, eser üzerindeki veya sadece icracı sanatçının yorumu üzerindeki mali hakları icracı sanatçıya toptan devir etmişse o zaman “devir” hükümleri gereğince icracı sanatçı bu mutlak hakkı dilediği gibi kullanabilir. Eser üzerindeki veya sadece icracı sanatçının yorumu üzerindeki devir konusu bu hak artık eser sahibinin malvarlığından çıkıp icracı sanatçıya geçmiş olur. Öte yandan eser sahibi çeşitli açılardan sınırlanmış biçimde *“eserimin ... tarafından icrasına ve bu icranın ... tarafından çoğaltılmasına ve umuma iletilmesine ilişkin haklar için ve bu hakların .. tarafından 3. kişilere devredilmesi de dahil olmak üzere 2 yıl süre ile sadece Türkiye sınırları içinde lisans verdim”* gibi lisans verme şeklinde bir izin vermişse o zaman lisans anlaşması doğrultusunda icracı sanatçı bu haklarını kullanabilir. Bu konuda “Mali Hakların Devri” bölümünde daha geniş açıklamaları bulabilirsiniz.

Bu izinler FSEK 80. madde gereğince yazılı olmak zorundadır ve yazılı olma bu iznin sıhhat şartıdır.

Eser sahibi müzik eserlerinde söz ve bestenin kendisine ait olması halinde tek başına izin verebilir. Eğer söz bir kişiye ve müzik başka kişiye aitse, bu durumda icracı sanatçı her iki eser sahibinden ayrı ayrı izin

⁷⁸ ARKAN, age., s. 57 vd. ve Şirin AYDINCIK, *Fikri Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri*, İstanbul, 2006, s. 137 vd.

almak durumundadır. Eser birden fazla icracı tarafından icra edilecekse icracıların her biri için eser sahibinden yazılı izin gerekir.

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre; bir sanat eseri birden fazla icracı sanatçı tarafından icra ediliyorsa ve ortaya çıkan eser de kısımlara ayrılabilirse, bu sanatçılardan her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır. Şayet icra edilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, bu yapının sahibi onu vücuda getirenlerin birliğidir. Ortaya çıkan ortak yapım ile ilgili tüm hakların kullanımında hak sahipleri birbirlerinin haklarına öncelikle uymak zorundadırlar. İracı sanatçılar hakların korunmasında ortak hareket edebilirler ya da içlerinden birisine yetki verebilirler. İracı sanatçılardan biri, birlikte yapılacak bir işleme haklı bir sebep olmaksızın izin vermezse, bu izin mahkeme tarafından verilebilir. İracı sanatçılardan her biri birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket ederek yasal yollara başvurabilir.

İcra; bir orkestra, koro veya tiyatro grubu tarafından yapılmışsa FSEK madde 80/A-6 gereğince artık münferit sanatçılardan değil, sadece o topluluğun *şefinden* izin alınması yeterli olacaktır. Müzik gruplarının icra ettiği şarkılar için de bu kural uygulanır. Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 9. maddesinde⁷⁹ de benzer düzenleme vardır. Şayet sanatçı grubu bir müteşebbis (girişimci/organizatör) tarafından çalıştırılıyorsa, şeften başka girişimci/organizatörün de FSEK madde 80/A-7 gereğince izninin alınması gerekir. Özellikle konser düzenleyen organizatörlerin konserde çalınan şarkıların yayını ve çoğaltılması konusunda bu madde doğrultusunda izninin alınması gereklidir. Tabii ki yayın ve çoğaltma için ek olarak icracı sanatçı ve diğer hak sahiplerinin izni de gereklidir. Şefin ve keza girişimcinin/organizatörün izin verme yetkisi doğrudan Kanun'dan doğmaktadır ve kesindir. İracı sanatçılar topluluğuna dahil olan sanatçılar kural olarak buna karşı koyamazlar.⁸⁰ Ancak icranın tespit veya yayını kendi manevi haklarına bir tecavüz teşkil ediyorsa, o takdirde FSEK madde 14, 70 ve 80/son fıkralar gereğince kendilerine bu tespit ve yayını men edebilme ve tazminat iste-

⁷⁹ *Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği* madde 9: Koro, orkestra ve sahne eserlerinin icrasını tespit etme, bu tespiti çoğaltma, kiralama, icranın telli-telsiz her türlü araçla yayınlanması ya da temsili suretiyle faydalanma hakkının devrinde yalnız şefin izni yeterlidir.

⁸⁰ Aksi fikir ARSLANLI, age., s. 51 dipnot 3.

yebilme yetkisi tanınmıştır.⁸¹ Eğer eser sahipleri ortak veya birlikte eser sahibi iseler bu durumda da devreye FSEK 9. ve 10. maddeler girmektedir. Bu konuda daha geniş bilgi için “Eser Sahipliği” bölümüne bakabilirsiniz.

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; bir icracı sanatçı ile yapımcı arasında yapılan sözleşmeyle çoğaltma, kiralama, icranın telli ve telsiz her türlü araçla yayınlanması ya da temsili yolu ile faydalanma hakkı uygun bir bedel karşılığında yapımcıya devredilmişse, artık icracı/yorumcu sanatçıların yazılı izni aranmaz. Ancak, bu haklardan belli bir kısmının yapımcıya devredilmesi halinde, devredilmeyen kısma ilişkin hakların kullanımı söz konusu olduğunda bunlar için icracı sanatçılarla eser sahibinin yazılı izninin alınması gereklidir. İracı sanatçıların icralarını iş ve hizmetten doğan sorumluluklarından dolayı yapmaları ve yapılan bu icra sonunda elde edilen tespitin, iş ve hizmet kapsamı dışında kullanılmak istenmesi halinde, bu kullanımın şartları işveren ya da iş sahibiyle icracı sanatçılar arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Burada ek olarak, eser sahiplerinin meslek birliği tarafından da bu izinlerin verilebildiğini belirtelim. Ancak meslek birlikleri aldıkları yetki belgesine göre hareket ettiğinden hangi hak elde edilmek isteniyorsa bu hakka ilişkin meslek birliğinin yetkili olup olmadığının incelenmesi gerekir.

Eğer verilen iznin kapsamı “devir” hükümlerine uyuyorsa FSEK madde 58’de bulunan cayma hakkının, “izin” hak alımı için kullanımı zordur. Eğer lisans şeklinde bir sözleşme gereğince izin alınmışsa, eser sahibinin verdiği izine karşılık cayma hakkını kullanabilmesi olanaklıdır.

FSEK madde 80/bent 4 fıkra IV’e göre icracı sanatçılar, eser sahipleri gibi tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i ve tazminat davası haklarından faydalanabileceklerdir. Ayrıca sanatçının yazılı izni olmaksızın icra üzerindeki haklarına tecavüz edenler hakkında hapis ve para cezasına hükmolunacaktır.

İracı sanatçıların haklarının hangi süreyle korunacağı hususunda 4110 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce Fikir ve sanat Eserleri Kanunu’nda bir hüküm mevcut değildi. Bu durumda doktrinde sanatçıya tanınacak korumanın kapsam ve içerik olarak eser sahibinin korunmasından daha dar olması gerektiği düşüncesiyle, koruma süresinin asıl

⁸¹ AYİTER, age., s. 79.

esere tanınan süreyi aşamayacağı öne sürülmüştü.⁸² Ancak 4110 sayılı Kanunla FSEK madde 82 hükmünde yapılan değişiklik sonucu, icracı sanatçıların haklarının *icranın tespiti*nin ilk yayınlandığı tarihten başlayarak 70 yıl süreyle korunacağı, *icra*⁸³ yayınlanmamışsa bu sürenin *icranın ilk aleniyet kazanmasıyla başlayacağı* kabul edilmiştir. Bu şekilde doktrinde genellikle benimsenen ilkeye aykırı olarak, asıl eser için koruma süreleri dolmuş olsa bile icra daha uzunca bir müddet korunacaktır.⁸⁴

EREL'e göre; Kanundaki koruma süresine ilişkin bu hüküm için açıklama gereklidir. Öncelikle icra tespit edilmiş değilse, mesela bir müzik eseri konserde canlı olarak çalınmış, fakat ses kaydı yapılmamışsa, bunun aleniyet kazanmasından sonra daha 70 yıl müddetle korunması anlamsızdır. Tesbit edilmiş bir icra ise yayınlanmadığı sürece zaten aleniyet kazanamayacağına göre, hükmün ikinci cümlesi de EREL'e göre anlamsız bir tekrardan ibaret kalmaktadır.⁸⁵

İcracı sanatçının FSEK madde 80/II gereğince, icrası üzerindeki mali haklarını sözleşmeyle yapımcılara devir edebileceğini belirtmiştik. Ancak Kanunda bu hakların “münhasıran sanatçıya ait olduğu” açıkça hükme bağlandığından, miras yoluyla intikal bakımından nasıl bir sonuca varılması gerektiği şüphe uyandırmaktadır. AYİTER, Kanun'da icranın ancak icracının rızası ile çoğaltılıp yayınlanabileceği söylendiğine göre, icra üzerindeki hakkın da sanatçının ölümü ile sona ereceği, mirasçılara intikal etmeyeceği görüşündedir.⁸⁶ EREL'e göre bu hususta bir ayırım yapılmalıdır. Şayet sanatçı hayatta iken sadece icrasının tespiti için izin vermiş, fakat bu tespitin çoğaltma ve yayınına izin vermemişse, ölümünden sonra bu hakların mirasçıları tarafından kullanılmaması gerekir; zira icranın sanatçının kişiliğine bağlı olan manevi yönü buna engeldir. Halbuki sanatçı sağlığında icranın tespitinden başka çoğaltma ve yayınına da izin vermişse, artık bir malvarlığı değerine dönüşmüş olan bu hakkın mirasçılar tarafından kullanılmasına engel yoktur. İcra üzerindeki manevi haklar ise, niteliklerine uygun olarak sanatçının hayatı bo-

⁸² ARSLANLI, age., s. 51; AYİTER, age., s. 80

⁸³ Kanundaki “icra” deyiimi “tespit” olarak anlaşılmalıdır.

⁸⁴ EREL, age., s. 172

⁸⁵ EREL, age., s. 172

⁸⁶ AYİTER, age., s. 80

yunca devam ederler. EREL, FSEK madde 19 hükmünün kıyas yoluyla burada uygulanabileceği kanısındadır.⁸⁷

İcracı sanatçıların hakları, diğer komşu hak sahipleriyle birlikte uluslararası sözleşmeler ve FSEK tarafından sınırlanmıştır. Bu sınırlamaların sonucu; aşağıda sıralanan hallerde sanatçının icrası onun yazılı izni olmaksızın kullanılabilir.

Roma Sözleşmesi'nin 15. maddesine göre;

"1- Her Akit Devlet, işbu Sözleşme ile teminat altına alınan koruma hükümlerine aşağıdaki hallerde kendi ulusal mevzuatıyla istisnalar öngörebilir:

- a) Özel kullanım;*
- b) Güncel olayların bildirimi ile ilgili olarak küçük alıntılarının kullanılması;*
- c) Bir yayın kuruluşu tarafından kendi araçları ile ve kendi yayınları için geçici bir tespit yapılması;*
- d) Münhasıran eğitim veya bilimsel araştırmalar amacıyla kullanılması.*

2- Birinci paragrafın hükümleri mahfuz kalmak üzere, her Akit Devlet, icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve yayın kuruluşlarının korunması konusunda, kendi ulusal mevzuatında, edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki telif hakkının korunmasına ilişkin sınırlamalara benzer nitelikte sınırlamalar öngörmek imkanına sahiptir. Bununla beraber, zorunlu ruhsatlar ancak işbu Sözleşme hükümlerine uygun bulunduğu oranda öngörülebilir".

FSEK madde 80/IV hükmüne göre ise:

"1.Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veya röportaj amacıyla ve kazanç amacı güdülmeksizin icra edilmesi ve kamuya arzı gerekiyorsa,

2.İcra, fikir ve sanat eserleriyle radyo-televizyon programlarının yayınlanma ve kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması için kullanılacaksa,

3.İcra, radyo-televizyon kuruluşlarının kendi olanaklarıyla, kendi yayınları için yaptıkları geçici tespitlerde kullanılacaksa,

4. İcra, FSEK madde 30 kapsamında eser üzerindeki hakkın veya eser sahipliğinin ispatı maksadıyla mahkeme ve diğer resmi makamlar huzurunda yahut zabita ve ceza işlerinde bir muameleye konu teşkil etmek üzere kullanılacaksa; FSEK madde 32 kapsamında (bu hükmün

⁸⁷ Bkz. EREL, age., § 6, B, II.

müzik eserleri açısından pek bir uygulaması yoktur) kullanılacaksa; *FSEK madde 34 kapsamında eğitim-öğretim için seçme ve toplama eserle meydana getirilmesinde icradan iktibas yoluyla istifade edilecekse; FSEK madde 35 kapsamında asıl eserden iktibas yapılmasının caiz olduğu hallerde, icra yine bu amaçla kullanılacaksa; FSEK madde 43 (bu hüküm FSEK 43. maddesinin eski halinde; müzik yapıtlarından kısa parçalar alınması ve TRT'nin yurt dışına kısa dalga yayınlarına ilişkin ama şimdi 43. madde olduğu gibi değiştiğinden bu istisna zımnen ortadan kalkmıştır-inşallah birileri farkına varır ve bunu değiştirir) için kullanılacaksa; FSEK madde 46 kapsamında devletin eserden faydalanma yetkisinin bulunduğu hallerde, kamu kurum ve kuruluşların zilyedliğinde bulunup da, icracı sanatçı tarafından çoğaltma ve yayımı açıkça men edilmemiş olan tespitlerden söz konusuysa ve nihayet FSEK madde 47 kapsamında eserin aslının kamuya maledilmesi için gerekli şartlar, tespit edilmiş bir icra için de mevcutsa;*

icra, sanatçıdan izin alınmasına gerek kalmadan kullanılabilir.”.

Kanun bu düzenlemede, icracı sanatçıdan izin alınmadan icralarının kullanılmasına olanak veren sayılan istisnai durumların, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremeyeceğini ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamayacağını belirtmektedir.

Bu kısımda son olarak Eser Sahiplerine Komşu Haklar Yönetmeliğinin bir başka garip ve hukuka aykırı düzenlemesine değinelim.

Yönetmeliğin 14. maddesi Kanun'un 80. maddesine tamamen aykırı bir düzenleme içermektedir. 1997 yılında 14. madde ile “*İcracı bir sanatçının icrasının tespit edildiği ses taşıyıcısı, herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kamuya arz edildiği takdirde, ses taşıyıcısı yapımıcısı icracı sanatçıdan elde edilen gelirin bir bölümünü genel hükümler çerçevesinde talep edebilir.*” şeklinde getirilen bu hüküm, 2001 yılında FSEK 80. maddesi ile, icracı sanatçılar ve fonogram yapımıcılarına ticari gelir elde ettikleri temsil hakkı, yayın hakkı ve umuma iletim hakları için izin verme ve yasaklama hakkı verilmesi ve buna bağlı her bir grup hak sahibine ayrı ayrı telif hakları tahsil olanağı tanınması ile uygulanamaz hale gelmiştir. Tabii ki bir Yönetmelik hükmü, “normlar hiyerarşisi” kuralına göre, üstünde olan Kanun düzenlemesine aykırı olamaz. Bu yüzden hiçbir akıl kişi veya mahkeme tarafından bu Yönetmelik maddesi uygulanamaz. 2001 yılında FSEK madde 80 değişikliği paralelinde 14. maddenin değiştirilmeden, Yönetmelikte unutulmuş olması önemli

bir ihmaldir. Umarız kısa bir zamanda bu ihmal ortadan kaldırılır ve Yönetmelik değişir.

B. FONOGRAM YAPIMCILARININ HAKLARI

Fonogram yapımcısı veya müzik yapımcısı; müzik eserleri alanındaki tüm kişileri organize ederek, müzik eserlerini plak, kaset, cd gibi sabit ortamlara veya bilgisayar diski gibi digital ortamlara kaydederek bu kayıtlardan oluşan ürünlerin pazarlama faaliyetlerini organize eden kişi veya kuruluşlardır. Müzik eseri yaratıcılarına ve şarkıları yorumlayanlara çalışmalarını sürdürebilmeleri için maddi olanaklar yaratan fonogram yapımcıları müzik sektörünün göbeğinde yeralan aktörlerdir. Özellikle sektörün maddi gelirlerini toplayarak müzik sektöründe çalışanların bir tür para dağıtıcısı olan yapımcılar, diğer hak sahiplerinin çalışmalarından daha fazla ekonomik getiri elde etmesine öncülük etmektedir. Ekonomik yaşamın diğer aktörleriyle yakın ilişkide bulunan müzik yapımcıları, müzik eserleri ve ürünlerinden gelir elde edilmesi için tüm sektörlerle işbirlikleri ve ortaklıklar yapmaktadırlar. Gerek müzik yapımlarının ortaya çıkmasından önce sponsorluk ilişkileri ve gerekse müzik yapımları ortaya çıktıktan sonraki reklam ve pazarlama faaliyetleri ile diğer mal ve hizmet sektörleri ile ilişkide bulunan bu kişiler doğaldır ki, bu faaliyetleri sebebiyle müzik eserlerinde hak sahiplerinden biri olarak 1960’lardan bu yana yasal korumadan yararlanabilmektedirler.

Fonogram yapımcısı ibaresinde yer alan “fonogram” terimi, günlük yaşamda müzik kayıtlarını içeren ortamları ifade etmekte olup, yaklaşık 130 yıllık bir tarihçeye sahiptir.

Thomas Edison’un 1877 yılında kalay kağıdı üzerine ilk ses tespiti sonucu ortaya çıkan fonogram; 1887 yılında Emile Berliner’in ilk plağın patentini alması ve sonra Thomas Edison’un gramofonu icat etmesiyle birlikte ticari anlamda gelir getiren bir ürün olmuştur. Özellikle 1925 yılından itibaren kayıt için elektriğin kullanımı ile birlikte ticari anlamda yaygınlaşan çalışmalar, 1948 yılında Columbia şirketinin 33 devirli plakları üretmesiyle birlikte eğlence yaşamını müzik topluluklarının canlı olarak çaldığı bar ve gece klüplerinden evlere kadar taşımıştır. 1960’larda müzik kasetleri, 80’lerde cd ile kitlelere ulaşan müzik ürünleri, günümüzde müzik çalan pikap, teyp ve radyo ve televizyon cihazlarının tek bir sigara paketine sığan aletlere dönüşmesi sonucu, mP3 ve mP4 adı verilen sıkıştırılmış veri yapısı ile içinde bozuk para büyüklüğündeki disklere ve cep telefonlarına kaydedilir hale gelmiştir.

Teknik olarak “**fonogram**”, Roma Anlaşması’nın 3/b maddesinde “**bir icra ürününün veya diğer seslerin münhasıran ses olarak tespiti**” şeklinde tanımlanmıştır. Fonogram; WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 2/b maddesinde ise “sinematografik veya diğer görsel-işitsel eserlerde yapılan bir tespit biçimi dışında kalan, *bir icradaki ses veya diğer seslerin tespiti ya da seslerin temsili*” olarak belirtilmiştir.

Ses tespiti veya ses tespit aracı olarak adlandıracağımız fonogram ifadesinin önemli bir unsuru “tespit”dir. WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 2/c maddesinde “**tespit**”, “**bir araç yoluyla, anlaşılabilen, çoğaltılabilen, iletilebilen, seslerin kaydedilmesi veya sunumu**” olarak tanımlanmıştır.

Türk Hukukunda ise FSEK 1. maddesinde “**fonogram**”, “*sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortam*” olarak ve “**tespit**”, “*seslerin veya ses temsillerinin veya ses ve görüntülerin anlaşılabilir, çoğaltılabilir veya iletilebilecek şekilde bir araca kaydedilmesi işlemi*” olarak tanımlanmışlardır. Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliğinin 4. maddesinde “tespit”, “*seslerin maddi bir araç üzerine herhangi bir yöntemle algılanabilmesini, çoğaltılabilmesini ya da başka bir yoldan kamuya iletilmesini sağlayacak biçimde kaydedilmesi*” ve “fonogram” yerine kullanılan “**ses taşıyıcısı**” kavramı “bir icranın seslerinin ya da elektronik bir yöntemle eserlerin üzerine tespit edildiği her türlü aracı” olarak tanımlanmıştır.

FSEK ilk maddesinde “**fonogram yapımcısı**”, “**bir icradaki seslerin veya diğer seslerin veya diğer ses temsillerinin ilk tespitine ilişkin girişimde bulunan ve sorumluluğu olan gerçek veya tüzel kişi**” ifade etmektedir.

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliğinin 4. maddesinde “fonogram yapımcısı” kavramı yerine “**ses taşıyıcısı yapımcısı**” kavramı kullanılmış ve “*sözlü ya da sözsüz tüm seslerin ilk tespitini yapan, bu durumun hukuksal sorumluluğunu üstlenen gerçek ya da tüzel kişi*” olarak tanımlanmıştır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esas itibariyle fikri yaratıcılığın ürünü olan eseri korur. Bununla birlikte; fikir veya sanat ürününe vücut vermeyen, ancak yine de sarf edilen fikri veya sanatsal emeğin korunma-

sının gerektiği haller mevcuttur.⁸⁸ Özellikle eserin toplumda yaygın şekilde dinlenip seyredilmesini sağlayacak ses ve görüntü tespitlerini veya kayıtlarını yapan yapımcıların haklarının da fikri hukuk tarafından korunması gerektiği uygar dünyada kabul edilmektedir.⁸⁹ Uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği direktifleri benzer gerekçeyle bağlantılı hakların tanınması gereğini çeşitli biçimlerde dile getirmişlerdir.

Avrupa Birliğinde bağlantılı haklara değinen 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı “*Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi*”nin girişinde; yeni yaratıcı sanat eserlerinin oluşturulma temeli olarak, eser sahiplerine ve icracılara ait yaratıcı sanat çalışmalarına yeterli gelir miktarı gerektiğinden; özellikle fonogram ve film yapımı için gereken yatırımlar oldukça yüksek ve riskli olduğundan; bu gelirin korunma olasılığı ve söz konusu yatırımın karşılanmasıyla ilgili hak sahiplerinin yeterli yasal korunmaları ile etkin bir şekilde garanti edilebileceğinden; adı geçen yaratıcı, sanatsal ve girişimcilik gerektiren faaliyetler, büyük ölçüde serbest meslek sahiplerine ait olduğundan; bu nevi faaliyetlerin takibinin Topluluk içerisinde uyumlaştırılmış yasal koruma sağlanarak kolaylaştırılması gerektiğinden; özellikle bağlantılı hak sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik bir Direktifin çıkarıldığı vurgulanmıştır.

22 Mayıs 2001 tarih ve 2001/29/AT sayılı “*Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi*”nde ise; bağlantılı hakların tanınması gerekçeleri şu şekilde sayılmıştır:

“- Bilgi toplumunun çeşitli sosyal, toplumsal ve kültürel etkileri; ürünlerin ve hizmetlerin içeriklerinin özel niteliklerinin dikkate alınmasını gerektirdiğinden; bunların korunmasının eser sahiplerinin, icracı sanatçıların, yapımcıların, tüketicilerin, kültür, endüstri ve en geniş anlamda kamunun menfaatine olarak yaratıcılığın korunması ve geliştirilmesine yardım ettiğinden; bu yüzden fikri mülkiyetin “mülkiyet hakkı”nın ayrılmaz bir parçası olarak tanındığından,

-Yazarlar ve icracı sanatçıların, yaratıcı ve artistik eserlerini sürdürmeleri gerektiğinden, eserlerinin kullanımı açısından yapımcıların da bu eserleri finanse edebilmek için uygun karşılık almaları zorunlu olduğundan; fonogram, film ya da multimedya ürünleri gibi ürünlerin ve

⁸⁸ AYİTER, age., s. 72-89; ARSLANLI, age., s. 49-60

⁸⁹ ERELage., s. 163

erişim hizmetlerinin üretilmesi için gereken yatırım dikkate değer olduğundan; bu yatırımların tatmin edici bir şekilde geri dönüşleri için fırsat temin etmek ve belirtilen karşılıklarını garanti etmek için fikri mülkiyet haklarının yasal olarak yeterli derecede korunması gerekli olduğundan.”

WIPO *İcralar ve Fonogramlar Andlaşması*’nın⁹⁰ girişinde de bu anlaşmaya taraf devletlerin;

-icracı sanatçılar ve fonogram yapımcılarının haklarının mümkün olduğunca etkili ve düzenli olarak korunmasını sürdürmeyi ve geliştirmeyi isteyerek,

-icra ve fonogramların yaratılması ve kullanımına ilişkin iletişim teknolojileri ve haberleşmenin gelişimindeki güçlü etkiyi bilerek,

-icracı sanatçılar ve fonogram yapımcılarının hakları ile, eğitim, araştırma ve bilgiye erişim hakkındaki geniş kamu yararı arasındaki dengeyi koruma gereksinimini bilerek

işbu Anlaşmayı imzaladıkları düzenlenmiştir.

İşte bu gerekçelerle fonogram yapımcılarına tanınan haklar uluslararası sözleşmelerde şu şekilde düzenlenmiştir.

Fonogram yapımcılarına ilk kez hak tanıyan Roma Anlaşması’nın 10. maddesine göre; “*fonogram yapımcıları, kendi fonogramlarının doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılmasına izin verme veya önleme hakkına sahiptir*”. Aynı Anlaşmanın 11. maddesi, “*bir akit devletin ulusal mevzuatı, plak yapımcılarının, icracı sanatçıların veya her ikisinin haklarının koruma şartı olarak bazı formalitelerin yerine getirilmesini öngörmüşse, satışa çıkarılmış olan fonogramın bütün nüshaları veya kapakları (P) işareti ile birlikte, ilk yayım yılını, korumanın mahfuz tutulduğunu açık surette gösterir şekilde taşımaları halinde bu talep yerine getirilmiş addedilir. Ayrıca, bu fonogram nüshaları veya kapakları, fonogram yapımcısını veya yapımcı tarafından kendisine izin verilmiş olan kişinin isim, marka veya başkaca uygun işaretlerle kimliğini tespiti elvermiyorsa, sözü edilen işaret aynı zamanda fonogram yapımcısının haklarını elinde bulunduran kimsenin adını da ihtiva etmelidir*” düzenlemesini getirmektedir.

Yaklaşık 50 yıl önce öncülük yaparak fonogram yapımcılarına haklar tanıyan Roma Anlaşması günümüzde fonogram yapımcısının sahibi olduğu birçok hakkı içermemesine rağmen o dönem için devrimci bir yaklaşım getirmiştir. Roma Anlaşması’nın umuma iletim açısından

⁹⁰ Bu anlaşma TBMM tarafından 02.05.2007 tarihinde 5646 sayılı Kanun ile kabul edilmiştir.

sadece fonogram yapımcılarına bir bedel ödeme zorunluluğu getirdiğini, tespitlerinin kullanılması için onlardan izin alınma zorunluluğunun olmadığını savunan birçok hukukçu tarafından kullanılan 12. maddesi ise; *“Ticari amaçlarla yayımlanmış olan bir fonogram veya bunun çoğaltılmış nüshaları, doğrudan doğruya radyo ve televizyon yayınları veya umuma arz için kullanılmışsa, kullanan tarafından, icracı sanatçılara veya fonogram yapımcılarına veyahut her ikisine bir defaya mahsus olmak üzere makul bir ücret ödenir. Söz edilen ilgililer arasında anlaşma mevcut olmadığı takdirde, bu ücretin taksim şekli ulusal mevzuat ile tayin edilebilir”* düzenlemesine sahiptir.

Uluslararası anlaşmalardan bir başkası da TRIPS Anlaşmasıdır. Bu Anlaşma’nın 14. maddesine göre; *“Plak yapımcıları, plaklarının doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılmasına izin verme ya da önleme olanağından yararlanacaklardır”*.

Fonogram yapımcıları açısından Roma Anlaşması’ndaki birçok eksiği tamamlayan ve onların haklarının bugün uygulandığı şekliyle kabulünü sağlayan uluslararası sözleşme ise *WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması*’dır. Bu Anlaşmanın 11. maddesi fonogram yapımcılarının “çoğaltma hakkı”nı, *“fonogram yapımcıları fonogramların herhangi bir şekil veya yöntemle doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılmasına münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır”* şeklinde düzenlemiştir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 12. maddesi fonogram yapımcılarının “yayma hakkı”nı;

“(1) Fonogram yapımcıları, fonogramlarının aslı veya kopyalarını satış veya başka bir şekilde hak sahipliğini devretmek yoluyla topluma sunulmasına münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

(2) Bu Andlaşmadaki hiçbir hüküm, akit tarafların fonogram yapımcısının izni ile fonogramın aslı veya kopyası üzerinde hak sahipliğinin ilk satışı ya da başka bir şekilde hak sahipliğinin devrinden sonra (1) inci paragrafta öngörülen hakların tükenmesine ilişkin muhtemel şartları belirleme yetkisine halel getirmez” şeklinde düzenlemiştir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 13. maddesi fonogram yapımcılarının “kiralama hakkı”nı ise şu şekilde düzenlemiştir.

“ (1) Fonogram yapımcıları, fonogramlarının asıl ya da kopyalarının, yapımcının verdiği yetki ile ya da bu yetkiye uygun şekilde dağıtılmasından sonra dahi, topluma ticari olarak kiralınması hususunda münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

(2) (1) inci paragraf hükümlerine rağmen, 15 Nisan 1994 tarihinde fonogramlar ile tespit edilmiş olan icraların kopyalarının kiralınması karşılığında fonogram yapımcılarına hakkaniyetli bir ücret sistemi uygulayan veya uygulamakta olan akit bir taraf, fonogramların ticari olarak kiralınması, fonogram yapımcısının münhasır çoğaltma hakkına maddi şekilde zarar vermedikçe, bu sistemi muhafaza edebilir”.

Komşu hak sahiplerinin aleyhine olarak, onların izin verme haklarının olmadığına ve sadece bir bedel alma haklarına sahip olduklarına dair yorumlarının dayanağı Roma Anlaşması’ndan⁹¹ sonra oluşturulan WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 14. maddesi, fonogram yapımcılarının umuma iletim hakkı konusunda bedel dışında ayrıca izin verme haklarına sahip olduklarını “gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim sağlayabilecekleri şekilde, fonogram yapımcıları fonogramlarının telli veya telsiz araçlarla topluma iletilmesine münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır” düzenlemesi ile açıkça ortaya koymuştur.

Tespitlerin kullanılması için fonogram yapımcılarının izin haklarının yanı sıra “bedel alma” haklarını gösteren düzenleme WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 15. maddesinde; “(1) İcracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları, topluma iletilme ya da radyo ve televizyonla yayınlanması için ticari amaçlarla yayımlanmış fonogramların doğrudan ya da dolaylı kullanımı karşılığında tek ve hakkaniyetli bir ücret hakkından yararlanırlar.

(2) Akit taraflar ulusal mevzuatlarında icracı sanatçı, fonogram yapımcısı veya her iki tarafın kullanıcıdan tek ve hakkaniyetli bir ücret talep edebileceğini öngörebilirler. Akit taraflar icracı sanatçı ve fonogram yapımcısı arasında bir anlaşmanın mevcut olmaması halinde, tek ve hakkaniyetle ücretin sanatçı ve fonogram yapımcısı arasında paylaştırılmasına ilişkin şartları ulusal mevzuatlarında kabul edebilirler.

(3) Akit taraflardan herhangi biri, WIPO Genel Müdürlüğüne tevdi edebilecekleri bir bildirim ile (1) inci paragraf hükümlerinin yalnızca bazı kullanımlarda uygulanacağını ya da bu hususu başka bir şekilde

⁹¹ Bizim bu yoruma katılmadığımızı ve WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması olmasaydı bile, Roma Anlaşması Türk Hukukundaki FSEK 80 ile birlikte yorumlandığında, icracı sanatçıların ve fonogram yapımcılarının icra ve tespitlerinin kullanılması için onlardan izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığına ilişkin yorumlarımızı genişçe “VI.A. İcracı Sanatçıların Hakları” başlığındaki “e. Umuma İletim Hakkı” adlı bölümde bulabilirsiniz.

sınırlandıracağını ya da bu hükümlerden hiçbirini uygulamayacağını beyan edebilir.

(4) Bu madde çerçevesinde gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim sağlanacak şekilde telli ya da telsiz araçlarla toplumun kullanımına sunulmuş fonogramlar ticari amaçla yayınlanmış kabul edilecektir” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu uluslararası kuralların Türk Hukukuna yansımaları FSEK madde 80 ile gerçekleşmiştir. FSEK madde 80/1 no’lu fıkrada B bendinde fonogram yapımcılarının hakları şu şekilde düzenlemiştir.

“Bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara sahiptir.

(1) Eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme veya yasaklama hakları münhasıran fonogram yapımcısına aittir. Yapımcılar tespitlerinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir.

(2) Fonogram yapımcısı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir.

(3) Fonogram yapımcısı, icraların tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. Umuma iletim yoluyla tespitlerin dağıtım ve sunulması yapımcının yayma hakkını ihlal etmez.”

FSEK yine 80. maddede film yapımcılarının haklarını düzenleyen maddeden sonra, *“Fonogramlara tespit edilmiş icraların ve filmlerin, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanı sıra, icracı sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlüdürler”* düzenlemesini getirmiştir.

Bu açıklamaların ardından FSEK 80. madde sistematüğini esas alırsak, fonogram yapımcılarının haklarını iki başlık altında inceleyebiliriz:

Bunların ilki fonogram yapımcısının izin verme ve yasaklama haklarıdır.

İzin verme ve yasaklama haklarının alanları şu şekilde sıralanabilir:

1. Çoğaltma,
2. Dağıtılma, satış, kiralama ve ödünç verme,
3. İşaret ses ve/ veya görüntü nakline yarayan araçlarla
 - umuma iletim,
 - yeniden iletim.
4. Satışa ve dağıtımına çıkmamış veya dağıtılmamış tespitlerinin aslının ve nüshalarının satışı yoluyla ve diğer yollarla dağıtımı,
5. Telli ve telsiz araçlarla;
 - satış yoluyla veya
 - diğer yollarla
- 5.1. umuma dağıtılması,
- 5.2. sunulması,
6. Gerçek kişilerin seçtiği yer ve zamanda tespitlere ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletim.

Fonogram yapımcılarının ikinci grup hakkı ise bedel alma hakkıdır. FSEK 80. maddesinin film yapımcısının haklarının olduğu 2 no'lu bölümden sonra bedel alma hakkı; tespit edilmiş icraların her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi halinde, bunları kullananların, yapımcılara veya ilgili alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlü olacakları şeklinde düzenlenmiştir. Görüldüğü gibi bedel alma hakkı umuma iletme özgü olarak düzenlenmiştir.

Fonogram yapımcılarının hakları ayrıca FSEK 41. ve 43. maddelerinde de düzenlenmiştir. Fonogramlardan umumi yerlerde yararlanma yolları ve usulü FSEK 41. maddesinde, “*Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı malî hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar*” girişi ile düzenlenmiştir. Fonogramların radyo ve televizyon yayınlarında kullanılması ise FSEK 43. maddesinde, “*Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve*

benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin almak zorundadırlar” girişi ile düzenlenmiştir.

Eser sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği madde 12 hükmünde, ses taşıyıcısı yapımcılarının hakları şöyle sıralanmıştır:

“Aşağıdaki durumlarda ses taşıyıcısı yapımcısından yazılı izin alınması zorunludur.

a) Tespit edilen seslerin doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılabilmesi,

b) Bu ses taşıyıcısı kopyalarının kiralanması,

c) Ticari dolaşıma konmuş ses taşıyıcılarının radyo ve televizyon kuruluşları ya da başka kuruluşlar tarafından yayınlanması ya da kamuya açık yerlerde temsil edilmesi”.

Görüldüğü gibi Yönetmelik fonogram yapımcılarının haklarını Kanuna aykırı ve eksik biçimde düzenlenmiştir. Bunun sebebi de Yönetmeliğin 1997 tarihinde çıkarılmasından sonra icracı sanatçılarla birlikte fonogram yapımcılarının haklarının 2001 yılında FSEK 80. maddenin çıkarılması ile genişletilmesidir. 2001 yılındaki Kanun değişikliğinden sonra Yönetmeliğin bu bölümü ve çeşitli bölümlerde açıkladığımız özellikle 14. ve 15. ve dahi birçok hükmü “normlar hiyerarşisi” kuralı sonucu FSEK’e aykırı olmaktan dolayı hukuken uygulanamaz hale gelmiştir. Aradan bu kitabı yazdığımız 2009 yılı itibarıyla sekiz yıl geçmesine rağmen hâlâ kısa sürede düzeltilecek diye duyumlar alıyoruz.

Fonogram yapımcılarının haklarını topluca sıralarken fark ettiğiniz gibi manevi bir haktan bahsetmedik. Fonogram yapımcılarının faaliyeti çoğunlukla ticari nitelikte olduğu için yaratıcıları ve eserin sahiplerine ilişkin manevi duyguların tatmini fonogram yapımcıları açısından düşünülmemiş ve fonogram yapımcılarından bu yönde talepler gelmemiştir. Ama fonogram yapımcıları icracı sanatçılar gibi fonogramları ve tespitleri kullanılırken anılmalıdırlar. Bu yüzden özellikle radyo, televizyon ve internet ortamlarında fonogram yapımcılarının tespitleri kullanılırken onların adlarına yer verilmesi adil olacaktır diye düşünüyoruz. Zaten sektörden aldığımız bilgilere göre, fonogram yapımcıları meslek birlikleri şeklinde örgütlendiklerinden kullanıcılarla yaptıkları sözleşmelere benzer hükümler koymaktadırlar. Belki bu yüzden bu konuda bir talepte bulunma ihtiyacı hissetmiyorlar. Bu konuda Roma Sözleşmesi’nin 11. maddesindeki fonogramlarda yapımcının adının yer alması kuralının da manevi haklarla ilgisinin bulunmadığını belirtmekte fayda görüyoruz.

Şimdi de fonogram yapımcılarının haklarını ayrıntılı olarak alt başlıklar halinde inceleyelim.

1. Çoğaltma Hakkı

Fonogram yapımcılarına ilk kez hak tanıyan Roma Anlaşması'nın 10. maddesine göre; *“fonogram yapımcıları, kendi fonogramlarının doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılmasına izin verme veya önleme hakkına sahiptir”*.

TRIPS Anlaşması'nın 14. maddesine göre; *“plak yapımcıları, plaklarının doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılmasına izin verme ya da önleme olanağından yararlanacaklardır”*.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 11. maddesi fonogram yapımcılarının “çoğaltma hakkı”nı, *“fonogram yapımcıları fonogramların herhangi bir şekil veya yöntemle doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılmasına münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır”* şeklinde düzenlemiştir.

AB Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin 22.05.2001 tarihli ve 2001/29/AT sayılı Direktifin 2. maddesine göre; *“Üye devletler, kısmen veya tamamen, her türlü yöntem ve şekilde, kalıcı veya geçici röprodüksiyonları hakkında:*

... (c) fonogram üreticileri ve onların fonogramlarını; ... doğrudan veya dolaylı yasaklama veya müsaade etmeye münhasır haklarını korur”.

FSEK madde 80/B 1 fıkrasına göre; *“eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması ...hususlarında izin verme veya yasaklama hakları münhasıran fonogram yapımcısına aittir”*.

Komşu Haklar Yönetmeliğinin 12. maddesi çoğaltma hakkı açısından, tespit edilen seslerin doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılabilmesi için ses taşıyıcısı yapımcısından yazılı izin alınması zorunluluğunu düzenlemektedir.

Yukarıda fonogram yapımcılarının haklarının, eser sahibinin ve icracı sanatçının izniyle müzik eserlerini ilk kez tespit etmeye dayalı olduğunu belirtmiştik. Bu çalışmada özellikle müzik eserlerine odaklandığımız için ilk tespitin korunma şartı, tespitin konusunun eser olmasıdır.

Fonogram yapımcısının konusu eser olmayan tespitleri ise FSEK madde 84 veya Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hükümleri kapsamında korunur⁹².

Bağlantılı hak korumasından yararlanan, bir müzik eserinin icrasının ilk tespitini yapan yapımcıdır. Bununla birlikte aynı icranın, başka bir yapımcı tarafından kendi imkanlarıyla tespiti de korunur. Yani diğer yapımdan (tespitten veya fonogramdan) yararlanmaksızın meydana getirilen yeni yapım da (eğer eser sahibi ve icracıdan gerekli izinler varsa) korumadan yararlanacaktır. Sözgelimi Y1 adlı yapımcı Ahmet Özhan'ın icra ettiği bir eseri tespit etmiştir. Ahmet Özhan eğer ilk yapımcı ile sözleşmesinde özel bir yasak yoksa sonradan Y2 adlı başka bir yapımcıya giderek aynı eseri icra etmek suretiyle icrasını yeniden tespit ettirebilir. Bu halde Y2 yaptığı tespit, Y1'in yapımını kullanmadığından, her iki yapım da FSEK'deki fikrîsel ve sanatsal haklara ilişkin korumadan yararlanacaktır⁹³.

Yapımcı koruma süresi dolmamış eserler veya icralar kadar, koruma süresi dolmuş eser ve icraları ... çoğaltıp, yayma imkanına sahiptir. Şayet ses, işaret ve resimler koruma süreleri dolmuş eserlere aitse ... herkes bunları çoğaltma ve yayma imkanına sahiptir. Bu taktirde korunan husus yapımcının bu tespit ve çoğaltmada kullandığı vasıtalaradır. Yoksa bu ürünler yapımcının kullandığı araçlardan yaralanmamak kaydıyla, herkes tarafından serbestçe tespit edilip çoğaltılabilir ve yayımlanabilir⁹⁴.

FSEK madde 80/B 1 fıkrasında fonogram yapımcısının çoğaltma hakkından bahsederken doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması kavramı kullanılmaktadır. Tespiti içeren ses ya da görüntü taşıyıcısından yapılan çoğaltmalara, doğrudan çoğaltma; tespitin iletildiği radyo, televizyon internet gibi araçlardan kayıt yapılarak çoğaltmaya ise dolaylı çoğaltma adı verilmektedir⁹⁵.

⁹² Bkz. İlhami GÜNEŞ, *Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku*, Ankara, 2008, s. 161 ve doğadaki su şırıltısı, rüzgar ve kuş seslerinin de bağlantılı hak korumasına konu edilebileceği yönündeki karşı yönde görüş için Cahit SULUK, *Telif Hakkı ve Korsanlıkla Mücadele*, İstanbul, 2004, s. 111

⁹³ Sami KARAHAN, Cahit SULUK, Tahir SARAÇ, *Temel NAL, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları*, Ankara, 2007, s. 101

⁹⁴ EREL, age., s. 177

⁹⁵ SCHRICKER/KRUGER, § 75 N 9; ULMER, *(Der Rechtsschutz der ausübenden Künstler...)*, s. 45. Naklen ARKAN, age., s. 146

Aşağıdaki karar fonogram yapımcısının bir kaydının, bir başka fonogram yapımcısı tarafından izinsiz olarak doğrudan çoğaltım yolu ile kaset yapılması üzerine verilmiştir.

“Davacı vekili, müvekkili firmanın piyasaya sürdüğü “*Karadeniz Kemeçe Show-94*”, “*Bol Horonlu Karadeniz*”, “*Kemeçe-Yayla Şenlikleri*” ve “*İşte Kemeçe- İşte Bizim Uşaklar*” adlı ses kasetlerinde yer alan eserlerin bir kısmının; davalı tarafından piyasaya sürülen “Kemeçe Düğün-Kanaryalı H.K.” adlı eserde, kopya edilmek suretiyle kullanıldığını ileri sürerek eylemin haksız rekabet oluşturduğunun tespiti ve haksız rekabetinin men’ini, davalı şirkete ait “*Kemençeli Düğün*” adlı kasetin imali ve satışının önlenmesini, çoğaltılmış nüshaları ile imale yarayan elemanlarla, reklam araçları ve 3. şahıslardaki nüshalarının toplatılarak imhası ve hüküm özetinin ilanını, 75,000,000 lira maddi, 25,000,000 lira manevi tazminatın reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir...

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, **davacı tarafından daha önce yayınlanmış bulunan müzik kasetlerinde yer alan eserlerin ses kayıtlarının kopya edilerek, davalı tarafından “Kemençeli Düğün- Kanaryalı H.K.” adlı müzik kasetinde yayınlanmasının eser sahibinin hakları ve komşu haklarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu**, maddi tazminatın talep edilebilir miktarının 90,000,000 lira olduğu, manevi tazminat isteme hakkının doğmadığı, gerekçesiyle **davanın kısmen kabulüne, haksız rekabetin tespit ve men’ine, davalının anılan ses kasetinin imal ve satışının önlenmesine, kaset üretiminde kullanılan araçlar ile tanıtım araçlarının ve piyasaya arz edilen kasetlerin toplatılmasına, 75,000,000 lira maddi tazminatın dava tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.**⁹⁶

Günümüzde çoğaltma yapmak için çok çeşitli araçlardan yararlanılmaktadır. Kasetler, cd’ler, cep telefonları, bilgisayar ve internet ortamı bunlara örnek olarak verilebilir. Web sayfalarına, tespit edilmiş bir icranın yüklenmesi (upload) veya bu sitelerden icraların indirilmesi (download) işlemlerinin ve bir tespitin mp3 formatına sokulmasının da çoğaltma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yukarıda eser sahiplerinin ve icracı sanatçıların çoğaltma hakkı incelenirken tespit edilmiştir⁹⁷.

Yine, bir müzik eserinin reklam müziği olarak kullanılabilmesi ve bunun reklam filmi içinde çoğaltılabilmesi ve çoğaltılan filmin ve içindeki müziğin umuma iletimi ve yayınlanabilmesi için fonogram açısın-

⁹⁶ Yargıtay 11. H.D, 16.6.1997, E. 1997/3583, K. 1997/4725, SULUK/ORHAN, age, s. 191.

⁹⁷ ARKAN, age., s. 146.

dan fonogram yapımcısı ile birlikte eser sahibinden de izin alınmalıdır. Bu konuda bir Yargıtay kararı şöyledir:

“Davacı vekili, davalının, müvekkilinin telif hakkı sahipleri bulunduğu müzik eserini izinsiz reklam müziği olarak kullandığını ileri sürerek, 10.000 USD maddi ve 4.000 USD manevi tazminatın ihtarname tarihinden itibaren en yüksek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, sunulan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak, zamanaşımı ve husumet savunmasının yerinde olmadığı, davacı telif hakkı sahibinin FSEK’in 25. maddesine dayanarak mali hak talebinde bulunabileceği, ancak eser sahibine ait manevi tazminat isteminin dayanaksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 10,000 USD’nin faiziyle birlikte BK 83’e göre davalıdan tahsiline, FSEK 68. maddesinden kaynaklanan üç misli talep hakkının saklı tutulmasına karar verilmiştir⁹⁸.”

Yine fonogram yapımcısının haklarını takip için yetki veya lisans verdiği kişiler de, fonogram yapımcısının haklarını ihlal ederek onun müzik yapıtlarının çoğaltılmasını ve umuma iletimini engellemek ve tazminat almak için aşağıda görüldüğü gibi dava açarlar. Ancak, hakları takip yetkisi olduğunu yazılı sözleşmelerle ispatlayamazlarsa mahkeme davaya bakmaz.

“Davacı vekili, müvekkili şirketin Türkiye temsilcisi olduğu ... Music Publishing tarafından her türlü hakkı saklı tutulan “*Hippy Hippy Shake*” isimli eseri davalının izinsiz olarak reklam filminde kullandığını ileri sürerek, telif hakkı bedeli 10.000. İngiliz sterlininin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosyadaki belgelere göre, **davacının** davaya konu mali hakları ve **bu haklara ilişkin dava açma yetkisini FSEK’nun 52. maddesine uygun bir sözleşme ve kesintisiz devir silsilesi içinde devir aldığını ortaya koyabilecek bir belge bulunmadığı**, davacının aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı **gerekçeyle, davanın reddine karar verilmiştir.**⁹⁹”

Çoğaltma haklarının ihlal edildiği alanlara baktığımızda iki alan dikkat çekmektedir: Bunlardan ilki “fiziksel korsan kopyalar” ve ikincisi bilgisayar ve internet ortamında gerçekleşen “digital korsan kopyalar”.

Fiziksel korsan kopyalar 1990 ve 2000 yılları arasında en önemli çoğaltma hakkı sorunu olmuştur. Dünyanın pek çok yerinde kaset ve CD

⁹⁸ Yargıtay 11. H.D, 27.06.2002, E. 2002/4172, K. 2002/6637, SULUK/ORHAN, age., 852-853.

⁹⁹ Yargıtay 11. H.D. 2002/3622 E. 2002/7725 K.

şeklinde yapılan bu kopyalar emniyet güçleri tarafından ele geçirilmiş ve sokaklarda üzerinden vinçler geçirilerek yok edilmiştir. Özellikle ekonomik açıdan geri kalmış ülkelerde fiziksel korsan kopyalar halen yaygın biçimde kullanılmaktadır. FSEK madde 81, bu korsan kopyaların bandrolsüz olması dolayısı ile bandrole ilişkin olarak çeşitli düzenlemeler getirerek bu ihlali engellemeye çalışmıştır. Bandrol ile ilgili daha sonra geniş açıklamalarda bulunacağız.

Digital alanda, yani bilgisayar ve internetin kullanıldığı ortamlarda müzik eserlerinin kullanılması; klasik bant, plak, kaset, cd üzerinde bulunan ses tespitlerinin bilgisayar disklerine aktarılması ile ortaya çıkmıştır. Gelişen teknoloji ve yazılım doğrultusunda bu aktarma esnasında “sıkıştırma” adı verilen bazı programlar kullanılarak ses ve görüntü tespitlerinin çok az yer kaplaması sağlanınca, mp3 adı verilen ses tespitlerinin (ve sonrada mp4 adı verilen ses ve görüntü tespitlerinin) bilgisayar ortamında izinsiz çoğaltılmış kopyaları Dünya’da dolaşmaya başlamıştır. İnternet gibi bilgisayarları birbirine bağlayan yöntemlerin gelişmesi ile mp3’ler (ve mp4’ler) bilgisayardan bilgisayara aktarılma veya p2p adı verilen dosya paylaşımı yöntemleriyle izinsiz olarak milyonlarca kopya çoğaltılmasıyla herkesin bulabileceği şekilde yaygınlaşmıştır. Bu gelinen noktada özellikle iPod gibi portatif mobil müzik dinleme ve izleme cihazlarının ve cep telefonlarının gelişmesi sonucu artık fiziki kopyalar olan kaset ve cd satışları azalmış ve izinsiz çoğaltma şeklindeki digital korsanlık müzik endüstrisini kelimenin tam anlamıyla vurmuştur.

Özellikle müzik eserlerinin izinsiz olarak umuma sunulduğu web siteleri fonogram yapımcıları açısından digital korsanlığa karşı ulusal ve uluslararası hukuki mücadele için ilk hedefler olmuştur. Bu web sitelerinin eylemleri umuma iletim içindeki “kamunun erişimine sunma” hakkının yanı sıra, çoğaltma hakkının da ihlalidir. Bu alanda geçmiş yıllarda en önemli ihlaller Napster, Gnutella ve Majo Nation adlı yazılım program ve sitelerinin kullanımı dolayısıyla olmuştur. Napstere karşı Amerikan Kayıt Endüstrisi (RIAA) tarafından ABD’de açılan dava, Napster’in davanın gidişatını kötü görmesiyle uzlaşmayla bitmiş, açılan bir başka davada ise, Mahkeme Napster açısından, korunan müzik eserlerine ilişkin gözetim ve kontrol mükellefiyeti olduğunu kabul ederek, çoğaltmaya izin vermeme görevi yüklemiş ve Napster bu doğrultuda bir filtreleme sistemi oluşturmuştur. Sony ve Universal Müzik gibi büyük şirketlerle Mahkemede anlaşılan Napster bu firmaların eserlerine ilişkin bir filtre sistemi kurarak kopyalama ve indirmeyi engellemiş ve ayrıca diğer mü-

zik yapımcısı şirketlerle anlaşarak sistemi paralı hale getirmiştir. Ancak halen ekonomik ve hukuki yapının gelişmediği ülkelerde kurulu birçok web sitesinde digital korsanlık ve izinsiz kullanım sorunu devam etmektedir. Bu nedenle dosya paylaşımı programlarını yapan ve siteleri işleten kişilere ve şirketlere karşı; eser, sanatçı isimleri ve hak sahipliğini gösteren belgelerle müracaat ederek filtreleme isteğinde bulunulması yararlı görülmektedir.¹⁰⁰

Müzik yapımcıları yine Avustralya'da Kazaa adlı bir internet şirketini dava ederek; müzik ve filmler için dosya paylaşımına izin veren p2p sistemini kullanımda tutarak, bireysel kullanıcıların telif hakları ihlaline neden olduğunu ve dosya paylaşımı konusunda gerekli önleyici sistemleri kurmayarak, kendilerini zarara uğrattığını ileri sürmüşlerdir. Yapılan yargılama sonucu Federal Mahkeme, davalı Kazaa ve ona servisler sağlayan Altnet adlı şirketi; gerekli filtreleme sistemleri koyarak telif hakkı ihlallerini önlemediğinden ve izinsiz müzik dosyalarını arama ve paylaşma teknolojisi sağlamasından dolayı sorumlu bularak, bu ihlalleri önlemeye mahkum etmiştir.¹⁰¹

Danimarka'da Danimarka Video Birliği, DD adlı kuruluşa yine dosya paylaşım hizmeti ile kullanıcılarına telif hakkı ödemediği videolar içindeki filmlerin izinsiz kullanımına izin vermesinden dolayı dava açtı. Mahkeme; bu davada davalıyı izinsiz olarak müzik eserlerini kendi bilgisayarına kopya ederek, dosya paylaşımına izin vererek umuma açık hale getirmesi sebebiyle yasadışı dosyaları silmeye, davacıların telif kaybı zararlarını ve artan telif hakları ihlallerini denetleme masraflarını karşılamaya mahkum etmiştir.¹⁰²

İzinsiz müzik sunan web sitelerine karşı, alternatif yasal kullanımlar sağlamak için günümüzde artık büyük müzik şirketleri web ortamında sanal mağazalar açarak veya açılmasına izin sağlayarak digital müzik eserlerinin yaygın olarak satışını yapmaktadırlar. Buna rağmen digital dünya'da halen müzik eserleri büyük çoğunlukla yasalara aykırı kullanılmaktadır.

Yukarıda özetlediğimiz gibi ağ paylaşımli bilgisayar ortamlarına veya kaydetme ve depolama alanı olan müzik cihazlarına, müzik

¹⁰⁰ MEMİŞ, age., s. 59

¹⁰¹ www.austlii.edu.au/au/cases/cth/federal_ct/2005/1242.html

¹⁰² 30.01.2006 BS 99-875/2004 nolu mahkeme kararı.

eserlerinin eser veya bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmadan indirilmesi, kayıt edilmesi ve depolanması öncelikle çoğaltma hakkına aykırıdır.¹⁰³ Çünkü bir ses tespitinin kaset ve cd yerine bilgisayarlara veya müzik dinleme cihazlarının içindeki kopyalama ortamına yeniden kopyalanması çoğaltmadır. FSEK madde 22 2. fıkrasına göre; “Eserlerin aslından ikinci bir kopyasının çıkarılması ya da eserin işaret, ses ve görüntü nakil ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kayıt edilmesi, **her türlü ses ve müzik kayıtları** .. da çoğaltma sayılır...Çoğaltma hakkı, bilgisayar programının geçici çoğaltılmasını gerektirdiği ölçüde, programın yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve depolanması fiillerini de kapsar”. FSEK madde 22 ve 80 hükmü açısından bu tür çoğaltmalar için müzik eserinin ilk tespitini yapan fonogram yapımcısından izin almak gerekir. Fonogram yapımcısının yanında çoğaltma hakkını yapımcıya devretmişse eser sahibi ve icracı sanatçıdan da ayrıca izin almak gerekir.

Burada FSEK madde 38 uyarınca bilgisayarında şahsen kullanım için müzik eserlerini çoğaltmış olanlara da değinmemiz gerekir. Evet, bu kişiler şahsen kullanmak için bir biçimde müzik eserini kendi bilgisayarlarında çoğaltmış ve saklıyor olabilirler. Ancak şahsen kullanan kişiler bu müzik dosyasını üçüncü kişilerin paylaşımına ve kullanmasına sunamazlar. Eğer bu müzik dosyasını, hiçbir önlem almadan başkalarının da izinsiz çoğaltma yapmasına olanak sağlayacak şekilde, erişime açık tutuyorlarsa veya (kendi sınırlı şahsi çevrelerini aşan şekilde) başkalarına e mail yoluyla çoğaltarak gönderiyorlarsa, o zaman fonogram yapımcısı ve diğer hak sahiplerinin potansiyel alıcılara çoğaltma yapma ve ticaret yapmasına engel olup, onun gelir kaybetmesine neden oldukları için hem tazminat ödeme yükümlülüğü ile ve hem de hapis cezaları tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Çünkü şahsen kullanma istisnası tanıyan FSEK 38. maddesi, şahsen kullanmaya yönelik bu çoğaltmanın **eser ve bağlantılı hak sahiplerinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremeyeceğini ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamayacağını** düzenlemiştir. Hak sahiplerinin bu eseri satışa sunarak gelir elde etmesi onlar açısından normal meşru bir menfaat elde edilmesidir. Bu yüzden kendi şahsi kopyasını başkaları için çoğaltan veya çoğaltılmasına izin veren kişi eser ve bağlantılı hak sahiplerinin bu müzik eserlerini satarak gelir elde etmesi meşru menfaatine engel olmuş olur.

¹⁰³ Bkz. Aksi görüş MEMİŞ, age., s. 112 v.d.

FSEK 80. maddesinde, bağlantılı haklara sahip olanların eser sahipleri gibi tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i ve tazminat davası açacakları hüküm altına alınmıştır. Bu yasal düzenleme doğrultusunda, fonogram yapımcısı, çoğaltma hakkının ihlali halinde; FSEK madde 67'ye dayanarak tecavüzün ref'i; FSEK madde 69'a dayanarak tecavüz tehlikesinin varlığı halinde tecavüzün men'i davaları ile şartları gerçekleşmişse FSEK madde 68 ve 70'e dayanarak maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

2. Yayma Hakkı

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 12. maddesi fonogram yapımcılarının "yayma hakkı"nı;

"(1) Fonogram yapımcıları, fonogramlarının aslı veya kopyalarını satış veya başka bir şekilde hak sahipliğini devretmek yoluyla topluma sunulmasına münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

(2) Bu Andlaşmadaki hiçbir hüküm, akit tarafların fonogram yapımcısının izni ile fonogramın aslı veya kopyası üzerinde hak sahipliğinin ilk satışı ya da başka bir şekilde hak sahipliğinin devrinden sonra (1) inci paragrafta öngörülen hakların tükenmesine ilişkin muhtemel şartları belirleme yetkisine halel getirmez" şeklinde düzenlemiştir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 13. maddesi fonogram yapımcılarının "kiralama hakkı"nı;

"(1) Fonogram yapımcıları, fonogramlarının asıl ya da kopyalarının, yapımcının verdiği yetki ile ya da bu yetkiye uygun şekilde dağıtılmasından sonra dahi, topluma ticari olarak kiralınması hususunda münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

(2) (1) inci paragraf hükümlerine rağmen, 15 Nisan 1994 tarihinde fonogramlar ile tespit edilmiş olan icraların kopyalarının kiralınması karşılığında fonogram yapımcılarına hakkaniyetli bir ücret sistemi uygulayan veya uygulamakta olan akit bir Taraf, fonogramların ticari olarak kiralınması, fonogram yapımcısının münhasır çoğaltma hakkına maddi şekilde zarar vermedikçe, bu sistemi muhafaza edebilir" biçiminde düzenlemiştir.

TRIPS Anlaşması madde 14/2'de ise, fonogramların kiralınması ile ilgili olarak herhangi bir üye ülkede, 15 Nisan 1994 tarihinde, hak sahiplerine adil bir ödeme yapılması sistemi yürürlükte ise; fonogramların ticari olarak kiralınmasının, hak sahiplerinin çoğaltma

hakkının esaslı biçimde zarar görmesine yol açmaması koşuluyla, bu üyenin söz konusu sistemi sürdürebileceği ifade edilmiştir¹⁰⁴.

92/100/AET sayılı “*Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi*”nin 2. maddesinde; **“kiralama ve ödünç vermeyi yetkilendirme ve yasaklama münhasır hakkı,**

- *eserin orijinali ve diğer nüshaları hakkında, eser sahibine,*
- *icra tespiti hakkında, icracı sanatçıya,*
- **fonogramlar hakkında, fonogram yapımcısına ... aittir”** düzenlemesi bulunmaktadır.

Aynı Direktifin 9. maddesine göre; **“Üye devletler, fonogramları hakkında fonogram yapımcılarına, satış ya da başka yollarla, buradan itibaren “dağıtım hakkı” olarak göndermede bulunan söz konusu maddelerin asıl ve kopyalarının kamuya sunumu münhasır hakkını sağlarlar.**

Direktifin 4. maddesine göre;

“1. Eser sahibinin ya da icracının fonogram, film ya da kopyasına ilişkin kiralama hakkını fonogram ya da film yapımcısına aktardığı ya da devrettiği durumda, söz konusu eser sahibi ya da icracı, kiralama konusunda adil bedel elde etmek için, bu hakkı elinde tutar.

2. Kiralama konusunda adil bedel elde etme hakkı, eser sahipleri ya da icracıları temsil eden meslek birliklerine havale edilebilir.

3. Adil bedel elde etme hakkının yönetimi, eser sahiplerini ya da icracıları temsil eden meslek birliklerine havale edilebilir.

4. Üye devletler, söz konusu bedelin kimden talep edilip alınacağı konusu yanında, adil bedel elde etme hakkının meslek birlikleri tarafından yönetiminin uygulama sınırlarını düzenleyebilirler”.

Bu düzenlemelerin Türk Hukuku’na yansımaları FSEK 80. maddesi B bendinde görüyoruz. Bu maddeye göre;

(1) Eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, ... dağıtılması, satılması, kiralınması ve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme veya yasaklama hakları münhasıran fonogram yapımcısına aittir.

(2) Fonogram yapımcısı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüs-

¹⁰⁴ ARKAN, age., s. 152

halarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir.

(3) Fonogram yapımcısı, icraların tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ... izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir.

Görüldüğü gibi fonogram yapımcılarının yayma hakkı çeşitli maddelere serpiştirilmiştir. Hakların gruplar halinde yazılmayıp toplama veya serpiştirme metodu ile yazılması 80. madde için genel bir sorundur. Umarız FSEK’de yapılacak temel bir değişiklik fırsatı ile bu karışıklık ortadan kaldırılır ve bağlantılı hak sahiplerinin hakları eser sahipleri hakları gibi madde içinde gruplanarak sayılır.

FSEK 80. maddesi B bendi açıkça; fonogram yapımcılarının ilk kez tespit etmiş olduğu ses kayıtlarının yayma hakları için fonogram yapımcılarından izin alınması gereğini ortaya koymuştur. Müzik sektöründe çok istisnai şekilde rastlanmakla birlikte, eğer eser sahipleri bu fonogramda yer alan eserlerin bu tespitleri için tüm haklarını fonogram yayıncılarına devretmemişlerse ve icracı sanatçılar kendi icralarının tespitleri açısından tüm haklarını fonogram yapımcılarına devretmemişlerse sadece yayma hakkı doğrultusunda müzik kaset ve cd’lerinin satışı ve dağıtımı için fonogram yapımcılarının izni yeterli olmaz. Bu durumda eser sahiplerinin ve icracı sanatçıların da iznine gerek vardır. Eğer sektörde genel kabul gördüğü şekilde, yapımcı eser sahibinin ve icracı sanatçının haklarını tespitler için devralmışsa o zaman sadece fonogram yapımcısından izin alınarak yayma konusu haklar kullanılabilir.

Bağlantılı hak sahiplerinin yayma hakkına ilişkin bir tanımın FSEK’de ve Komşu Haklar Yönetmeliği’nde yer almadığını daha önce belirtmiştik. Eser sahibinin yayma hakkını düzenleyen FSEK madde 23’den yararlanarak, fonogram yapımcılarının yayma hakkı;

- tespit edilmiş bir icranın asıl veya çoğaltılmış maddi nüshalarını;
- kiralamak,
- satmak,
- ödünç vermek veya
- diğer yollarla dağıtmak şeklinde tanımlanabilir¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Yaymanın bir yolu olan “**kiralama**”, Komşu Haklar Yönetmeliği’nin 4. maddesinde: “üzerine seslerin ya da görüntülerin ya da her ikisinin kaydedildiği maddi araçların bir kopyasının ticari amaçla belli bir süre için ücret karşılığında zilyetliğinin el de-

Daha önce icracı sanatçılar için söylediğimiz gibi yayma hakkı konusu kayıtlar plak, kaset, cd, ups gibi sabit ve maddi mallar için geçerlidir. Maddi bir materyal üzerine kayıtlı olmayan, digital veya online satış, ödünç verme, dağıtma ve kiralama ise “kamunun erişimine sunma hakkı” ile ilgilidir.

Komşu Haklar Yönetmeliğinin 12. maddesinde, yayma haklarından sadece kiralama hakkı için yapımcıdan izin alınması öngörülmüştür. Yönetmelikte diğer yayma haklarından bahsedilmemektedir. Bunun sebebi, Yönetmeliğin yapıldığı 1997 yılında FSEK’de komşu hakların şu anki geniş şekliyle koruma altında olmamasıydı. Bu ortamda 1997 yılında yapılan Eser Sahibine Komşu Haklar Yönetmeliği FSEK’de bulunmayan kiralama kavramını mevzuata getirmiştir. Ancak 2001 yılında bağlantılı haklar genişçe FSEK’e dahil edildikten sonra Yönetmeliğin değiştirilmesi ihmal edilmiştir.

Burada son olarak, icracı sanatçıların yayma hakkı incelenirken detaylı olarak bilgi verilen ilk satış veya tükenme ilkesi adı verilen prensibin, fonogram yapımcısının yayma hakkı konusunda da geçerli olduğu ifade edilmelidir. FSEK madde 80/1B-2’ye göre, fonogram yapımcıları yurt içinde satış veya başka yollarla dağıtılmamış, tespitlerinin satış veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama yetkisine sahiptirler. Ancak fonogram yapımcısı, tespitinin bir kez satışına izin verdikten sonra, bu izin izleyen satışlar için de geçerli olacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, tükenme ilkesi kural olarak ülkeseldir. Ancak Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerle, ülkesel tükenme ilkesi yerini bölgesel tükenme ilkesine bırakmıştır¹⁰⁶.

3. Temsil Hakkı

FSEK madde 24’den yararlanarak temsil hakkını; “*bir eseri doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle*

giştirmesidir” şeklinde tanımlanmıştır. Bunun dışında ne FSEK’de ne de Komşu Haklar Yönetmeliği’nde konuya ilişkin bir tanım mevcut değildir.

Tespitin Satılması: “Üzerine seslerin ya da görüntülerin ya da her ikisinin kaydedildiği maddi araçların herhangi bir tarzda satılması”; **Tespitin Ödünç Verilmesi:** “Üzerine seslerin ya da görüntülerin ya da ikisinin kaydedildiği maddi araçların bedelsiz olarak başkalarının yararlanması için bırakılması” şeklinde tanımlanabilir. Bkz. TEKİNALP, age., § 17 N. 27-28.

¹⁰⁶ TEKİNALP, age., § 17 N. 28. Naklen ARKAN, age., s. 153

umumi yerlerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek” şeklinde tanımlayabiliriz. Eskiden temsil hakkının içinde olan “umuma iletim”in ayrılması ile fonogram yapımcıları açısından temsil; sadece konserlerde sanatçıların playback kayıtlarını kullanması ve umumi yer ve mahallere fonogramların içeriğinin sunulması şeklinde gerçekleşmektedir. Temsil hakkı için yapılan yayının (okuma, çalma, oynama, gösterme) mutlaka umumi yerde olması gereklidir. Temsilde belirli bir yere özgü olarak hopörlör, radyo, televizyon, bilgisayarla veri transferi gibi her türlü işaretleme, ses veya resim nakline yarayan “aletler” kullanılır.

Temsilde iki temel unsur bulunmaktadır;

- Eserden yararlanma, geçici olmalı ve yararlanma anıyla sınırlı kalmalıdır.
- Temsil, kamunun istifadesine elverişli umumi bir yerde gerçekleşmelidir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 15. maddesi “temsil hakkı” ile ilgili olan fonogram yapımcılarının bedel alma hakkını şu şekilde düzenlemiştir.

“(1) *İcracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları, topluma iletilme ya da radyo ve televizyonla yayınlanması için ticari amaçlarla yayımlanmış fonogramların doğrudan ya da dolaylı kullanımı karşılığında tek ve hakkaniyetli bir ücret hakkından yararlanırlar.*

(2) *Âkit taraflar ulusal mevzuatlarında icracı sanatçı, fonogram yapımcısı veya her iki tarafın kullanıcıdan tek ve hakkaniyetli bir ücret talep edebileceğini öngörebilirler. Âkit taraflar icracı sanatçı ve fonogram yapımcısı arasında bir anlaşmanın mevcut olmaması halinde, tek ve hakkaniyetle ücretin sanatçı ve fonogram yapımcısı arasında paylaştırılmasına ilişkin şartları ulusal mevzuatlarında kabul edebilirler*”.

92/100/AET sayılı *Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi*’nin madde 8 de temsil hakkını ilgilendirir biçimde “yayın ve kamuya iletim” şu şekilde düzenlenmiştir.

“ 1. Üye devletler, yayın icrası veya tespit sonucu gerçekleştirilen icra haricinde, icracılara kablosuz yayın konusunda yetkilendirme ya da yasaklama ve icralarının kamuya iletimi münhasır hakkını sağlarlar.

2. Üye devletler, ticari amaçlarla yayınlanan fonogram ya da bu nevi fonogramın çoğaltımı kablosuz yöntemlerle yayın ya da kamuya ile-

tim amacıyla kullanılıyorsa, tek adil bedelin kullanıcı tarafından ödenmesini sağlamak ve söz konusu bedelin ilgili icracılar ve fonogram yapımcıları arasında paylaşılmasını sağlamak için hak sağlarlar. Üye devletler, icracılar ve fonogram yapımcıları arasında anlaşma olmaması durumunda, söz konusu bedelin onlar arasında paylaşılmasını belirleyen şartları düzenlerler.

3. Üye devletler, söz konusu iletim kamuya açık alanlarda giriş ücreti karşılığında yapılıyorsa, yayın kuruluşlarına yayınlarının kablosuz yöntemlerle çoğaltımı ya da kamuya iletimi münhasır hakkını sağlarlar”.

FSEK 80. maddesi, fonogram yapımcılarının temsil hakkını şu şekilde düzenlemiştir:

“(3) Fonogram yapımcısı, icraların tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla veya ...diğer biçimlerde umuma ... sunulmasına ... izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir”.

FSEK 41. maddesi ise; umumi yerlerde müzik yayını için fonogram yapımcılarından izin alma gereğini diğer hak sahipleri ile fonogram yapımcılarını organize ederek aşağıdaki biçimde farklı bir sisteme bağlamıştır.

“Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı malî hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar.

Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanan ve/veya ileten umuma açık mahaller; mahallin bulunduğu bölgenin özelliği, mahallin nitelik ve niceliği, fikrî mülkiyete konu eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası ve ürün veya hizmete katkısı olup olmadığı ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle sınıflandırılır veya sınıflandırma dışı bırakılır.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımından ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile umuma açık mahaller arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

Tarifelere ilişkin sözleşmelerde takvim yılı esas alınır ve bu tarifeler takvim yılı başından itibaren geçerli olur.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasını teminen:

1. Meslek birlikleri temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bilgileri, Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimler her üç ayda bir güncellenir ve Bakanlıkça oluşturulan ortak bir veri tabanı üzerinden ilgili taraflara açılır.

2. Eser sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya bağlantılı hak sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya aynı sektörlerde faaliyet gösteren meslek birlikleri, biraraya gelerek protokole bağlamak suretiyle ortak tarifeler belirleyebilirler. Ortak tarifeler protokole taraf meslek birlikleri açısından bağlayıcıdır.

Meslek birlikleri, tarifeler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildirirler ve kamuoyuna duyururlar. Umuma açık mahaller, müzakere ve sözleşme yapılmasına ilişkin verecekleri bağlayıcı nitelikteki yetki belgeleri ile üye oldukları meslek kuruluşları aracılığıyla da tarifeleri veya ortak tarifeleri müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler. Ancak, tarifelerin götürü usulde tespit edilmesi halinde umuma açık mahaller sadece meslek kuruluşları aracılığı ile müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler.

Onuncu ayda umuma açık mahaller veya meslek kuruluşları ile meslek birlikleri arasında tarifeler veya ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde, en geç bu ayın sonuna kadar, meslek birlikleri ve/veya meslek kuruluşları tarafından bu tarifelerin Bakanlıkça oluşturulacak uzlaştırma komisyonunda müzakere edilmesi talep edilebilir.

Uzlaştırma komisyonu, taraflardan birinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, tarifeleri müzakere etmek üzere, Bakanlık tarafından talep tarihinden itibaren onbeş gün içinde oluşturulur. Komisyon Bakanlıktan bir, Rekabet Kurumundan iki temsilci ve ilgili meslek birlikleri ile kullanıcıları temsil eden meslek kuruluşlarının birer temsilcisinden oluşur. Bakanlık temsilcisi aynı zamanda komisyon başkanıdır. Aynı usulle, komisyon üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık ilgili birimi tarafından yürütülür. Komisyon, oluşturulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde, raporunu hazırlayarak, Bakanlığa ve taraflara bildirir. Umuma açık mahaller ve meslek birlikleri, Komisyon raporunun açıklandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde, meslek birliklerinin açıklamış oldukları tarifeleri veya müzakereler neticesinde mutabakata vardıkları tarifeleri sözleşmeye bağlayabilirler. Meslek birliklerince belirlenen tarife veya ortak tarifeler üzerin-

den sözleşmenin yapılmaması halinde, taraflar yargı yoluna başvurabilirler. Yargılama sürecinde, bir önceki yıl sözleşme yapmış olan mahaller, ilgili meslek birlikleri aksini bildirmedikçe, dava konusu tarifenin 1/4'ünü dava sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir meslek birlikleri adına açılmış banka hesabına yatırmak suretiyle eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilir ve/veya iletebilirler. Bir önceki yıl sözleşme yapmamış umuma açık mahaller ile ilk defa sözleşme yapacak umuma açık mahallerin bu fıkra da öngörüldüğü şekilde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilmeleri ve/veya iletebilmeleri ise ilgili meslek birliklerinin iznine bağlıdır. Dava sonuçlanıncaya kadar bu şekilde ödenen miktar, mahkeme kararıyla tespit edilen tarife bedelinden mahsup edilir.

Tarifelerin tespit edilmesinde ve uzlaşmazlıkların hallinde, bu Kanunun 42/A maddesinin üçüncü fıkrasında¹⁰⁷ yer alan, tarife tespitine ilişkin esaslar dikkate alınır.

Mahallerde kullanılan ve/veya iletimi yapılan eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar üzerinde hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, bunların kullanımına ve/veya iletimine ilişkin ödemelerin yapılmasını yetki verdikleri meslek birlikleri aracılığı ile talep edebilirler. Sinema eserleri bakımından bu fıkranın uygulanması zorunlu değildir.

Sınıflandırma, uzlaştırma komisyonuna başvuru halinde Bakanlıkça alınacak ücretler ve uzlaştırma komisyonunun çalışması ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.”

Bu düzenleme birçok açıdan fonogram yapımcıları ve diğer hak sahipleri için sakıncalar içermekle birlikte tekrardan kaçınmak için, bu sakıncalar ve eleştirilerimiz hakkında “V. Müzik Eseri Sahibinin Hakları, B. Müzik Eseri Sahiplerinin Mali Hakları, 4. Temsil Hakkı, Umuma

¹⁰⁷ FSEK 42/A 3. fıkrası: Tarifelerin tespit edilmesinde; tarifelerin uluslararası uygulamaların ülkenin ekonomik ve toplumsal koşullarına uyarlanabilirliği göz önünde bulundurularak makul seviyede belirlenmesi ile teknolojik alandaki değişimlerin yanı sıra eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların yaratıldığı ve kullanıldığı sektörlerin yapısını tahrip edici, üretimi ve kullanımı engelleyici ve genel kabul görmüş uygulamalara zarar verici bir etki yaratılmaması, rekabeti bozucu şartlar oluşturulmaması, yapılan sınıflandırma, ilgili sektörlerdeki ürün fiyatları ve bu sektörlerin gayrisafi milli hâsıladaki payı, eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletim sıklığı, birim fiyat veya götürü usulü ödeme, ödeme planı ve benzeri hususlar esas alınır.

Açık Yerlerde Müzik Eserlerinin Kullanılması” adlı bölüme bakılmasını öneriyoruz.

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliğinin 12. maddesine göre ise; “*Aşağıdaki durumlarda ses taşıyıcısı yapımcısından yazılı izin alınması zorunludur.*

c) *Ticari dolaşıma konmuş ses taşıyıcılarının ... kamuya açık yerlerde temsil edilmesi”.*

Bu düzenlemelerde görüleceği üzere, fonogram yapımcısı ilk kez tespit etmiş olduğu ses tespitlerinin umuma açık mahallerde ve yerlerde temsili (dinletilmesi ve gösterilmesi) için izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir.

ARKAN’a göre, bir eser icrasını içeren fonogramın umuma açık bir yerde çalınması ya da bir fonogram kullanılarak yapılan radyo-televizyon yayınlarının umuma açık bir yerde dinlettirilmesi ya da izlettirilmesi veya bir fonogramın, çalınması için izin verildiği mekanın dışında bir yere işaret, resim veya ses nakline yarayan, hoparlör veya ekran gibi bir araçla nakledilerek, aynı anda orada da izlettirilmesi veya dinlettirilmesi dolaylı temsil kavramına girer ve icracı sanatçılar gibi fonogram yapımcılarının dolaylı temsile ilişkin izin ve yasaklama hakkı yoktur¹⁰⁸. Biz bu görüşe katılmıyoruz.

Fonogram yapımcılarının ses tespitleri çoğunlukla bir umumi mahalde doğrudan yani kaset, cd veya plak çalınması yoluyla gerçekleşir. FSEK 24. maddesinin kıyasen uygulanması ile bu temsil durumu fonogram yapımcıları açısından doğrudan temsildir. Dolaylı temsil ise bu fonogramların veya müzik kliplerinin radyo, televizyon veya internet yoluyla umumi yerler olan otel, cafe, lokanta, mağaza gibi yerlerde dinletilmesi veya gösterilmesidir.

Bize ve Türk Hukuku’na göre; fonogram yapımcısı, doğrudan veya dolaylı temsil hakkı açısından, fonogramlar ve müzik kliplerinden yararlanacak olanlara izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir.

FSEK 41. maddesi, fonogram yapımcılarına 80. maddede tanınmış olan temsil hakkına ilişkin umumi yerler açısından “*girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır*

¹⁰⁸ ARKAN, age., s. 155

ve sözleşmelerde yazılı malî hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar” şeklinde özel bir düzenleme getirmiştir.

FSEK 80/B 3 ve 41. maddeleri birlikte incelendiğinde umumi mahallerde; ister kaset, cd, dvd veya bunların bilgisayarlara kaydedilmiş kopyaları doğrudan çalın isterse bu cd, dvd, kaset veya bilgisayara kaydedilmiş kopyaları bir radyo, televizyon aracılığıyla veya bir internet sitesi ya da ortamından aktarılacak yoluyla dolaylı çalın, neticede fonogramlardaki ses kayıtları ve fonogram içeren müzik videoları temsil edildiğinden mutlaka fonogram yapımcılarından izin alınması gerekir. Eğer temsil dolaylı veya doğrudan izinsiz olarak yapılıyorsa fonogram yapımcısının bu temsili yasaklama hakkı bulunmaktadır. Bu izin alınmazsa ve bedeli ödenmezse ek olarak hatırlatalım ki, FSEK madde 71’de bulunan ceza hükümleri doğrultusunda hapis ve para cezası ödenmesi devreye girer.

Bağlantılı hakları inceleyen ARKAN, bu konuda hatalı ve hukuka aykırı bir yorumu eserlerinde dile getirmektedir. Yazar; radyo ve televizyonlar aracılığıyla umumi mahallerde fonogramların temsil edilmesi ve yayınlanması halinde FSEK 80/2.2 ye göre fonogram yapımcısından izin alınmasına gerek olmayıp; ona yalnız ödemede bulunulması yeterlidir demektedir¹⁰⁹.

Öncelikle fonogram yapımcılarının temsil hakkı Yazarın dediği gibi FSEK 80/2.2 de değil 80. maddenin B bendinin 3 no’lu kısmındadır. Bu düzenleme “*fonogram yapımcısı, icraların tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla veya ...diğer biçimlerde umuma ... sunulmasına ... izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir*” şeklindedir (ki yazar bu maddede temsil hakkının olduğunu aynı eserde bir önceki sayfada söylemektedir). FSEK 41. maddesi de açıkça ve umumi mahal/yerlere özel bir düzenleme ile; “*umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapımlar ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır*” dediği için (yasa koyucu FSEK 41’de eser sahibi dememiş ve fonogram yapımcılarını da kapsamak amacıyla hak sahibi demmiştir) fonogram yapımcılarının; radyo, televizyon ve diğer yollarla fonogramlarının kullanılması ve umumi mahallerde gösterilmesi halinde izin verme ve yasaklama yetkisi şüphesiz olarak bulunmaktadır. Yazar, icracı sanatçılar açısından da benzer yorumda bulunduğu için orada da

¹⁰⁹ Bkz. ARKAN, age., s. 155 vd.

bu konuya değinilmişti. Daha geniş açıklama için o bölüme bakmanızı da öneririz. Eklemeliyiz ki, 2010 yılı itibarıyla ülkemiz açısından; gerek fonogramların doğrudan cd ve kasetten çalınması ve gerekse fonogramların ve müzik kliplerinin radyo ve televizyonlardan gösterimi sebebiyle fonogram yapımcılarının temsil hakkı için umumi mahallere izin verme sistemi oturmaya başlamıştır. Fonogram yapımcıları ile birlikte diğer hak sahipleri ile toplu müzik eseri kullanımı sözleşmeleri imzalayan mağazacı dernekler, otel dernek ve birlikleri önemli sayıda umumi yerin toplu olarak lisanslanmasını sağlamışlardır.

ARKAN, fonogram yapımcılarının temsil için izin hakkı olmadığı, sadece bir bedel alabileceği yönündeki görüşlerini Roma Anlaşması başta olmak üzere uluslararası sözleşmelere dayandırmaya çalışmaktadır. İcracı sanatçıların hakları anlatılırken geniş olarak bahsettiğimiz gibi Roma Sözleşmesi 1961 yılının koşullarını taşımaktadır. Geçen 50 yıl içinde hazırlanan diğer uluslararası sözleşmelere baktığımızda bağlantılı hak sahiplerine Roma Sözleşmesi'ne nazaran çok daha fazla haklar verildiğini görmekteyiz. Uluslararası sözleşmelerin yapılma gayesi, ülkelere fiktisel ve sanatsal haklar konusunda olmazsa olmaz kuralları göstermektir. Diğer ülkeler gibi ülkemiz de bu olmazsa olmaz kuralların yanı sıra gelişmiş birçok ülkedeki gibi icracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları haklarını kullanmak isteyenler için onlardan izin alma zorunluluğunu getirmiştir. Sözleşmelerdeki kurallara nazaran hak sahipleri için daha geniş koruma yöntemleri getirilebileceği; Roma Sözleşmesi'nin 21. maddesindeki ***“Bu Sözleşme tarafından öngörülen koruma, icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının ve yayın kuruluşlarının başka şekilde yararlanabilecekleri korumaya halel getirmez”*** düzenlemesi ve 22. maddesindeki ***“Akit devletler, icracı sanatçılara, fonogram yapımcılarına veya yayın kuruluşlarına, bu Sözleşmedeki haklardan daha kapsamlı haklar tanıyan veya bu Sözleşmeye aykırı bulunmayan diğer hükümleri içeren özel anlaşmalar yapma hakkını saklı tutarlar”*** düzenlemesi ile ortaya konulmuştur. Sözleşmelerle sadece olmazsa olmaz asgari kuralları koyma amacı; Bern Sözleşmesi'nden sonra hazırlanan Roma Sözleşmesi, WIPO sözleşmeleri ve AB direktiflerinin hepsinde sürdürülmektedir. İşte uluslararası sözleşmelere uygun hazırlanan bizim Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'muz, daha sonra ortaya çıkan uluslararası hukuk sözleşme ve kurallarındaki gelişmeler paralelinde bağlantılı hak sahiplerine, uygun bedel alma asgari koruması yanında, ülkemizdeki yaygın telif hakları ihlalleri sebe-

biyle izin ve yasaklama yetkilerini de kapsayan daha geniş hukuki koruma kurallarını ve hakları tanımıştır. Ayrıca ARKAN'ın tüm örneklerinde kullanmış olduğu Alman Fikri Haklar Kanunu Almanya'nın tercihidir.

Fonogram yapımcıları; temsil hakkı doğrultusunda fonogramları kullanacaklara izin verme ve yasaklama hakkını kullanabilecekleri gibi, FSEK madde 41 gereğince, verecekleri izinlerin karşılığında bir bedel alma haklarına da sahiptirler. Bu bedeller FSEK 41 gereğince meslek birliklerinin belirlemiş oldukları tarifeler uyarınca kullanıcılardan tahsil edilmektedir. Fonogram kayıtlarındaki müzik eserlerini kullanmak için fonogram yapımcısından izin alınmaması halinde, kullanımın yasaklanması, maddi ve manevi tazminat ödenmesi söz konusu olur. Ek olarak FSEK 71/1 hükmü gereğince ilgililerin hapis ve para cezası ile karşılaşacağını da eklemekte yarar görüyoruz.

Eğer eser sahipleri ve icracı sanatçılar kendi icralarının tespitleri açısından temsil hakkına ilişkin haklarını veya tüm haklarını fonogram yapımcılarına devretmemişlerse umumi mahallerde müzik eserlerini kullanmak isteyen işletmeciler için, sadece fonogram yapımcılarının izni yeterli olmaz. Bu durumda eser sahiplerinin ve icracı sanatçıların da iznine gerek vardır. Eğer müzik yapımcısı eser sahibinin ve icracı sanatçının temsil hakkını tespitler için devralmışsa o zaman sadece fonogram yapımcısından izin alınarak temsil konusu haklar kullanılabilir.

4. Umuma İletim Hakkı

2001/29/AT sayılı AB “Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Direktif”in girişinde;

“(9) Fikri yaratım anlamında çok önemli olduklarından, telif hakları ve bağlantılı haklarda her uyumlaştırmanın yüksek seviyede bir korumayı temel alması gerektiğinden; bunların korunmasının eser sahiplerinin, icracı-sanatçıların, yapımcıların, tüketicilerin, kültür, endüstri ve en geniş anlamda kamunun menfaatine olarak yaratıcılığın korunması ve geliştirilmesinin sağlanmasına yardım ettiğinden; bu yüzden fikri mülkiyetin mülkiyet hakkının ayrılmaz bir parçası olarak tanındığı,

(10) Yazarlar ve icracı sanatçılar, yaratıcı ve artistik eserlerini sürdürmek durumunda olduklarından, eserlerinin kullanımı için, yapımcılar da bu eserleri finanse edebilmek için uygun bir karşılık almaları zorunlu olduğundan; fonogram, film ya da multimedya ürünleri gibi

ürünlerin ve talep üzerine hizmetler gibi hizmetlerin üretilmesi için gereken yatırım dikkate değer olduğundan; bu yatırımların tatmin edici bir şekilde geri dönüşleri için fırsat temin etmek ve adı geçen karşılıklar gibi karşılıkları garanti etmek için, fikri mülkiyet haklarının yasal olarak yeterli derecede korunması gerekli olduğu” sebepleriyle işbu Direktifin çıkarıldığı belirtilmektedir.

Direktif 3. maddesi ile umuma iletimin bir bölümü için; “Üye devletler, tel üzerinden veya telsiz vasıtalarla eserlerini yayınlama, böyle bir yolla kamuya bireylerin tercih ettikleri bir zamanda ve bir yerden erişebilme münhasır haklarını, fonogram üreticileri, kendi fonogramları ...için korur” şeklinde düzenleme yapmış ve 8. maddesinde “üye devletler, bu Direktifte düzenlenen haklar ve sorumlulukların ihlali halinde başvurulacak uygun yaptırım ve hukuki yolları sağlarlar ve bu yaptırım ve hukuki yolların uygulanmasını temin etmek amacıyla gereken her türlü önlemi alırlar. Bu şekilde sağlanan yaptırımların etkili, orantılı ve caydırıcı olması sağlanır” şeklinde üye devletlere hakları etkili bir koruma sistemi oluşturma yükümlülüğü yüklemiştir.

Müzik eserleri açısından umuma iletim günümüzde üç biçimde gerçekleşmektedir. Bunlar; “yayın”, “yeniden yayın” ve “kamunun erişimine sunma”dır. Şimdi bu üç umuma iletim hakkını ayrı ayrı inceleyelim.

a. Yayın ve Yeniden Yayın

Yayın ve yeniden yayın kavramları, çalışmamızda icracı sanatçıların aynı haklarına ilişkin bölümde detaylı olarak incelendiğinden, tekrardan kaçınmak için burada söz konusu kavramlar hakkında kısaca açıklama yapmakla yetineceğiz.

Bilindiği gibi Türk Hukuku açısından **yayın**, görüntü ve/veya seslerin radyo, televizyon gibi radyo dalgaları, uydu veya kablo ile yani telli, telsiz araçlarla yayın yapan bir kuruluş tarafından kamuya iletilmesine; **yeniden yayın** ise; bir yayın kuruluşunun yaptığı yayının, bütünü-nün veya bir bölümünün başka bir yayın kuruluşu tarafından alınarak; yayın yapan kuruluşla aynı anda ya da daha sonra umuma iletilmesine denir. Burada sözü edilen, son tüketiciye ulaşan yayınlardır. Örneğin, bir vericinin uyduya gönderdiği yayın teknik anlamda yayın sayılmaz. Günümüzde yayın ya telsiz (radyo-hertezien dalgaları ile/ karasal) ya telli (kablolu) şekilde veya uydudan yapılmaktadır. Bir müzik eserinin talep üzerine elektronik olarak, televizyon veya bilgisayar ortamına getirilme-

sini sağlayan talebe bağlı iletimler de teknik anlamda yayın olmakla birlikte fikirsel ve sanatsal haklar açısından yayın kapsamında değil “kamunun erişimine sunma” kapsamında değerlendirilirler. Gerçekte dolaylı temsilin bir türü olan yayın, gelişen teknoloji sayesinde kazandığı önem dolayısıyla birçok mevzuatta bağımsız olarak düzenlenmiştir¹¹⁰.

Bu kısa girişten sonra uluslararası düzenlemelere bakalım:

Roma Anlaşması’nın icraların tespitlerinin kullanılmasına ilişkin 7. maddesinin 2. kısmında;

“(1) İcracı sanatçının, yayına izin vermesi halinde yayın tekrarlarına, yayın amacıyla yapılacak tespitlere ve böylece bir tespitin yayın amacıyla çoğaltılmasına karşı öngörülecek koruma, ülkesi üzerinde koruma istenilen akit devletin ulusal mevzuatı ile düzenlenir...” şeklinde düzenlenmiştir.

Roma Sözleşmesi’nin 12. maddesi ise; *“Ticari amaçlarla yayımlanmış olan bir fonogram veya bunun çoğaltılmış nüshaları, doğrudan doğruya radyo ve televizyon yayınları veya umuma arz için kullanılmışsa, kullanan tarafından, icracı sanatçılara veya fonogram yapımcılarına veyahut her ikisine bir defaya mahsus olmak üzere makul bir ücret ödenir. Söz edilen ilgililer arasında anlaşma mevcut olmadığı takdirde, bu ücretin taksim şekli ulusal mevzuat ile tayin edilebilir”* düzenlemesine sahiptir.

Roma Anlaşması’ndaki en büyük eksiklerden biri olan fonogram yapımcılarından yayın için izin alma zorunluluğunun eksikliği, diğer komşu hak sahipleri ile birlikte fonogram yapımcılarının aleyhine olarak “onların izin verme haklarının olmadığına ve sadece bir bedel alma haklarına sahip olduklarına” dair yorumlarının dayanağıdır¹¹¹. Öte yandan yapımcıların umuma iletim hakkı konusunda “bedel alma” dışında ayrıca izin verme haklarına sahip olduklarını dolaylı olarak belirten hüküm ise; WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 14. maddesindeki *“gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim sağlayabilecekleri*

¹¹⁰ ARKAN, age., s. 160

¹¹¹ Bizim bu yoruma katılmadığımızı ve WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması olmasaydı bile, Roma Anlaşması Türk Hukukundaki FSEK 80 ile birlikte yorumlandığında, icracı sanatçıların ve fonogram yapımcılarının icra ve tespitlerinin kullanılmasında onlardan izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığına ilişkin yorumlarımızı genişçe “VI.A. İcracı Sanatçıların Hakları” başlığındaki “e. Umuma İletim Hakkı” adlı bölümde bulabilirsiniz.

şekilde, fonogram yapımcıları, fonogramlarının telli veya telsiz araçlarla topluma iletilmesinde münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır” düzenlemesidir. Burada her ne kadar gerçek kişilere yönelik kamunun erişimine sunma hakkı hedeflenmişse de maddedeki “telli ve telsiz araçlarla topluma iletim” yayın hakkını da kapsayacak şekilde kolayca yorumlanabilir.

Tespitlerin kullanılması için fonogram yapımcılarının izin haklarının yanı sıra “bedel alma” haklarını gösteren bir başka düzenleme ise; WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 15. maddesinde “(1) İcracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları, topluma iletilme ya da radyo ve televizyonla yayınlanması için ticari amaçlarla yayımlanmış fonogramların doğrudan ya da dolaylı kullanımı karşılığında tek ve hakkaniyetli bir ücret hakkından yararlanırlar.

(2) Akit taraflar, ulusal mevzuatlarında icracı sanatçı, fonogram yapımcısı veya her iki tarafın kullanıcıdan tek ve hakkaniyetli bir ücret talep edebileceğini öngörebilirler. Akit taraflar icracı sanatçı ve fonogram yapımcısı arasında bir anlaşmanın mevcut olmaması halinde, tek ve hakkaniyetle ücretin sanatçı ve fonogram yapımcısı arasında paylaştırılmasına ilişkin şartları ulusal mevzuatlarında kabul edebilirler.

(3) Akit taraflardan herhangi biri, WIPO Genel Müdürlüğüne tevdi edebilecekleri bir bildirim ile (1) inci paragraf hükümlerinin yalnızca bazı kullanımlarda uygulanacağını ya da bu hususu başka bir şekilde sınırlandıracağını ya da bu hükümlerden hiçbirini uygulamayacağını beyan edebilir.

(4) Bu madde çerçevesinde gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim sağlanacak şekilde telli ya da telsiz araçlarla toplumun kullanımına sunulmuş fonogramlar ticari amaçla yayınlanmış kabul edilecektir” şeklinde düzenlenmiştir.

92/100/AET sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi”nin 8. maddesinde “Yayın ve Kamuya İletim” şu şekilde düzenlenmiştir:

“2. Üye devletler, ticari amaçlarla yayınlanan fonogramı ya da bu nevi fonogramın çoğaltımını kablosuz yöntemlerle yayın ya da kamuya iletim amacıyla kullanılıyorsa, tek adil bedelin kullanıcı tarafından ödenmesini sağlamak ve söz konusu bedelin ilgili icracılar ve fonogram yapımcıları arasında paylaşılmasını sağlamak için hak sağlarlar. Üye devletler, icracılar ve fonogram yapımcıları arasında anlaşma olmaması

durumunda, söz konusu bedelin onlar arasında paylaşılmasını belirleyen şartları düzenlerler.

3. Üye devletler, söz konusu iletim kamuya açık alanlarda giriş ücreti karşılığında yapıyorsa, yayın kuruluşlarına yayınlarının kablosuz yöntemlerle çoğaltımı ya da kamuya iletimi münhasır hakkını sağlarlar”.

93/83/AET sayılı Uydu Yayınları ve Kablo ile Yeniden İletime Uygulanan Telif Hakları ve Telif Haklarına İlişkin Belirli Kuralların Koordinasyonu Hakkında Konsey Direktifi’nin 4. maddesine göre;

“1. Uydu yoluyla kamuya iletim bakımından icracıların, fonogram yapımcılarının ve yayın kuruluşlarının hakları, 92/100/AET numaralı Direktifin 6, 7, 8 ve 10. madde hükümlerine uygun olarak korunacaktır.

2. 1. Fıkranın amaçları doğrultusunda, 92/100/AET numaralı Direktifte geçen “kablosuz araçlarla yayınlama”, uydu yoluyla kamuya iletimi de kapsayacak şekilde anlaşılacaktır.

3. 1. Fıkra da anılan hakların kullanılması yönünden, 92/100/AET numaralı Direktifin 2(7) ve 12. Maddeleri uygulanacaktır”.

“Uydu Yayınları ve Kablo ile Yeniden İletime Uygulanan Telif Hakları ve Telif Haklarına İlişkin Belirli Kuralların Koordinasyonu Hakkında Konsey Direktifi”nde her ne kadar yeniden iletim tek başına ele alınmamışsa da kablo ile yeniden iletim düzenlenmiştir. Direktifte geçen kablo ile yeniden iletim; “bir başka üye devlette kamuya iletmek amacıyla kablo ile veya uydu da dahil olmak üzere kablosuz yoldan ilk kez yayınlanan televizyon ya da radyo programlarının, kablo ya da mikro dalga sistemi ile değişiklik ve kesintiye uğratılmaksızın, eşzamanlı olarak yeniden iletilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Direktif’in “Kablo ile Yeniden İletim” başlığındaki 8. maddesine göre; “1. **Üye devletler**, başka bir üye devletteki yayınların kendi bölgelerinde kablolu yayında yeniden iletilmesi hallerinde, telif hakları ve bağlantılı haklara ilişkin kurallara uyulmasını ve **yeniden iletim telif hakkı ve komşu bağlantılı hak sahipleri ile kablo operatörleri arasında toplu ya da bireysel sözleşmelere dayanmasını sağlayacaklardır**.

2. 1. Fıkra hükmüne bakılmaksızın, üye devletler, 31 Temmuz 1991 tarihinde iç hukuklarında geçerli ya da uygulanan zorunlu lisans sistemlerini, 31 Aralık 1997 tarihine kadar muhafaza edebilirler”.

Aynı Direktif’in “Kablo ile Yeniden İletim Hakkının Kullanılması” başlığındaki 9. maddesine göre; “1. Üye devletler, telif hakkı ve

bağlantılı hak sahiplerinin kablo operatörlerine kablo ile yeniden iletim izni verme ya da bunu reddetme hakkını, sadece meslek birlikleri vasıtasıyla kullanabilmelerini sağlayacaklardır.

2. Bir hak sahibi haklarını bir meslek birliğine devretmediği takdirde, aynı kategorideki eserler üzerindeki hakları yöneten meslek birliği, o hak sahibinin haklarını yönetmeye yetkili kılınmış sayılacaktır. Aynı kategorideki eserler için birden fazla meslek birliği varsa, hak sahibi, hangi meslek birliğinin haklarını yönetme konusunda yetkili olacağını belirlemekte serbest olacaktır. Burada sözü edilen hak sahibi, haklarını yönetmeye yetkili kılındığı varsayılan meslek birliği ile kablo operatörü arasındaki sözleşmede belirlenen hak ve yükümlülüklerden, kurumu bizzat yetkili kılan hak sahipleri ile eşit olarak yararlanır ve bu hakları, hak sahibi olduğu eseri ya da korunan başka değerleri içeren kablolu yeniden iletimin yapıldığı tarihten itibaren üç yıldan az olmamak üzere, üye devlet tarafından belirlenecek süre içinde talep edebilir”.

FSEK 80. maddesinin fonogram yapımcılarının haklarını düzenleyen B bendindeki 1 no’lu fıkrasına göre; “...**yapımcılar** tespitlerinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla **umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir”.**

Özellikle 2004 yılında FSEK’de yapılan değişiklikle getirilen 43. madde yayın ve yeniden yayını şu şekilde düzenlemiştir:

*“**Radyo-televizyon kuruluşları**, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin almak zorundadırlar.*

*Bu kuruluşlar **sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak** ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek **zorundadırlar.***

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren radyo-televizyon kuruluşları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, anılan Kanun dışında kalan ve yayın ve/veya iletim yapan diğer kuruluşlar ise Bakanlık tarafından sınıflandırılır.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram ve yapımların yayın ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile kuruluşlar arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılan müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

Meslek birliklerinin temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bildirim zorunluluğu, tarifelerin belirlenmesi, duyurulması, müzakere edilmesi, sözleşme yapılması, uzlaşmazlıkların halli ve diğer hususlarda bu Kanunun 41 inci maddesinin dört ilâ onüçüncü fıkraları uygulanır. Ancak yayın ve/veya iletim yapan kuruluşlar bakımından 41 inci maddenin altıncı fıkrasının son cümlesinin uygulanması zorunlu değildir.

Ayrıca, 41 inci maddenin 10 uncu fıkrasının uygulanması bakımından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yayınlarında yer verdiği eser, icra, fonogram ve yapımları her üç ayda bir meslek birliklerince belirlenen yıllık tarifenin 1/4'ünü yatırmak suretiyle kullanabilir”.

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 12. maddesine göre ise; “Aşağıdaki durumlarda ses taşıyıcısı yapımcısından yazılı izin alınması zorunludur...

c) Ticari dolaşıma konmuş ses taşıyıcılarının radyo ve televizyon kuruluşları ya da başka kuruluşlar tarafından yayınlanması ...”

Görüldüğü gibi Türk Hukuku, uluslararası hukuk kuralları ve AB Direktiflerinde belirlenen asgari kuralların da üzerinde FSEK 80 ve 43. maddelerinde ve Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 12. maddesinde; yayınlarında fonogram yapımcılarının tespitini yapmış oldukları müzik eserlerini ve müzik kliplerini yayınlamak ve yeniden yayınlamak isteyen radyo ve televizyonların ve diğer kuruluşların fonogram yapımcılarından izin alma zorunluluğunu ve onlara bedel ödeme yükümlülüğünü getirmiştir. Fonogram yapımcıları, kendilerinden izin alınmadan fonogramları ve müzik klipleri kullanılarak radyo ve televizyonlarda ya da başka araçlarda yayın veya yeniden yapılması halinde, bu yayınları yasaklama hakkına da bu yasal düzenlemeler doğrultusunda sahiptir.

Mahkemeler ve Yargıtay, fonogram yapımcılarının yayın için izin verme hakkına aykırı biçimde televizyonlarda izinsiz yayın yapılması üzerine duraksamadan bu hukuka aykırı yayınları durdurmaktadır.

“Davacı vekili, müvekkilinin FSEK'nun 42. maddesine göre kurulmuş bir meslek birliği olduğunu, üyesi olan fonogram yapımcılarının sahip oldukları hakları müvekkiline devrettiklerini, davalı yayın kuruluşunun müvekkilinin üyeleri tarafından üretilmiş müzik kasetlerini, disklerini ve televizyon kliplerini izin almadan ve bedelini ödemediği TV kanalında yayınladığını, bu tecavüzlerin uzun süredir devam ettiğini, ihtara rağmen vazgeçilmediğini, noterce tespit yapıldığını ileri sü-

rerek, yayımlanmış ve tecavüzün tehlikesine maruz kalan tüm müzik yapıtları açısından FSEK'nun 69. maddesi uyarınca davalı TV kuruluşunun yayınlamada kullanılmasının men'ine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekil, ortada esaslı bir zarar veya ani bir tehlike bulunmaması nedeniyle tedbir kararı verilemeyeceğini, 4116 sayılı Kanun'un 12. maddesine göre, radyo ve TV kuruluşlarının ticaret mevkiine konulmuş olan ve her yerde satılan, kamuya arz edilmiş eserin yayınlanabilmesi için fonogram yapımcısından izin alınmak zorunda bırakılamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, **davalının TV kanalında davacı üyesi fonogram yapımcıların eserlerini izinsiz olarak kullandığı, yayınladığı tespit edilen eserler dışında kalan eserler konusunda yayına ilişkin bir ispat bulunmadığı gerekçesiyle**, davanın kısmen kabulü ile **yayınlandığı tespit edilen eserler yönünden davalının eyleminin davacının mali haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine**, bu eserlerin **icra edilmesinin önlenmesine karar verilmiştir.**¹¹²

Yargıtay, özellikle hukuka aykırılık karinesine ilişkin yukarıda yayınlandığı tespit edilen sınırlı eserler için verdiği yayın durdurma kararlarını değiştirerek, izinsiz yayınlanan eserlerin varlığı halinde sadece o eserler için değil, genel olarak davacının eser ve yapıtlarının kullanılarak yayın yapılmasını durdurma yönünde görüş değiştirmiş ve doğru yapmıştır.

“Davacı vekili, müvekkilinin üyesi olan eser sahiplerine ait eserlerin davalıya ait yayın kuruluşundan izinsiz olarak yayınlandığını ileri sürerek, tüm eserler yönünden **tecavüzlerinin kaldırılmasına ve olası tecavüzlerin önlenmesine** karar verilmesini istemiştir.

Davalı yanıt vermemiştir.

Mahkemece, davalının izinsiz yayınladığı 13 eser açısından tecavüzün önlenmesine karar verilmiş, Dairemizce karar onanmıştır.

Davacı vekili, karar düzeltme istemiştir.

Dava; meslek birliği üyesi fonogram yapımcılarının fonogramlarındaki eserlerden bir kısmının izinsiz yayınlanması suretiyle gerçekleştirilen tecavüzle, oluşması muhtemel tecavüzün önlenmesine ilişkindir.

FSEK'nun 69/1nci maddesindeki tecavüz tehlikesine maruz kalınması halinde eser sahibine tanınan muhtemel tecavüzün önlenmesini dava etme yetkisi, aynı Kanunun 80/1-1-B/1 hükmü uyarınca mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme izin verme hususunda mün-

¹¹² Yargıtay 11. H.D., 03.05.2004, E.2003/11026, K. 2004/4809

hasıran yetkili hale gelen eser sahibinin haklarına komşu hak sahibi davacı fonogram yapımcıları meslek birliğine geçmiştir.

FSEK'nun 76/son maddesinin açık hükmü karşısında davacı meslek birliğinin, eser işletme belgesine sahip fonogram yapımcılarından alınmış yetki belgeleri, **bu eserlerden bazılarının yayınlandığının tespit edildiği noter tespit belgeleri gibi**, davacı tarafından iddianın doğruluğu hakkında kuvvetli kanaat oluşturacak delillerin ibrazından sonra, Mahkemenin verdiği sürede Kanunda öngörülen izin ve yetkilerin alındığına dair liste ve belgeleri sunamayan davalının, **yayınlanan eserleri, fonogram yapımcılarına ait tüm fonogramlarındaki eserlerinin haksız kullanımı konusunda davalı aleyhine karine teşkil etmiştir.**

O halde, **eseri yayınlanan birlik üyesi müzik yapımcılarından alınan yetki belgelerinin düzenlenme tarihi itibarıyla bu belgelerin kapsamına giren müzik eseri işletme belgesi, fonogramların ve bunların içeriklerinin neler olduğunun tayin olunacak uzman bilirkişi ya da bilirkişilere tespitinden sonra oluşacak sonuca göre mevcut ve muhtemel tecavüzün önlenmesine karar verilmesi gerekirken, sadece yayınlandığı belirlenen fonogramlar bakımından davanın kabulü isabetsiz olmuştur.**

Mahkemece, yukarıda açıklandığı biçimde inceleme yapılarak sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeyle hüküm tesisi yerinde görülmemiş olmakla davacı vekilinin karar düzeltme itirazının kabulü ile Dairemiz 2003/11026 2004/4809 sayılı onama kararını kaldırarak kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.¹¹³

Günümüzde uluslararası anlaşmalardaki asgari korumalar artık birçok ülkelerde uygulanıyor; ama gelişmiş ülkeler -kendi yaşam kaliteleri için- ya da bizim gibi telif haklarını ödeme bilincinin yaygınlaşmadığı ve aşırı fikri hak ihlallerinin yaşandığı bazı ülkeler çok daha fazla yasal korumayı ulusal mevzuatlarına koyup, fikri ve sanatsal mülkiyette ihlal, haksızlık ve hırsızlıkların önüne geçiyorlar.

Bu bakış doğrultusunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; 1995'e kadar sadece asgari koşulları taşıırken, 1995, 2001 ve 2004 yıllarında dünya kamuoyunun da baskısıyla kendi vatandaşlarının ve diğer ülke eser yaratıcılarının ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını en iyi şekilde koruyan bir yasal düzenleme altyapısına kavuşmuştur. 1995 yılındaki değişiklik yapılırken Gümrük Birliği metinleri ve Roma Sözleşmesi esas alınırken, 2001 yılında yapılan değişiklikte Avrupa Birliği direktifleri ve WIPO sözleşmeleri (o tarihte henüz imzalanmasa bile) çağdaş bir kanun yapmak için ülkemize getirilmiştir. Ayrıca cezalar ve ihtiyati tedbirler

¹¹³ Yargıtay 11. H.D., 23.12.2004, E. 2004/11439, K. 2004/1277.

konusunda TRIPS Andlaşmasındaki ve AB direktiflerindeki bazı caydırıcı ve önleyici hükümler Kanuna dahil edilmiştir.

Bugün itibarıyla, **Türk Hukuku**; temel hak ve özgürlüklerden biri olan fikirsal ve sanatsal mülkiyet hakları alanında **milletlerarası antlaşmalarla belirlenen asgari koşulları (hakları) tanımış** ve buna ek olarak da WIPO Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa Birliği direktiflerini de göz önüne alarak bazı ek hak ve teminatları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na dahil etmiştir. FSEK'de 4630 sayılı Kanunla yapılan 2001 değişikliğinin “gerekçe”lerine baktığımızda; WIPO Telif Hakları Sözleşmesi ve WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi ile AB direktiflerinden açıkça bahsedilerek bu değişikliklerin getirildiğini görürüz.¹¹⁴

Roma Sözleşmesi'nin 2. maddesine, AB Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin 22.05.2001 tarihli ve 2001/29/AT sayılı Direktifi'nin 2. maddesine, WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına ve FSEK 80. madde hükümlerine baktığımızda; her bir hak sahibi topluluğun (eser sahipleri, icracı sanatçılar, fonogram ve film yapımcıları ile radyo ve televizyon kuruluşları) kendi yaratımı/ ürünü/ çabası üzerinde hak sahibi olduğunu görmekteyiz¹¹⁵. Hak sahipleri; tespit, çoğaltma, yayma, temsil, işleme, umuma iletim, kamunun erişimine sunma gibi çeşitli hak kullanım alanlarına sahiptir. Bu hak kullanım alanlarında hak sahipleri; izin verme, yasaklama ve bedel talebi haklarına sahiptirler.

İstanbul Mahkemelerinin yeniden iletim haklarına ilişkin aşağıdaki kararı da ilgi çekicidir.

“Davalı D.. Platform İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında; 2002 yılında hem kendine ait D... adlı dijital uydu platformunda yer alan diğer yayın kuruluşlarına ait radyo ve televizyon kanallarında davacı meslek birliğinin repertuarında yer alan fonogramları izin almadan yayın-

¹¹⁴ *En Son Değişikliklerle FSEK, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 150 madde 80'nin gerekçeleri.*

¹¹⁵ *22.05.2001 tarihli ve 2001/29/AT sayılı “AB Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Direktif”, 3. maddesi ile; umuma iletimin bir bölümü için, “Üye devletler, tel üzerinden veya telsiz vasıtalarla eserlerini yayımlama, böyle bir yolla kamuya bireylerin tercih ettikleri bir zamanda ve bir yerden erişebilme münhasır haklarını,*
(a) icracı-sanatçılar , kendi icralarının düzenlemesi;
(b) fonogram üreticileri , kendi fonogramları;
(c) filmleri düzenleyen ilk üreticiler, kendi orijinal filmleri ve kopyaları;
(d) yayın kuruluşları, kendi yayınlarını kablo veya uydu yayını da dahil olmak üzere, kablo üzerinden veya karasal üzerinde iletip iletmeme düzenlemesi;
için korur” şeklinde düzenleme yapmıştır.

lanmak suretiyle yeniden iletimi gerçekleştirdiği gerekçesi ile hem de kendisine ait radyo ve/veya televizyon kuruluşlarıyla veya bir takım ... isimler altında gerçekleştirdiği yayınlarda doğrudan iletim suretiyle davacının repertuarında yer alan fonogramları izin almadan yayınladığı gerekçesi ile İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2002/229 E. no'lu dosyası ile müdahalenin men'i davası açılmıştır. Bu dava 25.12.2007 tarihinde karara bağlanmış ve davacının lehine sonuçlanmıştır. Mahkeme; dava tarihi itibarıyla davacıya üye olan 42 adet fonogram yapımcısına ait fonogramların D... adlı uydu platformunda yayınlanmasının önlenmesine karar vermiştir. Mahkeme davalının ... logolu kanallarının doğrudan iletim yaptığını ve bu kanallardan davacıya üye fonogram yapımcılarına ait fonogramların izin almadan kullanılmasının hukuka aykırı olduğunu şu gerekçelerle kararında belirtmiştir: *"...Lisans Yönetmeliğinin 10. maddesinin (a) fıkrasına göre; davalı digital platform işletmecisi; Üst Kuruldan uydudan yayın lisansı ve izni almamış olan programcı kuruluş ile uydu platform işletmecilerinin yayınlarını iletmemekle yükümlüdürler."* Belirtilen fıkra gereğince (digital platform işletmecisi), lisansı tespit edilemeyen yukarıda isimleri belirtilen yayınlar nedeniyle doğrudan sorumludur. Davalı şirketin sahibi olduğu bu tür yayınlarla ilgili sorumluluğunun yayıncı kuruluş sıfatıyla sözkonusu olacağı tartışma götürmez. Zira 80. maddeye göre fonogram yapımcıları tespitlerinin işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir.

Davalı uydu platform işletmecisi sıfatıyla yayıncı kuruluşlardan aldığı yayınları aynı anda veya eş zamanlı olarak abonelerine ulaştırılmasına aracılık etmektedir. Bu işlevi itibarıyla yayıncı kuruluş olmadığı tartışma götürmez.

Lisans Yönetmeliğine göre, davalı platform kuruluşu yayınlara müdahale hakkı bulunmamakla beraber Yönetmeliğin 6/b maddesine göre *"programcı kuruluşlar ve uydu kuruluşlar ve uydu platform işletmeleri yurt içinde ve yurt dışında yapacakları yayınlarda Kanunda, Üst Kurulca çıkan yönetmeliklerde ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalarda belirtilen ilke ve esaslara uymakla yükümlüdür"*.

Davalı platform şirketi, digital platform ile programcı kuruluşlar arasındaki lisans sözleşmesinin 24. maddesinde; programcı kuruluşun program hizmeti ile ilgili bilgileri içeren dosyada bulunması gereken belgeler arasında program hizmetlerinin içeriği, genel yayın planı ve program saatleri ile kablo yayını halinde buna ait bilgilerin bulunması zorunluluğu vardır. 36. maddeye göre de Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulanacağı öngörülmüştür.

Taraflar (yayın kuruluşları) arasındaki sözleşme ile davalı, ücret karşılığı yayıncı kuruluşların yayınlarını iletmeye yükümlülüğü altına girerken, akidinin bu yayınlarla 3. kişilere zarar vermesini önleyici tedbirleri de almakla yükümlüdür.

Fonogram yapımcılarının haklarının FSEK 80. maddesi gereğince koruma altında olması ve özellikle yapımcıların tespitlerinin işareti, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve **yeniden iletimine izin verme konusunda münhasır hak sahibi olmaları**, 43. maddeye göre de radyo televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkanlardan yararlanılarak yayın ve ve/veya iletim yapacak kuruluşlar icra ve fonogram yapımları için ilgili alan meslek birlikleri ile 52. maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak ve söz konusu yayım veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ... zorundadır. **Davalı kuruluş Yasa'nın bu hükmü gereğince, akidi yayın kuruluşları ile sözleşme yaparken onların meslek birlikleri ile sözleşmelerini istemek ve yayınların yasaya uygun gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür.** Zira yayın kuruluşlarının sayısal olarak çokluğu ve bunların sürekli olarak yayın yapmaları nedeniyle de meslek birliğince yıl boyunca 24 saat kesintisiz yayın izlenmesi fiziki olarak imkan dahiinde değildir. Dolayısıyla da bu tür ihlalin önlenmesi ancak sözleşme sırasında platform kuruluşlarının akitleri olan yayın kuruluşlarından bu yayın sözleşmelerini istemeleri halinde mümkün olabilir. Zira yayına müdahale etmeme zorunluluğu ile tecavüz ve suç oluşturuvcu yayınlara vasıta olmamak için yasal tedbirler alma yükümlülüğü farklıdır.

Bu durumda içeriğe müdahale edilmemekte ancak içerikte yasal olmayan unsurların kullanılmaması yönünden karşı akitten yükümlülük beklenmektedir. Zira FSEK 84. maddeye göre, bir işareti, resmi veya sesi nakle yarayan bir alet üzerinde tespit eden veya ticari maksatla haklı olarak çoğaltan yahut yayan kimse aynı işaretin resmin veya sesin üçüncü kişi tarafından yayınlanmasını men edilebilir. Burada davalının bir yayın kuruluşu olmasa da, yayına aracı olması itibariyle yasal yükümlülüklerine uymaması halinde BK'nun *"herkesin haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken iyi niyet kurallarına aykırı davranamayacağına"* ilişkin genel hükümleri gereğince bu yükümlülükler uymayan platform işleticisi de yayıncı kuruluşla birlikte sorumlu olur. Zira ancak bu yöntemle hakların yaygın ihlali önlenebilir. Bu nedenle de davalı tarafın yayın kuruluşlarına ait yayınlara yönelik husumet itirazı haklı bulunmamıştır. Zaten Lisans Yönetmeliği 4. madde "Tanımlar" (n) başlığı altında, uydu platform işletmecisi; uydu platform hizmetini tertip eden yayın kuruluşu olarak tarif edilmiştir. Borçlar Kanunu kapsamında sözleşme hükümleri gereğince tecavüz oluşturan yayınları da teknik olarak önleme imkanına sahip olduğundan tecavüzün önlenmesi davasında taraf ehliyeti vardır. Davalının *"yayına müdahale edememe"* yönündeki itirazı ise ancak tazminat yükümlülüğü yönünden tartışılabilir. Bu dava sadece tecavüzün önlenmesine yönelik olduğundan bunun tartışmasına gerek görülmemiştir.

Böylece bazı yayınların davalı tarafından doğrudan yayınlanması ve diğer yayın kuruluşlarına ait yayınların da fikri hakları ihlal edici içerikte olmaması için yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi

nedeniyle davalının diğer yayın kuruluşlarından bağımsız olarak ... dava yönünden kendisine husumet düştüğü kabul edilmiştir.

Davacı meslek birliği(nin) temsil ettiği, ... fonogramların izinsiz yayınlanmasının önlenmesine karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenle;

...Davacı meslek birliğinin temsil ettiği ve yapımcıları ... belirtilen müzik yapımlarının; izin alınmadan ... logosu ile üyelerine deko-derle dijital yayın yapan televizyon ve radyo yayın kanalında yayınlanmasının önlenmesine, hüküm özetinin Türkiye genelinde yayın yapan yüksek trajlı bir gazetede bir kez ilanına, ... karar verilip teahhüt kılındı¹¹⁶."

Fonogram yapımcısının, üzerinde hak sahibi bulunduğu fonogramlarda bulunan müzik yapıtlarının işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanmasına ve yeniden yayınlanmasına izin vermek hususunda FSEK madde 43 ve 80 gereğince yetkilendirilmiş olması, fonogram yapımcılarının ihtiyati tedbir, ceza ve tazminat davaları gibi FSEK'ten doğan tüm dava ve şikayet haklarını kullanmaları için yeterlidir.

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun yayın ilkeleri ile ilgili 4. maddesinin "o" bendinde; "yayın- larda eser ve bağlantılı hak sahiplerine 5846 sayılı FSEK ile tanınan hakların ihlal edilmemesi"ni radyo ve televizyonlar için bir yükümlülük olarak koymuştur. Kanun 37. maddesinde de; "Radyo-Televizyon kurulu-şlarınınca yayınlanan ve/veya iletilen eser, fonogram ve yapımları kul- lanabilmek için, eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri veya bu kişilerin üyesi oldukları meslek birlikleri ile izin almak üzere sözleşme yaparlar ve bu sözleşme ile belirlenen mali hak bedellerini öderler. Bu sözleşme ve ödemeler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ilgili hü- kümleri çerçevesinde yapılır. Bu madde hükümlerini ihlal eden yayın kuruluşları hakkında ayrıca bu Kanunu'nun 33 üncü madde hükümleri uygulanır" diyerek, Kanuna uyulmaması halinde RTÜK'ün yayın kurulu-şlarına uyarı, program durdurma, para cezaları ve sonunda yayın izni- nin iptaline kadar varan cezalar verebileceğini belirtmektedir¹¹⁷.

¹¹⁶ T.C. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 25.12.2007 Tarih, E. 2002/229, K. 2007/355.

¹¹⁷ 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun'un 33. maddesi şöyledir:

Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve bu Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâl konulu olan programın yayını, bir ilâ oniki kez arasında durdurulur. Cezaya yol açan fiilde sorumlulukları belirlendiği takdirde yapımcısı ve varsa sunucusu da bu süre içerisinde hiçbir ad altında başka bir program yapamaz ve sunamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlatılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Aykırılığın tekrarı hâlinde;

a) Ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara, ihlâlin ağırlığına göre, ikiyüzellibin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla beşyüzbin Türk Lirasına kadar,

b) Yerel, bölgesel ve kablo ortamından yayın yapan kuruluşlara;

1. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, bir milyondan fazla nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, yüzyirmibin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla ikiyüzbin Türk Lirasına kadar,

2. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, beşyüzbin ilâ bir milyon arasında nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara ihlâlin ağırlığına göre, otuzbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla altmışbin Türk Lirasına kadar,

3. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibin ilâ beşyüzbin arasında nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, yirmibin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla kırkbin Türk Lirasına kadar,

4. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibinden az nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, beşbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla onbin Türk Lirasına kadar,

c) Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar,

idari para cezası verilir.

İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı hâlinde bu idari para cezaları yarı oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde ikinci kez tekrarında ihlâlin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur.

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılması hâlinde uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur. İhlâlin tekrarı hâlinde yayın süresiz olarak durdurulur ve yayın lisans izni iptal edilir.

Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile ile elde eden kuruluşların yayın lisans izni iptal edilir.

Uyarı cezasını gerektiren hâller dışındaki ihlâllerde ilgili tarafın savunması alınır.

Cezaların uygulanış usulleri ile gerekçeli olarak kamuoyuna duyuruş şekli yönetmelikle belirlenir.”

b. Kamunun Erişimine Sunma

Fikir ve sanat eserlerine yönelik en yeni kurallar; “kamunun erişimine sunma hakkı” adı verilen digital yararlanmalar alanında ortaya çıkmıştır. Önce uluslararası sözleşmeler ve AB direktiflerine konulan bu kurallar daha sonra ülkelerin iç hukuk düzenlemelerine de konu olmuştur. “Kamuya erişim hakkı”; özellikle web yayıncılığı ve bilgisayar ağ ortamlarında (internet) müzik eserlerinin kullanılmasında fikirselsal ve sanatsal hak sahiplerini korumak amacıyla getirilmiştir. Bu kurallar daha sonra, p2p adı verilen dosya paylaşım sistemleri yoluyla müzik eserlerinin izinsiz kullanılmasının yaygınlaşması ve çok ciddi hak kayıplarına neden olması yüzünden daha da geliştirilmiştir. Yine, klasik televizyon ve radyo yayıncılığının değişmesi; dinleyici ve izleyicilerin ne yayınlanırsa onu izlemek yerine, yayınlardaki programları seçebilmeleri, listeleyebilmeleri ve digital recorder aracılığıyla kopyalayabilmeleri sonucunda dinleyip, izlemeleri ya da internet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarından yararlanabilmeleri karşısında yeni hak koruma düzenlemelerine gereksinim duyulmaktadır. Müzik eserleri ve diğer eser türlerinden bu yeni yararlanma biçimleri, hukuk uygulamasına “kamuya erişim hakkı” kavramının girmesine ve yeni eser kullanım biçimlerinin bu kurallar aracılığıyla düzenlenmesine neden olmuştur.

Bu konuda fonogram yapımcıları açısından en temel düzenleme, WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’nın 14. maddesindeki “*gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim sağlayabilecekleri şekilde, fonogram yapımcıları, fonogramlarının telli veya telsiz araçlarla topluma iletilmesinde münhasıran izin verme hakkından faydalananlardır*” düzenlemesidir.

“*Bilgi Toplumunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara İlişkin Belli Konuların Uyumlaştırılmasına Yönelik Direktif*”in giriş kısmında; fikir ve sanat eserlerinin bu yeni kullanım biçimlerinin yer aldığı “kamuya erişim hakkı”na ilişkin düzenleme yapılmasının gerekçeleri geniş şekilde aktarılmıştır¹¹⁸.

Aynı Direktifin 3. 2 no’lu maddesinde “kamuya erişim hakkı” şu şekilde hüküm altına alınmıştır.

“*Üye devletler, tel üzerinden veya telsiz vasıtalarla eserlerini yayımlama, böyle bir yolla kamuya bireylerin tercih ettikleri bir zamanda ve bir yerden erişebilme münhasır haklarını...*

(c) *fonogram üreticileri, kendi fonogramları;... için korur*”.

¹¹⁸ Bu gerekçeleri “VI. A. İcracı Sanatçıların Hakları” bölümünde “Kamunun Erişimine Sunma” hakkı kısmında bulabilirsiniz.

Uluslararası bu düzenlemelere uygun olarak FSEK madde 80/1 no'lu fıkrasında B-3 bendi; *“Fonogram yapımcısı, icraların tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine* izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. Umuma iletim yoluyla tespitlerin dağıtım ve sunulması yapımcının yayma hakkını ihlal etmez” düzenlemesini yapmıştır.

FSEK yine 80. maddede film yapımcılarının haklarını düzenleyen maddeden sonra *“Fonogramlara tespit edilmiş icraların ve filmlerin, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanı sıra, icracı sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlüdürler”* düzenlemesini getirmiştir.

Eğer bu yararlanma biçimi, fonogramların kullanıldığı radyo ve televizyon yayıncısı şirketlerin yayınlarından, izleyicilerin dinlemek veya seyretmek istedikleri programları ve müzikleri listeledikleri şekilde talep üzerine veya internet üzerinde yapılacaksa o zaman ek olarak FSEK 43. maddesinin *“Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları ... sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52 nci maddede uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadırlar”* kuralı da devreye girecektir.

FSEK madde 80'nin ve 43'ün bu düzenlemesi karşısında; web sitelerinde, dosya paylaşım sistemlerinde, seçmeli yayınların seçildiği ve kopyalandığı bilgisayar veya yayın ortamlarında müzik eserlerinden faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşların ya da bunları işleten ve kamuya sunan kişi ve kuruluşların fonogram yapımcılarından veya onların meslek birliklerinden izin alarak sözleşme yapması ve bir bedel ödemesi gerekmektedir.

Bu alanda uygulamada sıkça karşılaşılan konu mp3 adı verilen müzik parçalarının ve mp4 adı verilen müzik kliplerinin sıkıştırılmış hallerinin internet aracılığıyla izinsiz olarak çoğaltılması, gönderilmesi ve

kullanımıdır. Bugün Dünya’da yüzbinlerce mp3, mp4 veya diğer şekillerde hukuka aykırı müzik sunumu yapılan internet sitesi var olduğu söylenmektedir.¹¹⁹ Diğer yandan da hak sahiplerinin telif bedellerinin ödendiği ve yasal kullanım yapılan internet siteleri sayısı hızla artmaktadır. İnternetteki digital müzik pazarı (mp3 ve müzik klipleri) hızla büyümektedir. 2004 yılında plak şirketlerinin digital müzik satışı 300 Milyon dolarken 2005 yılında 1,1 Milyar dolara ulaşmıştır. 2005 yılında tüketiciler plak şirketlerinin haricinde 60 milyon digital müzik satın aldılar ve toplam 9 Milyar dolar ödediler. Ancak yasal olmayan satışlar bunun on katı boyuttadır. 2008 rakamlarıyla internet ortamında yasal kullanım ancak %5 civarındadır, kalanı ise yasalara aykırı kullanımdır.¹²⁰ Müzik piyasası izinsiz müzik eseri sunumuna yönelik olarak 2005 rakamlarıyla 17 ülkede toplam 20.000 adet dava açmıştır.¹²¹ Bu alanda geçmiş yıllarda en önemli ihlaller Napster, Gnutella ve Majo Nation adlı yazılım program ve sitelerinin kullanımı dolayısıyla olmuştur. Napster’e karşı Amerikan Kayıt Endüstrisi (RIAA) tarafından ABD’de açılan davalarda bir dava, Napster’in davanın gidişatını kötü görmesiyle uzlaşmayla bitmiş, açılan bir başka davada ise, Mahkeme Napster açısından, korunan müzik eserlerine ilişkin gözetim ve kontrol mükellefiyeti olduğunu kabul ederek, kopyalanmaya ve umuma iletme izin vermeme görevi yüklemiş ve Napster bu doğrultuda bir filtreleme sistemi oluşturmuştur. Sony ve Universal Müzik gibi büyük firmalarla Mahkemede anlaşılan Napster bu firmaların eserlerine ilişkin bir filtre sistemi kurarak kopyalama ve indirmeyi engellemiş ve ayrıca diğer bazı müzik eseri üreten firmalarla anlaşarak sistemi paralı hale getirmiştir.

İnternette yapılan ihlaller; ya web sitelerine liste koyarak müzik eserlerinin dinlenmesine ve kopyalanmasına izin verme şeklinde veya kişisel bilgisayarlarda bulunan müzik ve diğer tür fikir ve sanat eserlerine ulaşabilecek p2p veya finder (bulucu) gibi yöntemler sunma şeklinde olmaktadır. İnternet ortamındaki müzik eseri ile ilgili hak ihlallerine karşı, manevi tazminat ve FSEK 68’e göre maddi tazminat davaları açılabilir. Bu tazminat davalarına; Borçlar Kanunu 41. ve 50. maddele-

¹¹⁹ MEMİŞ, *age.*, s. 39 v.d.

¹²⁰ Bu bilgi Münyap Meslek Birliği 2008 Faaliyet Raporu’ndan alınmıştır.

¹²¹ IFPI Digital Music Report 2006

rine göre, internet servis sağlayıcılar ve bilgi depolayıcıları da eğer ihlalden haberdarlarsa ve kontrol imkanları varsa dahil edilebilir¹²².

Aşağıda, bir edebiyat eseri ile ilgili olan ama kolayca müzik eserleri için de kullanılabilecek mahkeme kararını bilginize sunuyoruz. Kararda, hem yayıncı web sitesinin ve hem de bu sitenin internette erişimini sağlayan internet servis sağlayıcısı şirketin yapılan ihlalden dolayı sorumluluğunu görmektesiniz.

“Davacı vekili, müvekkilinin “Çocuk İsimleri Sözlüğü” adlı basılı eserinin davalılarca internet aracılığı ile izinsiz yayımlanarak FSEK’ten doğan hakların çiğnendiğini ileri sürerek, (5) milyar lira maddi (10) milyar manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan ...online A.Ş. vekili, eserin müvekkilince kullanılmadığını, internet sitesinin diğer davalıya ait olduğunu, servis sağlayıcısı olan müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini savunmuştur.

Diğer davalı temsilcisi, davacı kitabının başka yerlerden alıntılarla oluşturulduğundan eser niteliği taşımadığını, talebin fahiş olduğunu savunmuştur.

Mahkemece, davacının yayın sözleşmesine delil tespit dosyasına ve bilirkişi raporuna dayanılarak, **davacıya ait kitabın işleme eser niteliği taşıdığı**, FSEK. 68. maddesine göre istenebilecek **maddi tazminatın 1.965.000.000 TL olduğu, manevi hakların da ihlal edildiği**, davalılardan A.Ş.’nin husumet savunmasının yerinde olmadığı gerekçesiyle anılan miktar maddi ve takdir edilen 2.000.000.000 TL **manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiştir.**

Karar, davalılarca ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve **davalıların eyleminin, uyumsuzluğu doğuran faaliyetlerin gerçekleştiği tarihlerde yürürlükte olan FSEK’in 4630 sayılı Kanun ile değişik 25/2. maddesinde tanımlanan anlamda davacıya ait işleme esere gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişimini sağlamak biçimindeki eser sahibinin umuma iletim hakkına aykırılık oluşturmamasına, davalılar arasındaki sözleşmede davalı servis sağlayıcı şirketin, A.Ş. adlı üçüncü kişilere yönelik hak ihlalden sorumsuz kılınmasının iç ilişkide geçerli olmasına ve davacıya karşı oluşan hukuki sorumluluğu etkisiz kılmayacak bulunmasına göre**, davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir¹²³.”

¹²² Bkz. Gürsel ÖNGÖREN, *İnternet Hukuku*, İstanbul, 2006, s. 172 vd.

¹²³ Yargıtay 11. H.D. 2003/12494 E. 2004/9096 K.

Bu mahkeme kararı, her ne kadar eser sahibinin açtığı dava üzerine verilmişse de, icracı sanatçı, fonogram ve film yapımcısı ve radyo ve televizyon yayın kuruluşları; ihlal edilen kendi hakları için aynı taleplerle dava açarak benzer yasal sonuçlara ulaşabilirler.

Saldırganlara karşı yasal mücadelede en caydırıcı olan FSEK 71. maddesine göre ceza davası açılmasıdır. Ayrıca FSEK Ek madde 4 doğrultusunda; yasalara aykırı, izinsiz fikir ve sanat ürünlerini veya müzik parçalarını bulunduran veya onlara diğer kişilerin ulaşmasına olanak tanıyan internet siteleri için (Türk Telekomdaki filtreleme sistemi veya servis sağlayıcılar aracılığıyla) “internet erişiminin durdurmasını savcılıklardan isteme” önemli bir mücadele yoludur. Müzik eserlerinin kullanıcılara izinsiz olarak ulaşmasını sağlayan web sitelerine ve kişisel sayfalara karşı önemli bir mücadele yöntemi oluşturan FSEK Ek madde 4’deki düzenleme şöyledir:

“Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

Maddi tazminat davalarına bakacak yargıçlar için veya kötü niyetliler için bir örnek verelim: mp3.com adlı siteye karşı RIAA herbir müzik eseri için 150.000 USD olmak üzere toplam 67,5 milyar dolarlık dava açmış ve bu dava kısmen kabul edilerek söz konusu site yöneticileri milyarlarca dolar tazminata mahkum olmuşlardır.¹²⁴ Ayrıca, hak sahiplerinden izinsiz olarak müzik eserlerinin (mp3 ve müzik klipleri

¹²⁴ MEMİŞ, age., s. 127 v.d.

için mp4 formatında) web sitelerinde çoğaltması, indirmesi, dinlemesi veya göndermesi için bulundurmak veya buna uygun olanakları sağlamak yahut en basitiyle web sitesinde fonda bile izin almadan müzik kullanmak veya izinsiz olarak sitelere koyulan müzik eserlerinin kullanımını için eser sahiplerinin maddi veya manevi haklarına aykırı olabilecek şekilde link vermek, dosya paylaşım programlarına olanak sağlamak, müzik veya diğer tür eserlere ulaşılabilmesi için tarayıcılar ve erişimcilerin çalışmasına izin vermek FSEK madde 71 gereğince hapis cezalarına da neden olabilir.

Bu kuralın önemli bir istisnası şahsi kullanımdır.

FSEK 38. maddeye göre, kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanım için bir müzik eserini çoğaltmak ve dinlemek mümkündür. Ancak bu eylem hak sahiplerinin meşru menfaatlerine aykırı ve başkasını yararlandırmak amacıyla yapılamaz. Yani parayla satılan bir eserden bedava yararlanma, başkasına gönderme veya başkalarıyla paylaşım yapılamaz. Şahsi kullanım için kamunun erişimine sunulan müzik eserinden veya müzik klibinden yararlanma hak sahibinin meşru menfaatlerine zarar veremeyeceğinden ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olmayacağından, bu eserlerin veya kayıtların parasız kullanılması, başkalarının kullanabilmesi için sitelere yerleştirilmesi, eserlerin kişisel bilgisayarlarda saklanan kayıtlarının bulunmasına yarayan programların bulundurulması veya eserde başka türlü manevi haklara aykırı kullanımlar yapılması ihlal olarak görülür ve müeyyideleri yukarıda sayılmıştır. Bu konuda Avrupa’da şahsi kullanıcılara birçok dava açıldığını ve şahsi kullanıcıların para cezaları ödediğini duyduğumuzu da belirtelim¹²⁵.

5. Fonogram Yapımcılarının Haklarına İlişkin Ortak Hükümler

FSEK 80. madde; komşu hak sahipleri açısından “**eser sahibinin izniyle**” ve “**icracı sanatçının izni ile**” ibareleriyle “**izin**” adı altında, fikri haklara ilişkin hak alımı yöntemleri olan “devir” ve “lisans”a ek üçüncü bir hak alımı yöntemi ortaya çıkarmıştır.

Müzik yapımcısı FSEK madde 80/B ilk fıkra gereğince, eser sahibi veya icracı sanatçıdan ilk tespit hakkı için bir izin almaktadır. Bizim kanaatimize göre, bu izin, “devir” veya “lisans/ruhsat” değildir. Bu hak alımı, alan kişi açısından “devir”e benzeyen hükümler taşıyan **mutlak**

¹²⁵ ÖNGÖREN, age., s. 177

hak niteliğinde özel bir hukuki durumdur. Bu izin sonucu fonogram yapımcısı fonogramını oluşturur. Oluşturduğu anda da elinde tamamıyla kendine ait, buna izin verenlerin bile hiçbir biçimde müdahale edemeyeceği komşu hak içeren master kayıt vardır. Bu kayıt için daha önce izin verenler ya da mahkeme bile *“sen haklarını kullanmıyorsun, kötüye kullanıyorsun, bu yüzden ses kaydını/fonogramı bana ver”* diyemez. Bu kayıt eser sahibi ve icracıdan izni aldıktan sonra fonogram yapımcısına aittir. Bu açıklamamıza örnek bir karar:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık; dava konusu ve isimleri yukarıda yazılan türkülerin, davacılar ile murisleri Ö.G.’ün izinleri alınmadan, davalı Şirket tarafından kasete tespit edilerek çoğaltılıp dağıtılmasından kaynaklanmaktadır. Uyuşmazlık konusu türkülerin tamamının muris Ö.G. tarafından icra edildiği ve bunlardan *“Çöz de Al Mustafa Ali”* isimli türkü dışındakilerin tamamının ya derleyeni, ya da kaynak kişisi olması nedeniyle sahiplerinin yine Ö.G. olduğu anlaşılmaktadır. ... davacıların mirasbırakanı Ö.G.; (Çözde Al Mustafa Ali) adlı... türkü hariç diğerlerinin hem (eser sahibi) hem de icra eden sanatçısı, *“Çöz de Al Mustafa Ali”* isimli türkünün ise sadece icra eden sanatçısıdır...

... Yasanın anılan maddesinde fonogram yapımcılarının haklarına da yer vermiştir. ... Fonogram yapımcılarının da ... tespit yapabilmeleri için, aynı icracı sanatçılar gibi ilk önce eser sahibinden, hemen arkasından da icracı sanatçıdan izin alması gerekir. Bu olgu FSEK’in 80/1- A ve B maddelerinde açıklıkla vurgulanmıştır. Kuşkusuz eser sahibi ile icracı sanatçının aynı kişi olması halinde tek izin yeterli olacaktır. **Ancak, burada üzerinde durulması gereken “izin” 49. maddede belirtilen “lisans”tan (ruhsattan) oldukça farklıdır. Çünkü ruhsat, eser sahibinden alınacak bir kullanma hakkının devriyle elde edilir ve sahibine kullanma ile yararlanma hakkı verir.** Yine koşulları gerçekleşirse ruhsatın (lisansın) iptali ve feshedilmesi de mümkündür. ... **icracı sanatçının, icrasının tespiti ile ilgili olarak fonogram yapımcısına verdiği ... izinle; fonogram yapımcısı, 80. maddede vurgulandığı gibi mutlak bir hakkı aslen iktisap etmiş olur. Böyle bir izinden geri dönülmesi olanaksızdır. ...**

Bu açıklamalardan sonra somut uyuşmazlığa dönersek; davacıların murisi Ö.G., dava konusu eserlerden *“Çöz de Al Mustafa Ali”* isimli olanı hariç, diğerlerinin hem maliki hem icracı sanatçısı, *“Çöz de Al Mustafa Ali”* isimli türkünün ise icracı sanatçısıdır. ... dosya içinde yer alan ve İstanbul 22. Noterliği tarafından düzenlenen **10.03.1973 tarih ve 1381 yevmiye no’lu izinname ile (icracı sanatçı Ö.G.); dava konusu edilen tüm ilgili icralarının tespiti için ... H. Plak/ M.D.’e izin vermiş, bu iznin karşılığını da o tarihte peşin olarak almıştır.** Aldığı paranın az veya çok olması, arttırılıp arttırılmaması gerektiği bu davanın konusu değildir. Kaldı ki, böyle bir iznin bedelsiz

verilmesi dahi olanaklıdır. Böylece H. Plak/M.D. yapılan bu işlemle; yapımıcılıkla ilgili mutlak hakkını aslen iktisap etmiş olup, bu hakkına dayanarak yapılan tespitle ilgili; takip edecek devir, izin, çoğaltma ve yayma için ayrıca muris Ö.G. veya mirasçıları(ndan izin alması gerekmeyeceği) gibi (Ö.G. ve mirasçılar açısından) verilen bu izinden dilekçede belirtilen nedenlerle dönmek de olanaklı değildir. Nitekim H. Plak/M.D. bu hakkına dayalı olarak önce, Kültür Bakanlığından 9.12.1991 tarih ve 1534 no'lu "Eser İşletme Belgesi" almış, daha sonra da İzmir 10. Noterliğinden tanzimli 30.10.2000 tarih ve 21975 no'lu senetle bu hakkını davalı Şirket'e (A. Müzik Yapım Ltd. Şirketi'ne) devretmiştir. Davalı Şirket de devirden kaynaklanan hakkına dayalı olarak uyuşmazlık konusu kasetleri çoğaltıp yaymıştır. (Davalıların) eylemleri yukarıda geniş bir şekilde açıklandığı gibi tamamen FSEK' in amir hükümlerine uygun olup, davacıların talep ettikleri maddi ve manevi tazminatın koşulları gerçekleşmemiştir. ...Yukarıda açıklanan nedenlerden ve tüm dosya kapsamından, açılan davanın reddine ... dair karar davacı vekilinin huzurunda temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunup anlatıldı." Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin, 15.02.2005 T., E. 2004/38, K. 2005/79 no'lu bu kararı Yargıtay tarafından onanmıştır.

Fonogram yapımcısı tespitini yaptığı kaydı; çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim gibi bir yararlanmanın konusu yapacaksa, bu durumda "izin" işleminin içeriğine bakılır. Yapımcı, eser sahibi ve icracıdan aldığı "izin belgesi" nin içinde yazılı olan (FSEK madde 52'ye göre sayılan) yararlanma biçimlerini (hakları) kullanır. Öte yandan fonogram yapımcısı, eser sahibi veya icracı sanatçıdan aldığı izin kapsamının dışına çıkıp, izin almadığı hakları kullanmaya kalkarsa; o durumda aşağıdaki mahkeme kararında görüldüğü üzere yaptırıma tabi olur.

"Davacı vekili, davalının taraflar arasında imzalanan sözleşme uyarınca plak yapmak için devraldığı ve plak olarak satışa arz edilen müvekkiline ait eseri işleyerek, ses kaseti ve kompakt disk olarak üreterek satışa arz ettiğini belirterek, fazlaya ilişkin hak saklı kalmak kaydıyla %50 fazlasıyla ses kaseti için 1,000,000 lira, kompakt disk için 1,000,000 lira maddi tazminat ile tecavüzden ötürü 10,000,000 lira manevi tazminatın en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, üretimin durdurulmasına, müdahalenin menine ve muhafaza (altına) alınan nüshaların ve kalıpların imhasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemeye, davanın kısmen kabulüyle, 2,000,000 lira maddi tazminatın dava tarihinden itibaren %30 faiziyle birlikte davalıdan tahsiline ve manevi tazminat isteminin reddine ilişkin olarak verilen karar taraflarca temyiz edilmiş, Dairemizin 21.10.1993 tarihli ilamıyla davacı

yararına bozulması üzerine bu kez de davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

1-Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme taleplerinin reddi gerekmiştir.

2-Ancak; (davacı) dava dilekçesinde sadece plak için sözleşme yapıldığı halde, davalının, eserini ses kaseti ve kompakt diske çekme eyleminin manevi tazminatı gerektirdiğini ileri sürerek 1,000,000 lira manevi tazminatın davalıdan tahsili talebinde bulunmuş(tur), ... , dava dilekçesinde **sözü edilen eylem, manevi tazminatı gerektiren bir eylem değildir**. Kaldı ki eserin kolektif bir eser olması ve FSEK'in 70. maddesi hükmüne göre de bilirkişilerce belirtilen hususlar dahi manevi tazminatı gerektiren bir husus olarak kabul edilemez. Bu itibarla davalı vekilinin bu yöne ilişkin karar düzeltme itirazının kabulü ile Dairemizin 21.10.1993 tarihli bozma ilamının (2) no'lu bendinin 6. paragrafında başlayan "**FSEK'in 70. maddesi koşulları olayda oluştuğu ve bilirkişilerce de bu husus doğrulandığı halde davacı tarafın manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi de doğru görülmemiştir**" bölümünün ilamdan çıkarılmasına karar vermek gerekmiştir.¹²⁶

Yargıtay; bir başka kararında fonogram yapımcısına, izin almak için gerçek eser sahibini araştırma yükümlülüğü yüklemiştir.

"Davacı vekili, bestesi ve güftesi müvekkiline ait "**Susun Ağla-yacağım**" isimli eserin, davalılar tarafından "**Koy Koy**" isimli kasette haksız ve izinsiz olarak kullanıldığını, bu nedenle müvekkilinin maddi ve manevi zarar uğradığını ileri sürerek, 80.000.000 TL maddi ve 70.000.000 TL manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir...

Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, "**Susun Ağlayacağım**" isimli eser davacıya ait olup, davalı Z.C. ve yapımcı firma olan diğer **davalı tarafından FSEK'nun 48 ve 52. maddelerine uygun izin alınmadan kullanıldığı, davalı şirketin basiretli bir tacir gibi davranıp gerçek hak sahipliği yönünde araştırma yapmadığı için iyi niyet savunmasının dinlenemeyeceği, tespit edilen zarardan davalıların sorumlu olduğu** gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, davacının mali haklarına tecavüzün önlenmesine, 61.980.000 TL maddi ve 20.000.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden yürütülecek %57 ve değişen oranlardaki reeskont faizi ile **davalılardan müteselsilen tahsiline** karar verilmiştir.¹²⁷

FSEK madde 80/B bendine göre; "... sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları eser sahibinden ve icracı sanatçıdan **mali hakları**

¹²⁶ Yargıtay 11. H.D, 24.2.1994, E. 1994/16, K. 1994/1395

¹²⁷ Yargıtay 11. H.D, 9.6.1998, E. 1998/1638, K. 1998/4351

kullanma yetkisini devraldıktan sonra işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim gibi kendi haklarına sahip olur. FSEK 80. madde B bendinde her ne kadar “mali hakları kullanma yetkisi” ibaresi yazılmışsa da **burada “devir” işleminden bahsedilmektedir**. Fonogram yapımcısının icracı sanatçı ve eser sahibiyle yaptığı devir sözleşmeleri “izin” işlemi ile birleşik olarak aynı yazılı belge ile yapılmaktadır ve genellikle “devir” amacı ve iradesi taşımaktadır. Bu sözleşmelerde ya mali haklar “çoğaltma ve yayma” şeklinde sayma yoluyla ayrıntıya girmeden devredilmekte veya “*plak, kaset, cd ve benzerleri ile sonradan çıkacak diğer tüm kayıt araçlarına tespitiyle/kaydıyla, bu kayıtların (ses tespitlerinin) çoğaltma, radyo, tv ve diğer yollarla yayın ve umuma iletimi*” gibi ayrıntılı açıklanarak devredilmektedir. Zaten bu izin ve mali hakları kullanma yetkisinin devri; komşu hak sahiplerini, “Mali Hakların Devri” bölümünde göreceğiniz Yargıtay 11. Daire kararlarında belirtildiği üzere, adeta mali haklar açısından “eser sahibi” hukuki durumuna eşit ve hatta devirden üstün bir duruma getirmektedir. Eğer haklar fonogram yapımcısı tarafından eser sahibi ve icracıdan devir alınmışsa, müzik eseri ve müzik kliplerinin çoğaltma, temsil, satış ve kiralama ve yayın dahil umuma iletimi için bu kayıtlardan/ fonogramlardan yararlanacaklar için sadece fonogram yapımcısının izni yeterlidir. Bu görüş yapımcı ile eser sahibi ve icracı sanatçının arasındaki sözleşmenin amacına bakılarak, “artık icracı sanatçıdan ve eser sahiplerinden izin dahi almaya gerek yoktur” şeklinde genişletilebilir. Bu görüşümüzün kanıtı da eser sahiplerinin hakkını nitelerken kullanılan üstünlük ifadesi olan “**münhasır**” kelimesinin FSEK 80. maddede komşu hak sahiplerinin hakları için aynen kullanılmasıdır. Yine FSEK 80. maddedeki komşu hak sahiplerine icra ve yapımları üzerinde, eser sahibine ve icracıya karşı bile kullanılabilen izin ve yasaklama hakkı verilmesi bu görüşümüzü desteklemektedir¹²⁸. Bu konuda elimize geçen bir yargı kararında hakim; “izin” kavramını “devir” ve “lisans”tan farklı yorumlayarak, icracı veya eser sahibi tarafından FSEK 80 gereğince kaset yapma izni verilen fonogram ya-

¹²⁸ 11. H.D. 01.02.1999, E.1998/8794, K. 1999/311; ...ruhsatın.. tam ruhsat niteliğinde olduğu ve bu nedenle eser sahibinin çoğaltma ve yayma haklarını bu sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe bir başka kişi ve kuruluşa devredemeyeceği...11.H.D., 12.12.1995, E. 1995/6393, K. 1995/9199; ...dava konusu olan ...şiiri tüm mali hakları ile süresiz olarak devir ve temlik etmiştir. Bu durumda davalı şirket en geniş bir biçimde bu hakları kullanabilir ... Hal böyle olunca davacının...şiiri için hiçbir hakkı kalmadığı sonucuna varılmıştır.

pımcısının mutlak bir hakkı aslen iktisap ettiği, böyle bir izinden geri dönülmesinin olanaksız olduğu, bu nitelikleri sebebiyle izin sahibi fonogram yapımcısının sahip olduğu hakları üçüncü kişiye devir için eser sahibi ve icracı sanatçıdan izin almasının gerekmeyeceğini hüküm altına almıştır.¹²⁹

Buradan çıkan bir başka konu radyo, televizyon ve internette yayın, kamunun erişimine sunma veya yayma gibi mali hakları devralan veya lisans/ruhsat alanların bu hakları üçüncü kişilere devrederken sınırlamalar olup olmadığıdır. Özellikle eser işletme belgesi sahibi müzik ve film yapımcıları açısından devirler uygulamada sık sık görülmektedir. Eğer FSEK 48 ilk fıkradaki “devir” hukuki işlemi yapılmışsa hak, eser sahibinin malvarlığından çıkıp devralanın malvarlığına girdiğinden, bunun üçüncü kişilere devri için tekrar dönüp eser sahibinden izin almaya gerek yoktur. Sözleşmede üçüncü kişilere devirde hiçbir düzenleme yoksa yahut özellikle bir yasak koyulmamışsa böyledir. AYİTER’e göre de işlemeyen başka bir mali hakkın devrinde, eser sahibi mali hakkını A’ya devretmişse A eser sahibinden izin almadan B’ye ve B yine eser sahibinden izin almadan C’ye devredebilir¹³⁰.

Eğer FSEK 48. maddenin ikinci kısmındaki “ruhsat (lisans verme) işlemi yapılmışsa o zaman durumu ikiye ayırmak gerekir.

FSEK 49. maddenin düzenlemesi “*eser sahibi veya mirasçılardan mali bir hak veya böyle bir hakkı kullanma ruhsatını iktisap etmiş olan bir kimse, ancak bunların yazılı muvafakatiyle bu hakkı veya kullanma ruhsatını diğer birine devredebilir*” demektedir. Burada 49. madde “**mali bir hak ... ruhsatı**” ve “**mali bir hakkı kullanma ruhsatı**” şeklinde iki tip ruhsat saymaktadır; 48. maddenin ilk fıkrasındaki “devir” işleminden bahsetmemektedir. Mali hak ruhsatı, kanaatimce, devir hak alımı yöntemindeki hükümlere benzer biçimde “*çoğaltma hakkım konusunda haklarımı ...’ya devrettim*” ibaresi ile yapılabilir ve burada hak sahibinin hakla artık bir ilgisi kalmamıştır. Mali bir hakkı kullanma ruhsatına ise “*çoğaltma hakkını sadece internet için iki yıl süreyle*

¹²⁹ Ankara FSHHM E. 2004/38 K. 2005/79 15.02.2005

¹³⁰ AYİTER, age., s. 209. ve 11.H.D., 12.12.1995, E. 1995/6393, K. 1995/9199; ...dava konusu olan ...şii tüm mali hakları ile süresiz olarak devir ve temlik etmiştir. Bu durumda davalı şirket en geniş bir biçimde bu hakları kullanabilir ve başkalarına devredebilir. Hal böyle olunca davacının...şii için hiçbir hakkı kalmadığı sonucuna varılmıştır...

verdim” örneği verilebilir. Bu konuda başka örnekler üzerinden düşünce üretilebilir. İlk örnekte eser sahibi sözleşmede ek bir madde ile çeşitli olasılıklar doğrultusunda üçüncü kişilere bu ruhsatı geçirme amacı ile izin vermiş olabilir; bu halde fonogram yapımcısının ruhsatı üçüncü kişilere devrine bir engel yoktur. İlk devir edenin verilen haklarla artık bir ilgisi kalmamıştır. Burada eser sahibi ve icracı sanatçı, hakların üçüncü kişilere devri veya devirleri için fonogram yapımcısına toptan bir izin (yetki) verebilir veya her biri için tek tek düzenleme yapılabilir. İkinci örnekte, mali bir hakkı kullanma lisansı sözleşmesinde üçüncü kişilere devir konusunda bir izin verildiği açıkça belirtilmiyorsa; eser sahibi veya mirasçısından A Şirketi ruhsat almışsa bunu B Şirketine devretmek için ayrıca eser sahibinin yazılı muvafakatını işlem öncesi alması gerekir. B Şirketi yine yazılı muvafakatla C’ye ve yine yazılı muvafakat varsa C’ de D’ye devredebilir. Aksi takdirde A Şirketi, FSEK 49 gereği mali hakkı veya kullanma yetkisini B’ye devredemez. Üçüncü örnekte ise sözleşmede üçüncü kişiler için devir yasağı olmasıdır. Bu durumda devir imkanı bulunmamaktadır¹³¹.

Özünde bu konuda FSEK 49 düzenlemesi hatalıdır. Maddede tam ruhsat mı yoksa basit ruhsat mı kastediliyor sorusunun cevabı açık değildir. Bizce, 49. madde sadece basit ruhsatlar için bu kuralı getirmelidir. Zira “tam ruhsat”, “devir” hukuki sonucuna yakın hukuki sonuçları devralan için sağlamaktadır. Ve tam ruhsat bir kere fonogram yapımcısına verilmişse, artık ruhsatı verenden bu hak çıktığından ruhsatı verenin bu hak ile ilgisi kalmamaktadır. Ruhsatı alan kişi bu haklar üzerinde üçüncü kişilere devir açısından serbestçe işlem yapabilir. Nitekim, Yargıtay bu konudaki kararlarında tam bir kararlılık göstermese de görüşümüze uygun kararları da vermektedir. Yargıtay 11. H.D. 15.10.2001, E. 2001/4951, K. 2001/7904 sayılı kararıyla, ölenin sağlığında eserle ilgili haklarını devralan kişilerin, bu hakları devrettiği kişilerin de haklarının korunması gerektiğini ve bu hakların artık ölenin terekesinden çıktığını söylemekte ve bizim “devir” ve “tam ruhsat” için ileri sürdüğümüz mutlak hak görüşümüzü desteklemektedir. Yine 11. H.D. 15.10.2001, E.2001/4928, K. 2001/7866 sayılı kararıyla “...1995 tarihli sözleşme ile...filmlerin SVMEK’den kaynaklanan hakları(nın) film ve negatifleri ile birlikte Kanal ... A.Ş. ‘ne devredildiği, **sözleşmenin 5. maddesi gereğince mülkiyet haklarının alınan şirkete gittiği**, ... işletme haklarının devir ve

¹³¹ 11. H.D. 27.04.1998, E. 1998/1104, K. 1998/2748

*tescil işlemleri yapılmak üzere yetkilendirildiği, bu şekilde **devralınan haklarının Kanal ... A.Ş. tarafından davalıya (bir başka yayıncı olan Y) verilmesi nedeniyle** davacının (filmlerin Kanal ..A.Ş.'dan önceki hak sahibi olan X Şirketinin) tazminat talep hakkı bulunmadığı...”* hüküm altına alınmıştır. Fakat, 11.H.D. 09.06.2003, E. 2003/499, K. 2003/6125 sayılı kararıyla, “...sözleşmede... **eserin tüm yayın haklarının** bu davalıya ait olduğunu kabul etmişse de, yayın haklarının (bir başka) davalıya devredilmesine muvafakati olduğuna dair sözleşmede bir hükme yer verilmemiştir. Oysa eser sahibinin, eserinin yayın hakkını vermiş olduğu aktinin (karşı tarafının) bu hakkı bir başkasına devretmesi için... FSEK 49. maddesi gereğince yazılı olarak muvafakatte bulunması gerekmekte olup...” ibareleriyle tam ruhsata ilişkin devirde eser sahibinden izin alınması gereğini belirtmiştir. Kanatımızca Yargıtay basit ruhsatlar hakkında 2003 tarihli kararını uygulamalı ancak, tam ruhsatlar hakkında 2003 tarihli bu uygulamasını değiştirmelidir.

Devir konusundaki önemli bir tartışma da eser işletme belgelerinin şirketler arasında devredilmesi alanında çıkmaktadır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 18.11.1999 tarihinde verdiği bir kararda, 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu (Şimdi bu Kanun ortadan kaldırılmış ve kullanılmamaktadır) uyarınca, ilgili Bakanlıktan eser işletme belgesi alınmış olmasının, dava konusu eser üzerindeki hakların davacıya devredildiğine dair yeterli kanıt olmayacağını belirtmiştir. Ancak Yargıtay 11. HD., 29.06.1999 tarihli daha eski bir kararında, SVMEK madde 8 maddesi gereğince Kanun kapsamındaki eserler üzerindeki çoğaltma, yayma ve gösterim hakkının işletme belgesi sahibine ait olacağını ve eser üzerindeki her türlü tasarrufun işletme belgesi sahibinin iznine tabi olduğunu, FSEK ve uluslararası sözleşme hükümlerini dikkate almadan katı biçimde uygulanmıştır¹³².

Fonogram yapımcılarının icracı sanatçılardan alacağı “izin” ve “mali hakları kullanma yetkisi” konusunda şu düzenlemeleri de hatırlamakta yarar var. İcra ve gösteri bir orkestra, koro veya müzik grubu tarafından yapılmışsa FSEK madde 80/A-6 gereğince artık münferit sanat-

¹³² Özellikle SVMEK da yer alan ceza hükümleri ve Yargıtay kararları bakımından bakınız; Cevat ÖZEL, “3257 sayılı Video ve Müzik Eserleri Kanunu İle 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Üzerine Bir İnceleme”, (Çevrimiçi) <http://www.turkhukuksitesi.com/faq/3257.shtml>, 24.05.2002. TOPALOĞLU ise, SVMEK md. 5/II'deki tescil kurumunu yerinde bulmaktadır. TOPALOĞLU, age., s. 93).

çılardan değil, sadece o topluluğun *şefinden* izin alınması yeterli olacaktır. Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 9. maddesinde¹³³ de benzer düzenleme vardır. Eğer icracı sanatçı grubu bir müteşebbis (girişimci/organizatör) tarafından çalıştırılıyorsa, şeften başka girişimci/organizatörün de FSEK madde 80/A-7 gereğince izninin alınması gerekir. Şefin ve keza girişimcinin/organizatörün izin verme yetkisi doğrudan Kanun'dan doğmaktadır ve kesindir.

FSEK madde 82 gereğince, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ses taşıyıcıları yapımcılarla ilgili hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan yapımcılarla, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan ses taşıyıcılarına uygulanacaktır. FSEK'in bağlantılı haklara ilişkin hükümleri, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümlerine göre korunan yapımcılara da uygulanır.

1961 Roma Antlaşması madde 15 hükmü, aşağıdaki şartlardan birinin mevcudiyeti halinde her akit devletin plak yapımcılarına ulusal uygulama tanıyacağını kabul etmiştir:

- a) plak yapımcısının diğer bir akit devlet tebası olması,
- b) Sesin, ilk defa diğer bir akit devlet sınırları içinde tespit edilmiş olması,
- c) Plajın ilk defa diğer bir akit devlet sınırları içinde yayımlanmış olması.

İlk yayım, akit olmayan bir devlet sınırları içinde yapılmış olmakla beraber, ilk yayımı takip eden otuz gün zarfında, akit bir devlet sınırları içinde de yayımlanırsa, bu plajın akit devlet sınırları içinde ilk defa yayımlandığı kabul edilecektir.¹³⁴

Kimi zaman bazı istisnai durumlarda, fonogram yapımcılarının tespitleri üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim hakları kendilerinden izin alınmadan ve kendilerine bir bedel ödenmeden kullanılabilir. Bu sınırlamalar hem uluslararası sözleşmelerde hem AB direktiflerinde ve hem de FSEK'de düzenlenmiştir. Bu sınırlamalara ileride **“Hakların Kullanılması ve Devri”** adlı bir bölümde değineceğimiz için burada kısa bir özet vermek istiyoruz.

¹³³ Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği madde 9: Koro, orkestra ve sahne eserlerinin icrasını tespit etme, bu tespiti çoğaltma, kiralama, icranın telli-telsiz her türlü araçla yayınlanması ya da temsili suretiyle faydalanma hakkının devrinde yalnız şefin izni yeterlidir.

¹³⁴ EREL, age., s. 175

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın bağlantılı haklara ilişkin sınırlamalar hakkındaki 16. maddesine göre;

“(1) Akit tarafların ulusal mevzuatlarında edebi ve sanat eserleri üzerindeki hakların korunması konusunda öngörülenlerle aynı şekilde icracılar ve fonogram yapımcılarının korunması konusunda da sınır-lama ve istisnalar öngörme yetkileri vardır.

(2) Akit taraflar, bir icra veya fonogramın normal kullanımıyla çelişmeyen ve icracı sanatçı veya fonogram yapımcısının yasal çıkarlarına halel getirmeyen bu Andlaşmadaki özel durumlar için sağlanan hakların sınırlanması veya istisnaların getirilmesini kısıtlayabilirler”.

Bu düzenleme paralelinde FSEK 80. maddesi fonogram yapımcılarını da kapsar biçimde şu hükmü getirmiştir.

“Aşağıda belirtilen hallerde komşu hak sahibi ile film yapımcısının yazılı izni gerekli değildir:

1. Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veya haber amacıyla ve kazanç amacı güdülmeksizin icra edilmesi ve kamuya arzı.

2. Fikir ve sanat eserleri ile radyo-televizyon programlarının yayınlanma ve kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması.

3. Radyo-televizyon kuruluşlarının kendi olanaklarıyla kendi yayınları için yaptıkları kısa süreli geçici tespitler.

4. Bu Kanunun 30 uncu, 32 nci, 34 üncü, 35 inci, 43 üncü, 46 ncı ve 47 nci maddelerinde belirtilen haller.”

Maddenin 1 no'lu fıkrasındaki, fikir ve sanat eserlerinin ve dolayısıyla fonogramların kamu düzeni, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veya haber amacıyla fonogram yapımcısından izin alınmadan ve bir bedel ödenmeden kullanılabilmesi için özel şart; bu faaliyetlerin kazanç amacı güdülmeksizin yapıyor olmasıdır. Bir yandan eğitim- öğretim için kullanılıyor ama bir yandan da bir kazanç elde ediliyorsa bu istisnadan yararlanılamaz.

Maddenin 2 no'lu fıkrasındaki şahsen kullanma için fonogramların çoğaltılabilmesinin özel şartları; yayınlanma ve kâr amaçlarından hiçbirinin olmamasıdır. Eğer şahsi kullanım için bir fonogramı (müzik kaydını) çoğaltan kişi bu işten doğrudan veya dolaylı bir kâr elde ediyorsa bu istisnadan yararlanamaz. Yine şahsen kullanmak için çoğaltılan müzik kaydı internet veya diğer yayın araçlarında yayınlanamaz. Yayınlanırsa bu istisna ortadan kalkar ve ilgili kişi fonogram yapımcısından

izin almadan bu ihlali yaptığından bu işten yasaklanır; FSEK’de yazılı tazminatları öder ve başvuru halinde ceza yargılamasına maruz kalır.

Maddenin 3 no’lu fıkrasında ise; radyo ve televizyon kuruluşlarının fonogramlardaki tespitlerden yaptıkları kısa süreli geçici tespitleri (müzik yapıtının tamamı asla değil) -kendileri kayıt etmişlerse veya kameraya almışlarsa- kendi yayın kuruluşlarında yayınlatabilecekleri düzenlenmiştir. Eğer bu kısa süreli tespitler başkasının kayda aldığı ve kameraya aldığı tespitlerse veya fonogram yapımcısının ticari amaçla hazırladığı kısa süreli tespit ise bu istisna hükmüne dahil değildir. Başkalarının yaptığı kısa tespitlerin (müzik yapıtlarından başkaları tarafından yapılmış kaydın bir kısmının) yayınlanabilmesi sadece haber amacı varsa maddenin 1 no’lu fıkrasına göre olanaklıdır.

Bu sınırlamalar arasındaki 4 no’lu maddeyi şöyle açıklayabiliriz: Özellikle fonogram FSEK madde 30 kapsamında eser üzerindeki hakkın veya eser sahipliğinin ispatı maksadıyla mahkeme ve diğer resmi makamlar huzurunda yahut zabıta ve ceza işlerinde bir muameleye konu teşkil etmek üzere kullanılacaksa; FSEK madde 32 kapsamında kullanılacaksa (bu hükmün müzik eserleri açısından pek bir uygulaması yoktur); FSEK madde 34 kapsamında eğitim-öğretim için seçme ve toplama eserler meydana getirilmesinde fonogramdan iktibas yoluyla yararlanılacaksa; FSEK madde 35 kapsamında asıl eserden iktibas yapılmasının caiz olduğu hallerde, fonogram bu amaçla kullanılacaksa; FSEK madde 43 (bu hüküm FSEK 43. maddesinin eski halinde müzik yapıtlarından kısa parçalar alınması ve TRT’nin yurt dışına kısa dalga yayınlarına ilişkin ama şimdi 43. madde olduğu gibi değiştiğinden bu istisna zımnen ortadan kalkmıştır-inşallah birileri farkına varır ve bunu değiştirir-); FSEK madde 46 kapsamında devletin eserden faydalanma yetkisinin bulunduğu hallerde, kamu kurum ve kuruluşların zilyedliğinde bulunup da eser sahibi tarafından çoğaltma ve yayımı açıkça men edilmemiş ve henüz yayınlanmamış ve alenileşmemiş olan eserler söz konusuysa ve nihayet FSEK madde 47 kapsamında eserin mali haklarından yararlanma yetkisinin kamuya maledilmesi için gerekli şartlar, tespit edilmiş bir fonogramdaki bir eser için de mevcutsa; fonogram, yapımcıdan izin alınmasına gerek kalmadan ve bazı hallerde uygun bir bedel ödenerek kullanılabilir.

Kanun, 80. maddedeki düzenlemede, fonogram yapımcısından izin alınmadan fonogramları/ kayıtların kullanılmasına olanak veren bu istisnai durumların, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olma-

dan zarar veremeyeceğini ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamayacağını belirlemektedir.

Bağlantılı haklara sahip olanlar da eser sahipleri gibi tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i ve tazminat davası haklarından faydalanırlar.

Koruma süreleri ileride topluca ayrı bir bölümde incelenmekte beraber burada fonogramların korunma sürelerine kısaca değinmekte fayda görüyoruz.

Roma Sözleşmesi 14. madde ile koruma süreleri konusunda şu düzenlemeyi yapmıştır:

"Bu Sözleşmeye göre tanınacak koruma süresi:

a) Fonogramlar ile fonogram üzerine tespit edilmiş icralar için tespit yılının sonundan; ...

başlamak üzere yirmi yıllık bir süreden az olamaz".

Roma Sözleşmesi'nin getirdiği 20 yıllık süre yeterli bulunmadığından WIPO Anlaşması ile bu süre 50 yıla çıkarılmıştır. WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 17. maddesine göre; *"...Bu Andlaşma ile fonogram yapımcılarına tanınan koruma süresi; fonogramın yayımlandığı yılın sonundan itibaren veya fonogram tespitinden itibaren 50 yıllık bir süre içerisinde böyle bir yayım olmadığı takdirde, tespit yapıldığı yılın sonundan itibaren hesaplanmak üzere en az 50 yıldır".*

Uluslararası sözleşme hükümleri ile getirilen bu elli yıllık olmazsa olmaz süre ülkemizin yaygın fikri hak ihlallerine maruz kalması sebebiyle daha da genişletilmiş ve 70 yıla çıkarılmıştır. FSEK madde 82 hükmüne göre, *"yapımcıların hakları ilk tespit yapıldığı tarihten başlayarak 70 yıl devam eder."* Koruma süresinin başlangıç anı olarak "ilk tespit yapıldığı an belirlenmiştir.

Yapımcıların ses taşıyıcıları dışında kalan ürünleri (FSEK madde 84'de sayılan ve eser olmayan tespitleri) bakımından Kanunda bir koruma süresi öngörülmemiştir. Eserler hakkındaki koruma sürelerinin kıyas yoluyla burada da uygulanması düşünülebilirse de doktrinde eserin işaret, ses ve resim vasıtasıyla tekrarına yarayacak araçların, eserin aslından daha kısa bir süreyle korunması gerektiği öne sürülmüştür.¹³⁵ Biz de bu fikre katılıyoruz. Koruma süresi dolmuş eserlerin ve eser niteliğinde olmayan ürünlerin tespit ve tekrarına yarayan araçlar bakımından da evveliyatla aynı sonuca varılmalıdır. Ancak Kanun'un yapımcıya

¹³⁵ ARSLANLI, age., s. 56; AYİTER, age., s. 83

tanındığı haklar ticari bir menfaatin korunmasına yönelik olduğundan, haklı bir ticari menfaat bulundukça korumanın da sürmesi gerekir.¹³⁶

4110 sayılı Kanunla değişik FSEK madde 81 hükmü, yapımcıların denetlenmesi amacıyla bazı yeni düzenlemeler getirmiştir. Buna göre; bir eserin çoğaltılabilmesi için; basımevi, yapımevi veya dolum tesisine, eser sahibi veya hak sahibi olduğunun noter ve 52’nci maddeye uygun sözleşme veya yetki belgesi ile kanıtlanması gerekir. Süreli olmayan yayınlara Kültür Bakanlığı’ndan alınacak bandrolün yapıştırılması zorunludur.¹³⁷

C. RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARININ HAKLARI

1982 tarihli Anayasanın 133 üncü maddesiyle 1993 tarih ve 3913 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce, Türkiye’de radyo ve televizyon istasyonlarının ancak devlet eliyle kurulacağı ve idarelerinin tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenleneceği hükme bağlanmıştı.

Bu nedenle de Türkiye Radyo ve Televizyon Kuruluşu (TRT) olarak bilinen kamu kuruluşu ülkemizdeki tüm radyo ve televizyon yayınlarını¹³⁸ yapıyordu. Değişiklikten sonra, radyo ve televizyon istasyonları kurulması ve işletilmesinin Kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbest olduğu kabul edilmiş, ardından da 1994 tarih ve 3984 sayılı “*Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun*”¹³⁹ çıkarılmıştır.

Kamu yayıncılığı yapan TRT için ise 2954 sayılı “Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu” geçerlidir.

3984 sayılı Kanun’un 29. madde hükmüne göre, özel radyo ve televizyon kuruluşları sadece anonim şirket olarak kurulur ve aynı şirket ancak bir radyo ve bir televizyon işletmesi kurabilir. 2954 sayılı Kanuna göre ise Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu (TRT) tarafsız bir kamu kurumudur.

Radyo ve televizyon kuruluşları yayınlarını ya bütün ülkeye dağılmış antenler vasıtasıyla karasal vericilerden, ya uydu yoluyla ya da kablo ağları vasıtasıyla yaparlar. Bu yayınları şifresiz olarak yapabilecekleri

¹³⁶ AYİTER, age., s. 83

¹³⁷ EREL, age., s. 178

¹³⁸ TRT’ye ek olarak Polis ve Meteoroloji radyoları da özel izinle yayın yapıyorlardı.

¹³⁹ Resmi Gazete 20.4.1994, Sayı 21911

gibi decoder adı verilen aletlerin kullanıcılara dağıtılması ile şifreli olarak yapılabilirler.

1. Radyo ve Televizyonların Eser ve Diğer Hak Sahiplerinden İzin Alması

Radyo-televizyon kuruluşunun bir tüzel kişilik olarak fikir ve sanat eserleri üzerinde komşu hak sahipliği çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu kuruluş eser yaratmak üzere bir gerçek kişiyi istihdam edip, FSEK madde 18 gereğince, gerçek kişinin yarattığı eserin mali haklarını kullanan kişi sıfatıyla yayınlarında bu eserin icra ve temsiline yer verebilir; ya da asıl eser sahibinden eserin radyo veya televizyonla yayını hususundaki mali hakkını devir alıp eseri yayınlayabilir; yahut eser sahibi ve icracı sanatçı ile yaptığı sözleşme sonucu icrayı bizzat tespit ederek yayınlayabilir; nihayet fonogram yapımcısı veya diğer yayıncı kuruluşla bir sözleşme yaparak, eseri onların yaptığı tespitten faydalanmak suretiyle yayınlayabilir.¹⁴⁰ Bu şekilde yayınlanan müzik eserleri, klipler, sinema filmleri, diziler, siyasal, toplumsal, kültürel ya da tamamen eğlendirici nitelikli programlar veya açık oturumlar, yarışma programları, radyo-televizyon yorumları birer eser niteliğindedir. Dolayısıyla radyo-televizyon kuruluşları, eser ve diğer bağlantılı sahiplerinden gerekli izinleri alarak bu programları yayınladıkları takdirde, yayınları üzerinde bağlantılı hak sahibi olacaktır.¹⁴¹

Haber programları ise kural olarak eser niteliği taşımaz; gerçi kompozisyonu veya sunuluşu itibariyle özellik taşıyan haber veya haber programları bulunabilir, ancak yine de biçimin içindeki öz hiç kimsenin tekelinde olmayan ve herkesin başkasına nakledebileceği bir olaydır.¹⁴² O halde radyo-televizyon kuruluşlarının komşu hak sahipliği haber veya haber programlarını kapsamayacaktır.¹⁴³ Haber programları ve eser niteliği olmayan yayınlar FSEK madde 84'e göre korunabilir.¹⁴⁴

¹⁴⁰ EREL, age., s. 179

¹⁴¹ ARKAN, age., s. 176

¹⁴² AYİTER, age., s. 161

¹⁴³ Buna karşılık haberler 5187 sayılı Basın Kanunu ile korunmuştur. Bu Kanunun 24. maddesine göre; bir süreli yayında yayınlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayınlayanlar beş milyar liradan on milyar liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Haber ajansları da Kanun'un 2 ve 4. maddesine göre "süreli yayın" olduklarından, aynı yasak bir haber ajansının özel gayretle elde ettiği

Radyo-televizyon kuruluşu; yayınlamak amacıyla bir fikri ürün meydana getirmek için, bazı kişileri bir hizmet akdi çerçevesinde istihdam etmişse, bu durumda FSEK madde 18/2'ye göre, yaratılan eser üzerindeki mali hakları kullanma yetkisi ona ait olacak ve herhangi bir kim-seden izin almasına gerek olmayacaktır. Örneğin, yayıncı kuruluş; bir eğlence programında bir şarkıcıyı ve orkestrayı istihdam eder, besteci ve söz yazarlarından izin aldıktan sonra bu şarkıcıya her programda beş şarkı söyletir ve bunun ilk tespitini yapar. Bu şarkıları içeren yayın üzerinde yayın kuruluşu; FSEK madde 80'de sayılan çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarına sahiptir. Eğer yayın kuruluşu eser sahibi ve icracı sanatçıdan yayınlı ilgili tüm hakları almışsa tek başına bu yayınların başka bir yayın kuruluşunca yayınlanmasına izin verebilir. Eser sahipliğinin yayın kuruluşunda mı yoksa yaratıcılarda mı olduğunu tartışan bir kararı bilginize sunuyoruz:

“...Mahkemece, sunulan kanıtlara dayanılarak, “Televole” programının 7.11.1994 tarihinden beri X A.Ş.ne ait Kanal ... TV.sinde yayınlanmakta olduğu, dava dışı Ş.B. ve arkadaşlarının, X A.Ş. ile yaptığı sözleşme tarihinin ise 15.11.1995 olduğu, sözleşmenin 4/c maddesinden bu programın sözleşmeden önce yayınlandığı teyit edilmekle anılan yapımcı ve sunuculardan oluşan ekibin sözkonusu programın yaratıcıları ve ilk kez yayıncıları olduklarının anlaşıldığı ve bu nedenle “Televole” adı üzerinde eser sahibi hakları bulunmadığı, taraflara ait TV. Kanallarında yayınlanan programın aynı olduğu, sahibi bulunduğu Kanal ... televizyonunda bu program üzerinde korumaya değer kadim ve üstün hakkı bulunduğu gerekçesiyle asıl ve birleştirilen İstanbul 3.Ticaret Mahkemesi'nin 1997/985 sayılı davaların kararı ile “Televole” program adının Y A.Ş. tarafından kullanılmasının

haberler için de geçerlidir. Hükmün amacı gazeteler, haber ajansları vb. arasında haksız rekabeti önlemektir. FSEK md. 36 hükmü Basın Kanunu'nun eski 15./yeni 24. maddesini hem basın, hem de radyo (televizyon) için saklı tutmaktadır. Radyo-televizyonlarının haber alanındaki faaliyetleri basın ve haber ajanslarına benzediğinden, özel fedakarlıkla elde ettikleri haberlerin, kaynak gösterilmeden başka radyo-televizyon kuruluşlarınca yayınlanmaması gerekir. Bkz. AYİTER, age., s. 161-162

¹⁴⁴ FSEK madde 84: *Bir işareti, resim veya sesi, bunları nakle yarıyan bir alet üzerine tespit eden veya ticari maksatlarla haklı olarak çoğaltan yahut yayan kimse, aynı işareti, resmin veya sesin 3 üncü bir kişi tarafından aynı vasıttan faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını veya yayımlanmasını men edebilir.*

Tevacüz eden tacir olmasa bile birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında haksız rekabete mütaallik hükümler uygulanır.

Eser mahiyetinde olmıyan her nevi fotoğraflar, benzer usullerle tespit edilen resimler ve sinema mahsulleri hakkında da bu madde hükmü uygulanır.

haksız rekabet oluşturduğunun tespitine ve önlenmesine, Y A.Ş.ne ait 171513 no'lu Televole markasının sicilden silinmesine, birleştirilen diğer davanın ise reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı ve birleştirilen dava davacısı AKS. A.Ş. vekili temiz etmiştir.

Dava, "Televole" adlı TV magazin program adı üzerindeki muarazadan kaynaklanmaktadır.

FSEK madde 5'e göre, anılan ad ve formattaki TV yapımı da yasa kapsamındaki bir eser sayılmalıdır. FSEK'nun 8. maddesi hükmüne göre ise, bir eserin sahibi onu meydana getirendir. Bu maddenin 7.6.1995 tarih ve 4110 sayılı yasa ile değiştirilmeden önceki ikinci fıkrası ile *"aradaki özel sözleşmeden veya işin doğasından aksi anlaşılmadıkça memur, hizmetli ve çalışanların işlerini görürken meydana getirdikleri eserlerin sahiplerinin bunları çalıştıran veya tayin eden gerçek veya tüzel kişiler oldukları"* düzenlenmiş iken değişiklikten sonra, çalışanların hakları sadece mali hakları kullanma ile sınırlandırılmış, izleyen fıkra ile de bir eserin yapımcısı veya yayıncısının ancak eser sahibi ile yaptığı sözleşmeye göre eserin mali haklarını kullanabileceği öngörülmüş bulunmaktadır. Bu açıklamalar ışığında, öncelikle dava konusu programı ilk kez meydana getirenin saptanması zorunlu bir husus olmaktadır. Mahkemece, anılan programın 7.11.1994 ten itibaren yayınlanmaya başlandığı, oysa Ş.B. ve ekibi ile yapılan hizmet sözleşme tarihinin 15.11.1995 olduğu, sözleşmede programın bu ekipçe yaratıldığı belirtilmemesi ve spor servisine önceden hazırlana gelmekte olduğundan söz edilmesinden hareketle programı ilk olarak yayına sokan Kanal ... TV sahibinin öncelikli ve üstün hakkı bulunduğu sonucuna varılırken, bu kanı yeterli inceleme ve araştırmaya dayandırılmamıştır. Bu bakımdan, davalı ve birleştirilen dava davacısı Y A.Ş. vekilinin istemi doğrultusunda, uzman bilirkişiler aracılığı ile 7.11.1994 ile 15.11.1995 programlarının bantları ve o tarihlerdeki gazete haberleri incelenerek programı meydana getirenlerin kim veya kimler olduğu ve bunun sonucunda eser sahipliği sıfatının aidiyetinin saptanması gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporu ile yetinilerek karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Öte yandan, **uyuşmazlığın Ş.B. ve arkadaşlarından oluşan programcı ekibinin dava konusu program ile olan ilişkisinin niteliği üzerinde odaklandığı gerçeği karşısında, davacı X A.Ş. vekiline bu kişilere karşı dava açılması için, uygun bir önel tanınarak açılacak davanın birleştirilmesinden sonra programın eser sahipliği hususunun nihai biçimde çözüme kavuşturulması gerekirken, adı geçenleri (dava dışı S.B. ve arkadaşları) tarafı bulunmadıkları bir davada bağlayıcı ve menfaatlerini etkileyici biçimde karar verilmiş olması da kabule göre isabetsiz olduğundan, kararın bu yön bakımından da bozulması gerekmiştir¹⁴⁵.**

¹⁴⁵ Yargıtay 11. H.D. 31.10.2000 T., 2000/6049 E. 2000/8439 K.

Radyo-televizyon kuruluşu, bir başkasının yarattığı eseri veya bir başkasına ait fonogramı da yayınlatabilir. Başkasına ait bir televizyon programının yayını hakkındaki aşağıdaki karar ilgi çekicidir.

“Davacı vekili, müvekkili ile birlikte ... Reklamcılık Ltd. Şti ortaklığının, davalının siparişi üzerine her biri 10’ar dakikalık 52 bölümden oluşan “Hata Kimde” rumuzlu spot filmlerden oluşan bir dizi hazırladığını, protokol gereğince eserin yayınının herhangi bir televizyon kanalında bir defalık yayınlanması gerekir iken müvekkilinin izni dışında davalı tarafından S. TV’de yayınlatılarak FSEK 68. maddesine aykırı davranıldığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hak saklı tutularak 2.000.000.000 TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı vekili, 1990 yılında yapılan film için telif hakkı talebinin zamanaşımına uğradığını, Devlet Bakanlığı’nın siparişi üzerine yaptırılan eğitici dizinin ücretinin davacıya ödendiğini ve tüm haklarının Devlet Bakanlığına ait olduğunu, kaldı ki dizinin yurtdışı yayın yapan TRT-INT kanalında yayını amacıyla yapılacak montaj için ücret istemesinin de eser üzerindeki her türlü hakkın anılan Bakanlığa ait olduğunun teyidi anlamını taşıdığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre; FSEK’nun 3/1 maddesi gereğince eser olan yapımın davalının siparişi üzerine davacı ile birlikte dava dışı firma tarafından yapıldığı, FSEK 8/3 maddesi gereğince aralarında özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça bir ve birden fazla kimse yayınlayanın tayin ettiği plan dairesinde bir eser meydana getirmişler ise **bu eserin sahibinin yayınlayan olduğu**, taraflar arasındaki protokolün imza tarihinde yürürlükte bulunan FSEK 3-4 maddeleri gereğince istisna akdi ile oluşturulan **eserin mali haklarının iş sahibi davalıya ait olduğu** gibi protokol tarihinden itibaren de davacı taleplerinin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar onanmıştır¹⁴⁶”.

Yukarıdaki kararda çalıştıran ilişkisi, dışarıdan eser siparişine (istisna aktiyle eser yaptırmaya) genişletilmiş ve dışarıdan birine siparişle yaptırılan esere firmanın içinde çalışan kişilere özgü olan çalıştıran ilişkisi uygulanmıştır. Bizce, bir firma için çalışanların eserlerinin mali hakları şirketçe kullanılır ama dışarıya yaptırılan eserlerde ve yapımlarda taraflar arasındaki sözleşmeye göre mali hakların kime ait olacağı ya da kullanılacağı belirlenmelidir.

Yine, uluslararası bir müzik yarışmasını izin alarak birden çok kanal canlı olarak yayınlatabilir. Burada yayınlayan her kanal, kendi yayını üzerinde bağlantılı hak sahibi sıfatını kazanacaktır¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Yargıtay 11. H.D. 2003/9931 E. 2004/5299 K.

¹⁴⁷ ARKAN., age., s. 178

Ancak diğer bağlantılı hak sahiplerinden farklı olarak, radyo-televizyon kuruluşlarının kendilerine tanınan haklara sahip olabilmesi için almaları gereken izin, bağlantılı haklarının düzenlediği FSEK madde 80/1 C’de değil; yukarıda detaylı olarak incelenen FSEK madde 43’de¹⁴⁸ düzenlenmiştir. FSEK madde 80’e göre, icracı sanatçılar için eser sahiplerinden izin, fonogram yapımcıları için eser sahipleri ve icracı sanatçılardan mali hakları kullanma yetkisinin alınması aşamasından sonra kendi hakları oluşmakta idi.

FSEK madde 43/1’e göre ise, radyo ve televizyonda yayın yapabilmek için, sahneye konmuş eserlerle (müzikal, opera, bale, müzikli gösteri) **ilgili hak sahiplerinden** önceden izin alınacaktır. İkinci fıkraya

¹⁴⁸ FSEK madde 43: “Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin almak zorundadırlar.

Bu kuruluşlar sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadırlar.

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren radyo-televizyon kuruluşları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, anılan Kanun dışında kalan ve yayın ve/veya iletim yapan diğer kuruluşlar ise Bakanlık tarafından sınıflandırılır.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram ve yapımların yayın ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile kuruluşlar arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılan müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

Meslek birliklerinin temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bildirim zorunluluğu, tarifelerin belirlenmesi, duyurulması, müzakere edilmesi, sözleşme yapılması, uzlaşmazlıkların halli ve diğer hususlarda bu Kanunun 41 inci maddesinin dört ilâ onüçüncü fıkraları uygulanır. Ancak yayın ve/veya iletim yapan kuruluşlar bakımından 41 inci maddenin altıncı fıkrasının son cümlesinin uygulanması zorunlu değildir.

Ayrıca, 41 inci maddenin 10 uncu fıkrasının uygulanması bakımından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yayınlarında yer verdiği eser, icra, fonogram ve yapımları her üç ayda bir meslek birliklerince belirlenen yıllık tarifenin 1/4’ünü yatırmak suretiyle kullanabilir”.

göre ise, sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için, ilgili alan **meslek birliklerinden** FSEK 52'nci maddeye uygun sözleşme yapılarak **izin alınacak** ve söz konusu yayın ve/veya yeniden yayına ilişkin ödemeler meslek birliklerine yapılacaktır.

Radyo-televizyon kuruluşunun bağlantılı hak sahibi olabilmesi için alması gereken izin, ***yayın hakkına ilişkindir***. İzin; ruhsat/lisans ile birlikte verilebileceği gibi mali hakların devri ile birlikte de verilebilir. İzinin niteliği ve kapsamı her olayda ayrı ayrı değerlendirilmelidir. ARKAN'a göre, eğer yoruma ihtiyaç duyuluyorsa, hakkın devredildiği değil de bunun kullanım yetkisinin ***ruhsat (lisans)*** verildiği kabul edilmelidir. ARKAN, Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 23. maddesi uyarınca bağlantılı hakların devir ve intikali halinde de FSEK madde 56/2 uyarınca verilen ruhsatın basit ruhsat olduğu sonucuna varılması gerektiğini belirtmektedir. Biz ARKAN'ın bu görüşlerine katılmıyoruz. Bu konuda tarafların arzu ve amaçları ile sektör gelenekleri devreden iradesini ortaya koyacaktır. Bize göre; hak sahibi haklarını “devir” iradesi taşıyorsa veya hakları konusunda “tam ruhsat” verme irade ve amacını taşıyorsa ve bunu sözleşmeye yazıyorsa; artık bu haklar devreden malvarlığından çıkıp, devralanın malvarlığına geçer ve geri dönüşü de yoktur. Sözleşmelerin yorumu yapılırken taraf iradeleri dışında sektörlerin geleneklerine de bakılmalıdır. Bu konudaki görüşlerimiz yukarıda “VI.B. Fonogram Yapımcılarının Haklarına İlişkin Ortak Hükümler” başlığı ve ileride “VII. D. Mali Hak Devri” bölümlerinde açıklanmıştır.

FSEK madde 80/2 6 ve yine Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 23. maddesi uyarınca kıyasen uygulanacak FSEK madde 52'ye göre, hak sahiplerinden iznin yazılı şekilde alınması zorunludur. Burada öngörülen şekil bir sıhhat şeklidir. Dolayısıyla yazılı olarak yapılmayan sözleşmeler geçerli olmayacaktır. Yine FSEK madde 52'ye göre, iznin kapsamına giren hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır¹⁴⁹.

Bazen; izin alınması gereken hak sahipleri birden çok sayıda olabilir. Örneğin eser sahibinin veya icracıların birden çok olduğu haller gibi. Bu konular, eser sahibinin ve icracı sanatçıların hakları bölümlerinde ayrıntılı olarak incelendiğinden, tekrardan kaçınmak amacıyla söz konusu bölüme atıf yapmayı yeterli buluyoruz¹⁵⁰.

¹⁴⁹ ARKAN, age., s. 183

¹⁵⁰ ARKAN, age., s. 183

Radyo ve televizyonların icracı sanatçılardan alacağı izin konusunda şu düzenlemeleri de hatırlamakta yarar var. İcra ve gösteri bir orkestra, koro veya müzik grubu tarafından yapılmışsa FSEK madde 80/A-6 gereğince artık münferit sanatçılardan değil, sadece o topluluğun *şefinden* izin alınması yeterli olacaktır. Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 9. maddesinde¹⁵¹ benzer düzenleme vardır. Eğer icracı sanatçı grubu bir müteşebbis (girişimci/organizatör) tarafından çalıştırılıyorsa, şeften başka girişimci/organizatörün de FSEK madde 80/A-7 gereğince izninin alınması gerekir. Şefin ve keza girişimcinin/organizatörün izin verme yetkisi doğrudan Kanun'dan doğmaktadır ve kesindir.

Eğer radyo televizyon kuruluşu tarafından yayından önce eser sahiplerinden, icracı sanatçılardan veya fonogram yapımcılarından izin alınmadan eser, icra veya fonogramlar yayınlanıyorsa yahut yayıncı tarafından hak sahiplerinden alınan lisanstaki sınırlar aşılarak yayın yapılıyorsa; eser ve diğer hak sahipleri FSEK'e dayanarak tecavüzün refi, tecavüzün menî, tazminat davaları ve ilgililerin hapisle cezalandırılması için ceza davaları açabilirler.

Bu duruma bir örnek olarak müzik eserlerine kolayca uyarlanabilecek şu kararı verebiliriz:

"Davacılar vekili, davacı S.Ç'a ait ve temsil hakkı diğer davacıya devredilmiş, "Gülyüzlüm" adlı romanın küçük değişikliklerle ve ismi "Annem ve Ben" olarak değiştirilerek davalılar tarafından 90 dakikalık film haline getirilerek televizyonda yayınlandığını, bu surette davacıların FSEK.'dan doğan maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, şimdilik, 100.000.000-TL maddi, 100.000.000-TL manevi ve elde edilen kara karşılık 100.000.000-TL'nin, birleşen davada da 650.000.000-TL. maddi tazminatın reeskont faizi ile davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

...Mahkemece, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, mali hakları davacılarla ait "Gülyüzlüm" adlı eserin **fark edilemeyecek derecede birtakım değişiklikler ile** "Annem ve Ben" adı altında **film haline getirilerek televizyonda yayınlandığı**, bu hususun davacıların **maddi ve manevi haklarına tecavüz oluşturduğu**, tespit edilen zardan davalıların sorumlu olduğu gerekçesi ile, asıl davada davalı tecavüzlerinin men'i ile 100.000.000-TL. maddi ve 100.000.000-TL.

¹⁵¹ Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği madde 9: Koro, orkestra ve sahne eserlerinin icrasını tespit etme, bu tespiti çoğaltma, kiralama, icranın telli-telsiz her türlü araçla yayınlanması ya da temsili suretiyle faydalanma hakkının devrinde yalnız şefin izni yeterlidir.

manevi, birleşen davada 650.000.000-TL. maddi tazminatın olay tarihi olan 12.02.1997 tarihinden yürütülecek reeskont oranındaki temerrüt faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmiştir¹⁵².”

Bu davaların yanı sıra eser sahibi, icracı sanatçı ve fonogram yapımcısı; eser, icra ve fonogramlarını izinsiz kullanan radyo ve televizyon kuruluşlarının idari olarak uyarılması ve cezalandırılması için Radyo Televizyon Üst Kuruluna da 3984 sayılı Kanun gereğince başvurabilirler. 3984 sayılı *Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun* yayın ilkeleri ile ilgili 4. maddesinin “o” bendinde; “yayınlarda eser ve bağlantılı hak sahiplerine 5846 sayılı FSEK ile tanınan hakların ihlal edilmemesi”ni radyo ve televizyonlar için bir yükümlülük olarak koymuştur. Kanun 37. maddesinde de; “Radyo-Televizyon kuruluşlarınca yayınlanan ve/veya iletilen eser, fonogram ve yapımları kullanabilmek için, eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri, veya bu kişilerin üyesi oldukları meslek birlikleri ile izin almak üzere sözleşme yaparlar ve bu sözleşme ile belirlenen mali hak bedellerini öderler. Bu sözleşme ve ödemeler, 5846 sayılı *Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu*’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır. Bu madde hükümlerini ihlal eden yayın kuruluşları hakkında ayrıca bu Kanun’un 33 üncü madde hükümleri uygulanır” diyerek, Kanuna uyulmaması halinde yayın kuruluşlarına RTÜK’ün; uyarı, program durdurma, para cezaları ve sonunda yayın izninin iptaline kadar cezalar verebileceğini belirtmektedir.

2. Radyo ve Televizyonların Yayınları Üzerindeki Hakları

Radyo ve televizyon yayınlarının diğer kişi ve kuruluşlar tarafından izinsiz olarak kullanımını engelleyecek düzenlemeler, uluslararası alanda ilk olarak *Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Anlaşması*’nda¹⁵³ ele alınmıştır.

Sözleşmenin amacı, girişte “... müzik, dramatik icra ve benzeri programların düzenleyicileri ve spor olayları organizatörleri, programların özel olarak izlenmesinden başka amaçlarla kullanılmaması şartıyla diğer ülkelere yayınlanmasına muvafakat ettikleri halde, televizyon kuruluşlarının çoğunluğunun kendi yayınlarının tekrarlanmasını, tespitini ya da umuma arzını önlemeye muktedir bulunmamaları nedeniyle söz konusu program değişiminin engellendiği” dikkate alınarak,

¹⁵² Yargıtay 11. H.D., 04.04.2002, E. 2002/310, K. 2002/3101

¹⁵³ Resmi Gazete, 08.08.1975 tarih ve 15320 sayısında yayınlanmıştır.

“..halen incelenmekte olan “Komşu Haklara İlişkin Evrensel Sözleşme” gerçekleşinceye kadar yalnız televizyon yayınlarına inhisar eden mahdut süreli, bölgesel bir anlaşma akdinin uygun olacağı...” düşünülerek, Avrupa ülkeleri arasında televizyon programları değişimini gerçekleştirecek bazı temel kuralların tespiti olarak belirtilmektedir.

Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Anlaşması’nın 1. maddesine göre yayın kuruluşları, Anlaşmaya taraf olan devletlerin ülkelerinde:

- a) Yayınlarının tekrarlanmasına,
 - b) Yayınların telle umuma yayılmasına,
 - c) Yayınların işaret, ses ve görüntü nakline yarayan herhangi bir (şekilde) umuma ulaştırılmasına,
 - d) Yayınların tespitine, fotoğraflarının alınmasına ve bu gibi tespitlerin çoğaltılmasına,
 - e) Hak sahibi kuruluşun, bu paragrafın (d) sözü edilen tespit ve çoğaltmaların satılmasına izin verildiği haller dışında, bu paragrafın (d) bendinde değinilen tespit ya da çoğaltmalar yoluyla yayınlarının tekrarlanmasına, telle yayınına ya da toplum önünde icra edilmesine,
- izin verme veya bunu yasaklama hakkından yararlanırlar.

Anlaşmanın 2. maddesinde ise, “öngörülen bu korumanın süresinin; sözleşmeye taraf bir ülkede yapılan ilk yayım yılını izleyen onuncu takvim yılı sonuna kadar” olduğu belirtilmektedir.

Radyo ve televizyon yayınlarının korunması gereğinin sebebi; radyo ve televizyon yayıncılığının haber, eğlence, kültür, spor vb. alanda önemli yatırımları ve insan emeğini bir araya getirecek büyük bir organizasyonu gerektirmesidir. Diğer yandan, teknolojik gelişmeler televizyon yayınlarının haksız yollardan kolayca elde edilmesini sağlamaktadır. Bu haksız kullanımda, kıtalar ve ülkeler arasında kültür ve sanat olaylarının iletiminde ve televizyon programları taşıyan sinyallerin dağıtımında etkin bir araç olan haberleşme uyduları rol oynamaktadır. Televizyon programları taşıyan sinyallerin yer istasyonundan uyduya, uydudan yer istasyonu arasında gidip gelişi sırasında yayınların yetkisiz yayın kuruluşları tarafından alınabilmesi ve yayınlanabilmesi mümkün olduğundan, bazı yayın kuruluşları bu yolla haksız kazanç sağlamaktaydı. Bu haksız yararlanmayı engellemek için bazı yayın kuruluşları yayınlarını şifreleyerek uyduya vermeyi tercih etmektedir¹⁵⁴.

¹⁵⁴ BEŞİROĞLU, age., s. 173

Radyo-televizyon yayınlarının haksız kullanımı karşısında bu yayınların korunmasına ilişkin düzenlemeleri içeren uluslararası alanda önemli bir anlaşma 26 Ekim 1961 tarihinde Romada imzalanarak 18 Mayıs 1964 tarihinde yürürlüğe giren *Roma Sözleşmesi* olarak bilinen “*Yorumlayan ve İcracı Sanatçılar, Plak Yapımcıları ve Radyo Kuruluşlarının Korunmasına Dair Uluslararası Konvansiyon*”dur¹⁵⁵. İcracı sanatçı, fonogram yapımcısı ve radyo yayını tanımlarının verilmiş olduğu Sözleşme’nin 3. maddesinde; radyo yayını “*seslerin veya resim ve seslerin, umumun istifade edilebileceği şekilde radyo dalgaları ile yayını*” olarak tanımlanmıştır. Sözleşme’nin bütünü ele alındığında “televizyon yayını” kavramının anılmadığı görülmektedir. Ancak, “radyo yayını”nın tanımı yapılırken “ses ve resim” ifadesinin kullanılması bu tanımın ve radyo yayınları için söz konusu olan kuralların televizyon için de geçerli olduğunu göstermektedir. Zira, radyo kavramını teknik araç olarak ele aldığımızda bu aletin resim iletme özelliği olmadığı, bu özelliğin televizyona özgü olduğu ortadadır¹⁵⁶.

Diğer yandan Sözleşmenin 3. maddesinin (g) bendinde de; bir yayın kuruluşunun yapmış olduğu yayının, diğer bir yayın kuruluşu tarafından aynı anda yayını halinde “tekrar yayın” uygulaması olduğu belirtilmiştir.

Roma Sözleşmesi 6. madde hükmü sözleşmeyi imzalayan devletlerin radyo (ve televizyon) kuruluşlarına aşağıdaki şartlarla ulusal uygulama tanıyacağı kabul etmektedir:

- a) *Radyo kuruluşu idare merkezinin başka bir akit devlette bulunması,*
- b) *Radyo yayınlarının, başka bir akit devlette yer alan verici tarafından yayınlanmış olması.*

Roma Sözleşmesi’nin 13. maddesinde radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarını koruma esasları düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre; kullanılma şartları, bu hakkın korunması kendisinden istenen ülkenin hukuk kurallarınca belirlenecek olan yayın kuruluşlarına yayınları üzerinde tanınan haklar ve yetkiler dört grupta toplanmaktadır:

I. Radyo televizyon kuruluşları yayınların tekrar yayınlanmasına izin verme veya izinsiz yapılan yayınları men etmek yetkisine sahiptir.

¹⁵⁵ *Roma Sözleşmesine Türkiye’nin katılımı, 7 Temmuz 1995 tarih ve 4116 sayılı Kanunla olmuştur.*

¹⁵⁶ *Bkz. Jale SARMAŞIK, Radyo Televizyon Yayıncılığında Eser Hakları, www.hukukcu.com*

Bu yetki kaynak (yayının ilk yapıldığı) ülke dışındaki ülkelerde yapılabilecek izinsiz yayınların yanısıra kaynak ülke içindeki diğer yayın kuruluşlarının yaptıkları izinsiz yayınları da kapsamaktadır.

II. Radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarının tespit edilmesine izni verme ve izinsiz tespitleri önlemek yetkisi vardır.

III. Radyo ve televizyon kuruluşlarına tanınan bir başka yetki yayınların çoğaltılmasına ilişkindir. Yayınların çoğaltılmasına izin verme ve izinsiz çoğaltılmalarını önleme yetkisi iki şekilde ele alınmıştır.

(1)Yayın kuruluşları yayınlarının izinsiz yapılan tespitlerinin çoğaltılmasına izin verebilir veya men edebilir.

(2)Yayın kuruluşları yayınlarının;

(a) özel kullanım,

(b) güncel olayların bildirimi ile ilgili olarak küçük alıntılarının kullanılması,

(c) bir yayın kuruluşu tarafından kendi araçları ile kendi yayınları için geçici tespit yapılması,

(d) eğitim ve bilimsel araştırmalar yapmak amaçlarının dışında bir amaç için çoğaltılmasına izni verebilir veya men edebilir.

IV. Yayın kuruluşları, halkın giriş ücreti ödeyerek girebileceği mahallerde, televizyon yayınlarının halk istifadesine çıkarılmasına izin verebilir veya men edebilirler.

Radyo ve televizyon yayınlarının bağlantılı haklar açısından korunması konusundaki bir başka hüküm, TRIPS Anlaşması'nın 14. maddesinde şöyle düzenlenmiştir:

“(3) Radyo-televizyon kuruluşları izinleri olmaksızın girilen aşağıdaki fiilleri önleme hakkına sahiptir: Yayınlarının tespit edilmesini, bu tespitlerin çoğaltılmasını ve telsiz araçlarla tekrar yayınlanmasını ve televizyon yayınlarının topluma iletilmesini.

Yayın kuruluşlarına bu hakları tanımayan üyeler, yayın içeriğini oluşturan düşünce hakkı sahiplerine, Bern Sözleşmesi (1971) hükümlerine uygun olarak yukarıdaki fiilleri önleme olanağı vereceklerdir.

(5) Bu Anlaşmaya göre, ... 3 ncü paragrafta uygun şekilde öngörülen koruma süresi radyo ya da televizyon yayınının yapıldığı takvim yılının sonundan başlayarak en az 20 yıl devam eder.

(6) Her üye, ... 3 ncü paragrafta yer verilen haklar ile ilgili olarak, Roma Sözleşmesi'nde izin verildiği oranda, koşullar, sınırlamalar, bağışlıklar ve çekinceler öngörebilir.”

Avrupa Birliği Hukuku'nda 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi” madde 8/3’de, Roma Sözleşmesi’ne benzer bir düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemeye göre; iletim kamuya açık alanlarda giriş ücreti karşılığında yapılıyorsa yayın için yayın kuruluşlarından izin alınması gerekmektedir. 93/83/AET sayılı Konsey Direktifi de bu maddeye atıfta bulunmuştur.

2001/29 sayılı “Bilgi Toplumunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara İlişkin Belirli Konuların Uyumlaştırılmasına Yönelik Direktifi”ndeki madde 2’ye göre; “üye devletler, kısmen veya tamamen, her türlü yöntem ve şekilde, kalıcı veya geçici röprodüksiyonları hakkında: ...

(e) yayın kuruluşları ve onların yayınlarının kablo veya uydu yayını da dahil olmak üzere, kablolu veya karasal iletilip ileilmeyeceğinin düzenlemesini;

doğrudan veya dolaylı yasaklama veya müsaade etmeye münhasır haklarını korur”.

Aynı Direktifin 3. maddesine göre; “üye devletler, tel üzerinden veya telsiz vasıtalarla eserlerini yayımlama, böyle bir yolla kamuya bireylerin tercih ettikleri bir zamanda ve bir yerden erişebilme münhasır haklarını,

(d) yayın kuruluşları, kendi yayınlarını kablo veya uydu yayını da dahil olmak üzere, kablo üzerinden veya karasal üzerinde iletilip iletmeme düzenlemesi;

için korur”.

27 Eylül 1993 tarihli “Uydu Yayınları ve Kablo ile Yeniden İletime Uygulanan Telif Hakları ve Telif Haklarına İlişkin Belirli Kuralların Koordinasyonu Hakkında Konsey Direktifi”nde madde 4 şu düzenlemeleri getirmektedir:

“1. Uydu yoluyla kamuya iletim bakımından icracıların, fonogram yapımcılarının ve yayın kuruluşlarının hakları, 92/100/AET numaralı Direktifin 6, 7, 8 ve 10. madde¹⁵⁷ hükümlerine uygun olarak korunacaktır.

¹⁵⁷ 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi Madde 6: 1. Üye devletler, icracılara, icralarının tespiti konusunda yetki verme ya da yasaklama münhasır hakkını sağlarlar.

2. Üye devletler, yayın kuruluşlarına, yayınları kablolu ya da kablosuz olsun, yayınlarının tespiti hakkında yetkilendirme ya da yasaklama münhasır hakkını tanırlar.

3. Kablo yayıncısı, kablo yoluyla sadece yayın kuruluşlarının yayınlarını iletiyorsa, 2. fıkrada sağlanan haktan yararlanmaz.

Madde 7: 1. Üye devletler,

2. Birinci fıkranın amaçları doğrultusunda, 92/100/AET numaralı Direktifte geçen “kablosuz araçlarla yayınlama”, uydu yoluyla kamuya iletimi de kapsayacak şekilde anlaşılacaktır.

3. Birinci fıkra da anılan hakların kullanılması yönünden, 92/100/AET numaralı Direktifin 2(7) ve 12. Maddeleri¹⁵⁸ uygulanacaktır”.

- icracılara icralarının tespiti konusunda,
 - fonogram yapımcılarına fonogramları konusunda,
 - filmlerinin orijinalleri ya da kopyalarının ilk tespitleri konusunda, yapımcılara, ve
 - madde 6 (2)'de belirtildiği üzere, yayınlarının ilk tespitleri konusunda yayın kuruluşlarına,
 doğrudan ya da dolaylı çoğaltıma izin verilmesi ya da bunun yasaklanması münhasır hakkını sağlarlar.

2. Birinci fıkra da göndermede bulunulan çoğaltım hakkı, aktarılabilir, devredilebilir ya da akdi lisansların verilmesine tabi olabilir.

Madde 8 : 1. Üye devletler, yayın icrası veya tespit sonucu gerçekleştirilen icra hari-cinde, icracılara kablosuz yayın konusunda yetkilendirme ya da yasaklama ve icrala-rının kamuya iletimi münhasır hakkını sağlarlar.

2. Üye devletler, ticari amaçlarla yayınlanan fonogram ya da bu nevi fonogramın çoğaltımı kablosuz yöntemlerle yayın ya da kamuya iletim amacıyla kullanılıyorsa, tek adil bedelin kullanıcı tarafından ödenmesini sağlamak ve söz konusu bedelin il-gili icracılar ve fonogram yapımcıları arasında paylaşılmasını sağlamak için hak sağlarlar. Üye devletler, icracılar ve fonogram yapımcıları arasında anlaşma olma-ması durumunda, söz konusu bedelin onlar arasında paylaşılmasını belirleyen şartları düzenlerler.

3. Üye devletler, söz konusu iletim kamuya açık alanlarda giriş ücreti karşılığında yapıyorsa, yayın kuruluşlarına yayınlarının kablosuz yöntemlerle çoğaltımı ya da kamuya iletimi münhasır hakkını sağlarlar.

Madde 10 : 1. Üye devletler,

a) özel kullanım;

b) güncel olaylar hakkında rapor verilmesine ilişkin olarak, kısa alıntılarının kullanımı;

c) bir yayın kuruluşu tarafından kendi tesislerinin olanaklarıyla ve kendi yayınları için gerçekleştirilen geçici tespit;

d) sadece eğitim ya da bilimsel araştırma amaçlı kullanım,

hakkında, Bölüm II'de göndermede bulunulan haklara sınırlama getirebilirler.

2. Herhangi bir üye devlet, 1. fıkrayı göz önünde bulundurmaksızın, edebiyat ve sa-nat eserlerinin telif haklarının korunmasıyla bağlantılı olarak sağladığı şekilde, ic-racılara, fonogram yapımcılarına, yayın kuruluşlarına ve filmlerin ilk tespitlerinin yapımcılarına ilişkin olarak da aynı çeşit sınırlamalar getirebilir. Ancak, zorunlu li-sanslar, sadece Roma Anlaşması ile uyumlu olması şartıyla verilebilir.

3. Fıkra 1 (a), çoğaltım ya da özel kullanıma ilişkin bedel hakkındaki mevcut ya da muhtemel mevzuata halel getirmez.

¹⁵⁸ 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi Madde 2/7: Üye devletler, adı geçen sözleşme madde 4 çerçevesinde adil bedel sağlıyorsa, film yapımı hakkında, icracı ya da film yapımcısı arasında sözleşme imzalanmasını

Türk Hukuku'nda ise, bu konuda FSEK 80. madde 1 no'lu fıkrada C bendinde şu şekilde düzenleme yapılmıştır:

“Radyo-televizyon kuruluşları bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirirler. Radyo-televizyon kuruluşları, gerçekleştirdikleri yayınlar üzerinde;

(1) Yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına izin verme veya yasaklama,

(2) Özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına izin verme veya yasaklama,

(3) Yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına izin verme veya yasaklama,

(4) Tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin verme,

(5) Haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine ilişkin izin verme veya yasaklama,

hususlarında münhasıran hak sahibidirler.”

Yayın kuruluşlarının hakları; yasal düzenlemeden daha eski tarihli olan *“Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği”*nde madde 16'da şöyle belirtilmiştir:

“Yayın kuruluşları;

- a. Herhangi bir konuda yayın üretme,*
- b. Yayınlarını tekrar yayınlama,*
- c. Yayınlarını başka bir yerde ve araçlarla topluma gösterilebilme,*
- d. Kendi yayınlarının bütününe veya bir kısmını fonogram, videogram veya veri taşıyıcılarına kaydetme ve bu kayıtları çoğaltma,*

sağlayabilir. Üye devletler, aynı zamanda bölüm II' de belirtilen haklarda gerekli değişiklikleri yaparlar.

Madde 12: İcracılar, fonogram yapımcıları ve yayın kuruluşlarına ilişkin olarak, işbu Direktifte göndermede bulunulan haklar, daha ileri uyuma halel getirmeksizin, RomaAnlaşması'nda belirtilen ayrı sürelerin bitiminden önce sona ermez. Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılara ilişkin bu Direktifte göndermede bulunulan haklar, tespitin gerçekleştirildiği yılın sonundan itibaren hesaplanan 20 yıllık sürecin bitiminden önce son bulmaz.

e. Yayınlarının çoğaltılmış kopyalarını satışa sunma, satma veya başka yollardan dağıtımını yapma haklarına sahiptirler.”

Yine Yönetmeliğin 17’nci maddesine göre yayın kuruluşlarının yazılı iznini gerektiren durumlar şunlardır:

“... a) *Bir tespit izinsiz olarak yapılmışsa, bu tespiti izleyen yayınların tümünün ya da bir kısmının çoğaltılması,*

b) Yayınlarının başka yayın kuruluşları tarafından aynı anda ya da yeniden telli ya da telsiz olarak yayınlanması,

c) Yayınlarının başka kişi ya da kuruluşlar tarafından giriş ücreti olan yerlerde toplumun istifadesine sunulması...”

Fark edeceğiniz üzere, Komşu Haklar Yönetmeliği, Kanun’dan önce yapıldığı için radyo ve televizyon kuruluşlarına Kanunda sayılan haklardan daha az ve eksik biçimde haklar sunmaktadır. Bu yüzden Yönetmeliğin değiştirilerek Kanuna uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Yayın kuruluşlarının sahip oldukları bağlantılı haklar bazı özel durumlarda onlardan izin almadan da istisnai olarak kullanılabilir.

Bu konuya ilişkin ilk düzenleme; TRIPS Anlaşması’nın 13. maddesinde; *“üyeler, eserin olağan kullanımına ters düşmeyen ve hak sahibinin meşru yararlarına haksız şekilde zarar vermeyen bazı özel durumlarda inhisari haklara sınırlamalar ya da istisnalar öngörecektir”* şeklindedir.

Yine benzer sınırlamalar 92/100/AET sayılı Avrupa Konseyi Direktifi’nin 10. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

“1. Üye devletler,

a) özel kullanım;

b) güncel olaylar hakkında rapor verilmesine ilişkin olarak, kısa alıntılarının kullanımı;

c) bir yayın kuruluşu tarafından kendi tesislerinin olanaklarıyla ve kendi yayınları için gerçekleştirilen geçici tespit;

d) sadece eğitim ya da bilimsel araştırma amaçlı kullanım,

hakkında, Bölüm II’de göndermede bulunulan haklara sınırlama getirebilirler.

2. Herhangi bir üye devlet, 1. fıkrayı göz önünde bulundurmaksızın, edebiyat ve sanat eserlerinin telif haklarının korunmasıyla bağlantılı olarak sağladığı şekilde, icracılara, fonogram yapımcılarına, yayın kuruluşlarına ve filmlerin ilk tespitlerinin yapımcılarına ilişkin olarak da

aynı çeşit sınırlamalar getirebilir. Ancak, zorunlu lisanslar, sadece Roma Anlaşması ile uyumlu olması şartıyla verilebilir.

3. Fıkra 1 (a), çoğaltım ya da özel kullanıma ilişkin bedel hakkındaki mevcut ya da muhtemel mevzuata hâlel getirmez”.

Yukarıdaki uluslararası düzenlemeler doğrultusunda FSEK; bazı özel hallerde yayın kuruluşlarının izni alma gereği olmadan yapılabilecek yayınları 80. maddesinde şu şekilde düzenlemiştir.

“Aşağıda belirtilen hallerde komşu hak sahibi ile film yapımcısının yazılı izni gerekli değildir:

1. Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veya haber amacıyla ve kazanç amacı güdülmeksizin icra edilmesi ve kamuya arzı.

2. Fikir ve sanat eserleri ile radyo-televizyon programlarının yayınlanma ve kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması.

3. Radyo-televizyon kuruluşlarının kendi olanaklarıyla kendi yayınları için yaptıkları kısa süreli geçici tespitler.

4. Bu Kanunun 30 uncu, 32 nci, 34 üncü, 35 inci, 43 üncü, 46 ncı ve 47 nci maddelerinde belirtilen haller.

Bu uygulama, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep dışında zarar veremez veya eserden normal yararlanmaya aykırı olmaz”.

FSEK 80 gereğince; eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı haklara sahip olanlar da eser sahipleri gibi tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i ve tazminat davası haklarından faydalanırlar.

Radyo-televizyon kuruluşlarının hakları, FSEK madde 80/son fıkra gereğince programın ilk yayınlandığı tarihten başlayarak 70 yıl süreyle korunur. Aynı düzenleme Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 3. bendinde yer almaktadır. Uluslararası düzenlemelere gelince; Roma Sözleşmesi'nin 14/c hükmüne göre, yayın kuruluşlarının koruma süresi yayının yapıldığı yılın sonundan başlayarak 20 yıldan az olamaz. TRIPS Anlaşması madde 14/5' de de aynı düzenleme mevcuttur.

Yayın kuruluşlarının yayınlarına ilişkin koruma süresi, Avrupa Birliği Hukuku'nda 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifinin 12. maddesinde düzenlenmiş fakat 93/98 sayılı Direktifle bu madde kaldırılmıştır. Bu konudaki koruma

süresi 93/98 sayılı Direktifin 3. maddesinin 4. bendinde; “*yayın örgütlerinin hakları, uydu veya kablo yolu da dahil olmak üzere, yayın ister tel isterse havadan iletilsin, yayının ilk iletiminden sonraki 50 yılda sona erer*” şeklinde ifade edilmiştir. Koruma süresi, 93/98 sayılı Direktifin 8. maddesi uyarınca süreleri başlatan olayın gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak ayının ilk gününden itibaren hesaplanabilmektedir.

Bu genel açıklamalar doğrultusunda radyo ve televizyon kuruluşlarının mali haklarını tek tek inceleyelim. Bu inceleme esnasında, eser sahibi ve icracı sanatçılardan izin alındıktan sonra, radyo ve televizyon kuruluşu tarafından; sanatçıların televizyon stüdyosuna toplandığını ve bir şarkının veya müzikal gösterinin ilk kez stüdyoda ses kaydedicileri ve kameralar tarafından kaydedildiğini ve bu kaydın yayınlandığını örnek olay olarak düşünebiliriz.

a. Tespit Hakkı

Roma Sözleşmesi’nin 13/b ve TRIPS Anlaşması’nın 14. maddesi 3. bendine göre; radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarının tespitine izin verme ve yasaklama haklarına sahiptirler.

AB Hukuku açısından da 92/100 sayılı “*Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Eser Sahiplerinin Haklarına Bağlantılı Haklara İlişkin Konsey Direktifi*”nin 6. maddesinin 2 ve 3 no’lu bendinde; yayın kuruluşlarının kablo yayınlarıyla kendi yayınlarını yeniden yayınlamaları hariç telli, telsiz veya uydudan yaptıkları tüm yayınların tespiti hakkı ve 93/83/AET sayılı *Uydu Yayınları ve Kablo ile Yeniden İletime Uygulanan Telif Hakları ve Telif Haklarına İlişkin Belirli Kuralların Koordinasyonu Hakkında Konsey Direktifi*’nin 4. maddesinde tespit hakkı düzenlenmiştir.

Hukukumuzda, FSEK madde 80/1C-1’ye göre; “*radyo-televizyon kuruluşları, gerçekleştirdikleri yayınlar üzerinde; yayınlarının tespit edilmesine izin verme veya yasaklama hakkı*” tanınmıştır.

Komşu Haklar Yönetmeliği madde 16/d’de; radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarının tespitine izin verme veya bunu yasaklama konusunda münhasıran yetkili sayılmışlardır.

Sonuç olarak; radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarının ses nakil ve tekrarına yarayan her türlü araca kaydedilmesine izin vermek veya bunu yasaklamak hususunda münhasıran yetkilidir¹⁵⁹.

¹⁵⁹ ARKAN, age., s. 184

b. Çoğaltma Hakkı

Radyo ve televizyon kuruluşlarının çoğaltma hakkıyla ilgili uluslararası anlaşmalara baktığımız zaman Roma Sözleşmesi madde 13/c hükmünde; daha önce tespiti için izin alınmamış tespitlerle, Sözleşmenin 15. maddesinde öngörülen sınırlamalar dışında kalan tespitlerin çoğaltılması için yayın kuruluşlarından izin alınması gerektiğinin ifade edildiğini görmekteyiz. Öyleyse, daha evvel tespit edilmesi için izin alınmış veya madde 15’de sayılan sınırlamalara dahil olduğu için izinsiz tespit edilebilen yayınların çoğaltılması için izin alınmasına gerek yoktur.¹⁶⁰

TRIPS Anlaşması madde 14/3’de; radyo ve televizyon kuruluşlarına, izinleri olmaksızın yayınlarının tespitlerinin çoğaltılması fiilini önleme hakkı tanımıştır.

Avrupa Birliği Hukuku’nda radyo ve televizyon kuruluşlarının çoğaltma hakkı; 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı *Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi* madde 7’de düzenlenmekte iken 2001/29 sayılı *Bilgi toplumunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara İlişkin Belirli Konuların Uyumlaştırılmasına Yönelik Direktifi*’nin 11. maddesiyle kaldırılmıştır. Artık bu konudaki düzenleme 2001/29 sayılı Direktifin 2. maddesinin “e” bendinde bulunmaktadır. 2001/29 sayılı Direktifin 2. maddesi “e” hükmüne göre; yayın kuruluşları; telli, telsiz ya da uydudan yaptıkları yayınlarının tespitlerinin çoğaltılmasına izin verme konusunda yetkilidirler.

Uydu Yayınları ve Kablo İle Yeniden İletime Uygulanan Telif Hakları ve Telif Haklarına İlişkin Belirli Kuralların Koordinasyonu Hakkında 27 Eylül 1993 Tarihli Direktifi’n; “İcracıların, Fonogram Yapımcılarının ve Yayın Kuruluşlarının Hakları” başlıklı 4. maddesinde 2001/29 sayılı Direktife atıfta bulunulmuştur.

FSEK 80. madde 1 no’lu fıkra C bendinde 2 no’lu kısımdaki çoğaltma hakkı düzenlemesine göre; radyo televizyon kuruluşlarının “*özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına izin verme veya yasaklama*” hakkı bulunmaktadır. Benzer hüküm 2954 sayılı TRT Kanunu’nun 32. maddesiyle¹⁶¹ de tekrarlanmaktadır.

¹⁶⁰ ARKAN, age., s. 187

¹⁶¹ 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu Madde 32: Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yayınları, Kurumun yazılı izni alınmadan telli veya telsiz olarak

Bu düzenlemeye göre radyo-televizyon kuruluşları yayınları üzerindeki çoğaltma, tekrar yayın ve vasıtalı/vasıtasız temsil hakları bakımından eser sahibine benzer yetkilerle donatılarak korunmuştur.¹⁶²

Eser sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliğinin 16. maddesinin “d” bendine göre; radyo ve televizyon kuruluşları “*kendi yayınlarının bütününi veya bir kısmını fonogram, videogram veya veri taşıyıcılarına kaydetme ve bu yayınları çoğaltma hakkına sahiptir. Aynı Yönetmeliğin 17. maddesine göre de “bir tespit izinsiz olarak yapılmıyorsa, bu tespiti izleyen yayınların tümünün ya da bir kısmının çoğaltılması” için yayın kuruluşunun izni gerekir.*

c. Yayma Hakkı

Yayma hakları; radyo ve televizyon yayınlarını ve programlarını dvd ve vcd gibi fiziksel kopyalar ve ürünler şeklinde ticarete koyma haklarıdır. Radyo ve televizyon kuruluşları; yayınlarını ve programlarını satmak, uydu ve kablo ile dağıtmak ve kiralamak haklarına sahiptirler.

FSEK 80. madde 1 no’lu fıkrada C bendinde yayma hakkı şu şekilde düzenlenmiştir:

“Radyo-televizyon kuruluşları, gerçekleştirdikleri yayınlar üzerinde;

(1) Yayınlarının ... uydu veya kablo ile dağıtımına izin verme veya yasaklama,

(2) Özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir şekilde ... dağıtımına izin verme veya yasaklama,

hususlarında münhasıran hak sahibidirler.”

Yayın kuruluşlarının yayma hakları “Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği”nde 16. maddede şöyle belirtilmiştir:

“Yayın kuruluşları; yayınlarının çoğaltılmış kopyalarını satışa sunma, satma veya başka yollardan dağıtımını yapma haklarına sahiptirler.”

tekrar yayınlanamaz, ücretli veya ücretsiz olarak tedavüle çıkarılmak üzere bütünü veya bir kısmı tespit olunamaz, çoğaltılamaz ve girişi ücrete tabi yerlerde halka gösterilemez. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun birinci fıkra hükmüne aykırı davranışlara karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı mevcut olduğu gibi, Kurum, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda öngörülen hukuki ve cezai korumadan da yararlanır.

¹⁶² EREL, age., s. 179

d. Temsil Hakkı

Temsil hakkı radyo ve televizyon yayınlarının umuma açık yerlerde doğrudan veya dolaylı gösterilmesidir.

Roma Anlaşması'nın 13/d hükmüne göre, radyo ve televizyon kuruluşları; yayınlarının halkın ücret ödeyerek girdiği bir yerde temsiline ve TRIPS Anlaşması'nın 14. maddesi 3. bendine göre de yayınların genel olarak temsiline izin verme ve yasaklama haklarına sahiptirler.

AB Hukuku açısından da, 93/83/AET sayılı *Uydu Yayınları ve Kablo ile Yeniden İletime Uygulanan Telif Hakları ve Telif Haklarına İlişkin Belirli Kuralların Koordinasyonu Hakkında Konsey Direktifi*'nin 4. maddesinde ve 92/100 sayılı *"Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Eser Sahiplerinin Haklarına Bağlantılı Haklara İlişkin Konsey Direktifi*'nin 8. maddesinin 3 no'lu bendinde, radyo ve televizyon kuruluşlarının; yayınlarının halkın ücret ödeyerek girdiği bir yerde temsiline izin verme hakkı olduğu düzenlenmiştir.

FSEK 80. madde 1 no'lu fıkrada C bendinde temsil hakkı şu şekilde düzenlenmiştir:

"Radyo-televizyon kuruluşları, gerçekleştirdikleri yayınlar üzerinde;

(3) Yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına izin verme veya yasaklama,

hususlarında münhasıran hak sahibidirler."

FSEK 41. maddesi ise; umumi yerlerde radyo ve televizyonlar kullanılarak müzik yayını yapılabilmesi için radyo ve televizyon yayın kuruluşlarından izin alma gereğini diğer hak sahipleri ile yayın kuruluşlarını organize ederek aşağıdaki biçimde farklı bir sisteme bağlamıştır:

"Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı mali hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar.

Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanan ve/veya ileten umuma açık mahaller; mahallin bulunduğu bölgenin özelliği, mahallin nitelik ve niceliği, fikrî mülkiyete konu eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası ve ürün veya hizmete katkısı olup olmadığı ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle sınıflandırılır veya sınıflandırma dışı bırakılır.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımından ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile umuma açık mahaller arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

Tarifelere ilişkin sözleşmelerde takvim yılı esas alınır ve bu tarifeler takvim yılı başından itibaren geçerli olur.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasını teminen:

1. Meslek birlikleri temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bilgileri, Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimler her üç ayda bir güncellenir ve Bakanlıkça oluşturulan ortak bir veri tabanı üzerinden ilgili taraflara açılır.

2. Eser sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya bağlantılı hak sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya aynı sektörlerde faaliyet gösteren meslek birlikleri, biraraya gelerek protokole bağlamak suretiyle ortak tarifeler belirleyebilirler. Ortak tarifeler protokole taraf meslek birlikleri açısından bağlayıcıdır.

Meslek birlikleri, tarifeler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildirirler ve kamuoyuna duyururlar. Umuma açık mahaller, müzakere ve sözleşme yapılmasına ilişkin verecekleri bağlayıcı nitelikteki yetki belgeleri ile üye oldukları meslek kuruluşları aracılığıyla da tarifeleri veya ortak tarifeleri müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler. Ancak, tarifelerin götürü usulde tespit edilmesi halinde umuma açık mahaller sadece meslek kuruluşları aracılığı ile müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler.

Onuncu ayda umuma açık mahaller veya meslek kuruluşları ile meslek birlikleri arasında tarifeler veya ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde, en geç bu ayın sonuna kadar, meslek birlikleri ve/veya meslek kuruluşları tarafından bu tarifelerin Bakanlıkça oluşturulacak uzlaştırma komisyonunda müzakere edilmesi talep edilebilir.

Uzlaştırma komisyonu, taraflardan birinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, tarifeleri müzakere etmek üzere, Bakanlık tarafından talep tarihinden itibaren onbeş gün içinde oluşturulur. Komisyon Bakanlıktan bir, Rekabet Kurumundan iki temsilci ve ilgili meslek birlikleri ile kullanıcıları temsil eden meslek kuruluşlarının birer temsilci-

sinden oluşur. Bakanlık temsilcisi aynı zamanda komisyon başkanıdır. Aynı usulle, komisyon üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Komisyonun sekreteryaya hizmetleri Bakanlık ilgili birimi tarafından yürütülür. Komisyon, oluşturulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde, raporunu hazırlayarak, Bakanlığa ve taraflara bildirir. Umuma açık mahaller ve meslek birlikleri, Komisyon raporunun açıklandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde, meslek birliklerinin açıklamış oldukları tarifeleri veya müzakereler neticesinde mutabakata vardıkları tarifeleri sözleşmeye bağlayabilirler. Meslek birliklerince belirlenen tarife veya ortak tarifeler üzerinden sözleşmenin yapılmaması halinde, taraflar yargı yoluna başvurabilirler. Yargılama sürecinde, bir önceki yıl sözleşme yapmış olan mahaller, ilgili meslek birlikleri aksini bildirmedikçe, dava konusu tarifenin 1/4'ünü dava sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir meslek birlikleri adına açılmış banka hesabına yatırmak suretiyle eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilir ve/veya iletebilirler. Bir önceki yıl sözleşme yapmamış umuma açık mahaller ile ilk defa sözleşme yapacak umuma açık mahallerin bu fıkra da öngörüldüğü şekilde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilmeleri ve/veya iletebilmeleri ise ilgili meslek birliklerinin iznine bağlıdır. Dava sonuçlanıncaya kadar bu şekilde ödenen miktar, mahkeme kararıyla tespit edilen tarife bedelinden mahsup edilir.

Tarifelerin tespit edilmesinde ve uzlaşmazlıkların hallinde, bu Kanunun 42/A maddesinin üçüncü fıkrasında¹⁶³ yer alan, tarife tespitine ilişkin esaslar dikkate alınır.

Mahallerde kullanılan ve/veya iletimi yapılan eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar üzerinde hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, bunların kullanımına ve/veya iletimine ilişkin ödemelerin yapılmasını yetki verdikleri meslek birlikleri aracılığı ile talep edebilirler. Sinema eserleri bakımından bu fıkranın uygulanması zorunlu değildir.

¹⁶³ FSEK 42/A 3. fıkrası: Tarifelerin tespit edilmesinde; tarifelerin uluslararası uygulamaların ülkenin ekonomik ve toplumsal koşullarına uyarlanabilirliği göz önünde bulundurularak makul seviyede belirlenmesi ile teknolojik alandaki değişimlerin yanı sıra eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların yaratıldığı ve kullanıldığı sektörlerin yapısını tahrip edici, üretimi ve kullanımı engelleyici ve genel kabul görmüş uygulamalara zarar verici bir etki yaratılmaması, rekabeti bozucu şartlar oluşturulmaması, yapılan sınıflandırma, ilgili sektörlerdeki ürün fiyatları ve bu sektörlerin gayrisafi milli hâsıladaki payı, eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletim sıklığı, birim fiyat veya götürü usulü ödeme, ödeme plânı ve benzeri hususlar esas alınır.

Sınıflandırma, uzlaştırma komisyonuna başvuru halinde Bakanlıkça alınacak ücretler ve uzlaştırma komisyonunun çalışması ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.”

Bu düzenleme birçok açıdan yayıncı kuruluşlar için sakıncalar içermekle birlikte tekrardan kaçınmak için, bu sakıncalar ve eleştirilerimiz hakkında “V. Müzik Eseri Sahibinin Hakları, B. Müzik Eseri Sahiplerinin Mali Hakları, 4. Temsil Hakkı, Umuma Açık Yerlerde Müzik Eserlerinin Kullanılması ve VI. Komşu ve Bağlantılı Hak Sahiplerinin Hakları, B. Fonogram Yapımcılarının Hakları, c. Temsil Hakkı” adlı bölümlere bakılmasını öneriyoruz.

Yayın kuruluşlarının temsil hakları “Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği”nde madde 16’da şöyle belirtilmiştir:

“Yayın kuruluşları; yayınlarını başka bir yer(de) ve araçlarla topluma gösterilebilme” konusunda izin hakkına sahiptir. Yine Yönetmeliğin 17. maddesine göre; *“yayınların başka kişi ya da kuruluşlar tarafından giriş ücreti olan yerlerde toplumun istifadesine sunulması...”* halinde yayın kuruluşlarının yazılı izni gerekmektedir.

Uluslararası kurallar ve Türk Hukuku’nun yukarıda belirttiğimiz düzenlemelerine göre; herhangi bir kamuya açık yerde yayın kuruluşlarının yayınının temsili, yani radyo yayınının dinlettirilmesi veya televizyon yayının izlettirilmesi için yayın kuruluşundan izin alınması gereklidir. Girişin ücretli olup olmaması önem taşımaz. Ancak girişin ücretli olması o yerin kamuya açık olduğuna dair karine sayılmalıdır¹⁶⁴.

Bu arada hemen ifade edilmelidir ki; bir yayının hukuka uygun olarak temsili için, yayın kuruluşundan izin almanın yanı sıra, canlı bir icranın yayını söz konusu ise eser sahibi ve icracı sanatçıdan da izin alınması gereklidir¹⁶⁵. Eğer yayın bir ses veya görüntü taşıyıcısından (kaset, cd ve yayın bandından) yararlanılarak yapılmakta bu tespitin sahibi olan fonogram yapımcısından veya kaydı ilk tespit eden diğer yayın kuruluşundan izin alınması da gereklidir.

İcracı sanatçılarla ilgili bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, temsil doğrudan ve dolaylı temsil olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan temsilde bir eser, arada bir araç olmaksızın çalınmakta, gösterilmekte

¹⁶⁴ ARKAN, age., s. 190

¹⁶⁵ ARKAN, age., s. 190

veya oynanmaktadır. Bir başka deyişle icra edilmektedir. Dolaylı temsilde ise, eser onu nakle ya da tekrara yarayan mekanik bir vasıta aracılığıyla temsil edilmektedir. Görüldüğü gibi, radyo-televizyon yayınlarının umuma açık bir yerde bulunan kimselere izlettirilmesi veya dinlettirilmesi dolaylı temsil kapsamına girmektedir¹⁶⁶.

Umumi mahallerin temsil ettikleri yayınlara ilişkin ödemeleri nasıl yapacaklarına ilişkin şunları söyleyebiliriz:

Fikri ürünlerin umumi mahaller tarafından kullanımı karşılığında yapacakları ödemelere ilişkin sistem, 2004 yılında FSEK madde 41’de yapılan son değişiklikle temelden değiştirilmiştir. Bu hüküm, icracı sanatçılarla ve fonogram yapımcıları ile ilgili bölümlerde detaylı olarak incelendiği için oradaki açıklamalarımıza atıf yapmakla yetiniyoruz¹⁶⁷. Ama ekleyelim ki, umumi yerlerde radyo ve televizyon yayınlarının gelenlere izlettirilebilmesi için (veya radyo ve televizyonlar vasıtasıyla müzik klipi ve şarkıları yayınlamak için); otel, mağaza, lokanta, bar, diskotek gibi umumi yer sahipleri ve işleticilerinin; eser sahiplerinden, icracı sanatçılardan, fonogram yapımcılarından ve bu bölümde açıklandığı üzere, kendi yayınları üzerinde hak sahibi olan radyo ve televizyon kuruluşlarından izin alınması gerekir. Ancak; radyo televizyon yayınında müzik eserleri veya diğer tür fikir ve sanat eserleri kullanılmıyorsa (mesela sadece haber veya magazin programları varsa); o zaman sadece radyo ve televizyon yayın kuruluşundan veya onun üyesi olduğu meslek birliğinden ve yayınların içinde film gibi başka eserler varsa filmlerdeki hak sahibi kişilerden izin almak gerekir. Eğer yayıncı kuruluş diğer eser sahiplerinden umumi yerlerde yayınları izlettirmek için tüm hakları devralmışsa (sınırlı lisanslarda lisansın içeriği önemli) sadece yayın kuruluşundan izin alınarak yayın yapılabilir. Ancak; müzik eserleri için yaygın uygulamada eser sahipleri, icracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları radyo ve televizyonlarla yaptıkları yayın sözleşmelerinde, umumi mahallerde temsil hakkı için izin vermediklerinden, sadece radyo ve televizyon kuruluşu veya onların meslek birliğinden izin almak yeterli olmaz.

e. Umuma İletim Hakkı

Genel olarak umuma iletim hakkı; yayın, yeniden yayın ve gerçek kişilerin bilgisayarlar veya cep telefonları ile seçtikleri yer ve zamanda

¹⁶⁶ ARKAN, *age.*, s. 190

¹⁶⁷ ARKAN, *age.*, s. 190

yayınlarla erişim hakkı (kamuya erişim hakkı) olarak üç ayrı hakkı içermektedir. Ancak; radyo ve televizyon kuruluşları yayın hakkını kendi radyoları veya televizyonlarından kullandıkları için sadece yeniden yayın ve kamuya erişim hakkı konusunda haklara sahiptirler.

Radyo ve televizyon kuruluşlarının yeniden yayın yoluyla kamuya iletim hakkı; uluslararası düzenlemelerde şu şekilde düzenlenmiştir:

Roma Sözleşmesi 13/a maddesinde, yayın kuruluşlarına yeniden yayın hakkı tanınmıştır.

TRIPS Anlaşması'nın 14/3 maddesinde; yayın kuruluşlarına yayınlarının telsiz araçlarla tekrar yayınlanmasını önleme hakkı tanınmıştır.

Avrupa Birliği Hukuku'na gelince; 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı *Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi*'nin "Yayın ve Kamuya İletim" başlıklı 8. maddesinin 3. bendinde; iletim kamuya açık alanlarda giriş ücreti karşılığında yapılıyorsa, yayın kuruluşlarına yayınlarının kablosuz yöntemlerle kamuya iletimi münhasır hakkını sağlarlar, şeklinde ifade edilmiştir.

Bununla beraber; 27 Eylül 1993 tarihli 93/83/AET sayılı *Uydu Yayınları ve Kablo ile Yeniden İletime Uygulanan Telif Hakları ve Telif Haklarına İlişkin Belirli Kuralların Koordinasyonu Hakkında Konsey Direktifi*'nin 4. maddesiyle, yeniden iletim hakkı ile ilgili olarak; 92/100/AET sayılı Direktifin 8. maddesine atıf yapılmaktadır. Atıf yapılan madde şöyledir:

"1. Üye devletler, yayın icrası veya tespit sonucu gerçekleştirilen icra haricinde, icracılara kablosuz yayın konusunda yetkilendirme ya da yasaklama ve icralarının kamuya iletimi münhasır hakkını sağlarlar.

2. Üye devletler, ticari amaçlarla yayınlanan fonogram ya da bu nevi fonogramın çoğaltımı kablosuz yöntemlerle yayın ya da kamuya iletim amacıyla kullanılıyorsa, tek adil bedelin kullanıcı tarafından ödenmesini sağlamak ve söz konusu bedelin ilgili icracılar ve fonogram yapımcıları arasında paylaşılmasını sağlamak için hak sağlarlar. Üye devletler, icracılar ve fonogram yapımcıları arasında anlaşma olmaması durumunda, söz konusu bedelin onlar arasında paylaşılmasını belirleyen şartları düzenlerler.

3. Üye devletler, söz konusu iletim kamuya açık alanlarda giriş ücreti karşılığında yapılıyorsa, yayın kuruluşlarına yayınlarının kablosuz yöntemlerle çoğaltımı ya da kamuya iletimi münhasır hakkını sağlarlar."

FSEK 80. madde düzenlemesi 1 no’lu fıkrada C bendine göre;

“Radyo-televizyon kuruluşları, gerçekleştirdikleri yayınlar üzerinde;

(1) Yayınlarının ... diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına izin verme veya yasaklama,

(4) Tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin verme,

(5) Haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine ilişkin izin verme veya yasaklama, hususlarında münhasıran hak sahibidirler.”

FSEK madde 80 doğrultusunda, bir radyo veya televizyon yayın kuruluşunun eser niteliğindeki bir yayınının ve tespitinin başka bir yayın kuruluşu tarafından eş zamanlı iletimi, gecikmeli iletimi, kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi, yeniden iletimi için tespiti veya yayını yapan radyo ve televizyon kuruluşundan izin alınması gerekir.

Yayın kuruluşlarının umuma iletim hakları “Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği” madde 16’da şöyle belirtilmiştir:

“Yayın kuruluşları;

- Yayınlarını tekrar yayınlama,

- Yayınlarını başka bir yer ve araçlarla topluma gösterilebilme, haklarına sahiptirler.”

Yine Yönetmeliğin 17’nci maddesine göre yayın kuruluşlarının yazılı iznini gerektiren durumlar şunlardır:

“...b) Yayınlarının başka yayın kuruluşları tarafından aynı anda ya da yeniden telli ya da telsiz olarak yayınlanması”

Bu hukuki düzenlemeler doğrultusunda; kendilerinden izin alınmaksızın eser niteliğindeki yayınlarının bir başka yayın kuruluşu tarafından kullanılması halinde hak sahibi radyo ve televizyon kuruluşu, FSEK’e dayanarak; tecavüzün refi, tecavüzün menı, tazminat davaları ve ilgililerin hapisle cezalandırılması için ceza davaları açabilirler.

Bu davaların yanı sıra yayın kuruluşları kendi yayınlarını izinsiz kullanan Türkiye’deki diğer özel radyo ve televizyon kuruluşlarının idari olarak uyarılması ve cezalandırılması için Radyo Televizyon Üst Kurulu’na da 3984 sayılı Kanun gereğince başvurabilirler. 3984 sayılı

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun yayın ilkeleri ile ilgili 4. maddesinin “o” bendinde; “yayınlarda eser ve bağlantılı hak sahiplerine 5846 sayılı FSEK ile tanınan hakların ihlal edilmemesi”ni radyo ve televizyonlar için bir yükümlülük olarak koymuştur. Kanun 37. maddesinde de; “Radyo-Televizyon kuruluşlarınca yayınlanan ve/veya iletilen eser, fonogram ve yapımları kullanabilmek için, eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri, veya bu kişilerin üyesi oldukları meslek birlikleri ile izin almak üzere sözleşme yaparlar ve bu sözleşme ile belirlenen mali hak bedellerini öderler. Bu sözleşme ve ödemeler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır. Bu madde hükümlerini ihlal eden yayın kuruluşları hakkında ayrıca bu Kanunu’nun 33 üncü madde hükümleri uygulanır” diyerek, Kanuna uyulmaması halinde yayın kuruluşlarına RTÜK’ün uyarı, program durdurma, para cezaları ve sonunda yayın izninin iptaline kadar cezalar verebileceği düzenlenmektedir.

Daha evvel, icracı sanatçılarla, fonogram yapımcılarının haklarını incelerken ayrıntılı olarak üstünde durduğumuz gibi, internetin doğuşu ve kullanımının yaygınlaşması sonucunda ortaya çıkmaya başlayan sorunlar, özel hukuksal düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu tür sorunlar karşısında geleneksel mali hakların yeterli olmadığını gören yasa koyucular, eser ve bağlantılı hak sahiplerini korumak için bağımsız bir hak tanımaya başlamışlardır. İngilizce’de “right of making available to the public” ve Almanca’da “Recht der öffentlichen Zugänglichmachung” şeklinde ifade edilen ve Türkçe’ye “kamunun erişimine sunma hakkı” veya “kamuda erişilebilir kılma hakkı” şeklinde çevirdiğimiz bu hak bazı ülkelerde yayın kuruluşlarına da tanınmıştır¹⁶⁸.

Abonelerin, istedikleri programa istedikleri saatte erişebildikleri aboneliğe bağlı elektronik iletimler ile bilgisayarlar yardımıyla internet üzerinden yapılan iletimler ve cep telefonlarında yayın izlemeye yönelik olan bu hak, yapılan son yasa değişikliği ile FSEK madde 80/1C-4’de yayın kuruluşlarına tanınmıştır. Bu sebeple, bir yayın kuruluşunun yayınının kamunun erişimine sunulması için bu kuruluşun iznine ihtiyaç vardır¹⁶⁹.

Radyo ve televizyon yayınlarının kullanıcılara izin alınmaksızın ulaşmasını sağlayan internet web sitelerine ve kişisel sayfalara karşı erişimin önlenmesi yoluyla önlem alınmıştır. FSEK’e 2004 yılında ekle-

¹⁶⁸ ARKAN, age., s. 197

¹⁶⁹ ARKAN, age., s. 197

nen bir hüküm ile, Türk Telekom gibi internet servis sağlayıcılar vasıtasıyla kullanıcıların bu sitelere erişimi engellenmektedir. Bu düzenleme şöyledir:

“Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâlê konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlê durdurulmasını ister. İhlâlê devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâlê devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlê durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

Son yapılan kanun değişikliği ile FSEK madde 80/1 C-5 ile yayın kuruluşlarına; haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine ilişkin olarak da izin verme veya yasaklama hakkı tanınmıştır¹⁷⁰.

Bu düzenleme ile yayın kuruluşlarına, henüz yayınlamış olmadıkları yayın sinyallerini başka bir yayın kuruluşunun yayınlanmasını engelleme hakkı verilmiştir. Aslında, bir yayın kuruluşunun yayını üzerinde bağlantılı hak kazanabilmesi için, öncelikle yayını gerçekleştirmesi gerekmektedir. ARKAN’a göre; henüz gerçekleşmemiş bir yayın üzerinde, yayın kuruluşlarına bağlantılı hak tanınması, sisteme uygun olmayan bir düzenlemedir¹⁷¹.

Bu hukuki düzenlemeler doğrultusunda; kendilerinden izin alınmaksızın eser niteliğindeki yayınlarının, kamuya erişim yoluyla ve bilgi-

¹⁷⁰ ARKAN, age., s. 198

¹⁷¹ ARKAN, age., s. 198

sayarlar veya cep telefonlarıyla üçüncü şahıslar, web siteleri veya cep telefonları operatörleri tarafından kullanılması halinde hak sahibi radyo ve televizyon kuruluşu, FSEK'e dayanarak tecavüzün refi, tecavüzün menî, tazminat davaları ve ilgililerin hapisle cezalandırılması için ceza davaları açabilirler.

D. FİLM YAPIMCISININ HAKLARI

Müzik eserlerinin kullanımı ile sınırlı olarak film yapımcısının haklarını inceleyeceğimiz bu bölümde, sinema eseri ve film yapımcılığı ile temel kavramlara da konumuzu açıklayabilmek için değineceğiz.

Sinema eserlerinde kullanılan müzikler açısından asıl olarak iki tane hak sahibi bulunmaktadır:

Bunlardan ilki; yönetmen, senaryo yazarı ve dialog yazarı ile birlikte sinema eserinin sahibi olan müzik bestecisidir. İkincisi ise film yapımcısıdır. Bağlantılı hak sahibi olarak film yapımcısı, bazı durumlarda sinema eserine dahil olan müzik eserinin mali haklarını devralmakta ve bu hakları üçüncü kişilere karşı kullanabilmektedir.

Sinema eserinin birlikte hak sahiplerinden biri olan müzik bestecisi, sinema eserinde kullanılan müzik eseri üzerinde (sadece bestesini yaptığı kısım açısından) zaten ve aslen hak sahibidir. Müzik eseri doğal olarak sinema filminden bağımsız olarak kendi başına tasarruf edilebilen ve ayrılabilir bir eserdir. Müzik eseri sinema filminden bağımsız olarak plağa, cd'ye alınabilir veya cep telefonu ile bilgisayarlar üzerinden üçüncü kişilere yararlandırılabilir. Bu anlamda FSEK madde 80'de, müzik eseri sahibinin, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcı ile yaptığı sözleşmedeki hükümler saklı olmak kaydıyla, eserini yayımlama ve icra hakkını muhafaza edeceği özel olarak hüküm altına alınmıştır. Sinema filminden ayrılabilen müzik eseri üzerindeki hak sahipliği açısından yukarıda "IV.B.Müzik Eseri Sahipliği" bölümündeki açıklamalarımız birebir geçerlidir. Müzik bestecisinin müzik eseri sahibi olarak hakları ve bu hakların kullanılması ile üçüncü kişilere karşı korunması hakkında "V. Müzik Eseri Sahiplerinin Hakları" bölümündeki tüm açıklamalarımız geçerlidir.

Bestecisi tarafından müzik eserinin tüm hakları film yapımcısına devir edilebilir veya besteci, film yapımcısının müzik eserinden yararlanması için lisans/ruhsat verebilir. Bu açıdan film yapımcısı, müzik eserinin yeni mali hak sahibi veya lisans kullanıcısı olarak FSEK tara-

findan korunur. Film yapımcısı, devir veya lisans aldığı müzik eseri ile ilgili mali haklar açısından müzik bestecisinin yerine geçerek onun gibi korunur. Film yapımcısının yeni hak sahibi olarak korunması eser sahibinden farksız olup, film yapımcısının devraldığı müzik üzerindeki haklarının nasıl korunacağına ilişkin “V. Müzik Eseri Sahiplerinin Hakları” adlı bölüme bakılmasını öneririz.

Müzik bestecisinin, sinema eseri üzerindeki haklarının kullanma yetkisini film yapımcısına devretmesi halinde, konunun müzik eseri ile bir ilgisi kalmayacağından, artık ortada saf bir sinema eseri ve bundan doğan haklar söz konusu olacağından (çalışmamızın kapsamı dışındaki) bu olasılık bizim inceleme alanımız dışındadır.

Müzik eseri ile filmin çakıştığı önemli bir konu; bir müzik eserinin bir sinema filmi haline getirildiği işlenme sinema eseridir. İşlenme eserlerin düzenlendiği FSEK madde 6’nın 3 no’lu bendinde belirtilen “*musiki ... eserlerinin film haline sokulması veya filme alınmaya ... müsait hale sokulması*” sonucu ortada **müzik eserinden ayrılamaz** bir sinema eseri bulunacaktır. Her ne kadar müzik eseri sinema filminden ayrı bir eser olarak korunmakla birlikte, çoğu zaman sinema görüntüleri ve filmin senaryosu müzik eserini çıkarttığımız zaman anlamsız görüntüler dizisi olarak kalabilir. Bu sebeple müzik eserinin sinema filmi haline gelmiş hali çalışmamızı ilgilendirdiğinden ve içindeki müzik eseri ile ayrılmaz bir bütün olan bu sinema eseri bizim bu kısımda incelememize dahil edilmiştir.

Bu bölümde, film yapımcısının; içinde müzik eserinden unsurlar bulunan sinema filmindeki hakları nasıl kullanacağını ve haklarının üçüncü kişilere karşı nasıl koruyacağını inceleyeceğiz.

Bu inceleme için öncelikle sinema eserinin kısaca ne olduğunu, sonra film yapımcısını ve en son olarak film yapımcısının haklarını irdeleyeceğiz.

Sinema eseri tanımı, 1866 tarihli Bern Sözleşmesi’nin ilk metninde yer almamakla beraber; 1908 yılındaki Bern Sözleşmesi değişikliği sırasında ilk kez belirli şartlar altında sinema filminin korumaya konu olabileceği kabul edilmiştir. Ancak, sinema eserleri alanındaki en önemli gelişme Bern Sözleşmesi’nde 1948 tarihli Brüksel Değişikliği esnasında ortaya çıkmıştır. Yapılan değişiklikle “sinema eserleri ve sinematografi tekniğine benzer bir yöntemle ifade edilen ürünler”, bağımsız bir fikir ve

sanat eseri olarak, Sözleşmenin fikir ve sanat eserlerinin genel çerçevesini oluşturan 2. maddesi kapsamına dahil edilmiştir.¹⁷²

Sinema eseri; tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbirleriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir. Sinema eserleri, diyalog, müzik ve resim kompozisyonundan meydana gelen bir bütündür. Eser, birden çok resme suni bir hareketlilik, canlılık kazandırılması ile oluşturulmaktadır. Bu nedenle, kullanılan resim ya da fotoğrafların bir bütünlük içerisinde kaynaştırılmaları, onların hareketli görüntüler dizisi oluşturulması, diğer tür eserlerden sinema eserlerini ayırmaktadır.¹⁷³

AYİTER, sinema eserini; birden fazla kimsenin değer itibariyle eş olmayan çeşitli yaratma ve çalışmalarından meydana gelen ortak bir eser olarak tanımlamıştır.¹⁷⁴ Bu ise, sinema eserlerinin en büyük özelliğidir. Söz, hareketli resim ve müzik unsurları bir arada kullanılarak filmler meydana getirilmektedir. Çekilen bir filmin sinema filmi olabilmesi için bir eser özelliği göstermesi gerekmektedir. Örneğin, bir olayı sırf seyircisine nakletmek için çekilmiş görüntüler, çekicisinin özelliğini taşımadığı için sinema eseri sayılmaz. Ancak, belli bir düzen altında olayların gösterilmesi bir özellik taşıyorsa, kameranın kullanılmasında bir kompozisyon yaratılmışsa bir sinema eserinden bahsedilebilir. Kanun'un eski düzenlemesinde de "sırf beste, nutuk, konferans vesaireyi nakle yarayan filmler sinema eseri sayılmaz" demektir.¹⁷⁵

FSEK'in 5. maddesi; sinema eserlerini,

- a) Sinema filmleri,
- b) Öğretici ve teknik mahiyette olan ve günlük olayları tespit eden filmler ve
- c) Her nevi ilmi, teknik veya bedii mahiyette projeksiyon dispozitifleri olarak saymıştır.

Bu hükme göre sesli veya sessiz filmlerin hepsi sinema eseri kabul edilmektedir.¹⁷⁶

Kanun'a göre, öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler, aktüalite filmleri sinema eseridir. Burada sinema filmleri için bir unsur olarak önemli olan, bu filmlerin öğretici

¹⁷² ATEŞ, age., s. 67 vd

¹⁷³ KINACIOĞLU, agm. s. 209-219

¹⁷⁴ AYİTER, age., s. 62

¹⁷⁵ YARSUVAT, age. s. 51-52

¹⁷⁶ YARSUVAT, age., s. 52

veya teknik nitelikte olmalarıdır. Ek olarak, burada bakılması gereken husus, bu filmlerde “eser” niteliği oluşturan bir özelliğin bulunmasıdır. Özellik bulunmayan teknik veya bilimsel filmler korunmazlar. Sözgeçlimi, bir futbol maçının filme alınması bu filmi, sinema eseri haline dönüştürmez¹⁷⁷. ARKAN’a göre; bir sportif faaliyet, yakın uzak plan çekimleri pozisyonların dondurulması veya tekrarlanması gibi sinema teknikleri kullanılarak ve buna, spikerin kendine has üslubuyla maçı yorumlaması eklenerek kayda alınmışsa; günlük olayları tespit eden film kategorisinde, bir sinema eserinden bahsetmek mümkün olmalıdır.¹⁷⁸

Yukarıdaki açıklamalar esas alındığında sinema eserinin üç temel unsurdan meydana gelmesi gerekmektedir:

- Birbirleriyle ilişkili olmak kaydıyla hareketli bir görüntü dizisi.
- Bu görüntü dizisinin az veya çok kalıcı bir ortama tespit edilmiş olması.
- Tespit edilen görüntü dizisinin mekanik, elektronik veya benzeri bir araçla gösterilebilir olmasıdır.¹⁷⁹

Film kavramı Kanunumuzda tanımlanmamakla birlikte 92/100 sayılı Topluluk Direktifinde film; “*sesli veya sessiz bir sinematografik veya görsel- işitsel eser ile sair hareketli görüntüler dizisidir*” olarak tarif edilmektedir.¹⁸⁰

Sinema eseri sahipliği, FSEK madde 8’de düzenlenmiştir. 4630 sayılı Kanunla değişik söz konusu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, “***sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler. Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin birlikte sahipleri arasındadır***”¹⁸¹. Maddenin eski halinde “*sinematografik eserlerde; yönetmen, özgün müzik bestecisi ve senaryo yazarı eserin birlikte sahipleridir*” denmekteydi. Kanun değişikliği bu hükme iki yenilik getirmiştir. Birincisi, “diyalog yazarı”nın eser sahiplerine eklenmesi, ikincisi ise animasyon tekniği ile üretilen eserlerde animatörün sinema eseri sahiplerine eklenmesidir. Eser sahibi olarak gösterilen bu kişilerin ortak özelliği, sinema eserinin meydana getirilmesinde “özellik arz eden emekleri” ile

¹⁷⁷ YARSUVAT, age., s. 52

¹⁷⁸ ARKAN, age., s. 204

¹⁷⁹ ATEŞ, age., s. 69

¹⁸⁰ YARSUVAT, age., s. 52

¹⁸¹ ATEŞ, age., s. 83

katkıda bulunmuş olmalarıdır. Belirtilenler dışında kalan kişilere, sinema eserinin meydana getirilmesindeki katkıları “esere hususiyet verici düzeye” ulaşmadığından, eser sahibi olma statüsü verilmemiştir¹⁸².

Sinema filminin finansman ve organizasyon sorumluluğunu üstlenen kişiye “film prodüktörü” veya “film yapımcısı” denir. Film yapımcısı kavramı da Kanunda tanımlanmış değildir. Fakat FSEK' in 80. maddesinin 2. bendinde; “*filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcısı*”ndan söz edilmektedir. Tespit terimi ise FSEK madde 1 / B' de “*seslerin veya ses temsillerinin veya ses ve görüntülerin anlaşılabilir, çoğaltılabilir veya iletilerilecek şekilde bir araca kaydedilme işlemi*” olarak kullanılmıştır.

ATEŞ, yapımcıyı; “*sesli olup olmamasına bakmaksızın, görüntüleri anlaşılabilir, çoğaltılabilir ve iletilerilecek şekilde bir araca ilk kez kaydeden gerçek ya da tüzel kişi*” olarak tanımlamaktadır. TEKİNALP film yapımcısını; “*bir sinema eserini, sermayesi ve örgütlenme gücü ve yeteneğiyle meydana getirerek, filme tespit eden gerçek veya tüzel kişi*” diye tanımlamıştır. Doktrinde genel kabul görmüş olan görüşe göre de; her film yapımcısının bağlantılı hak sahibi sıfatını kazanamayacağını, yalnızca sinema eseri yapımcılarının bu sıfatı kazanabileceğini, çünkü eser niteliği taşımayan bir filmin esere bağlı bir hakkının olmayacağını söyleyebiliriz. Eser niteliğini taşımayan filmlerin tespitini yapan kimselerin FSEK madde 84'e göre haksız rekabet esasları çerçevesinde korunacağını da belirtmekte fayda görüyoruz.¹⁸³ ATEŞ ise aksi görüşte; sinema eseri niteliği taşıyan taşımanın herhangi bir filmin ilk tespitini yapan her filmin yapımcısının bağlantılı hak sahibi olduğunu belirtmiştir. Bu konuyla ilgili olarak 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi'nin 2/1. maddesinde; film ya da yayınları hakkında kiralama ve ödünç hakkının, filmin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıya ait olduğu belirtilmiştir. Direktif'e göre film; eser niteliği taşıyan veya taşımayan şeklinde ayrılmadığından, eser niteliği taşıyan veya taşımanın filmin ilk tespitini yapan kişi filmin yapımcısı ve bağlantılı hak sahibi olarak korunacaktır.

FSEK madde 80/III'e göre, “*bir sinema eserinde, olağan şekilde adı bulunan gerçek veya tüzel kişi, aksine bir kanıt bulunmadıkça, filmin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcı olarak kabul edilir*”. Kanunda film yapımcısından söz edilirken “tespiti ilk kez yapan kişiye” vurgu yapılmaktadır. Bu sebeple, daha önce tespiti yapılan bir görüntünün çoğaltıl-

¹⁸² ATEŞ, age., s. 84

¹⁸³ TEKİNALP, age., S.17 N 41.

ması, örneğin; bir video bandında veya sinema şeridinde kayıtlı filmin başka ortamlara kopyalanması, bu anlamda ilk tespit olmadığı gibi, bu kopyalamayı yapanı da film yapımcısı olarak kabul etmek mümkün değildir. Film yapımcısı, görüntüyü (film bandı veya digital chip üzerine) kayda ilk kez alan kişidir.¹⁸⁴

FSEK madde 80/2’de; “*filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcısı, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara sahiptir*” şeklinde, film yapımcısının haklarının, eser sahibi ve icracı sanatçıdan devren iktisap olunan haklar niteliğinde olduğunu çağrıştıran bir ifadeye yer verilmiştir¹⁸⁵. Bu ifadeden film yapımcısının bağlantılı hak sahibi olabilmesi için eser sahibi (yönetmen, senarist, diyalog yazarı, müzik bestecisi ve varsa animatör)ve icracı sanatçıdan¹⁸⁶ (oyunculardan) tüm mali hakların **kullanma yetkisini devralması** gibi bir sonuç çıkmaktadır. Oysa, film yapımcısının eser sahibi ve icracı sanatçıdan tespit için **izin** alması bağlantılı hak sahibi olabilmesi için yeterlidir. Ancak, “*Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Ve Federasyonları Hakkında Tüzük*” madde 4 uyarınca, bu izni verecek olan eser sahibi veya bağlantılı hak sahibi, meslek birliğine kayıtlı ise yani birliğe haklarının takibi için yetki vermiş ise artık izin meslek birliğinden alınacaktır.

Kanunda yapılan son değişiklikle eser sahipliği statüsü verilmemiş ise de, yapımcının durumu, eser sahibinin haklarına “bağlantılı hak sahibi” olarak tanımlanmıştır. Kanuni düzenlemeye göre, yapımcı, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra, eserin doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi, radyo - televizyon gibi her türlü ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi konusundaki mali yetkilerin tek sahibi olmaktadır¹⁸⁷.

Sinema eseri sahiplerinin iç ilişkilerinde, olayın özelliğine göre, iştirak halinde eser sahipliğine veya müşterek eser sahipliğine ilişkin kurallar uygulanır¹⁸⁸. Eğer eser FSEK madde 10 gereğince iştirak halinde meydana getirilmiş ise o zaman film yapımcısı tüm eser sahiple-

¹⁸⁴ ATEŞ, age., s. 233

¹⁸⁵ ATEŞ, age., s. 234

¹⁸⁶ FSEK madde 8’de eser sahibi olarak gösterilmediği halde sinema eserinin vücuda getirilmesine önemli katkıda bulunan oyuncuların (aktör, artist, figüranların) hakları, icracı sanatçı olarak FSEK madde 80 hükümlerine göre korunacaktır.

¹⁸⁷ ATEŞ, age., s. 85

¹⁸⁸ ATEŞ, age., s. 85

rinden izin almalıdır. Eğer eser FSEK madde 9 gereğince müşterek olarak meydana getirilmişse o zaman her bir bağımsız bölümün sahibinden izin alınması gereklidir.

Uluslararası sözleşmelere baktığımız zaman film yapımcılarına bağlantılı hak tanınmasıyla ilgili bir düzenleme görememekteyiz. Avrupa Birliği Hukuku'nda ise film yapımcılarına bağlantılı hak tanınması 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı *Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi*'nin 6, 8 ve 9¹⁸⁹. maddeleriyle ve 2001/29 sayılı *Bilgi Topluluğunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara İlişkin Belirli Konuların Uyumlaştırılmasına Yönelik Direktifi*'nin 2. ve 3. maddelerinde¹⁹⁰ düzenlenmiştir.

2001 yılında Avrupa Topluluğu'nun 92/100 sayılı Konsey Direktifi hükümleri doğrultusunda yapılan ve halen geçerli olan 4630 sayılı Kanun ile FSEK değiştirilerek; film yapımcıların hakları, "bağlantılı haklar" kapsamında yeniden düzenlenmiştir. Bu Kanunla değiştirilen 80. maddenin 2. bendi, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları

¹⁸⁹ 92/100/AET sayılı *Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi Madde 9: 1. Üye devletler, ...*

- filmleri ve kopyaları hakkında filmlerin ilk tespitlerini gerçekleştiren film yapımcılarına,
- madde 6 (2)'de belirlendiği üzere, satış ya da başka yollarla, buradan itibaren "dağıtım hakkı" olarak göndermede bulunulan söz konusu maddelerin ve kopyalarının kamuya sunumu münhasır hakkını sağlarlar.

4. Dağıtım hakkı, aktarılabilir, devredilebilir ya da akdi lisansların verilmesine tabi olabilir.

¹⁹⁰ 2001/29 sayılı *Bilgi Topluluğunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara İlişkin Belirli Konuların Uyumlaştırılmasına Yönelik Direktif Madde 2: Üye devletler, kısım veya tamamen, her türlü yöntem ve şekilde, kalıcı veya geçici röprodüksiyonları hakkında: ...*

(d) filmleri ilk düzenleyen üreticiler ve filmlerinin orijinalleri ve kopyaları;

doğrudan veya dolaylı yasaklama veya müsaade etmeye münhasır haklarını korur.

Madde 3: 1. Üye devletler, eser sahiplerinin, tel üzerinden veya telsiz vasıtalarla eserlerini yayımlama, böyle bir yolla kamunun tercih ettikleri bir zamanda ve bir yerden erişebilmeyi mümkün kılmayı içeren, her türlü haberleşmeyi yasaklama veya müsaade etmeye münhasır haklarını temin eder.

2. Üye devletler, tel üzerinden veya telsiz vasıtalarla eserlerini yayımlama, böyle bir yolla kamuya bireylerin tercih ettikleri bir zamanda ve bir yerden erişebilme münhasır haklarını ...

(a) filmleri düzenleyen ilk üreticiler, kendi orijinal filmleri ve kopyaları; için korur.

3. Paragraf 1 ve 2'de atıf edilen haklar bu maddede beyan edilen yayımlama veya yayımlama kararının alınması için yapılan haberleşmenin her hangi bir işlemi tarafından tüketilemez.

kullanma yetkisini devralan film yapımcısına tanınan hakları ayrıntılı şekilde düzenlemiştir.

FSEK 80. maddenin 2 no’lu fıkrasına göre; “*Filmlerin ilk tespiti gerçekleştirilen film yapımcısı, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara sahiptir.*

(1) *Eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme veya yasaklama hakları münhasıran film yapımcısına aittir. Yapımcılar tespitlerinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir.*

(2) *Film yapımcısı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış film tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir.*

(3) *Film yapımcısı, film tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. Umuma iletim yoluyla tespitlerin dağıtım ve sunulması yapımcının yayma hakkını ihlal etmez.*

Fonogramlara tespit edilmiş icraların ve filmlerin, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanı sıra, icracı sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Bir sinema eserinde, olağan şekilde adı bulunan gerçek veya tüzel kişi aksine bir kanıt bulunmadıkça filmin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcı olarak kabul edilir.

Sinema eserlerinin birlikte sahipleri filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıya mali haklarını devrettikten sonra, sözleşmelerinde aksine veya özel bir hüküm bulunmadığı takdirde filmin dublajına veya alt yazı yazılmasına itiraz edemezler.

Müzik eseri sahibi, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcı ile yaptığı sözleşmedeki hükümler saklı olmak kaydıyla eserini yayımlama ve icra hakkını muhafaza eder.”

Avrupa Birliği Hukuku'nda ise 92/100 sayılı Konsey Direktifinin 7. maddesi film yapımcılarının çoğaltma hakkını düzenlemişti, fakat bu madde 2001/29 sayılı Konsey Direktifinin 11. maddesi ile kaldırılmıştır. Avrupa Birliği Hukukunda şu anda bu hak 2001/29 sayılı Konsey Direktifinin 2. maddesinin “d” bendinde, “*üye devletler, kısmen veya tamamen, her türlü yöntem ve şekilde, kalıcı veya geçici röprodüksiyonları hakkında: ...*

(d) *filmleri ilk düzenleyen üreticiler ve filmlerinin orijinaleri ve kopyaları;*

doğrudan veya dolaylı yasaklama veya müsaade etmeye münhasır haklarını korur” şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

FSEK 80. maddesi ise çoğaltma hakkını; “*eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, ... hususlarında izin verme veya yasaklama hakları münhasıran film yapımcısına aittir*” şeklinde düzenlemiştir.

Film yapımcısının yaptığı tespitin fiziki kopyalarının dvd veya vcd olarak dağıtılması, satılması, kiralınması veya kamuya ödünç verilmesi yayma hakkının kapsamındadır. Avrupa Birliği Hukuku'nda; 92/100 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi'nin 2. maddesi; “*kiralama ve ödünç vermeyi yetkilendirme ve yasaklama münhasır hakkı, ... film ya da yayınları hakkında, filmin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıya aittir*” ve 9. maddesi dağıtım hakkını; “*üye devletler ... filmleri ve kopyaları hakkında filmlerin ilk tespitlerini gerçekleştiren film yapımcılarına ... buradan itibaren “dağıtım hakkı” olarak göndermede bulunulan söz konusu maddelerin ve kopyalarının kamuya sunumu münhasır hakkını sağlarlar*” şeklinde düzenlemektedir. Buna ilaveten, 92/100 sayılı Konsey Direktifinin vazgeçilmez bedel hakkı başlıklı 4. maddesinde, eser sahibi veya icracı sanatçıdan kiralama hakkının devralınması durumunda adil bir bedel ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Öyle ki eser sahibi veya icracı sanatçı bu hakkından feragat dahi edemez.¹⁹¹

FSEK 80. maddesi ise yayma hakkını “*eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, ... dağıtılması, satılması, kiralınması ve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme veya yasaklama hakları münhasıran film yapımcısına aittir*”; “*film yapımcısı, yurt içinde*

¹⁹¹ Cüneyt YÜKSEL, “Fikri Mülkiyet Hukukunda Kiralama ve Ödünç Verme Hakları”, İHFM, Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl'a Armağan, C. LV, S. 4, İstanbul, 1997, s. 258-259

henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış film tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir” ve “film yapımcısı, film tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına ... izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir” şeklinde düzenlemiştir.

Eğer film yapımcısından veya ondan hakları devralan kişilerden izin alınmadan filmler çoğaltılırsa veya broşürlerde gösterilmek suretiyle yayma hakkının konusu yapılsa aşağıdaki mahkeme kararında belirtildiği gibi bir sonuç ortaya çıkar.

“Davacı vekili, müvekkilinin, merkezi yurtdışında bulunan (R... Film Distributors Limited) firmasının Türkiye mümessili olduğunu, **da-valının, telif hakları müvekkilinin mümessili olduğu firmaya ait filmle-rin isimlerini reklam broşürlerinde ve basın organlarında kullan-dığını, iş yerlerinde bu filmlerin video kasetlerini yasadışı çoğal-tarak tedavüle koyduğunu, böylelikle müvekkilinin mali haklarına tecavüzde bulunduğunu, durumun tespit edildiğini ileri sürerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 68. maddesi uyarınca şimdilik 6,750,000 liranın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.**

Mahkemece toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, **dava konusu filmlerin telif hakkının davacıya ait olduğu, bu film-lerin isimlerinin davalının ilan ve broşürlerinde yer almış olması-nın haksız rekabetin varlığını gösterdiği gerekçesiyle** 5,250,000 li-ranın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsi-line, söz konusu filmlere davalının vaki tecavüzünün önlenmesine, **karar verilmiştir.**^{192,}

Film yapımcılarının temsil hakkı konusunda FSEK 80. madde-sinde açık bir düzenleme yoktur. FSEK 80. madde düzenlemesindeki “film yapımcısı, film tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla ... veya diğer biçimlerde umuma ... sunulmasına ... izin vermek veya yasaklamak hak-kına sahiptir” ibareleri temsil hakkı kapsamında yorumlanabilir. Ancak, eserlerin umuma açık yerlerde gösterilmesi olarak bilinen temsil hakkı konusundaki FSEK madde 41 düzenlemesi açıkça filmlerden ve (film) yapımcılarından bahsederek, film yapımcılarının temsil hakkını umumi mahaller/yerler için düzenlemiştir. FSEK 41. maddesinin bu konudaki düzenlemesi şöyledir:

“Girişi ücretli veya ücretsiz **umuma açık mahaller;** eser, icra, fonogram, **yapım** ve yayınların kullanım ve/veya **iletimine ilişkin** 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak **hak sahiplerinden** veya üyesi olduk-

¹⁹² Yargıtay 11. H.D, 16.12.1986, E. 1986/6314, K. 1986/6869, SULUK/ORHAN, age, s. 776.

ları meslek birliklerinden **izin alır** ve sözleşmelerde yazılı malî hak ödemelerini bu madde hükümlerine göre yaparlar...

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımından ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile umuma açık mahaller arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır...

Mahallerde kullanılan ve/veya iletimi yapılan eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar üzerinde hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, bunların kullanımına ve/veya iletimine ilişkin ödemelerin yapılmasını yetki verdikleri meslek birlikleri aracılığı ile talep edebilirler”.

Film yapımcılarının umuma iletim hakları FSEK 80. maddede; “(1) ...Yapımcılar tespitlerinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir.

(3) Film yapımcısı, film tespitlerinin ... gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir” şeklinde düzenlenmiştir.

Film yapımcısının hak sahibi olduğu filmlerin yayını ve yeniden yayını konusunda FSEK madde 80’nin yanı sıra madde 43’e¹⁹³ de bakmak gereklidir. 43. maddenin 2. fıkrasında; yayın ve yeniden yayın yapan yayıncı kuruluşların yayınlayacakları sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak, söz ko-

¹⁹³ FSEK Madde 43: Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin almak zorundadırlar.

Bu kuruluşlar sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadırlar...

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram ve yapımların yayın ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile kuruluşlar arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılan müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

nusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak zorundadırlar. FSEK 80 ile 43 düzenlemelerini karşılaştırdığımızda, ortada açık bir şekilde çelişki bulunduğunu görmekteyiz. Avrupa Birliği Hukukuna baktığımız zaman film yapımcıları için yayın ve yeniden yayın hakkına ilişkin bir düzenleme olmadığı görülmektedir.

Film yapımcılarına ait yapımlarının televizyonda yayın hakkı için bu hakkı içeren şekilde bir “devir” veya “lisans” sözleşmesi yapılması gereklidir. Eğer lisans sözleşmesi mali haklardan “çoğaltma ve yayma” hakkında iken yayıncı sözleşmede yazılmayan “yayın” eylemini yaparsa o zaman film yapımcısı haklarını mahkeme yolu ile aşağıdaki örnekte olduğu gibi savunur.

“Davacı vekili, müvekkili şirketin “Beyoğlu-Beyoğlu” adlı müzikal görsel gösterimin ve sinema yapıtının eser sahibi olduğunu, davalı şirketin, bu eseri video kasetlerine kaydederek pazarlama için Kültür Bakanlığından “Eser İşletme Belgesi” ve 2000 adet video kaset çoğaltma hakkı aldığını, bu belgenin nasıl alındığının bilinemediğini, davalının bu hakkı Reklamcılık Ltd. Şti.nden devralmış olamayacaklarını çünkü ... Reklamcılık Ltd. Şti.nin 16.11.1984 tarihinde davaya konu yapıtın, yalnızca video kasetlere kayıt edilerek, bu kasetlerin pazarlanması hakkını devir almışsa da, anılan sözleşmede davaya konu yapımın televizyon yayın haklarının ve sinema filmi olarak yararlanılması haklarının sözleşme dışında bırakıldığının açıkça belirtildiğini, o nedenle anılan sözleşmeye dayanılarak yapımın televizyonlarda yayın hakkının devredilemeyeceğini, müvekkili şirketin eserin film olarak televizyonda yayınlanması haklarını ... Televizyon Prodüksiyon A.Ş.’ne devrettiği halde, yapıtın bir kısım televizyon kanallarınca davalı şirketle yapılan sözleşmeler uyarınca gösterildiğini ileri sürerek, davalının haksız rekabetinin önlenmesine ve 900.000.000 lira maddi, 100.000.000 lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, karar özeti nin ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili davaya cevabında, davaya konu eser sahibinin davacı olmayıp, dava dışı “X Yapım Ltd. Şti.” olduğunu, dava dışı ... Reklamcılık Ltd. Şti.nin X Yapım Ltd. Şti. ile yapmış olduğu sözleşme ile devraldığı hakları müvekkiline bedeli karşılığında devrettiğini, müvekkilinin eseri video bant yayını olarak, sözleşmede yasaklanmamış her yerde, eser işletme sahibi sıfatı ile gösterime sunma hakkına haiz olduğunu, istenilen tazminatın fahiş bulunduğunu, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran, “X Yapım Ltd. Şti.ne ait olan “Beyoğlu-Beyoğlu” adlı eserin önce 16.11.1984 tarihli sözleşme ile video haklarının ... Reklamcılık Ltd. Şti.ne satıldığı, **bu sözleşme ile eserin televizyonda yayın, ses bandı ve sinema filmi haline getirilme haklarının dev-**

redilmediği, 6.11.1984 tarihli ... Reklamcılık Ltd. Şti. ile davalı arasındaki sözleşme ile bu eserin Türkiye ve Dünya video işletme haklarının davalı şirkete devredildiği, davalının da eserin yayın haklarını 20.4.1993 ve 22.11.1995 tarihli sözleşmelerle bir kısım özel TV Kanallarına devrettiği ve eserin yayınlandığı, oysa davalının sadece eseri video kasetlere kaydederek, pazarlama hakkını devraldığı, gösterim ve devir haklarının davacı uhdesinde bulunduğu, davalının eyleminin haksız fiil oluşturduğu, davacının istediği maddi tazminatın eserin popüleritesine göre kadri maruf olduğu ve manevi tazminata da hak kazandığı gerekçeleriyle, davalı tarafından yapılan haksız rekabetin ve satışmanın önlenmesine 900.000.000 lira maddi tazminatı ile 20.000.000 lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline ve ilana karar verilmiştir. Karar onanmıştır.¹⁹⁴

Film yapımcısı ile yayıncı kuruluş arasında, yapımın televizyonda yayınlanması konusunda lisans sözleşmesi yapılmasına rağmen, yayıncı kuruluşun bu lisans sözleşmesini aşarak, sözleşmeyi aşan sayıda yayın yapması halinde de film yapımcısı haklarını dava yolu ile alabilir.

"Davacı vekili, müvekkiline ait "Atatürk" belgeselinin taraflar arasında imzalanan sözleşme ile 3 defa gösterilmesi gerekirken izinsiz olarak 4 defa gösterildiğini ileri sürerek, 3.000 USD maddi ve 6.000 USD manevi tazminatın davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı vekili, uluslararası yayıncılık ilkeleri gereğince 24 saati aşmayan zaman dilimindeki tekrar gösterimlerin ayrı yayın olarak değerlendirilmediğini, kaldı ki kurumun kuruluş yasası gereğince 10 Kasım özel günü nedeniyle yapılan yayının da tazminat hakkı vermeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, 3.000 USD'nin dava tarihindeki karşılığı 1.715.031.000.-TL maddi, 250 USD'nin karşılığı 142.919.250.-TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, Dairemizce karar onanmıştır. Karar düzeltme talebi reddedilmiştir¹⁹⁵.

FSEK 80 gereğince; filmlerin, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanı sıra, icracı sanatçılara ve (film) yapımcılar(ın)a veya ilgili alan meslek birliklerine bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Günümüzde birçok eser gibi film yapımcılarının filmleri de internet vasıtasıyla hak sahiplerinden izin alınmadan ve hiçbir bedel ödenmeden kolayca kopyalanarak çoğaltılabilmekte ve izinsiz olarak bazı web siteleri tarafından ya da p2p yöntemiyle dağıtım yapan kişilerce

¹⁹⁴ Yargıtay 11. H.D. 21.1.2000 T., 1999/9588 E., 2000/430 K.

¹⁹⁵ Yargıtay 11. H.D. 7.10.2003 T., 2003/9924 E. 2003/9002 K.

umuma iletilmektedir. FSEK madde 80 gereğince; film yapımcısı, film tespitlerinin, gerçek kişilerin seçtiği yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek ve yasaklamak yetkisine sahip olduğundan; izinsiz girişimlere karşı önleme, tazminat isteme ve hapis cezaları şikayet hakkından yararlanır. Bu mücadele yöntemlerine ek olarak film yapımcısı FSEK Ek madde 4'den de yararlanır.

FSEK Ek madde 4 ile; film yapımcısı, film tespitlerinin kullanıcılarına izinsiz olarak ulaşmasını sağlayan sitelerin erişimini sağlayan Türk Telekom gibi internet servis sağlayıcılar vasıtasıyla önlem alabilmektedir. Bu düzenleme şöyledir:

“Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâlê konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlê durdurulmasını ister. İhlâlê devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâlê devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlê durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlıkça bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

Sinema eserlerinin birlikte sahipleri filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıya mali haklarını devrettikten sonra, sözleşmelerinde aksine veya özel bir hüküm bulunmadığı takdirde filmin dublajına veya alt yazı yazılmasına itiraz edemezler. Kanun koyucu böylelikle film yapımcısına sinema eseri sahiplerinin eserin bütünlüğünün korunması ve bozulmaması şeklindeki manevi haklarına istisna oluşturacak bir hak tanımıştır.¹⁹⁶

FSEK madde 82 uyarınca yapımcıların hakları, ilk tespitin yapıldığı tarihten başlayarak yetmiş yıl devam etmektedir. Kanun; diğer bağlantılı hak sahipleri gibi film yapımcılarının koruma sürelerini de sınır-

¹⁹⁶ ATEŞ, age., s. 236

landırmıştır. Avrupa Birliği Hukuku'nda bu konudaki düzenleme 93/98 sayılı Konsey Direktifinin 3/3 maddesinde bulunmaktadır. Şöyle ki; bir filmin ilk tespitinin üreticilerinin hakları, tespitin yapıldığı tarihten sonraki 50 yılda sona erer. Ancak, eğer film bu dönem içinde yasal olarak yayımlanmış veya yasal olarak kamuya iletilmiş ise, haklar hangisi daha erken ise, ya böyle bir ilk yayınlama veya böyle bir ilk iletim tarihinden sonraki 50 yılda sona erer. Yine aynı Direktifin 8. maddesi sürelerin hesaplanmasını düzenlemiştir, buna göre; süreler onları başlatan olayın gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak ayının ilk gününden itibaren hesaplanır.

FSEK bazı hallerde film yapımcılarının izni olmadan filmlerden yararlanmayı 80. maddesinde şu şekilde düzenlemiştir:

“Aşağıda belirtilen hallerde komşu hak sahibi ile film yapımcısının yazılı izni gerekli değildir:

1. *Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veya haber amacıyla ve kazanç amacı güdülmeksizin icra edilmesi ve kamuya arzı.*

2. *Fikir ve sanat eserleri ile radyo-televizyon programlarının yayınlanma ve kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması.*

3. *Radyo-televizyon kuruluşlarının kendi olanaklarıyla kendi yayınları için yaptıkları kısa süreli geçici tespitler.*

4. *Bu Kanunun 30 uncu, 32 nci, 34 üncü, 35 inci, 43 üncü, 46 ncı ve 47 nci maddelerinde belirtilen haller.*

Bu uygulama, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep dışında zarar veremez veya eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz”.

FSEK 80 gereğince film yapımcıları; haklarına tecavüz eden kişilere karşı tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i ve tazminat davası haklarından faydalanırlar.

VII. MANEVİ VE MALİ HAKLARIN KULLANILMASI VE DEVRİ

A. GENEL OLARAK

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yürürlüğe girdiği 1951 yılının şartları dolayısıyla eser sahibini ve eser sahibi haklarını esas alarak düzenlenmişti. Bu doğrultuda baktığımız zaman ilk FSEK metninde yer alan tüm kuralların eser sahipleri açısından uygulanacağını söyleyebiliriz. Ancak Kanun'un yapılmasından sonra bağlantılı hakların ortaya çıkması sebebiyle bağlantılı hak sahipleri ve onların hakları da Kanun'a özel bazı maddeler ile eklenmiştir. Bu özel maddeler içinde FSEK'in aslında eser sahipleri için düzenlenmiş bazı genel hükümlerinin bağlantılı hak sahipleri için de uygulanacağı *“eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı haklara sahip olanlar da eser sahipleri gibi tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i ve tazminat davası haklarından faydalanırlar”* gibi özel düzenlemeler bulunmaktadır.

Uygulamada karmaşa yaratan bu konu için başka bir yöntem olarak, FSEK'de bulunan eser sahiplerine ilişkin genel düzenlemelerin hangisinin bağlantılı hak sahipleri için uygulanacağını yönetmelikle belirleme yöntemi de kullanılmıştır¹. Bu yöntemin kullanıldığı *“Eser Sahibine Komşu Haklar Yönetmeliği”*nin 23. maddesine göre; *“komşu hak sahiplerinin haklarının devir ve intikali, 5846 sayılı Kanun ile genel hükümler çerçevesinde yürütülür.”*

FSEK'de bağlantılı hakların devrine ve mirasçılara geçişine ilişkin eser sahiplerinde olduğu gibi özel düzenlemeler yoktur. Bu yüzden; eser sahibi açısından FSEK'in genel hükümlerinden yararlanırken, komşu hak sahipleri için, *“Eser Sahibine Komşu Haklar Yönetmeliği”*nin 23. maddesinden yararlanacağız. Bu Yönetmelik hükmü gereğince, komşu hak sahiplerinin haklarını ve bu hakların kullanılmasını düzenleyen 80. maddedeki hükümlere ek olarak (aslında eser sahibi için düzenlenmiş

¹ Aslında Yönetmelikle hüküm ekleme yöntemi bence temel hakları etkilediğinden hatalıdır. Doğrusu, bu maddenin Yönetmelik yerine 5846 sayılı Kanun'a koyulmasıdır.

olan) diğer maddelerdeki genel hükümler de komşu hakların mirasçılar tarafından kullanılması ve komşu hak sahiplerine hakların devri ve onlardan diğer kişilere devri konularında geçerli olacak ve kıyasen uygulanacaktır.

Bu bölümdeki incelemelerimiz açısından ilgili kısımlarda önce eser sahiplerine ilişkin düzenlemelere değinip, daha sonra bağlantılı hak sahiplerinin durumuna değineceğiz.

FSEK madde 80’de anılan eser sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri arasındaki “izin” verme hak geçirme yöntemi ve hakların devri çalışmamızın önceki bölümlerinde her bir hak sahiplerinin hakları incelenirken irdelendiğinden, burada mali hakların devri bölümünde özellikle hakların eser veya bağlantılı hak sahiplerinden üçüncü kişilere devrine odaklanacağız. Bu konular anlatılırken varsa eser ve bağlantılı hak sahipleri arasındaki devir hükümlerine de yer vereceğiz.

B. MANEVİ HAKLARIN KULLANILMASI VE MİRASÇILAR

Kural olarak, telif hakları eser sahibine aittir ve esere ait mali ve manevi hakları kullanma yetkisi münhasıran eser sahibininindir. Ancak FSEK 18.² ve 19. maddeleri, eser sahibinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu hakların üçüncü kişilere bırakılabileceğinden bahsetmektedir.

Bu anlamda sadece mali değil; manevi haklara özgü bir durum da bulunmaktadır. Manevi haklar bilindiği gibi; eser sahibinin şahsına bağlı haklardandır. Eser sahipleri tarafından kullanılabilecek manevi hak türleri FSEK madde 19’da³ şöyle belirtilmiştir:

² FSEK Madde 18: *Mali hakları kullanma yetkisi münhasıran eser sahibine aittir. Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce kullanılır. Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır.*

Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir.

³ FSEK Madde 19: *Eser sahibi 14 ve 15 inci maddelerin birinci fıkralarıyla kendisine tanınan salahiyyetlerin kullanılış tarzlarını tespit etmemişse yahut bu hususu her hangi bir kimseye bırakmamışsa bu salahiyyetlerin ölümünden sonra kullanılması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu tayin edilmemişse sırasıyla sağ kalan eşi ile çocuklarına ve mansup mirasçılarına, ana - babasına, kardeşlerine aittir.*

- FSEK madde 14/1'e göre; eserin umuma arz edilip edilmeme, yayınlanma zamanını ve tarzını tayin etme yetkisi,
- FSEK madde 15/1 gereğince; eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak umuma arz etme veya yayımlama yetkisi,
- FSEK madde 14/3'deki; eserin umuma arz edilmesinin veya yayımlanma tarzının eser sahibinin şeref ve itibarı zedeleyecek şekilde olması halinde, eser sahibi başkasına yazılı izin vermiş olsa bile, eser sahibinin gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanmasını menetme yetkisi,
- FSEK madde 15/3 gereğince; eserin kimin tarafından vücuda getirildiğinin ihtilafı olması veya herhangi bir kişinin eser sahibi olduğunu iddia etmesi halinde, eser sahibinin hakkının tespitini mahkemeden isteme yetkisi,
- FSEK madde 16/3 uyarınca; eser sahibi kayıtsız şartsız olarak yazılı izin vermiş olsa bile şeref ve itibarını zedeleyen veya eserin mahiyet ve hususiyetini bozan her türlü değiştirmeleri men etme yetkisi.

Manevi haklar miras yoluyla intikal etmezler.

Eser sahibi, saydığımız bu hakların kullanılmasını sağlar arası veya ölüme bağlı tasarrufla başka birine bırakabilir⁴. Bu şekilde bir tasarruf işlemiyle hakların devri söz konusu değilse, FSEK madde 19'a göre, Kanun'un sınırlı sayıda saydığı kimseler; eser sahibinin ölümü

Eser sahibinin ölümünden sonra yukarıdaki fıkrada sayılan kimseler eser sahibine 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl kendi namlarına kullanabilirler.

Eser sahibi veya birinci ve ikinci fıkralara göre salahiyyetli olanlar, salahiyyetlerini kullanmazlarsa; eser sahibinden veya halefinden mali bir hak iktisap eden kimse meşru bir menfaati bulunduğunu ispat şartıyla eser sahibine 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları kendi namına kullanabilir.

Salahiyyetli kimseler birden fazla olup müdahale hususunda birleşemezlerse; mahkeme, eser sahibinin muhtemel arzusuna en uygun bir şekilde basit yargılama usulü ile ihtilafı halleder.

18 inci madde ile yukarıdaki fıkralarda sayılan salahiyyetli kimselerden hiçbiri bulunmaz veya bulunup da salahiyyetlerini kullanmazlarsa yahut ikinci fıkrada belirlenen süreler bitmişse, eser memleketin kültürü bakımından önemli görüldüğü takdirde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 14, 15, 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında eser sahibine tanınan hakları kendi namına kullanabilir.

⁴ SULUK/ORHAN, age., s .415.

sonrasında bu hakları kullanma yetkisine sahiptirler. Kanunda sayılan bu kişiler; vasiyeti tenfiz memuru; memur tayin edilmemişse sırasıyla; eser sahibinin sağ kalan eşi, çocukları, mansup mirasçıları, ana babası ve kardeşleridir. Bu kimseler eser sahiplerinin yakınları kavramı içindedirler.

Eser sahibi ya da icracı sanatçı, FSEK madde 19'da sayılan kimse-lerden birini veya birkaçını Medeni Kanun madde 510 uyarınca mirasın-
dan çıkarmışsa ya da Medeni Kanun madde 578'de düzenlenen mirastan
yoksunluk sebeplerinden biri söz konusu ise; bu kimselerin güvenilir
olma özelliği ortadan kalktığı için manevi haklar sözü edilen kimseler
tarafından kullanılamamalı ve kullanma yetkisi sırasıyla diğer kimselere
geçmelidir⁵.

ARKAN'a göre, çözülmesi gereken önemli sorun, bu kimselerin
kendilerine tanınan hakları icracı sanatçının ölümünden itibaren ne kadar
süre ile kullanacaklarıdır? FSEK madde 19/2'de söz konusu kişilerin, bu
hakları eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl kendi namlarına
kullanabilecekleri ifade edilmiştir. Ancak FSEK madde 82/5'de icracı
sanatçıların haklarının, icranın ilk tespitinin yapıldığı tarihten, icra tespit
edilmemişse icranın ilk aleniyet kazanmasından itibaren yetmiş yıl de-
vam edeceği açıkça ifade edilmiştir. ARKAN'a göre, bu konuda madde
82/5'de icracı sanatçılarla ilgili olarak özel olarak öngörülen sürenin
uygulanması daha yerinde olacaktır. Yani icranın ilk tespitinin yapıldığı
tarihten, icra tespit edilmemişse icranın ilk aleniyet kazanmasından itiba-
ren yetmiş yıl zarfında icracı sanatçının ölmesi halinde, yetmiş yıl ta-
mamlanana kadar yakınların söz konusu hakları kullanabilecekleri kabul
edilmelidir⁶.

FSEK madde 19/3'e göre, eser sahibinin sağlığında kendisinin;
ölümünden sonra ise sözü edilen güvenilir kişilerin, kendilerine tanınan
manevi hakları kullanmamaları durumunda; mali bir hak elde etmiş kim-
seler, meşru bir menfaatlerinin olduğunu ispat şartıyla, manevi hakları
kendi namlarına kullanabileceklerdir⁷. Aynı hüküm, Komşu Haklar
Yönetmeliği'nin, 23. maddesi uyarınca kıyasen icracı sanatçılar bakı-
mından da uygulanmalıdır.

⁵ ARKAN, *age.*, s. 241

⁶ ARKAN, *age.*, s. 241

⁷ AYİTER, *age.*, s. 202; EREL, *age.*, s. 244. Naklen ARKAN, *age.*, s. 241

FSEK madde 19/4, yetkililerin birden fazla olup da bunların yetkilerini aynı doğrultuda kullanma konusunda anlaşamamaları durumunda mahkemenin, eser sahibinin muhtemel arzusuna en uygun şekilde uyuşmazlığı çözeceğini ifade etmiştir. Aynı hükmü, kıyasen icracı sanatçılar bakımından da uygulamak gerekir.

FSEK madde 19/5’de ise, manevi hakları kullanacak eser sahibi ardılları ya da güvenilir kişilerin bulunmaması ya da bulunmakla birlikte, bu yetkilerini kullanmamaları ya da koruma süresinin geçmiş olması halinde ve eser memleket kültürü açısından önemli görüldüğü takdirde Kültür Bakanlığı’nın bu hakları kendi namına kullanabileceği hükme bağlamıştır. Bu hüküm de kıyasen icracı sanatçılar bakımından uygulanmalıdır.

FSEK madde 80/1A-1’de belirtildiği gibi icracı sanatçılar, mali haklardan bağımsız olarak ve bu hakları devretmelerinden sonra dahi manevi haklarını kullanabileceklerdir⁸. Ayrıca icracı sanatçının mali haklarının Kanun tarafından sınırlandırıldığı hallerde de manevi haklar devam etmelidir⁹.

FSEK madde 80’e göre, bağlantılı hak sahiplerinden yalnızca icracı sanatçılar manevi hakka sahiptirler. Ancak FSEK’de icracı sanatçıların manevi haklarının sağlar arası işlemle başkalarına kullandırmasına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Bununla birlikte Komşu Haklar Yönetmeliği’nin 23. maddesinde komşu (bağlantılı) hakların devir ve intikalinin, FSEK ve genel hükümler çerçevesinde gerçekleşeceği ifade edildiğinden, burada eser sahibine ilişkin hükümler kıyasen uygulanacaktır. FSEK madde 19’dan yola çıkarak, manevi hakların devrinin mümkün olmadığı bununla beraber; bunların “kullanılması”nın icracı sanatçılar tarafından hayattayken başkalarına devredilebileceği (bırakılabileceği) sonucuna varılmalıdır¹⁰. Zira bir kimsenin ölümünden sonrası için atayabileceği bir kimseyi hayatta olduğu süre için yetkilendirmemesi mantıksızdır.

⁸ TEKİNALP, age., § 17 N. 32. Naklen ARKAN, age., s. 241

⁹ Eser sahibine ilişkin olarak bu yönde EREL, age., s. 121. Naklen ARKAN, age., s. 241

¹⁰ Eser sahibi haklarıyla ilgili olarak aynı yönde EREL, age., s. 112; AYİTER, age., s. 200; GÖKYAYLA, age., s. 53. Alman düzenlenmesi açısından da manevi hakların sağlararası işlemle devredilemeyeceği kabul edilmektedir. (SCHRICKER/VOGEL, § 83 N. 7; FROMM/NORDEMANN/VINCK/HERTIN, (HERTIN), vor § 83 N.2 ve bu kenar notlarda anılan yazarlar). Naklen ARKAN, age., s. 226

Birden çok icracının varlığı halinde, icra kısımlara ayrılabiliriyorsa, icracılardan birinin ölümü halinde ne olacağı Kanunda düzenlenmiş değildir. Eser sahiplerine ilişkin olarak da bu konuda bir hüküm yoktur. Yine de ölenin manevi haklarının, FSEK madde 19'un kıyasen uygulanması ile burada sayılan şahıslar tarafından kullanacağı kabul edilme-
lidir¹¹.

Şayet icra, ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, icracı sanatçılardan birinin ölümü halinde Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 23. maddesinin atfı uyarınca eser sahiplerine ilişkin FSEK madde 64 uygulanmalıdır. Eğer icra tamamlanmış ve alenileşmiş ise ölenin manevi hakları için FSEK madde 19 kıyasen uygulanmalıdır. Örneğin, ölmüş de olsa, icracının adının zikredilmesi gerekir. Ayrıca, icra tamamlanmamış olsa bile bulunduğu düzey gerekli kılıyorsa, manevi hakların FSEK madde 19'un kıyasen uygulanması ile ölenin yakınları tarafından korunması yerinde olur¹².

Bu arada belirtmekte fayda vardır ki; manevi hakların kullanılması ile manevi tazminat ikame edilmesi farklı kavramlardır. Örneğin, eser sahibinin (söz yazarı/besteci) mirasçılarına sadece esere saldırı halinde dava açma hakkı tanınmıştır¹³. Bu davayı ikame edenler manevi hakları kullanmamaktadırlar¹⁴.

C. MALİ HAKLARIN KULLANILMASI VE MİRASÇILAR

FSEK madde 18/1 gereğince, mali hakları kullanma yetkisi eser sahibine aittir.

Eser sahibi mali haklarını başkalarına devredebilir veya bunlar üzerinde başkalarına lisans hakkı verebilir. Bu durumda, eser sahibinin ölümünden sonra mali haklar veya ilgili mali hakkı kullanma yetkisi bu kişilere geçecektir.

Öte yandan, sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça çalışanların (işçi, memur veya hizmetlilerin) işlerini görürlerken meydana getirdikleri eserlerin üzerindeki mali haklar, bunları çalıştıran

¹¹ Eser sahibine ilişkin olarak aynı yönde *TEKİNALP, age., § 15 N. 4. Naklen ARKAN, age., s. 240*

¹² *ARKAN, age., s. 241*

¹³ *SULUK/ORHAN, age., s. 416.*

¹⁴ *TEKİNALP, age, s. 163.*

veya tayin edenler tarafından kullanılmaktadır. Tüzel kişilerin organları hakkında da bu kural geçerlidir.

Belli şartlar altında eser sahibinin ölümünden sonra Kanun'da gösterilen kişiler tarafından da bu haklar kullanılabilir¹⁵.

FSEK 63. madde “*bu Kanunun tanıdığı mali haklar miras yolu ile intikal eder. Mali haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruflar yapılması caizdir*” demektedir. Bu sebeple mali hakların tamamı miras yoluyla mirasçılara intikal edebilir. Fakat mirasa konu olacak mali haklar yalnızca mirasçı olabilecek kişiler tarafından kullanılır. Mali haklar bu şekilde mirasla geçtiği takdirde, FSEK 65. maddesine göre; Medeni Kanun madde 640 uyarınca miras kalan mallar için bir temsilci tayin edilmişse, temsilci bu haklar için yapacağı işlemler açısından mirasçıların kararını almak zorundadır.

Birden çok icracının varlığı halinde, icracılardan birinin ölümü halinde iki ihtimale göre değerlendirme yapmak gerekir. İcracı sanatçıların icra ettikleri eser kısımlara ayrılabilirse, bu icracılardan birinin ölümü halinde ne olacağı Kanunda düzenlenmemiştir. Eser sahibine ilişkin olarak da bu konuda bir düzenleme söz konusu değildir. Ancak ona ait kısım ile ilgili mali hakların mirasçılara geçeceği kabul edilmelidir¹⁶.

Şayet icra, ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, icracı sanatçıların birinin ölümü halinde Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 23. maddesinin atfı uyarınca eser sahiplerine ilişkin FSEK madde 64 uygulanacaktır. FSEK 64. maddesi, birlikte yaratılan ama henüz alenileşmemiş müzik eserlerine uygulanabilen bir düzenleme getirmektedir. Bu madde “*Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri, eserin tamamlanmasından yahut alenileşmesinden önce ölürse hissesi, diğerleri arasında taksime uğrar. Bunlar, ölenin mirasçılarına münasip bir bedel ödemekle mükelleftirler. Miktar üzerinde uzlaşamazlarsa bunu mahkeme tayin eder. Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri eserin alenileşmesinden sonra ölürse diğerleri, ölenin mirasçılarıyla birliği devam ettirip ettirmemekte serbesttirler. Devama karar vermeleri halinde, sağ kalan eser sahipleri mirasçılardan birliğe karşı haklarının kullanılmasında bir temsilci tayini talep edebilirler. Devama karar verilmediği takdirde birinci fıkra*

¹⁵ SULUK/ORHAN, age., s. 415-416.

¹⁶ Eser sahibine ilişkin olarak aynı yönde TEKİNALP, age., § 15 N. 4. Naklen ARKAN, age., s. 243

hükümleri uygulanır” şeklindedir. Bu düzenleme ile eser sahiplerinden birinin ölümü sonucu diğer eser sahipleri ölenin mirasçılarına bir bedel ödeyerek eserin tamamlanmasını ve tamamlandıktan sonra da alenileşmesini sağlayabilmektedirler. Her bir müzik eseri aynı zamanda ülkenin kültürel zenginliği olduğu için, bu hüküm eserin tamamlanarak ülke zenginliğine katılmasını sağlamaktadır. Eğer eser tamamlanmış ve alenileşmişse ve bu aşamada eser sahiplerinden biri ölmüşse, diğer eser sahipleri mirasçılarla bu eserin idaresini yapmak istemezlerse yine mirasçılara bir bedel ödeyerek bu eserin kendileri tarafından rahatça kullanımını sağlayabilirler.

Yukarıda eser sahibi ve icracı sanatçı açısından belirttiğimiz mali hakların mirası ve intikali hükümleri ve açıklamaları, Komşu Haklar Yönetmeliğinin 23. maddesinin yollaması ile fonogram yapımcıları ve radyo- televizyon kuruluşları için de geçerlidir.

Bu arada hemen hatırlatılmalıdır ki, mali hakların mirasla intikali, diğer hakların intikali gibi değildir. Zira buradaki intikal, mali haklara ilişkin koruma süreleri ile sınırlıdır. Bu sürelerin geçmesinden sonra herkes serbestçe fikirsal ve sanatsal ürünlerden faydalanabilir¹⁷.

Komşu hak sahipleri açısından da kıyasen uygulanması gereken FSEK madde 59’a göre; mali hakkın devredilmesi ya da ruhsat verilmesi, belirli bir amacın gerçekleşmesi veya belirli bir süre için söz konusu olmuşsa; amacın ortadan kalkması veya sürenin dolmasıyla hak, kendiliğinden hak sahibinin veya mirasçılarının malvarlığına döner, ruhsat da son bulur. Bu hüküm, başkasına geçirilmesine sözleşme ile izin verilmemiş olan bir mali hakkı iktisap eden ya da ruhsat verilen kimse- nin ölümü ya da iflası halinde geçerli olmayacaktır; meğer ki, işin mahiyeti icabı hakkın kullanılması iktisap edenin şahsına bağlı bulunsun¹⁸.

FSEK madde 60 gereğince; eser sahibi yahut mirasçıları, kendilerine kanunen tanınan mali haklardan, önceden yapılmış anlaşmaları ihlal etmemek şartıyla, bir resmi senet tanzimi ve bu hususun Resmi Gazete’de ilanı suretiyle vazgeçebilirler. Vazgeçme, ilan tarihinden başlayarak koruma süresinin bitmesi halindeki hukuki neticeleri doğurur.

¹⁷ Bkz. ARKAN, *age.*, s. 243 vd.

¹⁸ EREL, *age.*, s. 274 vd; TEKİNALP, *age.*, § 15 N. 48; GÖKYAYLA, *age.*, s. 300. Naklen ARKAN, *age.*, s. 238

D. MALİ HAKLARIN DEVRİ

Önceki bölümlerimizde mali hakların **devir**, **ruhsat** ve **izin** şeklinde üç tip hak geçirimine konu olabileceğinden bahsetmiştik¹⁹.

“İzin” konusunda önceki bölümlerde eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını incelerken geniş bilgiler verdiğimiz için bu kısımda “devir” ve “lisans/ruhsat” adı verilen mali hak geçirimlerine odaklanacağız. Buradaki açıklamalarımız Komşu Haklar Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince; icracı sanatçının icrası, fonogram yapımcısının fonogramı ve radyo- televizyon kuruluşunun yayınının devri için geçerlidir.

Devir, devralanın devredilen mali haklara ait bütün hakları kullanabilmesi, sözleşme ile engellenmemişse başkalarına söz konusu hakları kısmen veya tamamen devredebilmesi ve devralınının üzerinde haklar tanıyabilmesi demektir. **Devir’de devredilen hak artık devredenin malvarlığından çıkmaktadır.** Bir hakkı devralan kişi, **“mutlak bir hak”** almış olur²⁰. Devredilen mali hak, devreden eser veya bağlantılı hak sahibinin malvarlığından çıktığından, bu hakkın bir biçimde kısıtlanması için mutlaka sözleşmede kısıtlamaya ilişkin özel bir düzenleme gereklidir. Eğer bir kısıtlama yoksa devralan kişi eser sahibi gibi bu hakları kullanabilir.

FSEK madde 48’de devir, *“eser sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları süre, yer ve muhteva itibarıyla mahdud veya gayrimahdud, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına devredebilirler”* şeklinde düzenlenmiştir. Komşu Haklar Yönetmeliğinin 23. maddesinin göndermesi ile, bu hüküm komşu hak sahipleri ve onların mirasçıları için de geçerlidir.

Öncelikle tekrarlayalım ki, FSEK madde 52 hükmüne göre, mali haklara ilişkin tüm hak geçirim sözleşmelerinin yazılı olması gerek-

¹⁹Yargıtay’ın ruhsat ve devir’in birbirinden farklı olduğuna ilişkin geniş görüşü için bkz. 11.HD. 26.04.1999, E. 1999/594, K. 1999/ 3250. Fikri haklarda devir, lisans ve izin açısından geniş bir değerlendirme için bkz. ÖNGÖREN, age., s. 153 vd.

²⁰ Mutlak haklar, hak sahibine hakkın konusu üzerinde doğrudan bir egemenlik sağlayan ve bu nitelikleri itibarıyla herkese karşı öne sürülüp, herkes tarafından da ihlal olunabilecek haklardır. Mesela, mutlak hakların tipik bir örneğini teşkil eden mülkiyet hakkı, malik olan şahsa mülkiyet konusu olan mal üzerinde başka bir şahsın izin veya aracılığına gerek duymaksızın egemenlik kurma ve o maldan hukuk düzeninin sınırları içinde yararlanma yetkisi sağlar. EREL, age., s. 4., OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, Eşya Hukuku, İstanbul, 2006, s. 6 ve GÖKYAYLA, age., s. 134.

mekte ve içinde geçirilen hakların ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. FSEK 52. maddeye göre, yazılı olma zorunluluğu emredici şekil kuralıdır. Ancak bazen işin niteliğine bakarak Yargıtay'ın da belirttiği gibi²¹ “dürüstlük kuralı” gereği, arada yazılı bir sözleşme ve yazılı lisans verme olmasa bile, iş sahibi edimlerini yerine getirmişse; işin parasını ödeyen ve eser veya bağlantılı hak sahibine karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş kişiye bir besteyi, icrayı, yapıyı, yayını veya filmi belirli biçimde çoğaltmak, yani kaset veya cd yapmak, internette umuma iletmek yetkisinin geçtiğini söyleyebiliriz. Bu şekildeki “geniş” yorumu sadece olayın özellikleri bu sonucu gösteriyorsa istisnai olarak yapabiliriz; yoksa mali hakların devri açısından taraflar arasında mutlaka yazılı sözleşme aranmak gerekir.

FSEK madde 52 gereğince, “devir” ve “ruhsat” sözleşmelerinde tek tek hakların belirtilmesi zorunluluğunun sebebi, toplumda eser üzerindeki hakkın “telif hakkı” denilen tek bir mali haktan ibaret olduğu ve bunun bir defa devredilmesiyle, devralanın eser üzerinde istediği şekilde tasarruf edebileceği yönündeki yanlış kanaati bertaraf etmektir²². Şunu da belirtmek gerekir ki, bu maddedeki tek tek hakları sayma şartı bir

²¹ Yargıtay bu tür kararları genellikle gayrimenkul satışları ile ilgili olarak yazılı ve resmi sözleşmeler açısından vermekte, ancak diğer bazı hukuk dallarında da –aşağıda görüldüğü gibi Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda da- bu kararlar uygulanmaktadır.

“Davacı ile davalı ... Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında düzenlenen 12.1.1993 tarihli sözleşme ile davacı şirket 13 bölümden oluşan “Olacak O Kadar” isimli televizyon dizisini ... TV’inde gösterilmesi için yayına hazırlama konusunda anlaşmışlardır. Yine davacı, davalı şirket ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği dava dışı ...A.Ş. ile yapmış olduğu 8.7.1993 tarihli sözleşme ile bu kez 16 bölümden oluşacak “Olacak O Kadar” isimli dizi şeklindeki eseri .. TV için yayına hazırlamıştır.

Her iki sözleşmede anılan diziler davacı tarafça hazırlanmış ve bunlar davalıya ait .. TV sinde yayınlanmıştır. Davacı vekili her iki sözleşmenin 4110 Yasa ile değişik 5846 sayılı Yasanın 48/3 ve 52 maddeleri uyarınca geçersiz olduğunu, buna göre maddi ve manevi hakların davalıya gitmeyip müvekkilinde kaldığını ileri sürmüştür ise de, davacı tarafından yapılan diziler davalıya teslim edilmiş ve 29 bölüm olarak davalıya ait .. Televizyonda yayınlanmış, böylece edimler ifa edildikten sonra sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmenin MK. 2 maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından davacının bu yöne ilişkin temyiz itirazı kabul edilmemiştir. Yargıtay 11. H.D., 1.10.1999, E. 1999/1726, K. 1999/7358

²² EREL, age., s. 277.

ispat şartı değil, geçerlilik (sıhhat) şartıdır. Buna göre bir müzik eserinin bir filme dönüşebilmesi için verilecek olan işleme yetkisi, muhakkak yazılı olarak ve bilhassa bu haktan bahsedilerek verilebilir. Çok istisnai olarak Yargıtay, Medeni Kanun (MK) 2. maddeye aykırı özel durumlarda yazılı sözleşme şeklini aramamaktadır²³.

Günümüzde Yargıtay kararları ve doktrin; mali haklara veya manevi haklara ilişkin verilen yetki ve izinlerin tek tek sayılması gerektiği²⁴ konusunda hemfikirdir. Bu nedenle “*mali hakları devrettim*” ya da “*bütün haklarımı devrettim*” şeklindeki ibareler geçersizdir. Ancak, bugün için geçerli olmasa da Yargıtay’ın eski tarihli kararlarında “tüm telif haklarımı devrettim” şeklindeki hakların toplu olarak devrini kabul ettiğini de söylemeliyiz²⁵. Sözleşmede hakların tek tek sayılması; yayma, temsil, çoğaltma veya umuma iletim gibi başlıklar halinde yapılsa dahi sözleşmenin geçerliliği için yeterlidir²⁶. Yoksa ayrıca çoğaltma için türleri kapsayan; “kaset, cd, bilgisayar” gibi veya umuma iletim için “radyo, televizyon, cep telefonu ve internet” gibi araçlara ilişkin bir sayma gerekmemektedir. “*Umuma iletim hakkını devrettim*” ibaresi tek tek “yayın, yeniden yayın, kamunun erişimine sunma” veya “radyo, te-

²³ 11. H.D. 19.03.2001, E.2001/226, K. 2001/2031 ve 26.6.1997, E. 1997/2854, K. 1997/5116

²⁴ TEKİNALP; age., s. 171 ve Yargıtay 11.H.D., 18.11.1999, E. 1999/2264, K. 1999/9338; “...sözleşmede video çekimi ve yayın hakkı devredildiği belirtilmiş ...televizyonda gösterim hakkının verildiğinden söz edilmemiştir... Sözleşmelerin tv yayın hakkını da kapsadığı yolunda daha geniş bir yoruma tabi tutulması mümkün değildir...”

²⁵ “Metni yukarıya aynen derç’edilen temliknamenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, merhum bestekar S.A., temliknamede isimleri yazılı sekiz eseri üzerindeki telif hakkını, hiçbir ayrıma tabi tutmadan, diğer bir deyişle, hem maddi (mali) ve hem de manevi telif hakkını birlikte, davacıya temlik etmiş bulunmaktadır. Bu husus temliknamede yer alan, (...telif haklarımı) cemi edatı kullanılmış olması ile, yine aynı temliknamedeki, (...artık bu eserlerde benim hiçbir hakkım ve alakam kalmayıp bütün bunlar bayan (S.A.T.)’nin mülkiyetine geçmiştir), cümlesinden kesinlikle anlaşılmaktadır.” (HGK., 11.2.1983, E. 4-70, K.123)

²⁶ 11. H.D. 01.02.1999, E.1998/8794, K. 1999/311; “...ruhsatın.. tam ruhsat niteliğinde olduğu ve bu nedenle eser sahibinin çoğaltma ve yayma haklarını bu sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe bir başka kişi ve kuruluşa devredemeyeceği...”, 11. H.D., 08.12.1992, E. 1991/4907, K. 1992/11246; “... davacının eserleri üzerindeki kullanma, çoğaltma ve yayma haklarını içeren mali hakları sözleşme ve taahhütnameler uyarınca süre ve yer kısıtlaması olmaksızın davalıya devrettiğinden...”

levizyon, internet” gibi tüm umuma iletim biçimlerini ve araçlarını kapsar. Yargıtay bu açıdan 11. H.D. 03.07.2000, E. 2000/5403, K. 2000/6334 sayılı kararıyla “...*hak sahibi mali hakkı herhangi bir sınırlama olmaksızın devredebileceği gibi... mali hakkın devrine ilişkin tasarruf işleminin herhangi bir sınırlama olmaksızın devri (yapılması) mümkündür*” demektedir. Yargıtay’ın bu yöndeki kararları uzun bir süredir istikrar göstermektedir²⁷.

Ancak “devir” hukuki işleminde, “çoğaltma” açısından genel ibare yerine “müzik eserinin cd yoluyla çoğaltılması” şeklinde tek çoğaltma biçimlerinin sayılması veya umuma iletim açısından “radyo ile yayın” şeklinde umuma iletim biçimlerinin sayılması sistemi ile sözleşme yapılmışsa; sayılmayan diğer biçimlerdeki çoğaltma hakları devir kapsamında değildir (istisna edilmiştir) diye düşünmek gerekir. Bu görüşten yola çıkarak, sözleşmede eğer “müzik eserinin cd yoluyla **ve diğer yollarla çoğaltma haklarını devrettim**” gibi bir ibare varsa kaset, gsm ve internet de dahil olarak çoğaltma kavramına giren tüm mali haklar devredilmiştir kanaatindeyiz. Yargıtay’ın da kararları bu yöndedir²⁸.

Burada diğer bir önemli nokta, işleme hakkının, diğer haklara ilişkin “*hakkın ismini sayarak devir sistemi*”nden farklı düzenlendiğidir. Yani “çoğaltma, umuma iletim hakkımı devrettim” ibaresinde olduğu gibi “*işleme hakkımı devrettim*” deyip her çeşit işleme haklarını devre-demeyiz. FSEK madde 55’de “*aksi kararlaştırılmış olmadıkça mali bir hakkın devri veya bir ruhsatın verilmesi eserin tercüme veya sair işlenmelerine şamil değildir*” demektedir²⁹. Bu yüzden işleme biçimlerinin yapılan devir sözleşmesinde açıkça sayılması gerekir.

“Devir”in hukuki sonucu konusunda Yargıtay, 11. H.D., 08.12.1992, E. 1991/4907, K. 1992/11246 sayılı kararıyla, “... *davacının, eserleri üzerindeki kullanma, çoğaltma ve yayma haklarını içeren*

²⁷ 11. H.D., 04.05.1998, E. 1998/1096 K. 1998/3035; “...1981 tarihli anlaşma ile filmin dünya üzerindeki her türlü gösterim hakkının davacıya devredildiği, ... devrin FSEK 52. maddesine uygun olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ...”

²⁸ “...müzik eserlerinin yayın hakkı dava dışı M’de iken tüm hakların 1992 yılında ... devredildiği ve bu durumun müzik eseri işletme belgesine şerh edildiğini... dava konusu eserler üzerinde davacının komşu hak sahibi olarak mali ve manevi hakları bulunduğu ... maddi tazminatın davalıdan tahsiline...” 11. H.D., 11.10.2004, E. 2004/393, K. 2004/9567.

²⁹ 11.H.D., 27.12.1999, E. 1999/9039, K.1999/10796; “...işleme hakkının tekrar devredilmesi için eser sahibinin muvafakatının zorunlu bulunduğu...”

mali hakları sözleşme ve taahhütnameler uyarınca süre ve yer kısıtlaması olmaksızın davalıya devrettiğinden (davacının/**eser sahibinin** bu eserler üzerinde artık) **mali hakkı kalmadığı**” kanaatindedir.

Mali hakları, hak sahibinin malvarlığından çıkararak devralana geçiren devir işlemi doktrinde alacağın temlik gibi soyut bir tasarruf işlemi olarak kabul edilmektedir. Yani bu işlemin dayandığı hukuki sebebin gösterilmesi gerekli değildir. Bunun sebebi FSEK madde 53’e göre, mali hakkı devreden devralana karşı hakkın varlığını Borçlar Kanunu madde 169 ve 171 uyarınca tekeffül etmesidir. Eğer sebep geçerli değilse, devralanın malvarlığında sebepsiz zenginleşme meydana geleceğinden, Borçlar Kanunu madde 61 ve devamında yer alan sebepsiz zenginleşme hükümlerine başvurmak mümkündür³⁰.

Önemli bir konu da; hak devralanların bu mali hakları diğer üçüncü kişilere devrederken, dönüp kendilerine sözkonusu hakkı devreden ilk hak sahibinden izin alma zorunluluğunun olup olmamasıdır. Eğer FSEK madde 48’in ilk fıkrasındaki “devir” hukuki işlemi yapılmışsa, hak; eser sahibinin malvarlığından çıkıp devralanın malvarlığına girdiğinden, bunun üçüncü kişilere devri için tekrar dönüp eser sahibinden veya bağlantılı hak sahibinden izin almaya gerek yoktur. Devir sözleşmesinde üçüncü kişilere devir açısından hiçbir düzenleme yoksa yahut özellikle bir devir yasağı koyulmamışsa üçüncü kişilere devirde ilk devreden izin gerekmez. AYİTER’e göre de; “işleme hakkı”ndan başka bir mali hakkın devrinde, eser sahibi mali hakkını A’ya devretmişse A eser sahibinden izin almadan B’ye ve B yine eser sahibinden izin almadan C’ye devredebilir³¹. ARKAN ise devir ve lisans verme arasında bir ayırım yapmaksızın sadece icracı sanatçıların hakları için (diğer bağlantılı hak sahipleri için değil) tüm hak geçirim biçimlerinde, devralanın bu hakları üçüncü kişilere devri konusunda ilk devreden icracı sanatçının yazılı iznini gerekli görmektedir³². Bu görüş sadece icracı sanatçılar aç-

³⁰ AYİTER, age., s. 206-207; ARSLANLI, age., s. 172; EREL, age., s. 260; GÖKYAYLA, age., s. 45; Ancak DURAL, age., s. 69’da bu işlemin sebebe bağlı sayılması gerektiği yönünde görüş belirtmiştir. ARKAN naklen, age, s. 228

³¹ AYİTER, age., s. 209. ve 11.H.D., 12.12.1995, E. 1995/6393, K. 1995/9199; “...dava konusu olan ...şiiri tüm mali hakları ile süresiz olarak devir ve temlik etmiştir. Bu durumda davalı şirket en geniş bir biçimde bu hakları kullanabilir ve başkalarına devredebilir. Hal böyle olunca davacının...şiiri için hiçbir hakkı kalmadığı sonucuna varılmıştır...”

³² ARKAN, age., s. 229

sından düşünülse bile hatalıdır. Eğer devir veya ruhsatın hukuki sonuçları aynı olsaydı FSEK 48 içinde devir ve ruhsat ayrı ayrı hükümlerle düzenlenmezdi. ARKAN'ın hakkın devralan tarafından üçüncü kişilere devri açısından devredeninin iznine gerek olduğu düşüncesi sadece ruhsat/lisans verme hak alım biçimi için, o da manevi haklara sahip eser sahipleri ve icracı sanatçılar açısından geçerlidir.

Belirtmemiz gerekir ki, manevi haklara sahip olan eser sahibi veya icracı sanatçıların, çalışmaları üzerindeki mali haklarını “devir” işlemi ile başkalarına vermiş olsalar bile, eser veya icraya manevi haklar açısından saldırı olması halinde eser veya icra üzerindeki manevi haklar için dava açma olanağı vardır. Yargıtay eskiden beri bu yönde kararlar vermektedir.

“Davacı, güfte ve bestesi kendisine ait “Gaziantep Gülleri” ismindeki müzik eserini, davalı O... Şirketinin, S.S.’ ye mal ederek “Gonca Gül Suyu Ne Eyler” ismi altında M.B.’ ye plağa okutmak suretiyle yaydığı için davalıdan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmaktadır.

Mahkeme, 18.5.1965 tarihli sözleşme sebebiyle davacı(nın), eserin telif hakkını G. Şirketine devir ettiğinden dolayı davayı reddetmiştir.

... Henüz alenileşmemiş bir eserden her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalanma hakkı, sahibine aittir. Eser sahibi, Kanunun tanıdığı mali hakları süre, yer ve muhteva itibarıyla mahdud veya gayri mahdud karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına devredebilir. **Mahkemenin dayandığı 18.5.1965 günlü sözleşme** bu nitelikte ve sadece **mali hakkın devrini öngören bir mukaveledir.** Eser sahibinin şahsına has ve onun tarafından kullanılacak **manevi hakları, bu gibi sözleşmeler devir alana nakletmez.** Hatta ismin zikrini isteyebilmek yetkisi, kısaltma ve değişikliklere karşı müdahale etmek salahiyeti, eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değiştirmelere muhalefet hakkı gibi manevi haklardan feragat olunduğu yolunda şart ihtiva eden mukaveleler de hükümsüzdür.

O halde, davacı(nın) eserindeki manevi haklarının himayesine taalluk eden iddiasının dinlenmesi, iddia ve müdafaaya ilişkin delillerin toplanması ve neticeye göre bir karar verilmesi gerekli iken, telif hakkı devir olduğundan bahisle noksan tahkikata müsteniden isteğin reddine karar verilmesinde isabet yoktur³³ⁿ.

Devir konusundaki önemli bir tartışma da eser işletme belgelerinin şirketler arasında devredilmesi alanında çıkmaktadır. Yargıtay 11. HD., 29.06.1999 tarihli kararında, SVMEK madde 8 maddesi gereğince Ka-

³³ TD, 14.12.1970, E. 1970/2985, K. 1970/5092, BATİDER, C. VI, 1971, s. 220-221

nun kapsamındaki eserler üzerindeki çoğaltma, yayma ve gösterim hakkının işletme belgesi sahibine ait olacağını ve eser üzerindeki her türlü tasarrufun işletme belgesi sahibinin iznine tabi olduğunu hüküm altına almıştır³⁴. Ancak, Yargıtay 11. H.D. bu görüşünden dönerek, 18.11.1999 tarihinde verdiği bir kararda, 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu (Şimdi bu Kanun ortadan kaldırılmış ve kullanılmamaktadır) uyarınca, ilgili Bakanlıktan eser işletme belgesi alınmış olmasının, dava konusu eser üzerindeki hakların davacıya devredildiğine dair yeterli kanıt olmayacağını belirtmiştir³⁵.

Ancak müzik sektöründe; “eser işletme belgesi” aracılığı ile devirler çok yaygın ve çoğunlukla geçerlidir. Zira, fonogram yapımcısı; eser sahibi ile icracı sanatçıdan aldığı “izin” sonucu bir mutlak hak olarak sağladığı tespit hakkını ve tespit üzerindeki çoğaltma ve yayma haklarını, hukuki bir işlemle bir başkasına devredebilmektedir. Yargıtay’ın 2007 yılında onadığı aşağıdaki karar, müzik sektörünün uygulamaları paralelindeki bizim görüşümüzün Yargıtay tarafından da benimsendiğini göstermektedir.

“Davacılar ... vekilleri, müvekkillerinin tüm yurtda sevilen ve tanınan merhum sanatçı, Ö.G.’ün mirasçıları olduklarını, ... davalı A. Müzik Yapım Ltd. şirketlerinin de kendilerinden izin almadan muris Ö.G. tarafından çalınıp okunan “Asmam Çardaktan, Ninenin Mektubu (1), Çözde Al Mustafa Ali, Sabuncunun Düzüne (Avşar Beyleri), Ninenin Mektubu (2), Azimem, Uzadım Kamış Oldum, Torundan Nineye Mektuplar, Dudu Kız, Avşar Beyleri, Ninenin Mektubu (3) ve Tepside Tepsi Fındıklar” isimli türküler “Yaren” adı altındaki bir kasete tespit edip satışa sunduklarını öğrenince eldeki davayı açmak zorunda kaldıklarını, çünkü gerek müvekkillerinin gerekse muris Ö.G.’ün davalı Şirket’e böyle bir tespit ve dağıtım için izin vermediklerini, açıklanan nedenlerle de ... Kanunun çoğaltma ve yayma haklarının ihlal edildiğini, ayrıca böyle bir eylem nedeniyle davacıların derin bir elem ve keder içine düştüklerini bildirerek, 5846 sayılı FSEK’in anılan maddeleri delaletiyle 68. maddesi gereğince, her bir davacı için

³⁴ Özellikle SYMEK da yer alan ceza hükümleri ve Yargıtay kararları bakımından bakınız; Cevat ÖZEL, “3257 sayılı Video ve Müzik Eserleri Kanunu İle 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Üzerine, Bir İnceleme”, (Çevrimiçi) <http://www.turkhukuk sitesi.com/faq/3257.shtml>, 24.05.2002. TOPALOĞLU ise, SYMEK md. 5/II’deki tescil kurumunu yerinde bulmaktadır. TOPALOĞLU, age., s. 93).

³⁵ Aynı kararda mali hak sahibi olan kişi, “eser sahibi” olarak nitelendirilmiş, kavramlar arası bir kargaşa oluşturulmuştur. Bakınız; 11. H.D., 29.06.1999 T., 1999/3506 E., 1999/6012 K. sayılı kararı (Yayınlanmamıştır).

1.000.000.000.-TL olmak üzere 3.000.000.000.-TL maddi tazminat ile davacı A. için 10.000.000.000.-TL., E. ve E. için de 6.000.000.000.-şar TL'den olmak üzere toplam 25.000.000.000.-TL tazminatın yayın tarihinden itibaren davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı A. Müzik Yapım Ltd. Şirketi, açılan davanın yerinde olmadığını, 5846 sayılı Yasanın 48. maddesi gereğince; eser sahiplerinin tüm mali haklarını yer, zaman ve süre yönünden bir sınırlama olmaksızın başkalarına devretmelerinin olanaklı olduğunu, somut olay da muris Ö.G.'ün İstanbul 22. Noterliği tarafından düzenlenen 10.03.1973 tarih ve 1381 yevmiye no'lu izinname ile dava konusu edilen tüm eserlerle ilgili haklarını H. Plak/M.D. isimli kişiye devrettiğini, adı geçenin de bu izne dayalı olarak Kültür Bakanlığından 9.12.1991 tarih ve 1524 no'lu "Eser İşletme Belgesini" alıp, daha sonra İzmir 10. Noterliğinden tanzimli 30.10.2000 tarih ve 21975 no'lu senetle davalı Şirket'e (A. Müzik Yapım Ltd. Şirketi'ne) devrettiğini davalının da devir yoluyla elde ettiği bu hakkına dayalı olarak uyuşmazlık konusu kaseti (yaptıklarını belirtmiştir).

Taraflar arasındaki uyuşmazlık; dava konusu ve isimleri yukarıda yazılan türkülerin, davacılar ile murisleri Ö.G.'ün izinleri alınmadan, davalı Şirket tarafından kasete tespit edilerek çoğaltılıp dağıtılmasından kaynaklanmaktadır. Uyuşmazlık konusu türkülerin tamamının muris Ö.G. tarafından icra edildiği ve bunlardan "Çöz de Al Mustafa Ali" isimli türkü dışındakilerin tamamının ya derleyeni, ya da kaynak kişisi olması nedeniyle sahiplerinin yine Ö.G. olduğu anlaşılmaktadır. ... davacıların mirasbırakanı Ö.G.; (Çözde Al Mustafa Ali) adlı... türkü hariç diğerlerinin hem (eser sahibi) hem de icra eden sanatçısı, "Çöz de Al Mustafa ali" isimli türkünün ise sadece icra eden sanatçısıdır...

... Yasanın anılan maddesinde fonogram yapımcılarının haklarına da yer vermiştir. ... Fonogram yapımcılarının da ... tespit yapabilmeleri için, aynı icracı sanatçılar gibi ilk önce eser sahibinden, hemen arkasından da icracı sanatçıdan izin alması gerekir. Bu olgu FSEK'in 80/1- A ve B maddelerinde açıklıkla vurgulanmıştır. Kuşkusuz eser sahibi ile icracı sanatçının aynı kişi olması halinde tek izin yeterli olacaktır. **Ancak, burada üzerinde durulması gereken "izin" 49. maddede belirtilen "lisans"tan (ruhsattan) oldukça farklıdır. Çünkü ruhsat, eser sahibinden alınacak bir kullanma hakkının devriyle elde edilir ve sahibine kullanma ile yararlanma hakkı verir.** Yine koşulları gerçekleşirse ruhsatın (lisansın) iptali ve feshedilmesi de mümkündür. ... **icracı sanatçının, icrasının tespiti ile ilgili olarak fonogram yapımcısına verdiği ... izinle; fonogram yapımcısı, 80. maddede vurgulandığı gibi mutlak bir hakkı aslen iktisap etmiş olur. Böyle bir izinden geri dönülmesi olanaksızdır.** ...

Bu açıklamalardan sonra somut uyuşmazlığa dönersek; davacıların murisi Ö.G., dava konusu eserlerden "Çöz de Al Mustafa Ali" isimli olanı hariç, diğerlerinin hem maliki hem icracı sanatçısı, "Çöz de

Al Mustafa Ali" isimli türkünün ise icracı sanatçısıdır. ... dosya içinde yer alan ve İstanbul 22. Noterliği tarafından düzenlenen **10.03.1973 tarih ve 1381 yevmiye no'lu izinname ile (icracı sanatçı Ö.G.); dava konusu edilen tüm ilgili icralarının tespiti için ... H. Plak/M.D.'e izin vermiş, bu iznin karşılığın da o tarihte peşin olarak almıştır.** Aldığı paranın az veya çok olması, artırılıp arttırılmaması gerektiği bu davanın konusu değildir. Kaldı ki, böyle bir iznin bedelsiz verilmesi dahi olanaklıdır. **Böylece H. Plak/M.D. yapılan bu işlemle; yapımcılıkla ilgili mutlak hakkını aslen iktisap etmiş olup, bu hakkına dayanarak yapılan tespitle ilgili; takip edecek devir, izin, çoğaltma ve yayma için ayrıca muris Ö.G. veya mirasçıları(ndan izin alması gerekmediği) gibi (Ö.G. ve mirasçılar açısından) verilen bu izinden dilekçede belirtilen nedenlerle dönmek de olanaklı değildir.** Nitekim H. Plak/M.D. bu hakkına dayalı olarak önce, Kültür Bakanlığından 9.12.1991 tarih ve 1534 no'lu "Eser İşletme Belgesi" almış, daha sonra da İzmir 10. Noterliğinden tanzimli 30.10.2000 tarih ve 21975 no'lu senetle bu hakkını davalı Şirket'e (A. Müzik Yapım Ltd. Şirketi'ne) devretmiştir. **Davalı Şirket de devirden kaynaklanan hakkına dayalı olarak uyuşmazlık konusu kasetleri çoğaltıp yaymıştır.** (Davalıların) eylemleri yukarıda geniş bir şekilde açıklandığı gibi tamamen FSEK'in amir hükümlerine uygun olup, davacıların talep ettikleri maddi ve manevi tazminatın koşulları gerçekleşmemiştir. ...Yukarıda açıklanan nedenlerden ve tüm dosya kapsamından, açılan davanın reddine ... dair karar davacı vekilinin huzurunda temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunup anlatıldı." Ankara Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 15.02.2005 T., E. 2004/38, K. 2005/79.

Müzik eserlerini ilgilendiren bir başka bilinmesi gereken düzenleme de FSEK 57. maddesindedir. Bu hükme göre; asıl veya çoğaltılmış nüshalar üzerindeki mülkiyet hakkının devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, fikri hakların devrini ihtiva etmez. Bu konuya örnek olarak, sipariş edilen bir bestenin notalarının besteci tarafından sözleşme gereğince yapımcıya teslim edilmesini veya icracı tarafından hazırlanan master kaydının bir yapımcıya verilmesini veya bir yapımcının elindeki master kaydı ve çoğaltılmış cd'lerin başka bir yapımcıya verilmesini gösterebiliriz. Orijinal imzalı notalar elinde olan veya master kayda malik olan kişi mutlaka hakları devralmış değildir. Bunun için asıl veya çoğaltılmış kopyaları elinde bulunduranların; besteciden veya icracı sanatçıdan ya da diğer yapımcıdan yazılı olarak bir anlaşma ile hangi hakları amaçlıyorsa onları devralması gerekir.

Eser sahipleri ve Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 23. maddesinin atfı uyarınca, komşu hak sahipleri, FSEK madde 50/1'e göre, hakkını

devretmek yerine **“devir taahhüdünde”** de bulunabilir³⁶. Bu halde mali hak, devralanın malvarlığına geçmez. O sadece devredene karşı hakkın kendisine geçirilmesi konusunda bir talep hakkı elde eder. Bir hakkın devri taahhüdünde, taahhüt edilen, bir tasarruf işlemi niteliğinde olan mali hakların devri işleminin yapılmasıdır. Dolayısıyla bu taahhüt, bir ön sözleşmeye değil; sözleşmeye konu olabilir³⁷.

Eser sahipleri ve kıyasen komşu hak sahipleri açısından uygulanacak FSEK madde 50/2’de ise, eser sahibinin ileride yapacağı tüm ya da aynı türden tüm icralarının bir devir taahhüdüne konu olabileceği yer almaktadır. Bu hükmün komşu hak sahiplerine kıyasen uygulanması sonucunda örneğin, bir icracı sanatçı, ileride yapacağı tüm icralara ilişkin haklarını bir yapımcıya devretmeyi taahhüt edebilir. Bu tarzda bir sözleşmeyi taraflar, ihbar tarihinden bir yıl sonra hüküm ifade etmek üzere feshedebileceklerdir. İracı sanatçının fesih hakkının sözleşmeyle kısıtlanması da söz konusu olmayacaktır. Zira, böyle bir fesih hakkı söz konusu olmasa idi, bireyin kişiliğini ve ekonomik özgürlüğünü ahlaka aykırı şekilde sınırlayan bu tarz sözleşmeler batıl olacaktı (Medeni Kanun madde 23/2, Borçlar Kanunu madde 19-20). Hüküm, özgürlüğü kısıtlamanın sınırını çizerek, bu tarz sözleşmelerin batıl sayılmasının önüne geçmiştir³⁸.

Yine kıyasen uygulanacak FSEK madde 50/3’de devir taahhüdünün infisah edeceği haller sayılmıştır. Bu hükme göre; fikri ürün tamamlanmadan önce hak sahibi ölür veya eseri, icrayı, fonogramı tamamlama kabiliyetini kaybeder ya da kusursuz olarak, tamamlama imkansız hale gelirse sözleşme münfesihi olur. Bu hallerde devir taahhüdünün yerine getirilmesi mümkün olmaz ve borç mirasçılara geçmez³⁹.

³⁶ Bu sözleşmeyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. GÖKYAYLA, age., s. 223 vd. Naklen ARKAN, age., s. 231

³⁷ DURAL, age., 79. Naklen ARKAN, age., s. 231

³⁸ TEKİNAY, age., s. 252 vd.; OĞUZMAN, M.K./ SELİÇİ, Ç./ OKTAY, S. *Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler)*, 7. Bası, İstanbul, 2002, 129-131; DURAL, M./ ÖĞÜZ, T., *Türk Özel Hukuku C. II, Kişiler Hukuku*, 6. Bası, İstanbul, 2002, s. 136-138; AYİTER, age., s. 215-216; TEKİNALP, age., §15 N. 36; EREL, age., s. 253; DURAL, age., s. 80. Naklen ARKAN, age., s. 232

³⁹ EREL, age., s. 254; TEKİNALP, age., § 15 N. 38; DURAL, age., s. 81. Naklen ARKAN, age., s. 232

Aynı hüküm, sözleşmenin karşı tarafına ilişkin devir taahhüdünün infisah sebeplerini de düzenlemiştir. Buna göre, sözleşmenin karşı tarafı iflas eder veya devralacağı hakları kullanmaktan aciz duruma düşerse veya bu hakları kullanması kusur olmaksızın imkansız hale gelirse sözleşme münfesi olacaktı⁴⁰.

Burada, FSEK madde 51/1'e de değinmek yararlı olacaktır. Bu hükme göre, ileride çıkarılacak mevzuatın, eser sahibine tanınması muhtemel mali hakların, devrine ilişkin sözleşmeler batıldır. Bunun gibi, ileride çıkarılacak mevzuatla, mali hakların içeriğinin genişletilmesi veya koruma sürelerinin uzatılmasından doğacak yetkilerden vazgeçmeyi veya bunların devrini içeren sözleşmeler de geçersizdir⁴¹. Bu hüküm de komşu hak sahipleri açısından kıyasen uygulanır.

E. MALİ HAKLARIN LİSANSI

Mali haklar açısından ikinci tip hak geçirme yöntemi “**ruhsat**” veya diğer adıyla “**lisans**”tır. Lisans/ ruhsat verme; hakkın, devreden malvarlığını bütünüyle terk etmeden devralana sadece kullanılması yetkisinin tanınmasıdır. Ruhsatın “devir”den farkı; sadece belli ve sınırlandırılmış hak veya haklarla ilgili kullanma yetkisi vermesidir. “*Bir müzik eserinin sadece ... adlı şarkıcı tarafından tek bir albüm için seslendirilmesi*”, “*eserin internette iki yıl süre ile umuma iletimi*”, “*yapımların üç yıl müddetle sadece internet ve cep telefonları açısından digital araçlarla umuma iletimi*” veya “*sahibi olduğum şarkının web sitesinde başlangıç sayfası olarak kullanılması*” yahut “*icranın sadece Türkiye’de çoğaltılması ve yayma haklarının izni*” gibi hak yetkilendirmeleri ya da kullanma yetkileri ruhsat vermedir.

Mali hakların lisansına ilişkin açıklamalarımız, hem eser sahibine ve hem de Komşu Haklar Yönetmeliği’nin 23. maddesi gereğince, komşu hak sahiplerine uygulanır.

Mali hakkı devreden malvarlığından çıkarmadan, sadece kullanım yetkisini sağlayan ruhsatın hukuki niteliği oldukça tartışmalıdır⁴².

⁴⁰ EREL, age., s. 254; TEKİNALP, age., § 15 N. 39; DURAL, age., s. 81. Naklen ARKAN, age., s. 232

⁴¹ TEKİNALP, age., § 15 N. 23; AYİTER, age., s. 216. Naklen ARKAN, age., s. 233

⁴² Lisansın hukuki niteliğine ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. Saibe OKTAY ÖZDEMİR, , *Sinai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması*, İstanbul, 2002, s. 18 vd. ve STAUB, R.,

FSEK madde 48/3 ile 50/1’de bu işlem devirle birlikte tasarruf işlemi olarak nitelenmiştir⁴³. Ancak, elbette Kanun’un yanlış nitelendirilmesi, bir işlemin niteliğini değiştiremez. Bu hukuki işlem ile hakkın kendisi devreden malvarlığından çıkmamakta, kullanma iznini alan kişi, verilen lisans çerçevesinde hakkı kullanma olanağını elde etmektedir. Bu nedenle ruhsat (lisans) sözleşmesi, konusu kullandırma olan kiraya ve daha çok hasılat kirasına benzemektedir. Bu gerekçelerle söz konusu işlemin borç doğuran bir işlem, bir sözleşme olduğu şeklinde görüşleri paylaşıyoruz⁴⁴. FSEK madde 56/3, basit ruhsatlar hakkında hasılat kirasına, tam ruhsatlar hakkında ise intifa hakkına dair hükümlerin uygulanacağını belirtmiştir. Burada Kanun’un emrettiği bir kıyas söz konusudur. Tam ruhsatta taahhüdün kapsamının genişliğinden dolayı; lisans veren, lisans alan karşısında adeta intifa hakkı sahibi karşısındaki çıplak mülkiyet sahibi gibi değerlendirilmektedir. Ancak buradan, ruhsatın mutlak bir etki sağlayacağı sonucuna ulaşılmamalıdır⁴⁵.

FSEK madde 56 hükmüne göre, ruhsat; mali hak sahibinin başkalarına da aynı ruhsatı vermesine mani değilse “basit ruhsat”tır. Eğer bir müzik eserinin icrası için icracı sanatçıya basit ruhsat verilmişse, müzik eseri sahibi tarafından aynı müzik eserinin başka bir icracı sanatçı tarafından icra etmesi için yeni bir lisans verilebilir. Kanun veya sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça her ruhsat basit sayılır. Basit ruhsatlar hakkında hasılat kirasına dair kurallar geçerlidir. Koşulları varsa basit ruhsatların feshi veya iptali mümkündür.

FSEK madde 56 gereğince, eğer devredilen mali haklar, yalnız bir kimseye (yani devralana) mahsus olduğu takdirde “tam ruhsat”tır. Tam ruhsat verme hukuki işlemi inhisaridir yani devredilen haklar artık

Leistungstörungen bei urheberrechtsverträgen, Bern, 2000, s. 50 vd. ve 90 vd. Naklen ARKAN, age., s. 233

⁴³ Bu görüşte TEKİNALP, age., § 15 N. 29; EREL, age., s. 263; ARSLANLI, age., s. 174. Yargıtayın da bu görüşü paylaştığı karalarından anlaşılmaktadır. Örnek olarak bkz. 11. H.D. 11.3.1999 T. ve 1998/9958 E., 1999/3423 K. sayılı kararı. [ERDİL, (İçtihatlı ve Gerekçeli FSEK.) s. 229-230]; 11. H.D. nin 11.3.1999 T. ve 1998/9958 E. 1999/3423 K. sayılı kararı [ERDİL, İçtihatlı ve Gerekçeli FSEK.) s. 145]. Naklen ARKAN, age., s. 233

⁴⁴ OKTAY ÖZDEMİR, age., s. 65-66; Haluk TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. I/1, 5. Baskı, İstanbul, 1988, s. DURAL, age., s. 68; AYİTER, age., s. 210-211; STAUB, age., s. 50. Naklen ARKAN, age., s. 234

⁴⁵ AYİTER, age., s. 212-213. Naklen ARKAN, age., s. 234

devredilen kişinin tekelindedir ve eser sahibinden de ayrılmıştır. Bu halyle “tam ruhsat”, “devir” işlemine benzer sonuçları doğurur. Tam ruhsatlar hakkında intifa hakkına dair hükümler uygulanır⁴⁶.

Yargıtay’ın tam ruhsatın sonuçlarına ilişkin kararlarını şöyle sıralayabiliriz:

11. H.D. 11.03.1999, E.1999/9858, K. 1999/3423 no’lu kararına göre, “...*tam ruhsat verilmişse, ruhsat sahibinin fiilen mali hak sahibinden farkı yoktur...*”, 11. H.D. 26.04.1999, E.1999/594, K. 1999/3250 no’lu kararına göre, “...*tam ruhsatta, mali haklara ait kullanma yetkisi tamamen ruhsat sahibine devir edildiğinden....tam ruhsatta....devir alan... Markalar Kanunu’ndaki inhisarı lisans sahibi gibi(dir)... **eser sahibi ve komşu hak sahibi tam ruhsatta mali hakkı kullanma yetkisini tamamen ruhsat sahibine devir ettiğinden*** (ve devredenin artık hakkı kalmadığından), *tam ruhsat sahibine dava hakkı tanınmaması halinde eser ve komşu hak korumasız kalacaktır.*”

Yargıtay’ın aşağıdaki kararlarında tam ruhsat konusunda ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır:

“....FSEK 48/II madde uyarınca, **eser sahibi veya mirasçuları bir mali hakkın sadece kullanma yetkisini devir** edebilirler. Bu durumda **mali hak özü itibariyle eser sahibinin mal varlığında kalmakla birlikte, maddi bir malın hasılat kirasına verilmesinde olduğu gibi, mali hakkı kullanma ve semelerinden yararlanma yetkisi ruhsat alan tarafa geçmiş olur** (FSEK 56/III). Ruhsat veya lisans verme; ilgili mali hakka özgü olan kullanma veya yararlanma yetkilerinden bir kısmının veya tamamının mali haktan ayrılarak ruhsat sahibine tahsis edilmesi olarak benimsenmektedir. Kullanma yetkisinin ruhsat veya lisans ile devri Kanun tarafından mali hakkı tahdit eden, kayıtlayan bir tasarruf işlemi kabul edilmiş olup, **tam ruhsat sahibi haiz olduğu yetkileri gerek mali hak sahibine gerekse üçüncü şahıslara karşı öne sürebilecek ve kullanmayı engelleyen müdahaleleri men ettirebilecektir. Tam ruhsatta, mali hakka ait kullanma yetkisi tamamen ruhsat sahibine devir edildiğinden, devir alan da bu yetkiyi kendi başına kullanabilecek ve tecavüzün men ve ref’i davası ile birlikte 68 nci ve devam maddelerinde yazılı bedel davasını açabilecektir.** (Bkz. Prof. Dr. Şafak N. Erel. Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Yenilenmiş 2. Bası 1998 sh. 260 vd. 293 sh. Dr. Halil Arslanlı – Fikri Hukuk Dersleri, II, Fikir ve Sanat Eserleri).

... Davacının Yasada yazılı anlamda bir meslek kuruluşu olmadığı açıktır. Ancak, eser sahibi ve komşu hak sahibi mali haklarını

⁴⁶ TEKİNALP, age., s. 212 vd.

üye olduğu meslek kuruluşuna devir edebileceği gibi, FSEK 48/2 ve 56 nci maddeleri uyarınca mali hakkını tam ruhsat vermek suretiyle başkasına devir etmesi halinde yukarıda anılan kurallar doğrultusunda tam ruhsat sahibinin de dava hakkı bulunduğu kabulü gerekecektir. Nitekim 556 sayılı KHK'nin 21/6. maddesinde “*aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından marka sahibinin markadan doğan hakların tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin bu kanun hükmünde kararname uyarınca açabileceği davaları kendi adına açabilir*” hükmü getirilmiş olup inhisari lisans sahibine marka sahibi gibi mütecavize karşı her türlü dava açabilme hakkı Kanun tarafından benimsenmiş olup, **5846 sayılı Yasa uyarınca; aksi “Tam Ruhsat Sözleşmesi”nde kararlaştırılmamış olmak şartıyla tam ruhsat ile, mali hakka ait kullanma yetkisini eser sahibi ve komşu hak sahibinden devir alan tam ruhsat sahibinin de, Markalar Kanunu’ndaki inhisari lisans sahibi gibi, eser sahibi ve komşu hak sahiplerinin üçüncü kişilere karşı açabilecekleri davaları kendi adına açabileceklerini kabul etmek gerekir.** Aksinin kabulü halinde, eser sahibi ve komşu hak sahibi tam ruhsatla mali hakka ait kullanma yetkisini tamamen ruhsat sahibine devir ettiğinden tam ruhsat sahibine dava hakkı tanınmaması halinde eser ve komşu hak korumasız kalacaktır. Bu gerekçeler ve dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.⁴⁷”

“FSEK 56/1 maddesinde düzenlenen Tam Ruhsat, eser sahibinin mali hakka özgü olan kullanma veya yararlanma yetkilerinden bir kısmının veya tamamının mali haktan ayrılarak ruhsat sahibine tahsis edilmesidir. Aynı ruhsatın başkalarına verilememesi nedeniyle de Basit Ruhsat’tan ayrılır. Tam ruhsat verilmişse, ruhsat sahibinin fiilen maddi hak sahibinden farkı yoktur. Ancak FSEK ruhsat sahibinin tecavüzün ref’ini talep edip edemeyeceği hususunda bir hüküm getirmemiştir. Doktrinde ruhsat, tasarruf işlemi olarak kabul edildiğine ve tam ruhsat sahibinin eser sahibi ve komşu hak sahibinin sahip olduğu mali hakları kullanma veya yararlanma açısından farkı olmadığına göre, tam ruhsat sahibi de mali hak sahipleri gibi tecavüzün önlenmesi ve tazminat davası açabilirler. Hatta açmadığı takdirde doğacak zarardan mali hak sahibine veya eser sahibine karşı sorumlu olabilirler.”⁴⁸

⁴⁷ Yargıtay 11. H.D., 26.4.1999, E. 1999/594, K. 1999/3250.

⁴⁸ Yargıtay 11. H.D., 11.3.1999, E. 1998/9958, K. 1999/3423

Önemle belirtmek gerekir ki; FSEK madde 49’a göre, eser sahibi veya mirasçılardan mali bir hak veya böyle bir hakkı kullanma ruhsatını iktisap etmiş bir kimse, ancak bunların yazılı izniyle bu hakkı veya kullanma ruhsatını diğer birine devredebilir. Bu yazılı izin ilk imzalanan sözleşmede olabilir veya sonradan bir sözleşme düzenlenerek alınabilir. Yani, eser sahibi ve mirasçıları, sonraki el değiştirmeleri engelleme yetkisine sahiptir. Buna göre; bir icracı tarafından seslendirilmiş bir müzik eserini çoğaltmak için ruhsat alan fonogram yapımcısı, bu hakları sözleşmesinde devre ilişkin bir izin olmadan ya da sonradan gidip icracı sanatçıdan izin almadan, bir başka fonogram yapımcısına devredemez. Yine eserin çoğaltım hakkı konusunda 100.000 cd çıkarmak veya iki yıl süre almış olan fonogram yapımcısı, bu hakkını bir yıl kullanıp, ikinci yılını eğer sözleşmede devre ilişkin izin yoksa başkasına devredemez. 50.000 cd çıkarıp, kalan 50.000 cd için haklarını kendisine bu hakkı tanıyan kişiden özel bir devir yetkisi almadan başkasına devredemez. ARKAN’a göre, Kanun’un böyle bir hüküm getirmesinin sebebi, eser sahibi ile eser arasındaki bağın, mali hakların devri ile kesilmemesi, manevi hakların devam etmesidir. Kanun koyucu, eser üzerindeki hakkın kötü kullanılması ihtimaline karşı bir garanti olarak kendisine hak devredilen veya ruhsat verilen kişinin bu hakkı şahsen kullanmasını gerekli addetmiştir. Yani yasa koyucu, eser sahibine bir izleme ve denetleme hakkı tanımıştır⁴⁹. ARKAN’a göre bu hükümlerin Kanuna konuş amacından varılacak sonuç, FSEK madde 48 ve 49’da (eser sahipleri için) yer alan düzenlemelerin, yalnızca icracı sanatçılar açısından kıyasen uygulanabilir olduğudur. Zira izleme ve denetleme amaçlı bu düzenlemenin gayesi, mali hakkın devri sonucunda, manevi hakkın kesilmemesi ve zedelenmemesidir. Dolayısıyla manevi hakka sahip olmayan diğer bağlantılı hak sahipleri açısından üçüncü kişilere devirlerde ilk devredenden izin alınması uygulanması Yazarca mümkün değildir. Bizim de sadece “ruhsat” hak geçirme yöntemi açısından (“devir” hak geçirme yöntemi açısından bu görüşe katılmamakla birlikte) sınırlı olarak katıldığımız bu görüşe göre; diğer bağlantılı hakların sahipleri icracı gibi manevi haklara sahip olmadığından, ruhsat verme ilişkisi açısından hakların başkalarına devri konusunda izin verilmediğini ileri sürme yetkisine sahip değillerdir.

⁴⁹ ARKAN, *age.*, s. 229

FSEK 49. maddenin düzenlemesi “*eser sahibi veya mirasçılardan mali bir hak veya böyle bir hakkı kullanma ruhsatını iktisap etmiş olan bir kimse, ancak bunların yazılı muvafakatiyle bu hakkı veya kullanma ruhsatını diğer birine devredebilir*” demektedir. Burada 49. madde “**mali bir hak ... ruhsatı**” ve “**mali bir hakkı kullanma ruhsatı**” şeklinde iki tip ruhsat saymakta böylece, 48. maddenin ilk fıkrasındaki “devir” işlemini hariç tutmaktadır. Mali bir hakkı kullanma ruhsatına “*çoğaltma hakkını internet için alma*” verilebilir. Bu konuda çeşitli örnekler üzerinden düşünce üretilebilir. İlk örnekte, eser sahibi sözleşmede ek bir madde ile çeşitli olasılıklar doğrultusunda üçüncü kişilere bu ruhsatı devir için izin vermiş olabilir, bu halde devir için sorun yoktur. Bu devir veya devirler için toptan bir izin veya her biri için tek tek düzenleme yapılabilir. İkinci örnekte, sözleşmede üçüncü kişilere devir konusunda bir izin verildiği açıkça belirtilmiyorsa; eser sahibi veya mirasçısından A Şirketi ruhsat almışsa bunu B Şirketine devretmek için ayrıca eser sahibinin yazılı muvafakatını işlem öncesi alması gerekir. B Şirketi yine yazılı muvafakatla C’ye ve yine yazılı muvafakat varsa C de D’ye devredebilir. Aksi takdirde A Şirketi, FSEK madde 49 gereği mali hakkı veya kullanma yetkisini B’ye devredemez. Üçüncü örnek ise, sözleşmede üçüncü kişiler için devir yasağı olmasıdır. Bu durumda devir imkanı bulunmamaktadır⁵⁰.

Özünde FSEK madde 49 düzenlemesi hatalıdır. Maddede “*tam ruhsat mı yoksa basit ruhsat mı kastediliyor*” sorusunun cevabı açık değildir. Bizce 49. madde sadece basit ruhsatlar için bu kuralı getirmelidir. Zira yukarıda da açıkladığımız gibi “tam ruhsat”, “devir” hukuki sonucuna yakın hukuki sonuçları devralan için sağlamaktadır. Nitekim Yargıtay bu konuda tam bir kararlılık göstermese de görüşümüze uygun kararlar vermektedir. Yargıtay; 11. H.D. 15.10.2001, E. 2001/4951, K. 2001/7904 sayılı kararıyla, ölenin sağlığında eserle ilgili haklarını devralan kişilerin, bu hakları devrettiği kişilerin haklarının korunması gerektiğini ve bu hakların artık ölenin terekesinden çıktığını söylemekte ve bizim “devir” ve “tam ruhsat” için ileri sürdüğümüz mutlak hak görüşümüzü desteklemektedir. Yine 11. H.D. 15.10.2001, E. 2001/4928, K. 2001/7866 sayılı kararıyla “...1995 tarihli sözleşme ile...filmlerin SVMEK’den kaynaklanan hakları(nın) film ve negatifleri ile birlikte Kanal ... A.Ş’ne devredildiği, sözleşmenin 5. maddesi gereğince mülkiyet

⁵⁰ 11. H.D., 27.04.1998, E. 1998/1104, K. 1998/2748.

haklarının anılan Şirkete gittiği, ... işletme haklarının devir ve tescil işlemleri yapılmak üzere yetkilendirildiği, bu şekilde devralınan haklarının Kanal ... A.Ş. tarafından davalıya (bir başka yayıncı olan Y'ye) verilmesi nedeniyle davacının (filmlerin Kanal ..'dan önceki hak sahibi olan X Şirketinin) tazminat talep hakkı bulunmadığı... hüküm altına alınmıştır. Fakat, 11.HD. 09.06.2003, E. 2003/499, K. 2003/6125 sayılı kararında “...sözleşmede... **eserin tüm yayın haklarının** bu davalıya ait olduğunu kabul etmişse de, yayın haklarının bu (bir başka) davalıya devretmesine muvafakati olduğuna dair sözleşmede bir hükme yer verilmemiştir. Oysa eser sahibinin, eserinin yayın hakkını vermiş olduğu aktinin (diğer tarafın), bu hakkı bir başkasına devredilmesi için... FSEK 49. maddesi gereğince yazılı olarak muvafakatte bulunması gerekmekte olup...” ibaresiyle, tam ruhsata ilişkin devirde eser sahibinden izin alınması gereğini belirtmiştir. Kanaatimizce, Yargıtay basit ruhsatlar hakkında 2003 tarihli kararını uygulamalı ancak, tam ruhsatlar hakkında 2003 tarihli bu uygulamasını değiştirmelidir.

Aşağıdaki karar, eser sahibinin hakları konusunda lisans verirken, lisans verilen kişiye bu hakları üçüncü kişilere devretmesi konusunda yasak koyduğu bir sözleşmeden doğan uyuşmazlığın mahkemelerde nasıl çözüldüğünü göstermektedir.

“Davacı vekili, müvekkillerinin yazar R.B.'ye ait telif haklarının temsilcisi olduğunu, yazarın “İsyancılar” ismindeki tiyatro eserinden yararlanma hakkının bazı koşullarla müvekkili ajans tarafından davalıya devredildiğini, **tarafklar arasındaki sözleşmenin 3. maddesine göre, davalının bu hakları başkalarına devredemeyeceğinin** belirlenmesine karşın, anılan tiyatro eserinin muvafakat ve bilgileri dışında “O.. Organizasyon” ismindeki firmaya devredildiği ve **eserin Almanya'da 19 kez temsil olduğunu, gösterilerde her bir biletin ortalama 30 DM fiatla satıldığını, asgari bir hesapla beher temsili 100 kişinin izlediğinin kabul edilmesi halinde toplam 57.000 DM'lık bir hasılat elde edildiğini, aradaki sözleşmeye göre telif hakkının hasılatın % 40'ı olduğunu ileri sürerek 22.800 DM karşılığı 1.279.400.000 TL'nin reskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.**

Davalı vekili davaya cevabında; ... müvekkili ile O.. Organizasyon arasında imzalanan sözleşmeye göre (eser sahibi ya da haleflerine) ekstra telif ücreti ödemesinin organizasyon şirketi tarafından üstlenildiğini, durumun davacıya bildirilmesi üzerine davacı ile organizatör şirket arasında ekstra telif hakkı için sözleşme imzalandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran; **yazarın 27.4.1994 günlü anlaşma ile “İsyancılar”**

isimli tiyatro eseri üzerindeki kullanma haklarını davacı Şirkete devrettiği, davalının davacı ile yapmış olduğu sözleşmeye aykırı hareketi nedeniyle taleple bağlı kalınarak davacının talep ettiği 2.379.400.000 TL'nin dava tarihinden itibaren % 57 ve değişen oranlarda reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmıştır.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Davacı şirketin, yazar R.B.'in "*İsyancılar*" adındaki tiyatro eseri üzerindeki temsil hakkını kullanma yetkisini 27.4.1994 günlü sözleşmeyle devraldığı anlaşılmaktadır. Davacının devraldığı bu yetkiyi 26.9.1995 tarihli sözleşme uyarınca, başkasına devredilmemek koşuluyla davalıya devrettiği hususunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık davalının Almanya turnesindeki temsillere ilişkin olarak dava dışı O.. Organizasyon ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile imzaladığı 2.2.1996 tarihli sözleşme ve 8.2.1996 tarihli ek sözleşmelerden kaynaklanmaktadır. Davacı ile davalı arasında imzalanan sözleşme bakımından, davalının temsil yetkisini ... bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredemeyeceği hususu tartışmasız olmasına karşın, davacının bahse konu turnenin organizasyonunu yapan, uyuşmazlık dışı O.. Organizasyon Ltd. Şti. ile yapmış olduğu 3.4.1996 tarihli sözleşmenin niteliği üzerinde durulması, değerlendirilmesi ve sonucuna göre hüküm tesis edilmesi (gerekirken) noksan incelemeye yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir⁵¹."

Ancak eser üzerindeki mali haklar, haciz veya rehin sonucu yahut iflas masasına dahil olarak paraya çevrilirse, bunların üçüncü şahıslar tarafından iktisabında hak sahiplerinin izni gerekli değildir⁵².

Ruhsat konusunda bir başka konu, bir müzik eserinin filme alınması için veya rap müzik yapılmak üzere bir halk müziği parçasının işleme hakkı konusunda ruhsat veya izin verilmesidir. FSEK madde 16/2 maddesindeki izin/müsaade kavramı klasik anlamda bir ruhsattır. İşleme konusunda verilen ruhsat çok geniş kapsamlı olsa bile, belirli yasal koşullara uyulmamışsa eser sahibi tarafından menedilebilir. Zira, FSEK 16. maddesi "*eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak yazılı izin vermiş olsa bile eserin mahiyet ve özelliklerini bozan her türlü değiştirmeleri men edebilir, menetme yetkisinden bu hususta sözleşme yapılmış olsa bile vazgeçmek hükümsüzdür*" düzenlemesini içermektedir.

⁵¹ Yargıtay 11. H.D., 27.4.1998, E. 1998/1104, K. 1998/2748

⁵² EREL, age., s. 271.

Devir veya ruhsatlar açısından önemli bir konu, bağlantılı hak sahibi veya kullanıcıların hak sahibi olmayan kimselerden hak aldıklarını zannederek birçok zararlara uğramalarıdır. FSEK madde 54 gereğince; mali bir hakkı yahut kullanma ruhsatını devre yetkili olmayan kimseden satın alan veya kiralayan kişi, iyiniyet sahibi olsa bile hak sahibi olamaz. Bu kural, komşu hak sahipleri açısından da kıyasen uygulanır. Yapımcı bir albüm için bir besteci ile anlaşır, fakat besteci besteyi arkadaşına veya başka bir besteciye yaptırır ve sözleşmede belirtildiği tarihte yapımcıya teslim eder. Yapımcı daha sonra bu besteyi aranje etmek için başka bir aranjöre verir. İşte burada problem çıkar. Çünkü yapımcının sözleşme yaptığı besteci hak sahibi değildir. Bu yüzden bu bestenin yeniden aranje edilmesi veya albüm şeklinde çoğaltılması asıl eser sahibi tarafından kolayca durdurulabilir. Bu yüzden de yapımcı para ve zaman kaybına uğrar, hatta üçüncü kişilerle bu albümün dağıtımını veya internette satışı hakkında dahi anlaşmış olabilir ve işin sonunda üçüncü kişilerle bu albüm için yaptığı anlaşmaların bozulması ile karşılaşabilir. Bu durumda yetkisi olmaksızın mali bir hakkı başkasına devreden veya kullanma ruhsatını veren besteci aynı maddeye göre; yetkili bulunmadığını diğer tarafın bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat etmedikçe yapılan sözleşme ve sözleşmeden dönülerek işin hükümsüz kalmasından doğan menfi zararı ödemekle sorumludur. Kusur halinde mahkeme; hakkaniyet gerektiriyorsa sadece menfi zararı değil, ayrıca kâr kaybı gibi müspet zararı içeren daha geniş bir tazminata hükmedebilir. Aynı şekilde, bir internet sitesi sahibi, bir müzik yapımcıdan hak sahibi olduğunu düşünerek bazı müzik yapıtlarının kamunun erişimine sunma hakkını alma konusunda sözleşme yapıp, ücretini ödemiş olur. Eğer hakları devreden hak sahibi değilse, internet sitesi sahibi bu eserleri internet üzerinden kullanıcılara yararlandırıamaz. Yanılıp da internette bu müziklerden üçüncü kişileri yararlandırırsa o zaman gerçek hak sahibinin açtığı davalar karşısında normal ederin üç katı bedeli tazminat ödeme ve hapis cezası riski ile karşılaşır. Bir film yapımcısı veya televizyon kuruluşu sahibi; filmde veya yayınlarda kullanmak için bir yapımcıdan fonograma kayıtlı bir şarkıyı sözleşmeyle alabilir. Eğer yapımcı bu şarkının haklarına sahip değilse aynı hukuki sakıncalar film yapımcısı veya yayıncı için gerçekleşir.

Tüm bu örneklerde olduğu gibi eserle ilgili hak devralmak isteyenlerin eserin veya icranın ya da fonogramın gerçek sahibini araştır-

ması gerekmektedir. Yargıtay da aşağıdaki kararda görüleceği gibi aynı görüştedir.

“Davacı vekili, bestesi ve güftesi müvekkiline ait “*Susun Ağlayacağım*” isimli eserin, davalılar tarafından “*Koy Koy*” isimli kasette haksız ve izinsiz olarak kullanıldığını, bu nedenle müvekkilinin maddi ve manevi zarar uğradığını ileri sürerek, 80.000.000 TL maddi ve 70.000.000 TL manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir...

Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran; “*Susun Ağlayacağım*” isimli eserin davacıya ait olduğunu, davalı Z.C. ve yapımcı firma olan diğer **davalı tarafından FSEK’nun 48 ve 52. maddelerine uygun izin alınmadan kullanıldığını, davalı şirketin basiretli bir tacir gibi davranıp gerçek hak sahipliği yönünden araştırma yapmadığı için iyi niyet savunmasının dinlenemeyeceğini, tespit edilen zarardan davalıların sorumlu olduğunu** ..., davanın kısmen kabulü ile, davacının mali haklarına tecavüzün önlenmesine, 61.980.000 TL maddi ve 20.000.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden yürütülecek %57 ve değişen oranlardaki reeskont faizi ile davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.⁵³”

F. CAYMA HAKKI

FSEK madde 58’de cayma hakkı şu şekilde düzenlenmiştir:

“*Mali bir hak veya ruhsat iktisap eden kimse, kararlaştırılan süre içinde ve eğer bir süre tayin edilmemişse icabı hale göre münasip bir zaman içinde hak ve salahiyetlerden gereği gibi faydalanmaz ve bu yüzden eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlal edilirse eser sahibi sözleşmeden cayabilir.*

Cayma hakkını kullanmak isteyen eser sahibi sözleşmedeki hakların kullanılması için noter vasıtasıyla diğer tarafa münasip bir mehil vermeye mecburdur.

Hakkın kullanılması, iktisap eden kimse için imkansız olur veya tarafından reddedilir yahut bir mehil verilmesi halinde eser sahibinin menfaatleri esaslı surette tehlikeye düşmekte ise mehil tayinine lüzum yoktur.

Verilen mehil neticesiz geçerse veya mehil tayinine lüzum yoksa noter vasıtasıyla yapılacak ihbar ile cayma tamam olur. Cayma ihbarının tebliğinden itibaren 4 hafta geçtikten sonra caymaya karşı itiraz davası açılmaz.

⁵³ Yargıtay 11. H.D, 9.6.1998, E. 1998/1638, K. 1998/4351

İktisap edenin mali hakkı kullanmamakta kusuru yoksa veya eser sahibinin kusuru daha ağır ise hakkaniyet gerektiği hallerde iktisap eden, münasip bir tazminat isteyebilir.

Cayma hakkından önceden vazgeçme caiz olmadığı gibi bu hakkın dermeyerini iki yıldan fazla bir süre için meneden takyitler de hükümsüzdür”

Yukarıdaki düzenlemeye göre, mali bir hak veya ruhsat elde eden kimse, kararlaştırılan süre içinde ve eğer bir süre belirlenmemişse duruma göre uygun bir zaman içinde hak ve yetkilerinden gereği gibi faydalanmaz ve bu yüzden eser sahibinin çıkarları önemli şekilde ihlal edilirse eser sahibi sözleşmeden cayabilir. *Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği*’nin 23. maddesine göre bu hüküm komşu hak sahipleri için de kıyasen uygulanır. Ancak bu düzenleme daha çok manevi haklar açısından önemli olduğundan icracı sanatçı dışındaki komşu hak sahiplerine uygulanması zordur. Yine de mali haklara ilişkin önemli bir menfaat ihlali varsa bağlantılı hak sahiplerine de uygulanabilir. Bizce bu hak tazminat ile karşılanabilecek (önlenebilecek) normal mali hak ihlallerinde uygulanmamalıdır.

Kanun cayma hakkının doğması için eser ya da hak sahibinin menfaatlerinin esaslı surette ihlal edilmiş olmasını aramaktadır. Bunların ne tür menfaatler olduğu ve ne tür ihlallerin esaslı sayılacağı Kanun’da belirtilmemiştir. Ancak hak veya ruhsatı kullanmama sebebiyle sözleşmeye aykırılık sadece mali menfaatleri ihlal etseydi, bunun Borçlar Kanunundaki müeyyidelerle karşılanması mümkündü ve FSEK madde 58 hükmüne gerek kalmazdı. O yüzden, doktrin cayma hakkının daha ziyade manevi menfaatlerinin ihlali halinde kullanılabileceği görüşündedir⁵⁴. Mamafih mali menfaatlerin ihlali de Borçlar Kanunu’na nazaran eser sahibini daha iyi koruyan bu hükümden istifadeye engel yoktur.⁵⁵ Bize göre cayma hakkı, her tür mali hak menfaatinin ihlali de kullanılamaz. Bu menfaatlerin esaslı surette ihlali açısından bu düzenleme geçerlidir. Yargı organları bu esaslı ihlalleri önüne gelen davada dikkatle belirlemelidir. Küçük bir mali hak ihlali için beş- on yıl geçerli olabilecek bir telif hakkı anlaşması cayma yolu ile ortadan kaldırılmamalıdır.

EREL’e göre cayma hakkı, eserin kamuya sunulma ve yayımını engelleme konusundaki FSEK madde 14/3 ile ilişkilidir. FSEK madde

⁵⁴ ARSLANLI, age., s. 194-195; AYİTER, age., s. 219.

⁵⁵ EREL, age., s. 256

14/3'e göre eser sahibi şeref ve itibarını düşürecek tarzda eserin kamuya sunulmasını veya yayımını men edebilir. Mali hakların veya ruhsatların kullanılması, çoğu kez eserin kamuya sunulmasını veya yayımını gerektirir. Eser sahibinin şeref ve itibarı, hak veya ruhsatın hiç veya gerektiği gibi kullanılmaması yahut uygun olmayan bir süre veya tarzda kullanılması yüzünden ihlal olunursa, eserin kamuya sunulması men edilerek sözleşmeden cayılabilir. Doktrin, FSEK madde 14/3 hükmünden, eser sahibinin eserinde öne sürdüğü görüşlerini değiştirmesi sebebiyle eserin yayımından vazgeçmesi halinde de istifade olunabileceği ve sözleşmeden cayılabileceği kabul edilmektedir⁵⁶.

Ruhsat sonrasında karşılaşılan bir konu da anlaşmanın sonunda hakların eser sahibine geri dönmesidir. FSEK 59. madde gereğince; eser sahibi veya mirasçıları mali bir hakkı belirli bir amaç için yahut belirli bir süre için devretmişlerse amacın ortadan kalkması veya sürenin geçmesiyle ilgili hak, sahibine geri döner.

FSEK'de madde 59, *“eser sahibi veya mirasçıları mali bir hakkı muayyen bir gaye zımında yahut muayyen bir süre için devretmişlerse gayenin ortadan kalkması veya sürenin geçmesiyle ilgili hak, sahibine avdet eder. Bu hüküm, başkasına devrine sözleşme ile müsaade edilmiş olan mali bir hakkı iktisap eden kimsenin ölümü yahut iflası halinde cari değildir; meğer ki, işin mahiyeti icabı, hakkın kullanılması, iktisap edenin şahsına bağlı bulunsun. Muayyen bir gaye zımında veya muayyen bir süre için verilen ruhsatlar birinci fıkra da sayılan hallerde son bulur.”* şeklinde düzenlenmiştir.

EREL'e göre; mali hak veya ruhsat bunlardan gerektiği gibi faydalanmak gayesiyle ve belirli bir süre için devredileceğinden, kararlaştırılan tarzda yahut uygun bir süre içinde kullanma gerçekleşmezse devir gayesi ortadan kalkar ve mali hak eser sahibine geri döner, ruhsat da son bulur (FSEK madde 59). Bu suretle cayma hali ile aynı hukuki sonuçlar doğmuş olmaktadır. Aralarındaki fark; sözleşmeden geri dönmenin kendiliğinden *“ipso jure”* hüküm ifade etmesine karşın, caymada eser sahibinin yapacağı bazı usul işlemlerine gerek bulunmasıdır. Eser sahibi devir gayesinin gerçekleşmediğini ve mali hakkın geri dönmesi yahut ruhsatın son bulması gerektiğini iddia ediyorsa, manevi menfaatlerinin

⁵⁶ AYİTER, age., s. 219; Alman Telif Hakları Kanunu & 42

bu yüzden (önemli şekilde) ihlal olduğunu ispat şartıyla cayma hakkını kullanabilir.⁵⁷

Kanun cayma hakkının eser sahibi tarafından kullanılacağı belirtmekte birlikte; onun ölümü halinde bu hakkın, FSEK madde 19/I hükmüne göre manevi hakların intikal ettiği şahıslar tarafından da kullanılması mümkündür. Mali hak devren iktisap olunmuşsa, devreden hak sahibinin de iktisap edene karşı FSEK madde 19/3 hükmünde belirtilen hallerde cayma hakkından yararlanabileceği kabul edilebilir.⁵⁸

Cayma hakkının kullanılmasının esasa ve şekle ilişkin bazı şartlara bağlı olduğunu belirtmiştik.

Esasa ilişkin şart, yukarıda belirtildiği üzere devredilen mali hak veya ruhsattan hiç veya gerektiği gibi istifade olunmaması yahut kararlaştırılan sürede; süre kararlaştırılmamışsa uygun bir zaman zarfında bunların kullanılmamasıdır. Ayrıca eser sahibinin manevi veya mali menfaatleri bu yüzden **esaslı surette** ihlal edilmiş olmalıdır.⁵⁹

Şekle ilişkin şarta gelince, Kanun bu hususta Borçlar Kanunu madde 106 ve 107 hükümlerine paralel bir düzenleme öngörmektedir. Eser sahibi ilk önce sözleşmedeki hakların kullanılması için noter vasıtasıyla karşı tarafa uygun bir mehil tanımalıdır⁶⁰. Bu, hak veya ruhsatın sözleşmeye uygun şekilde kullanılması için diğer tarafa verilen son bir imkandır. Ancak şu üç halde bir mehil tayinine lüzum kalmaz. Bu haller, hakkın kullanılmasının iktisap eden için imkansız olması; iktisap eden tarafından hakkın kullanılmasının red edilmesi ve hak sahibinin menfaatlerinin esaslı surette tehlikeye düşecek olmasıdır (FSEK madde 58/2). Keza Borçlar Kanunu madde 107'ye kıyasen hak veya ruhsatın kullanılması için kesin bir vade edilmemişse, yine mehil verilmesi gerekmez⁶¹. Mehil tayinine lüzum olmayan hallerde cayma işlemi noter ihbarının karşı tarafa tebliğ edildiği tarihten itibaren tamamlanır ve hüküm ifade eder. Buna karşılık mehil verilmişse, verilen sürenin sonuç

⁵⁷ EREL, age., s. 257

⁵⁸ ARSLANLI, age., s. 195, not 2

⁵⁹ EREL, age., s. 257

⁶⁰ FSEK md. 58 hükmünün tatbik edilebilmesi için, mali hak müktesibinin mezkûr hakkı kullanmamış olması ve bu hususta kendisine yine maddenin gösterdiği usul dahilinde bu kullanma keyfiyetinin ihtar edilmesi gerekir. TD. 20/4/1973, E. 1973/1967, K.1973/1818, Res. Kar. Der. 1973 11/2 s. 414-417

⁶¹ ARSLANLI, age., s. 195.

alınmadan dolması halinde ikinci bir noter ihbarı gönderilir ve bunun tebliği ile cayma tamamlanmış olur (FSEK madde 58/3). ARSLANLI, her iki ihbarın aynı ihtarnamede birleştirilebileceğini ve ilk ihbarda mehilin sonuçsuz kalması halinde cayma hakkının kullanılmış sayılacağını belirterek, ikinci ihbara gerek olmadığı kanaatindedir⁶².

Yargıtay'ın cayma hakkı konusunda verdiği aşağıdaki karar koyca müzik eserlerine uygulanabilir.

“Davacı, ders kitapları yazarı olduğunu, yazdığı kitapların 12’sini davalı ile yapılan sözleşme gereğince Y... Yayınları’na bırakmak zorunda kaldığını, sözleşmenin FSEK’na aykırı olarak düzenlendiğini, bu nedenle cayma hakkını kullandığını, cayma ihtarının tebliğ edilmesine rağmen, caymaya karşı itiraz davası açılmadığını, cayma hakkını ve değişikliklere muhalefet hakkını süresiz olarak ortadan kaldırmaya yönelik sözleşme hükümlerinin tümüyle hükümsüz olduğunu ileri sürerek sözleşmenin iptaline, sözleşmeye konu olan kitapların bütün haklarının tarafına avdetine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının aynı konuda açtığı davanın reddedildiğini, o kararın henüz kesinleşmemesi nedeniyle derdestliğin söz konusu olduğunu, yapılan sözleşmeye müvekkilinin bağlı kaldığını, cayma hakkının kullanılmasını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, **cayma hakkının** kullanılması yenilik doğuran hak niteliğinde olup, **tebliğinden sonra dört hafta içerisinde caymaya karşı itiraz davası açılmadığı gerekçesiyle, sözleşmenin feshedilmesine, karar kesinleşinceye kadar kitapların basımının, dağıtımının, basımla ilgili film vs. malzemelerin kullanılmasının tedbiren önlenmesine karar verilmiştir.**

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

İlke olarak her dava, açıldığı tarihteki fiili ve hukuki duruma göre hükme bağlanır. Dava tarihinden sonra doğacak haklar için görülmekte olan davada karar verilmesi mümkün değildir.

Davacı, 27.06.1998 tarihinde davalıya tebliğ edilen cayma ihtarnamesine dayanarak bu davayı açmıştır. Yargılama sırasında gerek 09.03.2000 havale tarihli dilekçesiyle davadan önce gönderdiği cayma ihbarında hukuki bir hata yaptığını söylemiş olması ve gerekse bilirkişi tarafından anılan **cayma ihtarına şarta bağlı olduğu gerekçesiyle** itibar edilmemesi nedeniyle davacı tarafından gönderilen **ilk cayma ihtarı FSEK’nun 58 nci maddesine uygun olarak düzenlenmemiştir.**

⁶² ARSLANLI, age., s. 196.

Davacı tarafından 08.07.1999 tarihinde bir cayma ihtarı daha davalıya tebliğ edilmiş ise de, bu cayma ihtarı yargılama sırasında gönderilmiş olmakla, yukarıda açıklanan ilke doğrultusunda ikinci kez yapılan cayma ihtarının bu dava içerisine tartışılıp tartışılmayacağını belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, gerekçe gösterilmeksizin ikinci cayma ihtarına geçerlilik tanınarak eksik incelemeye dayalı olarak davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.⁶³

Cayma hakkı yenilik doğuran bir haktır. Mali hakkın eser sahibine dönmesi veya ruhsatın son bulması için ayrı bir tasarruf işlemine gerek yoktur ve cayma, ihbarın tebliğ tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Caymaya itiraz davası mahkeme tarafından red olunmuşsa, red kararının hükmü ihbar tarihine kadar geriye yürür⁶⁴.

Yapılan sözleşme ile bir hak elde edenin mali hakkı kullanmamakta hiçbir kusuru yoksa ya da eser sahibinin kusuru daha ağır ise hakkaniyetin gerektirdiği hallerde cayma sonucu hakkı yeniden elde edenin, uygun bir tazminat ödemesi gerektiğini hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Cayma hakkından önceden vazgeçme olanağı olmadığı gibi, bu hakkın ileri sürülmesini iki yıldan fazla bir süre için yasaklayan sınırlamalar da hükümsüzdür.

Cayma hakkı açısından bir başka konu bağlantılı hak sahiplerinin; eser sahipleri ve diğer bağlantılı hak sahiplerinin FSEK 80 maddesinde belirtilen “izin” açısından cayma hakkının kullanılıp, kullanılamayacağıdır. İzin, alan kişi açısından “devir”e benzeyen hükümler taşıyan mutlak hak niteliğinde özel bir hukuki durumdur. İzin ile; icracı sanatçı icrasını ve fonogram yapımcısı fonogramını oluşturmaktadır. Bu oluşumlar sonucunda; icracı sanatçı veya fonogram yapımcısının elinde bulunan yapımlar açısından; bunlara izin verenlerin dahi dokunamayacağı komşu haklar niteliğinde bağımsız ve müdahale edilemeyecek haklar oluşturulmaktadır. Bu nedenle de daha önce de bahsettiğimiz gibi FSEK madde 58’de bulunan cayma hakkı, hakkın konusunun gerçekleştiği, fonogramın oluştuğu, yayının veya filmin tespitinin yapıldığı hallerde, “izin” hak alımı için kullanılamaz. Yine “devir” hak geçirim yönteminde, artık hakkın eski sahibi ile ilgisi kalmadığından kanaatimizce cayma hakkı kullanılamaz.

⁶³ Yargıtay 11. H.D., 15.10.2001, E. 2001/5026, K. 2001/7942

⁶⁴ ARSLANLI, age., s. 196.

G. HAK YÖNETİM SİSTEMLERİ

Özellikle bilgisayar ve cep telefonlarıyla, internet veya gsm hatları üzerinden müzik eserlerinin kullanılması ile birlikte, belli şifrelerle kullanıcıların sınırlandırılması hak yönetim sistemleri ile olanaklı olmuştur. Günümüzün teknolojik koşulları doğrultusunda bu sistemler “digital hak yönetimi” olarak anılmaktadır. Digital hak yönetimi; temel olarak elektronik yöntemler kullanılmak suretiyle medya üzerinde bulunan fikri hakların kullanılan tekniğe göre korunması, izlenmesi, kısıtlanması olarak tanımlanabilir⁶⁵.

Digital hak yönetimi ile internet dünyasındaki korsan sorunu da önemli ölçüde engellenebilmektedir. Bu sistem, fikri haklar sektörlerinin yanı sıra yazılım ve telekomünikasyon sektöründe de gelişmeler sağlamaktadır⁶⁶. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, digital haklar yönetimi sistemlerini düzenleyen hukuk kurallarında güncellemelerin zaman kaybedilmeden yapılması hak ihlallerini önlemede etkin olacaktır.

Digital hak yönetimi sisteminin iki ana unsuru vardır:

Bunların ilki eser ve bağlantılı hak sahiplerinin, korunan fikri hakların, eserin yaratılma zamanının ve teknolojik yöntemin tanımlandığı **tanımlama** kısmıdır. İkinci unsur ise **sınırlamalar** kısmıdır.

Sınırlamalar kısmında;

- a) İçeriğin tümüne erişimin engellenmesi,
- b) İçeriğin belirli bir bölümüne erişimin engellenmesi,
-Zaman bakımından,
-Bütünlük bakımından,
-Devamlılık bakımından (sayıyla sınırlı erişim)
- c) İçeriğin değiştirilmesinin engellenmesi,
- d) İçeriğin kopyalanmasının engellenmesi gibi uygulamalar bulunmaktadır⁶⁷.

⁶⁵ Leyla KESER BERBER, Erdem TÜRKEGUL, Tuğrul SEVİM, Yasin BECENİ, Nurdan ÇAVDAROĞLU, Gonca KARA, Sayısal Haklar Yönetimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2006, s. 6

⁶⁶ KESER BERBER, TÜRKEGUL, SEVİM, BECENİ, ÇAVDAROĞLU, KARA, age., s. 6

⁶⁷ KESER BERBER, TÜRKEGUL, SEVİM, BECENİ, ÇAVDAROĞLU, KARA, age., s. 16 vd.

Digital hak yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzenlemeler bulunmaktadır.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması; diğer hak sahipleri gibi icracı sanatçılar ve fonogram yapımcılarının da özellikle internet ve bilgisayar ortamlarında çoğaltma, yayma, temsil ve kamunun erişimine sunma haklarını korumak için çeşitli önleyici hükümler düzenlemiştir. Anlaşmanın “Teknolojik Tedbirlere İlişkin Yükümlülükler” başlığı altındaki 18. maddesine göre; *“Akit taraflar, ilgili icracı sanatçılar ya da fonogram yapımcılarına yetki veya kanunla izin verilmeyen fiillerin gerçekleştirilmesini kısıtlayan ve bu Andlaşma ile kendilerine tanınan haklar çerçevesinde icracı sanatçılar ve fonogram yapımcılarınca kullanılan etkin teknolojik yöntemlerin etkisiz hale getirilmesine karşı uygun yasal koruma ve etkin yasal yaptırımlar öngörecektir”*.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması “Hak Yönetim Bilgilerine İlişkin Yükümlülükler” başlığı ile 19. maddesinde şu düzenlemeleri öngörmüştür:

“(1) Akit taraflar, bu Andlaşma ile öngörülen herhangi bir hakkın ihlalinin mümkün kılındığını, kolaylaştırıldığını veya saklandığını düşündürecek geçerli sebeplerle aşağıdaki fiilleri bilerek işleyenlere karşı veya hukuki tedbirlere tabi olanlar için yeterli ve etkin yasal tedbirler öngörecektir.

(i) Yetkisiz olarak elektronik hak yönetim bilgilerini değiştirmek ya da ortadan kaldırmak,

(ii) Elektronik hak yönetim bilgilerinin izinsiz değiştirildiği ya da ortadan kaldırıldığı bilinen icraları, tespit edilmiş icra veya fonogram nüshalarını yetkisiz olarak dağıtmak, dağıtılmak üzere ithal etmek, radyo ve televizyonla yayınlamak ya da topluma sunmak veya iletmek,

(2) Bu maddede geçen “Hak Yönetim Bilgisi” ifadesi, bilgi ögelerinden herhangi biri tespit edilmiş icra veya fonogram nüshaları üzerinde olduğunda veya tespit edilmiş icranın veya fonogramın topluma sunumu veya iletme bağlı olarak görüldüğünde icracının icrası, fonogram yapımcısının fonogramı, icra veya fonogram üzerindeki herhangi bir hakkın sahibi ya da fonogram veya icra kullanımına ilişkin koşullar ve süreler hakkındaki bilgiler ve bu bilgileri temsil eden tüm sayı ya da kodları tanımlayan bilgiler anlamına gelmektedir.”

2001/29 sayılı AB “Bilgi toplumunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara İlişkin Belirli Konuların Uyumlaştırılmasına Yönelik

Direktifi”nin “Teknolojik Önlemlerle İlgili Yükümlülükler” başlıklı 6. maddesinde;

“1. Üye devletler, herhangi bir teknolojik önlemin, ilgili kişi tarafından bilerek veya bilmesi gerektiğine dair makul sebeplere binaen etrafından dolanılmasına karşı etkili yasal korumayı sağlarlar.

2. Üye devletler, herhangi bir etkili teknolojik önlemin,

(a) etrafından dolanmak amacı için teşvik edilen, ilan edilen veya pazarlanan veya,

(b) etrafından dolanmaktan başka sadece sınırlı önemde ticari amaca sahip veya amaçla kullanılan veya,

(c) esas olarak, dolanmayı kolaylaştırmak veya temin etmek amacıyla tasarlanan, üretilen, kabul edilen, veya icra edilen,

üretim, ithal etme, dağıtma, satma, kiralama, satma veya kiralama için ilan etme veya ticari amaçla araçları, ürünleri, ya da parçaları elde bulundurma veya hizmetin sunumuna karşı yeterli yasal korumayı sağlar.

3. Bu Direktifin amaçları için, ‘teknolojik önlemler’ ifadesi, normal kullanımlarında, eser veya diğer konular ile ilgili, telif hakları veya hukuken sağlanan telif hakkı veya 96 /9/AT sayılı Direktifin 3. kısmında sağlanan kendine özgü hak gibi tüm hakların hak sahibi tarafından müsaade edilmeyen kullanılmalarını önlemek ve sınırlandırmak için tasarlanan her türlü teknoloji araç veya bunların parçalarını ifade eder. Teknolojik önlemler, hak sahibi tarafından, korunan bir eserin veya diğer bir konunun, koruma hedefine ulaştıracak kodlama, şifreleme ya da diğer eser veya diğer konuların transformasyonu ya da bir kopyalama denetim mekanizması gibi erişim kontrolü ya da koruma usullerinin uygulanması halinde “etkin” sayılırlar.

4. Birinci fıkrada sağlanan yasal korumaya rağmen, hak sahiplerince alınan ve hak sahipleri ve ilgili diğer taraflar arasındaki anlaşmaları da içeren gönüllü önlemlerin yokluğunda, üye devletler, hak sahiplerinin, 5. maddenin 2. fıkrasının a, c, d ve e bendine, 3. fıkranın a, b veya e bendine uygun olarak ulusal hukuklarda bulunan bir istisna ve sınırlamanın faydalanıcısına, bu sınırlama ve istisnadan yararlanma araçlarını, faydalanıcı, ilgili korunan esere veya konuya eriştiğinde ve istisna veya sınırlamadan gerektiği kadar faydalanana dek, elde etmesini garanti altına alan uygun önlemleri alır. Özel kullanım için yeniden üretme, hak sahibi tarafından, 5. madde ve 5. maddenin 2. fıkrasının b bendinin hükümlerine uygun olarak ve ilgili sınırlama ve istisnadan yararlanılincaya dek olanaklı kılınmamış ise, bir üye devlet bu hükümlere göre röprodüksiyonun sayısı ile ilgili olarak yeterli önlemlerin almaktan

hak sahiplerini alıkoymadıkça, 5. maddenin 2. fıkrasının b bendine göre temin edilen bir sınırlama veya istisnanın yararlanıcısı ile ilgili olarak da bu tür önlemler alabilir.

Birinci ve ikinci bent hükümleri, bireylerin, kişisel olarak seçilen bir zaman ve yerden bu eser ve konulara ulaşması şeklinde kararlaştırılan akdi koşullar nedeniyle halka erişimine açık eserler veya diğer konulara uygulanmaz.

Bu madde, 92/100/AET ve 96/9/AT sayılı Direktifler bağlamında uygulandığında, bu fıkra gerekli uyarlamalar yapılmak koşuluyla uygulanır.”

Aynı Direktifin “Hak Yönetimi Bilgisi ile İlgili Yükümlülükler” başlıklı 7. maddesine göre;

“1. Üye devletler, izin almaksızın ve bilerek aşağıdaki işlemlerden birini icra eden kişilere karşı, eğer bu kişi, herhangi bir telif hakkının veya kanun tarafından konulan telif hakları ile bağlantılı tüm hakların veya 96/9/AT sayılı Direktifin 3. kısmında temin edilen kendine özgü hakkın, ihlalini sevk ettiğini, temin ettiğini, kolaylaştırdığını, veya böyle bir ihlali gizlediğini bilir veya bilmesi için yeterli neden var ise , gerekli yasal tedbirler alırlar:

(a) herhangi bir elektronik hak yönetimi bilgisini değiştirmek veya kaldırmak,

(b) bu Direktif veya 96/6/AT Direktifinin III. kısmı altında korunan elektronik hak yönetimi bilgisi izinsiz olarak değiştirilmiş veya kaldırılmış olan eserleri veya diğer konuları dağıtmak, dağıtım için ithali, yayınlamak, iletmek veya kamunun erişimine açmak,

2. Bu Direktifin amaçları için, ‘hak yönetimi bilgisi’ ifadesi, bu Direktifteki eser veya diğer konuları tanımlayan veya 96/9/AT sayılı Direktifin 3. kısmında düzenlenen kendine özgü hak, yazar veya diğer herhangi bir hak sahibini, eser veya diğer konuların kullanma şart ve koşulları hakkındaki bilgi ve böyle bir bilgiyi tevsik eden herhangi bir numara ya da kodu içeren her türlü bilgi demektir.

Birinci bent bu Direktifte belirtilen bir eser veya diğer bir konunun veya 96/9/AT Direktifinin 3. kısmında düzenlenen kendine özgü hakkın kopyasına bağlantılı olan ya da kamuya yapılan bir bildirimle bağlantılı görünen bilginin parçalarına uygulanır.”

FSEK madde 72’de hak yönetim bilgilerine karşı eylemleri de kapsar şekilde şu düzenleme yapılmıştır:

“Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

FSEK Ek madde 4’deki ilk fıkraya göre; “eser ve eser sahibi ile eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodları yetkisiz olarak değiştirilen veya ortadan kaldırılan eserlerin asılları veya kopyaları dağıtılamaz, dağıtmak üzere ithal edilemez, yayınlanamaz veya topluma iletilemez” ve FSEK 71. maddesine göre de “Bu Kanunun Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ...hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur”

H. MESLEK BİRLİKLERİ

Meslek birlikleri, menfaatleri koruma sözleşmesi çerçevesinde eser ve bağlantılı hak sahiplerinin, kural olarak, mali haklarına yapılan tecavüzleri tespit edip, bunlarla hukuken mücadele eden, gereğinde dava açan; bu hakları devralmak veya üzerlerinde ruhsat almak isteyenlerle sözleşmeler yapan, sözleşmelerin ifasını sağlayan ve izleyen; eser sahiplerine ödenmesi gerekli ücretleri tahsil eden ve hak sahiplerine dağıtan, yapıları ve çalışma şekilleri Kanun tarafından belirlenmiş, özel hukuk tüzel kişisi niteliği taşıyan kuruluşlardır.⁶⁸

Meslek Birlikleri FSEK’in yanı sıra “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ve Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkındaki Tüzük” hükümleri doğrultusunda üstlendikleri görevleri yerine getirirler.

Tüzüğe göre, müzik eserleri alanında; eser sahipleri, icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo ve televizyon kuruluşları, meslek birliği kurabilirler. O alandaki yaratıcılar, yorumcular, yapımcılar ve yayıncılar tarafından kurulan meslek birlikleri üyelerinden aldıkları yetki belgeleri doğrultusunda müzik eserlerini, icraları, yapımları ve yayınları kullanan kişilere izin vererek sözleşmeler yapar; telif bedellerini tahsil

⁶⁸ TEKİNALP, age., s. 276, Naklen ARKAN, age., s. 122

eder ve eğer üyelerinin hakları izinsiz olarak kullanılmışsa bu saldırılara karşı gerekli davaları açar.

Aşağıda meslek birliklerinin dava açma yetkisini gösteren bir karar görülmektedir:

“Davacı vekili, davalının müvekkili üyelerine ait müzik eserleri ile Sacem Sözleşmesi ve yabancı meslek birliği ile yapılan karşılıklı anlaşmalar gereği korumaları altında bulunan yabancı müzik yapıtlarını izin almadan ve yasalara aykırı olarak kullandığını, bu durumun 5846 sayılı Yasa’dan kaynaklanan hakların ihlali olduğunu iddia ederek, davalının tecavüzünün tespit ve önlenmesini, hüküm özetinin ilânına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, **davacının yerli ve yabancı müzik eserlerini koruma hakkına sahip bulunduğu, davalının, davacı korumasındaki bazı eserleri izinsiz olarak kullandığı, bu durumun FSEK’in 66, 69 ve 76. maddeleri gereği tecavüz oluşturduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davalının davacı meslek birliği tarafından himaye edilen eserleri izinsiz olarak yayınlarında kullanmasının FSEK’ten doğan eser sahibi haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine ve tecavüzün önlenmesine, hüküm özetinin bir kez ilânına karar verilmiştir.**⁶⁹,

FSEK 41. madde gereğince “girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52. maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin” almak zorundadır. Bu düzenlemeye göre, meslek birlikleri; hak sahiplerinin yerine geçerek, hak sahiplerinden aldıkları yetkiler gereğince umuma açık yerlerde müzik eserlerinin kullanılması için izin verme yetkisine ve yaptıkları sözleşmelerle bedel tahsil etmek yetkisine sahiptirler. FSEK 41. maddesi doğrultusunda; faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımından ve/veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile umuma açık mahaller arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu belirlenecek bedeller üzerinden yapılır.

⁶⁹ Yargıtay 11. H.D, 29.04.2003, E. 2002/11498 K. 2003/4266, ERDİL, age., s. 107-108.

Yine FSEK 41'e göre; umumi yerlerde kullanılan ve/veya iletimi yapılan eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar üzerinde hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, bunların kullanımına ve/veya iletimine ilişkin ödemelerin yapılmasını yetki verdikleri meslek birlikleri aracılığı ile talep edebilirler.

Meslek birlikleri, radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin olarak yayıncılara izin vermek ve bedellerini tahsil etmek konusunda yetkilendirilmiştir. Bu düzenleme şöyledir:

“Bu (yayıncı) kuruluşlar sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadırlar”.

Radyo ve televizyon yayıncıları için meslek birlikleri yine tarifeleri tespit edip, sözleşmeler yaparlar ve yayın telif bedellerini tahsil ederler.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 42. maddesinde meslek birliklerini şu şekilde düzenlemiştir:

*“**Eser sahipleri** ve eser sahiplerinin hakları ile **bağlantılı hak sahipleri** ile, bu Kanunun 52 nci maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden malî hakları kullanma yetkilerini devralarak bu Kanunun 10 uncu maddesine göre ilim-edebiyat eserleri üzerindeki hakları kullanarak, **sürelili olmayan yayınları çoğaltan ve yayınlar;** üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere, Kültür Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tüzük ve tip statülere uygun olarak tespit edilecek alanlarda birden fazla meslek birliği kurabilirler.*

Eser sahipleri veya icracı sanatçılar bakımından zorunlu organlarının asıl üye sayısının dört katı kadar; yapımcılar veya radyo-televizyon kuruluşları bakımından bu organların asıl üye sayısının iki katı kadar üye olma niteliklerini taşıyan gerçek veya tüzel kişiler meslek birliği olarak faaliyet gösterebilmek için izin almak üzere Bakanlığa başvurmak zorundadırlar.

Meslek birlikleri bu izni aldıktan sonra kuruldukları alanda faaliyet gösterirler.

Aynı alanda, başka bir meslek birliğinin kurulabilmesi için, yukarıda zikredilen kurucu üye sayılarından az olmamak kaydıyla o alanda kurulmuş en fazla üyesi olan meslek birliğinin üye tam sayısının 1/3'ü kadar üye olma niteliklerini taşıyan gerçek veya tüzel kişiler faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvururlar. Bakanlığın bu başvuruyu uygun bularak izin vermesi halinde faaliyet gösterirler. Her birlik ihtiyaçlar doğrultusunda şubeler açarak çalışabilir. Aynı alanda kurulmuş en az iki meslek birliği, Bakanlıkça hazırlanan tüzük ve tip statülerin belirlendiği usul ve esaslar çerçevesinde federasyon kurabilir. Aynı alanda birden fazla federasyon kurulamaz.

Meslek birlikleri ve federasyon özel hukuka tabi tüzelkişilerdir. Üyeleri sermaye koymak, kar ve zarara, hukuki mesuliyete iştirak etmekle yükümlü tutulamazlar.

Meslek birliklerinin ve federasyonun tip statülerinde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik - bilim kurulu ve haysiyet kurulu mecburi organ olarak düzenlenir. Bu birliklerin ve federasyonun kurulması, kontrolü; denetlenmesi ile ilk genel kurullarını toplayabilmeleri için gerekli en az üye sayısı, diğer ihtiyari organları, kurullarının teşekkül tarzı, üye sayısı ve görevleri üyeliğe girme, çıkma ve çıkarılma şartları, şubelerini kurabilecekleri bölgelerin tespiti, yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile olan ilişkileri, bu ilişkilerdeki hak ve yetkileri, üyeleriyle olan mali ilişkileri, elde edilen telif ücreti ve tazminatların dağıtımı ve diğer usul ve esaslara ilişkin hususlar; ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hazırlanacak tüzükle belirlenir.

4/10/1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası, 30, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ve 90 inci maddeleri, bu maddeye göre kurulacak meslek birlikleri ve federasyon için de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır.

Eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunla tanınmış hakları, ülke içinde bu maddeye göre kurulan meslek birlikleri dışında; başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez. Bu maddede geçen üyelik, kurucu üye sayısı ve üye tam sayısı gibi hususlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan meslek birlikleri için de aranır. Bütün meslek birlikleri Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde bu maddede getirilen esaslara uygun hale gelmek mecburiyetindedirler. Bu süre içinde bu şartı yerine getirmeyen meslek birlikleri altı ay sonunda kendiliğinden dağılmış sayılır.”

FSEK 42/A maddesi, meslek birliklerine bazı bildirim yükümlülükleri yüklemiş ve temsil ettikleri eserlerin kullanıcılar tarafından yararlanması koşullarını belirleyecekleri tarifelerde bulunması gereken zorunlulukları şu şekilde hüküm altına almıştır:

“Bu Kanunun 42 nci maddesinde öngörülen amaçlarla hakların idaresini sağlamak üzere kurulan meslek birlikleri;

1. Temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığa bildirmek ve ilgili kişilere açık bu bildirim her üç ayda bir güncellemekle,

2. Üyesi olan hak sahiplerinin faaliyetlerinden kaynaklanan haklarının idaresini hakkaniyete uygun koşullarda sağlamakla,

3. Üyelerinin haklarının idaresine ilişkin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri, dağıtım plânlarına uygun olarak hak sahiplerine dağıtmakla,

4. Yazılı talepte bulunan ilgili kişilere, temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile ilgili bilgileri vermekle,

5. Sözleşme yapılırken idare ettikleri haklara ilişkin olarak hakkaniyete uygun davranmakla, kendi maddî ve/veya manevî menfaatleri bakımından gerekli gördükleri indirim veya ödeme kolaylıklarını sağlamakla,

6. Sözleşme yapılabilmesi için idaresini sağladıkları haklara ilişkin ücret tarifelerini süresinde belirlemek ve belirlenen tarifeleri ve bu tarifelerdeki her türlü değişikliği süresinde duyurmakla,

7. Hesaplarını yeminli malî müşavirlere onaylatmakla yükümlüdürler.

Yukarıdaki fıkranın radyo-televizyon kuruluşlarının yayınları bakımından uygulanmasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kayıtları esas alınır.

Tarifelerin tespit edilmesinde; tarifelerin uluslararası uygulamaların ülkenin ekonomik ve toplumsal koşullarına uyarlanabilirliği göz önünde bulundurularak makul seviyede belirlenmesi ile teknolojik alandaki değişimlerin yanı sıra eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların yaratıldığı ve kullanıldığı sektörlerin yapısını tahrip edici, üretimi ve kullanımı engelleyici ve genel kabul görmüş uygulamalara zarar verici bir etki yaratılmaması, rekabeti bozucu şartlar oluşturulmaması, yapılan sınıflandırma, ilgili sektörlerdeki ürün fiyatları ve bu sektörlerin gayrisafi millî hâsıladaki payı, eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımı ve/veya iletim sıklığı, birim fiyat veya götürü usulü ödeme, ödeme plânı ve benzeri hususlar esas alınır.

Aynı alanda ve/veya sektörde faaliyet gösteren birlikler, tarife tespitinde, sözleşme yapılmasında ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer iş ve işlemlerde birlikte hareket edebilirler.

Ortak tarife yapılmış olması halinde, aynı alanda faaliyet gösteren meslek birlikleri, tarifelere esas olmak üzere her takvim yılının başında, alandaki temsil kabiliyetleri ile temsil ettikleri eser, icra, fonogram, yapıpım ve yayınlara ilişkin kullanım oranlarını tespit ederek Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Bu oranların tespitinde anlaşma sağlanamaması ve/veya bu oranların Bakanlığa bildirilmemesi halinde, Bakanlıkça oluşturulacak bir komisyon bu tespiti yapar. Bu tespit yapılmıncaya kadar, sözleşme yapmış kullanıcılar, ödemeleri gereken meblağı, Bakanlığın talebi üzerine mahkemece belirlenmiş tevdi mahalline yatırırlar.

Burada toplanan meblağ, komisyon çalışma giderleri mahsup edildikten sonra, ilgili meslek birlikleri arasında, komisyonca tespit edilen orana ya da herhangi bir aşamada, birliklerin aralarında anlaşmaları halinde, mutabakata vardıkları kullanım oranına göre paylaştırılır.

Komisyon Bakanlık, Rekabet Kurumu ve ilgili meslek birliklerini temsilen birer kişiden oluşur. Bakanlık temsilcisi aynı zamanda komisyon başkanıdır. Komisyon kararlarına yargı yolu açık olup, görevli mahkeme ilgili ihtisas mahkemesidir.

Bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması gereken bildirimlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenen meslek birliklerinin dağıtımına ilişkin hesabına Bakanlıkça, mahkemeden yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar tedbir konulması istenebilir.

Meslek birliğine üye eser veya bağlantılı hak sahiplerinin alenileşmiş veya yayımlanmış tüm eser, icra, fonogram, yapıpım ve yayınlarına ilişkin haklarının takibi meslek birliğine verilecek yetki belgesine göre yapılır. Yetki belgesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

FSEK 42/B maddesi; meslek birliklerinin yukarıda 42/A maddesine dayanan yükümlülüklerini yerine getirmezse neler olacağını ve Kültür ve Turizm Bakanlığının meslek birliklerini nasıl düzenleyeceğini şu şekilde düzenlemiştir.

“Meslek birlikleri, idarî ve malî açıdan Bakanlığın denetimine tâbidir. Bakanlık, meslek birliklerinin bu Kanunla belirlenmiş görev ve yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini her zaman kendisi denetleyebileceği gibi bu denetimin bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırıl-

masını meslek birliklerinden de isteyebilir. Bu kuruluşlarca yapılan denetimlere ilişkin raporların bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Denetimler sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve bilgilerin ibraz edilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme gibi taleplerin yerine getirilmesi zorunludur.

Meslek birlikleri tarafından;

1. Bu Kanunun 42 ve 42/A maddeleri ile bu maddede belirlenen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmediği,

2. Sözleşmelere uygun tahsilat veya dağıtımın yapılmadığı ya da yanlış ve haksız dağıtım yapıldığı,

3. Tarifelerin bu Kanunun 42/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen esaslara göre düzenlenmediği,

tespit edildiği takdirde, bu birlikler Bakanlıkça yazılı olarak bir defa uyarılır, uyarının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde kusurun giderilmemesi halinde, meslek birliği ikinci kez uyarılır.

Yukarıdaki fıkra da bahsi geçen kusurların ikinci uyarıyı takip eden otuz gün içinde de giderilmemesi veya yapılan denetimlerde, birlik kayıtlarında ve diğer iş ve işlemlerinde mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, Bakanlık en geç üç ay içinde olağanüstü genel kurul yapmak üzere üyeleri davet eder. Olağanüstü genel kurul yapılınca kadar, birliğin iş ve işlemlerinde suiistimali görülenler tedbiren işten el çektirilir, Bakanlıkça yerine atama yapılır veya sırası gelen yedek üye göreve çağrılır.

Bu Kanunun 42 ve 42/A maddeleri ile bu madde hükümleri, 42 nci madde çerçevesinde kurulacak federasyonlar için de uygulanır.”

VIII. ESER VE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİNİN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların sınırlandırılması ya eser sahibinin bu hakları kullanmaktan çeşitli gerekçelerle kısmen veya tamamen alıkonulması veya bu hakları kullanma yetkisinin onun izni alınmadan başka şahıs veya kuruluşlara devredilmesi anlamına gelir.¹ Aynı hal-lerde bağlantılı hak sahiplerinin hakları da sınırlandırılmaktadır. Bir hakkın herhangi bir şekilde sınırlandırılmasının temelinde çeşitli sebepler bulunabilir. Unutulmaması gereken husus fikri hakların başta Anayasa olmak üzere kanunların teminatı altında olduğudur. Bu yüzden, fikri haklara sağlanan koruma gibi, getirilen sınırlamaların da Kanunla konulması gerekmektedir.²

Uluslararası sözleşmelere baktığımız zaman Bern Sözleşmesi'nin konuyla ilgili hükmü 18. maddesidir. Roma Sözleşmesi madde 15'e göre:

*“Her akid devlet, bu sözleşme ile teminat altına alınan koruma hü-
kümlerine aşağıdaki hallerde kendi ulusal mevzuatıyla istisnalar öngörebilir.*

- a- özel kullanım,*
- b- güncel olayların bildirimi ile ilgili olarak küçük alıntılarının kullanılması,*
- c- bir yayın kuruluşu tarafından kendi araçları ile ve kendi yayın-
ları için geçici bir tespit yapılması,*
- d- münhasıran eğitim veya bilimsel araştırmalar amacıyla kullanılması.”*

Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre; *akid devletler; icracı sanatçı-
lar, fonogram yapımcıları ve yayın kuruluşlarının korunması konusunda,
kendi ulusal mevzuatında, edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki telif
haklarının korunmasına ilişkin sınırlamalara benzer nitelikte sınırla-
malar getirebileceklerdir.*

TRIPS Anlaşması madde 14/6, Roma Sözleşmesi'ne atıfta bulun-
maktadır. WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması madde 16/1' e göre;

¹ EREL, age., s. 193

² ATEŞ, age., s. 240

imzacı devletler kendi ulusal mevzuatlarında eser sahibi hakları için getirdikleri aynı türde sınırlamaları icracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları içinde getirebilmektedirler. Aynı Anlaşmanın 16/2. maddesinde ise, sınırlamaların icra veya fonogramın normal kullanımıyla çelişmeyen ve icracı sanatçı veya fonogram yapımcısının yasal çıkarlarına hanel getirmeyen şekilde olması gerektiği belirtilmiştir.

Avrupa Birliği Hukuku'nda 19 Kasım 1992 tarihli 92/100/AET sayılı *“Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi”* nin 10. maddesinde, hakların sınırlandırılması Roma Sözleşmesi'ndeki düzenlemeyle aynıdır. Ancak; söz konusu Direktifin 10. maddesinin 3. fıkrası, 2001/29/AT sayılı *Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına ilişkin Konsey Direktifi* 'nin 11/b hükmü ile kaldırılmış; yerine yeni hüküm getirilmiştir. Yeni hüküm, WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 16. maddesiyle aynıdır.

Türk Hukuku'nda ise fikri haklara ilişkin sınırlamalar FSEK'in ilgili maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre eser sahibinin hakları;

- A. Kamu düzeni,
- B. Genel menfaat ve
- C. Özel menfaat
- düşünceleriyle veya
- D.Hükümete tanınan yetkilerle sınırlandırılmıştır.

Aşağıda eser ve bağlantılı hak sahiplerine ilişkin bu sınırlamaları ilgili başlıklarının altında FSEK'in sınırlamalarla ilgili maddeleri eşliğinde inceleyeceğiz.

Bağlantılı hak sahipleri ile ilgili hakların kullanılması açısından sınırlamalar sadece 80 maddenin içinde ve son kısmında toplu olarak sayılmıştır. Bu madde şöyledir:

“Aşağıda belirtilen hallerde komşu hak sahibi ile film yapımcısının yazılı izni gerekli değildir:

1. Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veya haber amacıyla ve kazanç amacı güdülmeksizin icra edilmesi ve kamuya arzı.

2. Fikir ve sanat eserleri ile radyo-televizyon programlarının yayınlanma ve kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması.

3. Radyo-televizyon kuruluşlarının kendi olanaklarıyla kendi yayınları için yaptıkları kısa süreli geçici tespitler.

4. Bu Kanunun 30 uncu, 32 nci, 34 üncü, 35 inci, 43 üncü, 46 nci ve 47 nci maddelerinde belirtilen haller.

Bu uygulama, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep dışında zarar veremez veya eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz”.

Bağlantılı hak sahipleriyle ilgili sınırlamalar yine, Komşu Haklar Yönetmeliği’nin 24. maddesinin b bendinde;

“Komşu hak sahibinin iznini gerektirmeyen haller şunlardır:

- a) Aile çevresinde gerçekleştirilen özel ve ücretsiz icralar,
 - b) Özel kullanım için hazırlanmış ve herhangi bir ortak kullanım amacı taşımayan çoğaltmalar ve evde yapılan kayıtlar,
 - c) Eserin tanıtımı ya da bilimsel araştırmalar amacıyla yapılan analizler ve kısa tespitler,
 - d) Güncel bilgilendirme amaçlı olarak toplantılarda yapılan sunuşlar ve konuşmalar,
 - e) Yayın kuruluşlarının haber verme ve bilgilendirme amaçlı kullanımı,
 - f) Eser sahibinin ve komşu hak sahibinin şeref, itibar ve kişilik haklarını zedelemeyecek, türünün kurallarına uyan parodi ve karikatürler,
 - g) Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ya da röportaj amacıyla kazanç amacı güdülmenden icra edilmesi.”
- şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Şimdi bu sınırlamaları müzik eserleri açısından değerlendirerek inceleyelim.

A. KAMU DÜZENİ DÜŞÜNCESİYLE SINIRLANDIRMA

Kamu düzeni EREL tarafından; belirli bir yer ve zamanda toplumsal düzenin, huzur ve güvenliğin korunması için uyulması ve ihlal edilmemesinde toplumun mutlak menfaati bulunan kurallar bütünü olarak tanımlanmıştır. Eser sahibine tanınan haklarda kamu düzeni açısından getirilen sınırlamalar; eserin ispatı amacıyla mahkemelerde ve diğer resmi kurumlar önünde kanıt olarak kullanmak ve kolluk güçlerinin sanıkları teşhis etmeleri, izlemeleri veya suçun ortaya çıkarılmasında kolaylık sağlama gibi birçok sebeple olabilir.

FSEK madde 30’da konu; “*eser sahibine tanınan haklar, eserin ispatı maksadıyla mahkeme ve diğer resmi makamlar huzurunda ve aleltilak zabıta ve ceza işlerinde bir muameleyle konu teşkil etmek üzere*

kullanılmasına mani değildir...Eserin herhangi bir suretle ticaret mevkisine konmasını, temsilini veya diğer şekillerde kullanılmasını meneden yahut müsaade veya kontrole bağlı tutan kamu hukuku hükümleri mahfuzdur” şeklinde düzenlenmiştir.

Bağlantılı hak sahiplerine ilişkin kamu düzeni sebebi ile sınırlama; FSEK madde 80’deki sınırlamalar kısmında ilk maddede ve Komşu Haklar Yönetmeliğinde 24. maddenin b bendinde g fıkrasında düzenlenmiştir.

Eser ve bağlantılı hak sahibinin izin verme ve yasaklama hakkını ortadan kaldıran bir sınırlamadan söz edebilmek için kullanılan veya çoğaltılanın eser olması ve umuma arz edilmiş bulunması gerekir. Umuma arz edilmemiş bir eserden kamu düzeni düşüncesiyle yararlanılamaz. Kanuna, ahlaka, adaba, kamu düzenine aykırı olan eserlerde eser sahibi haklarını kullanamaz.³ Maddenin son cümlesinin uygulaması açısından da çeşitli örnekler verilebilir. Bir müzik eserinde çocuk pornosu veya cinsel ilişkinin pornografik unsurları bulunabilir ve savcılık bu eserlere ilişkin temsil veya satış yasağı koyabilir.

Kamu düzeni gerekçesine dayanılarak yapılan sınırlamalar, fikri hakkın eser sahibince kısmen veya tamamen kullanılmasına engel olacak ya da hakkın kullanılmasını denetime veya kamu makamlarının iznine tabi kılacak sonuçlara yol açabilmektedir. Konusu suç teşkil eden bir eserin toplatılması buna en iyi örnektir.⁴

B. GENEL MENFAAT DÜŞÜNCESİYLE SINIRLANDIRMA

Genel menfaat (kamu yararı) düşüncesiyle fikri haklara sınırlandırma getirilmesinin temelinde, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan gelişime ihtiyacının olması nedeniyle toplumun fikir ürünlerinden genel menfaat düşüncesiyle yararlanabilmesi gerekçesi yatmaktadır. Fikri haklara konulan sınırlamalar, kamu yararı için tam ve sınırlı bir ölçüde ya da eser sahibine belli bir bedel ödenmek kaydıyla tam veya sınırlı bir yararlanma serbestisi tanınması ve nihayet; eser, yapıpım, yayın ve filmler üzerindeki hakların genel yararlar nedeniyle sınırlandırılması şeklinde yapılmaktadır.

³ TEKİNALP, age., s. 185

⁴ ATEŞ, age., s. 271

FSEK madde 31 ve 32 kamu yararına tam bir yararlanma serbestisine örnektir. Bu maddelerde; mevzuat ve içtihatlardan herkesin yararlanması, kamuya açıklanması yararlı olan söz ve nutukların herkes tarafından bilinmesi olanağının yaratılması, günlük olaylardan kamunun bilgi alabilmesi için eserlerden serbestçe yararlanma düzenlenmiştir. Bu sınırlama sebepleri bağlantılı hak sahipleri açısından da FSEK 80. maddede, FSEK madde 32'ye atıf yapılarak düzenlenmiştir. Bu sınırlama sebebi, müzik eserleri açısından uygulama olanağı bulmadığından ayrıntıya gerek görmüyoruz.

FSEK madde 33 ise, eser sahiplerine özgü olarak kamu yararına sınırlı serbest yararlanmaya örnek oluşturmaktadır. Maddeye göre, yayınlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla, doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eser adının olağan şekilde açıklanması şartıyla serbesttir. Bu amaçla yapılacak temsiller için eser sahibinden önceden izin alınması ve herhangi bir bedel ödenmesi söz konusu değildir; eser sahibinin adının belirtilmesi yeterlidir. Burada yüz yüze eğitimden kasdedilen öğretici ile öğrenenlerin aynı veya aynı sayılabilecek mekanda bulunmalarıdır.⁵ Bu nedenle televizyon veya internet yoluyla yapılan eğitimler bu istisnadan yararlanamaz. Örneğin, televizyonda açık öğretim dersleri adlı bir yapımda veya internet üzerinden eğitim veren bir sistemde; bir müzik eserinin kullanılması 33. maddedeki serbesti dahilinde değildir.

Yüz yüze eğitim maksadıyla doğrudan veya dolaylı olarak eser temsili için Kanun eser türü belirtmemiştir. Kanunun öngördüğü şart yalnızca eserin yayınlanmış olması şartıdır. Eğitim öğretim maksadıyla yapılan temsilin gayesi açısından baktığımız zaman Kanun kâr amacı güdülmemesini şart olarak belirtmiştir. Burada şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır. Acaba belirli bir ücret karşılığı müzik eğitimi veren bir müzik okulunda bir musiki eserin temsili bu madde hükmüne girecek midir? ARSLANLI; eserin, eğitim-öğretim amacıyla temsili ivazlı olabilir demektedir. ATEŞ'e göre; bu gibi durumlarda yapılan temsilin ücrete tabi olup olmamasına bakmak gerekir; katılımcılardan özel bir ücret talep ediliyorsa, eserin serbest temsilinden söz edilemez. ATEŞ ile aynı görüşte olan EREL'e göre ise; temsil serbestisi, eserin şahsi menfaat sağlama amacı -Kanundaki deyimiyle "intifa kastı"- olmaksızın oynan-

⁵ TEKİNALP, age., s. 187

ması, gösterilmesi, çalınması ve okunmasını kapsar. Bu nedenle temsil ücretsiz olmalı veya ücret alınsa bile, masraflar çıktıktan sonraki safi gelir tamamen hayır amaçlarına tahsis edilmelidir. Buna karşılık, temsilde eğitim ve öğretim yahut hayır amaçları söz konusu değilse, temsilin veya yapıldığı yere girişin ücretsiz olması serbestiden yararlanmaya hak kazandırmaz. Özellikle bir restoran veya kafede temsil için doğrudan ücret alınmasa bile vasıtalı bir intifa kastının bulunduğu açıktır ve FSEK 33. maddesindeki temsil serbestisinden faydalanılamaz⁶.

Yine EREL'e göre; kamuya sunulma niyeti bulunmaksızın, nispeten dar bir seyirci veya dinleyici kitlesine verilen temsil esasen serbesttir ve bunun için temsil serbestisi hükmünden yararlanmak gerekmemektedir. Bizim de katıldığımız bu görüşe en güzel örnek, bir musiki derneğinin kendi üyelerine verdiği ücretsiz temsildir⁷.

Eğitim ve öğretim sınırlaması bağlantılı hak sahipleri açısından da FSEK 80. maddede, istisnaların olduğu bölümde ilk fıkrada düzenlenmiş, bu şekilde eğitim ve öğretim amaçlı müzik eserlerinden belli parçaların ve bütününün kullanılması durumlarında bağlantılı hak sahiplerinin izin verme ve yasaklama hakkı ve de bir bedel talep etme olanağı ortadan kaldırılmıştır. Aynı madde, bilimsel araştırma açısından da müzik eserlerinden, bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmadan yararlanılabileceğini kabul etmektedir.

Eğitim ve öğretim amacıyla eserlerden izin almaksızın yararlanma, eser sahipleri açısından yüzyüze eğitim ortamlarında kullanılma şartını gerektirirken, bağlantılı hak sahipleri açısından eğitim ve öğretim amacı ile; yapım, icra, yayın ve filmlerden her türlü eğitim ortamı için yararlanma mümkün olup, illaki yüzyüze eğitim şartı aranmaz.

Ancak bağlantılı hak sahipleri için hem eğitim öğretim gayesi ve hem de bilimsel araştırma amacı ile getirilen izin almadan icra, yapım, yayın ve filmlerin kullanabilme istisnası kazanç amacı güdülmeden icra edilme şartına bağlanmıştır. Bu demektir ki eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma amacıyla müzik ürünleri kullanılırken, bunları kullanan kişi veya kuruluş, bu işten bir kazanç sağlıyorsa o zaman istisna ve sınırlama ortadan kalkar ve kullanıcı izinsiz kullanan durumuna düşer. Bu durumda da kendisine karşı önleme, tazminat ve hapis istemli davalar açılır.

⁶ ARSLANLI, age., s. 123 ve ATEŞ, age., 273

⁷ EREL, age., s. 203

FSEK 34. maddeye göre, eğitim ve öğretim amacına yönelik olmak şartıyla hem eser sahiplerinin yayınlanmış müzik eserlerinden ve hem de bağlantılı hak sahiplerinin yayınlanmış icra, yapım, yayın ve filmlerinden iktibaslar yapmak suretiyle toplama veya seçme eser meydana getirilebilir. İktibas bir eserden alınan parçaların başka bir eserde kullanılmasıdır. Uluslararası sözleşmelere baktığımız zaman, Bern Sözleşmesi'nin Brüksel metninin 10. ve Paris metninin 10. maddesinde iktibas serbestisine değinildiğini görmekteyiz. Kanunun maddesine baktığımız zaman müzik eserleri bakımından iktibas serbestisi şartı olarak sadece müzik eserinin yayınlanmış olmasını aradığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra eserden yapılacak olan iktibas Kanun maddesinde belirtilmiş olan eğitim öğretim amacı dışında yapılamaz. Yayınlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, iktibaslar yapılmak suretiyle **eğitim ve öğretim gavesi dışında** seçme ve toplama eserler vücuda getirilmesi ancak eser sahibinin izniyle mümkündür. Örneğin, bir müzik eserinden yapılacak olan iktibas yalnızca eğitim ve öğretimde kullanılacak materyaller oluşturma amacıyla yapılabilir. Bunun dışında sanatsal veya ticari amaçlarla meydana getirilen seçme ve toplama eserler için söz konusu hüküm uygulanmaz.

FSEK madde 34 iktibası belirli bir oranla sınırlamıştır. Buna göre, iktibas maksadın haklı göstereceği oranda yapılmalıdır. Aksi durumda birçok eser sahibinin eserini toplayıp hiçbir kişisel özellik ve bilgi katmadan toplama bir müzik albümü veya kaydı yapılması hukuka aykırıdır ve yine **bu serbestlik, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar verir veya eserden normal yararlanma ile çelişir şekilde kullanılamaz.**

Bu açıklamaların örneği bir mahkeme kararını dikkatinize sunuyoruz. Müzik eserleri ile ilgili olmamakla beraber kolayca müzik eserlerine de uyarlanabilir.

“Davacı vekili, müvekkilinin 1975 yılından beri ilkokullar için kitaplar bastırıp sattığını, davalılardan N.'nin de daha önce müvekkili ile birlikte çalıştığını, bilahare müvekkilinden ayrılarak diğer davalılarla birlikte “M... Yayıncılık” firmasını kurduklarını, davalı N.'nin 1. Baskıda “Yıldız Okuma,” 2. Baskıda “Mutlu Okuma” isimli kitapları basarak piyasaya sürdüğünü, oysa bu kitapların sayfelerinin tertibi, içeriği, kullanılan cümleler vs. bakımından müvekkilinin yazdığı “1. Sınıflar için Okuma-Anlatım-Dilbilgisi” kitabıyla iltibas yaratır nitelikler taşıdığını ileri sürerek davalıların haksız rekabetinin men'ini, kitapların toplatılmasını, basım ve dağıtımının önlenmesini, 10,800,000 TL maddi,

10,000,000 TL manevi tazminatın tahsiliyle, hüküm özetinin gazeteyle ilanını talep ve dava etmiştir....

Mahkemece; davalıların maksadın haklı göstereceği orandan fazla, alıntılar ve benzetmeler yaparak, dil, üslup, dizayn, örnekleme konularında davacıya ait kitaplardan alıntılar yaptıkları, bu halin haksız rekabet oluşturacağı gerekçeleriyle haksız rekabetin men'ine, davalılar kitabının basım, dağıtım, satışının durdurulmasına, dağıtılanların toplanmasına, 10,800,000 TL maddi, 5,000,000 TL manevi tazminatın tahsiline, hüküm özetinin gazeteyle ilanına hükmedilmiştir⁸.

İktibas, bağlantılı hak sahipleri açısından da FSEK 80. maddede, 34. maddeye atıf yapılarak düzenlenmiş; iktibas halinde bağlantılı hak sahiplerinin izin verme ve yasaklama hakkı ile bir bedel talep etme olanağı ortadan kaldırılmıştır.

ARKAN'a göre; seçme ve toplama eserler FSEK madde 6/7 hükmü gereğince işleme eserdir. FSEK madde 21 uyarınca işleme hakkı münhasıran eser sahibine tanınmıştır, bağlantılı hak sahiplerinin böyle bir hakkı yoktur. Bağlantılı hak sahiplerine işleme hakkının tanınmamasının nedeni; FSEK madde 34'de eser sahibinin işleme hakkına getirilen sınırlamanın kullanılmasının; bağlantılı hak sahibi tarafından tespit, çoğaltma, yayma gibi haklarına dayanarak engellenmesine mani olmak istenmiş olmasıdır. O zaman, bir bestecinin eserlerini öğretmek amacıyla, çeşitli kasetlerden yararlanarak, o bestecinin eserlerinin tümünün yer aldığı bir kaset oluşturmak için icracı sanatçılardan ya da fonogram yapımcılarından izin alınması gerekmemektedir.⁹

Genel menfaat gayesine yönelik olan bir başka sınırlama FSEK 35¹⁰ de düzenlenen genel iktibas sınırlamasıdır.

⁸ Yargıtay 11. H.D, 26.1.1995, E. 1994/7727, K. 1995/461, SULUK/ORHAN, age, s. 763-764.

⁹ ARKAN, age., s. 262

¹⁰ FSEK madde 35: "Bir eserden aşağıdaki hallerde iktibas yapılması caizdir:

1. Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması;
2. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müstakil bir musiki eserine alınması;
3. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve yayımlanmış diğer eserlerin, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderacatını aydınlatmak maksadiyle bir ilim eserine konulması;

FSEK 35. madde de bahsedilen **iktibas**; alenileşmiş bir eserden, bazı cümlelerin, paragrafların, motif ve tınların, hatta ezgilerin veya alenileşmiş güzel sanat eserinin resimlerinin aynen, kaynak gösterilerek, başka bir esere konulmasıdır. “İktibas”; sözlük anlamıyla “*bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça*” veya “*aktarma*”dır. FSEK’da kullanılan anlamıyla ise, “*alenileşmiş bir eserden bazı cümle, paragraf, motif ve tınların, ezgilerin ya da güzel sanat eserlerinin aynen alınması*”dır. İktibas gerekli şartları taşıyorsa serbesttir ve hukuka uygun bir davranıştır. İktibasın şartlarından olan, iktibas yapılacak eserin alenileşmiş olması şartı müzik eserleri için de geçerlidir.

İktibas serbestisi eğitimin, bilimin veya sanatın yararına konulmuştur. Örneğin, bir müzik hocası bir müzisyeni anlatabilmek için onun eserlerini kullanabilir. Ancak bu serbestinin bazı sınırları bulunmaktadır. Kanun ilmi konferans veya derslerde yapılacak iktibasların projeksiyon vb. vasıtalarla gösterme suretiyle olacağını belirtmektedir. Kanaatimizce, bu emredici değildir ve eserin aslının gösterilmesi suretiyle temsil de mümkün sayılmalıdır¹¹. FSEK madde 35’e göre müzik eserleri açısından şu hallerde iktibas yapılması mümkündür:

- a. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir türünden parçalarının bağımsız bir müzik eserine alınması;
- b. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve yayımlanmış diğer eserlerin, amacın haklı göstereceği bir oran dahilinde ve içeriğini aydınlatmak gayesiyle bir bilim eserine konulması.

Kanun maddesinde belirtilmiş olduğu üzere, bir müzik eserinden yapılan iktibas; sadece bağımsızlığını ve özelliğini koruyan diğer bir müzik eserinde kullanılabilir.

Melodilerin iktibas edilip edilemeyeceği Kanun tarafından düzenlenmemiştir. ARSLANLI; melodilerin başka bir müzik eserine alınabileceğini ancak müzik eserlerinin hafif ve ağır olmak üzere ikiye ayrıldığını ve hafif müzik eserinde melodinin eserin asli unsurunu oluşturduğunu bu nedenle iktibaslarına cevaz verilmemesi gerektiğini belirtmiştir.

4. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ilmi konferans veya derslerde, konuyu aydınlatmak için projeksiyon ve buna benzer vasıtalarla gösterilmesi.

İktibasın belli olacak şekilde yapılması lazımdır. İlim eserlerinde, iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bu kısmın alındığı yer belirtilir.”

¹¹ EREL, age., s. 215.

AYİTER; eser niteliği taşıyan melodilerin, iktibas serbestisi içinde başka bir müzik eserine alınmasını mümkün görmekte, ancak Türk Müziği gibi tek sesli müziğin amaçları için geniş bir melodi himayesinin tanınmasının zorunlu olduğunu savunmaktadır. EREL ise, melodinin bir müzik eserine özellik kazandıran en önemli unsur olduğunu ve müzik eserinin çeşitli melodilerden meydana gelmiş olması nedeniyle, bunlardan birinin veya bir kısmının bütünüyle ve serbestçe iktibas olunamayacağını; bu nedenle melodinin bütünüyle değil; fakat tema, motif, pasaj veya fikir olarak iktibas edilebileceğini savunmaktadır. Bizim de katılmış olduğumuz görüşe göre, ATEŞ; Kanunda iktibasa konu edilebilen unsurlar arasında açıkça zikredilmiş olmaması nedeniyle, bir müzik eserine hususiyetini veren melodinin iktibas edilmemesi gerektiğini ama buna karşılık bir melodide bulunan ve bir müzik eserinden iktibasına cevaz verilen tema, motif, pasaj veya fikir gibi melodi öğelerinin iktibasının serbest olması gerektiğini belirtmektedir. EREL'in aksine ATEŞ; folklor müziği gibi topluma mal olmuş veya kime ait olduğu bilinmeyen (anonim) eserler ile, koruma süresi dolmuş olan eserlere ait melodilerden iktibas serbestisi çerçevesinde yararlanılabileceğini ve bunların işlenmesinin dahi caiz olduğunu savunmuştur. EREL ise bu müzik eserlerinin orijinal hallerinin koruma altında olmadığından, iktibas serbestisine tabi olmadıklarını savunmuştur¹².

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 03.04.2006'da verdiği 2005/3742 E. 2006/3428 no'lu kararında, müzik eserlerinde koruma konusunun; işitilen eserler arasındaki sıra ve bağlılık, seslerin melodi, ritim ve harmoni ile belirli karışımları ve aynı zamanda ses ile ifade edilen müzik eserlerinin içeriği olduğunu belirtmiştir. Bu kararda Yargıtay, müzik eserlerinde sahibinin hususiyetinin varlığının, o eserin sıradan bir dinleyici nezdinde yarattığı izlenim ile belirlenebileceğini söylemektedir¹³.

Genel iktibas bağlantılı hak sahipleri açısından da FSEK 80. maddede, 35. maddeye atıf yapılarak düzenlenmiş, bu şekilde bağlantılı hak sahiplerinin izin verme ve yasaklama hakkı ve de bir bedel talep etme olanağı genel iktibas durumlarında ortadan kaldırılmıştır.

Burada özellikle dikkat edilecek konu; iktibasın belli olacak şekilde yapılması gereğidir.

¹² EREL, (2009) age., s. 64 ve 259, ATEŞ, age., 213

¹³ Yargıtay Kararlar Dergisi, 2006, Sayı 10, s. 1617

FSEK 36. madde gereğince, gazete ve dergilerdeki haberlerden bazı sınırlamalarla yararlanılabilir, ama bu konu müzik eserlerini ilgilen-dirmediğinden üzerinde durmuyoruz.

FSEK 37. madde gereğince; haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla, günlük hadiselerle ilgili olarak fikir ve sanat eserlerinden bazı parçaların işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla alınması mümkündür. Bu şekilde alınmış parçaların çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi veya radyo ve televizyon gibi araçlarla yayınlanması serbesttir. Bu serbestlik, hak sahibinin hukuki menfaatlerine zarar verecek şekilde veya eserden normal yararlanmaya aykırı biçimde kullanılamaz. Ayrıca madde de belirtilmemiş olsa dahi bu tür iktibaslarda da eser ve eser sahibinin adının belirtilmesi gerekir.

FSEK madde 37 hükmünün amacı, eser veya eser sahibi ile ilgili olarak kamuya haber ve bilgi verilirken, eserden bazı parçaların verilen haber kapsamında kamuya sunulmasıdır.¹⁴

Haber verme kapsamında ve **bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla**, bir müzik eserinden bazı parçaların kullanılması serbestisi; eserin, haber ve topluma bilgi verme kapsamında kullanılması, ilgili haberin konusu ile eser arasında dolaylı da olsa bir ilişki bulunması, eserin alenileşmiş olması, eserin tümünün değil bazı parçalarının alınması şartlarına bağlıdır. Örneğin, Sezen Aksu'nun yeni çıkan kaseti hakkında televizyonda yayınlanmak üzere yapılan bir haberde, fonda, kasetinde bulunan müzik eserlerinden kısa bölümlerin çalınması bu madde hükmüne göre hukuken mümkündür.

Haber; bağlantılı hak sahipleri açısından da FSEK 80. maddede, istisnaların olduğu bölümde ilk fıkrada düzenlenmiş; bu şekilde haber amaçlı olarak (ancak bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla) müzik eserlerinden bazı parçaların kullanılması durumlarında bağlantılı hak sahiplerinin izin verme ve yasaklama hakkı ile bir bedel talep etme olanağını ortadan kaldırılmıştır.

C. KİŞİSEL KULLANIM İÇİN GETİRİLEN SINIRLANDIRMALAR

Kanun koyucu, fikir ve sanat eserleri üzerinde kişisel kullanım (özel kullanım veya şahsen kullanım) için eser ve bağlantılı hak sahibi-

¹⁴ ATEŞ, age., s. 233

nin çoğaltma hakkına sınırlamalar getirmiştir. Kişisel kullanmayı kanun koyucu FSEK madde 38’de; *“her türlü eser kâr amacı güdülmeksizin, şahsen kullanılmaya mahsus olarak çoğaltılabilir ve işlenebilir”* şeklinde ifade etmiştir. Bu madde, çoğaltma hakkı için eser sahibinden izin alma zorunluluğunun istisnasını oluşturmaktadır. Bağlantılı hak sahipleri açısından bu sınırlama; FSEK madde 80 de istisnalar bölümünde 2 no’lu bendde *“Aşağıda belirtilen hallerde komşu hak sahibi ile film yapımcısının yazılı izni gerekli değildir: ...*

2. Fikir ve sanat eserleri ile radyo-televizyon programlarının yayınlanma ve kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması.

Bu uygulama, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep dışında zarar veremez veya eserden normal yararlanmaya aykırı olmaz” şeklinde düzenlenmiştir.

Yine bu konu, Komşu Haklar Yönetmeliği’nin 24. maddesinin b bendinde;

“Komşu hak sahibinin iznini gerektirmeyen haller şunlardır: ...

b) Özel kullanım için hazırlanmış ve herhangi bir ortak kullanım amacı taşımayan çoğaltmalar ve evde yapılan kayıtlar,” şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Uluslararası sözleşmelere baktığımız zaman Bern Sözleşmesi’nin 9. maddesinin 2. fıkrasında; eser sahibinin menfaatlerine zarar vermek ve eserden yararlanmasına engel olmamak kaydıyla, bazı özel durumlarda eserin çoğaltılmasına verilecek iznin birlik ülkelerinin kendi özel mevzuatlarıyla düzenlenebileceğini görmekteyiz. Yine, Paris Anlaşması madde 15’de de buna benzer bir düzenleme bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Hukuku’nda ise, 19 Kasım 1992 tarihli *“92/100/AET sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının Kiralanması, Ödünç Verilmesi ve Bağlantılı Haklara Dair Konsey Direktifi”* nin 10. maddesinin a bendinde *“özel kullanım”* sebebiyle sınırlamadan bahsetmiş bulunmaktadır. *“2001/29 sayılı Bilgi toplumunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara İlişkin Belirli Konuların Uyumlaştırılmasına Yönelik Direktifi”* n *“İstisnalar ve Sınırlamalar”* başlıklı 5. maddesi de bu konuda bir düzenlemeye sahiptir.

Üçüncü kişilerin, özel menfaatler sebebiyle fikri eserleri çoğaltabilmeleri için bazı şartların varlığı gerekmektedir. Birincisi; **çoğaltmanın şahsen kullanmaya özgü olarak yapılması** gerekmektedir.

Şahsen kullanma deyimini ARSLANLI; şahsi çevre içinde kullanma olarak; şahsen çoğaltmayı da üçüncü kişilerin çoğaltma ile kâr veya yayım amacı gütmemeleri olarak açıklamıştır. EREL; şahsen kullanmayı; eser nüshalarının gerek bizzat çoğaltan tarafından şahsi ihtiyaçları için kullanması gerek aile ve iş çevresi gibi yakın ve şahsi bir muhit içinde kullanmak olarak ifade etmiştir. AYİTER ise; şahsen kullanma deyiminin yorumlanmasında Kanunun amacına bakılmak gerektiğini; bu amacın kişilerin bilim, kültür, sanat, öğretim gibi ideal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olduğunu belirterek; Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku'nun temelinde yatan düşüncenin, eser sahibine eserden yararlanma karşılığında ivaz verilmesi olduğunu; eser sahibinin bu hakkının kişisel yararlar için zedelenmesini en düşük ölçüde tutabilmek için, eser üzerindeki haklara getirilen sınırlamaların dar yorumlanması gerektiğini savunmaktadır¹⁵.

İkinci şart ise; **çoğaltmanın, hak sahibinin haklı menfaatlerine zarar verecek şekilde veya eserden normal yararlanmaya aykırı biçimde olmamasıdır**. Kanaatimizce, çoğaltmanın hangi hallerde eser sahibinin haklı menfaatlerine zarar vereceği, her somut olaya göre belirlenecek bir konudur. Yukarıda doktrindeki şahsi kullanım deyimini ile ilgili çeşitli görüşleri belirtmiştik. Bu açıklamalar ışığı altında, şahsi kullanma için çoğaltmanın yalnızca şahsi çevre için sınırlı sayıda olması gerektiğini belirtmekte fayda vardır. Bu durumda, şahsi kullanım için çoğaltma hukuka uygundur. Bununla beraber şahsi kullanım için eserden yapılan çoğaltma kesinlikle ekonomik çıkar elde etme amacıyla olmamalıdır. Örneğin, bir kişi evde dinlemek üzere gitmiş olduğu bir konserin kaydını yaptıysa ve bunu daha sonra başkalarına kiralıyorsa burada hukuka aykırı bir çoğaltma söz konusudur ve bu çoğaltma eser sahibinin haklarına tecavüz teşkil etmektedir.

Öte yandan belirtmeliyiz ki, FSEK 38. maddedeki “şahsi” kavramı, “genel” ya da “kamuya açık” kavramlarının tersi şeklinde anlaşılmamalı; kamuya kapalı çevre ve toplulukların da FSEK madde 38 sınırlamasından yararlanamayacağı, eser sahibinin çoğaltma hakkının korunması bakımından gereklidir¹⁶. Çünkü kavram geniş yorumlanırsa, özellikle son yıllarda artan eserlerin kopyalanması olanakları karşısında eser sahibinin haklarının ihlali kolaylaşacaktır. Bu sebeple, istisnalar dar

¹⁵ EREL, age., s. 227

¹⁶ İsviçre Federal Mahkemesinin görüşü hakkında bakınız; TEKİNALP, age., s. 179, N. 151.

yorumlanır kuralı gereğince, FSEK madde 38/I'de çoğaltmanın belli sayıda olması gerektiği belirtilmemiş olsa da kişiye iş ve aile çevresi bakımından yakınlık gösteren kişilerin kullanması ile sınırlı sayıda eserin çoğaltılabilmesi kabul edilmelidir¹⁷.

Bu bölümde değinmek istediğimiz bir başka konu ise, peer to peer (p2p) olarak tanınan dosya paylaşım sistemleri ile müzik eserlerine ilişkin müzik ve video dosyalarının çoğaltılmasıdır. p2p yöntemiyle çoğaltma olanağının şahsen kullanma kapsamında eser ve bağlantılı hak sahiplerinden izin almadan yapılıp, yapılamayacağı önemlidir.

Önceleri, şahsen kullanım kapsamında masum bir yararlanma olarak değerlendirilen p2p dosya çoğaltması, bu çoğaltma yönteminin yaygınlaşması sonucu müzik endüstrisinin ürünlerinden ticari gelir elde etmesini engeller düzeye varmıştır. Cd veya kaset gibi fiziki ortamlarda yer alan müzik eserlerinin, bilgisayar ortamlarına kayıt edilebilmesi sonucu ve özellikle dosya sıkıştırma yöntemleriyle müzik ses ve video dosyalarının bir başka bilgisayara ağlar yoluyla transferinin sadece satışları alması sonucu, kişiler fiziki müzik ürünleri almak yerine bunları bilgisayardan dinlemeyi tercih etmişlerdir. Bu tercih; cd ve kaset gibi fiziki ürün satışlarına darbe vurmuştur. Daha sonra mp3 ve mp4 formatındaki müzikleri dinletici ve izletici araçların bir çakmak boyutuna inmesi sonucu ve nihayet cep telefonlarının mp3 ve mp4 dinleme ve izlemeyi içerir teknolojilerle üretilmesi sonucu bilgisayarlarda kayıtlı müzik dosyalarının bu aletlerde kullanılması cd ve kaset gibi fiziki ürün kullanımlarını daha da azaltmıştır. Sorun, mp3 ve mp4 formatındaki müzik eserlerinin izinsiz dosya paylaşım sisteminden bilgisayar ve cep telefonlarına indirilmesi ile eser ve bağlantılı hak sahiplerinin bu kullanımlardan hiçbir bedel alamamasıdır. IFPI¹⁸ tarafından yapılan araştırmalara göre; 2008 yılında sadece 16 farklı ülkede 40 milyarı aşkın izinsiz müzik dosyası paylaşımı gerçekleşmiştir. Avrupa'daki internet kullanıcılarının %16'sı p2p ağlarından dosya paylaşımı yapmaktadır. p2p paylaşım ağları internet trafiğinin %80'ini oluşturmaktadır. Müzik sektörü ise bu kullanımdan sadece %5 oranında yasal gelir elde etmektedir. p2p trafiği ile müzik dosyaları paylaşımının %95'i izinsiz olarak ve bir bedel ödemeden gerçekleşmektedir¹⁹.

¹⁷ EREL, age., s. 227.

¹⁸ The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).

¹⁹ MÜYAP 2008 Faaliyet Raporu.

Sonuç olarak, p2p dosya paylaşım sistemi; tüm uluslararası sözleşmelerdeki ve FSEK'deki şahsi kullanım istisnalarının ana kuralı olan “ bu çoğaltma hak sahibinin meşru menfaatlerine zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz” ilkesine aykırı bir duruma gelmiştir. Bu nedenle müzik üreticileri, suistimal edilen şahsi kullanım istisnası ile çeşitli platformlarda yasal mücadeleye başlamıştır. Bir yanda şahsi kullanımın sınırlı kapsamını aşan şekilde dosya paylaşan ve bilgisayar dosyalarını paylaşımına açık tutan kişi ve kuruluşlara karşı davalar açılmış; diğer yanda dosya paylaşım sistemlerinin çalışmasına olanak sağlayan programları kullanan ya da filtre etmeyen web sitesi işleticilerine ve internet servis sağlayıcılarına davalar açılmıştır.

Bunlardan birinde, müzik yapımcıları Avustralya'da Kazaa adlı bir internet şirketini dava ederek; müzik ve filmler için dosya paylaşımına izin veren p2p sistemini kullanımda tutan Şirketin bireysel kullanıcıların bedel ödemedi müzik eserlerini kullanmasına neden olduğunu ve bu konuda gerekli önlemleri almayarak, kendilerini zarara uğrattığını ileri sürmüşlerdir. Yapılan yargılama sonucu Federal Mahkeme; davalı Kazaa ve ona servisler sağlayan Altnet adlı şirketi, telif hakkı ihlallerini gerekli filtreleme sistemleri koyarak önlemediğinden ve bireysel kullanıcılara izinsiz müzik dosyalarını arama ve paylaşım teknolojisi sağlamasından dolayı sorumlu bularak, davalıları bu ihlalleri önlemeye mahkum etmiştir.²⁰

Danimarka'da Danimarka Video Birliği, DD adlı kuruluşa, yine dosya paylaşım hizmeti ile kullanıcılarına telif hakkı ödemedi videolar içindeki filmlerin izinsiz kullanımına izin vermesinden dolayı dava açmıştır. Mahkeme; bu davada davalıyı izinsiz olarak müzik eserlerini kendi bilgisayarına kopya ederek, dosya paylaşımına izin vermesi sebebiyle yasadışı dosyaları silmeye, davacıların telif kaybı zararlarını ve artan telif hakları ihlallerini denetleme masraflarını karşılamaya mahkum etmiştir.²¹

Dosya paylaşımının hukuka aykırı kullanılmasını önlemek için davalar açmanın yanısıra büyük müzik şirketleri, bir başka mücadele yöntemi olarak web ortamında sanal mağazalar açarak veya açılmasına izin sağlayarak digital müzik eserlerinin yaygın olarak satışını yapmayı da kullanmaktadırlar.

²⁰ www.austlii.edu.au/au/cases/cth/federal_ct/2005/1242.html

²¹ 30.01.2006 BS 99-875/2004 nolu mahkeme kararı.

Verdiğimiz bilgiler ışığında, kanaatimizce, ağ paylaşımlı bilgisayar ortamlarına ya da müzik dinleme ve izleme cihazlarına eser veya bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmadan müzik eserlerinin indirilmesi, kayıt edilmesi ve çoğaltılması FSEK 38. maddesindeki şahsi kullanım kapsamında olamaz²². Bu yöntem, eserden normal yararlanmaya ve eser sahibi ile diğer hak sahiplerinin meşru menfaatlerine aykırıdır. Müzik eserlerinden normal yararlanma, onların para ödeyerek satın alınmasıdır. Para ödenmediği zaman normal dışı yararlanma ortaya çıkar. Ayrıca, bedava kullanım, müzik üreticilerinin meşru menfaatlerine zarar vermektedir. Müzik üreticileri şarkıları dinleyenlerden para kazanarak, müzik üretmeye devam edebilirler, yoksa üreticiler müzik üretmeyi bırakır. Yasal düzenlemeyle ve Doktrindeki diğer görüşlerle şu an için çatışan bu görüşümüzün, önümüzdeki yıllarda yaygınlaşacağını ve müzik eserleri açısından FSEK madde 38'deki sınırlamanın değişeceğini düşünüyoruz.

Öte yandan, bilgisayarında şahsen kullanım için müzik eserlerini çoğaltmış olan ve bu dosyaları bilgisayarlarında depolayan kişiler şahsi çevresini aşar ölçülerde yaygın biçimde bu müzik dosyalarını üçüncü kişilerin paylaşımına ve kullanmasına da kesinlikle sunamazlar. Bu kişiler müzik dosyasını, başkalarının da izinsiz çoğaltma yapmasına olanak sağlayacak şekilde hiçbir önlem almadan erişime açık tutuyorlarsa veya yaygın olarak başkalarına e-mail yoluyla çoğaltarak gönderiyorlarsa o zaman çoğaltma hakkı ihlal edilen eser sahibi ve bağlantılı hak sahiplerinin ticaret yapmasına engel olup, onun gelir kaybetmesine neden oldukları için hem tazminat ödeme yükümlülüğü ile ve hem de hapis cezaları tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Çünkü şahsen kullanma istisnası tanıyan FSEK 38. maddesi, şahsen kullanmaya yönelik bu çoğaltmanın **eser ve bağlantılı hak sahiplerinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremeyeceğini ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamayacağını** düzenlemiştir. Hak sahiplerinin bu eseri satışa sunarak gelir elde etmesi onlar açısından normal meşru bir menfaat elde edilmesidir. Bu yüzden elindeki müzik eserini sınırlı şahsi çevresi dışında başkaları için çoğaltan veya çoğaltılmasına izin veren kişi, eser ve bağlantılı hak sahiplerinin meşru menfaatine engel olmuş olur ve FSEK madde 38'deki şahsi kullanım istisnasından yararlanamazlar.

²² Bkz. Aksi görüş MEMİŞ, age., s. 112 vd.

Hukuk sistemleri özel menfaat sebebiyle sınırlı olarak kişisel çoğaltmaya imkan verirken eser sahibinin hak kaybına uğramasını engellemek için de bir çözüm getirmişlerdir. Bazı hukuk sistemlerinde, her türlü boş ses ve /veya görüntü taşıyıcı materyaller ile bunlar üzerine kayıt yapmaya yarayan cihazlar için belirli bir kesinti yapılmaktadır. Daha sonra bu kesintiler meslek birlikleri arasında paylaştırılmakta ve birlikler de hak sahiplerine bu bedelden dağıtım yapmaktadırlar²³.

Benzer bir uygulama, Türk hukuk sisteminde de mevcuttur. FSEK madde 42/2 gereğince her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD, gibi taşıyıcı materyali, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltımına yarayan her türlü teknik cihazı ticari amaçla üreten ve ithal eden gerçek ve tüzel kişiler; imalat ve ithalat bedeli üzerinden %3'ü geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek oranda bir parayı keserek Kültür Bakanlığı adına ulusal bir bankada açılacak özel bir hesaba yatırmakla yükümlüdürler. Bakanlık bu hesapta toplanan paraları, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi için ve yurt içindeki ve dışındaki kültür mirasının korunmasına ve devam ettirilmesine yönelik faaliyetlerde kullanır. Görüldüğü gibi maalesef, bizdeki uygulamada meslek birliklerine dolayısıyla da eser ve diğer hak sahiplerine kesintiden pay verilmemektedir. Bu nedenle de ARKAN'ın da belirtmiş olduğu üzere, kişisel kullanım sebebiyle eser sahiplerinin uğramaları muhtemel kayıpları biraz da olsa gidermeyi hedeflemiş olan bu sistem bizde amacına ulaşmamıştır. Fakat son zamanlarda duyduğumuz kadarıyla meslek birlikleri ile Kültür Bakanlığı bu konu için görüşmelerde. Umarız bu kesintiler Bakanlık tarafından gerçek hak sahiplerine ödenir.

D. DEVLETE TANINAN YETKİLERLE SINIRLANDIRMA

Devlete tanınan yetkiler arasında; meslek birliklerinin kurulması, eser, icra, fonogram ve yapımların yayınlanmasına ve/veya iletilmesine ilişkin esasların tespiti, fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi, güzel sanat eserlerinin bedellerinden pay verilmesi, Devletin yararlanma yetkisi ve kamuya mal etme hükümleri bulunmaktadır.

FSEK; 46 ve 47'inci maddeleriyle eser üzerinde Devlete bir takım yetkiler tanımaktadır. FSEK madde 46'da koruma süresi dolmuş eserden Devletin yararlanma yetkisi, madde 47'de de koruma süresi dolmamış eserler üzerindeki mali hakların kamuya mal edilmesi yani, fikir ve sanat

²³ ARKAN, age., s. 254

eserlerinin kamulaştırılması ve Ek madde 5’de kültür mirasının korunması ve devam etmesi için fikir ve sanat eserlerinin Kültür Bakanlığı’na derlenmesi düzenlenmiştir²⁴. Devlete tanınan her üç yetkinin kullanılması da bir idari bir işleme; yani, bu konuda yapılacak yönetsel düzenlemelere bağlıdır.

Devletin Yararlanma Yetkisi

FSEK madde 46’ya göre; “çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça men edilmemiş olan ve umumi kütüphane, müze ve benzeri müesseselerde saklı bulunan henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş eserler, mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş olmak şartıyla, bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna ait olur. Bunlardan kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel vesair amaçla yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşların izin alacakları merci ve bunlardan alınacak ücretlerle bu ücretlerin hangi kültürel gayelerde sarfedileceği ve diğer hususlar, ilgili kuruluşların görüşü alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na hazırlanacak tüzükle belirlenir”.

Görüldüğü gibi çoğaltma ve yayma hakkı, eser sahibi tarafından men edilmemiş olan ve umumi kütüphane, müze ve benzeri yerlerde saklı bulunan henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş eserler; mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş olmak şartıyla, bulunduğu kamu kurumu ve kuruluşlarına ait olmaktadır. Böyle bir eser kamu kurumunun eline; eser sahibinin vasiyeti ile, sağlığında tevdi etmiş olması ile veya mirasçıların o eseri ilgili kuruma vermeleriyle ya da başka yollarla geçmiş olabilir. Madde hükmünde belirtilen şartların varlığı ile söz konusu eserin maliki eseri elinde bulunduran kurum olacaktır. Bu nedenle, bu eserlerden herhangi bir amaçla yararlanmak isteyen kişiler, eserin maliki yetkili merciden izin almak ve belirli bir ücret ödemek zorunda olacaklardır. Ancak, bir eser veya icra bir kütüphaneye verilmekle zaten yayımlanmış, alenileşmiş sayıldığından böyle bir durumun gerçekleşmesi çok zordur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının elinde bulunan yayınlanmamış ve alenileşmemiş bu eserlerden bilimsel ve benzeri amaçlarla yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşların izin alacakları mercii ve bunlardan alınacak ücretlerle, bu ücretlerin hangi kültürel gayelerde sarf edileceği ve diğer

²⁴ AYİTER, age., s. 191

hususlar ilgili kuruluşların görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça hazırlanacak tüzükle belirlenir²⁵.

Kamuya Mal Etme

FSEK madde 47 hükmüne göre, ülke kültürü için öneme sahip bir eser üzerindeki mali haklardan faydalanma yetkisi, hak sahiplerine uygun bir bedel ödenerek koruma süresinin dolmasından önce bir kararname ile kamulaştırılabilir. EREL ve ATEŞ'e göre FSEK madde 47 hükmü eksik kanuni ruhsata örnek teşkil etmektedir²⁶.

Kamulaştırma yetkisinin doğması ve kullanılması için;

1) Eser memleket kültürü bakımından önemli görülmelidir. Bu husustaki takdir yetkisi kamulaştırma kararnamesini çıkaracak olan Bakanlar Kurulu'na aittir.

2) Eser Türkiye'de veya Türk vatandaşları tarafından Türkiye dışında yaratılmış olmalıdır. Bir yabancı tarafından Türkiye dışında yaratılmış eser memleket kültürü bakımından önemli görülse bile kamulaştırılmaz²⁷.

3) Eser nüshaları iki yıldan beri tükenmiş olmalı ve hak sahibinin uygun bir süre içinde bunun yenisini yayınlamayacağı tespit edilmelidir. Eserin yayımlanma imkanı bulunduğu sürece, memleket kültürü bakımından önem taşısa bile kamulaştırma yapılamaz²⁸.

4) Eserin mali haklara ilişkin koruma süreleri dolmamış olmalıdır. Mali haklar için belirtilen kanuni süreler dolmuşsa eserin herkes tarafından kullanımı serbest hale geleceğinden, kamulaştırmaya gerek kalmadan bütün üçüncü şahıslar gibi Devlet de eserden serbestçe yararlanabilir.

5) Kamulaştırma yetkisinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun bir kararname çıkarması gerekir. FSEK madde 47/III'e göre, bu kararnamede eser ve sahibinin adı, eser veya mali hak sahiplerine ödenecek kamulaştırma bedeli, mali hakları kullanacak makam veya müessese, kamulaştırma bedelinin düşülmesinden sonra elde edilecek safi kârın hangi kültürel gayelere tahsis edileceği belirtilir.

Yukarıda açıklanan şartlar doğrultusunda, bir müzik eserinin kültürel açıdan önem arz etmesi durumunda Bakanlar Kurulu'nun çıkaracağı bir kararname ile kamulaştırılması mümkündür.

²⁵ Bu konuda bir tüzük çıkarılmıştır. RG, 16.10.1986, S. 19253.

²⁶ EREL, age., 237 vd.

²⁷ ARSLANLI age., s. 158 Naklen EREL, age., 238.

²⁸ ARSLANLI age., s. 157 Naklen EREL, age., s. 238.

Kültür Bakanlığı'nın Derleme Yetkisi

FSEK Ek madde 5'e göre; bu Kanun kapsamında korunan çoğaltılmış fikir ve sanat eserleri kültür mirasının korunması ve devam ettirilmesi amacıyla Kültür Bakanlığı tarafından derlenir.

Fikir ve sanat eserlerini çoğaltan eser veya hak sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, çoğaltılan eser nüshalarından en az beş nüshayı derlenmek üzere, çoğaltımından itibaren bir ay içinde vermeleri zorunludur.

Derlenecek eserler, bu eserleri verecekler ve sorumlulukları, derleme işlemlerini yürütecek birimler, derlenecek nüshaların sayısı, verileceği kuruluşlar, derlemeyle ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Kültür Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

FSEK Ek madde 10 gereğince, derlenmesi gereken eserleri süresi içinde vermeyen kişi Kültür ve Turizm Bakanlığının telif haklarının korunmasıyla ilgili biriminin amiri tarafından bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır.

E. RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARININ GEÇİCİ TESPİTLERİ İÇİN SINIRLANDIRMA

FSEK madde 80'de istisnalar ve sınırlamalar ile ilgili bölümde, “radyo ve televizyon kuruluşlarının kendi olanaklarıyla kendi yayınları için yaptıkları kısa süreli geçici tespitler”in komşu hak sahibi ve film yapımcısından izin alınmadan yapılabilecekleri düzenlenmiştir. Bu sınırlama sadece bağlantılı hak sahiplerinin haklarına ilişkindir.

Radyo televizyon kuruluşları kendi yayınları için yaptıkları kısa süreli geçici tespitler için müzik eserlerinin eser sahiplerinden mutlaka izin almak zorundadırlar.

ARKAN'a göre, burada geçici tespitle kastedilen, radyo ve televizyon kuruluşunun herhangi bir sebeple naklen yayınlamadıkları bir yayını daha sonra yayınlamalarını sağlayan kayıtlardır. Örneğin, yayın izni alınan bir konserin kısa bir süre sonra yayınlanmak üzere radyo televizyon kuruluşu tarafından geçici olarak kayıt edilmesi için icracı sanatçı, fonogram yapımcısından izin alınmaya gerek yoktur. Ancak bu tespitler başka yayın kuruluşlarından yararlanılarak elde edilemez ve başka bir yayın kuruluşuna da verilemez²⁹.

²⁹ ARKAN, age., s. 258

IX. HAKLARIN KORUNMA SÜRELERİ

Fikri mülkiyet haklarını Eşya Hukuku kapsamındaki maddi mülkiyet haklarından ayıran en önemli fark, fikri mülkiyete ilişkin hakların sınırlı süreli bir korumaya sahip olmalarıdır. Buradaki amaç; toplumun genel çıkarlarıyla eser sahibinin bireysel menfaatlerini dengede tutmaktır¹.

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser kamunun malı haline gelir ve eserin mali hakları ister eser veya bağlantılı hak sahibinde bulunsun ister başkalarına devredilmiş olsun sona erer ve artık bu eserler eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri, diğer hak sahipleri ya da mirasçılarından izin alınmadan üçüncü kişiler tarafından serbestçe kullanılabilir.

FSEK madde 26/1² hükmünün yaptığı atıf uyarınca madde 46 ve 47 hükümlerinde öngörülen istisnai haller dışında³, artık herkes eseri serbestçe işlemek, çoğaltmak, yaymak ve temsil etmek imkânına kavuşur. Böylece bir müzik eserinin koruma süresinin dolmasından sonra çoğaltılması ve yayınlanması serbest hale gelmektedir.

Uluslararası sözleşmelere baktığımız zaman hakların koruma süreleri şu şekilde düzenlenmiştir:

Bern Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre; koruma süresi eser sahibinin hayatı boyunca ve ölümünden sonra elli yıl devam eder. Aynı maddenin 7/ 6 bendi; Birlik üyesi ülkelerin, bu sürelerden daha fazla koruma süresi sağlayabileceğini ve 8. bendi; her durumda koruma süresinin, korumanın talep edildiği ülke mevzuatı ile düzenleneceğini, bununla birlikte; bu ülke mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadıkça, koruma süresinin, eserin kaynak ülkesinde belirlenen süreden daha fazla olamayacağını düzenlemektedir.

¹ SULUK/ORHAN, *age.*, s. 521.

² FSEK Madde 26: *Eser sahibine tanınan mali haklar zamanla mukayyettir. 46 ve 47 nci maddelerdeki haller dışında koruma süresinin bitiminden sonra herkes, eser sahibine tanınan mali haklardan faydalanabilir.*

³ Bu istisnai durumlar; FSEK madde 46 “Devletin faydalanma salahiyeti” ve madde 47’de düzenlenen “kamuya maletme” halleridir.

Roma Sözleşmesi'nin 14. maddesine göre;

“Bu Sözleşmeye göre tanınacak koruma süresi:

a) *Fonogramlar ile fonogram üzerine tespit edilmiş icralar için tespit yılının sonundan;*

b) *Fonogram üzerine tespit edilmeyen icralar için icranın yapıldığı yılın sonundan;*

c) *Yayınlar için, yayının yapıldığı yılın sonundan, başlamak üzere yirmi yıllık bir süreden az olamaz”.*

TRIPS Sözleşmesi'nin 12. maddesi; *“bir fotoğraf ya da uygulamalı bir sanat eseri dışındaki bir eserin koruma süresi, gerçek kişinin yaşam süresi dışında bir esas ile hesaplandığında, bu süre, yasal yayımın gerçekleştiği takvim yılının sonundan itibaren 50 yıldan daha az olmayacak ya da yasal yayım, eserin oluşumundan itibaren 50 yıl içinde gerçekleşmişse, yapımın gerçekleştiği takvim yılının sonundan itibaren 50 yıl olarak hesaplanacaktır”* demektedir.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması, 17 maddesinde koruma süresini şu şekilde düzenlemiştir. *“Bu Andlaşma ile icracı sanatçılara tanınan koruma süresi bir icranın fonograma tespit edildiği yılın sonundan başlayarak en az 50 yıldır. Bu Andlaşma ile fonogram yapımcılarına tanınan koruma süresi; fonogramın yayımlandığı yılın sonundan itibaren veya fonogram tespitinden itibaren 50 yıllık bir süre içerisinde böyle bir yayım olmadığı takdirde, tespitin yapıldığı yılın sonundan itibaren hesaplanmak üzere en az 50 yıldır.”*

29 Ekim 1993 tarih ve 93/98/AET sayılı *“Telif Hakları ve Bağlantılı Bazı Hakların Korunma Sürelerini Uyumlaştıran Konsey Direktifi”* nin ilgili maddelerinde koruma süreleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“Madde 2; *Sinematografik veya görsel-işitsel eserlerin koruma süresi, eser sahiplerinden biri olarak belirtilmiş olup olmamalarına bakılmaksızın, aşağıda belirtilen yaşayan kişilerin sonuncusunun ölümünden yetmiş yıl sonra sona erer: Baş yönetmen, senaryonun yazarı, diyalogların yazarı ve sinematografik veya görsel-işitsel eserde kullanmak üzere özel olarak bestelenmiş müziğin bestecisi.*

Madde 3; *1. İcraların hakları icra tarihinden 50 yıl sonra sona erer. Ancak, eğer icranın bir tespiti bu dönem içinde yasal şekilde yayınlanmış veya yasal şekilde kamuya iletilmiş ise, haklar, hangisi daha erken ise, ya böyle bir ilk yayınlama veya böyle bir ilk iletim tarihinden sonraki 50 yılda sona erer.*

2. Fonogram üreticilerinin hakları tespitin yapılmasından 50 yıl sonra sona erer. Ancak, eğer fonogram bu dönem içinde yasal olarak

yayımlanmış veya yasal olarak kamuya iletilmiş ise, haklar, hangisi daha erken ise, ya böyle bir ilk yayınlama veya böyle bir ilk iletim tarihinden sonraki 50 yılda sona erer.

3.Yayın örgütlerinin hakları, uydu veya kablo yolu da dahil olmak üzere, yayın ister tel isterse havadan iletilsin, yayının ilk iletiminden sonraki 50 yılda sona erer.

Madde 7; Eserin menşe ülkesinin Bern Konvansiyonu anlamında üçüncü bir ülke olduğu ve eser sahibinin Topluluk vatandaşı olmadığı durumda, üye devletler tarafından sağlanan koruma süresi, eserin menşe ülkesinde sağlanan koruma süresinin bitişi tarihinde sona erer, ancak 1. maddede konulan süreyi aşamaz.

Madde 9; Bu Direktif üye devletlerin manevi hakları düzenleyen hükümlerini saklı tutar.”

FSEK madde 27/1'e göre; kural olarak fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali haklar, eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl süre ile korunmaktadırlar. 2001 yılındaki 4630 sayılı değişiklik ile birden fazla eser sahibi olması durumu da düzenlenmiş ve bu sürenin hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren işleyeceği belirtilmiştir.

FSEK madde 27/2; sahibinin ölümünden sonra alenileşen⁴ (kamu-nun bilgisine sunulan) eserlerin koruma süresini, eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl olarak belirlemiştir. FSEK madde 27/3 gereğince, sahibi belli olmayan eserlerde koruma süresi, aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. Ancak eser sahibi ölümünden önce ismini açıklarsa, koruma süresi eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl olarak belirlenmiştir⁵. Sahibinin adı belirtilmeden yayımlanan eserlerde aleniyet tarihinden itibaren 70 yıllık koruma süresinin dolmasından sonra eser sahibi adını açıklarsa da koruma süresi canlanmamaktadır⁶.

⁴ Aleniyetin fikri hukuk bakımından sonuç doğurabilmesi için iki unsuru bünyesinde taşıması gerekir: a) Fiili Unsur; eserin fiilen umuma arz edilmesi b) İradi Unsur; sahibinin eseri alenileştirme hususundaki niyeti.

⁵ Eser sahibinin ölümünden sonra isim açıklama yetkisi FSEK md.19 da belirtilen kimselere geçer. Bu kişilerin isim açıklama suretiyle koruma sürelerini eser sahibinin ölümünden itibaren daha 70 yıl süreyle uzatma imkanı doğacaktır. Ancak öğretide, gizli tutulan ismi açıklayarak koruma süresini uzatma yetkisinin 17. maddenin 3. fıkrası gereği, sadece eser sahibine tanınmış olduğu kabul edilmektedir. Bkz. EREL, age., s. 95; SULUK/ORHAN, age., s. 522; AYİTER, age., s. 152-153; ARSLANLI, age., s. 119.

⁶ SULUK/ORHAN, age., s. 522.

Yapılan bu açıklamalar, FSEK’de düzenlenen gerçek kişi eser sahiplerine ilişkin koruma süreleriydi. FSEK 27. maddenin son fıkrasında, tüzel kişilerin eser sahibi olmasına dair bir ibare bulunmaktadır. Bunun sebebi 4110 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce eser sahibinin tüzel kişi de olabileceğinin düşünülmesidir. Ancak 1995 yılında 4110 sayılı değişiklikten sonra FSEK’e göre, tüzel kişiler artık eser sahibi olamazlar. Bu halde de koruma süresinin aleniyetten itibaren başlayacağı belirtilmiştir.

Koruma sürelerinin sınırlı oluşu daha çok mali haklar bakımından öngörülmüş bir durumdur. Aynı sınırlamanın manevi haklar bakımından söz konusu olup olmadığı üzerinde fikir ayrılıkları mevcuttur⁷. 29 Ekim 1993 tarih ve 93/98/AET sayılı “*Telif Hakları ve Bağlantılı Bazı Hakların Korunma Sürelerini Uyumlaştıran Konsey Direktifi*”nin manevi hakları düzenleyen 9. maddesi “*bu direktif üye devletlerin manevi hakları düzenleyen hükümlerini saklı tutar*” demek suretiyle manevi haklar ile ilgili koruma süresini devletlerin insiyatifine bırakmıştır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda manevi hakların süreyle sınırlı olduğu belirtilmemiş olmakla beraber; eser sahibinin ölümünden sonra bu hakları kullanma yetkisinin kimlere intikal edeceği madde 19/2’de sayılmış ve 70 yıllık bir süre getirilmiştir. Gerçekten, burada hangi manevi hakların mirasçılara geçeceği ve geçen hakların ne kadar süre kullanılabileceği özellikle belirtilmiştir. Bu nedenle, kanaatimizce manevi hakların hepsi eser sahibinin ölümüyle son bulmaz.

Ancak, manevi haklara ilişkin getirilen bu düzenlemenin iki istisnası bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, eserin ülkenin kültürü bakımından önemli olduğu hallerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın süreye tabi olmadan sayılan hakları kullanabileceğidir. İkincisi ise, mali bir hakkı devralmış olan külli ve cüzi haleflerin ilgili manevi hakları kullanabilecek olmalarıdır.

Söz konusu bu koruma süreleri hakkında, FSEK’de ölüm veya alenileşme tarihlerinin hangisinden itibaren başlayacağı kesin olarak seçilmemiş olup, bunlardan birinin gerçekleştiği yıldan sonraki yılın ilk günü 70 yıllık sürenin başlayacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

⁷ EREL, age., s. 94

X. MÜZİK ESERLERİNE İLİŞKİN TECAVÜZLER VE HAKLARIN DAVA YOLUYLA KORUNMASI

Fikirsal ve sanatsal ürünler ve hakların saldırılara uğraması durumunda, bu saldırılara karşı hak sahiplerinin korunması, uluslararası sözleşmeler ve ülkelerin iç hukuk kuralları ile güvence altına alınmıştır. Bu bölümde, önce uluslararası sözleşmeler ve AB direktiflerindeki fikirsal ve sanatsal hakların etkin korunması ile ilgili düzenlemeleri daha sonra da bu düzenlemeler doğrultusunda Türk Hukuku'ndaki hukuk kurallarını bilginize sunacağız.

Roma Sözleşmesi'nin 26. maddesine göre; Sözleşmeyi imzalayan her imzacı devlet, kendi Anayasa hükümlerine göre bu Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 23. maddesine göre;

“(1) Âkit taraflar, bu Andlaşmanın uygulanmasını sağlayacak gerekli önlemleri kendi hukuk sistemlerine uygun olarak almayı taahhüt eder.

(2) Âkit taraflar, bu Andlaşma ile öngörülen korumanın herhangi bir şekilde ihlaline karşı ihlalleri önleyecek ve gelecekte olabilecek ihlallerde caydırıcılık sağlayacak özgün tedbirler içeren etkin eylemlere imkân veren uygulama prosedürlerinin kendi kanunlarında bulunmasını sağlayacaklardır”.

TRIPS Anlaşması'nın 41. maddesi gereğince;

“(1) Üyeler, ihlalleri önleyecek acil telafi yöntemleri ve daha başka ihlalleri caydırıcı telafi yöntemleri de dahil olmak üzere, bu Anlaşma kapsamındaki fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesine karşı etkin önlemlerin alınmasına olanak sağlamak için, bu kısımda belirtilen uygulama usullerinin kendi yasalarında da yer almasını sağlayacaklardır. Bu usuller, yasal ticarete engel olmaktan kaçınılacak ve bu usullerin kötüye kullanılmasını önleyici koruma sağlanacak şekilde uygulanacaktır.

(2) Fikri mülkiyet haklarının uygulanması ile ilgili usuller adil ve eşit olacaktır. Bu usuller gereğinden daha karmaşık veya masraflı olmayacak veya makul olmayan zaman sınırlarına veya haksız gecikmelere neden olmayacaktır.

(3) Herhangi bir davanın esasına ilişkin kararlar tercihan yazılı ve gerekçeli olacaktır. Bu kararlar en azından davaya taraf olanlara gereksiz gecikmelere meydan vermeden iletilecektir. Davanın esasına ilişkin kararlar yalnızca, taraflara dinlenme fırsatının verildiği konulara ilişkin delillere dayalı olacaktır.

(4) Davaya taraf olanlara, kesin idari kararların ve bir üye'nin herhangi bir davanın önemi ile ilgili kazai hükümlerine tabi olarak, en azından davanın esasına ilişkin başlangıçtaki adli kararların yasal açıdan incelenmesi fırsatı tanınacaktır. Ancak, ceza davalarında beraat kararlarının incelenmesi için fırsat tanınması zorunlu bir yükümlülük olmayacaktır.

(5) Bu kısmın, fikri mülkiyet haklarının uygulanması için, genelde yasaların uygulanması için tesis (olan) adli sistemden ayrı bir adli sistemin oluşturulması için herhangi bir yükümlülük yaratmadığı gibi, üyelerin genelde kendi yasalarını uygulamasını da etkilemediği anlaşılmaktadır. Bu kısımda yer alan hiçbir husus, fikri mülkiyet haklarının uygulanması ile genelde yasaların uygulanması arasında kaynak dağılımı ile ilgili herhangi bir yükümlülük yaratmamaktadır.”

2001/29 sayılı “Bilgi Toplumunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara İlişkin Belirli Konuların Uyumlaştırılmasına Yönelik Direktifi”nin giriş kısmında; AB üyesi ülkelerde eser ve bağlantılı hak sahiplerinin saldırılara karşı hukuk kuralları ile etkin bir biçimde korunması gerekçeleri aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

“(6) Topluluk seviyesinde bir uyumlaştırma olmaksızın, teknolojik gelişmelere birkaç üye devlet tarafından başlatılmış ulusal seviyedeki yasama faaliyeti ile cevap vermek, yasal uyumsuzluğa ve iç pazarın yeniden bölünmesine neden olacak şekilde, fikri hakları içeren veya fikri haklara dayanan ürünlerin ve hizmetlerin serbest dolaşımında korunmasında ve sınırlandırılmasında önemli farklılıklarla sonuçlanabileceğinden; bu çeşit yasal farklılıkların ve belirsizliklerin etkisi, fikri mülkiyetin sınır ötesi işletilmesini zaten büyük ölçüde artıran bilgi toplumunun gelişmesi nedeniyle, daha da önemli olacağından; bu gelişme daha da artacağı ve artması gerektiğinden; korumada önemli yasal farklılıklar ve belirsizliklerin telif hakları ve bağlantılı hakları kapsayan yeni ürün ve hizmetlerin ölçek ekonomilerini engelleyebileceğinden;

(7) Bu sebeple, telif hakları ve bağlantılı hakların korunması için Topluluk yasal çerçevesi, iç pazarın düzgün işlemesi için gerektiği sürece, uyarlanması ve tamamlanması gerektiğinden; bu amaçla, iç paza-

rın düzgün işlemesine kötü etkisi olmayan farklılıkların kaldırılması ve önlenmesine gerek olmaksızın, bir üye ülkeden diğer bir üye ülkeye önemli bir oranda değişen ya da iç pazarın düzgün işleyişini ve Avrupa bilgi toplumunun düzgün gelişmesinin sağlanmasını engelleyen yasal belirsizliklere neden olan telif hakları ve bağlantılı haklara ilişkin ulusal hükümlerin düzeltilmesi ve teknolojik gelişmelere uyumsuz ulusal karşılıklardan kaçınılması gerektiğinden;...

(11) Titiz ve etkili bir telif hakları ve bağlantılı haklar koruma sisteminin Avrupa kültürel yaratıcılığının ve üreticiliğinin gerekli kaynakları almasını temin eden ve sanatsal yaratıcıların ve icracı-sanatçıların bağımsızlığını ve onurunu koruyan ana yollardan biri olduğundan;...

(22) Kültürün yayılmasını düzenli destekleme amacının, hakların dar korumacılığına kurban edilerek veya korsan ya da taklit eserlerin yasadışı biçimlerinin dağıtılmasına hoşgörü gösterilerek başarılması mümkün olmadığından;...

(35) Belirli istisna ve sınırlamalarda, hak sahiplerinin, korunan eserlerin ve diğer konuların kullanımını karşılayacak ölçüde adil bir tazminat almaları gerektiğinden; işbu adil tazminatın biçimi detayları ve mümkün olan miktarı tayin edilirken, her bir olayın özel koşullarının dikkate alınması gerektiğinden; bu şartlar değerlendirilirken, hak sahibinin söz konusu işlemde ötürü uğrayabileceği zarar, başvurulabilecek önemli bir kriter olduğundan; hak sahiplerine başka bir biçimde, örneğin bir lisans ücretinin bir bölümü olarak, ödeme yapıldığı durumlarda, özel veya müstakil bir ödeme söz konusu olmayacağından; adil tazminatın miktarının, bu Direktifte sözü edilen teknolojik koruma tedbirlerinin ne ölçüde kullanıldığını tamamen kapsamaması gerektiğinden; hak sahibine verilen zararın asgari ölçüde kaldığı belli durumlarda, ödeme yükümlülüğü doğmayabileceğinden;...

(46)Uzlaştırmaya başvurmak, kullanıcıların ve hak sahiplerinin uyuşmazlıkları çözümlemesine faydalı olabildiğinden; Komisyon, Temas Komitesi bünyesinde üye devletlerle işbirliği yaparak, telif hakları ve bağlantılı haklara ilişkin uyuşmazlıkları çözümlemeye yönelik yeni yollar üzerinde düşünmek için bir çalışma üstleneceğinden;

(47) Teknolojik gelişmeler, hak sahiplerinin herhangi bir telif hakkı veya bağlantılı bir hak veya veri tabanlarındaki kendine özgü hak sahiplerince izin verilmeyen eylemleri önlemeye veya kısıtlamaya yönelik tasarlanan teknolojik tedbirlerin yararlanmalarına olanak vereceğinden; ancak, bu tedbirlerin sağlayacağı teknik korumanın aşılmasını kolaylaştırmak veya temin etmek için bazı hukuka aykırı faaliyetlerin

riski olduğundan; iç pazarın işleyişini potansiyel olarak engelleyebilecek kısmi ve bütünlükçü olmayan hukuksal yaklaşımlarından kaçınmak için, etkili teknolojik önlemlerin, araçların, ürünlerin veya hizmetlerin temininin etrafından dolanılmasını önlemeye yönelik uyumlaştırılmış yasal korumanın sağlanması ihtiyaç olduğundan;

(48) Bu hukuksal koruma, telif hakkı, bağlantılı haklar veya veri tabanlarındaki kendine özgü hakkın sahipleri tarafından izin verilmeyen davranışları etkin biçimde kısıtlayan teknolojik önlemlerle ilgili olarak sağlanması gerektiğinden; ancak, bu meyanda, elektronik teçhizatın normal işleyişi veya teknolojik gelişiminin engellenmemesi gerektiğinden; bu hukuksal koruma, söz konusu araç, ürün, parça veya hizmet 6. maddedeki yasağın kapsamına girmediği sürece, teknolojik önlemlere muadil olmak üzere araçlar, ürünler, parçalar veya hizmetler tasarlama yükümlülüğü getirmediğinden; bu hukuksal koruma, oransallık ilkesini gözetmeli ve teknik korumayı aşmak amacı olmadan, önemli bir ticari amacı veya kullanımı olan araçları veya faaliyetleri yasaklamaması gerektiğinden; özellikle bu korumanın şifreleme alanındaki araştırmaları engellememesi gerektiğinden;

(49) Teknolojik önlemlerin hukuksal korunması, teknolojik önlemlerin aşılmasına yönelik araç, ürün veya parçaların özel mülkiyetini yasaklayabilecek olan ulusal kuralların uygulanmasını etkilememesi gerektiğinden;...

(56) Bununla birlikte, elektronik telif hakkı yönetimine eklenen bilgiyi değiştirmek veya kaldırmak için yasadışı faaliyetlerde bulunulabileceği veya başka bir şekilde, bu çeşit bir bilginin izinsiz olarak eserden veya diğer korunan konulardan silinmesi ile halka veya halkın kullanımına açmak, yayınlamak, dağıtmak veya dağıtmak amacıyla ithal etme tehlikesi var olduğundan; iç pazarın işleyişini potansiyel olarak engelleyebilecek parçalı yasal yaklaşımlardan kaçınmak için, bu faaliyetlerin tümüne karşı uyumlaştırılmış yasal koruma sağlamak için bir ihtiyaç var olduğundan;...

(58) Üye devletler, bu Direktifte düzenlenen, hak ve yükümlülüklerin ihlaline karşı etkili yaptırım ve hukuki yolları sağlayacağından; bu yaptırım ve hukuki yolların uygulanmasını garanti altına almak için gerekli tüm önlemleri almaları gerektiğinden; konulan yaptırımların etkili, orantılı ve caydırıcı ve zararı ve/veya ihtiyaten alınacak tedbir önlemlerini takip edilebilmesine ve ihlale konu materyalin müsaderesine imkan verecek şekilde olması gerektiğinden;

(59) Özellikle dijital ortamda, araçların hizmetleri, üçüncü taraflarca ihlal edici faaliyetler için artarak kullanılabildiğinden; çoğu zaman bu çeşit araçlar ihlal faaliyetlerini sona erdirmek için en iyi şekilde yerleştirildiğinden; bu sebeple, diğer her türlü muhtemel yaptırım ve adli yollar saklı kalmak kaydı ile, hak sahipleri, bir ağ içinde korunan eser veya diğer konunun üçüncü bir tarafça ihlal edilmiş halini taşıyan araçlara karşı bir ihtiyati tedbire başvurma imkanına sahip olması gerektiğinden; bu imkanın, araçlar tarafından, 5. madde altında istisna edilen işlemlerde bile, geçerli olması gerektiğinden; bu tür tedbirlerin şartları ve usullerinin üye devletlerin ulusal hukuklarına bırakılması gerektiğinden;”

Aynı Direktifin 8. maddesinde ise fikirsel ve sanatsal haklara saldırılara ilişkin olarak “Yaptırımlar ve Hukuki Yollar” başlığı ile şu düzenlemeler yapılmıştır:

“1. Üye devletler, bu Direktifte düzenlenen haklar ve sorumlulukların ihlali halinde başvurulacak uygun yaptırım ve hukuki yolları sağlarlar ve bu yaptırım ve hukuki yolların uygulanmasını temin etmek amacıyla gereken her türlü önlemi alırlar. Bu şekilde sağlanan yaptırımların etkili, orantılı ve caydırıcı olması sağlanır.

2. Her üye devlet, kendi ülkesinde vuku bulan bir ihlal sebebiyle menfaati etkilenen hak sahibinin zararı için tazminat isteyebilmesini ve/veya bir ihtiyati tedbire ve mümkün olduğunda ihlale konu materyalin, 6. maddenin 2. fıkrasında belirtilen araç, ürün ya da tamamlayıcı kısımların müsadereesine başvurabilmesini garanti eden tüm gerekli tedbirleri alır.

3. Üye devletler, bir telif hakkı veya bağlantılı hakkın, araçların hizmetlerini kullanan üçüncü şahıslarca ihlaline karşı bir ihtiyati tedbire başvurma konumunda olan hak sahiplerinin bu durumunu teminat altına alır”.

Yukarıda belirttiğimiz uluslararası sözleşmeler ve AB direktifleri doğrultusunda, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile (1995, 2001, 2004 ve 2008 değişiklikleri ile), ülkemizde fikri haklar ihlallerinin yoğunluğu da düşünülerek, fikri haklara yönelik saldırıları engelleyecek ve saldırı sonrasında da cezalandıracak düzeyde hukuki ve cezai koruma hükümleri oluşturulmuştur.

Fikirsel ve sanatsal haklara tecavüz eden (saldırgan), özünde başkasının hukuken korunan hakkına müdahale etmektedir. Yapılan bu müdahale, haksız ve hukuka aykırı olduğu ve başkasına ait bir hakkı

ihlal ettiği için, hukuken tecavüz haksız fiil olarak kabul edilmektedir¹. Tecavüzler çoğunlukla bir müzik eseri oluşturulduktan sonra ortaya çıkmaktadır. Eser ortaya çıktıktan ve bir ortama kayıt edilip ürün haline getirildikten sonra ya bu ürüne katkıda bulunan eser ve bağlantılı hak sahipleri birbirlerinin haklarına saldırmaktadırlar, ya da çoğunlukla üçüncü kişiler müzik eserine veya ürüne tecavüz etmektedirler. Eser sahibi ve icracı sanatçı açısından manevi haklara ve işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim gibi mali haklara yönelik tecavüzler, bağlantılı hak sahipleri açısından mali haklara ilişkin olmaktadır. Mali haklar açısından en sık raslanan tecavüzler; yetkisiz çoğaltma (bir ölçüde korsan kopya) veya umuma iletimin yetkisiz yapılmasıdır.

Üçüncü kişilerin haklara saldırması ya da eser ve bağlantılı hak sahiplerinin birbirinin haklarına saldırması en sık rastlananlar olmakla beraber, eser sahiplerinin yaratım aşamasında başka eser sahiplerinin haklarına saldırmaları da söz konusu olabilmektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku'nda tecavüze yakın bir kavram olarak görülen “**intihal**” kavramı bir başka tecavüz yöntemi olup, eser sahiplerinin kendi aralarındaki saldırıların örneğidir. İntihal sözlük anlamı itibarıyla, “*aşırma, başkasına ait bir eseri kendisininmiş gibi gösterme*”²; *kaynak göstermeksizin başkasının eserinden parça alma*”³ olup, hukuk düzeninde bu eylem yasaklanmıştır (FSEK madde 66 vd.)⁴.

Fikri Mülkiyet Hukuku'ndaki bir başka tecavüz yöntemi olan “**iktibas**” ise; sözlük anlamıyla “*bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça*” veya “*aktarma*”dır. FSEK’da kullanılan anlamıyla ise, “*alenilemiş bir eserden bazı cümle, paragraf, motif ve tınların, ezgilerin ya da güzel sanat eserlerinin aynen alınması*”dır. İktibas gerekli şartları taşıyorsa serbesttir ve hukuka uygun bir davranıştır. İktibas serbestisi genel olarak; sanatın, bilimin, eğitimin ve kültürün gelişimi için getirilmiştir. Ancak bu serbestinin bazı sınırları bulunmaktadır. İktibas yapılırken eser sahibinin adını ve eserin adını belirtme gibi kurallara uyulmaması halinde ortaya fikri haklara saldırının başka bir türü çıkmaktadır.

¹ HGK, 17.12.1997, E.1997/11-836, K. 1997/1075

² Ferit DEVELİOĞLU/Neval KILIKÇINI, *Osmanlıca – Türkçe Sözlük, Rafet Zaimler Kitapevi, İstanbul, 1983, Cilt 5, s. 161.*

³ Ejder YILMAZ, *Hukuk Sözlüğü, Doruk Yayınları, Ankara 1976, s. 72.*

⁴ HGK, 29.1.2003, E. 2003/4-47, K.2003/37.

Açıkladığımız her türlü saldırıyı bu bölümde ileride ilgili kısımlarda inceleyeceğiz.

Bu genel açıklamalarımızdan sonra fikirsel ve sanatsal eserlerin hukuk yoluyla korunmasının, bir sanat eserin bütünü ve parçalarında nasıl uygulanacağına değinmekte yarar görüyoruz.

FSEK madde 13/2'ye göre; fikir ve sanat haklarının korunması eserin bütünü üzerindeki haklar kadar, parçaları üzerindeki hakların korunmasını da ifade eder. Ancak *eserin parçası* deyiminden ne anlaşılacak gerektiği incelenmelidir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda “eserin parçaları” deyiimiyle neyin kastedildiği hususunda bir açıklık yoktur. Günlük dilde parça, bir eserin bütününden bağımsız olarak algılayabildiğimiz kısımları ifade eder. Ancak bir eserin bu şekilde belirlenen bütün kısımları fikri hukuk bakımından bağımsız bir koruma konusu teşkil etmez. Eser parçalarının, eserin tümünden ayrı ve başlı başına bir koruma konusu teşkil edebilmesi için şu iki niteliğe sahip olmaları gerekir: ***Parçalar kendi içlerinde duyularımızla algılayabileceğimiz bir bütünlük taşımalı ve eser sahibinin özelliğini yansıtmalıdır.***⁵

Gerek eserin bütünü gerek parçaları eser sahibinin onda beliren özelliğini algılamamıza yetecek bir şekle ve tamlığa sahipse korunur. Bu yüzden henüz eser sahibinin özelliğini yansıtacak ölçüde şekillenmemiş bir fikir veya sanat ürününün korunması söz konusu değildir. Mesela, birkaç söz yahut dağınık bazı nota ve akortlar biçim ve muhteva olarak eser sahibinin özelliğini yansıtacak bir bütünlüğe erişemedikleri sürece korunamazlar.

Bununla beraber, eserin korunabilmesi için mutlaka bitmiş, tamamlanmış ve son halini almış olması da şart değildir. Eserin henüz bir araya getirilmemiş parçaları, müsveddeler, desen ve eskizler, canlandırılan tipler, figürler veya melodiler kendi içlerinde bir bütünlük taşıyorlar ve eser sahibinin özelliğini yansıtıyorlarsa eserin bütününden ayrı olarak başlı başına korunacaklardır. Mesela, bir şiirin beyiti veya kıtası, müzik eserindeki bir melodi bu şartlarda koruma kapsamına girer. Eser sahibi bütün içindeki parçaları ayırarak, onları bağımsız eser ve hak ko-

⁵ Bkz. TOPÇUOĞLU, age., s. 66-67; ÖZTRAK, age., s. 38; ARSLANLI, age., s. 39-42. Naklen EREL, age., s. 104

nusu haline getirebilir⁶. FSEK madde 13/1 hükmündeki "eser sahibine tanınan hak ve yetkiler eserin bütününe ve parçalarına şamildir" ifadesini böyle anlamak gerekir⁷.

Bu konuya örnek bir mahkeme kararını aşağıda sunuyoruz:

"Davacı vekili, müvekkillerinin "Aşık H." adıyla tanınmış halk ozanı S.O.'ın mirasçıları olduğunu, davalı şirketin çıkarmış olduğu "Prangalar-Ağıt" adlı müzik kasetindeki söz ve müzik Aşık M. olarak gösterilen "Hacı Bektaş" isimli şiirde bazı mısraların Aşık H.'den aynen alındığını ileri sürerek, 900,000,000 TL mali haklar tazminatı ile 2,000,000,000 TL manevi haklar tazminatının faiziyle tahsiline, şiirdeki davacı ozana ait dizelerin çıkartılmasına, değişikliklerin gazete ile ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, yetkili mahkemenin müvekkili şirketin adresi olan İstanbul Mahkemeleri olduğunu, dava konusu tazminat alacağının zamanaşımına uğradığını, müvekkili şirketçe çıkarılan kasetteki şiirin Aşık M.'ye ait olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; *davaya konu kasetlerin Ankara'da satılmış olması nedeniyle yetki itirazının reddine, davanın FSEK 68. maddeden kaynaklanması nedeniyle Yargıtay içtihatlarına göre zamanaşımının 10 yıl olduğunun kabulü ile davalının zamanaşımı itirazının reddine* ve FSEK 11. maddedeki karine gereğince, davacıların murisinin eser sahibi olduğu hususunun kesinleştiği, dava konusu olayda davacıların murisine ait şiirin üç dizesinden birisinin davalının eserinde aynen yer aldığı, diğerlerinin mealen iktibas olunduğu gerekçesiyle davacının FSEK 68. madde gereğince istemiş olduğu mali haklar tazminatının kabulü ile 900,000,000 TL'nin ve takdir edilen 1,000,000,000 TL manevi tazminatın yayın tarihi olan 24.12.1998 tarihinden itibaren faiziyle davalıdan alınmasına, **kasette murisin isminin yazılmasına** ve hüküm özetinin gazetede ilanına karar verilmiştir⁸."

Bir fikir ve sanat eserinde bu şekilde korunan parça veya kısımlar bulunabileceği gibi, korunmayan bazı unsurlar da mevcut olabilir. Mesela üslup, stil, tarz veya güzel sanat eserlerinde kullanılan teknikler koruma konusu teşkil etmezler⁹. Aynı şekilde musikide kullanılan farklı bir

⁶ AYİTER; age., s. 106. Naklen EREL, age., s. 104

⁷ EREL, age., s. 104

⁸ Yargıtay 11. H.D, 26.02.2004, E. 2003/7070, K. 2004/1799. SULUK/ORHAN, age., 1011-1012.

⁹ AYİTER, age., s. 106. Naklen EREL, age., s. 104

ses tekniği yahut resimde kullanılan orijinal bir renk tonu veya bir şiir-deki değişik bir vezin ve kafiye düzeni eserin parçası sayılmaz ve korunmazlar. Bilim ve edebiyat eserlerinde orijinal fakat soyut bir kavram, fikir veya ide de eserin korunan parçaları değildir. Esasen yazar ürettiği fikir ve ideleri kamuya sunarken, bunların herkes tarafından benimsenerek yayılmasını ister ve eserini bu amaçla meydana getirir; bunların başkalarının benimsenip kullanılmasını istemeyen bir yazar eserini yayımlamaz¹⁰. Bu yüzden tarih boyunca fikir ve ideler, teoriler, siyasi, ekonomik veya toplumsal görüşler her zaman serbest tartışmalara konu olmuşlar ve koruma görmemişlerdir. Zira bunlardan patent ve endüstriyel tasarımlarda olduğu gibi maddi bir istifade sağlamak da mümkün değildir¹¹.

Fikir ve idelerin, siyasi, iktisadi ve toplumsal görüş ve teorilerin serbest oluşu karşısında, fikri hukuktaki korumanın eserin muhtevası değil, şeklini yani bunları ifade etmekte kullanılan vasıtaları kapsadığı ve eser sahibinin özelliğinin bu ifade vasıtalarında belirmesi gerektiği yolunda görüşler ileri sürülmüştür¹². Ancak muhteva ve şeklin birbirinden kesin olarak ayrılmasının imkansızlığı ve bazı eserlerde doğrudan doğruya muhtevanın korunması gerektiği anlaşıldığından, bu görüşler tenkide uğramıştır. Bununla beraber, bilimsel eserlerle edebi eserler arasında bu bakımdan bir ayırım yapmak gerekir¹³. Edebi eserlerde eserin gerek parçaları, gerek tümü, şekil veya muhteva bakımından eser sahibinin yaratıcı gücünün özelliğini taşıyor olabilir. O takdirde bu özellik ister eserin tümünde veya parçalarında, ister muhtevasında veya şeklinde belirsinsin, bunun korunması asıldır. Halbuki, bilimsel eserlerde insanlığın ortak kültürüne mal olmuş bilimsel verilerin, teori ve görüşlerin başka tür işlenmesi, uygulanması, tertip veya tasnifi söz konusudur. Bunlarda korumanın konusunu, özellik gösteren işleme, uygulama, tertip veya tasnif teşkil edecektir. Yoksa, eserde yer alan bilimsel verilerin, teori ve görüşlerin orijinal olsalar bile soyut halleriyle başlı başına korunmaları söz konusu değildir¹⁴.

Sonuç olarak, müzik eseri veya icra, fonogram ve film gibi ürün hali üzerindeki eser ve bağlantılı hak sahiplerinin mali ve manevi hakla-

¹⁰ ARSLANLI, age., s. 41. Naklen EREL, age., s. 104

¹¹ ARSLANLI, age., s. 41. Naklen EREL, age., s. 104

¹² ARSLANLI, age., s. 40-41. Naklen EREL, age., s. 104

¹³ TOPÇUOĞLU, age., s. 67-68. Naklen EREL, age., s. 104

¹⁴ EREL, age., s. 104

rının ihlalleri halinde bir tecavüzün (saldırının) varlığı söz konusudur ve buna ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda sayılan davalara (hukuk ve ceza davalarına) müracaat edilerek hukuki korunmadan yararlanılır.

Söz konusu bu tecavüz ve yasal korunma yöntemlerinden bahsederken; bu çalışmada konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve somut örneklerle güçlenmesi için, Yargıtay kararları kullanılacaktır.

A. HUKUK DAVALARI

Kanun koyucu eser sahiplerini korumak için değişik dava ve talep hakları tanımıştır. Bu anlamda hak sahibine tanınan hukuk davaları şu şekildedir:

1. Eser Sahibinin Tespiti Davası

FSEK madde 15'e göre; eser sahibini belirlemek için açılan bir davadır. ARKAN, bu davanın bir tespit davası olduğunu, TEKİNALP ise, bu davanın bir eda davası olduğunu savunmuştur¹⁵. Bize göre; bu dava eda davası niteliğine sahiptir. Çünkü, dava sonunda sadece eser sahibi ortaya konmamakta aynı zamanda eserin sahipliği davayı kazanana verilmektedir. Bu dava iki halde açılmaktadır:

a) Eserin kimin tarafından vücuda getirildiğinin çekişmeli olduğu durumlarda veya

b) Herhangi birinin eserin sahibi olduğunu iddia ettiği hallerde.

Açılan davayı sonuçlandırabilmek için öncelikle mevcut eserin gerçekte kime ait olduğunun ispatlanması gerekmektedir.

Aşağıdaki kararda bu davaya örnek bulunmaktadır.

“Davacı vekili, söz ve müziği davacıya ait olan “Adana'ya Gel (Davet)” isimli türkünün, davalı plak şirketi tarafından davalı İ.İ ve H.K.'a (..... Kardeşler) kasete okutulularak piyasaya sürüldüğünü, eserin başka bir şahsa mal edildiğini belirtip, yapımcı firmadan 10,000,000 TL maddi, 3,000,000 TL manevi, davalılar İ.İ. ile H.K.'dan 1,000,000 TL maddi, 2,000,000 TL manevi tazminatın yasal faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, türkünün davacıya ait olmadığını, eserin söz ve müziğinin S.S.'ya ait olup telif ücretinin bu şahsa ödendiğini, ... davanın reddini istemiştir.

¹⁵ ARKAN, age., s. 272 vd.

Mahkemece, toplanan delillere, dosya kapsamı ve bilirkişi raporuna göre, **dava konusu eseri 26.7.1968 yılında davacının notere tasdik ve tescil ettirdiğini, anonim olmadığını, davacıdan izin alınmadan ve sözleri değiştirilerek kaset yapıldığı gerekçesiyle, davalılar İ.İ. ve H.K.'nın maddi tazminat nedeniyle sorumluluğu 1,000,000 TL ile sınırlı kalmak kaydıyla, 2,142,000 TL maddi ve 2,000,000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren %30 yasal faiziyle davalılardan müteselsilen tahsiline, fazla istemin reddine karar verilmiştir.**

Kararı davalı B.Plak ve Kasetçilik Yapım ve Pazarlama ve M.Ç. vekili temyiz etmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve temyizde ileri sürülen İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1988/694 Esas sayılı dosyası içeriğine göre, **S.S.'nin aynı türkü nedeniyle davacıya tazminat ödemesine karar verildiği ve eserin S.S.'ye ait olmayıp, davacıya ait olduğu tespit edilmiş bulunmasına göre** kararın onanması gerekmiştir¹⁶.

Doktrinde¹⁷ genel kabul edilen görüşe göre; eser sahibinin tespiti davası, intihali (eser hırsızlığını) kapsamamaktadır. İntihalde; müzik eseri zaten sahipli olup, sahipliği çekişmesiz bulunan aleniyete kavuşmuş veya yayımlanmamış bir eserden, eser sahibinin adı zikredilmeden veya **uygun görülmeyecek ölçüde** aktarma, yani çalma vardır. İntihal yapan kimse, başkasının eserini kendi eseri gibi göstermektedir¹⁸. İntihalin varlığı halinde tecavüzün ref'i, men'i ve tazminat davaları açılır.

Tespit davası somut olayın özelliğine göre; hasımlı veya hasımsız açılabilir. Hasımlı ise, davalı duruma göre belirlenmektedir. Davacı ise, eser sahipliği iddiasında bulunan kimsedir. FSEK madde 19'daki kişiler (eser sahibinin ölmeden önce manevi hakları kullanma konusunda yetkilendirdiği kişiler, böyle bir yetkilendirme yoksa vasiyeti tenfiz memuru, vasiyeti tenfiz memuru tayin edilmemişse sırasıyla; sağ kalan eş ve çocuklar, mansup mirasçılar, ana-baba, kardeşler, mali hak sahipleri) eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl içinde bu davayı açabilmektedirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı da FSEK madde 19'daki şartların varlığı halinde bu davayı açabilmektedir.

¹⁶ Yargıtay 11. H.D; 20.2.1995, E. 1995/55, K. 1995/1467, SULUK/ORHAN, age, s. 177.

¹⁷ EREL, age., s. 121

¹⁸ TEKİNALP, age., s. 292.

Bu dava hakkından önceden feragat mümkün değildir. Bu davada zamanaşımı cereyan etmemektedir. Çünkü, tecavüzün devamı süresince; tespit, durdurma ve önleme davaları açılabilir. Yargıtay¹⁹ koruma süresi dolan eserler bakımından da eser sahipliğinin tespiti davasının açılabilmesine haklı olarak karar vermiştir. Zira eser sahibi olarak tanıtılma hakkı manevi bir hak niteliğindedir.

2. Tecavüzün Ref'i Davası

FSEK madde 66 ve 68'e göre; ref davası, bir tecavüz gerçekleşmiş ve sonuç doğurmuşsa açılmaktadır.

FSEK madde 66'ya göre; *“Manevi ve mali hakları tecavüze uğrıyan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini dava edebilir.*

Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir.

Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir.

Mahkeme, eser sahibinin manevi ve mali haklarını, tecavüzün şümulünü, kusurun olup olmadığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün ref'i halinde tecavüz edenin düçar olması muhtemel zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikine karar verir.

Eser sahibi, ikamet ettiği yerde de tecavüzün ref'i ve men davası açabilir”.

FSEK madde 80 hükmüne göre, bağlantılı hak sahipleri de aynen eser sahibi gibi bağlantılı haklarının tecavüze uğraması halinde bu davayı açabilmektedir.

Tecavüzün ref'i davasının açılabilmesi için, mali ya da manevi haklara ilişkin bir tecavüzün yani objektif olarak hukuka aykırı bir faaliyetin varlığı şarttır. Hak sahibinin haklarına yönelik hukuka aykırı faaliyet gerçekleşmiş ve hukuka aykırı bir sonuç doğmuş veya hukuka aykırı faaliyet devam ettiği için sonuçlar da doğmaya devam etmiş veya hukuka aykırı faaliyet gerçekleşmiş ancak hukuka aykırı sonuç etkilerini sürdürmeye devam etmiş olabilir; işte, söz konusu “devam eden” sonuçları gidermek veya doğacak sonuçları önlemek amacıyla hakkı ihlal

¹⁹ 11.HD. 13.3.1995, E. 1994/6106, K. 1995/1880.

edilen kişilere, bu dava hakkı tanınmıştır²⁰. Örneğin, eser sahibi (A)'nın yurt dışında çoğaltılan eserinin onun izni olmadan Türkiye'ye getirilip piyasaya sunulması, satılması; Şair (B)'nin bir şiir kitabının korsan bas-kısının yapılması, (K) tarafından bir kasete (B)'den izin alınmaksızın kaydedilmesi²¹.

Doktrinde bazı görüşlere göre²²; ref davası yalnızca tecavüz başla-mış ve devam ediyorsa açılabilir; bu görüşe göre tecavüz sona er-mişse bu davanın açılması mümkün değildir; böyle bir durumda ancak tazminat davası açılabilir. Tecavüzün giderilmesi davası ile; ma-nevi ve mali haklara devam eden tecavüzün ortadan kaldırılması, yani, tecavüz ile ortaya çıkan hukuka aykırılığın sonucunun veya sonuçlarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Halbuki, FSEK'te düzenlenen ref davası daha geniş olup, sadece tecavüzün giderilmesini değil aynı zamanda tekrarlanmasını önleyecek önlemlerin alınması ve hatta tecavüze uğra-yan kişiye ödenen bir çeşit para cezası taleplerini de kapsar.

Yargıtay, aşağıdaki kararlarda görüleceği üzere tecavüzün ref'i ka-rarları ile ilgili uygulamasını kesinleştirmiştir.

“Davacı vekili, davalıya ait radyoda müvekkilinin üyelerine ait müzik eserlerinin izinsiz ve mali hakları ödenmeden yayınlandığını, davalının sözleşme yapmaya yanaşmadığını, davalının eylemlerinin mali haklara tecavüz oluşturduğunun tespiti ile müvekkilinin üyesi tüm eser sahipleri yönünden tecavüzün önlenmesine karar verilmesini ta-lep ve dava etmiştir.

Davalı vekili müvekkilinin izinsiz ve mali hakları ödenmeden yayın yapmadığını, davacının fahiş bedel istemesi nedeniyle söz-leşme yapılamadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece bozma kararına uyularak yapılan yargılama so-nucunda, davacının üç üyesinin eserlerinin izinsiz yayınlandığı-nın belirlendiği sonucuna varılarak, davanın sadece bunlar yö-nünden kabulüne diğer istemlerin reddine karar verilmiştir²³.”

²⁰ AYİTER, age., s. 254; TEKİNALP, age., s. 267, N. 27. Kişilik haklarının ihlallerine ilişkin olarak, tecavüzün durdurulması davası hakkında bakınız; ARPACI, age., s. 151; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY, age., s. 147 vd.

²¹ Y.11. H.D. 15.06.2000T., 2000/3342 E., 2000/5524 K. Sayılı kararı (Yayımlanmamış-tır). Naklen ARIDEMİR, age., s. 183.

²² ARKAN, age., s. 275

²³ Yargıtay 11. H.D. 2004/11814 E. 2004/10871 K.

Mahkemeler ve Yargıtay, hak sahiplerinin izin verme hakkına aykırı biçimde televizyonlarda izinsiz müzik yayını yapılması üzerine duraksamadan bu hukuka aykırı yayınları durdurmaktadır.

“Davacı vekili, müvekkilinin FSEK’nun 4. maddesine göre kurulmuş bir meslek birliği olduğunu, üyesi olan fonogram yapımcıların sahip oldukları hakları müvekkiline devrettiklerini, davalı yayın kuruluşunun müvekkilinin üyeleri tarafından üretilmiş müzik kasetlerini, disklerini ve televizyon kliplerini izin almadan ve bedelini ödmeden TV kanalında yayınladığını, bu tecavüzlerin uzun süredir devam ettiğini, ihtara rağmen vazgeçilmediğini, noterce tespit yapıldığını ileri sürerek, yayımlanmış ve tecavüzün tehlikesine maruz kalan tüm müzik yapıtları açısından FSEK’nun 69. maddesi uyarınca, (müzik yapıtlarının) davalı TV kuruluşunun yayınlarında kullanılmasının men’ine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekil, ortada esaslı bir zarar veya ani bir tehlike bulunmaması nedeniyle tedbir kararı verilemeyeceğini, 4116 s. Kanun’un 12. maddesine göre, radyo ve TV kuruluşlarının ticaret mevkiine konulmuş olan ve her yerde satılan, kamuya arz edilmiş eserin yayınlanabilmesi için fonogram yapımcısından izin alınmak zorunda bırakamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, **davalının, TV kanalında, davacı üyesi fonogram yapımcıların eserlerini izinsiz olarak kullandığı, yayınladığı tespit edilen eserler dışında kalan eserler konusunda yayına ilişkin bir ispat bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile yayımlandığı tespit edilen eserler yönünden davalının eyleminin davacının mali haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine, bu eserlerin icra edilmesinin önlenmesine karar verilmiştir.²⁴ⁿ**

Yargıtay, özellikle hukuka aykırılık karinesine ilişkin, yukarıda sınırlı eserler için verilen yayın durdurma kararlarını değiştirerek, izinsiz yayınlanan eserlerin varlığı halinde sadece o eserler için değil; genel olarak davacının eser ve yapıtlarının kullanılarak yayın yapılmasını durdurma yönünde görüş değiştirmiş ve doğru yapmıştır.

“Davacı vekili, müvekkilinin üyesi olan eser sahiplerine ait eserlerin, davalıya ait yayın kuruluşunda izinsiz olarak yayımlandığını ileri sürerek, tüm eserler yönünden **tecavüzlerinin kaldırılmasına** ve olası **tecavüzlerin önlenmesine** karar verilmesini istemiştir.

Davalı yanıt vermemiştir.

Mahkemece, davalının izinsiz yayınladığı 13 eser açısından **tecavüzün önlenmesine karar verilmiş, Dairemizce karar onanmıştır.**

²⁴ Yargıtay 11. H.D., 03.05.2004, E.2003/11026, K. 2004/4809

Davacı vekili, karar düzeltme istemiştir...

FSEK'nun 69/1nci maddesindeki tecavüz tehlikesine maruf kalınması halinde eser sahibine tanınan muhtemel tecavüzün önlenmesini dava etme yetkisi; aynı Kanunun 80/1-1-B/1 hükmü uyarınca mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme izin verme hususunda münhasıran yetkili hale gelen eser sahibinin haklarına komşu hak sahibi davacı fonogram yapımcıları meslek birliğine geçmiştir.

FSEK'nun 76/son maddesinin açık hükmü karşısında, davacı meslek birliğinin, eser işletme belgesine sahip fonogram yapımcılarından alınmış yetki belgeleri, **bu eserlerden bazılarının yayınlandığının tespit edildiği noter tespit belgeleri gibi**, davacı tarafından iddianın doğruluğu hakkında kuvvetli kanaat oluşturacak delillerin ibrazından sonra, Mahkemenin verdiği sürede Kanunda öngörülen izin ve yetkilerin alındığına dair liste ve belgeleri sunamayan davalının, **yayınlanan eserler, fonogram yapımcılarına ait tüm fonogramlarındaki eserlerinin haksız kullanımı konusunda davalı aleyhine karine teşkil etmiştir.**

O halde, **eseri yayınlanan birlik üyesi müzik yapımcılarından alınan yetki belgelerinin düzenlenme tarihi itibarıyla bu belgelerin kapsamına giren müzik eseri işletme belgesi, fonogramların ve bunların içeriklerinin neler olduğunun tayin olunacak uzman bilirkişi ya da bilirkişilere tespitinden sonra oluşacak sonuca göre; mevcut ve muhtemel tecavüzün önlenmesine karar verilmesi gerekirken, sadece yayınlandığı belirlenen fonogramlar bakımından davanın kabulü isabetsiz olmuştur.**

Mahkemece, yukarıda açıklandığı biçimde inceleme yapılarak sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeyle hüküm tesisi yerinde görülmemiş olmakla, davacı vekilinin karar düzeltme itirazının kabulü ile Dairemiz 2003/11026 2004/4809 sayılı onama kararını kaldırarak kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.²⁵

Şifreli digital cihazlarla yeniden yayın yapan yayıncı kuruluşlar; yayınlarında müzik eserlerini hak sahibinden izin almadan yayınlıyorsa, mahkemeler yayının önlenmesi yönünde kararları kolayca vermektedirler. 2007 tarihli bir karar:

"Davacı vekili, davalı yayın kuruluşunun ... logosu ile, üyelerine dekoderli digital yayın yapan televizyon ve radyo yayını yaptığını, bu televizyon ve radyo kanallarından müvekkili üyelerinin (müzik yapıtlarının) izni alınmadan ve ücreti ödenmeden yayınlandığının tespit edildiğini, bu durumun müvekkilinin FSEK'ten doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğini, müvekkili fonogram yapımcılarına ait tüm müzik kasetle-

²⁵ Yargıtay 11. H.D., 23.12.2004, E. 2004/11439, K. 2004/12776.

rinin, kompakt disklerin ve müzik kliplerinin reklamlarda, sinematografik yapımlarda ve jeneriklerde kullanılmasının önlenmesini ve hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin doğrudan veya dolaylı yayın yapan bir kuruluş olmadığını, yayıncı kuruluşların yayınlarını izleyicilere ileten bir sayısal uydu platformu olduğunu, yapılan yayınlara bir müdahalesinin olmadığını, davacının taleplerini doğrudan yayıncı kuruluşlara yönlendirmesi gerektiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur...

Davalı şirketin sahibi olduğu bu tür yayınlarla ilgili sorumluluğunun yayıncı kuruluş sıfatıyla söz konusu olacağı tartışma götürmez. Zira 80. maddeye göre; fonogram yapımcıları tespitlerinin işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir.

Programcı kuruluşların yayınlarında izinsiz müzik kullanmaları nedeniyle davalının sorumluluğuna gelince; ...

Lisans Yönetmeliği'ne göre, davalı platform kuruluşu yayınlara müdahale hakkı bulunmamakla beraber, Yönetmeliğin 6/b maddesine göre, **“programcı kuruluşlar ve uydu kuruluşlar ve uydu platform işletmeleri yurt içinde ve yurt dışında yapacakları yayınlarda Kanunda, Üst Kurulca çıkan yönetmeliklerde ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalarda belirtilen ilke ve esaslara uyumla yükümlüdür”.** ...

Taraflar arasındaki sözleşme ile davalı, ücret karşılığı yayıncı kuruluşların yayınlarını iletmeye yükümlülüğü altına girerken, akidinin (karşı tarafının) bu yayınlarla 3. kişilere zarar vermesini önleyici tedbirleri de almakla yükümlüdür.

... Borçlar Kanunu kapsamında sözleşme hükümleri gereğince (davalı), tecavüz oluşturan yayınları teknik olarak önleme imkanına sahip olduğundan tecavüzün önlenmesi davasında taraf ehliyeti vardır. Davalının “yayına müdahale edememe” yönündeki itirazı ise ancak tazminat yükümlülüğü yönünden tartışılabilir. Bu dava sadece tecavüzün önlenmesine yönelik olduğundan bunun tartışmasına gerek görülmemiştir.

Böylece, bazı yayınların davalı tarafından doğrudan yayınlanması ve diğer yayın kuruluşlarına ait yayınların da fikri hakları ihlal edici içerikte olmaması için (davalının) yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle davalıya diğer yayın kuruluşlarından bağımsız olarak ... dava yönünden husumet düştüğü kabul edilmiştir.

Davacı meslek birliğinin temsil ettiği ve yapımcıları gerekçe de belirtilen müzik yapımlarının izin alınmadan (davalıya ait) ... logosu ile üyelerine dekoderle dijital yayın yapan televizyon ve radyo yayın kanalında yayınlanmasının önlenmesine, hüküm

özetinin Türkiye genelinde yayın yapan yüksek trajlı bir gazetede bir kez ilanına, ... karar verilip tefhim kılındı²⁶.”

Manevi haklara tecavüz edilmesi üzerine açılacak tecavüzün ref'i davaları ise FSEK 67. maddesinde şöyle düzenlenmiştir:

“Henüz alenileşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı olarak umuma arz edildiği takdirde tecavüzün ref'i davası, ancak umuma arz keyfiyetinin çoğaltılmış nüshaların yayımlanması suretiyle vaki olması halinde açılabilir. Aynı hüküm, esere, sahibinin arzusuna aykırı olarak adının konulduğu hallerde de caridir.

Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa meydan verecek mahiyette olup ta eser sahibi 15 inci maddede zikredilen tespit davasından başka tecavüzün ref'ini talep etmişse, tecavüz eden gerek aslına, gerek tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalar üzerine eser sahibinin adını derç etmeye mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, hükmün en fazla 3 gazetede ilanı talep edilebilir.

FSEK 32 (söz ve nutukların Kanun'daki istisnalar dışında çoğaltımı), 33 (yayınlanmış eserlerin eğitim ve öğretim gayesi ile kullanılması), 34 (eğitim ve öğretim amacıyla seçme ve toplama eserler oluşturulması), 35 (bilimsel eserlerde ve konferanslarda iktibas yapılması), 36 (basında yer alan eserlerden haber amaçlı alıntılar yapılması), 39 (kalktı) ve 40 ıncı (güzel sanat eserlerinin umuma açık yerlerde temsili, umuma açık yerlerdeki eserlerden çoğaltma yapılarak yararlanılması, açık artırma konusu eserlerin kataloga basılması) maddelerde sayılan hallerde yanlış veya kifayetsiz kaynak tasrih edilmiş veyahut hiç kaynak gösterilmemişse ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Eser haksız olarak değiştirilmiş ise hak sahibi aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

1. Eser sahibi, eserin değiştirilmiş şekilde çoğaltılmasının, yayım ve temsilinin, radyo ile yayımının menedilmesini ve tecavüz edenin, tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki değişiklikleri düzeltmesini veya bunların eski haline getirilmesini talep edebilir. Değişiklik, eserin, gazete, dergi veya radyo ile yayımı sırasında yapılmışsa eser sahibi, masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş şekilde yayımlamış olan bütün gazete, dergi ve radyo idarelerinden değişikliğin ilan yolu ile düzeltilmesini talep edebilir;

²⁶ T.C. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 25.12.2007 T., E. 2002/229, K. 2007/355

2. Güzel sanat eserlerinde eser sahibi asıldaki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığını veya eserdeki adının kaldırılmasını yahut değiştirilmesini talep edebilir. Eski halin iadesi mümkün ise değişikliğin izalesi ammenin veya malikin menfaatlerini esaslı surette haleldar etmiyorsa eser sahibi eseri eski hale getirebilir.”²⁷

Eser sahibinin hem mali hem de manevi haklarının ihlali iddiası ile açtığı bir mahkeme kararı örneğini verelim:

“Davacı vekili, söz ve müziği müvekkiline ait olan “Unutama Beni” adlı eseri eşi E.’a ithaf edip ona plak doldurttuğunu, davalı K. Plakçılık şirketinin izinsiz olarak “Seni Sevmek” adlı kasette eseri izinsiz olarak S.C.’a okutup kasete aldığını, **S.C.’ın parçasının bazı sözlerini değiştirerek söylediğini**, bu nedenle davacının maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek FSEK’e aykırılıktan dolayı tecavüzün önlenmesini, 100,000,000 TL maddi ve 50,000,000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir. ...

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya içerisindeki yazılara göre, **davalıların; ne davacıdan ne de üyesi oldukları Mesam’dan (meslek birliğinden) izin belgesi olmadan ‘Unutama Beni’ adlı şarkıyı kasete aldıkları, davacının Mesam’a haklarını koruma konusunda yetki vermesinin davacının haklarını aramasına ve dava açmasına engel olamayacağı, davalıların izinsiz olarak şarkıyı kasete almasıyla davacının maddi ve manevi tazminat hakkının doğduğu**, telif ücretinin 20,000,000 TL olacağı, bunun en çok %50 fazlasının tazminat olarak istenebileceği **gerekçesiyle, haksız rekabetin tespiti ile davalı şirketin satışa sunduğu “Seni Sevmek” adlı kasetin üretimi ve satışının yasaklanması suretiyle haksız rekabetin men’ine**, 30,000,000 TL **maddi, 30,000,000 TL manevi tazminatın** dava tarihinden itibaren %48 ve değişen oranlarda rees-kont faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen **tahsiline**, fazla istemin reddine **karar vermiştir**.²⁸”

Doktrinde, tecavüzün ref’i davasını, eser sahibinin yanında mali hakları devralanın veya izin (lisans) sahibinin de açıp açamayacağı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Bir görüşe göre,²⁹ lisans sahibi davayı açabilmektedir. Diğer görüşe göre ise³⁰; lisans sahibi sadece söz-

²⁷ Bu madde en kısa sürede değiştirilmelidir. Çünkü madde, sadece radyo yayınının olduğu bir dönemde Kanuna eklendiğinden, televizyon, bilgisayar, cep telefonları gibi umuma iletim yöntemlerini kapsamamaktadır. Yapılacak değişikliklerle eksik umuma iletim yöntemleri maddeye eklenmelidir.

²⁸ 11. H.D. 23.3.1995 T., E. 1995/741 K. 1995/2407. Naklen SULUK/ORHAN, age, s. 176

²⁹ EREL, age., s. 294.

³⁰ AYİTER, age., s. 254. Naklen SULUK/ORHAN, age., s. 784.

leşme çerçevesinde izin verene başvurarak, ondan ref davasının açılmasını isteyebilir. TEKİNALP³¹, mali hakları devralanın bu davayı açabileceğini, ancak izin (lisans alanın) sahibinin sadece maddi tazminat davası açabileceğini, ref davasını açamayacağını savunmaktadır.³²

Tecavüzün ref'i davasının hukuki niteliğinin çoğu kez haksız fiil olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, BK madde 41 ve devamındaki tamamlayıcı hükümler uygulanmaktadır. Tecavüz devam ettiği sürece zamanaşımı devam etmemektedir. Aksi halde BK madde 60 uygulanmaktadır. Fakat tecavüz bir sözleşmenin ihlali niteliğini taşıyamıyorsa; BK madde 125 deki on yıllık zamanaşımı uygulanmaktadır.

Tecavüzün ref'i, davası, FSEK madde 66/son hükmüne göre; eser sahibinin ikametgahında açılabilir.

FSEK madde 66/3 gereğince; tecavüzde bulunanın kusuru, davanın bir koşulu değil, hakime alacağı tedbirleri belirlemede yol gösteren bir unsurdur. Çünkü FSEK madde 66/4 uyarınca, *“mahkeme, eser sahibinin manevi ve mali haklarını, tecavüzün şümulünü, kusurun var olup olmadığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün ref'i halinde tecavüz edenin duçar olması muhtemel zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikatına karar verir”*³³.

FSEK madde 66/3'ya göre, tecavüzün ref'i ve meni davalarında, hukuka aykırı faaliyette bulunanların, zarara **“kusuruyla”** sebebiyet vermeleri aranmaz. Doktrinde kusurun aranmadığı bu sorumluluk türü, *“sebeep sorumluluğu”* olarak adlandırılmaktadır³⁴. Tazminat davaları bakımından ise, maddi tazminat davasında FSEK madde 70/2 gereğince, BK md. 41 ve devamındaki haksız fiil hükümlerine atıf yapıldığı için davalının kusurlu olması şarttır. FSEK madde 70/1 ve BK madde 49

³¹ TEKİNALP, age., s. 278.

³² Mali haklarda izin ve devir arasındaki farklar açısından VII. D. Mali Hakların Devri bölümündeki açıklamalarımıza bakınız.

³³ ARSLANLI, age., s. 211; KAYPAKOĞLU, age., s. 153. Naklen ARIDEMİR, age., s. 184.

³⁴ Faruk EREN, *Borçlar Hukuku/Genel Hükümler*, C.2, İstanbul 1994, sh. 12; ARSLANLI, age., s. 212. Bazıları ise, FSEK madde 66 hükmünü nazara almaksızın, FSEK madde 68 gereğince bulunacak rayiç bedel itibariyle uğradığı zararın üç katını talep edebilmek için davalının *“kusurlu”* olması gerektiğini belirtmektedir. Bkz. Levent AKIN, *“Fikri Haklara Yönelik Tecavüzlere Karşı Hukuk Davaları”* Prof. Dr. Turhan ESENER'e Armağan, Ankara 2000, sh. 105-146. Bu görüşe FSEK madde 66'nın açık hükmü karşısında hak vermek mümkün değildir. Naklen EREL, age., s. 276

gereğince, manevi tazminat davasında ise bir açıklık olmadığı için bu konu tartışmalıdır. İlgili bölümde bu konu üzerinde duracağız.

3. Tecavüzün Men'i Davası

FSEK madde 69'a göre; tecavüz (saldırı) veya tecavüz tehlikesinin bulunduğu zamanlarda, tecavüzü veya tecavüz tehlikesini ortadan kaldırmak için açılan bir davadır. Yine aynı şekilde, mevcut bir tecavüzün devamını önlemek için de bu dava açılabilir.

Tecavüzün men'i davasında, hak sahiplerinin haklarına yönelik hukuka aykırı faaliyet henüz gerçekleşmemiş ve sonuçlar doğmamıştır; ancak tecavüzün gerçekleşmesi "tehlikesi" bulunmaktadır. Örneğin; eseri çoğaltmak için hazırlıklar yapılmış ancak henüz eser çoğaltılmamışsa, tecavüz gerçekleşmediği için tecavüzün ref'i davası açılmayacaktır; ancak, tecavüzün gerçekleşme tehlikesi olduğu için tecavüzün men'i davası açılabilir³⁵. Bu davanın, hukuka aykırı fiilin gerçekleşmesi ya da etkilerinin devam ediyor olması halinde açılması mümkün değildir; bu hallerde duruma göre tecavüzün ref'i davası ya da tazminat davaları açılmalıdır³⁶.

Tecavüzün meni davasının, ref'i davasından en önemli farkı; tecavüzün sonuçlarını ortadan kaldırma gayesinin olmamasıdır. Men davasındaki amaç; tehlikenin somut bir eyleme dönüşmesinin önlenmesidir. Ayrıca ref ve men davaları birlikte de açılabilirler.

Ayrıca bedel (tazminat) talebi ile birlikte tecavüzün men'i talep edilemez³⁷. Yargıtay'a göre, eğer davacı, FSEK madde 68 uyarınca "bedel" talebinde bulunmuşsa, " taraflar arasında sözleşme yapılmış gibi bir durum ortaya çıkmakta ve davalının kullanma ve çoğaltma durumu yasal hale gelmektedir. 5846 sayılı Kanunun 68. maddesinin düzenleme şeklindeki amacı da bu yöndedir.³⁸

³⁵ AYİTER, age., s. 260. Naklen ARİDEMİR, age., s. 197.

³⁶ Eser sahibi tecavüzün men'i davasını açtıktan sonra hüküm verilinceye dek geçecek sürede tecavüz gerçekleşirse, hakim "dava konusuz kaldığından esas hakkında karar verilmesine mahal olmadığına" karar verecektir (HUMK md 74). Bunu önlemek için terditli dava açmak gereklidir. Kanaatimizce sonucun gerçekleşmesini önlemek amacıyla dava açılmadan önce veya sonra FSEK madde 77 gereğince tedbir kararı da alınabilir. Naklen ARİDEMİR, age., s. 198.

³⁷ ÜSTÜN, Birlikçi Raporları I, s. 16. Naklen ARİDEMİR, age., s. 198.

³⁸ Yargıtay 11. H.D., 07.07.1987 T., 1987/1836 E., 1987/4131 K. Naklen ARİDEMİR, age. s. 198.

FSEK 66. maddenin iki, üç ve dördüncü fıkraları³⁹ bu davalar hakkında da uygulanır.

Tecavüzün men’i davasında davalının kusurunun olması şartı aranmamaktadır. Tecavüzün objektif olarak hukuk düzenine aykırı olması yeterlidir⁴⁰. Hakim, kusurun olup olmadığını, varsa ağırlığını, tecavüzün kapsamını ve tecavüzün men’i halinde tecavüz edenin meydana getireceği zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün men’i için gerekli gördüğü tedbirleri alacaktır. Buna göre hakim, tecavüz etmesi muhtemel kişiye bir işin yapılmasını veya yapılmamasını emredebileceği gibi, çoğaltılmış nüsha ve kalıpların ihtiyati tedbirle zaptedilmesine veya bozulmasına ya da imhasına karar verebilir⁴¹.

Men davasının zamanaşımı yoktur. Çünkü tecavüz devam ettiği müddetçe bu dava açılabilir.

Bu davanın davacısı, ref davasında olduğu gibi, eser sahibi ve FSEK madde 19’da sayılan kimselerdir. Ancak madde 69/1 hükmünde bulunan “*mali ve manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebilir. Vaki olan tecavüzün devamı veya tekrarı muhtemel görülen hallerde de aynı hüküm caridir.*” şeklinde ifade ile yalnızca “eser sahibi”nin bu davayı açabileceğine ilişkin bir sınırlama olduğunu düşünmemek gerekir. Çünkü ref davası, men davasına göre daha engelleyici olmasına karşılık, onda dahi FSEK madde 19’daki kişiler bu davayı açabilmektedirler. Ayrıca madde 69/1 metnini yorumlarken kapsamını dar düşünmek; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun “eser ve diğer hak sahiplerini haklara saldıranlara karşı koruma” amacı ile çelişki oluşturur.

³⁹ FSEK madde 66/2., 3. ve 4. fıkraları:

Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir.

Tecavüz edenin veya ikinci fıkra yazılı kimselerin kusuru şart değildir.

Mahkeme, eser sahibinin manevi ve mali haklarını, tecavüzün şümulünü, kusurun olup olmadığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün refi halinde tecavüz edenin düçar olması muhtemel zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün refi için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikına karar verir.

⁴⁰ ARSLANLI, age., s. 211. Hukuka aykırılık unsuru bakımından, Türk-İsviçre Hukukunda “normatif-objektif görüş” hakimdir. Bu konudaki tartışmalar hakkında bakınız; BELEN, age., s. 66 vd. Naklen ARIDEMİR, age., s. 199.

⁴¹ AYİTER, age., s. 261; EREL, age., s. 303; TOPALOĞLU, age., s. 111.

FSEK madde 80 hükmüne göre, bağlantılı hak sahipleri de aynen eser sahibi gibi bağlantılı haklarının tecavüze uğraması halinde bu davayı açabilmektedir.

FSEK madde 66/2'ye göre, tecavüz tehlikesi bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemi tarafından yapılmış ve hizmetlerinin ifası sırasında ortaya çıkmış veya vaki tecavüzün devamı niteliğinde eylemler varsa ya da eylemler vuku bulan bir tecavüzün devamı mahiyetindeyse tecavüzün men'i davası temsilci veya çalışanlar yanında işletme sahibi aleyhine de açılır.⁴²

FSEK madde 66, bu davanın da tıpkı ref davasında olduğu gibi; eser sahibinin ikametgahı mahkemelerinde açılabileceğini vurgulamıştır.

4. Tecavüzün Tespiti Davası

FSEK; tecavüzün tespiti davasını, saldırılara karşı açılabilecek davalar arasında düzenlememektedir. Bu dava, şartlarının varlığı halinde Türk Ticaret Kanunu madde 57 ve Medeni Kanun madde 25'e dayanarak açılabilmektedir. Bu davada tecavüzün varlığı ve hukuka aykırı olduğu mahkeme kararı ile saptanır.

Bu davanın açılabilmesi için kusur şartı aranmamaktadır. Yalnızca fikirsel ve sanatsal haklara saldırının bulunması yeterlidir.

FSEK madde 19'da sayılan kimseler bu davaları açabilir kanaatindeyiz.

Aşağıda hak sahiplerinden hakları devralan bir meslek birliğinin açtığı bir tecavüzün tespiti davası örneğini bilginize sunuyoruz:

“Davacı vekili, davalının müvekkili üyelerine ait müzik eserleri ile Sacem Sözleşmesi ve yabancı meslek birliği ile yapılan karşılıklı anlaşmalar gereği korumaları altında bulunan yabancı müzik yapıtlarını izin almadan ve yasalara aykırı olarak kullandığını, bu durumun 5846 sayılı Yasa'dan kaynaklanan hakların ihlali olduğunu iddia ederek, davalının tecavüzünün tespit ve önlenmesine, hüküm özetinin ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının yerli ve yabancı müzik eserlerini koruma hakkına sahip bulunduğu, davalının, davacı korumasındaki bazı eserleri izinsiz olarak kullandığı, bu durumun FSEK'in 66, 69 ve 76. maddeleri gereği tecavüz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davalının davacı meslek birliği tarafından himaye edilen eserleri izinsiz olarak yayınlarında kullanmasının FSEK'ten doğan eser sahibi haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine ve tecavüzün önlenmesine, hüküm özetinin bir kez ilanına karar verilmiştir.”⁴³

⁴² TEKİNALP, age., s. 307

⁴³ Yargıtay 11. H.D., 29.04.2003, E. 2002/11498 K. 2003/4266, ERDİL, age., s. 107-108.

Tazminat veya eski hale getirme gibi davalı tarafından bir eylemin yapılmasını gerektiren eda davasının açılabilceği hallerde, sadece soyut olarak saldırının veya saldırganın mahkemece belirlenmesini isteyen ve bir eylem talep edilmeyen tespit davası açılamamaktadır. Bununla ilgili aşağıdaki Yargıtay kararında görüleceği üzere, “davacıların tespitini talep ettikleri hususların derhal tespiti gereken hususlardan olmadığı, bunların açılacak bir eda davasında incelenecek ve değerlendirilecek konulardan olduğu” sonucuna varılmış ve dava reddedilmiştir.⁴⁴

“Davacılar vekili, 5846 sayılı Kanundaki düzenleme nedeniyle davalı Meslek Birliği ile TÜROB (Otelciler Birliği) arasında, otellerde mekanik ve canlı müzik kullanmasına yönelik telif bedellerine ilişkin olarak protokol düzenlendiğini, müvekkillerinin de meslek birlikleri ile görüşmeler yaptığını ancak taleplerin yasaya aykırı hükümler içermesi nedeniyle görüşmelerin sona erdirildiğini, Meslek Birliğinin tip sözleşmesinin tamamen davalı lehine olup, hakkaniyete uygun bir telif bedeli ödemek isteyen müvekkillerini güç durumda bıraktığını, davalının haklarının sınırlarının tespiti gerektiğini ileri sürerek, **bu dava ile davalının üyelerinin kimler olduğunun ve hangi üyenin hangi icraları bakımından davalıya yazılı mali hak yetki belgesi verdiğinin tespitini, telif ücreti ödenmesini isteme hakkı bulunup bulunmadığının tespitini, umumi mahallerle kullanım bandrolünün Kültür Bakanlığı tarafından çıkarılana kadar kaset ve CD dinletimi nedeniyle ücret ödenmesini talep hakkı olmadığının tespiti, otellerdeki radyo ve TV yayınlarının izlenmesi halinde FSEK 25. maddeye göre ücret ödemesini talep hakkı olmadığının, böyle bir talebin mükerrer tahsilat teşkil edeceğinin tespitini ve davalının talep haklarının tespiti ile hakkın ve hakim durumun kötüye kullanılması sureti ile rekabeti bozucu şartları oluşturmasını engellemesi suretiyle ile çekişmenin giderilmesini talep ve dava etmiştir.**

...Mahkemece iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre; davacıların tespitini talep ettikleri hususların derhal tespiti gereken hususlardan olmadığı, bunların açılacak bir eda davasında incelenecek ve değerlendirilecek konulardan olduğu, ayrıca davalının üyelerinin zaman içinde değişebileceği, değişen eserler için de yetki verildiği, eda davasına konu olabilecek hususların tespit davası ile mahkemeye getirilmesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle, koşulları oluşmayan davanın reddine karar verilmiştir.”

Tespit davasındaki zamanaşımı için her ne kadar TTK madde 62’de, bir ve üç yıllık zamanaşımının uygulanacağı belirtilse de; dava fiktisel ve sanatsal haklara bir saldırıya ilişkin olduğu için, yani tecavüz veya tecavüzün etkileri devam etmekte olduğundan TEKİNALP’e göre,

⁴⁴ 11. H.D., 4.4.2005, E. 2004/6683, K. 2005/3135.

davada zamanaşımı işlemeyecektir. Sona ermiş bir tecavüzün tespiti davasının açılmasına -eğer tecavüzün etkileri artık devam etmiyorsa- hukuk sistemimiz izin vermemektedir. Ancak istisnai olarak böyle bir davanın açılabilmesi olasılığı varsa, TTK madde 62'deki kural gereğince, davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren bir ve her halde bunların doğumundan itibaren üç yıllık sürede davasını açıp açmadığı dikkate alınmalıdır⁴⁵.

5. Tazminat Davaları

a. Manevi Hakların İhlali Halinde Tazminat Davası

FSEK madde 70'de manevi haklara saldırının varlığı halinde eser sahiplerinin manevi tazminat isteminde bulunulabileceği belirtilmektedir. FSEK madde 80 hükmüne göre de, bağlantılı hak sahiplerinden icracı sanatçılar aynen eser sahibi gibi manevi haklara sahip olduğu için haklarının tecavüze uğraması halinde bu davayı açabilmektedir. İcracı sanatçılar dışındaki bağlantılı hak sahiplerinin ise manevi hakları olmadığı için bu davayı açamayacaklarını söyleyebiliriz.

Manevi tazminat davasının açılabilmesi için eser sahibi veya icracı sanatçının herhangi bir manevi hakkına tecavüz edilmesi yeterlidir; ayrıca eser sahibinin veya icracı sanatçının manevi zarara uğramış olması gerekmemektedir. Manevi tazminat davaları eser sahibi, icracı sanatçı ve haleflerinin manevi hakları alanındaki saldırılar sonucu uğradıkları zararın giderilmesine yarar. Bu yüzden diğer davaların açılmış olması manevi tazminat davası açmaya engel değildir.

Bu dava mali bir hakla birlikte manevi hakkın ihlali halinde açılabilir. Örneğin, henüz umuma arz edilmemiş bir eser, sahibinin rızası hilafına çoğaltılır ve piyasaya sürülürse, çoğaltma ve yayma hakları ile birlikte umuma arz yetkisi; iktibas serbestisinin sınırlarının aşılması, kaynak göstermeme halinde eser sahibinin ad belirtme yetkisi ihlâl edilmiştir. Bu sebeple, eser sahibinin maddi tazminat davası ile birlikte hukuka aykırı fiil sonucu duyduğu elem ve acıyı telafi etmek amacıyla, FSEK madde 70 gereğince manevi tazminat davası açmak hakkı bulunmaktadır⁴⁶. Yargıtay da bu görüştedir⁴⁷. İşte bir örnek:

“Davacı vekili, bestesi ve güftesi müvekkiline ait olan “*Memleketim ve Sen*” adlı eseri, davalı şirketin 1997 yılında Küçük O. isimli sanatçıya “Ben Gardaşım” isimli kaset içerisinde “Bir Seni Özledim”

⁴⁵ TEKİNALP, age., s. 307.

⁴⁶ EREL, age., s. 306.

⁴⁷ Yargıtay 11.HD. 08.02.1999 T., 1998/9070 E., 1999/595 K. (Yayımlanmamıştır.). Naklen ARIDEMİR, age., s. 201.

ismi ile izinsiz yayınladığını, ... söz konusu kasetin kaset kapağı ve klip logosuna eserin söz ve müziğinin (eser sahibi olmayan) M.B.'a ait olduğunun yazıldığını, aynı bestenin müvekkilinin "Umuda Ezgi" müzik grubunun çıkardığı "Gün Işımış, Ağlama Artık Bebek" isimli kasetinde de yer aldığını, cezaevi koşullarında yazılan ve o döneme ait duyuları yansıtan **eserin çarpıtılarak ve tahrif edilerek her yerde çalınmasının müvekkili için dayanılmaz bir hal olduğunu ileri sürerek** fazlaya ilişkin talep hakları saklı kalması kaydıyla 1.000.000.000 TL **maddi** ve 2.000.000.000TL **manevi tazminatın**, ... davalıdan **tahsiline** karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

....Davalı şirket vekili, söz konusu eserin izin ve muvafakatını M.B.'tan aldıklarını, müvekkilinin iyi niyetli olduğunu, eserin çarpıtıldığı iddiasının doğru olmadığını savunmuş, davanın devamı sırasında söz konusu eserin kasetten çıkarıldığını savunarak yeni kasetin kartonetini ibraz ederek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından **eser sahibinin yazılı izni olmaksızın eseri kullandığı, tahrif ettiği, davacının ismini eserde belirtmediği ve fiilin vahameti, tarafların sosyal durumları dikkate alınarak davanın kısmen kabulü ile 1.598.400.000TL maddi ve, 400.000.000 TL manevi tazminatın** talep miktarına göre dava tarihlerinden itibaren değişen oranlarda reeskont faizi ile davalı P. Müzik Ltd. Şti.nden **tahsiline karar verilmiştir.**⁴⁸

Manevi tazminat davası için kusur şartının aranması doktrinde tartışmalıdır. TEKİNALP'e göre; nasıl tecavüzün ref'i ve tecavüzün men'i davalarında kusur aranmamışsa manevi tazminat davası açısından da aynı sonuca varılmalıdır. EREL'e göre ise, manevi tazminat davası haksız fiil niteliği taşımaktadır ve Borçlar Kanunu madde 41 ve devamında düzenlenmiştir. BK 41. maddede yapılan değişikliklerle madde metninden "kusurun ağırlığı" ibaresinin çıkarılması, davanın unsurları arasında kusurun bulunmadığını göstermez⁴⁹. ARIDEMİR'e göre; BK madde 49 gereğince, manevi tazminat davası kusura dayanan sorumlulukla ve şartları uyduğu sürece kusursuz sorumluluk hallerinde açılacaktır⁵⁰. Kanaatimizce manevi tazminat davası için davalının kusuru şartı aranmaktadır; ancak, kusurun ağırlığı bu tazminat isteminde bulunmak için önem taşımamaktadır. Hatta uygulamada, Yargıtay kararlarının geneline

⁴⁸ Yargıtay 11. H.D, 4.6.1998, E. 1998/2390, K.1998/4152

⁴⁹ TEKİNALP, age., s. 20 no 89 ve EREL, age., s. 303

⁵⁰ 22.06.1966 T. 7/7 sayılı YİBK gereğince, BK madde 49 bakımından kusursuz sorumluluk halinde manevi tazminat davası açılmayacaktır. Naklen ARIDEMİR, age., s. 202.

bakıldığında manevi bir hakkın ihlali halinde hemen hemen her durumda tazminata hükmedilmekte; kusurun varlığının araştırılmasına gerek görülmemektedir.

Eser sahiplerine ilişkin olarak, FSEK de madde 14 (ilk defa kamuya sunuş hakkı), madde 15 (eser sahibinin adının belirtilmesi hakkı), madde 16 (eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı) ve madde 17’de (eser sahibinin eseri elinde bulunduran ve sahip olana karşı engelleme hakkı) sayılan manevi haklardan biri çiğnenmişse ve bu eylem kusurlu olarak işlenmişse, ilgilinin dava açması halinde manevi tazminata hükmetmek gerekmektedir. Yine intihalin varlığı halinde eser sahibinin adıyla ilgili olarak manevi hakkına bir tecavüz söz konusudur. Bu nedenle FSEK madde 70’e dayanılarak dava açılabilir.

Bağlantılı hak sahibi icracı sanatçılar ise FSEK 80 gereğince; icrasının sahibi olarak tanıtılma, icranın icracının itibarını zedeleyecek şekilde değiştirilmesi ve kişiliğe zarar verecek şekilde icranın kullanılması hallerinde manevi hakları saldırıya uğradığından bu davayı açabilirler.

FSEK madde 70; sadece Kanun’da sayılan manevi hakların ihlali halinde manevi tazminat talebinde bulunulabileceğini düzenlemektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği 18.12.1981 tarihli kararda; eser sahibinin eseri üzerindeki manevi hakları ile kişisel menfaatlerinin birbirinden ayrı olduğu belirtilmiş, eser sahibinin FSEK’de sayılan manevi haklarının ihlali halinde isteyebileceği manevi tazminatın FSEK’te düzenlendiği, ancak FSEK’de yazılmayan şekillerdeki kişisel menfaat ihlallerinde isteyebileceği tazminatın ise BK madde 49’a bırakıldığı açıklanarak, ilgilinin genel olarak mülkiyet veya mesleki onur ihlallerinde Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun kişilik hakkı ihlallerine ilişkin manevi tazminat hükümlerinden yararlanacağı söylenmiştir⁵¹. FSEK madde 70 gereğince icracı sanatçılar için de, kişilik haklarının ihlal edilmiş olması FSEK’e göre açılan manevi tazminat davasında aranmaz. Ancak hem icraya ait manevi hakların ihlali ve hem de kişilik hakkı ihlali varsa bu durumda, kişilik hakkı ihlalleri için ayrı bir tazminat davası da açılabilir.

⁵¹ HGK., 18.12.1981, E. 1980/1, K.1981/2.

FSEK uygulaması açısından; manevi tazminat davasının açılması için eser sahibinin herhangi bir manevi hakkının ihlali yeterli olmaktadır⁵². Ancak, 29.3.2001 tarihli ve 493/2537 sayılı yayımlanmamış bir mahkeme kararına göre; hangi manevi hakların ihlal edildiğinin özellikle davada belirtilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Yargıtay'ın bu kararına göre; sadece manevi hakların hangilerinin ihlal edildiğinin davada belirtilmesi yeterli bulunmuş; sebep-sonuç ilişkisi ve bu ihlal nedeniyle bir zararın bulunduğu ispatlanması şartı getirilmemiştir. Bazı durumlarda ise, manevi hakların ihlali sonucunda ortaya çıkan zararın büyüklüğü ve hak sahibinin mali durumu tazminat miktarını etkilemektedir. Bazen oluşan zararı gidermek için, manevi tazminat isteminin yanında maddi tazminat isteminde de bulunulmaktadır.

Bazen ise bir eylem ile iki adet hak ihlal edilmektedir. Bu durumda da iki adet tazminata karar vermek gerekir. Yargıtay'ın mali haklarla ilgili olmasına rağmen, manevi haklara kolayca uygulanabilecek bir kararını bilginize sunuyoruz:

“Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporlarına nazaran, mali hakları davacıya ait “*Seni Andıkça*” adlı eserin edebi ve müzik eseri niteliği olduğu, davalıların ise **sözleri üzerinde önemsiz değişiklikler yaparak**, aynı eseri “Mektup” adı altında çoğaltıp **yayınladıkları, bu hususun davacıların mali ve manevi haklarını ihlal ettiği**, istenebilecek maddi tazminatın 18,185,999,999 lira olup, tecavüzün niteliğine ve ağırlığına, tarafların durumlarına nazaran **manevi tazminat isteğinin de yerinde olduğu gerekçesi** ile asıl ve birleşen **davaların kabulüne karar verilmiştir**.

Kararı, davalılardan H.L. ve ... Müzik Yapım San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve eserin aynen tekarlanması ve maddi bir varlık olarak ortaya çıkmasını sağlayan teknik bir işlem olan çoğaltmanın, eserden, sahibinin ekonomik yönden yararlanabilmesinin en olağan ve yaygın yolu olması, ... ve yine bağımsız olarak FSEK'in 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkının, çoğu kez çoğaltmayı izleyen bir aşama olup, çoğaltılmış eserin dağıtım, satış, kiralama gibi ticarete sunulması hakkı olması, **FSEK'te düzenlenmiş sistematik de nazara alındığında çoğaltma ve yayma haklarının ayrı haklar olduğunun açık olması ve dolayısıyla yayma hakkı ve çoğaltma haklarının ihlali nedeniyle ayrı ayrı tazminat hesaplanmasında bir isabetsizlik bulunmaması** kar-

⁵² 11.HD., 4.06.2001 tarihli kararında kabul edilmiştir. Naklen TEKİNALP, age., s. 308.

şısında, temyiz eden davalılar vekilinin yerinde görülme-
yen aşağıdaki bent dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek ge-
rekmiştir⁵³.”

Yargıtay, manevi zararın tazmini için bir miktar paranın verilmesi-
nin yanında, paraya ek olarak kararın gazetelerde ilanı gibi başka yaptırı-
mları da karara bağlayabilmektedir.

Manevi hakların ihlali halinde, bu davanın davacısı eser sahibi ve
icracı sanatçıdır. Mirasçılarının ise bu davayı açıp açamayacakları, Türk
Hukuku’nda tartışmalıdır⁵⁴. FSEK madde 19 gereğince eser sahibine ait
manevi hakların mirasla mirasçılara geçmesi mümkün olmadığı için;
ancak eser sahibinin mirasçıları veya vasiyeti tenfiz memuru açısından
saldırganlar tarafından yapılan eylem, onların eser sahibinin yakınları
olmaları sıfatıyla kişisel bir zararlarına yol açıyorsa bu davayı açabile-
cekleridir. Yargıtay’ın aksi sonucu doğuran bir kararına göre⁵⁵; “... 19/2.
madde, aynı Yasanın 19/1. maddesinde sayılan kimselerin, eser sahibi-
nin ölümünden sonra, 14, 15 ve 16. maddelerin üçüncü fıkralarında eser
sahibine tanınan hakları kullanabilecekleri öngörüldüğünden, manevi
zararın giderilmesini isteme haklarının da bulunduğu kabulü gerektiği”
belirtilerek, “davacılar yararına münasip bir manevi tazminata”
hükmedilmiştir. Yargıtay’ın verdiği bu karar; manevi tazminat davasını,
eser sahiplerinin yanında mirasçılar hatta mali hak sahiplerinin de açabi-
leceğine ilişkin HGK’nun verdiği, 1983 tarihli kararına dayanmaktadır⁵⁶.
Ancak HGK’nun verdiği karar FSEK hükümlerine uygun düşmemektedir.
Nitekim Yargıtay verdiği yeni tarihli başka bir kararda, mali hakları
devralan kimsenin manevi tazminat isteyemeyeceği sonucuna varmıştır.⁵⁷

Yargıtay’ın mirasçıların eser sahibinin manevi haklarının ihlali halinde
manevi tazminat isteyemeyeceklerine ilişkin bir başka kararı ise şöyledir⁵⁸.

“Davacılar, miras sonucu elde ettikleri eserin, davalı yayıncı
şirket tarafından kendilerinden izin alınmadan yayınladığını belirterek,
maddi ve manevi tazminat ödenmesini ve verilecek kararın gazetede

⁵³ Yargıtay 11. H.D., 07.12.2000, E. 2000/7797, K. 2000/9773. ERDİL, age., s. 105-107

⁵⁴ TEKİNALP, age., s. 309.

⁵⁵ 11.HD., 3.7.2000, E.2000/4764, K.2000/6252.

⁵⁶ HGK, 11.2.1983, E.4-70, K.123.

⁵⁷ 11. H.D., 16.6.2003, E.2003/784, K.2003/6343

⁵⁸ 11. H.D., 22.12.2005, E. 2004/14950, K. 2005/12769. YKD., Cilt: 32, Sayı: 4, Nisan
2006

ilanını talep etmişlerdir... 5846 sayılı FSEK'in 63. maddesi gereğince, bu Kanun ile tanınan mali haklar miras yolu ile intikal etmektedir. Eser sahibinin aynı Kanun'dan doğan manevi hakları ise ölümü halinde mirasçılara intikal etmemekle birlikte, eser sahibinin ölümünden sonra manevi hakları kullanabilecek olanlar; tayin edilmişse vasiyeti tenfiz memuru, tayin edilmemişse sağ kalan eşi, çocukları, mansup mirasçıları, ana babası ve kardeşidir. Görülen davada, işleme eser sahibinin mirasçısı olan **davalıların istemi, eserin davalı şirket tarafından izinsiz olarak umuma arzı nedeniyle FSEK'in 14. maddesi yoluyla aynı Kanun'un 70/1. maddesine dayalı manevi hak tazminatı olduğuna göre, FSEK'in 19/1. maddesi uyarınca davacıların tazminat talep etme hakları olamayacağı için istem reddedilmiştir.**"

Dava manevi saldırıdan sorumlu olan kişiye karşı açılmaktadır. İş-yeri sahipleri, çalıştırdığı kişilerin fiilinden sorumlu olduğundan ona da bu dava açılabilir.

Bu davanın zamanaşımı BK madde 60'a tabi bulunmaktadır. Zamanaşımı süresi saldırının veya saldırganın öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her halde zarara sebep olan fiilin öğrenilmesinden itibaren on yıldır.

Açılacak bu davada yetkili mahkeme FSEK madde 66/son'da belirtilen tecavüzün ref'i ve men'i davalarındaki gibi eser sahibinin veya icracı sanatçının ikametgahı mahkemesi değildir. Tazminat davalarında yetkili mahkeme HUMK hükümlerine göre, davalının ikametgahı mahkemesidir. Ancak EREL'in görüşüne göre; tazminat davalarının da davalının ikametgahı mahkemesinde açılabilmesi gerekmektedir.

b. Mali Hakların İhlali Halinde Tazminat Davası

Mali hakların ihlali hallerinde haksız fiil hükümleri uygulandığından maddi tazminat istenilmektedir. İşleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ihlal edilen eser sahibi veya bağlantılı hak sahibi ya da bu hakları devralan (veya lisans alan) kimseler, FSEK madde 70/2'ye⁵⁹ ve FSEK madde 80/2. madde 9. fıkraya göre; **tecavüz edenin kusuru bulunmak şartıyla** haksız fiil hükümlerine dayanarak maddi tazminat isteyebilecektir⁶⁰. Ancak mali haklara yapılan saldırı eylemi sonucunda, eser sahibinin manevi hakları da zarar görmüş olabilir. Örneğin, bir müzisyenin stüdyosuna röportaj amaçlı giden televizyon

⁵⁹ FSEK madde 70/2: Mali hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir.

⁶⁰ YARSUVAT, age., s. 22; YAVUZ, age., s. 552. Naklen SULUK/ORHAN, age., s. 801.

muhabiri sanatçının henüz umuma arz edilmemiş bulunan bir müzik eserini gizlice kaydederse ve daha sonra bunu cd ortamına aktarıp çeşitli televizyon kanallarına verirse ve televizyonda yayınlarsa müzik eseri sahibinin çoğaltma ve umuma iletim mali haklarına ve aynı zamanda da umuma arzdan kaynaklanan manevi hakkına tecavüz etmiş olur. Bu durumda önceki bölümde anlatıldığı şekilde maddi tazminata ek olarak manevi tazminat isteminde bulunulabilir.

FSEK 70 gereğince, mali hakların ihlali halinde maddi tazminat talep edebilmek için ortada bir **kusur olmasının** yanı sıra **maddi zararın da bulunması** gerekmektedir. Tazminat davası, eda davasıdır. Bu dava ile, zarar görenin; malvarlığının şimdiki durumu ile zarar veren olay meydana gelmeseydi sahip olacağı durum arasındaki farkın tazminat olarak ödenmesine hükmedilecektir.

Zarar, fiili zarar ve yoksun kalınan kâr şeklinde ortaya çıkabilir. **Fiili zarar**, malvarlığının eksilmesini yani aktifin azalmasını, pasifin artmasını ifade etmekte iken; **yoksun kalınan kâr**, malvarlığının artmasının engellenmesi sonucunda ortaya çıkan zarardır⁶¹. Fikir ve sanat eserlerinde zarar daha çok, yoksun kalınan kâr şeklindedir⁶². Bu nedenle, vekaletsiz iş görmeden kaynaklanan talepler ile maddi tazminat davasından kaynaklanan talepler bu konuda çatışmaktadır. Bazılarına göre, bu talepler yığılmaz, ancak yarıdır⁶³. Bazılarına göre ise, kazanç devri talebi ile maddi tazminat talebi yarıdır⁶⁴; bazılarına göre, fiili zarar halinde, kazanç devri ile maddi tazminat talebi yığılır; ancak zarar yoksun kalınan kâr şeklinde ortaya çıkmışsa, talepler yarıdır⁶⁵. Taleplerin yarışması kabul edildiğinde, eser sahibi menfaatine en uygun olan seçeneği tercih etmelidir. Özellikle, çoğaltma ve yayma sonucu eserden, eser sahibinin elde edeceği kârdan daha fazla kâr elde edilmişse ve eser sahibi, uğradığı zararı ispatlamakta güçlük çekmekte ise, vekâletsiz iş görme kurumuna

⁶¹ KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, HATEMİ, sh. 48-50. Naklen ARIDEMİR, age., s. 200.

⁶² AYİTER, age., s. 262; KAYPAKOĞLU, age., s. 163. Naklen ARIDEMİR age., s. 200.

⁶³ AYİTER, age., s. 263; ARPACI, age., s. 162; ÜSTÜN, age., s. 50. Naklen ARIDEMİR, age., s. 207.

⁶⁴ HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, age., s. 496. Naklen ARIDEMİR, age., s. 207.

⁶⁵ TEKİNALP, age., s. 287, N. 99. Bazıları ise zararlar bakımından bu yönde bir ayrım yapmaksızın, maddi ve manevi tazminat talepleri ile vekaletsiz iş görmeden doğan taleplerin yığılacağını belirtmektedir. DURAL, sh. 153-154. Naklen ARIDEMİR, age., s. 207.

başvurması ve kârın devrini istemesi menfaati gereğidir⁶⁶. Eklemeliyiz ki, FSEK madde 70/3'deki hak sahibinin devrini talep ettiği kârdan, FSEK madde 68'e göre talep edilen bedel indirilir.

Bu açıklamalarımıza rağmen, tazminat davalarında zararı tespit etmek oldukça güç bir iş olduğu için gerektiğinde hakim; BK madde 42/2 hükmünden yararlanarak “halin mutad cereyanını ve mutazarrır olan tarafın yaptığı tedbirleri” dikkate alıp, zararı takdir edecektir⁶⁷.

Bir müzik eseri, izinsiz çoğaltılıp da çoğaltılan nüshaları henüz satışa çıkarılmadıysa eser sahibi; FSEK madde 68 uyarınca, eserin izinsiz çoğaltılan kopyalarını imha, basılan kopyaların kendisine devri veya üç katı tazminat isteme seçeneklerinden birini bu davada isteyebilir. FSEK madde 68'e göre açılacak maddi tazminat davasında FSEK madde 70'deki maddi tazminat davasından farklı olarak, davalının kusuru şartı aranmamaktadır.

FSEK madde 68 (2008 yılında yapılan değişikliklerle) şu düzenlemeleri getirmektedir:

“Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden bu Kanuna uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya hertürlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir.

İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmamışsa hak sahibi çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını veya üretim maliyet fiyatını geçmeyecek uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını talep edebilir. Bu husus, izinsiz çoğaltanın hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmışsa hak sahibi, tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkradaki şıklardan birini kullanabilir.

⁶⁶ FSEK madde 70/3 hükmünün tazminat davası içinde değil de ayrı bir madde içinde düzenlenmesi gerektiği hakkında bakınız; AYİTER, age., s. 263; TANDOĞAN, age., s. 331; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY, age., s. 155. Naklen ARIDEMİR, age., s. 208.

⁶⁷ ARIDEMİR age., s. 200.

İkinci ve üçüncü fıkraların eser sahibinden başka hak sahiplerince uygulanabilmesi için eser sahibinin bu Kanunun 52 nci maddesine uygun yazılı çoğaltma izni aranır.

Hak sahiplerinden biri, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca talepte bulunduklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun el koymaya ilişkin hükmüleri delil elde etmek amacı dışında uygulanmaz.

Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde haiz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir.”

FSEK madde 68 uyarınca; davacı şu seçimlik haklardan birini açtığı davada isteyebilir:

1- Çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını veya

2- Çoğaltılmış kopyaların ve çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri gereçlerin uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini veya

3- Tazminat

a- Sözleşme yapılması halinde isteyebileceği bedelin en çok üç kat fazlası veya

b- Emsal veya rayiç itibarıyla uğradığı zararın en çok üç kat fazlası.

FSEK madde 68/1 ve 2 uyarınca hükmedilebilecek olan “sözleşme olması durumunda istenebilecek bedelin üç kat fazlası” talebinin hukuki niteliğini belirlemek gereklidir. TEKİNALP; eser sahibini zararı ispat külfetinden kurtarmak ve haksız tecavüzde bulunanı cezalandırmak amacıyla, bunları “kanuni bir ceza” olarak nitelendirmektedir⁶⁸. EREL ise, bir ayırım yapmaksızın bunları tazminat olarak nitelendirmektedir⁶⁹. KAYPAKOĞLU’na göre ise, FSEK madde 68/1 gereğince talep edilen bir tazminattır; oysa ikinci fıkra gereğince talep edilen tazminat değildir. Çünkü birinci fıkra zararın giderilmesinden söz edilmekte iken, ikinci

⁶⁸ TEKİNALP, age., s. 267, N. 27, 274, N.53. Aynı görüşte; Ahmet KILIÇOĞLU, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Yapılan Son Değişikliklerle ve Eleştirisi”, FİSUAM Konferanslar Dizisi I, Ankara 1998, s. 13-36. Hamdi YASAMAN, “Fikri Haklarda Tazminat İle İlgili Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Ömer TEOMAN’a 55. Yıl Armağanı, İstanbul 2002, s. 805-819. Naklen ARIDEMİR, age., s. 195.

⁶⁹ EREL, age., s. 301. Aynı görüşte, Ergun ÖZSUNAY, “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Uygulanmasından Ortaya Çıkan Belli Başlı Sorunlar ve Kanunda Yenilenmeler Yapılmasını Gerektiren Nedenler”, Fikri Mülkiyet Hakları ve Uluslar arası Uyum Sorunları, Gümrük Birliği Bilgilendirme Toplantıları-5 1996, s. 29 Naklen ARIDEMİR, age., s. 195.

fıkra da çoğaltılan nüshalar henüz satışa çıkarılmadığı için bir zarar doğmamış olacaktır⁷⁰.

Yargıtay’a göre, FSEK madde 68 uyarınca istenen bedeli “kanuni bir ceza” olarak nitelendirmek mümkün değildir⁷¹. Yargıtay kararlarında “FSEK madde 68 uyarınca maddi tazminatın” hesaplanmasından söz edilmektedir⁷². Bu nedenle, Yargıtay’ın FSEK madde 68 gereğince istenen bedeli ya da zararı, “tazminat” olarak nitelendirdiğini söylemek mümkündür⁷³.

Bu sorunun pratik önemi şudur: Eğer FSEK madde 68 gereğince talep edilecek şeyler, tazminat olarak nitelendirilirse, eser sahibi FSEK madde 70 gereğince ayrıca en azından maddi tazminat talebinde bulunamayacaktır. Çünkü hukuk düzeni bir zararın iki kez tazminine olanak veremez; bu hakkaniyete aykırıdır. Oysa, YASAMAN’a göre; talepler kanuni ceza olarak nitelendirilirse, zararın ispatlanması kaydıyla, davacı eser sahibi ayrıca tazminat talebinde bulunabilecektir⁷⁴. FSEK madde 68 uyarınca talep edilen bedeli “kanuni bir ceza” olarak yorumlayan TEKİNALP’e göre; FSEK madde 68/I uyarınca sözleşme olması durumunda istenecek bedelin üç kat fazlası talebinde bulunulması halinde ayrıca tazminat talep edilemez. Zararı ispat külfetinin bulunmaması, kusur koşulunun aranmaması (FSEK madde 66/III) nedeniyle, bu seçenek, eser sahibi bakımından daha avantajlıdır. Eser sahibi ancak bedeli aşan bir zararı olduğunda bunun tazminini talep edebilir⁷⁵.

Yargıtay FSEK madde 68’deki üç kat tazminat talebi konusunda verdiği bir kararda⁷⁶; bir heykelin izinsiz işlenerek, küçültülüp biblo şeklinde çoğaltılarak satışının yapılmasını hak ihlali olarak kabul etmiş ve bu durumda tazminat hesabı yapılırken FSEK madde 68’de sözü geçen rayiç bedeli belirleyen bilirkişi raporunun denetime elverişli olması ge-

⁷⁰ KAYPAKOĞLU, age., s. 156-157. Naklen ARIDEMİR, age., s. 195.

⁷¹ Yargıtay 4. H.D., 21.03.1957 T., 6994 E., 1535 K. Naklen ARIDEMİR, age., s. 195.

⁷² 11. H.D., 15.02.2000T., 199/7464E., 2000/1106 K.; 11. H.D., 25.01.2000 T., 1999/6935 E., 2000/325 K. (Kararlar yayımlanmamıştır); 11. H.D., 06.03.2000 T. 1999/9978 E., 2000/1893 K. (YKD., C.29, S.2. ŞUBAT 2002, sh. 183-184). Naklen ARIDEMİR, age., s. 195.

⁷³ ARIDEMİR age., s. 195.

⁷⁴ YASAMAN, age., s. 818-819; Aksi görüşte: TEKİNALP, age., s. 274, N. 55. Naklen ARIDEMİR, age, s. 196.

⁷⁵ TEKİNALP, age., s. 274, N. 55 ve s. 276, N.64. Naklen ARIDEMİR, age., s. 196.

⁷⁶ 11.HD., 2.12.2004, E. 2004/2662, K. 2004/11862

rektiğini vurgulamıştır. Davanın açıldığı ilk Mahkemece, rapordaki miktarın davacının talebi kıyaslanmak suretiyle kabulüne karar verilmişse de; rapordaki rayiç bedele ilişkin belirlemenin dayandığı verilerin raporda açık olarak gösterilmediği, tartışılmadığı, bu şekilde varılan sonucun Yargıtay denetimine elverişli olmadığı Yargıtayca vurgulanmıştır. Ayrıca bilirkişi raporunda telif ve çoğaltma hakkı bedelinin, gerekçesi gösterilmeden (davanın açıldığı tarih yerine) rapor tarihine göre belirlenmiş olması da doğru olmamıştır. Bu nedenle Mahkemece eser sahibinin tecavüze konu mali haklarının tayin ve tespitinde FSEK madde 68 göz önüne alınarak, somut verilere dayalı ve denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre davacıların talebinin değerlendirilmesi gerekirken, rapordaki miktarın davacının talebini karşıladığı gerekçesiyle, yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi Yargıtay tarafından doğru görülmemiştir.

Verilecek olan tazminatta bilirkişi raporları gerçekten de zarar tespiti için önemlidir. Bu konu, Yargıtay'ın bir başka kararında⁷⁷; *“bilirkişi raporları arasında çelişki bulunmasının, raporun denetime elverişli bulunmamasının, rapora ciddi itirazların giderilmeden hüküm kurulmasının bozmayı gerektireceği”* belirtilmiştir.

Yine FSEK madde 68'e göre hesaplanacak tazminatlarda Yargıtay faize ilişkin şu karara varmıştır:

“Davacı, *“Bir Yangının Külü”* adlı eserinin telif hakkının ödenmeden davalı şirket tarafından S.E. adlı sanatçının sesiyle disk ve kaset haline getirilerek yayımlandığını ileri sürerek ... 25,000,000 lira telif hakkı ücretinin %45 faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, talebin fahiş olduğunu, emsal ve MESAM'ın tarife cetveline göre ödeme yapılabileceğini belirtmiştir.

Mahkemece, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, davacıya ait eserin izinsiz kullanıldığının uyuşmazlık dışı olup, davacının popülaritesine, telif ücreti piyasası ve FSEK 68. madde hükümlerine göre talep edilen 25,000,000 liranın ılımlı ve uygun olduğu ve ticari faiz oranının da %30 olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne, 25,000,000 liranın dava tarihinden yürütülecek %30 kanuni faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir...

2-Davacılar vekilinin temyizine gelince, davalı tacir olup, TTK 3. ve 21. maddeleri karşısında, taraflardan yalnız biri için ticari iş mahi-

⁷⁷ 11.HD., 24.6.2004, E. 2003/11182, K. 2004/7064

yetinde olan mukavelelerin aksine hüküm olmadıkça diğeri için de ticari iş sayılmasına ve ayrıca 3095 sayılı Yasanın 2/3. maddesinde arada sözleşme olmasa bile, ticari işlerde temerrüt faizinin T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faizi oranına göre istenebileceğinin belirtilmiş olmasına, davacının %45 oranı belirttiğinden istem ile bağlı kalınarak, bu oranda reeskont faizine hükmetmek gerekirken %30 yasal faize hükmedilmesi doğru olmamış, bu nedenle kararın davacı yararına bozulması gerekmiş ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK'un 438/7. maddesi gereğince hükmün düzeltilerek onanması cihetine gidilmiştir.⁷⁸

Yargıtay'a göre; FSEK madde 68/2 gereğince öngörülen farazi sözleşme ilişkisi gereğince, önce eserin ve eseri meydana getirenin özellikleri itibariyle eserin değerini etkileyen bütün faktörler ve çoğaltılan nüsha sayısı nazara alınarak normal şartlarda oluşturulacak sözleşme uyarınca eseri çoğaltacak olanın hak sahibine vermesi gereken para miktarının bulunması ve sonra bunun üç katının hesaplanması gerekmektedir⁷⁹. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na göre, *"somut olayın özelliğine göre, varsayımsal sözleşme bedeli tayin edilirken eser sahibinin bilimsel/sanatsal yeteneği, üretim kapasitesi gibi sübjektif nitelikleri, eserin beğeni ölçüsü, sayfa sayısı, estetik görünümü, niteliği ve niceliği, ihlal edilen mali hakkın türü, coğrafi kapsamı, ihlal süresi, ihlalin yapıldığı vasıta, bunun geniş halk kitlesine ulaşımı gibi objektif kriterler eser sahibinin (ihlali...) yapanla sözleşmesi olması halinde, bu sözleşme uyarınca isteyebileceği bedel ve bunun faizi 68. madde uyarınca açılacak davada dikkate alınacaktır"*⁸⁰.

Yargıtaya göre; üç kat bedel tazminatı ile davacı ve davalı arasında bir sözleşme ilişkisi kurulduğundan, davacı tecavüzün men'ini isteyemez⁸¹.

⁷⁸ Yargıtay 11. H.D, 24.12.1996, E. 8673, K. 1996/9075, SULUK/ORHAN, age., 878-879.

⁷⁹ 11. H.D., 06.03.2000 T. 1999/9978 E., 2000/1893 K. (YKD., C. 28, S.10 EKİM 2000, s. 1543-1545).

⁸⁰ YHGK, 20.03.2002 T., 2002/11-176 E., 2002/214 K. (YKD., C.28, S.6 HAZİRAN 2002 s. 840-845). Naklen ARIDEMİR, age., s. 190.

⁸¹ "... Olayda davacı bedel istemiş ve zikredilen FSEK 68. maddesi hükmü gereğince davacı yararına bedele hükmedilmiş olmakla artık tecavüzün men'i isteminde bulunamaz. Zira bedeli %50 fazlasıyla almış olmakla taraflar arasında sözleşme yapılmış gibi bir durum hasıl olmakta ve davalının kullanma veya çoğaltma durumu yasal hale gelmektedir. 5846 sayılı Yasanın 68. maddesinin düzenleme şeklindeki amacında bu olduğu anlaşılmaktadır. O halde mahkemece bedele hükmedildiğine göre, davanın tecavüzün men'i bölümünün reddi gerekirken ona hükmedilmesi

Yargıtay kararlarına göre; taraflar arasında önceden bir sözleşme ilişkisi varsa ve bu sözleşme devam ediyorken hak sahibinin hakları sözleşmede belirtilen sınırların dışına çıkılıp aşılmışsa bu durumda FSEK madde 68 uyarınca tazminat istenemeyecektir⁸².

Uygulamada genel olarak davacılar, hak ihlallerinin karşılığında tazminat olarak ne talep ettiklerini tam olarak belirtmemektedirler. Bu durumda hakim, HUMK madde 75 gereğince davacının 68. maddedeki üç katı tazminatı mı, 70/2'deki maddi tazminatı mı yoksa 70. maddenin 3. fıkrasındaki kâr yoksunluğunu mu talep ettiği hususunda davacıdan açıklama istemelidir⁸³.

Bu davada davacılar, mali hakları tecavüze uğrayan eser ve bağlantılı hak sahipleridir.

Eserleri açısından eser sahipleri; işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarının saldırıya uğraması halinde bu davaları açabilirler. Aşağıda açılan tazminat davalarından bazı örnekleri sunuyoruz:

“Davacı vekili, müvekkili (meslek birliğinin) üyesi bulunan eser sahiplerinin FSEK'ten doğan haklarını ve ortak çıkarlarını korumayı devraldığını, davalının, üyesi bulunan eser sahiplerinin eserlerini kullanarak “Zeki Müren Solo” isimli yapıyı müzik kaseti olarak çoğaltıp piyasaya sürdüğünü ve kazanç sağladığını, kasetin dağıtıldığı dönemde MESAM üyesi bulunan eser sahiplerinin mali haklarının davalı tarafından ödendiğini, ancak anılan yapımda eseri kullanılan ve sonra MESAM'a üye olan Mehmet Bitmez'in mali haklarının ödenmediğini ileri sürerek 4,536,000 TL maddi, 3,000,000 TL manevi tazminatın banka iskonto faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir...”

bozmayı gerektirmiştir.” Yargıtay 11. H.D. 7.7.1987, E. 1987/1836, K. 1987/4131, SULUK/ORHAN, age, s. 787.

⁸² 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 68 nci maddesine dayanılarak tazminat istenebilmesi için; eserin eser sahibinin izni olmadan basılmış olması gerekmektedir. Taraflar arasında daha önceden imzalanmış sözleşmeye dayanılarak eserin basım hakkı davalıya bırakıldığına göre, izinsiz basımdan söz etmek ve dolayısıyla FSEK'nun 68 nci maddesine dayanılması mümkün değildir. Mahkemece, yukarıda 1 nolu bentte açıklanan araştırma sonucunda ortaya çıkacak durum gözetilerek, feshin hüküm doğurduğu tarihe kadar sözleşme hükümlerine, sonraki dönem için ise FSEK'nun 68 nci hükümlerine göre tazminat hesabı yaptırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hukuki nitelenmede hata yapılarak karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay 11. H.D. 2003/157 E. 2003/5613 K.

⁸³ SULUK/ORHAN, age., s. 801.

Mahkemece; iddia, savunma, dosyadaki yazılı kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre; davalının yayınladığı kasette yer alan “Seni Sordum Yıldızlara” adlı eser için mali haklarını korumakla görevli ve yetkili bulunan davacı kuruma telif ücreti ödemediği, davalının bu fiili nedeniyle 4,536,000 TL zarara uğradığı, ancak olayda manevi tazminat koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 4,536,000 TL’nin 1.6.1992’den itibaren reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.^{84,}

Temsil hakkı ile ilgili bir örnek karar.

“Davacı vekili, müvekkili koruması altındaki yerli ve yabancı müzik eserlerinin, davalı tarafından, müvekkilinden yazılı izin alınmaksızın ve telif ücreti ödenmeksizin ticari amaçla otelinde kullanıldığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1000 USD alacağın FSEK 68. maddesi uyarınca üç kat artırılarak 3000 USD olarak tespit tarihinden itibaren işleyecek döviz faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilince işletilmekte olan otelde müzik yayını yapıldığını, ancak, tüm müzik yayınlarında yasal koruma süresi devam eden eserlerin kullanımından kaçınıldığını, davacının iddia ettiği kadar alan bulunmadığını, disconun başka bir kiracı işletme tarafından kullanıldığını, müvekkilinin radyo istasyonundan yapılan yayın listesini ve toplantı salonunda çalınan müzik yayınlarını tespit etme imkanının olmadığını belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran, **davalı otelin her odasında P... FM radyosuna bağlı bir adet radyo alıcısının bulunduğu, mekanik araçlarla radyodan P... FM ve M.. FM’den yararlanıldığı, yapılan tespitte bulunan Jennifer Lopez isimli şarkıcıya ait kaset nedeniyle, anılan şarkıcının telif hakkının ASCAP ve BMI ile yapılan temsil anlaşmaları sonucu davacı MESAM tarafından istenebileceği,** davacının; davalıya ait otelde 508 yatak, 2 restoran, 3 adet bar, 1 adet disco için **toplam 9022 USD telif ücreti alacağının doğduğu, FSEK 68. madde uyarınca bu ücretin 3 katının 27.066 USD olarak belirlendiği gerekçesiyle** taleple bağlı kalınarak, davanın kabulü ile yıllık 1000 USD telif ücreti alacağının FSEK 68. maddesi uyarınca 3 kat artırılması suretiyle belirlenen 3000 USD nin haksız fiil tarihi olan 2.5.2000 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte fiili **tahsil tarihindeki TL karşılığının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.** Karar onanmıştır^{85.}”

Bazen davacılar, mahkeme harçları fazla tutmasın diye düşük bir tazminat miktarı ile pilot davalar açmaktadırlar. Ancak aşağıdaki Yargı-

⁸⁴ Yargıtay 11. H.D., 16.1.1995, E. 1994/6520, K. 1995/64, SULUK/ORHAN, age, s. 175.

⁸⁵ Yargıtay 11. H.D., 2003/12917 E. 2004/9335 K.

tay kararında görüleceği üzere bu konuda dikkatli olmakta ve FSEK madde 68 gereği isteyeceği tazminat için fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmakta fayda vardır.

“Davacı vekili, söz ve müziği müvekkiline ait “Söz Verip Gelmemiştin” adlı eserin davalılardan M.K. tarafından “...” adlı kasette “Hele Zalim” adı altında okunup, diğer davalı tarafından piyasaya sunulduğunu, davalılar tarafından yapılan bu müdahalenin önlenmesi ve maddi-manevi tazminatların tahsili için fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla açılan davada taleple bağlı kalınarak, 1,000,000,000 TL maddi ve 1,500,000,000 TL manevi tazminatın tahsiline karar verildiği, anılan dosyada alınan bilirkişi raporunda müvekkilinin olağan telif ücretinin 1,428,571,429 TL olarak belirlendiğini, FSEK 68. maddesi uyarınca müvekkilinin olağan telif ücretinin 3 katını talep hakkı bulunduğunu ileri sürerek, bakiye 3,285,714,428 TL’nin 20.2.1998 tarihinden itibaren işleyecek reeskont oranında temerrüt faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, davaya cevap vermemişlerdir.

Mahkemece, iddia ve dosyadaki kayıtlara nazaran, asıl davada alınan bilirkişi raporunda davacının telif ücreti olarak isteyebileceği tutarın 1,428,571,429 TL olarak belirlendiği, bu davada hüküm altına alınan 1,000,000,000 TL’nin mahsubu sonucu davacı alacağına 428,571,429 TL olacağı, davacının her ne kadar FSEK 68. maddesine göre 3 misli tazminat talep etmişse de asıl davada 5,000,000,000 TL manevi tazminat talep edip, 1,500,000,000 TL manevi tazminata hükmedilmesi karşısında davacının bu yöne ilişkin talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle, **davanın kısmen kabulü ile 428,571,429 TL’nin 18.5.2001 dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.**

Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, davacıya ait mali haklara tecavüz nedeniyle oluşan maddi zararın tazmini istemine ilişkindir. Davacı tarafından açılan ilk davada, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla telif ücreti karşılığı 1,000,000,000 TL maddi ve 4,000,000,000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsili talep edilmiş, mahkemece de maddi tazminat yönünden taleple bağlı kalınarak karar verilmiştir. Açıklanmaya çalışıldığı üzere, **açılan ilk davada davacı olağan telif ücreti alacağının davalıdan tahsilini talep etmiş, FSEK’in 68. maddesi kapsamında rayiç bedel itibariyle uğradığı zararın en çok üç katını talep etmediği gibi, böyle talebe ilişkin haklarını mahfuz tuttuğundan da bahsetmemiştir.** Diğer bir deyişle, davacı ilk davada anılan yasal düzenlemenin kendisine tanıdığı hakkı kullanmamıştır. **Bu durumda, temyize konu işbu dava ile fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğundan bahisle artık asıl davada talep etmediği ve saklı tutmadığı bir alacağı talep etmesi mümkün değildir.** Her ne kadar Mah-

kemenin gerekçesi FSEK çerçevesinde isabetli değilse de, varılan sonuç doğru olmakla HUMK'nın 438/9. maddesi uyarınca kararın açıklanan değişik bu gerekçeyle onanmasına karar vermek gerekmiştir.⁸⁶

İcracı sanatçılar da kendi icraları için; tespit, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletimin kendilerinden izinsiz yapılması halinde bu davaları açabilirler.

Fonogram yapımcıları, eser ve icraları ilk kez kaydettikleri ses kayıtlarının (fonogramların) kendilerinden izinsiz olarak; çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi ve umuma iletilmesi hallerinde maddi tazminat davaları açabilirler. İşte, fonogram yapımcılarının televizyon yayınlarını izinsiz yapan kuruluşa karşı açtığı bir dava:

"Davacı vekili, müvekkili meslek birliğinin ekli listede belirtilen müzik yapımcısı firmaların bu güne kadar yayımlamış oldukları müzik yapımlarının kayıtlı bulunduğu; ses kasetleri, kompakt disk plak ve benzeri ses ve görüntü taşıyıcıların içerdiği tüm müzik yapıtları üzerinde sahip oldukları eser sahibine komşu hakların, müzik yapımcılarına ait bulunan bölümü kapsamında yer alan radyo ve televizyon ile yayın haklarını devir aldığını, ayrıca 31.12.1998 tarihine değin de bu haklarını devir etmeyi taahhüt ettiklerini, bu sözleşmenin 5846 sayılı Yasaya göre tam ruhsat hükmünde olduğunu, yine aynı Yasanın 80. maddesine göre müzik yapıtları yayınlayan radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarında kullandıkları ses kayıtları üzerinde eser sahibinin haklarına komşu hak sahibi olan müzik yapımcılarından yazılı izin almalarının şart olduğunu, **davalı şirketin izin almadan bu eserleri yayımladığını**, bu yayımların noter aracılığıyla tespit edildiğini ileri sürerek fazlaya ait haklarının saklı kalması kaydıyla **150.000.000 TL maddi tazminatın** tespit tarihi 26.11.1997 tarihinden itibaren reeskont faizi ile davalıdan **tahsiline**, ekli listede yer alan 59 adet yapımcı firmanın bu güne kadar yayımlamış oldukları ve 31.12.1998 tarihine kadar yayımlayacakları müzik eserlerinin yayınlarında kullanılmasının yasaklanmasına, mali haklara tecavüzün men'ine, kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı davaya yanıt vermemiştir.

Mahkemece bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından **150.000.000 TL'nin 26.11.1997 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline**, ekli listede yer alan 59 adet yapımcı firmalara ait müzik yapıtlarının yayınlarda kullanılmasının engellemesi suretiyle müdahalenin men'ine, **kararın ilanına karar verilmiştir.**⁸⁷

⁸⁶ Yargıtay 11. H.D, 15.3.2004, E. 2003/8247, K. 2004/2524, SULUK/ORHAN, age., 908-909.

⁸⁷ Yargıtay 11. H.D, 11.3.1999, E. 1998/9958, K. 1999/3423

Bir tane de mağazalarda fonogramlar kullanılarak izinsiz müzik çalınması hakkında bir tazminat davası kararı;

“Davacı vekili ...müvekkili fonogram yapımcılarının bağlantılı haklarını takip yetkisine sahip meslek birliği olduğunu, **(davalının)** haklarını takip yetkisine **(sahip olduğu fonogramları) izinsiz temsil ettirdiğini**, ... bu hususun Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2005/169 Değişik İş sayılı dosyasında 23.12.2005 tarihinde yapılan delil tespitiyle de anlaşıldığını ifade ederek, davalı fiilinin hukuka aykırı olduğunun tespitini, FSEK’nun 66. maddesi uyarınca tecavüzün ref’ini, fazlaya dair hakları saklı tutulmak kaydıyla FSEK’nun 68. maddesi uyarınca 2.046,00.- YTL **telif tazminatının** haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte **davalıdan tahsilini** ve ittihaz olunacak hükmün tirajı en yüksek tüm Türkiye ‘de (yayın yapan bir gazete ile yayınlanmasını talep etmiş), (davacı ..) günlü ıslah dilekçesiyle de talep ettiği telif tazminatı miktarını 4.026,00.- YTL ye yükseltmiştir.

Tüm dosya kapsamına, kısmen benimsenen bilirkişi mütalaa-sına göre;

... **davalıya ait 2500 metrekare kullanım alanı bulunan, giyim ürünlerinin satıldığı mağazada**, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2005/169 değişik iş sayılı dosyasında 23.12.2005 tarihinde yapılan delil tespitiyle müzik eseri işletme belgesi kapsamına göre davacı meslek birliği üyesi olan Müzik ve Yayın Ticaret Limited Şirketi adına 05/340 sayı ile tescilli “Power Hits 15” adlı albümde/fonogramda kayıtlı Kylie Minoque isimli icracı sanatçının okuduğu, **“You won’t forget about me” isimli müzik eserinin, bandrollü biçimde edinilmiş yasal bir CD’den temsil edildiğinin tespit olunduğu...**

-anılan yasa hükümleri gereğince, yasal yollardan edinilmiş de olsa fonogramların umuma açık mahallerde temsili için, FSEK’nun 41. maddesi uyarınca, ... hak sahibi meslek birlikleri ile FSEK’nun 52. maddesine uygun sözleşme yapmak zorunda oldukları,

-oysa davacı ile davalı arasında anılan biçimde yapılmış yazılı bir sözleşme bulunmadığı,

- **Şu hale göre, davacının haklarını takip yetkisine sahip olduğu fonogramların, davalı tarafından kendisine ait mağaza biçimindeki umuma açık mahalde izinsiz biçimde temsil ettirilmesinin FSEK’nun 41 ve 80. madde hükümleri karşısında hukuka aykırı olduğu,**

- eylem tarihinde yürürlükte bulunan FSEK’nun 41. maddesi ile bu madde uyarınca hazırlanıp yürürlüğe konulan “Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ... 2005 yılı Tarifesi”nin 7. Bölümü uyarınca, 0-100 metrekare için 286,00.- YTL, ek her metrekare için de 0,44.- YTL eklenerek yıllık kullanım bedelinin bulunması gerektiği,

-buna göre 2400 metrekare için (2400X0,44=) 1.056,00.- YTL olarak tespit olunacak miktara ilk dilim uyarınca tespit olunan 286,00.- YTL'nin de eklenmesi ile 1.342,00.- YTL bedeline ulaşılacağı,

FSEK'nun 68. maddesi uyarınca davacının bu bedelin üç katını (1.342,00X3=4.020,00) isteme hakkının bulunması sebebiyle isteyebileceği telif tazminatının da 4.020,00.- YTL olduğu tespit olunmuş, ... anılan miktara eylem tarihinden itibaren reeskont oranları üzerinden faiz işletilmesi gerektiği kanaatine varılmış,

-telif tazminatı isteminin de, tecavüzün ref'i yöntemlerinden biri olması sebebiyle davalı tecavüzünün telif tazminatı ödenmesine karar vermek biçiminde ref'ine karar verilmesi icap etmiştir.

Davanın kabulüne,

Davalının kendisine ait işyerinde, davacının takip yetkisine sahip olduğu müzik eserlerini, kayıtlı bulunduğu fonogramlardan izinsiz ve sözleşme olmaksızın temsil ettirmesinin, davacının eserden kaynaklanan haklarına tecavüz oluşturduğunun tespitine,

FSEK 'nun 68/1. maddesi gereğince (1.342,00X3=) 4.020,00.- YTL telif tazminatının eylem tarihi olan 23.12.2005 tarihinden itibaren işleyecek değişir oranlı reeskont faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı meslek birliğine verilmesine,

Davalının tecavüzünün ... ref'ine Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar alenen okunup usulen anlatıldı.”⁸⁸

Radio ve televizyonların da, eser ve icraları ilk kez kaydettikleri yayın kayıtlarının (yayınların) kendilerinden izinsiz olarak, çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi ve umuma iletilmesi hallerinde maddi tazminat davaları açabilecekleri FSEK madde 80’de düzenlenmiştir. Bu düzenleme doğrultusunda; genel hükümlere ve FSEK madde 70’e dayanarak yayıncılar yayınlarının izinsiz kullanılması halinde maddi tazminat davaları açabileceklerdir. Ancak FSEK madde 68’in 2008 yılında yapılan değişikliği esnasında; sözleşme bedelinin veya rayiç bedelin üç katı tazminat isteme olanağı açısından, radyo ve televizyoncular unutulmuştur. Maddenin başında “*Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden...*” ibaresinde, “yayınları” ibaresi olmadığından; radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarının; izinsiz olarak temsili, yayılması ve umuma iletilmesi hallerinde bu olanaktan faydalanamayacaktır. Fakat “eser niteliği taşıyan programlar”ı açısından radyo ve televizyonlar FSEK madde 68 kapsamı içinde üç katı tazminat davası açma olanağına sahiptir. Çünkü maddede “eser” kapsam dahilinde

⁸⁸ T.C. Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 12.04.2007 T., E. 2006/187, K. 2007/102

dedir. Çoğu radyo ve televizyon programı eser olduğundan, eser niteliğindeki radyo ve televizyon programının izinsiz mali haklarının ihlaline karşı (her bir program için ayrı ayrı) üç katı tazminat davaları açılabilir. Fakat, eser niteliği taşımayan radyo ve televizyon yayınları açısından maalesef üç katı tazminat davası açma olanağı FSEK madde 68’de yoktur. Kanaatimizce, madde metnine “yayınları” ibaresinin eklenmesi ile bu sorun çözülebilir.

Yine film yapımcıları da filmlerinin kendilerinden izin alınmadan çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi ve umuma iletilmesi hallerinde maddi tazminat davaları açabilirler.

4110 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra, gerçek kişilerin eser sahibi olacakları mutlak olarak benimsendiği için tüzel kişiler, “eser sahibi” olarak dava açma hakkını haiz değillerdir. Onlar, ancak mali hak sahibi olarak dava açabilirler. Tüzel kişi, 4110 sayılı Kanun değişikliğinden önceki hükümler gereğince ise, eser sahibi olabileceğinden, hukuk düzenimizde genel olarak tüzel kişilere de dava açma hakkı tanıdığı için, eser sahibi sıfatı ile belirtilen davaları açma hakkını haizdir⁸⁹.

Müşterek eser sahipleri (paylı eser sahipliği), kendi meydana getirdikleri bölümler için tek başına dava açabilecekleri gibi, eserin bütünü bakımından diğerlerini temsilen de dava açabileceklerdir⁹⁰. İştirak halinde eser sahipliği (el birliği halinde eser sahipliği)nde ise, FSEK madde 10/2’ye göre bir eser sahibinin eserin tümü bakımından dava

⁸⁹ Medeni Kanun madde 48 gereğince, tüzel kişilerin de hak ve fiil ehliyeti olduğu için tüzel kişiler de davada taraf olma ehliyetini haizdir. Manevi tazminat davasını ise, tüzel kişilerin açıp açmayacağı tartışmalıdır. Manevi tazminat davasının, kişilik haklarının ihlali sonucunda uğranılan manevi zararın, yani duyulan acı ve elemin karşılanması için bir yaptırım türü olduğunu belirten “objektif görüş” arasındaki tartışma gereğince, ilk görüş kabul edilirse tüzel kişiler elem ve acı duymayacağı için manevi tazminat davasında taraf ehliyetine sahip bulunmayacak, ikinci görüş kabul edilirse tüzel kişilerin taraf ehliyeti kabul edilebilecektir. Tüzel kişilerin dava ehliyetinin olduğu hakkında; SEROZAN, age., s. 33; ARPACI, age., s. 155, 164; BELEN, agm., s. 97; Salim ÜSTÜNDAĞ, Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, 7. Bası, İstanbul 2000, s. 288; Rona SEROZAN, “Manevi Tazminat İstemine Değişik Bir Yaklaşım”, Prof. Dr. Haluk TANDOĞAN’IN Hatırasına Armağan, Ankara 1990 s. 67-101. (Manevi Tazminat). Aksi görüşte; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, “Kişilik Gelişmeler Korumayan Manevi Tazminat Davasına İlişkin Yeni Gelişmeler”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul 1980, s. 144 vd. Naklen ARDEMİR, age., s. 192

⁹⁰ EREL, age., s. 293.

açma hakkı bulunmaktadır. Tazminat davası bakımından, birlik yararına hareket ederek tek başına dava açabilen eser sahibi, tazminat tutarı bakımından tek başına hareket edemez⁹¹.

Hak sahibinin ölümü halinde kimlerin dava açma hakkı olacağı doktrinde tartışmalıdır. TEKİNALP' e göre; bu dava hakkının kıyasen FSEK madde 19'da sayılan kimselere de tanınması gerekmektedir. ARKAN ise, hak sahibinin ölümü halinde mali hakların manevi haklardan farklı olarak terekeye dahil olacağını bu nedenle de dava açma hakkının mirasçılara geçeceğini savunmaktadır⁹².

Eser veya bağlantılı hak sahiplerinin mali haklarını ihlal fiili, haksız fiil niteliğinde olduğu için zamanaşımı bakımından Borçlar Kanunu madde 60 kıyasen uygulanacaktır.

Yetkili mahkeme ise HUMK'a göre belirlenmektedir. Manevi tazminat davası için bahsettiğimiz usul kuralları bu konuda da geçerlidir.

c. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Tazminat Davası

FSEK madde 70/3; maddi ve manevi hakları ihlal edilen kimsele-
rin, tazminattan başka tecavüz nedeniyle temin edilen kârın da kendisine verilmesini talep edebileceğini belirtmektedir. Bu durum gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin sonucudur. Bu talep, tazminattan farklıdır. Bu düzenleme ile getirilen şudur; hak sahibinin mali veya manevi haklarına tecavüz ederek kâr sağlayan kimse, bunu hak sahibinin menfaati için yapmamış olsa bile, hak sahibi açısından vekaletsiz iş görmüş olacaktır. Söz konusu hükmün esas kaynağı Borçlar Kanunu madde 414'tür. Ancak bu hükmün bazı özellikleri bulunmaktadır. Her şeyden önce; **“temin edilen kârın devri”**, ne tazminattır ne de zararı ve dolayısıyla tazminatı tayin etme veya hesaplama yöntemidir. Çünkü bu istem zarar olmasa da ileri sürülebilmektedir. **“Temin edilen kâr”** bazen tazminat ile istenmektedir bazen de onun yerine geçmektedir⁹³.

Yine, tazminattan farklı olarak, kârın devri için saldırganın kusuru da şart değildir. Haksız fiil hükümlerine göre, maddi tazminat talep ede-

⁹¹ ARSLANLI, age., s. 70; EREL, age., s. 62; ÖZTRAK, age., s. 46; BELEN, agm., s. 98.

⁹² ARKAN, age., 293

⁹³ Azra ARKAN (AKBIYIK), Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998. Naklen TEKİNALP, age., s. 314.

bilmek için uğradığı zarar miktarını ve mütecavizin kusurunu ispatlamakla yükümlü kalacak olan hak sahibi, bu külfetten kaçınmak istiyorsa, kârın devri talebini tercih etmelidir. Kârın devriyle hak sahibinin fiili zararı veya mahrum kaldığı kâr zararı karşılanabiliyorsa, artık maddi tazminata hükmedilmez; zira artık malvarlığında tazmini gereken bir zarar kalmamıştır⁹⁴.

FSEK madde 70/3' e göre kazanç devri talep edildiğinde madde 68'e göre tecavüzün ref'i davasıyla talep edilen bedel indirilir. TEKİNALP bedel ile neyin kastedildiğinin anlaşılmadığını; çünkü, 68. madde de iki bedelin var olduğunu, bedellerden birincisinin; hak sahibinin çoğaltılmış kopyalar ile çoğaltılmış araç ve kalıpların kendisine "uygun bir bedel" ile devrini istemesi halinde söz konusu olan bedel olduğunu, ikincisinin ise hak sahibinin bir varsayım olarak mütecavizle arasında bir sözleşme yapılsaydı isteyebileceği telif ücretinin üç katı şeklinde hesaplanan bedel olduğunu ancak burada kastedilen bedelin üç kat fazlaya ilişkin bedel olduğunu ifade etmiştir. EREL ise burada, her iki bedelinde ifade edildiği görüşündedir⁹⁵.

Yargıtay, aşağıdaki kararı ile, karşı tarafın kârının istenmesi halinde FSEK 68'de yazılı tazminatın istenemeyeceğini kabul etmektedir.

"Davacı vekili, ünlü bir şair olan müvekkiline ait "Bugün de Ölmedim Anne" isimli şiirin, davacının ismi belirtilmeksizin ve izinsiz olarak müzik eseri halinde işlenerek kaset yapıp satışa arz edildiğini, bu hususun FSEK madde 70 gereğince davacının maddi ve manevi haklarına tecavüz oluşturduğunu ileriye sürerek asıl davada 25,000,000 lira maddi, 25,000,000 lira manevi, birleşen davada da 87,500,000 lira maddi tazminatın iskonto faizi ile davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir. ...

Mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin kararın, davacı ve davalı A.K. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 9.5.1994 tarih ve 1993/5657-3992 sayılı kararı ile (davacının kazanç kaybına ilişkin zararı 80,509,090 lira olarak belirlenmiş olup, **davacı tarafından FSEK 70/3 maddesine göre davalı tarafın elde ettiği kâr istendiğine göre bu şekilde hesap ve kabul edilen bedelin FSEK madde 68 uyarınca %50 arttırılmasının doğru olmadığı** gerekçesiyle) davalı A.K. yararına bozulmuştur⁹⁶.

⁹⁴ EREL, age., s. 307

⁹⁵ TEKİNALP, age., s 20 No 99, EREL, age., s. 307

⁹⁶ Yargıtay 11. H.D, 24.4.1995, E. 1995/2410, K. 1995/3720, SULUK/ORHAN, age, s. 175-6.

Yargıtay bazen bu davalarda tazminatın yanlış hesaplandığını görerek net kârın bulunması yöntemini şu şekilde belirtmiştir:

“Dava, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkindir. Davacı, maddi tazminat olarak, “davalının elde etmesi mümkün görünen menfaatin karşılığı”nın” hüküm altına alınmasını dava etmiştir. Mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporlarında, ortalama kaset ve CD fiyatlarına göre, itiraz üzerine düzenlenen raporda ise, kaset ve CD’lerin toptan satış tutarlarından bunların fabrika satış fiyatları düşülerek tazminat hesap edilmiştir. Mahkemece bu hesaplar irdelenerek sonuca varılmışsa da, davaya konu kasetlerin ve CD’lerin piyasaya sürülmesine kadar davalı tarafından yapılan imalat giderlerinin belirlenip, bu kalemlerin fabrika çıkış fiyatı olarak saptanan meblağın kapsamında olup olmadığı; böylece davacı lehine hükmedilen tazminatın hesabında imalat masraflarının düşülüp düşülmediği konusunda Yargıtay denetimine elverişli bilgilere rastlanmamıştır. Mahkemece de bilirkişi raporundaki rakamlar baz alınarak sonuca varılmıştır. Değinilen nedenlerle ilgili olarak mahkemece bilirkişilerden ek rapor alınmadan hükme varılması hatalı olduğundan, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulmasına karar verilmek gerekmiştir⁹⁷.”

Bu davada davacı tecavüze uğrayandır. Eser sahipleri gibi bağlantılı hak sahipleri ve onlardan bu hakları devralan hak sahipleri de davayı açabilir. Dava mirasçılar tarafından da açılabilir.

Davalının tayini için FSEK madde 66/1 ve 66/2 deki hükümlere riayet edilmelidir. Ve dava işletme adına da açılabilmelidir.

Bu davalar haksız fiil’e dayandığından zamanaşımı; BK madde 60 gereğince, zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve herhalde fiilin gerçekleşmesinden sonra on yıllık sürelerdir.

Yetkili mahkeme ise; yukarıda bahsettiğimiz gibi HUMK’da yetkili olan davalının ikametgahı mahkemelerdir. Tecavüzün ref’i veya men’i için yetkili kılınan eser sahibinin ikametgahı mahkemesi bu talep açısından yetkili değildir.

6. Hukuk Davalarına İlişkin Genel Bilgiler

a. Görevli Mahkeme

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan 2001 tarihli değişiklikle FSEK’ten doğan davalarda miktara bakılmaksızın görevin ihtisas

⁹⁷ Yargıtay 11. H.D., 11.10.2004, E. 2004/393, K. 2004/9567, SULUK/ORHAN, age, s. 842-843.

mahkemelerinde olduğu hükme bağlanmıştır. İhtisas mahkemeleri hukuk davaları için Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir. Bu mahkemeler Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulmuştur. Diğer bazı büyük illerde de zamanla kurulacaktır. İhtisas mahkemelerinin kurulduğu yerlerde görevli mahkemeler ihtisas mahkemeleridir. Kurulmayan yerlerde ise; ihtisas mahkemesi olarak görev yapacak mahkemelerin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilen asliye hukuk mahkemeleri olduğu kararına varılmıştır. İhtisas mahkemeleri ile diğer mahkemeler arasındaki ilişki işbölümü değil, görev ilişkisidir.

İhtisas mahkemelerinin görevi kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her safhasında dikkate alınacaktır⁹⁸.

Aşağıda mahkemelerin görev ve yetkisini gösteren iki örnek karar bulunmaktadır:

“Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi Aşık Daimi’ye (İ.A.) ait *“Bugün Bize Pir Geldi”* adlı eserin davalılar tarafından izinsiz bir şekilde ve eserin müzik formu ve metnini değiştirmek suretiyle kaset ve CD yapılarak piyasaya sürüldüğünü, televizyon ve radyolar ile konserlerde kullanıldığını ileri sürerek, davalılardan şimdilik 3,000,000,000 TL maddi, 1,120,000,000 TL manevi tazminatın temerrüt faiziyle birlikte tahsilini, davalıların haksız fillinin önlenmesini, hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı İ.T. vekili ile R.... Müzik Yapım A.Ş. vekili davanın reddini savunmuş, diğer davalı duruşmalara katılmamış ve savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece, davanın FSEK ile ilgili olduğu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 15.10.2003 tarih ve 436 sayılı kararı ile Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin faaliyete geçtiği gerekçesiyle Mahkemenin görevsizliğine, talep halinde dosyanın görevli ve yetkili Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalı İ.T. vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillere gerektirici sebeplere ve **görevin kamu düzenine ilişkin olup, davanın her aşamasında nazara alınması gerekmesine göre,** davalı vekilinin yerinde bulunmayan tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir⁹⁹.”

⁹⁸ 11.HD., 28.3.2005, E. 2004/1641, K. 2005/2862.

⁹⁹ Yargıtay 11. H.D, 28.3.2005, E. 2004/1641, K. 2005/2862, SULUK/ORHAN, age., 965.

“Davacı vekili, Adana Ticaret Mahkemesi'ne açtığı davada, müvekkilinin söz yazarı olduğu “Bu Akşam Ölürüm” adlı şarkının, müvekkilince verilen muvafakatnamede izin verilmeyen şekilde Adana'da yapılan konserde okunduğunu, piyasaya sürülen kasette müvekkilinin adının tam kullanılmadığını, bu suretle mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek şimdilik 10,000,000,000 lira manevi, 1,000,000,000 lira maddi tazminatın temerrüt faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, müvekkillerinden Limited Şirket bakımından yetki itirazında bulunmuştur.

Mahkemece, görevsizlik kararı verilerek, dosyanın Adana Asliye 3. Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesi üzerine, bu Mahkemece verilen yetkisizlik kararı, Dairemizce, görevsizlik kararının kesinleşmesi ve tarafların başvurusunun beklemesi için, esasın kapatılarak, dosyanın iade edilmesi gerektiği belirtilerek bozulmuş, bozmaya uyulmuş, iade kararı verilmiş, dosyanın iade edildiği Adana Ticaret Mahkemesi'nce, görevsizlik kararı tebliğe çıkarılmış, davacı vekilinin süresinde başvurusu üzerine dosya, Adana Asliye 3. Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmiş, bu mahkemece yetkisizlik kararı verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

...Konserin Adana'da gerçekleştiği ve kasetlerin Adana'da da satışa sunulduğu iddia edilmekle, mali ve manevi haklara, haksız eylem niteliğindeki tecavüzün gerçekleştiği ileri sürülen yer itibarıyla, HUMK'nın 21. madde hükmü uyarınca Adana Mahkemeleri yetkilidir. Seçimlik haklara sahip olan davacı, davalıların ikametgahının bulunduğu yer itibarıyla yetkili olan mahkemede dava açmamakla tercihini bu yönde kullanmıştır.

Öte yandan, eser sahibinin 5846 sayılı FSEK'in 66/son madde hükmü uyarınca kendi ikametgahı mahkemesinde de dava açması mümkün olup, davacının kendi ikametgahı itibarıyla davasını açtığı Adana Mahkemeleri bu yönden de yetkilidir.

Kaldı ki, davalılar vekili, müvekkillerinden M. bakımından yetki itirazında bulunmamış olup, esasen bu davalı bakımından da mahkemenin yetkisi kesinleşmiştir.

Bu durumda, Mahkemece, davacının tercih hakkını doğru kullandığı kabul edilerek, davalılar vekilinin davalılardan ... Ltd. Şti. bakımından yaptığı yetki itirazının reddi ile, tüm davalılar bakımından davanın esasına girilmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, tüm davalılar bakımından yetkisizlik kararı verilmesi doğru olmamıştır¹⁰⁰.”

¹⁰⁰ Yargıtay 11. H.D, 29.11.2004, E. 2004/2379, K. 2004/11561, SULUK/ORHAN, age., 961-962.

b. Davacı

Eserleri açısından eser sahipleri; işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarının saldırıya uğraması halinde hukuk davaları açabilirler.

İcracı sanatçılar da kendi icraları için; tespit, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletimin kendilerinden izinsiz yapılması halinde hukuk davaları açabilirler.

Eser sahipleri ve icracı sanatçılar manevi haklarının ihlali halinde tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i, tespiti ve tazminat davalarını açabilirler.

Fonogram yapımcıları eser ve icraları ilk kez kaydettikleri ses kayıtlarının (fonogramların) kendilerinden izinsiz olarak; çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi ve umuma iletilmesi hallerinde hukuk davaları açabilirler.

Radyo ve televizyonların da eser ve icraları ilk kez kaydettikleri yayın kayıtlarının (yayınların) kendilerinden izinsiz olarak, çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi ve umuma iletilmesi hallerinde hukuk davaları açabilecekleri FSEK madde 80'de düzenlenmiştir.

Yine film yapımcıları da filmlerinin kendilerinden izin alınmadan çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi ve umuma iletilmesi hallerinde hukuk davaları açabilirler.

c. Davalıya İlişkin Ek Bilgiler

FSEK madde 66/2 gereğince, *“tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir.”* Burada BK madde 55'te düzenlenen *“başkasını çalıştıranların sorumluluğu”* halinde ve Türk Medeni Kanunu madde 50'deki *“tüzel kişilerin, organlarının eylemlerinden sorumluluğu”* hükümlerine paralel bir düzenleme söz konusudur¹⁰¹. Hü-

¹⁰¹ Borçlar Kanunu madde 55'te düzenlenen kusursuz sorumluluk, başkalarını emri altında çalıştıran kimselerin, kendisine yükletilmiş özen gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu esasına dayanmaktadır. Böyle bir özen gösterme yükümlülüğünün bir davranış kuralı olarak istihdam edenlere yüklenmiş olmasının dayanağı, istihdam edenlerin kendi hakimiyetleri altında iş gördürmek suretiyle yararlandıkları şahısların meydana getirdiği hasarlara da katlanmalarının hakkaniyet icabı olduğu düşüncesidir. Bu sorumluluğun şartları şunlardır: 1- Üçüncü şahıs bir zarar uğramalıdır, 2- Zarar, yardımcı kişinin hukuka aykırı fiilinden doğmuş olmalıdır, 3- Zarar, yardımcı kişinin çalıştırının işini görürken ika

kümde geçen temsilci, tüzel kişilerin organları¹⁰², müstahdem (yardımcı kişi) ise işletmede çalışan müdür, temsilci, işçi şeklinde anlaşılmalıdır¹⁰³. Ancak işletme sahibinin sorumlu olması, mali hakları ihlal edenlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Haksız fiillere ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanması söz konusu olduğunda, BK madde 51'e göre; işletme sahibi ile hakkı ihlal eden kişi müteselsilen sorumludur¹⁰⁴. BK madde 50'de haksız fiili ika edenlerin kusurlu sorumluluğu; BK madde 51'de ise, birden çok kişinin ayrı sebeplerden dolayı sorumlu olmaları hali düzenlenmiştir¹⁰⁵.

Birden çok kişi kusursuz olarak sorumlu ise hangi hükmün uygulanacağı Borçlar Kanunu'nda ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenmemiştir. Doktrine göre, bu durumda eksik teselsül kuralları uygulanacak; davacı, zararını dilediğince karşılayacak; eksik kalan kısmı diğerlerinden talep edebilecektir¹⁰⁶. Buna göre, davacı, çoğaltma ve

edilmiş olmalıdır. İşletme sahibi, yardımcı kişinin seçiminde, ona talimat vermede, nezaret etmede özen gösterdiğini veya gerekli özeni gösterseydi bile zararın meydana gelmesini önleyemeyeceğini ispat etmekle sorumluluktan kurtulacaktır. Ayrıntılı bilgi için bakınız; OĞUZMAN/ÖZ, age., s. 564 vd.; Safa REİSOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. Bası, İstanbul 1998, s. 144-150. FSEK madde 66/2 hükmü "bir tekrardan ibaret olup esasında zaittir". (ARSLANLI, age., s. 210). Naklen ARIDEMİR, age., s. 177.

¹⁰² Organların hukuki işlem ve eylemlerinden ötürü tüzel kişinin sorumluluğu, Medeni Kanun madde 50'de düzenlenmiştir. Ancak "MK madde 48/2 kuralı (yeni MK madde 50/II) tüm önemine ve ağırlığına karşın, sorumluluk yaratıcı bir talep ya da bağımsız bir sorumluluk dayanağı değildir. Tek başına anlam taşımayan, kendi kendine yetmeyen, "koltuk değneği" benzeri, salt "sorumluluk doldurucu" bir "refakat kuralı"dır ancak ayrı ve özel bir sorumluluk kuralı...eşliğinde tüzel kişinin sorumluluğuna yol açabilir." (SEROZAN, age., s. 43). Bu sebeple, MK madde 50 kuralı, BK madde 55 ile birlikte değerlendirilmelidir. TOPALOĞLU, age., s. 108. Ayrıca bakınız; Hüseyin HATEMİ, Kişiler Hukuku Dersleri, İstanbul 2001, sh. 139 vd. Naklen ARIDEMİR, age., s. 177.

¹⁰³ YARSUVAT, age., s. 225. Naklen ARIDEMİR, age., s. 184.

¹⁰⁴ ARSLANLI, age., s. 210; EREL, age., s. 295. Naklen ARIDEMİR, age., s. 177.

¹⁰⁵ KOCAYUSUFPŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, HATEMİ, age., s. 121 vd. Naklen ARIDEMİR, age., s. 179.

¹⁰⁶ Bazılarına göre, Borçlar Kanunu madde 51 doğrudan uygulanmalıdır. Bkz; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993, s. 706. Bazılarına göre ise, BK madde 51 kıyasen uygulanacak olduğu için BK madde 51/II burada uygulanmayacaktır. Bakınız; OĞUZMAN/ÖZ, age., s. 676. Naklen ARIDEMİR, age., s. 179.

yayma haklarını birden çok kişi ihlal etmişse, bunlardan birine, birkaçına veya hepsine karşı dava açabilecek, sorumlulardan birisi sorumluluğunu yerine getirince ve tazminatı ödeyince, diğer sorumlulara rücu edebilecektir. Burada BK madde 51/2 uygulanmayacağı için hakim, rücu sorununun nasıl çözümleneceğini takdir edecektir¹⁰⁷.

Tazminat davalarında ise, bu yönde bir hüküm olmadığı için genel hükümler uygulanacaktır. Çünkü maddi tazminat davaları ile ilgili olan FSEK madde 70, genel olarak haksız fiil hükümlerine atıfta bulunmakta olduğu için kusursuz sorumluluğa ilişkin hükümler, koşulları uyduğu sürece burada da uygulanabilecektir. Tazminat davaları dışındaki davalarda bu yönde bir açıklık var iken, tazminat davalarında açıklık olmaması hukukun genel hükümlerinin göz ardı edilebileceği anlamına gelmez. Zaten FSEK madde 66/III hükmünün ayrıca düzenlenmesinin bir anlamı olmadığı da belirtilmiştir¹⁰⁸. Kusursuz sorumluluk hallerinde de (BK madde 55), kusursuz sorumluya karşı maddi ve manevi tazminat davası açmak mümkün olabilecektir¹⁰⁹.

Ayrıca ihlal, davacının birden çok eserine yönelikse, her bir eser bakımından davacının, ayrı talepte bulunma hakkı bulunmaktadır. Çünkü her bir davranış, ayrı bir hak ihlalidir¹¹⁰.

¹⁰⁷ BK madde 51/II gereğince, rücu sonucunda ilk önce kusurlu sorumlulara en son kusursuz sorumlu olanlara başvurulacaktır. Ancak bu hüküm hakime yol gösterici niteliktedir. (OĞUZMAN/ÖZ, age., s. 674). Ayrıca bakınız; Andreas von TUHR, Borçlar Hukukunun Umumi Kısım, C.I-II, Çev: Cevat EDEGE, Ankara 1983, s. 408 vd. Naklen ARIDEMİR, age., s. 179.

¹⁰⁸ ARSLANLI, age., s. 210.

¹⁰⁹ OĞUZMAN/ÖZ, age., s. 563, 649; EREL, age., s. 303. Aksi görüşte olan KAYPAKOĞLU'na göre, maddi tazminat davaları bakımından, FSEK madde 70/II'de "tecavüz edenin kusuru"ndan açıkça bahsedilmesi bu yoruma imkan vermez. Ancak maddi tazminat davalarında, manevi tazminat davalarının aksine, kusur koşulunun aranması isabetli değildir. (KAYPAKOĞLU, age., s. 162-163). Naklen ARIDEMİR, age., s. 179.

¹¹⁰ "Davacı taraf, dava dilekçesinde açıkça, davacının "Maskeli Balo" isimli yapıtındaki 11 ve 12 nolu eserlere haksız tecavüz olduğunu ileri sürerek, iki eser bazında tazminat talebinde bulunduğu halde, mahkemece, bu hususta bir irdeleme ve gerekçe gösterilmeden tek eser üzerinden...hükmedilmesi doğru olmamıştır." 11.HD, 03.02.2000 T., 1999/7019 E., 2000/616 K. sayılı kararı (Yayımlanmamıştır). Naklen ARIDEMİR, age., s. 179.

d. Zamanaşımı

Eser sahibinin dava haklarının hukuki kaynağı haksız fiil olarak değerlendirildiğinde; zamanaşımı, zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her durumda fiilin gerçekleşmesinden itibaren on yıl olarak kabul edilmektedir¹¹¹. Eserin izinsiz çoğaltılması genellikle gizli olarak yapıldığı için çoğaltma hakkına yönelik tecavüzün niteliği, kapsamı ve saldırıda bulunan kişi kesin olarak belirlenemez. Bu nedenle, zamanaşımı, saldırının kesin olarak öğrenildiği, çoğaltılmış nüshaların yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır¹¹². Şayet haksız fiil aynı zamanda bir suç teşkil etmekte ise, suç için bir ceza zamanaşımı öngörül-müşse ve bu diğerinden daha uzun ise ceza zamanaşımı uygulanacaktır¹¹³ (BK md. 60).

Yargıtay’a göre, “haksız eylem sürdükçe ve haksız eyleme konu ürünler piyasada bulundukça zamanaşımı işlemez”¹¹⁴.

Yargıtay’ın 11. HD., 28.06.1973 T., 1973/2648 E., 1973/3052 K.; 15.06.2000 T., 2000/3342 E., 2000/5524 K.; 07.12.2000 T., 2000/7666 E., 2000/9770 K. sayılı kararlarında; fikri haklara tecavüz bir haksız fiil teşkil ettiği için, akdi zamanaşımının uygulanamayacağı ve BK madde 60 gereğince bir ve on yıllık zamanaşımı sürelerinin uygulanacağı belirtilmiştir¹¹⁵. Ancak Yargıtay 05.12.2000 T., 2000/7580 E., 2000/9694 K. sayılı yayımlanmamış kararında, FSEK madde 68/1 uyarınca açılan ve “maddi tazminat” olarak nitelendirilen talep hakkında verdiği bir ka-

¹¹¹ TOPALOĞLU, age., s. 113; KAYPAKOĞLU, age., s. 165; Levent YAVUZ, “ Telif Hakları İle İlgili Olarak Mahkemeler Tatbikatı”, Çoğaltma Paneli, Ankara 2000, s. 25-30. Naklen ARIDEMİR, age., s. 181.

¹¹² ARSLANLI, age., s. 220; RESİSOĞLU, age., s. 204.

¹¹³ 11. H.D., 29.05.1980 T., 1980/213 E., 1980/2762 K. (ABD., C.37, 1980, sh. 504-505). Naklen ARIDEMİR, age., s. 181.

¹¹⁴ 11. H.D., 09.10.2000 T., 2000/6431 E., 2000/7566 K. (TEKİNALP, age., s. 279, N.76). M. Kemal OĞUZMAN, “İsviçre ve Türkiye’de Medeni Kanun ve Borçlar Kanununda Şahsiyetin Hukuka Aykırı Tecavüze Karşı Korunması ve Özellikle Manevi Tazminat Davası Bakımından Yapılan Değişiklikler”, Prof. Dr. Haluk TANDOĞAN’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s. 7-54. Naklen ARIDEMİR, age., s. 181.

¹¹⁵ 11.HD., 28.06.1973 T., 1973/2648 E., 1973/3052 K. (TUNÇOMAĞ, age., s. 1121); 11.HD., 07.12.2000 T. 2000/7666 E., 2000/9770 K.; 11.HD., 15.06.2000 T., 2000/3342 E., 2000/5524 K. (Kararlar yayımlanmıştır).

rarda, BK madde 125 gereğince on yıllık zamanaşımının uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Görüldüğü gibi Yargıtay kararları çelişkilidir.

ARIDEMİR'e göre; fikir ve sanat eserlerinden doğan davalar, eser sahibinin mutlak haklarına yönelik tecavüzü durdurma, önleme ve meydana gelen zararların tazmini amaçları ile öngörülmüş bulunmakta ve mutlak haklara yönelik hukuka aykırı faaliyetler "haksız fiil" niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, FSEK, zamanaşımı bakımından, açık bir hükme yer vermediği için BK madde 60 gereğince bir ve on yıllık zamanaşımı süreleri uygulanmalıdır¹¹⁶.

B. CEZA DAVALARI¹¹⁷

Fikri mülkiyet haklarına ilişkin ceza maddeleri, uygulamadan kaynaklanan çeşitli sorunlar ve özellikle üç aydan bir yıla kadar olan hapis ve para cezalarının caydırıcılığının bulunmaması sebebiyle 3.3.2004 tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucu eser sahiplerinin ve bunları devralan kişilerin mali ve manevi haklarına tecavüz edenler için iki yıldan başlayıp altı yıla varan oldukça ağır hapis ve 50.000 TL ile 200.000 TL arasında para cezaları getirilmiştir. Ancak bu kez de yasa uygulayıcılarının "iki yılın üstündeki hapis cezaları sonucu saldırganlara (amatör saldırganlar yanında otel ve radyo televizyonların sorumluları) ilk suçlarında bile çok ağır cezalar veriyoruz" şeklindeki itirazları sebebiyle FSEK'in ceza maddeleri 2008 yılında bir daha değiştirilmiştir. Şimdiki haliyle, cezanın alt sınırı bazı suçlarda altı aya ve genel olarak da bir yıla çekilmiş (hapis yerine adli para cezası da mümkün); ek olarak 50.000 TL ile 200.000 TL arasındaki para cezaları kaldırılmıştır. FSEK'te düzenlenen bu hükümler; "Manevi, Mali ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Halinde Oluşan Suçlar", "Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Suçlar" ve "Bandrole İlişkin Suçlar" olarak ayrı maddelerde sıralanmıştır.

Henüz konuya giriş yapmadan önce ceza ve hukuk yargılamalarının birbiri üzerindeki etkilerine de değinmekte fayda olduğu kanaatindeyiz. HGK'nun verdiği bir karara göre; ceza mahkemelerince saptanan maddi vakıalar hukuk hakimlerini bağlamaktadır. Ancak ceza davasında kusur yönünden alınan bilirkişi raporu hukuk hakimini bağlamamaktadır¹¹⁸.

¹¹⁶ ARIDEMİR age., s. 182.

¹¹⁷ Bakınız R. Yılmaz YAZICIOĞLU, *Fikri Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Suçlar*, İstanbul, 2009.

¹¹⁸ HGK., 17.6.1998, E. 1998/19-523, K.1998/508

1. Manevi, Mali ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Halinde Oluşan Suçlar

FSEK madde 71’de manevi, mali ve bağlantılı hakların ihlali halinde oluşan suçlar şu şekilde düzenlenmiştir:

“Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adli para cezasına hükmolunamaz.

3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde,

hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.”

2008 yılında FSEK’de değişiklik yapılmadan önce bu suçlar eser sahiplerinin haklarına yönelik olarak düzenlenmişti. Ek olarak FSEK 80. maddesinde de bağlantılı hak sahiplerine karşı işlenen suçlar düzenlenmişti. 2008 yılındaki değişiklikle eser ve bağlantılı hak sahiplerine karşı işlenen suçlar tek bir madde düzeni içinde sıralanmıştır.

Bu maddede önce mali haklara ilişkin saldırılar sonucu oluşan suçlar ve daha sonra da manevi haklara ilişkin saldırılar sonucu oluşan suçlar sıralanmıştır.

FSEK 71. maddesine göre; eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinin mali haklarına ilişkin saldırılardan doğan suçlar şu şekilde ayrıştırılabilir:

Eser sahibinin bir eserini, icracı sanatçının (şarkıcı/ yorumcu) bir icrasını, müzik yapımcısının (fonogram yapımcısı) ilk kez tespit ettiği bir fonogramı, film yapımcısının ilk kez tespit ettiği bir yapımı;

eser sahibi, icracı sanatçı, fonogram yapımcısı ve film yapımcısının yazılı izni olmaksızın;

- işlemek,
- temsil etmek,
- çoğaltmak,
- değiştirmek,
- dağıtmak,
- her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletmek¹¹⁹,

¹¹⁹ Müzik eserlerini izin almaksızın sitelerinde bulunduran ve dinlenmesine ve indirilmesine izin veren, bir yayın kuruluşu hakkında örnek sunalım.

“Yukarıda kimlikleri olan sanıklardan Mehmet B. ...’in ... Yayıncılık Dağıtım Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin yönetim kurulu başkanı, sanıklar M.A.K., S.S. Ç., S.K., M.S.’nin aynı şirketin yönetim kurulu üyesi oldukları, sanıklardan H.T.’in ... isimli bu şirkette genel müdür olarak görevli olduğu, sanık H.K.’nin ise hakkında şikayette bulunulan (...tvnet.com/playlist 2000) isimli internet sitesinin yöneticisi ve teknik müdürü olduğu,

Sanıkların mensubu bulundukları şirket tarafından yönetilen ve yukarıda ismi verilen İnternet Sitesinde MSG isimli Meslek Birliğinin üyesi bulunan eser sahiplerine ait eserlerin 01.04.2000 tarihinden itibaren bilgisayar ortamına kayıtlarının ve çoğaltmalarının dolayısıyla internet kullanıcılarına yayınlamalarının yapıldığı, gerek MSG tarafından gerekse Uluslararası Fonogram Endüstrisi tarafından yapılan ihtarlara

- her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayımlamak,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz etmek,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satmak,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri kiralamak suretiyle yaymak,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri ödünç vermek suretiyle yaymak,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri sair şekilde yaymak,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri ticarî amaçla satın almak,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri ithal etmek,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri ihraç etmek,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurmak,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri depolamak.

Bu suçları işleyen kişiler hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Müzik eserlerinin umumi yerlerde kullanılması üzerine hak sahipleri birçok kez ceza davaları açmışlardır. Ama bu davalar aşağıdaki eski bir karar sebebiyle ne yazıkki başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

“Dosya kapsamına göre suç tarihinde mağazada hangi eserlerin dinletildiği tespit edilemediği gibi, doğrudan kaset çalma ile ilgili olarak herhangi bir kazanç temini amaçlanmadığı, işyerinin kendi ticaret konusuna giren mal satımına ilişkin faaliyet gösterdiği cihetle eylemin ne suretle mesnet suçu oluşturduğu açıklanmadan yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.”¹²⁰

rağmen bu uygulamaya son verilmediği, böylece 5846 sayılı Yasaya göre MSG tarafından kullanılması gereken yayma hakkının ihlal edildiği, müşteki Meslek Birliği tarafından şikayet dilekçesinde ekli olarak ibraz edilen sanıklara ait İnternet Sitesi çıkışlarından anlaşılabacağından, ... Mahkemenizde sanıkların 5846 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca duruşmalarının yapılarak fiillerine uyan ve yukarıda gösterilen ilgili Kanun ve maddesi uyarınca ayrı ayrı tecziyelerine karar verilmesi kamu adına iddia olunur. (26.01.2001 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Basın No:2000/458 Mv. Hazırlık No: 2000/57673 Esas No:2000/ ... İddianame)”

¹²⁰ Yargıtay 7. CD, 13.5.2004, 2004/8236-6564 . ALBAYRAK, age., s. 109.

Ancak bu karardan sonra, geçen zaman içinde yapılan çalışmalar sonucu toplumda olduğu gibi yargı uygulayıcılarında da fikirsel ve sanatsal haklara ilişkin bilinç düzeyi yükselmiştir. Bu sebeple günümüzde, 2008 yılında yapılan FSEK 71. maddesine uygun, (hukuk davaları bölümünde belirttiğimiz) umumi mahal işletmecileri aleyhinde yeni kararlar verilmektedir. Çok yakında ceza davaları açısından da fikir ve sanat eseri sahiplerini ve bağlantılı hak sahiplerini koruyan ve işyerlerinde izinsiz müzik yapıtlarını kullanan umumi mahal yetkililerini cezalandırma kararları göreceğimize eminim. Şimdi ana konumuza geri dönelim.

FSEK'in 71. maddesi değiştirilirken bir hata yapılmıştır. Madde düzenlenirken FSEK madde 80 gereği bağlantılı hak sahibi olan radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarına karşı saldırılar ve yayınlardan izinsiz yararlanmalar suç kapsamına alınmamıştır. FSEK 71. maddenin bu haline göre; eser olmayan (ki eser olan televizyon yayınları yasal düzenleme kapsamındadır) radyo ve televizyon yayınlarını bağlantılı hak sahibi olan radyo ve televizyon kuruluşundan yazılı izin almadan işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan yayınları satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişiler ve bu eylemleri suç kapsamında değildir.

5728 sayılı Kanun ile FSEK 71. maddesinin değişikliği çalışmaları esnasındaki duyumlarımla oluşan kanaatimce, bu düzenlemede bulunan “yapım” ibaresi sadece filmler hedeflenerek koyulmuş ve televizyon yayınları veya televizyon yapımları kastedilmemiştir. Zaten televizyon yapımları eser niteliğinde ise FSEK madde 71 kapsamında korunmaktadır. Ama televizyon yayınlarının haklarını izinsiz kullanma eylemi suç değildir. FSEK 71. maddesini bu haline getiren 5728 sayılı Kanun’un gerekçesinde de televizyon yayınlarının izinsiz kullanımının 71/1. fıkrada sayılan suçlara dahil olduğuna ilişkin bir ibare yoktur.

Halbuki, bu düzenleme yapılırken maddenin 1. fıkrasında “*Bir eseri, icrayı, fonogramı, radyo veya televizyon yayını veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın*” denmiş olsaydı böyle bir hata ortaya çıkmazdı. Bu kitabı okuyan yetkililerin ve radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının harekete geçerek hızla bu hatayı düzelteceklerini umuyoruz.

FSEK 71. maddesinin bir başka küçük hatası ise “eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı (filmi) hak sahibinden yazılı izin almadan değiştirme suçu”nu mali hakların içinde düzenlemiş olmalarıdır. Eseri yetkisiz olarak değiştirmeyi engelleme eser sahibinin manevi bir hakkıdır. Yine FSEK 80 gereğince icracı sanatçı da bu hakka sahiptir. Öte yandan maddedeki “değiştirme suçu” ile ilgili bir başka sorun; bağlantılı hak sahiplerinin haklarının yazıldığı FSEK madde 80’de fonogram ve film yapımcısının, fonogramların ve filmlerin değiştirilmesini önlemek şeklinde bir manevi hakkının olmamasıdır. Ama FSEK 71. maddesi fonogramın veya filmin değiştirilmesini bir suç olarak almıştır. Halbuki, FSEK’de fonogram yapımcısı ve film yapımcısının böyle bir hakkı yoktur. Yine FSEK 71. maddesindeki suç kapsamına radyo ve televizyon yayınlarının izinsiz kullanılması da dahil edilirken radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarının değiştirilmesini engelleme hakkının olup olmadığı düşünülmelidir.

Mali Haklara ilişkin bir başka suç 71. maddenin son kısmında Ek 4. maddeye atıf yapılarak şöyle düzenlenmiştir: *“Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında¹²¹ bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükümlenir”*.

Bu maddede belirtilen suçlar şunlardır.

- Eser ve eser sahibi ile eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser, icra ve fonogram nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodları yetkisiz olarak ortadan kaldırmak veya değiştirmek.

- Eser ve eser sahibi ile eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser, icra ve fonogram nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar

¹²¹ FSEK Ek madde 4/1: Eser ve eser sahibi ile eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodlar yetkisiz olarak ortadan kaldırılamaz veya değiştirilemez. Bilgileri veya bu bilgileri temsil eden sayıları ve kodları yetkisiz olarak değiştirilen veya ortadan kaldırılan eserlerin asılları veya kopyaları dağıtılamaz, dağıtılmak üzere ithal edilemez, yayınlanamaz veya topluma iletilemez.

veya kodları yetkisiz olarak değiştirilen veya ortadan kaldırılan eserlerin asılları veya kopyalarını;

- * dağıtmak,
- * dağıtmak üzere ithal etmek,
- * yayınlamak
- * topluma iletmek.

- Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla bilgi içerik sağlayanlar tarafından, bu Kanunda tanınmış, eser sahiplerinin mali (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim) ve manevi (ilk defa kamuya sunuş hakkı, adının belirtilmesi hakkı, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı, eser sahibinin eseri elinde bulunduran ve sahip olana karşı eserden yararlanma hakkı), icracı sanatçıların mali (tespit, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim) ve manevi (icrasının sahibi olarak tanıtılma, icranın icracının itibarını zedeleyecek şekilde değiştirilmesi ve kişiliğe zarar verecek şekilde icranın kullanılması) haklarının, fonogram yapımcılarının mali (çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim) haklarının, radyo ve televizyon kuruluşlarının mali (tespit, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim) haklarının ve film yapımcılarının mali (çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim) haklarını ihlal etmeye (Ek 4. maddenin 3. fıkrasındaki başvuru/uyarı prosedürüne¹²² rağmen) devam etmek.

Yukarıdaki suçları işleyen kişilere üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Dipnotta da belirttiğim gibi, bu suçun düzenlenmesinde “ihlal etmeye devam etmek” ibaresinin ve fiilin belirtilmesi sonucu; bilgi içerik sağlayıcısının, hak sahibinin “ bu ihlali durdurun” şeklindeki başvurusu öncesinde ihlali yapılabileceği fakat FSEK Ek 4. maddesindeki hak sahibinin başvurusu/uyarısı ile ihlale son vermek yükümlülüğüne aykırı davranmak yani “ hak sahiplerinin haklarını ihlal etmeye devam etmek” suçu oluşturan eylem olmaktadır.

FSEK 71. maddesinin 2 no’lu fıkrasından itibaren manevi haklara karşı işlenen suçlar şu şekilde sayılmıştır:

- Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koymak. Bu suçu işleyen kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalan-

¹²² FSEK Ek madde 4/3: Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlali halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlale konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlalin durdurulmasını ister.

dırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adli para cezasına hükmolunamaz¹²³.

- Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunmak. Bu suçu işleyen kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

- Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunmak. Bu suçu işleyen kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak göstermek. Bu suçu işleyen kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak;

* çoğaltmak,

* dağıtmak,

* yaymak

* yayımlamak.

Bu suçu işleyen kişiler, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

2008 yılında FSEK de bulunan suçlara ilişkin 71, 72 ve 73. maddeler değiştirilirken, biri dışındaki tüm suçlar tek bir madde olan 71. maddeye toplanmış 72. maddede ise sadece bilgisayar programlarının izinsiz çoğaltılmasına engel olan programları etkisiz kılmaya yönelik programları ve teknik donanımları üretmek, satmak ve bulundurmamak suçu bırakılmıştır. FSEK 73. madde ise kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklik esnasında ne yazık ki iki adet suç 71. maddeye aktarılmayıp, unutulmuştur.

Bu suçlardan biri, eski 71/1. maddede yer alan “eser sahibi ve halefinin yazılı izni olmadan bir eseri umuma arz etmek” suçu ve 73/3 de

¹²³ Bu suç kaleme alınırken FSEK madde 80’in eski halinde var olan; başkasına ait icraya kendi icrası olarak ad koymak ve icracının icrasını itibarı zedeleyecek şekilde bozmak suçları unutulmuştur. FSEK madde 80’in eski halinde “bağlantılı haklara tecavüz edenlere” ceza verileceği düzenlenmişti. Bağlantılı hakların arasında da icracı sanatçının eserlerine ad koymak ve eserlerinin bozulmasını önlemek hakkı sayılmıştı. Şimdi bu haklar FSEK 71’e aktarılmamıştır. Bu sebeple, en kısa sürede bu suçların madde 71 kapsamına alınmasını diliyoruz.

yer alan “mevcut olmadığı veya üzerinde tasaffuf selahiyeti bulunmadığını bildiği veya bilmesi icabettiği mali hakkı veya ruhsatı başkasına devretmek veya vermek yahut rehin etmek veyahut herhangi bir tasarrufun konusu yapmak” suçudur. FSEK yeniden değiştirildiğinde eski Kanunda yeralan bu suçların FSEK düzenlemesi içine konulmasında zorunluluk bulunmaktadır.

2. Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Suçlar

FSEK madde 72’de bu suç şöyle düzenlenmiştir:

“Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Bu suç genel olarak bilgisayar yazılımlarının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasını engellemek için oluşturulmuş ek programları ve yazılımları etkisiz kılmaya yönelik programlar ve teknik donanımlar için konulmuştur. “Hak yönetim sistemi”ni etkisiz kılmaya yönelik söz konusu yazılımlar ve teknik donanımı üretmek, satmak ve kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurmak bu suç kapsamına girer.

3. Bandrole İlişkin Suçlar

Bilindiği gibi FSEK 81. maddesi gereğince; müzik ve sinema eserlerinin çoğaltılmış kopyalarına bandrol yapıştırılması zorunludur. Ayrıca, kolay kopyalanmaya müsait diğer eserlerin çoğaltılmış nüshalarına da eser veya hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandroller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bastırılır ve satılır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na belirlenen satış fiyatı üzerinden meslek birlikleri aracılığı ile de bandrol satışı yapılabilir.

Bandrol alınabilmesi için, bandrol talebinde bulunan hak sahibinin, yasal hak sahibi olduğunu beyan eden bir taahhütnameyi doldurması zorunludur. Bakanlıkça tespit edilen diğer evrak ve belgelerle birlikte başvuru yapılır. Bakanlık, bu başvuru üzerine başka bir işleme gerek kalmaksızın on iş günü içinde bandrol vermek mecburiyetindedir. Beyana müstenit yapılan bu işlemlerden Bakanlık sorumlu tutulamaz.

Bandrol yapıştırılması zorunlu kopya ve nüshaların tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya bu materyallerin do-

lum ve çoğaltımını yapan yerler, bu maddede belirtilen taahhütnamenin bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etmekle yükümlüdür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mülki idare amirleri bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların, bandrollü olup olmadıklarını her zaman denetleyebilir. Gerekli görüldüğünde, mülki idare amirleri re'sen veya Bakanlığın talebi ile bu denetimi gerçekleştirmek üzere illerde denetim komisyonu oluşturabilir. İhtiyaç halinde, bu komisyonlarda Bakanlık ve ilgili alan meslek birlikleri temsilcileri de görev alabilirler. Bu denetimler sırasında bu Kanunda koruma altına alınan hakların ihlal edildiğinin tespiti hâlinde 75 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Savcılıklarca el koyma işlemi yapılır.

İşte bu maddede belirtilen; müzik eseri sahiplerinin eserlerinin içinde yer aldığı ve fonogram yapımcıları ile icracı sanatçıların mali haklarını içeren kaset, cd gibi fiziki ürünlerin üzerine, sahte/korsan kopyaları engellemek için taklidi çok zor özel materyallere basılarak, üretilerek yapıştırılan bandrollerle ilgili olarak çeşitli şekillerde sahtecilik yapanlara karşı ve bandrollere ilişkin bazı yetkisiz eylemleri yapanlara karşı bu suçlar düzenlenmiştir. Bu tür bandrol sahtekarlıklarını ve bandrole ilişkin yetkisiz eylemleri suç olarak belirlemek hem hak sahibine ve hem de Ülkemizin kültür hayatına zarar verenlere karşı oldukça etkili bir koruma sistemidir.

FSEK madde 81'de bandrole ilişkin suçlar ve cezaları şöyle sıralanmıştır:

- Bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa arz eden, satan, dağıtan veya ticarî amaçla satın alan ya da kabul eden kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

- Bu Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler, Kabahatler Kanunu'nun 38 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılır.

- Sahte bandrol üreten, satışa arz eden, satan, dağıtan, satın alan, kabul eden veya kullanan kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

- Bir eserle ilgili olarak usulüne uygun biçimde temin edilmiş bandrolleri başka bir eser üzerinde tatbik eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

- Yetkisi olmadığı hâlde, hileli davranışlarla bandrol temin eden kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

- Yetkisi olmayan kişilere bandrol temin eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bandrol yükümlülüğüne aykırı eylemlerin aynı eserle ilgili olarak 71 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte yapılması halinde, fail hakkında sadece 71 inci maddeye göre cezaya hükmolunur. Ancak, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

Bu Kanunda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, ilgili tüzel kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri hükmolunur.

4. Ceza Davalarına İlişkin Genel Bilgiler

Bu kısımda ceza davalarına ilişkin bazı teknik konuları ve diğer kanunlarda bulunan genel bilgileri de özellikle hukuk uygulayıcılarını düşünerek vermek istiyoruz.

a. Şikayetçi ve Savcılık Soruşturması

FSEK madde 75; hakları tecavüze uğrayan eser sahibi, icracı sanatçı, fonogram yapımcısı ve film yapımcısının ceza davalarına şikayet yoluyla nasıl başvuracağını ve Savcılığın soruşturmasında neler yapılacağını şu şekilde belirtmiştir:

“71 ve 72 nci maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyetle bağlıdır. Yapılan şikâyetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikâyet süresi içinde Cumhuriyet başsavcılığına verilmemesi hâlinde kovuşturmayla yer olmadığı kararı verilir.

Bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikâyetle bağlı suçlar dolayısıyla başta Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve malî hak sahibi kişiler şikâyet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilirler.

Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kalır”.

Bir ceza davasını başlatmak için Savcılığa yapılacak şikayetin ne kadar süre içinde yapılacağı ve zamanaşımı süresi FSEK’de belirtilmediğinden bu konuda Türk Ceza Kanunu hükümleri belirleyicidir. Türk Ceza Kanunu’nun 73. maddesine göre; şikayete bağlı suçlarda suçtan zarar gören kişilerin altı ay içinde şikayet başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu süre geçirilirse Savcılıkça soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. Şikayet için altı aylık bu süre, şikayetçinin fiili ve faili (suç işlediği iddia edilen kişinin kimliğini) bildiği veya öğrendiği günden başlar.

Savcılık tarafından ceza davası açılabilmesi için şikayette bulunma yetkisi, hakları tecavüze uğrayan kimseye aittir. İhlal edilen manevi veya mali hak türüne göre, hukuk davalarını açmaya yetkili olanlar ceza davası için de şikayette bulunabilirler. Bu yetki; eser sahiplerine, bağlantılı hak sahiplerine, FSEK madde 19 ve 63 gereğince kanuni haleflerine ve mali hakkı yahut kullanma ruhsatını onlardan iktisap etmiş olan şahıslara ve meslek birliklerine aittir. Müsterek eser sahipliğinde, eser sahiplerinden her biri şikayette bulunmak yetkisini haizdir. İştirak halindeki eser sahipliğinde ise, tecavüze uğrayan eser sahipleri birliği olmakla beraber, ortaklardan her biri birlik menfaatlerini korumak için FSEK madde 10/2 gereğince yine kendi başına şikayete yetkilidir¹²⁴.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 73. maddesinde, suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olup, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı bulunan suçlarda fail ile mağdurun uzlaşmasına imkan sağlayan bir uygulamaya yer verilmiştir. FSEK’in 71 ve 72. maddelerinde düzenlenen mali ve manevi hakların ihlali suretiyle

¹²⁴ ARSLANLI, age., s. 222. Naklen EREL, age. (2009), s. 354

işlenen suçların takibi şikayete bağlı olduğundan, uzlaşma bu suçlar bakımından mümkündür¹²⁵.

TCK madde 73/son hükmüne göre; uzlaşmadan söz edilebilmesi için failin öncelikle suçu kabullenmesi ve doğmuş olan zararın tümünü veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi gerekmektedir. Bu koşul sağlandıktan sonra mağdur ile failin özgür iradeleri ile uzlaşmaları söz konusu olabilir. Bu suretle uzlaşmanın gerçekleştiği Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından saptandığında kamu davası açılmaz veya davanın düşürülmesine karar verilir. Uzlaşma sürecinin başlayabilmesi için şikayete hakkı olan kimsenin, şikayet süresi içinde bu hakkını kullanmış olması gerekmektedir.¹²⁶ Zira, ancak bundan sonra uzlaşma sürecinden söz etmek mümkün olabilecektir.

Fikirselsel ve sanatsal ürünlerin internet veya diğer ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla yayınlanması sonucu ilgili hakların ihlali halinde FSEK Ek 4. maddesi uyarınca, özel bir kovuşturma usulü öngörülmüştür. FSEK Ek Madde 4/2 fıkra düzenlemesi şöyledir:

“Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir”.

¹²⁵ EREL, age. (2009), s. 358

¹²⁶ ÖZDERYOL, age, s. 260. Naklen EREL, age. (2009), s. 358

b. Suçun Faili

5728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce, suç teşkil eden fiilleri işleyenler, Kanunun düzenleme tarzına göre aslı fail ve yardımcı fail şeklinde ayrılmaktaydı. Eski FSEK madde 74 hükmüne göre, aslı failler FSEK madde 71 ve 72 hükümlerinde belirtilen suçları ya bağımsız olarak veya bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemi sıfatıyla çalışırken işleyen kimselerdi. Suçun işlemesine engel olmayan işletme sahibi veya müdürü yahut hangi nam ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen idare eden kimsenin de fail gibi cezalandırılması; cezayı gerektiren fiil işletme sahibi veya müdürü yahut işletmeyi fiilen idare eden kimse tarafından emredilmişse, bunların da fail gibi cezalandırılmaları öngörül-müştü¹²⁷.

FSEK'in daha önce suçun failini düzenleyen "Fail" kenar başlıklı 74. maddesi, 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunun 578. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. FSEK madde 74 hükmü ilga edildikten sonra, Türk Ceza Kanunu'nun ilgililer hakkında "azmettirme" ve "suça iştirak" hakkındaki hükümleri (TCK madde 37-41) uygulanacaktır. FSEK madde 74'de Ceza Hukukunun genel prensiplerine aykırı olarak getirilen, objektif sorumluluk ve tüzel kişileri cezai yönden hükmedilen para cezasından müteselsil olarak sorumlu tutan düzenlemenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile uyumlaştırılması amacıyla yürürlükten kaldırılması isabetli olmuştur¹²⁸.

Bu değişiklikten sonra artık FSEK'te öngörülen suçlarda faili tespit ederken TCK'nın konuyu düzenleyen 37. ve devamındaki maddelerinden yararlanmak gerekecektir. Buna göre suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, işlenen suçun faili olarak; suçun işlemesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de yine fail olarak sorumlu tutulacaktır. (TCK madde 37). Ayrıca başkasını suç işlemeye azmettiren kimse TCK madde 38 uyarınca "azmettirme", başkasına suç işlerken yardımcı olan kimse ise TCK madde 39'a göre "yardım etme" sebebiyle sorumlu tutulacaktır¹²⁹.

¹²⁷ EREL, age. (2009), s. 354

¹²⁸ EREL, age. (2009), s. 354

¹²⁹ EREL, age. (2009), s. 355 ve YAZICIOĞLU, age., s. 309 vd.

Fikri hukukta suç faillerinin cezalandırılması Ceza Kanunu tarafından aranan manevi ve maddi unsurların gerçekleşmesine bağlıdır¹³⁰. 5728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce **failin kasden hareket etmiş olması** asli bir unsur sayılmış ve suçları belirten FSEK madde 71, 72 ve 73 hükümlerinin başında zikredilmişti. Ayrıca eski FSEK madde 73/bent 1, 2 ve 3 hükümlerinde belirtilen fiillerin, suç teşkil ettiğini bilmesi gereken kimseler tarafından icrası da, kasdın varlığına karine sayılmıştı. 2008 yılında FSEK'in ceza maddelerinde yapılan değişiklikten sonra FSEK'deki kast unsuru yerine Türk Ceza Kanunu'nun kast ve taksirli suçlara dair hükümleri uygulanacaktır (TCK madde 20-22).

Suçun işletme sahibi veya işletmeyi hukuken veya fiilen idare edenler tarafından emredilmiş olması halinde, temsilci veya müstahdemin cezalandırılabilmesi için emrin “suça azmettirme” niteliğinde olması gerekir (TCK madde 38). Zira azmettirme olmaksızın temsilci veya müstahdemin suç olduğunu bildikleri bir fiili icra etmeleri halinde yardımcı fail (TCK madde 39/(2)) sayılmaları düşünülemez. Sadece emretmek de aslı fail sıfatının kazanılması için yeterli değildir; çünkü temsilci veya müstahdem suç olduğunu bildikleri bir fiili icraya mecbur değildirler. İşletme sahibi veya idarecileri, müstahdem veya temsilcilerinin suç işlemesine mani olmamak sebebiyle cezalandırılacaklarsa, bu hususta ihtimali (olası) kast veya taksir unsurları aranacaktır (TCK madde 21/(2), 22)¹³¹.

Fail konusunda 2008 yılında getirilen yeni bir düzenleme de radyo ve televizyon yayınları ile FSEK'deki suçların işlenmesinde karşımıza çıkmaktadır. 3984 sayılı *Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun* 28/son maddesinde; “Radyo veya televizyon yayınları yoluyla işlenen suçlardan dolayı sorumluluk, Türk Ceza Kanunu'nun iştirak hükümlerine göre yayını yöneten veya programı yapanla birlikte sorumlu müdüre aittir. Ancak şirketi idare ve temsile yetkili kişilerin, sorumlu müdürün incelemesinden geçmeden veya rızası hilafına bir yayına karar vermiş olması halinde; kendileri sorumlu olurlar. Bu hüküm, yayın kuruluşunun bu Kanundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz” şeklinde özel bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme gereğince, eser sahiplerinin eserini, icracı sanatçının icrasını, fonogram yapımcısının fonogramını (kaset, cd, klip vs) izinsiz olarak yayınlayan veya yeniden

¹³⁰ ARSLANLI, age., s. 222. Naklen EREL, age. (2009), s. 355

¹³¹ EREL, age. (2009), s. 356

yayınlayan radyo veya televizyonlarda; açılan ceza davasında yargılana-
cak sorumlular, yayını yöneten, programı yapan kişiler ve/veya sorumlu
müdürdür.

Bu konuda son olarak şu bilgiyi de vermekte yarar görüyoruz.
FSEK madde 81 son fıkrası ve TCK madde 60 uyarınca; Kanunda ta-
nımlanan suçlar bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmişse, ilgili
tüzel kişi hakkında mahkemece Ceza Kanunu'nun tüzel kişilere özgü
güvenlik tedbirleri hükmolunacaktır.

c. Suç Konusu Eşyalara El Koyma, Zapt, Müsadere ve İmha

Bern Sözleşmesi'nde 16. maddeye göre; *“Birlik ülkelerinden bi-
rinde hukuki korumadan yararlanan eserler üzerindeki hakları ihlal
eden eser kopyalarına el konur”*.

İşte bu uluslararası sözleşme hükmüne ve XII no'lu bu Bölümün
ilk kısmında belirttiğimiz Roma Sözleşmesi'nin, TRIPS Anlaşması'nın,
WIPO Anlaşması'nın ve AB direktiflerinin etkin bir koruma isteyen
hükümlerine uygun olarak değiştirilerek düzenlenen Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gereğince, hak sahiplerinin hak-
larını korumak amacıyla, bir müzik eserinin izinsiz olarak çoğaltılan
kopyalarına ve suç eşyalarına Savcılık vasıtasıyla el koyulabilir, bunlar
zaptedilebilir, müsadere edilebilir ve neticede imha edilir.

FSEK'de yer alan ceza kovuşturmalarında el koyma ve müsadere-
ye ilişkin düzenlemeler; 5728 sayılı Kanun ile 2008 yılında yürürlük-
ten kaldırıldıktan sonra, ceza soruşturmaları ve kovuşturmalarında el
koyma ve müsadere hususlarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili
hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca, FSEK'in 68/II. maddesinde, bir özel
hukuk önlemi olarak, mali haklara tecavüz vukuunda, hak sahibinin
kendisine tanınan seçimlik haklardan biri olan programın çoğaltılmış
kopyalarının, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imha-
sını isteyebileceği yönündeki düzenleme ise halen geçerliliğini koru-
maktadır¹³².

Yeni TCK'da eski TCK'dan farklı olarak eşya müsadere (madde
54) ve kazanç müsadere (madde 55) şeklinde iki ayrı müsadere türüne
yer verilmiştir. Müsadere genel bir ifadeyle mahkumiyet sonucu olarak,
bir eşya veya kazancın devlete geçmesi demektir. Eşya müsadere,

¹³² EREL, age. (2009), s. 366

“iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak üzere, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan ya da suçun işlemesine tahsis edilen veya suç sebebiyle meydana gelen eşyanın devlete intikal etmesi”dir. Kazanç müsadere-i ise, “suçun işlemesi ile elde edilen yahut suçun konusunu oluşturan veya suçun işlemesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi ya da dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların devlete geçmesi”dir.¹³³ Halbuki el koymada, “eşyanın suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacı ile ya da müsadereye tabi olduğu için bir kimsenin elinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) öngörülen usullere göre ve rızası dışında geçici olarak alınması” söz konusudur¹³⁴. Müsadere edilen eşya mahkeme kararının kesinleşmesi ile birlikte devletin hüküm ve tasarrufuna geçer. Bundan sonra o eşya Adalet Bakanlığı’na çıkarılmış olan “Suç Eşyası Yönetmeliği” hükümlerine göre imha olunur¹³⁵.

Bu bakımdan el koyma müsadere-den farklı olup, zilyetliği geçici olarak ortadan kaldıran bir tedbirdir.¹³⁶ Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 123. maddesinde, ispat aracı olarak yararlı görülen veya eşya ya da kazanç müsadere-sinin konusunu oluşturan malvarlığı değerlerinin muhafaza altına alınacağı, yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyalara ise el konulabileceği hükme bağlanmıştır. Mali veya manevi hakların ihlal edildiğine dair hak sahibi tarafından yapılan usulüne uygun bir şikayet üzerine Cumhuriyet savcısı suça konu eşyalarla ilgili olarak CMK hükümleri uyarınca el koyma tedbirlerinin alınmasına yönelik gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür¹³⁷.

5728 sayılı Kanunla değişik FSEK madde 75/III hükmüne göre: “Şikayet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak

¹³³ Müsadere hakkında geniş bilgi için bkz. ÖZGENÇ, age., s. 684-693. Naklen EREL, age. (2009), s. 366

¹³⁴ Elkoyma ile ilgili geniş bilgi için bkz. Nurullah KUNTER/ Feridun YENİSEY/ Ayşe NUHOĞLU, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Onbeşinci Bası, İstanbul 2006, s. 932-957; Haluk ÇOLAK/Mustafa TAŞKIN, Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Güncellenmiş-Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2007, s. 533-610. Naklen EREL, age. (2009), s. 366

¹³⁵ EREL, age. (2009), s. 366

¹³⁶ Teknail ÖZDERYOL, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Suçlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006, s. 267 ve Mustafa ALBAYRAK, Fikir ve Sanat Eserleri ile Markalar Aleyhine İşlenen Suçlar, Ankara, 2003, s. 35

¹³⁷ EREL, age. (2009), s. 367

5721 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirlerinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi halinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yirmidört saat içinde hakim onayına sunulur. Hakim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kalır.”

Çoğaltılmış nüshaların ve kalıpların zabıt, müsadere veya imhası; bunların ancak mütecavizin, onunla birlikte müteselsilen sorumlu olanların yahut suça asli veya yardımcı fail sıfatıyla katılanların mülkiyetinde olması halinde mümkündür. Satışa çıkarılmamış olsa bile, üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan nüsha ve kalıplar üzerinde bu işlemler yapılamaz. Üçüncü şahısların kalıp ve nüshalar üzerinde fikri hukuktan doğan bir hakları olsun veya olmasın, bunların maddi maldaki aynı hakları saklıdır. Bu aynı hakkın mutlaka mülkiyet olması da gerekmez; kalıp veya nüshalar iyiniyetli bir üçüncü şahsa rehin edilmişlerse, zabıt müsadere veya imha yine mümkün değildir¹³⁸. Nitekim TCK madde 54/1 hükmü, üçüncü şahısların mülkiyet hakkını zabıt ve müsadereyle muaf tutmuştur ki, aynı esasın kalıp ve nüshaların imhasında da geçerli olması gerekir¹³⁹.

Buna karşılık yolsuz çoğaltılan nüshalar veya bunları çoğaltmaya yaran kalıplar; kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması ve satılması cürüm veya kabahat teşkil eden eşya niteliğinde ise, fail veya mütecavize ait bulunmasa bile zabıt, veya imha olunabilir (TCK madde 54/4)¹⁴⁰.

İhtiyati tedbir zımındaki zabıt, müsadere veya imha; ancak muhtemel bir tecavüzün önlenmesi veya başlamış bir tecavüzün durdurulması amacıyla hüküm altına alınır. O takdirde, mütecavizin kusuru aranmaz. Halbuki zabıt, müsadere veya imha hükmü hukuk ve ceza davaları sonucunda verilmişse, cezai bir nitelik taşır. Mali haklara tecavüz sebebiyle açılan tecavüzün ref'i davasında, ihtiyati tedbir olarak zabıt veya müsadereye karar verilmişse; hak sahibi lehine olağan telif ücretinin üç katının tazminine hükmolunması halinde, karar kaldırılarak kalıp ve nüshalar serbest bırakılmalıdır. Kanun bu durumda taraflar arasında bir sözleşme yapıldığı karinesine yer verdiği için (FSEK madde 68/I ve

¹³⁸ ARSLANLI, age., s. 215; AYİTER, age., s. 260. Naklen EREL, age. (2009), s. 367

¹³⁹ EREL, age. (2009), s. 367

¹⁴⁰ EREL, age. (2009), s. 367

son fıkra) tecavüz eden de kendi edimini yerine getirdikten sonra, Kanun dairesinde çoğaltma ve yayma haklarının sağladığı imkanlardan istifade edebilmelidir¹⁴¹.

Ceza davası sonucunda verilecek zabıt, müsadere veya imha kararının tabi olduğu yöntem hususunda; müsadere talebi hakkındaki yeni Türk Ceza Kanunu 54., 55., 60., 64., 70., 74. ve 75. maddeleri ile yeni Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 256-259. maddeleri hükümleri uygulanacaktır¹⁴².

d. Zamanaşımı

Eski FSEK madde 75/3 hükmünde, *“ceza davasının, fiilin icrasından itibaren bir yıl içinde açılması gerekir”* şeklinde bir dava zamanaşımı vardı. Hükmün 4630, 5101 ve 5728 sayılı kanunlarla tadilinden sonra ceza davasına ilişkin bu zamanaşımı hükmünün kaldırılması sebebiyle, artık Türk Ceza Kanunundaki cezanın miktarına göre dava zamanaşımı süresini belirleyen genel hükümler uygulanacaktır¹⁴³.

FSEK madde 75'in yeni haline göre; *“71 ve 72 nci maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyeteye bağlıdır. Yapılan şikâyetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin **şikâyet süresi içinde** Cumhuriyet başsavcılığına verilmemesi halinde kovuşturmayaya yer olmadığı kararı verilir”* şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.

Takibi şikâyeteye bağlı suçları düzenleyen 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu madde 73'e göre;

“(1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyeteye bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyetinde bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

¹⁴¹ ARSLANLI, age., s. 218. Naklen EREL, age. (2009), s. 367

¹⁴² EREL, age. (2009), s. 373

¹⁴³ EREL, age. (2009), s. 3734

(3) Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.

(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.

(5) İştirak hâlinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.

(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsî haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

(8) Suçtan zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olup, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bulunan suçlarda, failin suçu kabullenmesi ve doğmuş olan zararın tümünü veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur ile fail özgür iradeleri ile uzlaştıklarında ve bu husus Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından saptandığında kamu davası açılmaz veya davanın düşürülmesine karar verilir”.

Ceza davalarının tabi olduğu zamanaşımı ise TCK madde 66 hükmünde şöyle düzenlenmiştir:

“(1) Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası;

d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,

e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, geçmesiyle düşer.

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.

(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri de göz önünde bulundurulur.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; se-

çimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis cezası esas alınır.”

Böylece ceza (kamu) davası, FSEK madde 81/9. fıkrasındaki suçun üst sınırı yedi yıl olduğundan, onbeş yıl geçmekle; diğer maddelerde öngörülen suçlarda ise ceza üst sınırı beş yıl veya altında olduğundan, sekiz yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacaktır¹⁴⁴.

Ceza infazı (cezanın fiilen uygulanması) zamanaşımına gelince, TCK madde 68’e göre “*Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilemez.*

d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl,

e) Beş yıla kadar hapis ve adli para cezalarında yirmi yıl.

Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.”

e. Yetkili ve Görevli Mahkeme

2001 tarihli değişiklikle FSEK’ten doğan davalarda cezanın derecesine bakılmaksızın görevin ihtisas mahkemelerinde olduğu hükme bağlanmıştır. İhtisas mahkemeleri ceza davaları için Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesidir. Bu mahkemeler Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulmuştur. Diğer bazı büyük illerde de zamanla kurulacaktır. İhtisas mahkemelerinin kurulduğu yerlerde görevli mahkemeler ihtisas mahkemeleridir. Kurulmayan yerlerde ise; ihtisas mahkemesi olarak görev yapacak mahkemelerin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilen asliye ceza mahkemeleri olduğu karara varılmıştır. İhtisas mahkemeleri ile diğer mahkemeler arasındaki ilişki işbölümü değil, görev ilişkisidir.

İhtisas mahkemelerinin görevi kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her safhasında dikkate alınacaktır¹⁴⁵.

¹⁴⁴ EREL, age. (2009), s. 361

¹⁴⁵ 11.HD., 28.3.2005, E. 2004/1641, K. 2005/2862

XI. TÜRK HUKUKUNDA HUKUK VE CEZA DAVALARINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 77, 78, 79. ve Ek 4. maddelerinde hukuk ve ceza davaları için müşterek uygulanabilecek bazı tedbirlere yer vermiştir. Bunlar ihtiyati tedbir kararı, mahkemenin verdiği mahkûmiyet hükmünün ilanı ve izinsiz digital iletim halinde erişimin engellenmesidir.

A. İHTİYATİ TEDBİRLER

Roma Sözleşmesi'nin 26. maddesine göre; sözleşmeyi imzalayan her imzacı devlet, kendi Anayasa hükümlerine göre bu Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder.

WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması'nın 23. maddesine göre;
“(2) *Âkit taraflar, bu Andlaşma ile öngörülen korumanın herhangi bir şekilde ihlaline karşı ihlalleri önleyecek ve gelecekte olabilecek ihlallerde caydırıcılık sağlayacak özgün tedbirler içeren etkin eylemlere imkân veren uygulama prosedürlerinin kendi kanunlarında bulunmasını sağlayacaklardır*”.

TRIPS Anlaşması'nın 41. maddesi gereğince;

“(1) *Üyeler, ihlalleri önleyecek acil telafi yöntemleri ve daha başka ihlalleri caydırıcı telafi yöntemleri de dahil olmak üzere, bu Anlaşma kapsamındaki fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesine karşı etkin önlemlerin alınmasına olanak sağlamak için, bu kısımda belirtilen uygulama usullerinin kendi yasalarında da yer almasını sağlayacaklardır. Bu usuller, yasal ticarete engel olmaktan kaçınılacak ve bu usullerin kötüye kullanılmasını önleyici koruma sağlanacak şekilde uygulanacaktır.*

Bu uluslararası düzenlemelere uygun olarak ihtiyati tedbirler, hukukumuzda HUMK madde 101 ve devamındaki maddelerde düzenlenmektedir. FSEK’de ise madde 77’de konu HUMK’dan daha geniş olarak ele alınmıştır.

FSEK’in “İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde Geçici Olarak El Koyma” başlıklı 77. maddesi şöyledir:

“*Esaslı bir zararın veya ani bir tehlikenin yahut emrivakilerin önlenmesi için veya diğer herhangi bir sebepten dolayı zaruri ve bu hu-*

susta ileri sürülen iddialar kuvvetle muhtemel görülürse hukuk mahkemesi, bu Kanunla tanınmış olan hakları ihlal veya tehdide maruz kalanların ya da meslek birliklerinin talebi üzerine, davanın açılmasından önce veya sonra diğer tarafa bir işin yapılmasını veya yapılmamasını, işin yapıldığı yerin kapatılmasını veya açılmasını emredebileceği gibi, bir eserin çoğaltılmış nüshalarının veya hasren onu imale yarıyan kalıp ve buna benzer sair çoğaltma vasıtalarının ihtiyati tedbir yolu ile muhafaza altına alınmasına karar verebilir. Kararda, emre muhalefetin İcra ve İflas Kanunu'nun 343 üncü maddesindeki cezai neticeleri doğuracağı açıklanır.”

Fikir ve sanat eserleriyle ilgili olarak açılmış ve görülmekte olan davalarda yahut henüz bu davalar açılmadan, fikirsel ve sanatsal hakları ve eserleri süratle emniyete almak ve muhtemel bir tecavüz tehlikesini önlemek amacıyla hakim ihtiyati tedbire hükmedebilir. Hakim, bu hususta öne sürülen iddiaları kuvvetle muhtemel görürse, esere veya fikri haklara yönelik esaslı bir zararı veya ani bir tehlike tehdidini ortadan kaldırmak yahut oldu-bittileri önlemek için, Kanunda belirtilen tedbirleri alacaktır¹.

İhtiyati tedbir kararı, hakları tecavüze uğraması muhtemel şahsın yazılı talebi üzerine alınır. Başlamış bir tecavüzün devamına engel olmak için de dava öncesi ve sonrası ihtiyati tedbir talebinde bulunulabilir. Yeter ki hakimde “esaslı bir zararın veya ani bir tehlikenin, emrivakilerin engellenmesi için yeterli bir sebep bulunduğu” ve talep sahibinin haklı olduğu yolunda kuvvetli bir kanaat uyandırılınsın²!

Aşağıda, fonogramların hak sahiplerinden izin alınmadan kullanılması üzerine verilen, ayrıntılı değerlendirmelerin yapıldığı bir ihtiyati tedbir kararı örneği bulunmaktadır.

“Talepte bulunan vekili, 07.02.2007 tarihli talep dilekçesi ile özetle, İstanbul 2 No’lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2006/86 D.İş sayılı dosyası üzerinden yapılan tespitte, aleyhine ihtiyati tedbir talebinde bulunan ... HOTEL isimli işyerinde müzik yayını yapıldığının ve tespit esnasında “Mor ve Ötesi” isimli yorumcunun seslendirdiği ... isimli eserin kullanıldığının tespit edildiğini, bunun üzerine ilgiliye bir “Sözleşmeye Davet” mektubu gönderildiğini, ancak bu davate herhangi bir yanıt verilmediğini ve adı geçen otelde müzik yayınlarına devam edildiğini, fonogram yapımcılarının, üzerinde hak sahibi bulunduğu fonogramlarda bulunan müzik eserlerinin umuma

¹ EREL. age., s. 315.

² EREL, age. (2009) , s. 364.

iletimine ve kamuya açık yerlerde temsil edilmesine izin vermek hususunda (kendilerinin) yetkilendirilmiş olduğunu, 5846 sayılı Yasanın 66. maddesine göre manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse- nin tecavüz edene karşı tecavüzün ref' ini talep edebileceğini, geliş- miş ülkelerin hepsinde, otel, motel, restoran gibi yerlerde CD'den doğrudan veya radyo-TV gibi araçlarla dolaylı olarak müzik yayını ya- pılmasının, umuma iletim kapsamında ele alınarak tarife bağlandığı- nı, ihtiyati tedbir talep edilen otelde ... meslek birliğinin koruması altındaki eserlerden birkaçının yayınlandığının tespit edilmiş olması- nın, ...meslek birliği koruması altındaki tüm repertuarın kullanıldığına karine teşkil ettiğini, müvekkilinin bundan ciddi zarara uğradığını, bu- nun aynı zamanda, müzik yayını için izin almış diğer otellere karşı haksız rekabet oluşturduğunu, tedbir talebi için tüm şartların oluştu- ğunu iddia ile, ... **Hotel isimli işyerinde, otel, otelin genelinde, tek tek ünitelerinde veya odalarında kullanılacak müzik yayınlarında, ... üyesi fonogram yapımcılarının fonogramlarda yer alan ... re- pertuardaki fonogramlarda-albümlerde bulunan tüm müzik ya- pıtlarının kullanılmasının önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı ve- rilmesini talep etmektedir.**

5846 sayılı Yasanın 41/1. maddesi hükmü(nde) ... açıkça “meslek birliklerinden izin alınacağı” yazılıdır. ...Fonogram yapımcısı, 5846 sayılı Yasanın 41. maddesi ile Komşu Haklar Yönetmeliği'nin 12/c maddesi gereğince fonogramların umuma açık mahallerde kul- lanılması bakımından izin vermeye yetkilidir. Bir başka anlatımla umumi mahal olarak adlandırılan mağaza, otel lobisi, (temsil sağlayan tesisat otel yönetimi tarafından yapılmışsa) otel odaları, diskotek, lo- kanta gibi yerlerde bir kasetin ya da CD'nin çalınması eser sahibi ve icracı sanatçıya ek olarak fonogram yapımcısının da iznine bağlıdır. ...

Öte yandan aleyhine tedbir talep edilen **şirket vekilleri, mü- vekkilinin otel işletmesi olması nedeniyle, konaklama hizmeti nedeniyle gelir elde ettiklerini, yayınından gelir elde etmediklerini iddia etmişlerdir.** Ne bağlantılı hakların temel uluslararası belgesi olan İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunması Dair **Roma Sözleşmesi'nde, ne de 5846 sayılı Yasanın 80. maddesinde, “uygun bedel” ödemesi için, müzik yayını yapı- lan yerin, eğlence yeri olması ya da müzikten para kazanan bir yer olması gibi herhangi bir koşul öngörülmektedir.** Roma Söz-leşmesi'nin 12. maddesinde, “*ticari amaçla yayınlanmış bir fonogramın ya da bunun çoğaltılmış nüshalarının doğrudan doğruya radyo televizyon yayınları veya umuma arz için kullanılması duru- munda, bir defaya mahsus uygun bir bedelin ödeneceği*” hükmü bu- lunmaktadır. ... 5846 sayılı Yasanın 80. maddesinde de “fonogramları kullananların” uygun bir bedel ödemesi gerekliliği belirtilmektedir. **Dolayısıyla fonogramdan ya da radyo veya televizyondan bir müzik eserinin çalınmasının uygun bedel ödeme yükümlülüğü doğurması için bu yerin, eğlence yeri ya da müzikten para kaza- nan bir yer olması gibi bir zorunluluk öngörülemez.** Yasanın 41/2 maddesine göre; “*Eser, icra, fonogram yapım ve yayınları kullanan ve/veya ileten umuma açık mahaller; mahallin bulunduğu bölgenin özelliği, mahallin nitelik ve niceliği, fikri mülkiyete konu eser, icra,*

fonogram yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası ve ürün veya hizmete katkısı olup olmadığı ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle sınıflandırılır veya sınıflandırma dışı bırakılır.” (ifadesinden) **umumi mahallin müzik yayınlarından gelir elde edip etmemesi hususunun sadece tarife tespiti ve sınıflandırma ile ilgili olduğu sonucu çıkmaktadır.** Bu nedenle, müzik yayınından doğrudan gelir elde etmeyen ve eğlence yeri niteliği taşımayan mahallerin, müzik yayınlarını yapmak için izin almalarına gerek olmadığı ve bunun için uygun bir bedel ödeme yükümlülükleri bulunmadığının söylenmesi kesinlikle mümkün değildir. **Müzik yayınının yapıldığı yerin, lokanta, berber, otomobil tamircisi, giyim mağazası, pastane gibi umuma açık bir yer olması, ya da taksi gibi potansiyel olarak umuma açık bir alan olmasının hiçbir önemi bulunmamaktadır.** Bir başka anlatımla, otelde, lokantada, berberde, otomobil tamircisinde, pastanede müzik yayını yapılması da bağlantılı hak ihlali oluşturabilir ve uygun bedel ödemesini gerektirebilir. Bu nedenle bu yöndeki savunmaya itibar edilmemiştir.

... OTEL isimli işyerinin radyo ve televizyon aracılığı ile olsa da müzik yayını yapabildiği için, ... meslek birliği'nin iznine ihtiyaç bulunmamaktadır.

Buraya kadar yapılan açıklamalardan ve dosya içindeki tespite ilişkin değişik iş dosyasından, aleyhine tespit talebinde bulunan şirkete ait otelde müzik yayını yapıldığı ve adı geçen otelin ... meslek birliğinden ve ... meslek birliğinden herhangi bir izin almadığı, bu meslek birlikleri ile sözleşme imzalamadığı, dolayısıyla yapılan müzik yayınının hukuka aykırı olduğu, bu yayınlara devam edilmesinin, talepte bulunan meslek birliğinin üyelerinin haklarının ihlalinin sürmesi anlamına geleceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Somut olayda, ileri sürülen müzik yayını iddiaları kuvvetle muhtemel görülmüş, ilgili meslek birliğinin Kanunla tanınmış haklarının ihlal ve tehdide maruz kaldığı düşünülmüş, ihtiyati tedbir kararı verilmemesi durumunda meslek birliğinin ve dolayısıyla üyesi olan fonogram yapımcılarının telafisi mümkün olmayan zararlarının ortaya çıkacağı, fonogram yapımlarının azalacağı, sonuçta tüm müzik endüstrisinin ve eser sahiplerinin, besteci ve yorumcuların zarar göreceği kanaatine ulaşılmış ve açıklanan gerekçe ile, ihtiyati tedbir talebinin kabulüne ilişkin aşağıdaki karar verilmiştir.

... FSEK 77, 41/1, 80/2, 66/1 ve 80/9 maddeleri gereğince **ihtiyati tedbir talebinin taktiren teminatsız olarak kabulü ile aleyhine ihtiyati tedbir talebinde bulunan ... Otelcilik A.Ş. tarafından ... Hotel isimli işyerinin restoran, bar, lobi gibi umumi alanlarında ve otel odalarında ... meslek birliğinin repertuarında yer alan ve bu kararın ekinde bulunan, bir örneği aleyhine tedbir talep edilen şirket vekillerine tebliğ edilen ve aynı zamanda talep eden vekili tarafından ... internet adresinde de bulunduğu bildirilen ... meslek birliği üyesi tüm fonogram yapımcılarının tüm fonogramlarındaki tüm eserlerinin; canlı müzik performans hariç olmak üzere, CD, DVD, kaset ve benzeri elektronik (aletler) yardımıyla ya da mp3 ve benzeri dosya**

formatları kullanılarak bilgisayar yardımıyla, doğrudan veya radyo ve televizyon aracılığıyla ya da internet yayıncılığı yoluyla, dijital iletim ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zaman da erişim sağlamak da dahil olmak üzere her türlü umuma iletim yoluyla kullanılmasının 5846 sayılı Yasanın 77. maddesi gözetilerek ihtiyati tedbir önlenmesine, yasaklanmasına, ... karar verildi³.

Hakim, ihtiyati tedbir kararı vermek için duruma göre talepte bulunan şahıstan bir teminat isteyebilmektedir. Bu teminatın gayesi, ihtiyati tedbirin haksız olması durumunda karşı tarafın veya üçüncü şahısların zararını karşılamaktır. Ancak belli durumlarda hakim teminat isteyemeyebilir.

Hakim, ihtiyati tedbir olarak diğer tarafa bir işin yapılmasını veya yapılmamasını emredebileceği gibi, bir eserin çoğaltılmış nüshaların veya onu imale yarayan kalıp ve buna benzer diğer çoğaltma vasıtalarının geçici olarak zaptına da karar verebilir⁴.

İnternet yoluyla yapılan ihlaller karşısında ceza mahkemeleri; FSEK Ek 4'den de faydalanarak aşağıdaki gibi ihtiyati tedbir kararları vermektedirler.

"Bu gerekçelere istinaden, şikayet konusu web sitelerinde ... meslek birliğine üye fonogram yapımcılarına ait yapımlarda yer alan ve bu kararın bir parçası olan ekli listede gösterilen tüm şarkıların mp3 formatında ya da başka bir formatta internet kullanıcıları tarafından ulaşılmasının, dinlenmesinin ve bunların bireysel kullanıcıların bilgisayarlarına indirilmesinin engellenmesine, bu yönde Türkiye içinde faaliyet gösteren ve yukarıda adresleri yazılı bulunan web sitelerine servis sağlayan tüm internet servis sağlayıcılarının bu şarkılar yönünden internet alanı sağlama ve her türlü aracılık hizmetlerinin durdurulmasına karar vermiştir⁵."

İcra İflas Kanunu'nun 343. maddesine göre; ihtiyati tedbire makul bir mazeret olmaksızın muhalefet halinde talep edenin şikayeti üzerine, tedbire muhalefet eden 3 aya kadar hafif hapis cezasına çarptırılır.

2004 yılında getirilen yenilikle haklara tecavüz oluşturulması ihtimalinde, yaptırım gerektiren kopyaların ithalat ve ihracatı sırasında Gümrük Kanunu'nun ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

FSEK 77 gereğince; *"haklara tecavüz oluşturulması ihtimali hâlinde yaptırım gerektiren nüshaların ithalat veya ihracatı sırasında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57 nci maddesi hükümleri uygulanır.*

³ T.C. İstanbul 4 No'lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 02.03.2007 T., E. 2007/13 D. İş., K. 2007/15.

⁴ EREL, age., s. 315.

⁵ İstanbul 1 Nolu Fikir ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, 26.08.2005 T., 2007/2342 K.

Bu nüshalara gümrük idareleri tarafından el konulmasına ilişkin işlemler Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yürütülür.”

Bu husus TRIPS Anlaşması'nın getirdiği önemli yeniliklerden biridir ve sadece FSEK'de değil, patentler, markalar, endüstriyel tasarımlar ve coğrafi işaretlerle ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerde de yer almaktadır. Korsan ürün ve yayınlarla mücadele için, fikri haklara tecavüz ihtimali bulunan eser nüshalarıyla sair malların ithalat ve ihracatı sırasında 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57. maddesine göre, bunlara gümrüklerde el konulması mümkündür⁶. Bu hükmeye göre:

“1. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakları ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın gümrük işlemleri; hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine veya söz konusu eşyanın sahte markalı ya da telif hakkına tabi taklit mal tarifine uyduğuna ilişkin açık deliller olması halinde, re'sen gümrük idareleri tarafından durdurulur. Durdurma kararı ithalatçıya veya hak sahibine veya temsilcisine bildirilir.

2. Gümrük idareleri, olayın özelliğine göre ithalatçının veya kamunun hakkını güvenceye almak ve suiistimalleri önlemek amacıyla, başvuru sahibinden eşyanın kıymeti oranında bir teminat isteyebilirler.

3. Başvurunun kabul edildiği tarihte şikayet konusu eşya serbest dolaşıma girmiş ise başvurunun gümrük idaresince kabul edilmesi; söz konusu eşyanın gereğince muayene edilmeden ithaline izin verildiği gerekçesiyle hak sahibine tazminat hakkı doğurmaz. Sahte markalı veya taklit mallarla mücadele kapsamında, gümrük işlemleri gümrük idaresince re'sen durdurulan eşyadan dolayı, ilgili kişilerin yapılan işlemler sonucunda fayda veya zarara uğraması halinde, gümrük idaresi yetkilileri bu kişilere karşı sorumlu tutulmaz.

4. Gümrük idaresince alınan durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında yetkili mahkemede dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır.

5. Gümrük işlemleri durdurulan eşya, yetkili mahkemece alınan karar doğrultusunda, tasfiye rejimi hükümlerine göre imha veya asli nitelikleri değiştirilerek satış suretiyle tasfiye edilebilir.

6. Yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyeelik eşya ile posta kolları ile gönderilen ticari mahiyette olmayan eşya için bu madde hükümleri uygulanmaz.”

⁶ EREL, age. (2009) , s. 365.

B. HÜKMÜN İLANI

FSEK 78. maddeye göre; hukuk ve ceza davalarında haklı çıkan taraf, menfaati gerekli kılıyorsa masrafı diğer tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş olan mahkeme kararının gazete veya benzer vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep edebilir. Bu talep, mahkeme hükmünün kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay zarfında yapılmalıdır.

Mahkeme hükmünün ilanı, manevi haklardan ad belirtme hakkına tecavüzde ve iktibasta kaynak gösterme yükümlülüğünün ihlâlinde de uygulanan bir müeyyidedir. Bu hallerde FSEK madde 67/II ve III hükümlerine göre açılacak tecavüzün ref'i dâvalarında hükmün, masrafı tecavüz edene ait olmak üzere en fazla üç gazetede ilanı istenebilmektedir. FSEK madde 78'in bu hükme yaptığı atıf uyarınca, ilân talebi için üç aylık hak düşürücü süre, tecavüzün ref'i hükmünün ilanında da geçerlidir. Ancak madde 78'de ilanın şekil ve muhtevasının kararda tespit edileceği belirtildiğinden, tecavüzün ref'i hükmündeki *en fazla üç gazeteyle ilan* sınırının, diğer hallerde mevcut olmadığı kabul edilmelidir. Nitekim madde 78, ilânın gazeteyle değil, benzer başka vasıtalarla da yapılabileceğini belirtmiştir⁷.

Hukuk veya ceza mahkemeleri tarafından verilebilecek olan ilan kararı, bu davalar açısından öne sürülen manevi tazminat talepleri için bir tazmin yolu olarak düşünülebilir⁸.

Yargıtay, bir kararında davacının talebine rağmen davalı aleyhine verilen hükmün ilanı hususunda olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmamasını bozma nedeni saymıştır. Yargıtay yine aynı kararda, ihtiyati tedbire hükmetmek için belirlenen teminatın akıbeti için aynı sonuca varmış bulunmaktadır⁹.

⁷ EREL, *age.*, s. 316.

⁸ AYİTER, s. 269 Naklen EREL, *age.*, s. 316.

⁹ "... Davacı, dava dilekçesinde, yazarı ve telif hakkı sahibi olduğu "Türk Dernekler Hukuku" adlı eserine davalılarca yapılan müdahalenin men'ini, tecavüzün ref'ini, davalılarca yayınlanan kitabın basımının ve yayımının yasaklanmasını, mahkeme hükmünün FSEK 78. madde uyarınca tirajı yüksek bir gazetede yayınlanmasını talep ettiği halde, Mahkemece davacının bu talepleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

Yine, mahkemece dosya üzerinde verilen 8.12.1997 tarihli ihtiyati tedbir kararının uygulanması için davacıdan alınan 50, 000, 000 TL teminat hakkında da olumlu ya

Yargıtay bazen de talep edilmesine rağmen aşağıdaki kararda görüleceği üzere bu haklı talepleri reddedebilmektedir:

“Davacılar vekili, müvekkillerinin yayınladığı albümde yer alan “Yabangülü” isimli müzik eserinin davalının işlettiği TV kanalında yayınlanan “Bir Zamanlar İstanbul” adlı TV dizisinin efekt müziği olarak kullanıldığını, davacılardan izin alınmadığından dolayı manevi haklarını ihlal ettiğini ve mali haklarına tecavüz oluşturduğunu belirterek FSEK’nun 70/1. maddesi uyarınca 500.000.000 TL. manevi, aynı Kanunun 68/1 ve 70/11 nci maddeleri uyarınca 1.250.000.000 TL. maddi tazminatın faiziyle birlikte tahsilini, eser üzerindeki hakka vaki tecavüzün önlenmesini, kararın gazeteyle ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, dava konusu müzik eserinin halka mal olmuş anonim eser olduğunu, FSEK’nun 43 ncü maddesine (bu madde FSEK’in eski halinde olan maddedir ve şimdi kaldırılmıştır) göre, her türlü televizyon yayınlarında tanıtım amacıyla kullanılan eserin tümü üzerindeki hakları zedelemeyecek düzeydeki kısa tespitler için eser sahibinden izin alınmasına ve ücret ödenmesine gerek olmadığını belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamı nazara alınarak, davacıların eser sahibi ve icracı olarak sahibi bulundukları müzik eserinin izinsiz olarak TV dizisinde fon müziği olarak kullanılması nedeniyle manevi ve maddi haklarında tecavüze uğradıkları, her ne kadar bilirkişi raporunda maddi tazminat tutarının 1.500.000.000 TL olarak belirlenmesine rağmen dava dilekçesinde talep edilen miktarın toplam 1.250.000.000 TL olduğu, davacıların FSEK’nun 68/1 nci maddesine göre maddi tazminat talebinin 750.000.000 TL olduğu, davacıların zarar verici eylemden dolayı aynı Kanun’un 70/11nci maddesine dayanarak haksız fiil kurallarına göre tazminat isteme hakkı olmadığı, **davacıların bitmiş tecavüz keyfiyetinin gazete ilanıyla bildirilmesinde haklı yararı olmadığı**, **davalının davacıların haklarına yeniden tecavüz etmesi ihtimali olduğu gerekçesiyle davalının TV programının davacılara ait müzik eserini içerir biçimde yayınlanmasının önlenmesine**, 750.000.000 TL. maddi ve 500.000.000 TL. manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline, 500.000.000 TL. maddi tazminat ve **hükümün gazeteyle ilanı taleplerinin reddine karar verilmiştir**¹⁰.”

Tarafları ayrı olan mahkeme kararlarının da ayrı ayrı ilanı gerekmektedir¹¹.

da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir.” Yargıtay 11. H.D, 5.6.2000, E. 2000/4098, K. 2000/5155, SULUK/ORHAN, age., 958.

¹⁰ Yargıtay 11. H.D, 24.04.2001, E. 2001/1311, K. 2001/3632.

¹¹ 11. H.D., 7.10.1999, E. 1999/5553, K. 1999/7625

C. İZİNSİZ DIGITAL İLETİM İHLALLERİNDE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

Müzik eserlerinin kullanıcılara izinsiz olarak ulaşmasını sağlayan web sitelerine ve kişisel sayfalara karşı FSEK'e 2004 yılında eklenen bir hüküm ile; bu sitelerin erişimini sağlayan Türk Telekom gibi internet servis sağlayıcılar vasıtasıyla önlem alınmıştır. Bu düzenleme şöyledir.

“Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâlê konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlê durdurulmasını ister. İhlâlê devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâlê devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlê durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

Başvurular üzerine savcılıklarca verilen karar örneği aşağıdadır:

“Yukarıda isimleri ve adresleri belirtilen web sitelerinde bulunan ve yasa dışı olarak dağıtılan, yayımlanan ve çoğaltılan tüm müzik yapım ve yapıtlarının, herhangi bir formatta internet kullanıcıları tarafından; ulaşılmasının, dinlenmesinin ve bunların bireysel kullanıcıların, bilgisayarlarına ve cep telefonlarına indirilmesinin karar tarihinden itibaren 3 gün içinde **engellenmesine**,

Bu yönde, Türkiye’de faaliyet gösteren ve yukarıda adresleri yazılı bulunan web sitelerine servis sağlayan tüm internet servis sağlayıcılarının karar tebliğinden itibaren 3 gün içinde **internet alanı sağlama ve her türlü aracılık hizmetlerinin durdurulmasına**, karar verildi.”

İnternet yoluyla yapılan ihlaller karşısında ceza mahkemeleri aşağıdaki gibi ihtiyati tedbir kararları da vermektedirler:

“...İnternet sözleşmeleri olarak bilinen 1996 tarihli WIPO Telif Hakları Sözleşmesi (WCT) ile WIPO İcracı Sanatçılar ve Fonogram Yapımcıları Sözleşmeleri’nde de (WPPT) teknolojik gelişmelere bağlı olarak internet üzerinden yapılan hak ihlallerinin önüne geçilmesi amaçlanmış olup, bu amaç sözleşmelerin önsöz kısımlarında vurgulanmıştır. WIPO İcracı Sanatçılar ve Fonogram Yapımcıları Sözleşmesi’nin (WPPT) “Right Of Making Available Of Phonograms” başlıklı

14. maddesinde, WIPO Telif Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesine benzer bir biçimde, fonogram yapımcılarının fonogramların telli ya da telsiz araçlarla ya da kullanıcılar tarafından bireysel olarak seçilen bir yer ve zamanda umuma sunma konusunda münhasır (exclusive) hakka sahip olacakları emredici hükmü yer almaktadır.

Türkiye'nin taraf olduğu TRIPS Sözleşmesi'nin 14 (2) maddesi uyarınca da "... fonogram yapımcıları, fonogramların doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılmasına izin verme ve yasaklama hakkına sahip olacaktırlar."

Henüz Türkiye için bağlayıcı olmamakla birlikte; mevzuatımıza kaynak teşkil etmesi bakımından önemli olan Avrupa Birliği Bilgi Toplumu Direktifi'nin (Information Society Directive, 2001/29 EC) 3 (2) maddesi de WPPT'deki ifadeleri tekrar ederek; "Üye ülkelerin icracı sanatçıların icraları ve fonogram yapımcılarının fonogramlarını, telli ya da telsiz araçlarla veya toplumdaki bireylerin kendi seçtikleri yer ve zamanda erişebilecekleri bir biçimde topluma sunulması konusunda münhasır hak sağlayacaklarını" bağlayıcı bir biçimde ifade etmektedir.

Bu gerekçelere istinaden şikayet konusu web sitelerinde ... meslek birliğine üye fonogram yapımcılarına ait yapımlarda yer alan ve bu kararın bir parçası olan ekli listede gösterilen tüm şarkıların mp3 formatında ya da başka bir formatta internet kullanıcıları tarafından ulaşılmasının, dinlenmesinin ve bunların bireysel kullanıcıların bilgisayarlarına indirilmesinin ENGELLENMESİNE, bu yönde Türkiye içinde faaliyet gösteren ve yukarıda adresleri yazılı bulunan web sitelerine servis sağlayan tüm internet servis sağlayıcılarının bu şarkılar yönünden internet alanı sağlama ve her türlü aracılık hizmetlerinin durdurulmasına karar vermiştir¹²."

¹² İstanbul 1 Nolu Fikir ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, 26.08.2005 Tarih, 2007/2342 K.

KAYNAKÇA

AKBIYIK ARKAN, Azra: Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998.

ARKAN, Azra: Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar, İstanbul, 2005.

AKIN, Levent: “Fikri Haklara Yönelik Tecavüzlere Karşı Hukuk Davaları” Prof. Dr. Turhan ESENER’e Armağan, Ankara 2000.

AKİPEK, Şebnem/DARDAĞAN, E.: “Sanal Ortamda Gerçekleşen Telif Hakkı İhlallerine Uygulanacak Hukuk”, AÜHFD. 2001, C. 50, S. 3.

AKİPEK, Şebnem/DARDAĞAN, E.: “Sanal Ortamda Telif Hakları”, BATIDER, 2001, C. 21, S. 1.

ALBAYRAK, Mustafa: Fikir ve Sanat Eserleri ile Markalar Aleyhine İşlenen Suçlar, Ankara, 2003.

ARIKAN, A.S.: “Fikri ve Sınai Hakların Tükenmesi ve Rekabet Hukuku, Fikri Haklara İlişkin Sözleşmeler”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, C. 1, Ankara 2002.

ARAL, Fahrettin: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2000.

ARIDEMİR GENÇ, Arzu: Türk Hukukunda Eser Sahibinin Çoğaltma ve Yayma Hakları, Vedat Kitapçılık, Kasım, İstanbul, 2003.

ARSLANLI, Halil: Fikri Hukuk Dersleri, II: Fikir ve Sanat Eserleri, 1954, İstanbul.

ATAMAN, OROL S.: “Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’daki “Sanatsal Gözetim” ve “İşlenme” Kavramları Üzerine Düşünceler”, Mimarlık Dergisi, S.1995/266, s. 10-11.

ATEŞ, Mustafa: Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Seçkin Yayınları, Ocak, Ankara, 2003.

AYİTER, Nurşin: Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Sevinç Yayınları, Kasım, 1981, Ankara.

AYDINCIK, Şirin: Fikri Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri, İstanbul, 2006.

BELGESAY, Mustafa Reşit: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 1955, İstanbul.

BERBER, Leyla KESER/ TÜRKEGUL, Erdem/ SEVİM, Tuğrul/BECENİ, Yasin/ÇAVDAROĞLU, Nurdan/ KARA, Gonca: Sıyasal Haklar Yönetimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2006.

BİLGE, Necip: Borçlar Hukuku Dersleri-Hususi Borç Münasebetleri, Ankara, 1958.

BİLGE, Necip: Borçlar Hukuku - Özel Borç Münasebetleri, Ankara, 1971.

BEŞİROĞLU, Akın: “Fikir Haklarına Komşu Haklar”, Ankara Barosu Dergisi, 1967.

BEŞİROĞLU, Akın: “Düşünce Ürünleri Üzerindeki Haklar, Fikir Hukuku”, Ankara, 2002.

CERECİ, Sedat: “Radyoda Canlı Yayından Bant Yayınına Geçiş”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1988.

ÇEVİK, Orhan Nuri: İçtihatlı- Notlu Fikri Hukuk Mevzuatı, Ankara, 1988.

ÇOLAK, Haluk /TAŞKIN, Mustafa: Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Güncellenmiş-Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2007.

DEMİRKIRAN, İhsan/DEMİR, Aysel Cemile/BİLGİN, Çağlar: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Yıllık Emsal Kararları (1995-2004), Seçkin Yayınları, 2004, Ankara.

DEVELİOĞLU, Ferit/KILIKÇINI Neval: Osmanlıca – Türkçe Sözlük, Rafet Zaimler Kitapevi, İstanbul, 1983.

DURAL, M./ ÖĞÜZ, T.: Türk Özel Hukuku C. II, Kişiler Hukuku, 6. Bası, İstanbul, 2002.

DURAL, A.: İcracı Sanatçıların Hakları ve Korunması, İstanbul, 1998, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

ERDİL, Engin: İçtihatlı ve Gerekçeli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, Beta Yayınları, Nisan 2005, İstanbul.

ERDİL, Ergin: Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku’nda İşlenme Eserler, İstanbul, 2003.

EREL, Şafak: Türk Fikir ve Sanat Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1998.

EREL, Şafak: “Fikri Hukukta Musiki ve Sinema Eserleri ve Yararıtay’ın 18.2.1981 Günlü Esas 1980/1, Karar 1981/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Hukuk Bölümü Kararının İncelenmesi ve Tenkidi”, YD., C.15, S.4, Ekim-1987 .

EREL, Şafak: “Fikri Hukuk Açısından Müzik Klipleri”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl 6, Cilt 6, Sayı 1.

ERMAN, Sahir/ÖZEK, Çetin: Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul, 2000.

EROĞLU, Sevil: Rekabet Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması, İstanbul, 2000

ELBAŞ Oğuz/TURA Yalçın/BAYRAKTARKATAL Ertuğrul/EROL İsmail Lütfü: “Türk Müzik Kültürü”, T.C Kültür Bakanlığı, Online Internet.

ERTAŞ, Şeref/GÖKYAYLA, K. Emre: “Mimari Projeler Üzerindeki Telif Hakkı” Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, DEÜ Yay., İzmir, 2000.

GÖKTÜRK, Hüseyin Avni: Borçlar Hukuku, Akdin Muhtelif Nevileri, Ankara, 1951 .

GÖKYAYLA, Emre: Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 2000.

GÜNEŞ, İlhami: Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara, 2008.

GÜNGÖR, G.: “İnternet Yoluyla Girişilen Elektronik Tüketici Akitleri ve Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması”, AÜHFD, 1997, C.46, S. 1-4.

GÜVEMLİ, Oktay: “Müzik Yapım İşkolunda Telif Haklarının Giderleştirilmesi”, Vergi Dünyası, 2000.

HATEMİ/SEROZAN/ARPACI: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 1992.

HIRSCH, Ernst E.: Hukuki Bakımdan Fikri Say, C. II: Fikri Haklar (Telif Hukuku), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1943.

KALİ, S.: “Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkının Tüketilmesi ve Sınai Mülkiyet Hukukuyla İlişkisi”, FMR., 2001, C.1, S. 4.

KARAHAN, Sami/ SULUK, Cahit/ SARAÇ, Tahir/ NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara, 2007.

KAYHAN, Fahrettin: “Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthal ve Marka Hakkının Tükenmesi” , AB FM ve RHD, C. 1, S. 1.

KILIÇ, Bilge: “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda “Eser” Kavramı”, LEGAL Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Legal Yayıncılık, C.1, S.1, İstanbul, 2005.

KILIÇOĞLU, Ahmet: “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ve Eleştirisi”, FİSUAM Konferanslar Dizisi I, Ankara,1998.

KINACIOĞLU, Naci: “Sinema Eserleri ve Bunlarda Eser Sahipliği”, Prof.Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 1998.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: “Kişilik Gelişmeler Koruyan Manevi Tazminat Davasına İlişkin Yeni Gelişmeler”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, 1980.

KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Onbeşinci Bası, İstanbul, 2006.

MEMİŞ, Tekin: “Müzik Klipleri”, Bilimsel Mütalaa, İstanbul, 2007.

MEMİŞ, Tekin: Fikri Hukuk Bakımından İnternet Ortamında Müzik Sunumu, Ankara, 2002.

Mü-yap Meslek Birliği 2008 Faaliyet Raporu.

Mü-yap Meslek Birliği 2009 Faaliyet Raporu.

OĞUZMAN, M.K./ SELİÇİ, Ç./ OKTAY, S.: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 7. Bası, İstanbul, 2002.

OKUTAN, Gül: “Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Fikir ve Sanat Eserleri”, Prof. Dr. Nihal Uluocak Armağanı, İstanbul, 1999.

OLGAÇ, Senai: İstisna Akdi - Borçlar Hukuku - Akdin Muhtelif Nevileri (VI), İstanbul, 1966.

OLGAÇ, Senai: Fikir Hakları ve Yayın Sözleşmeleri, Ankara, 1979.

OĞUZMAN M. Kemal/SELİÇİ Özer/OKTAY-ÖZDEMİR Saibe: Eşya Hukuku, İstanbul, 2006.

ÖNGÖREN, Gürsel: İnternet Hukuku, Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul, 2006.

ÖZTAN, Fırat: “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler”, Prof.Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 1998.

ÖZCAN, Mehmet: Avrupa Birliğinde Fikri ve Sınai Haklar, Ankara, 1999.

ÖZDERYOL, Teknail: Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Suçlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006.

ÖZDİLEK, A.Osman: İnternet ve Hukuk, İstanbul, 2002.

ÖZSUNAY, Ergun: “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Uygulanmasından Ortaya Çıkan Belli Başlı Sorunlar ve Kanunda Yenilenmeler Yapılmasını Gerektiren Nedenler”, Fikri Mülkiyet Hakları ve Uluslararası Uyum Sorunları, Gümrük Birliği Bilgilendirme Toplantıları-5, 1996.

ÖZTRAK, İlhan: Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, 2. Bası, 1977, Ankara.

SAY, Ahmet: Müzik Ansiklopedisi, Başkent Yayınevi, Ankara, 1985.

SARIİBRAHİMOĞLU, Y. Selim: “Korsan Kopya Yayıncılık ve Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının İhlali”, ABD, C.45, 1988.

SARP, Aydılgö: Müzik Eserleri ve FSEK, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Ödevi.

SEROZAN, Rona: “Manevi Tazminat İstemine Değişik Bir Yaklaşım”, Prof. Dr. Haluk TANDOĞAN’IN Hatırasına Armağan, Ankara, 1990.

SULUK, Cahit/ORHAN, Ali: Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C. II, Arıkan Yayıncılık, Eylül, İstanbul, 2005.

TANDOĞAN, Haluk: “İstisna Akdi Kavramı, Unsurları ve Benzeri Akitlerden Ayırt Edilmesi”, İmran Öktem’e Armağan, Ankara, 1970.

TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkisi, C.2, Ankara, 1982.

TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayınları, Eylül, 2004, İstanbul.

TEKİNALP, Ünal: “Derleme Eser, Düşünce Yaratıcılığı ve Bunun “Hususiyyet” Üzerindeki Etkisi”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl 5, Cilt 5, Sayı 1.

TEKİNALP/TEKİNALP/ATAMER/ODER/ODER/OKUTAN: Avrupa Birliği Hukuku, Geliştirilmiş 2. Bası, İstanbul, 2000.

TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 1993.

TOPÇUOĞLU, Hamide: Fikri Haklar Ders Notları, Ankara, 1964.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.2, İstanbul, 1977.

TURHAN, C. Bülent: Fikri Hakların Uluslararası Boyutu ve Türkiye’de Yapılan Mevzuat Uyum Çalışmaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1996.

ÜSTÜN, Gürsel: Fikri Hukukta İşleme Eserler, Besam Yayınları, İstanbul, 2001.

ÜSTÜN, Gürsel: “Yargısal Uygulamada Fikri Haklar”, İBD., C.73; 1999.

ÜSTÜN, Gürsel: “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda 4630 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler ve Eleştirilerimiz”, İBD, 2001, C.75.

YARSUVAT, Duygun: Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1984.

YASAMAN, Hamdi: “Fikri Haklarda Tazminat İle İlgili Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Ömer TEOMAN’a 55. Yıl Armağanı, İstanbul, 2002.

YAVUZ, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 1997.

YAVUZ, Levent: “ Telif Hakları İle İlgili Olarak Mahkemeler Tatbikatı”, Çoğaltma Paneli, Ankara, 2000.

YAZICIOĞLU, R. Yılmaz: Fikri Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Suçlar, İstanbul, 2009.

YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Doruk Yayınları, Ankara 1976.

YILMAZ, İlhan: “Avrupa Topluluğunda Fikri ve Sınai Haklar”, MÜATE, Avrupa Araştırmaları Dergisi, C.4, S.1-2, 1995-1996.

YÜKSEL, Cüneyt: “Fikri Mülkiyet Hukukunda Kiralama ve Ödünç Verme Hakları”, İHFM, Prof. Dr. Orhan Münir Çağlı’a Armağan, C. LV, S. 4, İstanbul, 1997.

ZEVLİLİLER/AYDOĞDU/PETEK: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkisi, Ankara, 2001.

Prof. Dr. Gürsel Öngören'in Diğer Kitapları

- **Türk Hukukunda İdari Dava Açma Süreleri**
Kazancı Yayınları, İstanbul, 1990
- **İdari Yargılama Mevzuatı**
Der Yayınları, İstanbul, 1994
- **Kitle İletişim Mevzuatı**
Der Yayınları, İstanbul, 1995
(Prof. Dr. T. Akgüner ve Prof. Dr. E. İlal ile beraber)
- **Uluslararası İletişim**
Der Yayınları, İstanbul, 1995
- **Radyo ve Televizyonda Kişilik Haklarına Saldırılarına Karşı Hukuki Başvuru Yolları**
Der Yayınları, İstanbul, 1996
- **Medya İle Mücadele Rehberi**
Çınar Yayınları, İstanbul, 1998
- **Radyo ve Televizyon Hukuku**
RTÜK Yayınları, Ankara, 2003
(Doç. Dr. Zakir Avşar ile beraber)
- **İnternet Hukuku**
Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul, 2006
- **Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Mimari Eserler**
Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul, 2007
(Av. Filiz Ceritoğlu ile beraber)

